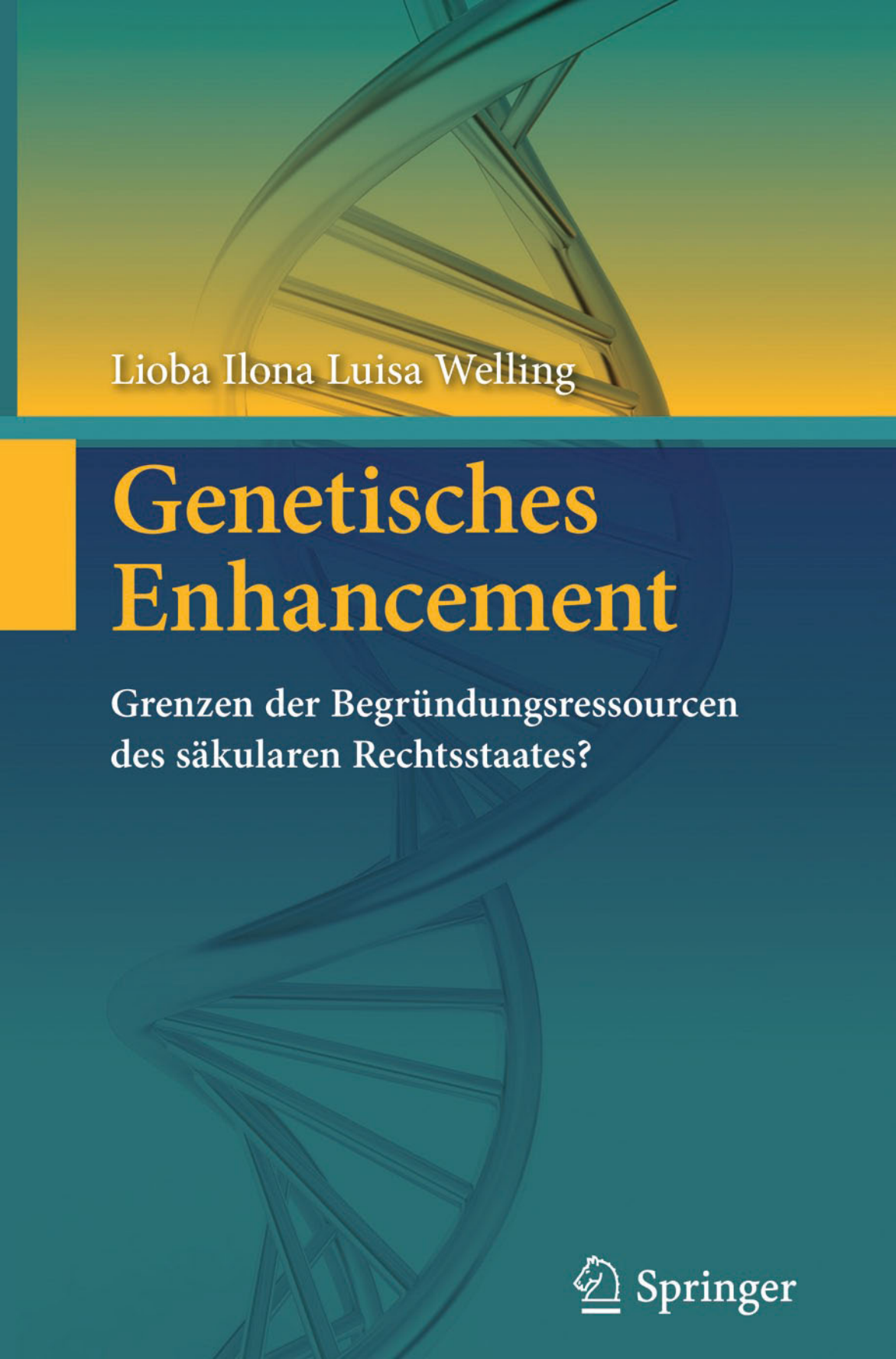




Lioba Ilona Luisa Welling

# Genetisches Enhancement

Grenzen der Begründungsressourcen  
des säkularen Rechtsstaates?



Springer

# Genetisches Enhancement

Lioba Ilona Luisa Welling

# Genetisches Enhancement

Grenzen der Begründungsressourcen des  
säkularen Rechtsstaates?



Springer

Lioba Ilona Luisa Welling  
Münster  
Deutschland

---

D 6

Zugl.: Münster (Westf.), Univ., Diss. der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, 2013

Erster Berichterstatter: Prof. Dr. Thomas Gutmann, M.A.

Zweiter Berichterstatter: Prof. Dr. Fabian Wittreck

Dekan: Prof. Dr. Thomas Hoeren

Tag der mündlichen Prüfung: 12. November 2013

Gedruckt mit freundlicher Unterstützung des Exzellenzclusters „Religion und Politik in den Kulturen der Vormoderne und Moderne“ an der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster aus Mitteln der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder

---

ISBN 978-3-642-53991-6

ISBN 978-3-642-53992-3 (eBook)

DOI 10.1007/978-3-642-53992-3

Springer Heidelberg New York Dordrecht London

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier

Springer ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media ([www.springer.com](http://www.springer.com))

*„Darf's auch ein bisschen mehr sein?“  
der Metzger meines Vertrauens  
auf dem münsteraner Wochenmarkt*

*Meinen Eltern und Alex*

# Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2013 von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster als Dissertation angenommen. Sie entstand in der Graduiertenschule des ebendort ansässigen, von Bund und Ländern im Rahmen der Exzellenzinitiative geförderten Exzellenzclusters „Religion und Politik in den Kulturen der Vormoderne und Moderne“ sowie in Assoziation an die, durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft geförderte, Kolleg-Forschergruppe „Theoretische Grundfragen der Normenbegründung in Medizinethik und Biopolitik“, ebenfalls an der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster.

Beide Forschungsverbünde haben mir durch ihre Interdisziplinarität und als Forum entsprechend fachübergreifender Diskussionen wertvolle Anregungen und Denkanstöße zu denjenigen Untersuchungen meiner Dissertation gegeben, die „über den juristischen Tellerrand blicken“. Hierfür und für die großzügige Übernahme der Druckkosten durch das Exzellenzcluster „Religion und Politik“ danke ich vielmals.

Besonderer Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Thomas Gutmann, M.A., der mein Interesse am wissenschaftlichen Arbeiten sowie an bioethischen, rechtsmedizinischen und -philosophischen Fragen bereits während des Studiums mit der Seminararbeit weckte. Dank seines überaus großen Engagements förderte er von der Themensuche bis hin zur Drucklegung in vielfältiger Weise nicht nur mein Promotionsprojekt, sondern auch mich persönlich.

Herrn Prof. Dr. Fabian Wittreck danke ich für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens und seine im Hinblick auf die Drucklegung hilfreichen Anmerkungen.

Nicht zuletzt gebührt mein herzlichster Dank meinen Eltern, meiner Großmutter und Alex. Meine Familie hat mich in meinen Bestrebungen immer unterstützt und gefördert, mir Orientierung und Halt gegeben. Dass sie und Alex an mich glauben und mich bestärken – und einige, zuweilen sicher nötige Geduld und nachsichtige Güte aufzubringen vermögen – ist und war auch während meiner Promotion die wohl größte Hilfe.

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Kapitel 1: Einleitung</b> .....                                       | 1  |
| <b>Teil I Begriffliche, medizinische und historische Grundlagen</b>      |    |
| <b>Kapitel 2: Der Enhancement-Begriff</b> .....                          | 7  |
| I. Allgemeine Wortbedeutung .....                                        | 7  |
| II. Enhancement als Gegenbegriff zur Therapie .....                      | 8  |
| 1. Weitere Konzeptionen des Enhancement-Begriffes .....                  | 10 |
| 2. Der Therapie-Begriff .....                                            | 12 |
| a) Der Therapie-Begriff in der Antike .....                              | 12 |
| b) Der moderne Therapie-Begriff .....                                    | 13 |
| aa) Die objektive Beurteilung von Gesundheit und Krankheit ...           | 14 |
| bb) Die Beurteilung von Gesundheit und Krankheit                         |    |
| aus subjektiver Sicht .....                                              | 15 |
| cc) Der relationale Aspekt von Gesundheit und Krankheit .....            | 16 |
| 3. Bedeutung für eine Definition des Enhancement-Begriffes .....         | 18 |
| <b>Kapitel 3: Medizinische Grundlagen</b> .....                          | 21 |
| I. Biologische Grundlagen .....                                          | 23 |
| 1. Vom Gen zum Protein .....                                             | 23 |
| 2. Die Zellteilung .....                                                 | 25 |
| 3. Mutationen und ihre Vererbung .....                                   | 25 |
| II. Die somatische Genmanipulation .....                                 | 26 |
| 1. Entwicklung, <i>status quo</i> und bestehender Forschungsbedarf ..... | 26 |
| 2. Die Methoden der somatischen Genmanipulation .....                    | 30 |
| a) Augmentations- oder Additionsmethode .....                            | 30 |
| b) Gensatztherapie und Genreparatur .....                                | 31 |
| c) Regulation der Genexpression .....                                    | 31 |
| d) Reaktivierung eigener Gene .....                                      | 32 |
| e) Genmanipulation an Stammzellen .....                                  | 32 |
| 3. Die Durchführung des Gentransfers .....                               | 33 |
| a) <i>in vitro</i> und <i>in vivo</i> .....                              | 33 |
| b) Die Werkzeuge des Gentransfers .....                                  | 34 |
|                                                                          | XI |



|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| aa) Transfektion .....                                                                 | 34 |
| bb) Transduktion .....                                                                 | 35 |
| III. Die Keimbahnmanipulation .....                                                    | 37 |
| 1. Die Keimbahn .....                                                                  | 37 |
| 2. <i>Status quo</i> und bestehender Forschungsbedarf .....                            | 38 |
| 3. <i>Knock-In</i> und <i>Knock-Out</i> .....                                          | 39 |
| 4. Eingriffsobjekte der Keimbahnmanipulation .....                                     | 39 |
| a) Keimbahneingriffe an Gameten .....                                                  | 39 |
| b) Keimbahneingriffe an der Zygote .....                                               | 40 |
| c) Keimbahneingriffe an embryonalen Stammzellen .....                                  | 41 |
| <b>Kapitel 4: Historische Grundlagen</b> .....                                         | 43 |
| I. Der Eugenik-Begriff .....                                                           | 43 |
| II. Eugenische Entwicklungen in Amerika .....                                          | 44 |
| III. Die Eugenik des Nationalsozialismus .....                                         | 46 |
| IV. Jüngere staatliche Eugenik-Programme am Beispiel Singapur .....                    | 49 |
| V. Die Abgrenzung zwischen Eugenik und Enhancement .....                               | 50 |
| <b>Teil II   Einfachgesetzliche Bewertung <i>de lege lata</i></b>                      |    |
| <b>Kapitel 5: Eingriffe in die Keimbahn</b> .....                                      | 55 |
| I. Die Entstehungsgeschichte des Embryonenschutzgesetzes .....                         | 56 |
| II. Die Verbotstatbestände .....                                                       | 57 |
| 1. Das Verbot des § 5 I, IV ESchG .....                                                | 57 |
| a) <i>Ratio legis</i> .....                                                            | 57 |
| b) Der Tatbestand des § 5 I ESchG .....                                                | 58 |
| aa) Der objektive Tatbestand .....                                                     | 58 |
| (1) Taugliches Tatobjekt .....                                                         | 58 |
| (2) Die Tathandlung .....                                                              | 59 |
| (3) Die Ausnahmen des § 5 IV ESchG .....                                               | 61 |
| bb) Der subjektive Tatbestand: Vorsatz in Bezug auf<br>den objektiven Tatbestand ..... | 62 |
| 2. Das Verbot des § 5 II ESchG .....                                                   | 63 |
| 3. Zwischenergebnis .....                                                              | 64 |
| III. Die möglichen Rechtfertigungsgründe .....                                         | 64 |
| 1. § 3 S. 2 ESchG .....                                                                | 64 |
| 2. Notwehr, § 32 StGB, und rechtfertigender Notstand, § 34 StGB .....                  | 66 |
| 3. Rechtfertigende Einwilligung .....                                                  | 67 |
| a) <i>Proxy consent</i> .....                                                          | 67 |
| b) Analogie der personensorgerichtlichen Vorschriften .....                            | 70 |
| 4. § 218a II StGB analog .....                                                         | 72 |
| IV. Ergebnis .....                                                                     | 73 |
| <b>Kapitel 6: Modifizierung somatischer Zellen</b> .....                               | 75 |
| I. Strafrechtliche Legitimation somatischer Enhancements? .....                        | 75 |

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. §§ 218 ff. StGB .....                                                               | 76 |
| 2. Unvorhergesehene Schädigungen als Straftaten .....                                  | 76 |
| 3. Die Durchführung somatischer Enhancements als Straftat .....                        | 77 |
| II. Spezialgesetzliches Regelungsregime .....                                          | 80 |
| 1. Regelungen im Gentechnikgesetz .....                                                | 81 |
| 2. Arzneimittelrechtliche Regelungen .....                                             | 82 |
| a) Grundsätzliche Anwendbarkeit des Arzneimittelgesetzes .....                         | 82 |
| b) Die Anzeigepflicht und Herstellungserlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz .....      | 83 |
| c) Erfordernis eines speziellen Genehmigungsverfahrens für das Inverkehrbringen? ..... | 84 |
| d) Die klinische Prüfung und Anwendung nach dem Arzneimittelgesetz .....               | 86 |
| e) Allgemeines arzneirechtliches Verbot .....                                          | 87 |
| f) Ergebnis .....                                                                      | 88 |

### **Teil III   *De lege ferenda* – Regelungsgehalt eines Enhancement-Gesetzes**

|                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kapitel 7: Der liberale Rechtsstaat – Einordnung in den verfassungsrechtlichen Anforderungszusammenhang .....</b> | <b>93</b> |
| I. Recht auf reproduktive Autonomie .....                                                                            | 94        |
| II. Berufsfreiheit des Arztes, Art. 12 I GG .....                                                                    | 96        |
| III. Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit, Art. 5 III GG .....                                                      | 97        |
| IV. Schutzaussagen des Elternrechts, Art. 6 II 1 GG .....                                                            | 98        |
| V. Art. 2 II 1 GG als Grundrecht des (zukünftigen) Kindes .....                                                      | 100       |
| VI. Allgemeines Persönlichkeitsrecht und informationelle Selbstbestimmung, Art. 2 I i. V. m. Art. 1 I GG .....       | 105       |
| 1. Eingriffe in Gameten oder die Zygote .....                                                                        | 106       |
| 2. Als Recht geborener Personen bei Modifizierung somatischer Zellen .....                                           | 107       |
| VII. Recht der Frau auf körperliche Unversehrtheit und auf Leben, Art. 2 II 1 GG .....                               | 109       |
| VIII. Schutz der Menschenwürde der Frau, Art. 1 I GG .....                                                           | 110       |
| IX. Fazit .....                                                                                                      | 111       |

|                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kapitel 8: Rechtfertigung eines gesetzlichen Verbotes des genetischen Enhancements .....</b> | <b>113</b> |
| I. Argumente erster Ordnung .....                                                               | 114        |
| 1. Menschenwürde i. S. d. Art. 1 I 1 GG .....                                                   | 114        |
| a) Schutzgehalt des Menschenwürdesatzes .....                                                   | 115        |
| aa) Ideengeschichte .....                                                                       | 115        |
| bb) Verfassungsrechtlicher Begriff und Inhalt der Menschenwürde .....                           | 120        |
| (1) Nichtdefinition, Negativdefinition .....                                                    | 120        |
| (2) Objektformel .....                                                                          | 120        |

|                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (3) Wert- oder Mitgifttheorien .....                                                                  | 122 |
| (4) Leistungstheorien .....                                                                           | 122 |
| (5) Kommunikationstheorie .....                                                                       | 123 |
| (6) Allgemein anerkannte Grundaussagen der<br>Menschenwürde .....                                     | 123 |
| b) Grundrechtsträgerschaft im Hinblick auf Art. 1 I 1 GG .....                                        | 124 |
| aa) Modifizierung somatischer Zellen .....                                                            | 124 |
| bb) Keimbahnmodifizierung bei Zygoten .....                                                           | 125 |
| (1) Ideen- und verfassungsgeschichtliche Bedenken .....                                               | 125 |
| (2) Rezeption in der Rechtsprechung und der<br>juristischen Literatur .....                           | 126 |
| (3) Biologische Entwicklung menschlichen Lebens<br>und Individuumsbezogenheit der Menschenwürde ..... | 128 |
| (4) Kontinuitäts-, Potentialitäts- und Identitätsargument ...                                         | 129 |
| (a) Kontinuitätsargument .....                                                                        | 129 |
| (b) Potentialitätsargument .....                                                                      | 130 |
| (c) Identitätsargument .....                                                                          | 133 |
| (5) Theorie des gestuften Schutzes der Menschenwürde ...                                              | 134 |
| (6) Fazit .....                                                                                       | 136 |
| cc) Keimbahnmodifizierung bei Gameten .....                                                           | 136 |
| dd) Zwischenergebnis .....                                                                            | 139 |
| c) Eingriff in die Menschenwürde durch<br>genetisches Enhancement .....                               | 139 |
| aa) Objektformel .....                                                                                | 141 |
| bb) <i>Rawls' primary goods</i> .....                                                                 | 150 |
| 2. Extension des Menschenwürdesatzes .....                                                            | 154 |
| a) Motivlage: Die Versuchung des Menschenwürde-Arguments ...                                          | 155 |
| b) Vorwirkung der Menschenwürde? .....                                                                | 157 |
| c) Würde als Ausdruck einer objektiv-rechtlichen Werteordnung ...                                     | 159 |
| d) Das Konzept der Gattungswürde .....                                                                | 161 |
| 3. Zwischenergebnis .....                                                                             | 163 |
| II. Argumente zweiter Ordnung .....                                                                   | 163 |
| 1. <i>Risk-Management</i> .....                                                                       | 164 |
| a) Schutz des Lebens, Art. 2 II 1, 1. Alt. GG .....                                                   | 166 |
| aa) Der Schutzbereich des Art. 2 II 1, 1. Alt. GG .....                                               | 166 |
| (1) Lebensbeginn aus naturwissenschaftlicher Sicht .....                                              | 166 |
| (2) Wortlautinterpretation .....                                                                      | 167 |
| (3) Entstehungsgeschichte .....                                                                       | 167 |
| (4) Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ...                                              | 167 |
| (5) Zäsuren in der Ontogenese .....                                                                   | 168 |
| (a) Nidation oder Individuation .....                                                                 | 169 |
| (b) Beginn der Hirntätigkeit .....                                                                    | 170 |
| (c) Erste Kindsbewegungen .....                                                                       | 170 |
| (d) Extrauterine Lebensfähigkeit .....                                                                | 171 |
| (e) Geburt oder Fähigkeit zur autonomen<br>Entschlussfassung .....                                    | 172 |

|                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (6) Zwischenergebnis .....                                                                                                  | 174 |
| bb) Art. 2 II 1, 1. Alt. GG als Grundlage einer<br>staatlichen Schutzpflicht .....                                          | 176 |
| cc) Beeinträchtigung des Rechts auf Leben .....                                                                             | 178 |
| dd) Reichweite der Schutzpflicht aus Art. 2 II 1, 1. Alt. GG ....                                                           | 179 |
| ee) Ergebnis und Ausblick .....                                                                                             | 185 |
| b) Schutz der körperlichen Unversehrtheit, Art. 2 II 1, 2. Alt. GG ....                                                     | 186 |
| aa) Schutzbereich des Art. 2 II 1, 2. Alt. GG .....                                                                         | 186 |
| bb) Art. 2 II 1, 2. Alt. GG als Grundlage einer<br>staatlichen Schutzpflicht .....                                          | 187 |
| cc) Beeinträchtigung des Rechts auf körperliche<br>Unversehrtheit .....                                                     | 188 |
| dd) Reichweite der Schutzpflicht aus Art. 2 II 1, 2. Alt. GG ....                                                           | 193 |
| ee) Ergebnis .....                                                                                                          | 194 |
| 2. Verteilungsgerechtigkeit und Ressourcenallokation, Wett-<br>bewerb und Markt .....                                       | 194 |
| a) Zugrundeliegende Annahmen .....                                                                                          | 195 |
| b) Bestehen eines sozialrechtlichen Anspruchs auf Enhancement ...                                                           | 197 |
| c) Art. 3 I GG .....                                                                                                        | 198 |
| d) Strategien zum Umgang mit Ungleichheiten .....                                                                           | 201 |
| 3. Authentizität, Zurechenbarkeit und Vergleichbarkeit von<br>Leistungen .....                                              | 208 |
| a) Der Wert der Anstrengung .....                                                                                           | 208 |
| b) Leistungsevaluation .....                                                                                                | 211 |
| 4. Selbstwahrnehmung und Selbstverständnis, persönliche<br>Authentizität, Autonomie und asymmetrische Machtverhältnisse ... | 214 |
| 5. Wunsch-Medizin versus Zwang-Medizin .....                                                                                | 223 |
| a) Entstehen einer gesellschaftlichen Erwartungshaltung .....                                                               | 224 |
| b) Art. 2 I GG .....                                                                                                        | 225 |
| 6. „Komplizenschaft“ .....                                                                                                  | 227 |
| 7. Ärztliches Ethos und Arzt-Patienten-Verhältnis .....                                                                     | 229 |
| 8. <i>Slippery slope</i> .....                                                                                              | 232 |
| 9. Fazit .....                                                                                                              | 235 |
| III. Theologisch-politische Versuche einer Verbotsbegründung .....                                                          | 237 |
| 1. <i>De dignitate speciei</i> .....                                                                                        | 238 |
| 2. Die Unantastbarkeit der Schöpfung und Unverfügbarkeit<br>über das Selbst .....                                           | 240 |
| a) Das Geschöpf als Schöpfer seiner selbst .....                                                                            | 241 |
| b) Gottesebenenbildlichkeit .....                                                                                           | 244 |
| 3. Heiligkeit und Unantastbarkeit des Natürlichen .....                                                                     | 245 |
| a) Natur und ethischer Naturalismus .....                                                                                   | 245 |
| aa) Natürlichkeit als universelle und gerechte Alltagsmoral ....                                                            | 246 |
| bb) Kritik am ethischen Naturalismus .....                                                                                  | 247 |
| b) Schutz des menschlichen Wesenskernes und eines<br>guten Lebens .....                                                     | 250 |
| aa) Das Natürliche und das Gemachte .....                                                                                   | 250 |

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| bb) Wesensbestimmung durch die ein gutes Leben<br>ausmachenden Determinanten .....          | 251 |
| cc) Das Genom als stoffliche Signatur der Seele .....                                       | 252 |
| 4. Kritik .....                                                                             | 253 |
| a) Abstraktion der Geltung von der Genesis des Rechts .....                                 | 254 |
| b) Implikationen eines Faktums des Pluralismus .....                                        | 255 |
| aa) Historisch-strategische Begründung der ethischen<br>Neutralität des Staates .....       | 257 |
| bb) Ethisch-politische Argumentation zugunsten der<br>Neutralität .....                     | 257 |
| cc) Voraussetzung für persönlichkeitsidealistische<br>Individualität .....                  | 258 |
| dd) Gerechtigkeitstheoretische Neutralitätskonzeption<br>des politischen Liberalismus ..... | 259 |
| (1) Der politische Liberalismus .....                                                       | 259 |
| (2) Prozedurale Umsetzung politisch-liberaler<br>Anforderungen .....                        | 261 |
| (3) Politisch-liberale Normenbegründung und<br>-Rechtfertigung .....                        | 261 |
| (a) Normenlegitimierende Wirkung von<br>Rechtfertigung und Zustimmung .....                 | 262 |
| (b) Der übergreifende Konsens im Sinne des<br>politischen Liberalismus .....                | 263 |
| (c) Legitimationsstiftende Rechtfertigung<br>durch Allgemeingültigkeit .....                | 265 |
| (d) Demokratische Mehrheitsentscheidungen<br>und ihre Grenzen .....                         | 267 |
| (aa) Verfassungsrechtlicher<br>Minderheitenschutz .....                                     | 268 |
| (bb) Freiheit des Mandats versus ethische<br>Neutralität des Staates .....                  | 268 |
| (cc) <i>public justification</i> .....                                                      | 269 |
| IV. Fazit .....                                                                             | 271 |
| <b>Literatur</b> .....                                                                      | 275 |

# Abkürzungsverzeichnis

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| AAV          | adeno-assoziiertes Virus                             |
| Abs.         | Absatz                                               |
| ADA-Mangel   | Adenosindeaminase-Mangel                             |
| ADHS         | Aufmerksamkeitsdefizits-/Hyperaktivitätsstörung      |
| AEUV         | Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union |
| a. F.        | alte Fassung                                         |
| AGG          | Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz                  |
| AIDS         | Acquired Immune Deficiency Syndrome                  |
| A.L.R.       | American Law Reports                                 |
| AMG          | Arzneimittelgesetz                                   |
| AöR          | Archiv des öffentlichen Rechts                       |
| ARSP         | Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie             |
| Art.         | Artikel                                              |
| AT           | Allgemeiner Teil                                     |
| ATMP         | Advanced Therapy Medical Products                    |
| BFH          | Bundesfinanzhof                                      |
| BFHE         | Sammlung der Entscheidungen des Bundesfinanzhofs     |
| BGB          | Bürgerliches Gesetzbuch                              |
| BGBI         | Bundesgesetzblatt                                    |
| BGH          | Bundesgerichtshof                                    |
| BGHSt        | Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen |
| BGHZ         | Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen |
| BMJ          | British Medical Journal                              |
| BT           | Bundestag                                            |
| BVerfG       | Bundesverfassungsgericht                             |
| BVerfGE      | Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts         |
| BVerwGE      | Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts         |
| DÄBl         | Deutsches Ärzteblatt                                 |
| ders., dies. | Derselbe, dieselbe                                   |
| DFG          | Deutsche Forschungsgemeinschaft                      |
| d. h.        | das heißt                                            |
| Diss.        | Dissertation                                         |

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| DNS        | Desoxyribonukleinsäure                                                |
| DÖV        | Die öffentliche Verwaltung                                            |
| Drze       | Deutsches Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften          |
| DVB1       | Deutsches Verwaltungsblatt                                            |
| DZPhil     | Deutsche Zeitschrift für Philosophie                                  |
| EMEA       | Europäische Arzneimittelagentur                                       |
| EschG      | Embryonenschutzgesetz                                                 |
| ESTG       | Einkommenssteuergesetz                                                |
| ES-Zellen  | embryonale Stammzellen                                                |
| et al.     | lateinisch für „und andere“                                           |
| EuGRZ      | Europäische Grundrechte Zeitschrift                                   |
| f., ff.    | folgende                                                              |
| Fn.        | Fußnote                                                               |
| FamRZ      | Zeitschrift für das gesamte Familienrecht                             |
| GenTG      | Gentechnikgesetz                                                      |
| GewStG     | Gewerbesteuergesetz                                                   |
| GG         | Grundgesetz                                                           |
| HIV        | Humanes Immundefizienz-Virus (Human Immunodeficiency Virus)           |
| Hrsg.      | Herausgeber                                                           |
| HStR       | Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland              |
| iPS-Zellen | induzierte pluripotente Stammzellen                                   |
| i. V. m.   | in Verbindung mit                                                     |
| JöR        | Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart                        |
| JR         | Juristische Rundschau                                                 |
| JuS        | Juristische Schulung                                                  |
| JZ         | Juristenzeitung                                                       |
| KJ         | Kritische Justiz                                                      |
| KritVj     | Kritische Vierteljahrsschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft |
| L.Ed.      | United States Supreme Court Reports, Lawyer's Edition                 |
| MDR        | Monatsschrift für deutsches Recht                                     |
| MedR       | Medizinrecht                                                          |
| mRNA       | messenger RNA, deutsch: Boten-RNS                                     |
| m.w.N.     | mit weiteren Nachweisen                                               |
| n. F.      | neue Fassung                                                          |
| NJW        | Neue Juristische Wochenschrift                                        |
| No./no.    | Number                                                                |
| NVwZ       | Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht                                 |
| p.         | page                                                                  |
| PID        | Präimplantationsdiagnostik                                            |
| Rdnr.      | Randnummer                                                            |
| RNS        | Ribonukleinsäure                                                      |
| RVO        | Reichsversicherungsordnung                                            |
| RW         | Rechtswissenschaft                                                    |
| S.         | Satz, Seite                                                           |
| S.Ct.      | Supreme Court Reporter                                                |

|           |                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S.E.      | South Eastern Reporter                                                                               |
| SGB V     | Sozialgesetzbuch Fünftes Buch                                                                        |
| SGB IX    | Sozialgesetzbuch Neuntes Buch                                                                        |
| StGB      | Strafgesetzbuch                                                                                      |
| st. Rspr. | Ständige Rechtsprechung                                                                              |
| TPG       | Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen<br>und Geweben (Transplantationsgesetz) |
| TSG       | Transsexuellengesetz                                                                                 |
| u. a.     | unter anderem                                                                                        |
| U.S.      | United States Reports                                                                                |
| UStG      | Umsatzsteuergesetz                                                                                   |
| Va.       | Virginia Reports                                                                                     |
| Vol.      | Volume                                                                                               |
| WRV       | Weimarer Reichsverfassung                                                                            |
| z. B.     | zum Beispiel                                                                                         |
| ZfL       | Zeitschrift für Lebensrecht                                                                          |
| ZfP       | Zeitschrift für Politik                                                                              |
| zit.      | zitiert                                                                                              |
| ZRP       | Zeitschrift für Rechtspolitik                                                                        |
| zugl.     | zugleich                                                                                             |
| X-SCID    | Severe Combined Immunodeficiency                                                                     |



# Kapitel 1: Einleitung

Die dynamische Entwicklung der Lebenswissenschaften unterwirft in zunehmendem Maß auch die menschliche Natur der Möglichkeit technischer Intervention. Dieser scheinbar auf ein „Ende der Natur“<sup>1</sup>zielende Prozess erreicht mit der Option „verbessernder“ Eingriffe in die genetische Ausstattung des Menschen eine neue Dimension. Diese Entwicklung hat wegen ihrer besonderen Bedeutung für das Selbstverständnis des Gemeinwesens ethische, politische und zunehmend auch rechtliche Debatten ausgelöst, in denen tiefgreifende normative Dissense sichtbar werden. Hierbei sind es insbesondere religiöse oder von religiösen Gehalten zehrende Argumente, die strikte Grenzen der Verfügbarkeit der menschlichen Natur zu begründen versuchen.

Die vorliegende Arbeit ist juristischer und rechtsphilosophischer Natur. Sie wird als rechtswissenschaftliche Untersuchung zunächst die Zulässigkeit von Maßnahmen des genetischen Enhancements beziehungsweise der „liberalen positiven“ Eugenik anhand des geltenden deutschen Rechts erörtern sowie sich sodann vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung der Humangenetik und einer möglicherweise „unausweichlichen“ Tendenz zu genetischem Enhancement<sup>2</sup> Regelungsoptionen *de lege ferenda* zuwenden. Hierbei wird von der Überlegung auszugehen sein, dass ein liberaler Rechtsstaat wie die Bundesrepublik Deutschland einen *prima-facie*-Vorrang individueller Freiheitsrechte garantiert und somit ein umfassendes oder teilweises Verbot genetischen Enhancements – insbesondere, wenn dieses mit den Mitteln des Strafrechts durchgesetzt werden soll – der Rechtfertigung *im Medium des Rechts* bedarf. Hier ist zunächst der Frage nachzugehen, welche grundgesetzlich verbrieften Rechtspositionen für die Zulässigkeit genetischer Interventionen streiten können. Der Schwerpunkt der Arbeit wird sodann der Evaluation möglicher rechtlicher Begründungsressourcen für ein umfassendes oder teilweises *Verbot* genetischen Enhancements dienen.

Weil genetisches Enhancement medizinisch-technisch vorerst nur begrenzt möglich ist, gibt es gegenwärtig kaum Normen des einfachen Rechts, die seiner expliziten Regelung dienen. Gleichwohl regeln einige spezialgesetzliche Vorschriften diesen Fall akzidentiell, daher aber nicht immer zugleich auch konsistent oder wenigstens sinnvoll mit. Entsprechend findet sich bislang erst wenig deutschspra-

---

<sup>1</sup> Anthony Giddens, BBC Reith Lectures – Risk.

<sup>2</sup> Baylis/Robert, Bioethics 18 (1), 1.

chige rechtswissenschaftliche (sowie ethische und theologische) Literatur, so dass ein Überblick über die Argumentationslandschaft gerade auch die weiter fortgeschrittenen Debatten im angelsächsischen Raum einbeziehen und teilweise in die deutsche rechtsphilosophische Diskussion „rückübersetzen“ muss. Interessant wird auch sein, wie sich allgemeine Grundsätze auf Fälle genetischen Enhancements verhalten, so etwa bei der Frage, ob und inwieweit (zukünftige) Eltern ihr Kind in dieser Entscheidung vertreten (*proxy consent*) und in seinem Interesse zustimmen dürfen, und wie die grundrechtliche Entscheidungskompetenz der Eltern und das Kindeswohl des Bürgerlichen Gesetzbuches aufeinander bezogen sind.

Der juristische Charakter der Dissertation bedingt, im Rahmen einer Prüfung und rechtlichen Bewertung von Regelungsoptionen für das genetische Enhancement *de lege ferenda* nicht nur die grundgesetzlich absoluten Vorkehrungen zum Schutz von höchstem Verfassungsrang in den Blick zu nehmen, sondern auch die Argumente zweiter Ordnung abzuarbeiten, die die ethische, juristische und rechtspolitische Diskussion bisher entwickelt hat. Angesprochen sind hier nicht zuletzt Probleme der Authentizität, Zurechenbarkeit und Vergleichbarkeit von Handlungen und Leistungen „verbesserter“ Individuen, sowie Aspekte sozialer Ungleichheit und Verteilungsgerechtigkeit beim Zugang zu „verbessernden“ genetischen „Leistungen“, bei denen, wie *Siep* es formuliert, die „*bisher zufällige Ausgangssituation für den sozialen Wettbewerb nunmehr selbst zum Gegenstand von Wettbewerb und Markt wird*“<sup>3</sup> und dies im Vergleich zu den natürlichen, anlagebedingten Unterschieden zwischen Individuen eine qualitativ andere Ungerechtigkeit begründen würde.

In ihrer rechtsphilosophischen Dimension zielt die vorliegende, im Rahmen des Münsteraner Exzellenzclusters „Religion und Politik in den Kulturen der Vor-moderne und der Moderne“ entstandene Arbeit sodann auf eine Fragestellung, die jedenfalls aus juristischer Sicht mit im Zentrum des gegenwärtigen Verhältnisses von Religion und Politik steht: Ist die Begründung einer *Unverfügbarkeit* der Natürlichkeit des menschlichen Genoms mit Argumenten, die sich im Rahmen einer säkularen, religiös „neutralen“ Rechtsordnung<sup>4</sup> als *rechtliche* formulieren lassen, möglich oder gelangen die Begründungsressourcen des säkularen Rechtsstaates hier an systematische Grenzen? Trifft die Vermutung zu, dass Rechtsordnungen, die sich als strikt säkular verstehen, hinsichtlich möglicher Eingriffe in das menschliche Genom auf Permissivität „programmiert“ sind und die Vorstellung eines schlechthin unverfügbaren natürlichen Substrats des Menschen nur von einem Staat um- und durchgesetzt werden kann, der *nicht* auf jede religiös-transzendente Verankerung des Rechts verzichtet? Ist mit diesem Befund ein Defizit der Theorie des politischen Liberalismus<sup>5</sup> benannt, die dem legitimen, weltanschaulich neutralen Gesetzgeber, der seine Bürger mit gleicher Rücksicht und gleichem Respekt zu behandeln habe, die öffentliche Rechtfertigung (*public justification*) zur Bedingung macht und ihm gebietet, sich auf Gründe zu beschränken, die im Prinzip jedermann

<sup>3</sup> *Siep*, Wissen – Vorbeugen – Verändern, S. 85.

<sup>4</sup> Vergleiche etwa *Huster*, Die ethische Neutralität des Staates.

<sup>5</sup> Exemplarisch *Rawls*, Politischer Liberalismus.

diskursiv einsichtig gemacht werden können,<sup>6</sup> und die religiöse und anderweitig transzendente Gehalte strikt und auch dann als Begründungsressourcen für staatlich gesetzte Normen sperren will, wenn solche Gehalte in „profane“ Semantik übersetzt werden? Dass die Rechtswissenschaft zur Begründung der „Unantastbarkeit des menschlichen Erbguts“ (womöglich zurecht?) glaubt, auf *funktionelle Äquivalente religiöser Argumentationsmuster* angewiesen zu sein,<sup>7</sup> kann darauf hindeuten, dass die Begründungsressourcen des säkularen Rechtsstaates hier an systematische Grenzen stoßen und die Begründung einer Unverfügbarkeit der Natürlichkeit des menschlichen Genoms mit Argumenten, die sich im Rahmen einer säkularen, religiös „neutralen“ Rechtsordnung **als rechtliche** formulieren lassen, womöglich nicht auf überzeugende Weise möglich ist.

---

<sup>6</sup> Gutmann, Religiöser Pluralismus und liberaler Verfassungsstaat, S. 294.

<sup>7</sup> Gutmann, Säkularisierung und Normenbegründung, S. 247.

**Teil I**  
**Begriffliche, medizinische und**  
**historische Grundlagen**

# Kapitel 2: Der Enhancement-Begriff

Wenn es in aktuellen Diskussionen und Zeitungsmeldungen um Doping im Leistungssport, Schönheitsoperationen und die Einnahme von Ritalin durch Personen, die nicht an einer Aufmerksamkeitsdefizits-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) leiden, sondern lediglich ihre Gedächtnis- und Lernleistung verbessern möchten, geht, so ist ein Themenbereich angesprochen, der als „Enhancement“ bezeichnet wird. Bevor eine juristische und insbesondere rechtsphilosophische Auseinandersetzung mit diesem medizinischen Eingriff möglich sein kann, ist zuvorderst dieser Begriff genau zu bestimmen. Erforderlich ist dies insbesondere, da juristische Regelungen, wofür vorliegende Arbeit im Hinblick auf genetische Enhancements ein Leitfaden sein soll, und die in ihnen verwendeten regulatorische Begriffe definitorische Klarheit voraussetzen.

## I. Allgemeine Wortbedeutung

Das Wort Enhancement bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie „*Verbesserung*“ oder „*Steigerung*“.<sup>8</sup> Oft werden auch die Begriffe „*genetic doping*“<sup>9</sup>, „*Melioration*“<sup>10</sup>, „*positive Eugenik*“<sup>11</sup> oder „*wunscherfüllende Medizin*“ beziehungsweise „*Wunschmedizin*“<sup>12</sup> verwendet. Um den Unterschied zur bloßen Therapie zu betonen, könnte man auch von „Optimierung“ sprechen. Dem allgemeinen Sprachgebrauch zufolge handelt es sich bei Enhancement um die Verstärkung einer Eigenschaft in

---

<sup>8</sup> *Oxford Dictionary of English*, Eintrag „enhancement“: „an increase or improvement in quality, value, or extent“; ähnlich auch *Pschyrembel*, Eintrag „Enhancement“, S. 522 („Erhöhung“, „Verstärkung“); *drze*, Enhancement, S. 15.

<sup>9</sup> *Bayertz*, The Normative Status of the Human Genome, S. 175; beziehungsweise „*Gendoping*“, so auch *Eberbach*, MedR 2008, 325 (331); *Pawlenka*, Der Künstliche Mensch, „Gen-Doping“ und die Naturalisierung der Leistung im Sport, S. 119.

<sup>10</sup> *Lenk*, Therapie und Enhancement, S. 30.

<sup>11</sup> *Zoglauer*, Konstruiertes Leben, S. 104.

<sup>12</sup> *Eberbach*, MedR 2008, 325.

qualitativer oder quantitativer Hinsicht. Die Konnotation ist somit eine grundsätzlich neutrale, wenn nicht sogar positive.<sup>13</sup>

## II. Enhancement als Gegenbegriff zur Therapie

In dem aktuellen juristischen und ethischen Diskurs wird der Begriff des Enhancements vorrangig in Abgrenzung und als Gegenbegriff zur Therapie verwendet,<sup>14</sup> sodass beide Begriffe in einem definitorischen Zusammenhang stehen. Dadurch wird deutlich, dass mittels des Enhancements nicht Ziele erreicht werden sollen, die medizinisch indiziert wären,<sup>15</sup> sinnbildlich gesprochen also eine Pflicht wären, sondern vielmehr die Kür darstellen. Während Therapien sich gegen Krankheiten richtende Eingriffe sind, betrifft das Enhancement gesunde Systeme und „normale“ Eigenschaften und strebt nach deren Verbesserung.<sup>16</sup> Was „normal“ ist, lässt sich, etwa mit Daniels' Ansatz des „*species-typical normal functioning*“, daran messen, was es dazu bedarf, ein funktionsfähiger und umfassender Teilnehmer sozialen Zusammenspiels zu sein. Dabei bedarf es jedoch einer vorsichtigen Unterscheidung dessen, was biomedizinisch und objektiv-wertfrei betrachtet faktische Voraussetzung einer funktionalen Einheit mit speziestypischen Fähigkeiten ist, und Wertvorstellungen, welche die Grenze zwischen den naturwissenschaftlich klar abgrenzbaren Polen von Gesundheit und Krankheit in die eine oder andere Richtung zu verschieben suchen. Ob Homosexualität oder Masturbation eine Krankheit darstellt, lässt sich anhand erstgenannter Kriterien ebenso deutlich verneinen wie sich Erkrankungen diagnostizieren lassen.<sup>17</sup>

Dem entspricht auch der Ansatz, dass unter den Begriff „Enhancement“ somit Eingriffe fallen, die nicht notwendigerweise medizinisch kontraindiziert sind, zu deren Durchführung der betreffende Arzt aber aufgrund seines Berufsstandes nicht verpflichtet ist und deren Zweck außerhalb medizinischer Zielsetzungen liegt.<sup>18</sup>

Im bioethischen Diskurs wird in einer weiteren Variante der definitorischen Differenzierung zwischen Enhancement und Therapie ersteres auch verglichen mit einer sinnlosen Therapie ( *futile treatment*). Auch hierauf habe der Patient kein rollenbedingtes Recht, während sich der Arzt, der eine solche Therapie durchführen möchte, einem besonderen Rechtfertigungszwang ausgesetzt sehe. Angesprochen von dieser Definition ist somit ein breites Feld von Aspekten, die im Kontext eines gesetzlichen Regelungsversuchs zu berücksichtigen sind. Beispielfhaft sind hier zu

<sup>13</sup> Lenk, Therapie und Enhancement, S. 27.

<sup>14</sup> Allhoff, Journal of Evolution & Technology 18, 10.

<sup>15</sup> Beck, MedR 2006, 95 (96); Juengst, What Does Enhancement Mean?, S. 31 f.; Lenk, Therapie und Enhancement, S. 27.

<sup>16</sup> Juengst, What Does Enhancement Mean?, S. 31 ff., 35 ff.; Allhoff, Journal of Evolution & Technology 18(1), 10.

<sup>17</sup> Buchanan/Brock/Daniels/Wikler, From Chance to Choice, S. 74, 119, 121 f., 126 f.

<sup>18</sup> Juengst, What Does Enhancement Mean?, S. 29, 44.

nennen die Rolle der medizinischen Profession in der Gesellschaft, die Rahmensetzung im Hinblick auf erforderliche biomedizinische Forschung sowie Fragen der Finanzierung. Allerdings wird bei diesem Vergleich ein gewichtiger Umstand außer Acht gelassen: Während sinnlose Therapien keine Wirkung haben, zu nichts führen und somit überflüssig sind, führen Enhancement-Maßnahmen *qua definitionem* zu einer Verbesserung.<sup>19</sup>

Auch im Recht werden die Begriffe des Enhancements, der Krankheit und Gesundheit diskutiert,<sup>20</sup> wobei der Inhalt in den jeweiligen Rechtsgebieten in Abhängigkeit von Entstehungsgeschichte und Zweck der anzuwendenden Norm durchaus ein unterschiedlicher sein kann.<sup>21</sup> So definierte der BGH im Zusammenhang mit dem Arzneimittelrecht eine Krankheit als *„jede, also auch eine nur unerhebliche oder vorübergehende Störung der normalen Beschaffenheit oder der normalen Tätigkeit des Körpers, die geheilt werden kann.“*<sup>22</sup> Gestützt wurde dieses sehr weite Begriffsverständnis auf die Überlegung, dass im Zusammenhang hiermit die Einordnung von Substanzen als Arzneimittel steht. Hierunter seien zum Schutz der Bevölkerung vor unsachgemäßer Herstellung, nicht fachmännischer Verbreitung und falscher Einnahme von Medikamenten angemessen viele Substanzen zu fassen, was sich über eine weite Auslegung des Krankheits-Begriffs erreichen ließe.<sup>23</sup> Enger hingegen ist der Krankheitsbegriff des Sozialrechts. Hiernach ist Krankheit ein *„regelwidrige[r] Körper- und Geisteszustand, der therapeutische Maßnahmen gebietet oder in Arbeitsunfähigkeit wahrnehmbar zutage tritt.“*<sup>24</sup> Gleiches gilt grundsätzlich auch im Arbeitsrecht. Hier ist der Begriff aber insofern enger, als dass zusätzlich noch Arbeitsunfähigkeit vorliegen muss. Andererseits umfasst er auch psychische Leiden.<sup>25</sup> Wie weitreichend die Bedeutung der Unterscheidung zwischen Krankheit und Gesundheit, zwischen Therapie und Enhancement ist, lässt sich auch im Steuerrecht beobachten. Gemäß § 4 Nr. 14 UStG sind Ärzte von der Umsatzsteuer befreit. Die Befreiung von der Gewerbesteuer ergibt sich aus den § 2 I GewStG, §§ 15 I Nr. 1, II, 18 I Nr. 1 S. 1 und 2 EStG. Dass diese Normen hinsichtlich einer Schönheitsoperation nicht privilegierend eingreifen, wenn diese nicht medizinisch indiziert ist, hat die Rechtsprechung bereits festgestellt.<sup>26</sup> Ob ähnliches gilt, wenn sie keine heilende, sondern eine verbessernde Tätigkeit ausüben, bleibt zu diskutieren.<sup>27</sup>

<sup>19</sup> Juengst, What Does Enhancement Mean?, S. 29 f.

<sup>20</sup> Beck, MedR 2006, 95 (96).

<sup>21</sup> BGH, Urteil vom 19.12.1980, I ZR 157/78, NJW 1981, 1316 (1317).

<sup>22</sup> BGH, Urteil vom 21.03.1958, 2 StR 393/57, NJW 1958, 916 (918).

<sup>23</sup> Vergleiche BGH, Urteil vom 21.03.1958, 2 StR 393/57, NJW 1958, 916 (917 f.).

<sup>24</sup> Laufs/Uhlenbruck-Laufs, Handbuch des Arztrechts, § 2 Rdnr. 11.

<sup>25</sup> Beck, MedR 2006, 95 (97).

<sup>26</sup> BFH, Urteil vom 15.07.2004, V R 27/03, BFHE 206, 471.

<sup>27</sup> Beck, MedR 2006, 95 (97).

## 1. Weitere Konzeptionen des Enhancement-Begriffes

Neben dieser wohl gängigsten Herangehensweise findet man in der Literatur zahlreiche weitere Interpretationen des Enhancement-Begriffes, die im Folgenden zunächst knapp erläutert werden sollen, bevor aus noch anzuführenden Gründen näher auf diejenige Definition eingegangen wird, die sich an der Abgrenzung zur Therapie orientiert.

Enhancement wird so zum Teil auch als Gegenbegriff zur Errungenschaft und Natürlichkeit angesehen. Enhancement sei von anderen verbessernden Handlungen dadurch abzugrenzen, dass bei ihm künstliche, eben nicht natürliche Mittel verwendet werden. Eine besondere Begründungsleistung ist mit dem Hinweis auf einen besonderen Wert der Natürlichkeit jedoch nicht erbracht; dass das Natürliche um seiner selbst willen bevorzugt werden soll, ist abseits „*erhebliche[r] metaphysische[r] Beweislasten*“ kaum zu argumentieren.<sup>28</sup>

Des Weiteren wird Enhancement zu Maßnahmen konventioneller Leistungssteigerung bisweilen anhand dessen abgegrenzt, ob die verwendeten Mittel körpereigene oder körperfremde sind: Enhancement erfordere Interventionen in den menschlichen Körper von außen, ihre Wirkung beruhe nicht auf körpereigenen Prozessen. Auch dies scheint jedoch nur wenig zu einem stichfesten Begriffsverständnis beizutragen. Schließlich rufen zahlreiche von außen in den Körper eingebrachte, diesem fremde Stoffe körpereigene Reaktionen hervor oder verstärken diese. Eine scharfe Trennung zu – dem konventionellen Verständnis nach – therapeutischen Maßnahmen ist anhand dieser Distinktion nicht möglich.<sup>29</sup>

Darüber hinaus wird hieran kritisiert, dass persönliche Verbesserungen durch Disziplin und Anstrengungen zu erreichen und sich zu verdienen sind. Ihr Wert werde jedoch durch verbessernde biomedizinische Eingriffe gemindert, weswegen diese einen Betrug an gesellschaftlichen Praktiken darstellten. Aufgrund seiner Künstlichkeit sei Enhancement daher abzulehnen. Es stelle eine pharmakologische und daher unlautere Abkürzung dar, die die Natürlichkeit des Menschen und seiner natürlichen Leistung beziehungsweise Leistungsfähigkeit nicht in Demut akzeptiere, sondern die wahre Natur der verbesserten Person verdecke. In verwerflicher Weise würde man sich dazu aufschwingen, Gott zu spielen. Auch wenn das Individuum noch Urheber seiner Leistung ist (denn schließlich hat nicht das Ritalin eine Prüfung absolviert, sondern die Person, die dieses Medikament eingenommen hat, um etwa die Nacht hindurch lernen zu können), so habe es den Erfolg der Leistung nicht verdient. Im Hinblick auf Klausuren oder Examina würde deren Zweck, nämlich die Leistungsüberprüfung und der Leistungsvergleich, gar konterkariert. Enhancement wird darüber hinaus auch als Pervertierung der Medizin verstanden. Relevanz erlangt diese Definition zumeist im Hinblick auf gesellschaftliche Vorurteile, die sich etwa gegen bestimmte äußerliche, zum Teil ethnische Merkmale richten. So werden Träger dieser Merkmale zuweilen dazu veranlasst, beispielsweise ihre dunkle Haut

<sup>28</sup> Ach, Enhancement, S. 108.

<sup>29</sup> Ach, Enhancement, S. 108 f.



zu bleichen oder eine Schönheitsoperation vornehmen zu lassen. Die Verabreichung von Wachstumsmitteln an Kinder zur Verbesserung ihres sozialen Status ist nur ein weiteres Beispiel. Kritik wird hieran insbesondere deswegen geäußert, weil es sich hierbei um soziale Probleme handelt, die *per definitionem* in der gesellschaftlichen Gruppe, aber keinesfalls im betroffenen Individuum liegen. Jede Maßnahme, die an diesem ansetzt und seinen sozialen Status zu verbessern sucht, sei, so wird kritisiert, somit eine Schuldzuweisung an das Opfer. Sie würde die Situation der betroffenen Personen darüber hinaus nur verschlechtern, indem sie die gesellschaftlichen Vorurteile perpetuiert und so gar eine Komplizenschaft begründet.<sup>30</sup>

Diese Versuche einer Definition des Enhancement sprechen allesamt zentrale Punkte in der ethischen und juristischen Debatte um dessen Zulässigkeit an. Schwierigkeiten bereiten sie jedoch hinsichtlich der für einen gesetzlichen Regelungsentwurf notwendigen Bestimmtheit des Begriffes. Deutlich wird dies insbesondere im Hinblick auf die „*Medikalisierung gesellschaftlicher Probleme*“<sup>31</sup>. Während einige Merkmale wie die Körpergröße, Schnelligkeit oder Sprungkraft naturwissenschaftlich messbar sind, können hingegen auch Eigenschaften betroffen sein, die dies nicht sind oder die noch nicht einmal in einem größeren Sinnzusammenhang verstanden werden können. *Juengst* führt beispielsweise Loyalität, Führungskraft, Verantwortung, Aggressivität und Altruismus auf. All diese Charakteristika betreffen unsere Mitmenschen und deren Beurteilung. Sie stellen, so *Juengst*, die „*Maschinerie des sozialen Gedeihens*“ dar und können ohne Bezug zu einem gesellschaftlichen Umfeld weder erkannt noch kultiviert oder bewertet werden.<sup>32</sup> Der Umstand, dass diese Eigenschaften also nicht messbar sind, führt zu einer definitorischen Unsicherheit, die ein gesetzlicher Ordnungsbegriff nicht aufweisen sollte. Des Weiteren lassen sich die angesprochenen Kriterien zwar nutzbar machen für eine private Entscheidung, aber können kaum Wegweiser für öffentliche Richtlinien sein. Insbesondere gilt dies für religiös motivierte Argumente, wie im Verlaufe dieser Arbeit an anderer Stelle noch zu zeigen sein wird. Auch die Abgrenzung zwischen Natürlichem und Unnatürlichem vermag nicht zu überzeugen. Unsere zivilisierte Lebenswelt ist keineswegs mehr naturbelassen. Unentwegt intervenieren wir in natürlich-biologische Abläufe, setzen Zahnkronen ein, benutzen Prothesen zur Substitution verlorener Glieder und bedienen uns Medikamenten zur schnelleren Genesung oder zur Familienplanung. Natürlich ist all dies nicht. Aber nichts davon stellt eine Maßnahme dar, die den Körper über sein ursprüngliches Maß hinaus verbessern würde. Von einem Enhancement kann daher keine Rede sein, die bloße (Un-) Natürlichkeit ist somit kein taugliches Abgrenzungskriterium. Auch die weiteren genannten Aspekte sind wenig zielführend in der Frage, was genau unter „Enhancement“ zu verstehen ist. Angesprochen sind damit vielmehr Folgen, zu denen bestimmte biomedizinische Maßnahmen führen könnten.

In meiner Arbeit möchte ich daher den Enhancementbegriff zugrunde legen, der sich aus einer Differenzierung zwischen diesem und dem Therapiebegriff ergibt.

<sup>30</sup> *Juengst*, What Does Enhancement Mean?, S. 41 ff.

<sup>31</sup> *Juengst*, What Does Enhancement Mean?, S. 42.

<sup>32</sup> *Juengst*, What Does Enhancement Mean?, S. 43.

Dieser erscheint nach den bisherigen Ausführungen als dasjenige Begriffsverständnis, welches die Grenze medizinischer Kompetenz zu ziehen vermag und die Grenze der medizinischen Pflicht darstellt. Daraus könnte folgen, dass es Ärzten unter Umständen erlaubt ist, Enhancement-Eingriffe durchzuführen. Sie könnten sie aber auch verweigern, und zwar gleich aus welchem subjektiven, das heißt gegebenenfalls auch religiös motivierten Grund, denn dieser bedarf nicht der Gültigkeit und Einsichtigkeit gegenüber allen Adressaten eines Enhancements regelnden Gesetzes.

## 2. Der Therapie-Begriff

Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, den Begriff der Therapie näher zu beleuchten. Seinen Ursprung hat dieser in der griechischen Sprache. *Therapeia* bedeutet hier so viel wie *Aufwartung* oder *Dienst*, das heißt, der Begriff weist ursprünglich keinerlei expliziten Bezug zu medizinischem oder heilendem Handeln auf.<sup>33</sup> Neben der Verwendung für die Bezeichnung von Kriegsdiensten<sup>34</sup> und religiöser Verehrung<sup>35</sup>, benennt dieser Begriff aber auch medizinische Dienste<sup>36</sup>. *Therapeia* ist somit eine Dienstleistung des Arztes am Patienten, die sich nicht auf nur heilende Handlungen beschränkt.

### a) Der Therapie-Begriff in der Antike

Dieses weite Begriffsverständnis schlägt sich auch im antiken Therapiebegriff nieder. Hierbei wurden drei Arten von Behandlungen unterschieden<sup>37</sup>:

Die Diätetik (διατητική) bezog sich nicht nur auf die Ernährung, sondern umfasste die gesamte Lebensweise, so auch die Lebensführung, die auf die unterschiedlichen Konstitutionen der Patienten abgestimmt wurde, sowie die Auswirkungen des Klimas oder der örtlichen Gegebenheiten.<sup>38</sup> Die Pharmazeutik (φαρμακευτική, φαρμακεία) hatte, wie sich aus der Bedeutung des Verbes *pharmakao* (leiden unter den Folgen von Drogen oder Zauberformeln) ergebe, so *Lenk*, einen schamanischen oder magischen Einfluss.<sup>39</sup> Die Chirurgie (χειρουργία) als die Handarbeit der Medizin stellt die *ultima ratio* dar. Schon aus dem Hippokratischen Eid ergibt sich, dass die Chirurgen als eine besondere Gruppe außerhalb der allgemeinen Ärzteschaft

<sup>33</sup> *Lenk*, Therapie und Enhancement, S. 32.

<sup>34</sup> *Homer*, Odyssee, 13. Gesang, Zeile 265.

<sup>35</sup> *Platon*, Der Staat, 427b.

<sup>36</sup> *Plato*, Protagoras, 354a6; *Aristoteles*, Politik, 1287a40.

<sup>37</sup> *Plato*, Protagoras 354a6.

<sup>38</sup> Vergleiche *Lenk*, Therapie und Enhancement, S. 32.

<sup>39</sup> *Lenk*, Therapie und Enhancement, S. 32.

besonderen Standesschutz genossen.<sup>40</sup> So lautet der Eid: „*Auch werde ich den Blasenstein nicht operieren, sondern es denen überlassen, deren Gewerbe dies ist.*“<sup>41</sup>

Ziel der Therapie im antiken Sinne war dabei nicht nur die Heilung von Krankheiten, sondern auch die Erhaltung der Gesundheit. So schreibt *Aristoteles* in seiner *Nikomachischen Ethik*: „*Da es nun viele Arten des Handels, Herstellungswissens (technē) und der Wissenschaft (epistēmē) gibt, gibt es auch viele Ziele; so ist das Ziel der Medizin die Gesundheit [...].*“<sup>42</sup> Der antike Therapiebegriff war gesundheitsorientiert. Auch heute gibt es sogenannte salutogenetische Ansätze der Medizin.

## b) Der moderne Therapie-Begriff

Im Gegensatz dazu ist die moderne Schulmedizin eher pathotroper Natur im Sinne *Walther Ch. Zimmerlis*.<sup>43</sup> Die Fokussierung von Therapieansätzen findet somit weniger auf die zu erhaltende oder herzustellende Gesundheit statt, wie es bei sich am antiken Therapiebegriff orientierenden, salutogenetischen Ansätzen der Fall ist. Der moderne Therapiebegriff ist vielmehr ein engerer, sich auf die Heilung (manifeste) Krankheiten beschränkender.<sup>44</sup> Entsprechend bemüht *Zimmerli* den Medizinerspruch „*Gesund‘ gibt’s nicht, es gibt nur ‚unvollständig abgeklärt‘.*“ So stellt er weiter fest, dass die Bedeutung von Krankheit und Gesundheit in dem jeweiligen kulturellen Zusammenhang festgelegt wird. In unserer Kultur begreifen wir Gesundheit *ex negativo* über unsere definitorische Kompetenz bezüglich pathogener Umstände.<sup>45</sup>

Derart ausgehend vom Krankheitsbegriff könnte man als Enhancement also mit *Fuchs* solche Maßnahmen betrachten, die einen Eingriff in den menschlichen Körper darstellen, der gerade nicht eine Krankheit heilen soll.<sup>46</sup>

Diese Feststellung führt jedoch nur zu scheinbarer Klarheit, stellt sich doch die dieser Differenzierung zugrunde liegende Frage, was Gesundheit und was Krankheit ist. Sowohl der Therapie- wie auch der Enhancementbegriff sind definitorisch somit von der Konzeption von Krankheit und Gesundheit abhängig, wobei im Rahmen einer konkreten Begriffsbestimmung nur ein weiteres Hindernis darin besteht, dass auch interdisziplinär keine Einigkeit erreicht ist.<sup>47</sup> So begreift der Medizinthoretiker Gesundheit als das intakte Funktionieren der Organe, während der Evolutionsbiologe darunter die adäquate Adaption an die Umwelt auffasst und der Medizinsoziologe nach den individuellen und gesellschaftlichen Faktoren von Ge-

<sup>40</sup> *Lenk*, Therapie und Enhancement, S. 32 f.

<sup>41</sup> Zitiert nach *Müri*, Der Arzt im Altertum, S. 9.

<sup>42</sup> *Aristoteles*, Nikomachische Ethik, Buch 1–I, 1094a.

<sup>43</sup> *Zimmerli*, Gesundheit als offenes System, S. 5 ff.

<sup>44</sup> *Lenk*, Therapie und Enhancement, S. 34.

<sup>45</sup> *Zimmerli*, Gesundheit als offenes System, S. 5.

<sup>46</sup> *Fuchs*, Lexikon der Bioethik, Band 1, Eintrag „Enhancement“, S. 604.

<sup>47</sup> Vergleiche auch *Boorse*, Philosophy & Public Affairs 1975, S. 50.

sundheit und deren Bedeutung für die Lebensqualität fragt. Philosophisch ließe sich auch fragen, an welchen Zielen und Präferenzen Gesundheit und ihre Erreichbarkeit gemessen werden sollten. Darüber hinaus wird unterschiedlich beurteilt, ob Gesundheit ein Status, der Begriff somit ein rein deskriptiver, oder eine Norm und der Begriff entsprechend ein präskriptiver ist. Versucht man ein umfassendes Verständnis von Gesundheit und Krankheit zu erarbeiten, so scheinen insbesondere, aber nicht ausschließlich, die im Folgenden zu erörternden drei Aspekte von Bedeutung zu sein, wobei diese keinesfalls isoliert zu betrachten sind, sondern interagieren:<sup>48</sup>

#### aa) Die objektive Beurteilung von Gesundheit und Krankheit

Ein bedeutendes Beispiel für eine Beurteilung von Krankheit und Gesundheit, die sich ausschließlich an objektiven Faktoren ausrichtet, ist in *Boorses* biostatistischem Ansatz zu finden. *Boorse* argumentiert, Gesundheit sei medizinisch definiert als die Abwesenheit von Krankheit und somit ein vollkommen wertneutraler Begriff: „*If diseases are deviations from the species biological design, their recognition is a matter of natural science, not evaluative decision.*“<sup>49</sup> Dabei versteht er die Abwesenheit von Krankheit als das normale Funktionieren des Organismus, wobei sich die Normalität nach dem statistischen Mittelwert beurteilen lässt und ein Funktionieren dann zu bejahen ist, wenn biologisch zugewiesene Funktionen erfüllt werden.<sup>50</sup> Krankheit ist demnach biologische Dysfunktionalität, eine Negativabweichung der humanen Artnatur, die für alle Menschen gleich ist und sich anhand dessen bestimmen lässt, was sich empirisch als arttypisch herausgebildet hat, also der statistischen Normalität entspricht.<sup>51</sup> Ebenso begreift auch *Karl Eduard Rothschuh* einen Menschen dann als krank, wenn dieser „wegen des Verlustes des abgestimmten Zusammenwirkens der physischen oder psychischen oder psycho-physischen Funktionsglieder des Organismus [und hier geht *Rothschuh* über den *Boorse*’schen Begriff hinaus] subjektiv (oder – und) klinischen (oder – und) sozial hilfsbedürftig wird.“<sup>52</sup>

*Boorse* differenziert weiter zwischen theoretischer und praktischer Gesundheit. Ersteres soll hiernach gegeben sein, wenn keinerlei zu behandelnde Krankheit im Sinne einer im Vergleich vom Normalmaß negativ abweichenden Funktionsstörung (*disease*) bei der betreffenden Person vorliegt. Von letzterem ist hingegen die Rede, wenn die Situation der betreffenden Person von subjektivem Wohlbefinden, d. h. im Duktus *Boorses* der Abwesenheit von *illness* geprägt ist.<sup>53</sup> Jemand, der sich theo-

<sup>48</sup> *Lenk*, Therapie und Enhancement, S. 35 ff.

<sup>49</sup> *Boorse*, Philosophy of Science 1977, S. 543.

<sup>50</sup> *Boorse*, Philosophy of Science 1977, S. 542; siehe auch *Boorse*, Philosophy & Public Affairs 1975, S. 50.

<sup>51</sup> *Lanzerath/Honnefelder*, Krankheitsbegriff und ärztliche Anwendung der Humangenetik, S. 54; vergleiche auch *Engelhardt/Wildes*, Encyclopedia of Bioethics, Eintrag „Health and Disease – Philosophical Perspectives, S. 1101.

<sup>52</sup> *Rothschuh*, Der Krankheitsbegriff, S. 417.

<sup>53</sup> *Boorse*, Philosophy of Science 1977, S. 542.

retischer Gesundheit erfreut, leidet somit unter keinen nachweisbaren Krankheiten. Über sein subjektives Wohlbefinden sagt dies jedoch nichts aus. Der praktisch Gesunde hingegen fühlt sich gesund, auch wenn er dies vielleicht gar nicht ist, sondern zum Beispiel eine bislang unentdeckte Krankheit hat.<sup>54</sup>

Kritik hieran betraf insbesondere die Frage nach der Normalität im Zusammenhang mit der Tatsache, dass nicht jede Abweichung vom statistischen Mittel zugleich auch eine krankhafte Erscheinung zu sein braucht.<sup>55</sup> Als zusagend erscheint an dieser Betrachtungsweise jedoch die naturwissenschaftliche Objektivität und damit verbundene „*beruhigende[...] Sachlichkeit*“<sup>56</sup>.

Auch die Rechtsprechung richtet sich bei der Definition von Krankheit beziehungsweise bei der Negativdefinition von Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit nach objektiven Kriterien. Hiernach sei Krankheit „*unabhängig von den subjektiven Vorstellungen (des Betreffenden) [...] ein objektiv nach ärztlichem Urteil bestehender anormaler Körper- und Geisteszustand*“<sup>57</sup>, „*eine nicht unerhebliche und nicht nur vorübergehende Abweichung von der Norm [...], die geeignet ist, das Wohlbefinden zu beeinträchtigen*“<sup>58</sup> oder setze „*einen anormalen körperlichen, geistigen oder seelischen Zustand voraus, der den Betroffenen in der Ausübung normaler psychischer oder körperlicher Funktionen derart beeinträchtigt, dass er nach herrschender Auffassung einer medizinischen Betreuung bedarf*“.<sup>59</sup> Subjektive Vorstellungen des Betroffenen seien, so Eberbach, demzufolge nicht ausschlaggebend für die Frage des Vorliegens einer Krankheit, sondern könnten höchstens ein Anlass zum Arztbesuch sein. Anders verhielte es sich hingegen beim Enhancement als Wunscherfüllung. Hier sind subjektive Vorstellungen sowohl Motiv als auch Ziel der Konsultation des Arztes.<sup>60</sup>

## bb) Die Beurteilung von Gesundheit und Krankheit aus subjektiver Sicht

Auf das subjektive Befinden stellt prominent die Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO) ab, wenn sie definiert, Gesundheit sei „*a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease and infirmity*“.<sup>61</sup> Kritikpunkte werden hierbei weniger in der Tatsache

<sup>54</sup> Lenk, Therapie und Enhancement, S. 37.

<sup>55</sup> Lenk, Therapie und Enhancement, S. 38; diese Problematik thematisierte auch Boorse selbst in *Philosophy & Public Affairs* 1975, S. 50 ff.

<sup>56</sup> Lenk, Therapie und Enhancement, S. 37.

<sup>57</sup> BGH, Urteil vom 17.12.1986, IVa ZR 78/85, NJW 1987, 703.

<sup>58</sup> BGH, Beschluss vom 21.04.1958, 2 StR 393/57, BGHSt 11, 304 (315)=NJW 1958, 916.

<sup>59</sup> BFH, Urteil vom 10.05.2007, III R 47/05, NJW 2007, 3596.

<sup>60</sup> Eberbach, MedR 2008, 325 (326).

<sup>61</sup> *World Health Organization*, Preamble to the Constitution; deutsch: „Zustand vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur des Freiseins von Krankheit und Gebrechen“; Lanzerath/Honnfelder, Krankheitsbegriff und ärztliche Anwendung der Humangenetik, S. 52; *Psyhyrembel*, Eintrag „Gesundheit“, S. 685.

gesehen, dass Gesundheit anhand von primär subjektiven Kriterien wie dem Wohlbefinden – terminologisch handelt es sich nach *Boorse* um die Bestimmung von praktischer Gesundheit, da die Existenz von physischen Funktionsstörungen gänzlich ausgeblendet wird<sup>62</sup> – definiert wird, sondern vielmehr in dem Umstand, dass sie hier eine maximalistische, neben physischen auch soziale und ökonomische Gesichtspunkte einbeziehende Ausrichtung erfährt, geht es hiernach doch um ein *vollständiges* Wohlbefinden.<sup>63</sup> Resultat wäre, so wendet *Illich* ein, eine Utopie, die die anthropologische Notwendigkeit von Krankheit und Tod leugnet und eine jenseitige Erlösungsvorstellung im diesseitigen Leben sucht.<sup>64</sup>

Häufig wird diese rein subjektive Betrachtungsweise aber auch um objektive Aspekte, nach *Boorse* solche der theoretischen Gesundheit, ergänzt.<sup>65</sup> *Culver* und *Gert* stellen in diesem Sinne nicht ausschließlich darauf ab, dass jemand einen Mangel an Wohlbefinden aufweist, sondern beziehen auch das Risiko, zukünftig ein Leiden zu entwickeln, und somit den Status der theoretischen Gesundheit im Sinne *Boorses*, mit ein. Hiernach ist eine Person krank „*if and only if he has a condition, other than his rational beliefs and desires, such that he is suffering, or at increased risk of suffering, an evil (death, pain, disability, loss of freedom or opportunity, or loss of pleasure) in the absence of a distinct sustaining cause.*“<sup>66</sup>

### cc) Der relationale Aspekt von Gesundheit und Krankheit

Die relationale Blickweise auf die Begriffe von Gesundheit und Krankheit betont, dass beides nicht isoliert anhand einer bloßen Untersuchung des Patienten betrachtet werden kann, sondern dass dabei auch externe Umstände und Einflüsse Berücksichtigung finden müssen.<sup>67</sup> Solche Kriterien könnten zum Beispiel sein: die Lebensgeschichte der betroffenen Person, ihre Lebensbedingungen, das Angebot von und der Zugang zu medizinischen Ressourcen und Leistungen, der Stand des medizinischen Wissens und der entsprechenden Möglichkeiten, das Selbstverständnis der mit dem Fall befassten Ärzte sowie die in der betreffenden Gesellschaft vorherrschenden Vorstellungen von der Rolle der Ärzteschaft. Wie gravierend diese Umstände divergieren können, belegen allein schon nüchterne Zahlen, die aufschlussreich dafür sein mögen, in welchem Umfang die Bevölkerung in den Genuss medizinischer Versorgung kommen kann: So wurden in der Bundesrepublik Deutschland im Zeitraum um 1990 jährlich etwa 12.000 Mediziner aus der Ausbildung entlassen. Hierzulande kam zu diesem Zeitpunkt auf 200 bis 300 der insgesamt etwa 80 Mio. Einwohner ein Arzt. Thailand, ein Land mit zu dem Zeitpunkt gut 50 Mio. Einwohnern,

<sup>62</sup> *Lenk*, Therapie und Enhancement, S. 38.

<sup>63</sup> So etwa *Lanzerath/Honnefelder*, Krankheitsbegriff und ärztliche Anwendung der Humangenetik, S. 52 f.; *Höffe*, Lexikon der Ethik, Eintrag „Krankheit“, S. 168 hält die Gesundheitsdefinition der WHO für zu anspruchsvoll und zu subjektiv.

<sup>64</sup> *Illich*, Die Enteignung der Gesundheit, S. 53–59.

<sup>65</sup> *Lenk*, Therapie und Enhancement, S. 38 f.

<sup>66</sup> *Culver/Gert*, Philosophy in Medicine, S. 81.

<sup>67</sup> *Lenk*, Therapie und Enhancement, S. 39.



bildete um 1990 hingegen jährlich nur 800 Ärzte aus.<sup>68</sup> Dies bedenkend ist es einsichtig, wenn auch solche Konzeptionen von Gesundheit und Krankheit, die *per se* keinesfalls relative sind wie etwa Boorses biostatistischer Ansatz, Gesundheit immer auch in ein Verhältnis setzen zu Parametern wie dem Alter oder Geschlecht.<sup>69</sup>

Unter den relationalen Aspekten einzuordnen sind ebenfalls die sogenannten Adaptionstheorien, die Gesundheit und Krankheit danach beurteilen, inwiefern die betreffende Person in der Lage ist, sich den Umständen und Gegebenheiten ihrer Umgebung anzupassen, wodurch ein stabiles Verhältnis zwischen beidem entsteht, das zur gegenseitigen Erhaltung beiträgt. Anschaulich beschreibt Kovács ein gesundes Verhältnis zwischen Körper und seiner Umwelt als einen dynamischen, aber dennoch stabilen Zustand im Sinne eines Gleichgewichts, das von der betreffenden Person trotz Veränderungen ihrer Umgebung aufrecht erhalten werden könne, was ihr die Fähigkeit zur Anpassung abverlange. Je besser die Person dazu in der Lage sei, desto höher sei auch ihre Lebenserwartung. Während Gesundheit in diesem wechselseitigen Verhältnis von höchstmöglicher gegenseitiger Erhaltung geprägt sei, wäre das Verhältnis als ein pathologisches zu beschreiben, sobald das Gleichgewicht instabil sei und bei Veränderungen zur Vernichtung eines der beiden kontrahierenden Pole führe. Über das Individuum hinaus gelte dies auch für die gesamte Spezies.<sup>70</sup>

Neben derlei adaptionstheoretischen Ansätzen sind auch die handlungstheoretischen Ansätze den relationalen zuzuordnen. Im Fokus der Betrachtung steht hier die Handlung, das heißt der Umstand, dass eine Person wissentlich und willentlich ein Ereignis hervorruft,<sup>71</sup> beziehungsweise ein vom menschlichen Willen beherrschtes oder beherrschbares Verhalten, welches in einem Tun oder Unterlassen liegen kann,<sup>72</sup> sodass die Anwendbarkeit dieser Theorie stets das Vorhandensein eines Subjektes erfordert. Hierunter versteht Nordenfelt „a socially integrated agent who performs a great number of daily activities and is involved in many personal and institutional relations.“<sup>73</sup> Unter stärkerer Berücksichtigung lebensweltlicher Umstände, insbesondere der Fähigkeit, Tätigkeiten des täglichen Lebens auszuführen und die Aufgaben zu erfüllen, die an ihn aufgrund seiner durch seine Sozialisation definierte Rolle gestellt werden, gelangt Nordenfelt zu folgender Definition von Gesundheit: „A is healthy if, and only if, A is able, given standard circumstances in his environment to fulfill those goals which are necessary and jointly sufficient for his minimal happiness.“<sup>74</sup> Gesundheit wird von Nordenfelt somit in Verhältnis gesetzt zu den Umständen und der Umgebung, den Fähigkeiten der betreffenden

<sup>68</sup> Vogel, Humangenetik und Konzepte der Krankheit, S. 335.

<sup>69</sup> Lenk, Therapie und Enhancement, S. 40.

<sup>70</sup> Kovács, The Journal of Medicine and Philosophy 1989 (14), 261; Kovács, Medicine, Health Care and Philosophy 1998, 31 (33 ff.).

<sup>71</sup> Höffe, Lexikon der Ethik, Eintrag „Handlung“, S. 129.

<sup>72</sup> So die Definition des strafrechtlichen Handlungsbegriffes nach der herrschenden Meinung: Rengier, Strafrecht Allgemeiner Teil, § 7 Rdnr. 8; Roxin, Strafrecht AT I, § 7 Rdnr. 5. Auf die zahlreichen Theorien der Handlungslehre, insbesondere die kausale, finale und soziale Handlungslehre, sei hingewiesen; sie bedürfen vorliegend jedoch keiner weiteren Erörterung.

<sup>73</sup> Nordenfelt, On the Nature of Health, S. 35.

<sup>74</sup> Nordenfelt, On the Nature of Health, S. 79.

Person, ihren subjektiven Zielen und der Erfüllbarkeit dieser Ziele als Grundlage einer gewissen Zufriedenheit.

### ***3. Bedeutung für eine Definition des Enhancement-Begriffes***

Die soeben erörterten Konzeptionen von Gesundheit und Krankheit als die dem Therapiebegriff, von dem der Begriff des Enhancement abzugrenzen ist, zugrunde liegende Differenzierung, stellen wie oben bereits ausgeführt keine isoliert zu betrachtenden Aspekte dar. Vielmehr ergänzen sie sich untereinander zumeist sinnvoll, wie das natürliche Begriffsverständnis und diesem entsprechend auch der alltägliche Sprachgebrauch belegen. Es ist somit nicht erforderlich, einer einzigen Betrachtungsweise den Vorzug zu geben.

Die Abgrenzung des Enhancement von der Therapie scheint intuitiv sinnvoll. Traditionell stehen Leiden im Zentrum der Medizin und sind diagnostizierbar, so dass beim Fehlen eines pathologischen Befundes von einer bloßen Therapie nicht mehr die Rede sein kann. Dennoch weist auch diese Definition Schwachstellen auf:

Ein beliebtes – aber nur scheinbares – Paradoxon wird häufig in dem kleinwüchsigen Kind gesehen. Weist dieses einen diagnostizierbaren Mangel an Wachstumshormonen auf, so stellt die Verschreibung von synthetischen Wachstumshormonen eine legitime Therapie dar. Im Gegensatz hierzu würde die Verabreichung der gleichen Medikamente an ein Kind, welches aus genetischen Gründen klein ist, weil seine Eltern dies ebenfalls sind, kein medizinisches und im Wege einer Therapie zu erreichendes Ziel darstellen. Vielmehr würde es sich nach dieser Definition um ein Enhancement handeln.<sup>75</sup> Dieses viel bemühte Beispiel zeigt aber nur scheinbar einen Widerspruch auf. Die Größe eines Kindes beziehungsweise dessen genetische Veranlagungen, die diese Größe bestimmen werden, sind das natürliche Resultat der zufälligen Kombination von Charakteristika des mütterlichen sowie des väterlichen Genpools. Sind beide Eltern klein, so besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass es das Kind ebenfalls sein wird. Dies gilt auch dann, wenn es keinen Mangel an Wachstumshormonen aufweist. Die Größe des Kindes resultiert dann aus den ihm mitgegebenen genetischen Veranlagungen, aber keinesfalls aus einer Dysfunktion. Die Tatsache, dass das Kind klein ist, folgt vielmehr den Regeln der Evolution. Anders verhält es sich, wenn ein Kind genetisch zu einer normalen oder gar großen Größe veranlagt ist. Bleibt es dennoch klein und ist dies auf einen pathologischen Mangel an Wachstumshormonen zurückzuführen, so liegt eine diagnostizierbare Krankheit vor. Deutlich wird hier also der Unterschied der Situation beider Kinder, der eine andere Beurteilung der Verabreichung von synthetischen Wachstumshormonen rechtfertigt.

Ein weiterer Kritikpunkt an dieser Definition des Enhancements als den Gegenbegriff zur Therapie kann aber auch darin gesehen werden, dass sie eine Tendenz zu fördern droht, die bereits heute zu beobachten ist, wenn es etwa um die Finan-

<sup>75</sup> So etwa Beck, MedR 2006, 95 (97); Juengst, What Does Enhancement Mean?, S. 32.



zierung von Schönheitsoperationen durch die Krankenkassen geht. Dort zeichnen sich vielfach Bestrebungen ab, ein psychisches, durch das unerwünschte körperliche Merkmal verursachtes Leiden des Patienten zu diagnostizieren mit dem Ziel der Kostenübernahme durch dessen Krankenkasse. In Umgehung des uralten Sprichwortes „*If it ain't broke, don't fix it*“ wird so versucht, eine Rechtfertigung des Eingriffs zu gewinnen.<sup>76</sup> Diese Befürchtung stellt jedoch nur eine Folgeerscheinung der Definition dar; sie ändert nichts daran, dass sie praktisch handhabbar ist. Wie mit derlei Folgen umzugehen ist, kann bereits heute anhand des Verhaltens der Krankenkassen untersucht werden, die derlei Diagnosen einer strengen Prüfung unterziehen. Ähnliche Maßnahmen sind auch im Sinne einer praktikablen Abgrenzung zwischen Enhancement, welches aufgrund seiner vermutlich großen Kosten nicht ersatzfähig sein kann und wird, und Therapie.

Die Praktikabilität dieser Definition wird zum Teil jedoch auch angegriffen vor dem Hintergrund, dass präventive medizinische Bemühungen hiernach keine beziehungsweise lediglich eine unbefriedigende definitorische Einordnung erfahren. Prävention dient dem Zweck, eine bestimmte Krankheit zu vermeiden. Sie setzt dazu bereits zu einem Zeitpunkt an, zu dem noch keinerlei pathologischer Zustand diagnostiziert werden kann, die betroffene Person also gesund ist. Obschon dies eine weithin akzeptierte und wünschenswerte medizinische Praxis ist, würde sie auf den ersten Blick dieser Definition zufolge nicht unter den Therapie-Begriff subsumiert werden<sup>77</sup> und somit nicht ohne besonderen Rechtfertigungsaufwand angewendet werden können, da weder in objektiver, noch in subjektiver oder relationaler Hinsicht eine Krankheit vorliegt. Dieser Definition zufolge würde es sich vielmehr um eine Enhancement-Maßnahme handeln. Intuitiv widerstrebt aber diese Einordnung, gesteht man sich ein gewisses ungutes, wenn auch nur diffuses und vielleicht auch kaum stichhaltig begründbares ungutes Gefühl hinsichtlich derlei Eingriffe ein. Prävention erscheint schließlich als ein sinnvoller Bestandteil der medizinischen Versorgung, wartet man doch nicht ab, bis „das Kind in den Brunnen gefallen ist“. Hierunter fallen Maßnahmen wie etwa eine regelmäßige professionelle Zahnreinigung ebenso wie Impfungen gegen Infektionskrankheiten. Zur Lösung dieses Problems gereichen jedoch zwei Überlegungen:

Erstens ergeben sich aus der Einordnung von präventiven Maßnahmen als Enhancement nur dann Schwierigkeiten, wenn dieses unzulässig wäre beziehungsweise seine Durchführung einer besonderen Rechtfertigung bedürfte. Unter dieser Voraussetzung wäre die beschriebene Folge der Klassifizierung präventiver Maßnahmen, da diese grundsätzlich wünschenswert sind, verfehlt. Dies ist hier jedoch lediglich dann der Fall, wenn vorliegende Arbeit zu dem Ergebnis kommt, dass ein Verbot des Enhancements gerechtfertigt werden kann oder gar geboten ist. Solange dieses Ergebnis nicht gefunden ist, bleibt auch eine Prävention selbst für den Fall, dass sie begrifflich einem Enhancement zuzuordnen wäre, zulässig. Für die medizinische Praxis bestünde dann kein Problem. Insoweit ein etwaiges Verbot aber auf sinnvolle Erwägungen, wie etwa die Berücksichtigung von mit der Maßnahme ver-

<sup>76</sup> Juengst, What Does Enhancement Mean?, S. 32.

<sup>77</sup> Vergleiche auch Juengst, What Does Enhancement Mean?, S. 33 f.

bundenen Risiken, die mit den intendierten Zielen abzuwägen sind, gestützt werden kann, ist es durchaus sinnvoll, diese auch im Hinblick auf präventive Maßnahmen zu bedenken, da auch hier der Intervention keine unmittelbaren gesundheitlichen Vorteilen gegenüberstehen, da nicht klar ist, ob sich das jeweilige Risiko verwirklichen wird, oder aber auch eine unmittelbare Auswirkung im Verhältnis zu dem Resultat einer therapeutischen Maßnahme als weniger dringend erscheint und so Risiken nicht im gleichen Ausmaß rechtfertigt.

Des Weiteren könnte man nicht nur Therapie und Enhancement voneinander abgrenzen, sondern präventive Maßnahmen in einem sodann entstehenden Dreiklang als selbständig betrachten, sodass sie keinem der beiden anderen Begriffe untergeordnet werden müssten.<sup>78</sup> Die Unterscheidung zwischen Enhancement und Prävention könnte sodann anhand der Frage getroffen werden, ob eine bestimmte Krankheit vermieden werden oder das Immunsystem ausschließlich zur Abwehr etwa von Hepatitis-Viren gestärkt werden soll (dann wäre die Rede von Prävention), oder ob eine allgemeine Gesundheitsförderung erreicht oder die Gesamtfunktion des Immunsystems gesteigert werden soll (dann läge eine Enhancement-Maßnahme vor).<sup>79</sup>

All dies bedenkend scheint die Differenzierung zwischen Therapie und Enhancement eine angemessene und praktikable Grundlage für eine Definition des Enhancement-Begriffes zu sein. Als „Enhancement“ werden somit Eingriffe bezeichnet, welche die menschliche Gestalt über das Maß hinaus verbessern sollen, das für die Erhaltung oder Wiederherstellung von Gesundheit erforderlich ist.<sup>80</sup> Dies kann die Verbesserung einer Funktionsweise bedeuten, aber auch das Hinzufügen neuer Eigenschaften und Fähigkeiten umfassen. Dass dieses Verständnis über die genannten Vorteile hinaus auch begrifflich neutral ist und keine Wertung präjudiziert, veranschaulicht ein von *Nick Bostrom* und *Anders Sandberg* gewähltes, wenn auch hinkendes Beispiel: Dass diese Definition nicht sogleich auch impliziere, das Enhancement sei wünschenswert, wird etwa dadurch ersichtlich, dass wir eine Erhöhung der (in regulärem, pathologisch unauffälligem Maße vorhandenen) Fähigkeit unserer Schweißdrüsen, als Reaktion auf Hitzeeinflüsse mit der Produktion von Schweiß zu reagieren, wohl kaum als positiv bewerten würden.<sup>81</sup> Obschon dieses Beispiel insofern nicht zutrifft, als dass eine in signifikantem Maße gesteigerte Schweißproduktion wiederum ein pathologischer Zustand und somit ohnehin kein Enhancement darstellt, wird aber dennoch klar, dass eine qualitative Steigerung oder quantitative Ausdehnung von Funktionen oder Fähigkeiten nicht stets auch positiv zu bewerten, die Definition somit wertneutral ist.

<sup>78</sup> So etwa auch *Coenen/Schuijff/Smits*, *The Politics of Human Enhancement and the European Union*, S. 524.

<sup>79</sup> Eine ähnliche Unterscheidung scheint auch *Juengst*, *What Does Enhancement Mean?*, S. 33 zu treffen.

<sup>80</sup> *Juengst*, *What Does Enhancement Mean?*, S. 29: „*The term enhancement is usually used in bioethics to characterize interventions designed to improve human form or functioning beyond what is necessary to sustain or restore good health.*“

<sup>81</sup> *Bostrom/Sandberg*, *The Wisdom of Nature*, S. 378.

# Kapitel 3: Medizinische Grundlagen

Zur angemessenen Beurteilung des genetischen Enhancements bedarf es über eine genaue Begriffsbestimmung hinaus eines Überblicks über die Gene involvierenden zellulären Abläufe und des Verständnisses der medizinisch-technischen Möglichkeiten und Verfahren, mit denen genetische Eingriffe vorgenommen werden können. Des Weiteren soll in diesem Kapitel der aktuelle *status quo* des medizinischen Wissens, der Möglichkeiten medizinischer Intervention, aber auch die weiterhin bestehenden Risiken beleuchtet werden.

Die Gebiete, auf denen Enhancement angewandt wird, sind weit gefasst. Die Maßnahmen können zunächst anhand dessen unterschieden werden, was optimiert werden soll. So kann auf eine Stärkung der physischen Eigenschaften abgezielt werden (*physical enhancement*), wie es zum Beispiel beim Doping im Leistungssport, der Schönheitschirurgie oder dem Einsatz von Wachstumshormonen in der Pädiatrie der Fall ist. Des Weiteren könnten auch die kognitiven Fähigkeiten dahingehend verbessert werden, dass zum Beispiel die Gedächtnis- und Lernleistung durch die Verabreichung von Ritalin an Personen, die nicht an einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) leiden, vergrößert werden soll (*intellectual enhancement*). Durch die Einnahme stimmungsaufhellender Substanzen soll darüber hinaus auf die psychische Befindlichkeit Einfluss genommen werden (*neuro enhancement*). Schließlich kommt aber auch die Einflussnahme auf bestimmte (Sozial-) Verhaltensattribute in Betracht (*moral enhancement*), wodurch zum Beispiel eine übermäßige Aggressivität eingedämmt werden soll.<sup>82</sup>

Der gentechnische Eingriff stellt nur eine von drei Möglichkeiten der verbessernden Modifizierung des Menschen dar. Neben ihm lassen sich die verfolgten Ziele auch durch die Verabreichung von Medikamenten oder chirurgische Eingriffe erreichen.<sup>83</sup>

Beleuchtet man die genetischen Modifikationen weiter, so lassen sich hier die Veränderung von somatischen Zellen, also Körperzellen, deren genetische Information nicht an die nachfolgende Generation weitergegeben wird, und die der Keimbahn unterscheiden. Während ein Eingriff in Somazellen zwar irreversibel ist, aber

---

<sup>82</sup> *drze*, Enhancement, S. 15 f.

<sup>83</sup> *Beck*, MedR 2006, 95 (96); *drze*, Enhancement, S. 16.

lediglich die jeweils behandelte Person betrifft, werden bei Enhancement-Maßnahmen, die an den Keimbahnen ansetzen, das Erbgut von Ei- oder Samenzelle, der Geschlechtszellen (Gameten), beziehungsweise des frühen Embryos modifiziert. Diese veränderte Erbinformation wird in der Folge auch an die Nachkommen weitergegeben.<sup>84</sup> So lassen sich unter weiterer Berücksichtigung des Zweckes die folgenden vier Kategorien des gentechnischen Eingriffes bilden:<sup>85</sup>

- Somatische Gentherapie, die der Prävention oder Therapie von Krankheiten dient,
- Eingriffe in die Keimbahn zur Prävention oder Therapie von Krankheiten,
- Somatische Genmanipulation mit dem Ziel der verbessernden Manipulation der genetischen Disposition und
- Eingriffe in die Keimbahn, die auf die verbessernde Manipulation der genetischen Disposition abzielen.

Während die ersten beiden Kategorien charakterisiert werden durch den therapeutischen, heilenden Aspekt, wird bei den letzten beiden Varianten betont, dass hiermit Charakteristika erzeugt werden sollen, die im Vergleich zu denjenigen, welche die betroffene Person (im Falle der somatischen Genmanipulation) natürlicherweise aufweist, eine Verbesserung darstellen.<sup>86</sup>

In vorliegender Arbeit soll es ausschließlich um die letzten beiden Kategorien gentechnischer Eingriffe gehen. Dabei ist zu beachten, dass die Fähigkeiten, verbessernde Eingriffe auf genetischer Ebene durchzuführen, zurzeit noch stark begrenzt sind. Dass diese jedoch eines Tages möglich sein werden, wird häufig nicht als eine Frage des Ob, sondern allenfalls als eine Frage des Wann beschrieben.<sup>87</sup> Bis zu diesem Zeitpunkt kann jedoch gesagt werden, dass die Verfahren, die zur Gentherapie entwickelt worden sind, auch im Rahmen von Enhancement-Maßnahmen fruchtbar gemacht werden können.<sup>88</sup> Vor diesem Hintergrund kann zur Erläuterung möglicher Funktionsweisen und Durchführungsvarianten auf die im Rahmen der sowohl somatischen als auch die Keimbahn betreffenden Gentherapie zurückgegriffen werden.

<sup>84</sup> *Wagner/Morsey*, NJW 1996, 1565; *Zoglauer*, Konstruiertes Leben, S. 97; *Bundesregierung Online*, <http://archiv.bundesregierung.de/Content/DE/Archiv16/Artikel/2005/06/2005-06-14-gentechnik-fragen-und-antworten.html> (zuletzt aufgerufen am 27.12.2012).

<sup>85</sup> Prominent vertreten wird diese Differenzierung durch *W. French Anderson*. Beispielhaft seien hier folgende Quellen zu nennen: *Anderson*, Science 226-1984, 401 (402); *Anderson*, Journal of Medicine and Philosophy 10 (1985), 275 f.; *Anderson*, Hastings Center Report 20 (1990), 21 (22 f.); darüber hinaus *Walters/Palmer*, The Ethics of Human Gene Therapy, Introduction xvii; vergleiche auch *Voss*, Rechtsfragen der Keimbahntherapie, S. 35 f.

<sup>86</sup> *Voss*, Rechtsfragen der Keimbahntherapie, S. 36.

<sup>87</sup> So etwa *Zoglauer*, Konstruiertes Leben, S. 103 mit Blick auf die Ergebnisse eines im Jahre 1998 an der Universität von Kalifornien in Los Angeles abgehaltenen Symposiums.

<sup>88</sup> Vergleiche *Stock*, Redesigning Humans, S. 39.

## I. Biologische Grundlagen

Um zu verstehen, warum und wie sich genetische Eingriffe auf den betroffenen Organismus auswirken, soll im Folgenden zunächst die Funktionsweise und Aufgaben der Gene und der Desoxyribonukleinsäure (DNS) erörtert werden.

### 1. Vom Gen zum Protein

Seitdem durch den Augustinerpater Gregor Mendel in einem Vortrag über Kreuzungsexperimente mit Erbsen vor dem Naturforschenden Verein in Brunn am 8. Februar 1865 erstmals die Existenz von Genen postuliert wurde,<sup>89</sup> hat die Forschung große Fortschritte gemacht – ein kleiner Ausschnitt des bereits Möglichen beziehungsweise möglich werdenden ist Gegenstand vorliegender Arbeit.

„Gene sind“, so Müller, „die strukturellen und funktionellen Grundeinheiten der Vererbung.“<sup>90</sup> Sie stellen zusammenhängende Abschnitte der DNS, die später näher erläutert wird, dar und enthalten Informationen für die Bildung von Eiweißmolekülen. Während man früher annahm, dass ein einzelnes Gen die Informationen für lediglich ein einziges Protein trägt (sogenannte Ein-Gen-ein-Protein-Regel) weiß man heute, dass in komplexeren Organismen die informationstragenden, sogenannten codierenden Teile (Exons, im Gegensatz zu den Introns) eines Gens unterschiedlich kombiniert werden können und somit für zahlreiche Proteine codieren. Die Gesamtheit aller Gene eines Organismus wird als Genom bezeichnet.<sup>91</sup> Über den genauen Umfang des menschlichen Genoms besteht keine Einigkeit. Die genannten Größenordnungen bewegen sich zwischen etwa 21.000 und 32.000 Genen.<sup>92</sup> Während zwar die Lokalisation der großen Mehrheit der Gene, also ihre Lage und Ausrichtung auf den Chromosomen mittlerweile bekannt sind, ist deren Funktion jedoch noch nicht vollständig erschlossen.<sup>93</sup>

Ein Gen ist dabei ein Abschnitt der Schlüsselsubstanz der Vererbung. Die darin enthaltenen Informationen sind bei Lebewesen, deren Zellen einen Zellkern besitzen (Eukaryonten), als sogenannte DNA beziehungsweise DNS, die 1869 von Friedrich Miescher entdeckten Desoxyribonukleinsäure, gespeichert. Die Bestandteile der DNS setzen sich zusammen aus einer Phosphorsäure, dem Zucker Desoxyribose und daran anknüpfend einer heterozyklischen Nukleobase. Diese Verbindung aus Zucker und der Base wird auch als Nukleotid bezeichnet. Bei der Base handelt es sich entweder um eine der Purinbasen Adenin und Guanin oder um eine der

---

<sup>89</sup> Müller, Genterapie, S. 41.

<sup>90</sup> Müller, Genterapie, S. 41.

<sup>91</sup> Wagner, Der gentechnische Eingriff in die menschliche Keimbahn, S. 21.

<sup>92</sup> Wagner, Der gentechnische Eingriff in die menschliche Keimbahn, S. 21, Müller, Genterapie, S. 42, mit weiteren Nachweisen Günther/Taupitz/Kaiser-Kaiser, Embryonenschutzgesetz, Einführung, A, Rdnr. 16.

<sup>93</sup> Wagner, Der gentechnische Eingriff in die menschliche Keimbahn, S. 21.

beiden Pyrimidinbasen Cytosin und Thymin. Über die Phosphatsäure sind die Nukleotide miteinander verbunden und bilden so einen fadenförmigen Strang, der mit einem zweiten, komplementären Strang zu einem einer spiralförmigen Strickleiter gleichenden Gebilde, der sogenannten Doppelhelix, verbunden ist. Diese gleichsam die Sprossen der Strickleiter darstellende Paarung wird über die Basen hergestellt, wobei sich ausschließlich Adenin und Thymin sowie Guanin und Cytosin miteinander verbinden. Die so entstehende Basenfolge wird als Basensequenz bezeichnet. Drei aufeinanderfolgende Baseneinheiten stellen dabei eine informative Einheit dar; sie wird Basentriplett oder Codon genannt.<sup>94</sup>

Die Umsetzung der in der DNS enthaltenen Information erfolgt schließlich in zwei Schritten, der Transkription und der Translation: Im Rahmen der Transkription werden die als Strickleiter miteinander verbundenen einzelnen Stränge der DNS an einem begrenzten Abschnitt wieder voneinander gelöst. An den freiliegenden Stellen entsteht sodann eine Verbindung zu den sogenannten Ribonukleotiden, die sich von der DNS nur insoweit unterscheiden, als dass sie anstelle der Desoxyribose als Zuckeranteil Ribose und anstelle von Thymin die Pyrimidinbase Uracil enthalten. Dieses Ribonukleinsäuremolekül (RNS) erstellt gewissermaßen eine Blaupause der DNS und befördert als sogenannte Boten-RNS oder *messenger RNA* (mRNA; A = *acid*) die zur Bildung eines Eiweißmoleküls wichtigen Informationen aus dem Zellkern hinaus, um sie an die Ribosomen, die in der Zelle für die Eiweißproduktion zuständig sind, zu übermitteln. Dort erfolgt als zweiter Schritt die Translation. Entsprechend der an der DNS von der Boten-RNS abgelesenen Information lagern sich Transfer-RNS an. Diese Transfer-RNS sind mit einer Aminosäure gebunden, die im Ribosom mit einer aus weiteren Aminosäuren bestehenden Polypeptidkette, dem entstehenden Eiweißmolekül, verknüpft wird. Die so neu gebildeten Proteine erfüllen die unterschiedlichsten Funktionen. So katalysieren sie beispielsweise als Enzyme den Stoffwechsel oder geben als Strukturproteine der Zelle ihre Form.<sup>95</sup>

In komplexen Zellen, wie etwa den menschlichen, liegt die DNS im Zellkern in der besonders kompakten Form des Chromatins vor, das in bestimmten Phasen des Zelllebens als Chromosomen lichtmikroskopisch sichtbar gemacht werden kann. Hiervon besitzt der Mensch 46 Stück. Dabei handelt es sich um 44 Autosomen und zwei Gonosomen, auf denen die Geschlechtsmerkmale codiert sind. Als sexuelles Lebewesen erbt der Mensch je einen halben Chromosomensatz von seiner Mutter und seinem Vater, woraus sich auch die stets gerade Anzahl an Chromosomen ergibt. Während die beiden Hälften dem Grunde nach homolog, das heißt gleich, sind, besteht hinsichtlich der Gonosomen eine Besonderheit: Diese sind lediglich bei der Frau, die zwei sogenannte X-Chromosomen besitzt, gleich, die Chromosomenformel (Karyotyp) lautet mithin 46,XX. Beim Mann sind sie voneinander

---

<sup>94</sup> Brocks/Pohlmann/Senft, Gentechnikgesetz, S. 2 f.; Giwer, Präimplantationsdiagnostik, S. 16 f.; Müller, Gentherapie, S. 41 f.; Wagner, Der gentechnische Eingriff in die menschliche Keimbahn, S. 19 ff.

<sup>95</sup> Die Darstellung folgt im Wesentlichen der von Wagner, Der gentechnische Eingriff in die menschliche Keimbahn, S. 20.

unterschieden: Er weist ein X- und ein Y-Chromosom auf, entsprechend ist die Chromosomenfolge 46,XY.<sup>96</sup>

## **2. Die Zellteilung**

Eine bedeutende Aufgabe der doppelsträngigen DNS im Organismus betrifft die Zellteilung. Hierbei gibt sie die genetischen Informationen an die Tochterzellen weiter, was zur Folge hat, dass einmal sämtliche Zellen in dem jeweiligen Organismus das gleiche Erbgut aufweisen, dass andererseits aber auch das Erbgut an Abkömmlinge weitergegeben wird. Voraussetzung hierfür ist die Verdoppelung der DNS, die dadurch bewirkt wird, dass die beiden DNS-Einzelstränge der Doppelhelix sich vollständig voneinander lösen, was anderen DNS-Nukleotiden ermöglicht, sich mit den freiliegenden Strängen zu verbinden. So entstehen zwei neue Doppelstränge, von denen jeder zur einen Hälfte aus dem Original-, zur anderen aus einem Tochterstrang besteht.<sup>97</sup>

## **3. Mutationen und ihre Vererbung**

Treten Veränderungen im Erbgut auf, so wird dies als Mutation bezeichnet. Auch hiervon können sowohl Körperzellen (sogenannte Somazellen) und damit nur das jeweilige Individuum, als auch die Keimzellen, worunter die Ei- und Samenzellen fallen, betroffen sein, was sich dann auch auf die Nachkommenschaft auswirkt. Mutationen sind einerseits Teil der biologischen Evolution und Voraussetzung für die Differenzierung der Arten, können andererseits aber auch zu Schädigungen führen. Die Auswirkungen einer Veränderung in der DNS können multifaktoriell, das heißt auf dem Zusammenspiel von sowohl genetischen Mutationen als auch Umwelteinflüssen beruhend, monogen, das heißt ausschließlich durch die Mutation eines einzigen Genes, oder polygenetisch, also durch die Mutation mehrerer Gene, bedingt sein.

Im Fall von rein genetisch bedingten Mutationen und unter der Voraussetzung der Betroffenheit der Keimzellen von diploiden Organismen, also solchen, die einen doppelten Chromosomensatz aufweisen, die aber nur einen haploiden Chromosomensatz in ihren Keimzellen an die Nachkommenschaft weitergeben, lässt sich die Wahrscheinlichkeit, nach der sich die Mutation vererbt, anhand der Mendelschen Gesetze bestimmen. Diese machen sich die Erkenntnis zunutze, dass ein Gen in jeder Zelle zwei Mal auftritt, da es sich auf jedem Chromosom befindet. Allerdings müssen nicht auch beide mutiert sein. Ist nur eines von der Mutation betroffen, so ist es heterozygot, andernfalls homozygot. Bei der Keimzellbildung wird der Chromo-

---

<sup>96</sup> Günther/Taupitz/Kaiser-Kaiser, Embryonenschutzgesetz, Einführung, A, Rdnr. 20; Wagner, Der gentechnische Eingriff in die menschliche Keimbahn, S. 22.

<sup>97</sup> Wagner, Der gentechnische Eingriff in die menschliche Keimbahn, S. 21.



somensatz halbiert und je eine Hälfte in eine der beiden Tochterzellen weitergegeben. Je nachdem, ob eine so entstandene Keimzelle mit oder ohne mutiertem Gen mit einer anderen Keimzelle verschmilzt, weisen die Gene des daraus hervorgehenden Individuums ebenfalls die Mutation auf oder nicht. Diese Mutation entfaltet im Falle von dominanten Erbgängen stets ihre Auswirkung: Der Genotyp, das heißt das Erbbild der chromosomalen Information, tritt immer auch phänotypisch, also das äußere Erscheinungsbild betreffend, in Erscheinung. Bei rezessiven Erbgängen ist dies hingegen nur dann der Fall, wenn beide Gene von der Mutation betroffen sind. Eine Ausnahme besteht allerdings im Hinblick auf Gonosomen. So sind rezessive Mutationen bekannt, die auf dem X-Chromosom liegen, und daher bei Männern, die lediglich ein X-Chromosom haben und somit ein dortiger Defekt nicht kompensiert werden kann, stets ihre Auswirkung manifestieren.<sup>98</sup>

## II. Die somatische Genmanipulation

Bei der somatischen Genmanipulation werden einzelne Körperzellen gentechnisch verändert, indem bei der Gentherapie ein gesundes, bei genetischem Enhancement ein erwünschtes Gen in die Zelle eingebracht wird. Dieser Gentransfer wird vorgenommen mittels eines Vektors, das heißt eines Vehikels, welches das Gen trägt. Betroffen von derlei Maßnahmen ist stets nur die behandelte Person, nicht aber ihre Nachkommen. Soweit man ausschließen kann, dass Keimbahnzellen betroffen werden, wird das Erbgut somit nicht verändert.<sup>99</sup>

### 1. Entwicklung, status quo und bestehender Forschungsbedarf

In den Jahren 1989/1990 erfolgten die ersten genehmigten Gentransfers beim Menschen.<sup>100</sup> Die vierjährige Ashanthi DaSilva litt unter Adenosindeaminase-Mangel (ADA-Mangel), einem schweren Immundefekt, aufgrund dessen sie bis zu der erfolgreichen Behandlung mit genetisch ergänzten T-Lymphozyten, einer Art weißer Blutzellen, die der Immunabwehr dienen, in einem Sterilzelt leben musste. Sie war die erste Patientin, die einer Gentherapie unterzogen wurde.<sup>101</sup>

Die Voraussetzungen für weitere Therapien mittels Genen wurden in den darauf folgenden zwei Jahrzehnten auf den Gebieten der Molekularbiologie und Genetik geschaffen, insbesondere gelang es im Jahr 2001, weite Teile des menschlichen

<sup>98</sup> Wagner, Der gentechnische Eingriff in die menschliche Keimbahn, S. 22 f.

<sup>99</sup> Vergleiche zur Gentherapie DFG, Entwicklung der Gentherapie, S. 6; Zoglauer, Konstruiertes Leben, S. 97.

<sup>100</sup> Wagner, Der gentechnische Eingriff in die menschliche Keimbahn, S. 27.

<sup>101</sup> Müller, Gentherapie, S. 49; Reiss/Straughan, Improving Nature?, S. 206 f.; ausführlich hierzu sowie zu anderen gentherapeutischen Behandlungen weiterer Krankheiten Strachan/Read, Molekulare Humangenetik, S. 689 ff.



Genoms zu entschlüsseln. Anfang der 1990er Jahre begannen dazu die ersten dokumentierten Gentherapie-Studien. Bis 2005 waren davon weltweit mehr als 1.100 durchgeführt worden. Ein Drittel dieser Studien fand in Europa, schwerpunktmäßig in Deutschland statt. In China wurden 2003 und 2005 erste Gentherapie-Arzneimittel zur Behandlung von malignen Tumoren zugelassen. Der erste Zulassungsantrag für ein solches Arzneimittel zur Therapie eines Hirntumors ging bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) im Jahr 2005 ein.<sup>102</sup>

Dieses Forschungsgebiet erhielt von Anfang an besondere, euphorische und häufig auch zu wenig kritische Aufmerksamkeit, was zu einer unrealistischen Erwartungshaltung führte, die in der Folge durch einige Rückschläge, zu denen es in einigen Studien kam, enttäuscht wurde. Die öffentliche Wahrnehmung der Gentherapie und ihre Risikobewertung änderten sich, als am 17. September 1999 der 18-jährige Jesse Gelsinger in Philadelphia an den Folgen einer somatischen Gentherapie starb. Er litt an einer seltenen Stoffwechselkrankheit (Ornithin-Transcarbamylase-Defekt oder OTC-Enzymdefizienz), die nicht lebensbedrohlich war und die er gelernt hatte, durch die Einhaltung einer eiweißarmen Diät und die Einnahme von Medikamenten zu beherrschen. Obschon die Gentherapie somit nicht notwendig war und ihm ohnehin bestenfalls zu einer lediglich temporären Besserung verholfen hätte, nahm er an einem Gentherapieversuch in der Hoffnung, dadurch anderen Kranken helfen zu können, teil. Sein Tod trat vier Tage nach Beginn der Therapie ein. Nachdem er anfangs für einen bedauerlichen Zufall gehalten wurde, stellte sich später heraus, dass im Rahmen der Studie gegen zahlreiche medizinethische Prinzipien verstoßen worden und so die Grundsätze der informierten Zustimmung, der Verhältnismäßigkeit von Nutzen und Risiko sowie des Vorranges des Wohls des Patienten missachtet worden waren. Nach dem Motto „viel hilft viel“ wurde Gelsinger eine Überdosis Adenoviren, die Erkrankungen der Atemwege verursachen, injiziert, sodass sich zeitweilig mehr Viren als rote Blutkörperchen in Gelsingers Körper befanden. Diese lösten heftige Immunreaktionen aus und führten zu einem multiplen Organversagen. In Folge dessen wurden weitere ungeklärte Todesfälle und die Tatsache bekannt, dass lediglich 6 % aller meldepflichtigen Unfälle der Nationalen Gesundheitsbehörde mitgeteilt wurden.<sup>103</sup> Ein weiterer bekannt gewordener Rückschlag trat ein, als drei Jahre nach der ersten erfolgreichen Behandlung von zehn Patienten mit der angeborenen Immunschwächekrankheit X-SCID (Severe Combined Immunodeficiency) in Frankreich drei Patienten ein leukämieähnliches Krankheitsbild entwickelten, an dem einer der Patienten starb. Ursächlich hierfür waren die retroviralen<sup>104</sup> Genvektoren, die durch ihren Einbau in das Genom der

---

<sup>102</sup> DFG, Entwicklung der Gentherapie, S. 6.

<sup>103</sup> Knoepffler, Menschenwürde in der Bioethik, S. 175; Müller, Gentherapie, S. 50 f.; Zoglauer, Konstruiertes Leben, S. 99 ff.

<sup>104</sup> Reverse Transkriptase Onkoviren (Retroviren) sind die Ursache für zum Beispiel Tumore, neurologische Erkrankungen oder Immunschwäche, können aber auch symptomlos vorkommen (apathogen). Sie kommen bei zahlreichen Spezies vor, gewissermaßen von der Muschel bis zum Menschen. Beispielsweise wäre zu nennen das HI-Virus.

behandelten T-Lymphozyten zelluläre Proto-Onkogene<sup>105</sup> aktiviert hatten, was zur Auslösung der Krebskrankheit beigetragen hat.<sup>106</sup>

Trotzdem ist man sich einig, dass die Gentherapie einen Ansatz mit hohem Innovationspotenzial darstellt. Die weitere Entwicklung sowie die Wirksamkeit der Therapie sind aber stets von der richtigen Wahl der geeigneten Vektoren abhängig. Die Auswahl hängt auch davon ab, ob der Gentransfer im Patienten (*in vivo*) oder in der Kulturschale (*in vitro* oder *ex vivo*) stattfindet, wobei bei ersterem die Anforderungen an Sicherheit und Zielgenauigkeit des Vektors enorm sind. Vektoren müssen sich im Rahmen der Auswahl anhand folgender drei Kriterien messen lassen: Sie müssen bestimmte Zellen effizient modifizieren können, sie müssen des Weiteren eine hinreichend starke, langfristige und, falls erforderlich, regulierbare Genexpression gewährleisten und ihnen darf schließlich kein unverhältnismäßiges Risiko innewohnen.<sup>107</sup>

Die verschiedenen Arten der Vektoren (viral, nicht-viral) und der Möglichkeiten des Gentransfers (*in vivo*, *in vitro*) werden später näher erörtert werden.

Große Erfolge können mittels der somatischen Gentherapie heute insbesondere erzielt werden bei Krebserkrankungen, die 60% der durchgeführten Gentherapien ausmachen, monogenen Erbkrankheiten, Infektionskrankheiten wie HIV und AIDS sowie kardiovaskulären Krankheiten.<sup>108</sup> Diese Erfolge beruhen vor allem auf einer stark verbesserten Effizienz des Gentransfers.<sup>109</sup>

Durch die Erhöhung des therapeutischen Wirkspiegels besteht jedoch auch eine erhöhte Gefahr der Nebenwirkung, sodass diesbezüglich weiterhin Forschungsbedarf besteht.<sup>110</sup> Insbesondere gilt dies für die molekularen Ursachen von Nebenwirkungen, etwa solchen, die durch den ungerichteten, bislang nicht kontrollierbaren und daher zufälligen Einbau des retroviralen Vektorgenoms in das Genom der Wirtszelle verursacht werden. Eine solche chromosomale Aufnahme der transferierten Gene ist zwar grundsätzlich wünschenswert, da sie gewährleistet, dass die Genveränderung bei der Zellteilung an die Tochterzellen weitergegeben wird, während extrachromosomale DNS in teilungsaktiven Zellen bald verloren geht. Dadurch, dass es jedoch noch nicht gelungen ist, die Gene an bestimmten Stellen auf dem Chromosom zu platzieren, kann es, wie im Fall oben vorgestellter X-SCID-Patienten, zu einer Dysfunktion der das Zellwachstum steuernden Gene, etwa einer Aktivierung von Onkogenen oder einer Deaktivierung von Tumorsuppressorgenen, und so zu ungerichtetem Wachstum und Tumoren kommen. Als weitere Nebenfolge möglich ist ebenso das Auftreten einer Insertionsmutation, durch die lebenswichtige Gene zerstört werden können, weswegen es zum Absterben der Zelle kommen

---

<sup>105</sup> Bei Onkogenen handelt es sich um Teile des Erbgutes einer Zelle, die den Übergang von normalem Zellwachstum zu ungebremstem Tumorwachstum hin fördern. Proto-Onkogene sind deren Anfangssequenzen.

<sup>106</sup> DFG, Entwicklung der Gentherapie, S. 8.

<sup>107</sup> DFG, Entwicklung der Gentherapie, S. 7.

<sup>108</sup> DFG, Entwicklung der Gentherapie, S. 7.

<sup>109</sup> DFG, Entwicklung der Gentherapie, S. 9.

<sup>110</sup> DFG, Entwicklung der Gentherapie, S. 9.

kann.<sup>111</sup> Dies kontrollieren zu lernen ist somit eine der größten Aufgaben zukünftiger Forschung.

Ein weiteres Problem besteht – jedenfalls bei der Verwendung viraler Vektoren – in der Gefahr einer Infektion durch die zu Zwecken des Gentransfers eingesetzten Viren. Diese werden zwar vermehrungsunfähig gemacht und stellen somit grundsätzlich keine Gefahr mehr dar. Dennoch besteht stets die Möglichkeit der Kontamination der Vektoren mit vermehrungsfähigen Viren sowie der Verbindung mit körpereigenen Viren oder mit im menschlichen Genom enthaltener viraler DNS.<sup>112</sup>

Die Forschung wird darüber hinaus noch lernen müssen, das Problem der bislang mangelnden Spezifität zu beheben: Während Viren, die als Genfähren genutzt werden, dahingehend programmiert werden können, dass sie nicht ihre eigenen Erbinformationen in die Zielzellen einbauen, sondern die gewünschten, um derentwillen das Enhancement durchgeführt wird, können sie jedoch nicht zwischen den anvisierten Zielzellen und anderen Zellen, die nicht verändert werden sollen, differenzieren. Selbst für den Fall, dass die Zielzellen über spezifische Rezeptoren verfügen, wäre zunächst auszuschließen, dass dieser Rezeptor in keiner anderen Zelle vorkommt.

Schließlich wird auch befürchtet, dass durch eine Verbindung mit Genen, die eine Resistenz gegen Antibiotika vermitteln, diese auch bei Bakterien erzeugt werden könnte, die über eine solche natürlicherweise nicht verfügen.<sup>113</sup>

Soeben Gesagtes gilt jedoch vorerst ausschließlich für die somatische Gentherapie. Hier nährt die Fähigkeit, genetische Defekte zu erkennen, die Hoffnung, diese auch heilen zu können. Das genetische Enhancement hingegen geht darüber hinaus. Dementsprechend befindet sich die Forschung hierzu erst in den Kinderschuhen. Eine Darstellung über die Möglichkeiten und Probleme der somatischen Gentherapie lässt jedoch einen vagen Eindruck davon zu, was es zur klinischen Anwendung von Enhancement-Maßnahmen noch bedarf.

Problematisch und entwicklungsbedürftig sind bei verbessernden ebenso wie bei therapeutischen genetischen Modifikationen somatischer Zellen neben den bereits geschilderten Risiken, die bislang noch nicht kontrolliert werden können, die Fragen der Zugänglichkeit und Vermehrung der Zellen und der damit zusammenhängenden geringen Effektivität des Eingriffs. Somatische Zellen befinden sich in dem jeweiligen Gewebe bereits in großer Anzahl, doch jede einzelne muss aber Target der Genmodifikation sein und die dazu eingesetzten Stoffe und Zubereitungen muss jede einzelne dieser Zellen erreichen. Faktisch ist dies aber geradezu unmöglich. Soll der Gentransfer in die Zielzellen nach der Extrahierung der Zellen aus dem Körper des Patienten *in vitro* vorgenommen werden, ergibt sich dies daraus, dass nur eine begrenzte Anzahl der Zellen aus dem Körper entfernt werden kann. Geschieht die

---

<sup>111</sup> DFG, Entwicklung der Gentherapie, S. 11; Brocks/Pohlmann/Senft, Gentechnikgesetz, S. 11; Graumann, Die somatische Gentherapie, S. 50 f.; Wagner, Der gentechnische Eingriff in die menschliche Keimbahn, S. 26; Zoglauer, Konstruiertes Leben, S. 98.

<sup>112</sup> Brocks/Pohlmann/Senft, Gentechnikgesetz, S. 11; Graumann, Die somatische Gentherapie, S. 60; Wagner, Der gentechnische Eingriff in die menschliche Keimbahn, S. 26 f.

<sup>113</sup> Brocks/Pohlmann/Senft, Gentechnikgesetz, S. 11.

Modifizierung *in vivo* durch eine Injektion der Zubereitung in das Gewebe, dessen Funktion verbessert werden soll, so entstehen dort, wo die Injektion erfolgt, kleine Inseln modifizierter Zellen. Da sich die meisten somatischen Zellen aber nicht mehr teilen und anzahlmäßig vermehren, sondern, so beispielsweise Muskelzellen im Training, lediglich ein größeres Volumen einnehmen, bleibt es bei einem bloßen Mosaik aus modifizierten Zellen und solchen in ihrer ursprünglichen Form. Selbst bei der Vornahme der Modifizierung bei Säuglingen, wo sich noch mehr Zellen teilen müssen, wird dieses Problem weiterhin bestehen. Auch wenn mittels zukünftig hinreichend sicherer Techniken die gewünschten Gene in die Zielzellen verbracht werden können, diese sich am richtigen Ort integrieren und kontrolliert exprimieren, bleibt die Wirkung dennoch lediglich auf diese verhältnismäßig wenigen Zellen begrenzt, was den Eingriff in somatische Zellen mangels Effektivität vermutlich eher unattraktiv bleiben lässt.

Im Rahmen der noch durchzuführenden Forschung und auf dem Weg zu einer eventuellen klinischen Anwendung von Enhancements kann aber zurückgegriffen werden auf die bereits mit der Gentherapie gemachten Erfahrungen und den dazu entwickelten Verfahren. Diese werden vermutlich zum Teil auch im Hinblick auf ein künftiges Enhancement zielführend sein. Unabhängig davon, welche Verfahren aussichtsreich erscheinen, sollen im Folgenden sämtliche Methoden der somatischen Gentherapie, dafür aber auch nur im Überblick, vorgestellt werden.

## ***2. Die Methoden der somatischen Genmanipulation***

### **a) Augmentations- oder Additionsmethode**

Bei der Augmentations- oder Additionsmethode soll in den Zellkern oder in das Zytoplasma, also in die den Zellkern umgebende und die Zelle ausfüllende Masse, ein Gen, das sogenannte Transgen, eingeschleust werden, das bei der Gentherapie den Ausfall eines anderen Gens kompensieren oder korrigieren,<sup>114</sup> beim Enhancement zu den gewünschten zellulären Eigenschaften wie der Produktion eines bestimmten Eiweißes führen soll. Da das Schlucken oder die intravenöse Injektion fremder DNA für einen solchen Gentransfer nicht ausreicht, bedarf es unterschiedlicher biologischer, chemischer und physikalischer Maßnahmen, um das Gen in die Zelle zu verbringen. Diese sollen unten dargestellt werden. Die Augmentationsmethode ist zumindest dann ausreichend, wenn es sich um Merkmale handelt, deren Vererbung rezessiv erfolgt. Die Kompensation des Defektes beziehungsweise die Etablierung der gewünschten Eigenschaften kann hier durch das einfache Einschleusen des erwünschten Gens erreicht werden.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Graumann, Die somatische Gentherapie, S. 50; Müller, Gentherapie, S. 44.

<sup>115</sup> Müller, Gentherapie, S. 46.

## b) Genersatztherapie und Genreparatur

Bei dominant vererbten Merkmalen hingegen ist es erforderlich, auf das mutierte und somit krankheitsverursachende beziehungsweise auf das unerwünschte Gen einzuwirken, um es zu reparieren, respektive zu optimieren. Entsprechende Verfahren sind jedoch schon hinsichtlich der somatischen Gentherapie weit von einer klinischen Anwendung entfernt.<sup>116</sup>

Das *gene targeting*, eine genetische Manipulation, bei der die Eigenschaft der DNA zur Durchführung einer homologen Rekombination, also einer Neuordnung des genetischen Materials aufgrund von Ähnlichkeiten in der Nukleotidsequenz, zunutze gemacht wird, könnte die Ausschaltung eines unerwünschten Gens oder gar die Substitution eines beschädigten Gens mit einem gesunden erreicht werden: Mittels der mit Blick auf die Durchführung der somatischen Genmanipulation erörterten Verfahren wird das zu blockierende Gen in die Zielzellen eingebracht. Dabei besteht jedoch die Besonderheit, dass das Gen eine Mutation aufweist, die es funktionsuntüchtig macht. Mit Implantation des Transgens wird so ebenfalls die Funktion des zellulären Gens geblockt. Relevanz erfährt dieses Verfahren insbesondere dann, wenn zu untersuchen ist, welche Funktionen das ausgeschaltete Gen erfüllt.<sup>117</sup>

## c) Regulation der Genexpression

Ebenfalls bei dominanten genetischen Merkmalen kommt die Regulation der Genexpression, das heißt auf dem Wege der Informationsübertragung zwischen DNA und Eiweißsynthese, in Betracht. So lassen sich sowohl die Transkription als auch die Translation blocken. Letzteres lässt sich etwa unter Verwendung von Anti-sense-Oligonukleotiden stoppen. Unter Oligonukleotiden versteht man einen aus 15 bis 27 Nukleotiden zusammengesetzten RNS- oder DNA-Strang. Das Präfix *anti sense* weist dabei darauf hin, dass die Basensequenz entgegengesetzt der einer normalen, funktionstüchtigen Boten-RNS ist, was die Translation blockiert, das heißt die Produktion von Proteinen und Polypeptiden unterdrückt.<sup>118</sup>

Sowohl auf DNA- als auch auf RNA-Ebene lässt sich bislang die Genexpression jedoch nicht effektiv regulieren, weil beispielsweise die Oligonukleotide rasch abgebaut werden beziehungsweise ein geeigneter integrierender Vektor, mit dessen Hilfe zuverlässig eine längerfristige Wirkung erreicht werden könnte, nicht vorliegt.<sup>119</sup> Es gibt zwar integrierende Genvektoren, die *anti sense* RNA dauerhaft pro-

<sup>116</sup> Graumann, Die somatische Gentherapie, S. 50; Müller, Gentherapie, S. 47; vergleiche auch Strachan/Read, Molekulare Humangenetik, S. 688 f.

<sup>117</sup> Graumann, Die somatische Gentherapie, S. 52; Strachan/Read, Molekulare Humangenetik, S. 643 ff.; Voss, Rechtsfragen der Keimbahntherapie, S. 48, 53.

<sup>118</sup> Graumann, Die somatische Gentherapie, S. 53 f.; Müller, Gentherapie, S. 47; Strachan/Read, Molekulare Humangenetik, S. 682 f.

<sup>119</sup> Näher hierzu Graumann, Die somatische Gentherapie, S. 53 ff.

duzieren, aber auch hier ergibt sich die Problematik der ungerichteten Integration und daher der Gefahr einer Insertionsmutagenese.

#### **d) Reaktivierung eigener Gene**

Eine weitere Möglichkeit der Manipulation der genetischen Konstitution besteht in der Reaktivierung eigener, funktionstüchtiger Gene, die jedoch während der Ontogenese, das heißt während der intrauterinen Entwicklung, abgeschaltet und deren Funktion durch andere, verwandte Gene ersetzt wurden. Somit lassen sich Krankheiten behandeln, die in einer Mutation des letzteren begründet liegen. Schon im Rahmen von therapeutischen Zwecken bestehen hier bedeutende Schwierigkeiten hinsichtlich der Steuerbarkeit sowie der geringeren Spezifität der die DNA regelnden Substanzen.<sup>120</sup>

Die Fruchtbarmachung dieser Technik für Enhancement-Maßnahmen erscheint jedoch wenig aussichtsreich. Neben soeben aufgezeigten Problemen lassen sich hierdurch auch keinerlei neue genetische Charakteristika manifestieren; es lassen sich ausschließlich Gene ab- und deren Vorgänger anschalten.

#### **e) Genmanipulation an Stammzellen**

Bei Stammzellen handelt es sich um Vorläuferzellen, die sich zu differenzierten Zelltypen, aus denen etwa die verschiedenen Gewebe bestehen, entwickeln können. Allgemein unterscheidet man zwischen toti-, pluri-, multi- und unipotenten Stammzellen.<sup>121</sup>

Der extrem frühe Embryo besteht aus exakt gleichen totipotenten Stammzellen. Diese können sowohl in die innere Zellmasse der Blastozyste, aus der die pluripotenten Stammzellen abgeleitet werden, als auch in das extraembryonale Gewebe, also Teile der Plazenta, differenzieren, weswegen sie alleine in der Lage sind, einen neuen Organismus hervorzubringen. *In vitro* können sie nur begrenzt weiterkultiviert werden; bereits nach einigen Teilungen tritt die beschriebene Spezifizierung ein. Dennoch sind sie etwa dann in der Lage, sich undifferenziert zu teilen, wenn ein Embryo im sehr frühen Stadium, wenn er beispielsweise aus circa 16 Zellen besteht, gesplittet wird. Die Zellen teilen sich sodann schlicht ein weiteres Mal, beginnen dann jedoch ebenfalls, sich zu differenzieren.

Pluripotente Stammzellen sind aus der Blastozyste gewonnen und können sämtliche Zellen der 200 unterschiedlichen Gewebearten erzeugen, die im Organismus vorkommen. Hieraus werden embryonale Stammzellen abgeleitet und hieraus entsteht der eigentliche Fötus. Multipotente Stammzellen, wie neurale Stammzellen, oder Blutstammzellen, können in verschiedene, aber nicht alle Zielzellen differenzieren.

---

<sup>120</sup> Müller, Gentherapie, S. 48.

<sup>121</sup> Lexikon der Biologie, Band 13, Eintrag „Stammzellen“.

Unipotente Stammzellen schließlich, beispielsweise im Hoden des Mannes, können nur in einen Zelltyp – im Beispiel können spermatogonale Stammzellen ausschließlich Spermien produzieren – differenzieren.

Allen Stammzellen ist gemein, dass sie sich differenzieren sowie gleichermaßen weiterteilen können. Im erwachsenen Organismus kommen nach aktuellem Erkenntnisstand jedoch nur die beiden letzten Typen vor. Die sich im Knochenmark befindlichen adulten Stammzellen weisen weiterhin Pluripotenz auf, im Übrigen sind sie für die Erneuerung der jeweiligen spezifischen Gewebe zuständig.

In den vergangenen Jahren wurden Methoden entwickelt, mit denen Stammzellen *in vitro* vermehrt werden können. Bei der Stammzelltherapie werden so vermehrte Stammzellen auf den Patienten übertragen, wo sie geschädigte oder zerstörte Zellen ersetzen sollen. Diese werden zuvor aber nicht genetisch verändert, weswegen Stammzelltherapie und Gentherapie zunächst einmal keine gemeinsame Schnittmenge haben. Es wäre jedoch denkbar, dem Patienten entnommene Stammzellen *in vitro* mit den gewünschten Merkmalen auszustatten und sie dann auf den Patienten zurück zu übertragen.<sup>122</sup>

### 3. Die Durchführung des Gentransfers

Im Rahmen der soeben beschriebenen Methoden stellt sich sodann die Frage, wie die Gene in die Zellen gelangen. Das Vorgehen kann in zweifacher Hinsicht grob untergliedert werden: Zum einen kann anhand des Ortes, an dem der Gentransfer erfolgt, also ob er *in vitro* oder *in vivo* vorgenommen wird, unterschieden werden, zum anderen nach der Art der verwendeten Vektoren, also der Vehikel, die das Gen tragen. Hierbei kann es sich um virale oder nicht-virale Vektoren handeln.

#### a) *in vitro* und *in vivo*

Wird der Gentransfer *in vivo* vorgenommen, so werden die Gene direkt in den Körper des Patienten injiziert. Im Übrigen werden dem Patienten zunächst die abzuändernden Zellen entnommen. Das jeweilige Gen wird sodann in diese Zellen eingeschleust, die anschließend in der Kulturschale vermehrt und auf den Patienten zurück übertragen werden.<sup>123</sup>

Auswirkung hat diese Differenzierung insbesondere im Hinblick auf die Anforderungen, die an die Sicherheit der für den Gentransfer zur Wahl stehenden verschiedenen Methoden und Werkzeuge zu stellen sind. Diese müssen, sofern sie unmittelbar auf den Patienten einwirken, da sie *in vivo* angewendet werden, hohen

<sup>122</sup> Müller, Gentherapie, S. 48 f.

<sup>123</sup> Voss, Rechtsfragen der Keimbahntherapie, S. 45; Wagner, Der gentechnische Eingriff in die menschliche Keimbahn, S. 25; Zoglauer, Konstruiertes Leben, S. 97.



Standards gerecht werden.<sup>124</sup> Die oben geschilderte Gefahr von Infektionen aufgrund der verwendeten viralen Vektoren, von Nebenwirkungen oder aufgrund der bisherigen Unkontrollierbarkeit der Genexpression gilt es zu minimieren. Erhöht werden muss hingegen die Effizienz der beschriebenen Methoden, um die Belastung des Patienten so gering wie möglich zu halten.

In der Forschung wird grundsätzlich eine *in vivo* Verabreichung des Genvektors angestrebt. Dies bietet bedeutende Vorteile: Bei der *in vitro* erfolgenden Manipulation kann im Gegensatz zu der *in vivo* durchgeführten nur eine verhältnismäßig geringe Anzahl von Zellen erreicht werden, nämlich die, die zuvor dem Patienten entnommen worden sind. Mit Ausnahme des Blutes sind die meisten Körperzellen zudem nicht einfach verfügbar. Auch dieses Problem würde durch eine *in vivo* erfolgende Manipulation umgangen werden. Allerdings werden die zur *in vivo*-Behandlung applizierten Vektoren rasch in ihrer Konzentration vom Blut verdünnt und gelangen hierüber auch mit Zellarten in Berührung, die nicht erkrankt sind beziehungsweise nicht modifiziert werden sollen. Zentrale Aufgabe der Forschung ist daher, die Spezifität sowie die Effizienz der Vektoren zu erhöhen.<sup>125</sup>

## b) Die Werkzeuge des Gentransfers

Welcher Vektor, das heißt welche Genfähre für den Transport des Gens in die zu modifizierenden Zellen für die jeweils in Frage stehende Maßnahme der optimale ist, lässt sich anhand dessen beurteilen, welche der folgenden Kriterien erfüllt werden:<sup>126</sup>

- Ausreichende Effizienz: Erreicht das gewünschte Gen genügend viele Zielzellen?
- Hohe Selektivität: Werden von dem Vektor ausschließlich die beabsichtigten Zellen modifiziert?
- Hohe Sicherheit: Wie groß ist das Risiko von Infektionen oder Nebenwirkungen, die durch den Vektor ausgelöst werden können?
- Besteht die Möglichkeit, das Gen auf Zellen zu transferieren, die sich nicht teilen beziehungsweise eine nur geringe Teilungsaktivität aufweisen?
- Ist die Gen-Aufnahmekapazität des Vektors ausreichend; wie viele Gene können mit dem jeweiligen Vektor transferiert werden?
- Kann eine dauerhafte Genexpression erreicht werden, das heißt ist die Modifizierung der Zielzellen eine ausreichend lange?

### aa) Transfektion

Bei der Transfektion handelt es sich um ein physikalisches und chemisches Verfahren der Einbringung der Gene in die Zielzellen. Hierzu gehört zum Beispiel die Ver-

<sup>124</sup> Vergleiche auch Hallek/Winnacker/Bröcker, Gentherapie, S. 12.

<sup>125</sup> DFG, Entwicklung der Gentherapie, S. 11.

<sup>126</sup> Hallek/Winnacker/Bröcker, Gentherapie, S. 12.



wendung einer Heliumgas-Pistole, der sogenannten *gene gun*, mit der unter hohem Druck sich an Projektilen aus Wolfram- oder Goldpartikeln befindliche DNA-Partikel mehrere Zellschichten tief in epitheliale<sup>127</sup> Gewebe verbracht werden können.<sup>128</sup> Dieses Verfahren gilt als relativ einfach und sicher. Allerdings ist es aufgrund der geringen Integration wenig effizient und für die klinische Anwendung daher von nur nachrangigem Interesse.<sup>129</sup>

Verwendung finden des Weiteren kationische Liposomen, also Membranbläschen, die positiv geladene Ionen aufweisen, sowie Proteine, die DNA zu binden vermögen. Auch kann nackte oder vektorfreie DNA intramuskulär injiziert werden.<sup>130</sup>

Ausschließlich für die *in vitro* erfolgende Manipulation eignet sich die Elektroporation. Diese stellt ein Verfahren dar, mittels dessen die Zellmembran der behandelten Zellen durch ein elektrisches Feld permeabilisiert, also durchlässig gemacht wird.<sup>131</sup>

Eine sehr hohe Transfektionseffizienz von nahezu 100 % ermöglicht die intrazelluläre Mikroinjektion von DNA in den Zellkern oder das Cytoplasma der Zelle, bei der die Zellmembran auf direktem und mechanischem Wege überwunden wird. Sie ist jedoch apparativ und manipulativ sehr aufwändig, sodass nur relativ wenige Zellen transfiziert werden können.<sup>132</sup>

## bb) Transduktion

Als Transduktion wird der Gentransfer mittels viraler Vektoren bezeichnet. Ein Großteil der klinischen Gentherapie-Studien verwendet diese Methode, wobei sie sich der natürlichen Eigenschaft von Viren, das eigene Erbmateriale in die Wirtszellen einzuschleusen, bedienen.<sup>133</sup> Zur Herstellung des Vektors werden aus dem Gen-Repertoire des Virus diejenigen Gene entfernt oder zerstört, die die Vermehrung des Virus steuern. In die so entstehende Lücke wird das zu transferierende Gen eingefügt. Dieses rekombinante Virus wird zum Gentransfer verwendet.<sup>134</sup>

Am häufigsten werden hierzu Retroviren genutzt. Sie bieten den Vorteil, dass sie eine zum Teil hohe Transfektionseffizienz aufweisen und eine stabile Integration des Transgens in die Zielzelle und somit eine dauerhafte Genexpression gewährleis-

<sup>127</sup> „Epithel“ ist eine Sammelbezeichnung von Deck- und Drüsengeweben und stellt neben Muskel-, Nerven- und Bindegewebe eine der vier Grundgewebearten dar.

<sup>128</sup> Singer/Berg, Gene und Genome, S. 286 f.

<sup>129</sup> Graumann, Die somatische Gentherapie, S. 69.

<sup>130</sup> Rochlitz, Gentherapeutische Ansätze bei Krebserkrankungen, S. 62; ausführlich zu der rezeptorvermittelten Endozytose, also die Verbringung eines Gen unter Zuhilfenahme eines Proteins, sowie dem liposomalen Gentransfer Graumann, Die somatische Gentherapie, S. 69 ff.

<sup>131</sup> Im Rahmen des *gene targeting* erörtert Strachan/Read, Molekulare Humangenetik, S. 644 diese Technik.

<sup>132</sup> Regenass-Klotz, Grundzüge der Gentechnik, S. 88 f.; Singer/Berg, Gene und Genome, S. 286; Strachan/Read, Molekulare Humangenetik, S. 637 ff.

<sup>133</sup> Hallek/Winnacker/Bröcker, Gentherapie, S. 13; Wagner, Der gentechnische Eingriff in die menschliche Keimbahn, S. 25 f.

<sup>134</sup> Hallek/Winnacker/Bröcker, Gentherapie, S. 13.

ten. Allerdings bestehen bedeutende Nachteile darin, dass nur sich teilende Zellen transfizierbar sind und die Integration bislang nicht kontrolliert werden kann, weswegen ein erhebliches karzinogenes Risiko besteht. Auch ist eine Rekombination des zunächst vermehrungsunfähigen Vektors mit körpereigenen Viren oder viraler DNS und somit die Entstehung vermehrungsfähiger Viren *in vivo* möglich. Schließlich ist – im Gegensatz zu nicht-viralen Vektoren, aber ebenso wie bei sämtlichen viralen Vehikeln – die Kapazität der Genfahre begrenzt: In einem Retrovirus lassen sich zwischen 7.500 und 10.000 Basenpaare verpacken.<sup>135</sup>

Neben Retroviren werden zu Zwecken der Transduktion häufig die für Erkrankungen der Atemwege verantwortlichen Adenoviren verwendet. Auch ihre Effizienz wird als hoch beschrieben, ohne dass sie jedoch gravierende Nebenwirkungen hätten. Entsprechendes belegen die Erfahrungen, die mit Impfungen unter Verwendung von Adenoviren gemacht wurden. Weiterhin gilt als positiv, dass sie ein breites Wirtsspektrum aufweisen, das heißt nicht nur replizierende, sondern auch ruhende und ausdifferenzierte Zellen transfizierbar sind. Die Kapazität eines adeno-viralen Vektors liegt bei etwa 7.500 Basenpaaren. Problematisch ist hingegen, dass eine Integration in das Genom der Wirtszelle nicht erfolgt. Zellteilungen führen daher zum Verlust der genetischen Information. Kritisch ist zudem die Immunogenität der Adenoviren, das heißt die Eigenschaft, eine Immunantwort, eine Reaktion des Immunsystems, auszulösen, die zumindest eine wiederholte Applikation schwierig macht. Eine solche wäre jedoch aufgrund der nur vorläufigen Genexpression zu-meist erforderlich.<sup>136</sup>

Verwendung finden darüber hinaus auch Herpesviren und adeno-assoziierte Viren (AAV), die von den Adenoviren, die als Helferviren dem AAV das Proliferationsgen, das heißt die für Wachstum und Vermehrung essentiellen Informationen, liefern. AAV sind zwar nicht mit Krankheiten assoziiert, stellen aber aufgrund ihres kleinen Genoms, woraus eine geringe Kapazität von weniger als 5.000 Basenpaaren folgt, ebenfalls keinen optimalen Vektor dar.<sup>137</sup>

Um Sicherheitsrisiken zu schließen, aber eine größtmögliche Effizienz zu erzielen, wird die Herstellung von sogenannten *gut-less vectors*, von Vektoren, die nur noch einen minimalen Rest des ursprünglichen Virus beinhalten, oder von vollständig artifiziellen viralen Vektoren angestrebt.<sup>138</sup>

<sup>135</sup> Sehr ausführlich dazu *Graumann*, Die somatische Gentherapie, S. 58 ff.; *Hallek/Winnacker/Bröcker*, Gentherapie, S. 13; *Rochlitz*, Gentherapeutische Ansätze bei Krebserkrankungen, S. 61.

<sup>136</sup> Sehr ausführlich dazu *Graumann*, Die somatische Gentherapie, S. 62 ff.; *Hallek/Winnacker/Bröcker*, Gentherapie, S. 13; *Rochlitz*, Gentherapeutische Ansätze bei Krebserkrankungen, S. 61 f.

<sup>137</sup> *Hallek/Winnacker/Bröcker*, Gentherapie, S. 13; *Rochlitz*, Gentherapeutische Ansätze bei Krebserkrankungen, S. 62.

<sup>138</sup> *Rochlitz*, Gentherapeutische Ansätze bei Krebserkrankungen, S. 62.

### III. Die Keimbahnmanipulation

Genetische Manipulationen können darüber hinaus auch an der Keimbahn ansetzen. Keimbahninterventionen sind somit Eingriffe, „durch die das Genom, d. h. die Gesamtheit aller Gene eines Organismus, in den Keimbahnzellen (Spermien oder Eizellen) in irgendeiner Weise gezielt unter Anwendung gentechnologischer Verfahren verändert wird.“<sup>139</sup>

#### 1. Die Keimbahn

Als Keimbahn wird die Weitergabe der genetischen Informationen, die an die Nachkommen vererbt werden sollen, bezeichnet. Die hieran beteiligten Zellen nennt man Keimbahnzellen. § 8 III ESchG zufolge sind hierunter „alle Zellen“ zu verstehen, „die in einer Zell-Linie von der befruchteten Eizelle bis zu den Ei- und Samenzellen des aus ihr hervorgegangenen Menschen führen, ferner die Eizelle vom Einbringen oder Eindringen der Samenzelle an bis zu der mit der Kernverschmelzung abgeschlossenen Befruchtung.“ Aus der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle entsteht die eine Urzelle des Kindes, die sogenannte Zygote<sup>140</sup>. Diese beginnt sich sodann zu teilen, wobei sich die Zellen differenzieren, das heißt spezialisieren, und so die verschiedenen Gewebe und Organe des wachsenden Individuums, aber auch dessen Geschlechtsorgane formen. In diesen werden wiederum einige Zellen abgesondert. Sie stellen die Gametozyten dar, die sich unter Halbierung des Chromosomensatzes wiederum teilen und zum Ursprung aller Gameten, also aller Geschlechtszellen des Kindes werden. Diese Reihenfolge „Gametozyten – Gameten – Zygote“ stellt die Keimbahn dar.<sup>141</sup>

Im Unterschied zu den Körperzellen beeinflussen die Keimbahnzellen die genetische Disposition der nachfolgenden Generationen und können generative, das heißt ein neues Individuum hervorbringende Funktion haben. Somazellen hingegen haben vegetative Funktion, sind also an Aufbau und Funktion der Organe beteiligt. Daraus ergeben sich für die Manipulation der jeweiligen Zellen bedeutende Unterschiede. Wird in die Keimbahn eingegriffen, so ist von der vollzogenen Änderung der gesamte Organismus betroffen. Hingegen bezieht sich die Modifizierung von somatischen Zellen lediglich auf den manipulierten Zelltyp als nur einen Teil des Organismus. Auch in zeitlicher Hinsicht sind die Auswirkungen häufig begrenzt, sodass die Maßnahmen zumeist wiederholt angewendet werden müssen. Während außerdem Keimbahnmanipulationen sämtliche Nachfolgenerationen des Indi-

<sup>139</sup> *Ibelgaufts/Winnacker*, Lexikon der Bioethik, Band 2, Eintrag „Keimbahnintervention“, S. 349.

<sup>140</sup> Bei der Zygote handelt es sich um das Resultat der Verschmelzung zweier haploider Zellen, das heißt also der Befruchtung. Ein weiteres Verständnis des Begriffs „Zygote“ umfasst jedoch auch den aufgrund der ersten bereits stattgefundenen Zellteilungen aus einer geringen Anzahl von Zellen bestehenden Embryo.

<sup>141</sup> *Rehmann-Sutter*, Keimbahnveränderungen in Nebenfolge?, S. 190.

viduums, an dem die Modifizierung ursprünglich durchgeführt wurde, betreffen, bleibt die Wirkung einer genetischen Veränderung von Somazellen auf das jeweilige, lebende Individuum begrenzt. Die Auswirkung von Keimbahnmanipulationen manifestiert sich hingegen erst im Organismus der nachfolgenden Generation.<sup>142</sup>

## ***2. Status quo und bestehender Forschungsbedarf***

Bislang wurden Keimbahnmanipulationen ausschließlich an Tieren, hier insbesondere an Mäusen, vorgenommen. Zwar ist durch die Verfügbarkeit der Eizelle sowie die Möglichkeit der In-vitro-Fertilisation und artifiziellen Veränderung der genetischen Struktur von Zellen auch eine Keimbahnmanipulation beim Menschen denkbar geworden. Die Erkenntnisse, die im Rahmen von Experimenten an beispielsweise Mäusen erlangt wurden, lassen sich auch grundsätzlich auf den Menschen übertragen. Jedoch bestehen weiterhin technische Probleme, etwa hinsichtlich der Integration des transferierten Gens am exakten Genlokus, der Stabilität der Genexpression oder des Krebsrisikos. Diese sind aber keinesfalls spezifische Probleme der Keimbahnmanipulation, sondern treten ebenfalls im Rahmen der Modifizierung somatischer Zellen auf.<sup>143</sup> Diesbezüglich sei auf die entsprechenden Ausführungen der vorliegenden Arbeit verwiesen.

Besonderheiten bestehen bei der Keimbahnmanipulation vor dem Hintergrund, dass die Unsicherheiten und Gefahren sich nicht auf das von dem Eingriff unmittelbar betroffene Individuum beschränken. In die Abwägung zwischen Risiko und Nutzen von Keimbahneingriffen muss einfließen, dass die vorgenommenen Veränderungen nicht nur ein noch zu zeugendes Individuum beziehungsweise die Person, die sich aus dem frühen Embryo, an dem der Eingriff vorgenommen wurde, entwickelt, beschränkt. Vielmehr sind davon auch alle nachfolgenden Generationen betroffen. Inwiefern die sich dort entfaltende Wirkung aber möglicherweise von der intendierten abweicht, vermag heute noch niemand zu sagen.<sup>144</sup>

Durch Keimbahnmanipulation wurden bisher somit ausschließlich sogenannte transgene<sup>145</sup> Tiere erzeugt oder Gene bei Tieren verändert oder gelöscht (siehe unten). Die erste erfolgreiche genetische Manipulation stellte die Einschleusung von Wachstumshormonen in befruchtete Eizellen kleinwüchsiger Mäuse dar, die dadurch verstärktes Körperwachstum zeigten. In der Folge gelang es Forschern, sogenannte Tiermodelle menschlicher Krankheiten zu generieren, um diese zu stu-

<sup>142</sup> *Ibelgauf/Winnacker*, Lexikon der Bioethik, Band 2, Eintrag „Keimbahnintervention“, S. 349; *Rehmann-Sutter*, Keimbahnveränderung in Nebenfolge?, S. 91.

<sup>143</sup> *Voss*, Rechtsfragen der Keimbahntherapie, S. 54 ff.

<sup>144</sup> *Zimmerman*, *The Journal of Medicine and Philosophy* 1991 (16), 593 (599).

<sup>145</sup> *Ibelgauf/Winnacker*, Lexikon der Bioethik, Band 2, Eintrag „Keimbahnintervention“, S. 349: Unter transgenen Organismen versteht man Tiere oder Pflanzen, in deren Zellen Gene aus einem anderen Organismus eingebracht wurden. Dieses fremde Gen wird als Transgen bezeichnet, das Erbmaterial der so veränderten Zelle als Transgenom.

dieren und Therapien entwickeln zu können.<sup>146</sup> So wurden in Ratten, Schweinen, Kühen, Ziegen und Schafen Modelle der Cystischen Fibrose, der Bluterkrankheit, des Zwergwuchses, von Krebs und Arteriosklerose produziert.<sup>147</sup> Unter der Internetadresse <http://www.jax.org> stößt man gar auf eine Art Versandhaus für Mausmodelle des Jackson Laboratory mit Sitz in Bar Harbor, Maine, USA und Sacramento, Kalifornien, USA.

### 3. *Knock-In und Knock-Out*

Die Begriffe „*Knock-In*“ und „*Knock-Out*“ bezeichnen zwei unterschiedliche Methoden zur Erzeugung gentechnisch veränderter Lebewesen.

Beim *Knock-In* werden nicht funktionstüchtige, weil mutierte, oder unerwünschte DNA-Bereiche ausgetauscht. Zu diesem Zweck werden die Zielzellen derart manipuliert, dass ihre genregulatorischen Bereiche genutzt werden, um die Expression eines anderen Gens zu steuern. Die Funktion des ursprünglichen Gens, aus dem die genregulatorischen Bereiche stammen, wird dabei deaktiviert. Dieses Verfahren wird insbesondere dann relevant, wenn untersucht werden soll, ob das substituierende Gen die Funktionen des ausgeschalteten zu übernehmen vermag.<sup>148</sup>

Bei dem *Knock-Out*-Verfahren handelt es sich um eine Methode, bei der ein oder mehrere Gene deaktiviert werden. Dies geschieht mittels des sogenannten und bereits oben erläuterten *gene targeting*.

### 4. *Eingriffsobjekte der Keimbahnmanipulation*

Für die Vornahme von genetischen Veränderungen kommen unterschiedliche Eingriffsobjekte, mithin unterschiedliche Zeitpunkte für die Durchführung in Betracht. Grundsätzlich wird hierbei unterschieden zwischen prä- und postkonzeptionellen Eingriffen, also danach, ob sie vor oder nach der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle ansetzen.<sup>149</sup>

#### a) *Keimbahneingriffe an Gameten*

Als eine im präkonzeptionellen Stadium eingreifende Maßnahme könnte versucht werden, die in männlichen Keimzellen vorhandenen genetischen Informationen abzuändern. Die Spermien könnten so einfach als natürliches Vehikel für den Gen-

<sup>146</sup> Ein kurzer Überblick über die Vorzüge bestimmter Tiere bei der Herstellung von diversen Modellen menschlicher Krankheiten findet sich bei *Strachan/Read*, Molekulare Humangenetik, S. 652.

<sup>147</sup> *Voss*, Rechtsfragen der Keimbahntherapie, S. 47.

<sup>148</sup> *Ibelgauf/Winnacker*, Lexikon der Bioethik, Band 2, Eintrag „Keimbahnintervention“, S. 350.

<sup>149</sup> *Wagner*, Der gentechnische Eingriff in die menschliche Keimbahn, S. 31 f.

transfer dienen. Da die Befruchtung einer Eizelle mit dem genetisch manipulierten Spermium *in vitro* durchgeführt werden kann, lässt sich der Transfer gezielt einsetzen.<sup>150</sup> Während lange Zeit diese Methode jedoch kaum praktikabel erschien,<sup>151</sup> rückte sie mit den im Jahre 1994 erlangten Forschungsergebnissen *Ralph Brinsters et al.* in den Bereich des Möglichen. Ihm war gelungen, männliche Keimbahnzellen einer männlichen Maus auf eine sterile Maus zu transferieren, bei der sodann eine normale Spermatogenese, also eine normale Produktion von Spermien einsetzte. Würde man zuvor die zu transferierenden Keimbahnzellen genetisch modifizieren, so läge eine Modifizierung der Keimbahn vor, die zur Folge hätte, dass sodann Spermien mit entsprechend veränderter Erbinformation produziert werden würden.<sup>152</sup>

Häufiger als männliche Samenzellen werden zur Züchtung transgener Tiere jedoch weibliche Eizellen genutzt, da diese größer und der Umgang mit ihnen somit leichter ist. Nach Einbringung der gewünschten DNA in den Kern der Eizelle erfolgen die In-vitro-Fertilisation sowie die Transplantation in die Gebärmutter des Muttertieres.<sup>153</sup>

## b) Keimbahneingriffe an der Zygote

Neben den Geschlechtszellen kommt auch die Zygote, also die aus der Verschmelzung der Geschlechtszellen entstehende Zelle beziehungsweise, einem weiteren Begriffsverständnis entsprechend, der nach den ersten Zellteilungen aus einigen wenigen Zellen bestehende Embryo, als Objekt eines postkonzeptionellen Keimbahneingriffes in Betracht. Mittels einer mit fremder DNA gefüllten, mikroskopisch kleinen Injektionsnadel wird die Membran durchbohrt und das Zytoplasma durchdrungen, um die fremde DNA unmittelbar in den männlichen Vorkern der Zygote zu injizieren (Mikroinjektion). Schwierigkeiten bereitet jedoch der Umstand, dass nur weniger als die Hälfte der so behandelten Embryonen die Fremd-DNA auch tatsächlich in ihre Chromosomen einbaut und diese so bereits in frühen Stadien der Embryonalentwicklung wieder verschwindet. Dies ist zurückzuführen auf die nur zufällige Integration in das Chromosom. Geschieht dies nicht am korrekten Genloкус, so kann sich das Gen nicht nur nicht exprimieren und daher nicht seine Funktion erfüllen, es bestehen darüber hinaus auch die (oben erläuterten) Gefahren der Tumorbildung durch Aktivierung von Onkogenen oder Störung von Tumorsuppressor-Genen sowie der Störung der Funktion eines anderen zellulären Gens.<sup>154</sup>

Um diese Probleme zu beseitigen, insbesondere um eine dauerhafte Genexpression zu erreichen und diese kontrollieren zu können, sind Bemühungen zu verzeichnen, die auf die Verwendung künstlicher Chromosomen anstelle von „nackten“ Ge-

<sup>150</sup> Voss, Rechtsfragen der Keimbahntherapie, S. 48 f.

<sup>151</sup> So etwa Zimmerman, The Journal of Medicine and Philosophy 1991 (16), 593 (595).

<sup>152</sup> Walters/Palmer, The Ethics of Human Gene Therapy, S. 61 f.

<sup>153</sup> Voss, Rechtsfragen der Keimbahntherapie, S. 49.

<sup>154</sup> Voss, Rechtsfragen der Keimbahntherapie, S. 49 f.

nen gerichtet sind. Dazu werden Sequenzen der Telomeren<sup>155</sup> und Zentromeren<sup>156</sup> aus natürlichen Chromosomen isoliert, vermehrt und neu kombiniert. Das Produkt wird in Zellen verbracht, die daraufhin spontan ein neues Chromosom bilden, welches bei der Zellteilung auch an die Tochterzellen weitergegeben wird, das heißt mitotisch stabil ist. Vorteil dieser Methode wäre, dass sie den Gentransfer nicht auf ein einzelnes Gen beschränkt, sondern es erlaubt, ein ganzes Paket zu transferieren. Allerdings ermöglicht dieses Verfahren wiederum nur eine Addition, keinesfalls aber die Substitution von unerwünschten Genen. Diese kann hingegen mittels der im Folgenden zu erörternden Technik erreicht werden.<sup>157</sup>

### c) Keimbahneingriffe an embryonalen Stammzellen

Schließlich ist es auch möglich, embryonale Stammzellen zu verändern und so Knock-Out-Lebewesen herzustellen. Dies geschieht zunächst unter Verwendung des oben erläuterten Knock-Out-Verfahrens. Zwar findet ein erfolgreicher Austausch von natürlichem und künstlich zugefügtem Genabschnitt nur in einer verschwindend geringen Anzahl behandelter Zellen statt, jedoch bietet dieses Verfahren einen bedeutenden Vorteil: Die Zellen können vor ihrer Weiterverwendung darauf untersucht werden, ob die neue Erbinformation am korrekten Locus integriert wurde und dort den gewünschten Bereich substituiert hat. Ist dies gelungen, so können die Zellen in die Blastozyste einer Pflegemutter injiziert werden, wo sie sich in alle Zellen, auch solche der Keimbahn, entwickeln können. Die Nachkommen des so modifizierten Lebewesens werden bei Paarung mit einem normalen, nicht derart manipulierten Lebewesen in einer der zwei Genkopien in jeder Zelle die Mutation aufweisen, das heißt sie werden heterozygot für diese Mutation sein. Bei Paarung zweier dieser heterozygoten Lebewesen werden sodann in zweiter Generation homozygote Lebewesen gezeugt.<sup>158</sup>

<sup>155</sup> Bei Telomeren (griechisch τέλος *télos*: „Ende“ und μέρος *méros*: „Teil“) handelt es sich um die Enden von Chromosomen. Bei jeder Zellteilung verkürzen sie sich, sodass man von ihrer Länge auf das Alter der Zelllinie schließen kann. Ist die Länge so bis zu einem gewissen kritischen Maß reduziert worden, unterbleibt in der Folge die Zellteilung und es tritt der Zelltod ein.

<sup>156</sup> Das Zentromer (griechisch κέντρον *kéntron*: „Mittelpunkt“; und μέρος *méros*: „Teil“) ist das Verbindungsstück, welches die beiden Chromatiden zu einem Chromosom zusammenfügt.

<sup>157</sup> Vergleiche Voss, Rechtsfragen der Keimbahntherapie, S. 50 ff.

<sup>158</sup> Voss, Rechtsfragen der Keimbahntherapie, S. 53 f.



# Kapitel 4: Historische Grundlagen

Im Zusammenhang mit Enhancement wird häufig auch das Thema der Eugenik angesprochen. Eindeutig wird diese Verknüpfung beispielsweise, wenn anstelle des Begriffes „Enhancement“ der Terminus „Positive Eugenik“ verwendet wird. Damit verbunden ist jedoch stets ein Ressentiment, ein Unbehagen, das auf der Erinnerung an die deutsche Vergangenheit beruht, die von Kritikern des Enhancements gerne bemüht wird und so wie ein Schatten über der Enhancement-Debatte liegt. Daher soll in diesem Kapitel ein kurzer Überblick über die Geschichte der Verbesserung des Menschen beziehungsweise der Menschheit vermittelt werden, der jedoch keinesfalls den Anspruch der Vollständigkeit erhebt. Insbesondere soll sich dieser Überblick nicht nur auf die Geschehnisse im Nationalsozialismus beschränken, sondern auch internationale Entwicklungen berücksichtigen, wobei, obschon auch zahlreiche skandinavische Staaten<sup>159</sup> in den Anfängen des 20. Jahrhunderts eugenische Sterilisationsgesetze erließen, beispielhaft die USA und Singapur dienen sollen. Darüber hinaus sollen auch Unterschiede zwischen den damaligen staatlichen Eugenik-Programmen und den heute diskutierten Enhancement-Maßnahmen aufgezeigt werden.

## I. Der Eugenik-Begriff

Als Eugenik oder Eugenetik (griechisch *eũ*: gut, schön, wohl; griechisch *génesis*: Zeugung, Schöpfung, Entstehung) wird das Vorhaben bezeichnet, die genetische Ausstattung der Menschheit zu verbessern. Der Begriff wurde maßgeblich im Jahre 1883 durch *Sir Francis Galton*, einen Cousin *Charles Darwins*, im Rahmen seiner statistischen Untersuchungen zu der genetischen Vererbung geprägt.<sup>160</sup> Er war der Überzeugung, dass Talente und Charakter den Regeln der Vererbung unterliegen

---

<sup>159</sup> Siehe hierzu beispielsweise *Broberg/Roll-Hansen*, *Eugenics and the Welfare State* sowie *Kuhlmann*, *Politik des Lebens – Politik des Sterbens*, S. 51 ff.

<sup>160</sup> *Sandel*, *The Case against Perfection*, S. 63.



und ging daher davon aus, dass es durch die sorgfältige Auswahl des Partners über mehrere, aufeinander folgende Generationen möglich sei, eine menschliche Rasse zu erschaffen, die sich durch besondere Fähigkeiten und Begabungen auszeichnet.<sup>161</sup> „*What Nature does blindly, slowly, and ruthlessly, man may do providently, quickly, and kindly. As it lies within his power, so it becomes his duty to work in that direction [...]*“.<sup>162</sup> Entsprechend rief er die gebildeten Bevölkerungsschichten dazu auf, sich bei ihrer Partnerwahl an eugenischen Zielen zu orientieren. So widerspricht er dem Einwand einiger Eugenik-Kritiker, die menschliche Natur würde niemals einen Eingriff in die Freiheit der Eheschließung (und damit der Freiheit der Fortpflanzung) dulden.<sup>163</sup>

## II. Eugenische Entwicklungen in Amerika

In Amerika fand dieser Ansatz große Zustimmung. Im Jahre 1910 gründete *Charles B. Davenport* das *Eugenic Records Office* in Cold Spring Harbor, Long Island, dessen Aufgabe es war, Daten über den genetischen Hintergrund von Personen mit geistigen Behinderungen zu sammeln. Den eugenischen Bestrebungen zufolge sollten diese Daten dazu dienen, die Fortpflanzung der *genetically unfit* zu unterbinden. Prominente Unterstützung fanden diese Bemühungen unter anderem in der Carnegie Institution, *John D. Rockefeller* und *Theodore Roosevelt*.<sup>164</sup> Letzterer schrieb an *Davenport*: „*Some day, we will realize that the prime duty, the inescapable duty, of the good citizen of the right type, is to leave his or her blood behind him in the world; and that we have no business to permit the perpetuation of citizens of the wrong type.*“<sup>165</sup> Die Feministin und Befürworterin von Familienplanung *Margaret Sanger* sah es als vornehmsten Zweck der Geburtenkontrolle an, dass intellektuell oder anderweitig benachteiligte Personen weniger Kinder bekommen. Mittels Empfängnisverhütung und Schwangerschaftsabbruch sollte der „*degenerierte[n] soziale[n] Ballast*“, der Niedergang der Bevölkerung verhindert werden.<sup>166</sup>

Das US-amerikanische Eugenik-Programm setzte mit Blick auf die Bevölkerung auf Wettbewerb und Aufklärung: Auf Volksfesten wurden Wettbewerbe („*Fitter Families contests*“) abgehalten, in denen die gesündesten Familien gekürt wurden. Hierzu wurden sie nicht nur auf ihre medizinische und psychologische Konstitution untersucht, sondern es wurde auch ihre Intelligenz getestet. Unter der Rubrik „*human stock*“ wurden beispielsweise auf dem *Kansas Free Fair* im Jahre 1924 unter den teilnehmenden Familien in drei Kategorien – klein, durchschnittlich, groß – diejenigen gekürt, die „*Grade A Individuals*“ hervorbrachten. Weil Gesundheit

<sup>161</sup> Galton, *Hereditary Genius*, S. 1.

<sup>162</sup> Galton, *Essays in Eugenics*, S. 42.

<sup>163</sup> Galton, *Essays in Eugenics*, S. 44.

<sup>164</sup> Sandel, *The Case against Perfection*, S. 64.

<sup>165</sup> Zitiert nach Black, *War against the Weak*, S. 99.

<sup>166</sup> Black, *War against the Weak*, S. 125–144; Kuhlmann, *Politik des Lebens – Politik des Sterbens*, S. 43.

auch Wohlstand bedeute und ein gesunder Geist in einem gesunden Körper das wertvollste aller menschlichen Besitztümer sei, sei die diesen Familien verliehene Medaille mehr wert als große Viehherden oder eine Ölquelle.<sup>167</sup>

Im Jahre 1920 wurde an 350 der amerikanischen Hochschulen Eugenik unterrichtet, wodurch die Studenten ihre reproduktive Verantwortung vor Augen gehalten werden sollte. Erforderlich, so war man überzeugt, war dies dadurch geworden, dass intelligente Frauen, die eine höhere Bildung anstrebten, angeblich weniger häufig heirateten und durchschnittlich lediglich zwei Kinder gebären, was lediglich die Hälfte der Kinder war, die Frauen niedrigeren Bildungsstandards bekamen. Die Eugenics Education Society sprach davon, dass die besten Frauen ihre natürlichen und ehrenvollsten Pflichten zu erfüllen verweigerten.<sup>168</sup>

Die eugenischen Bestrebungen wurden 1907 in Gesetzesform gegossen: In Indiana trat erstmals ein Gesetz in Kraft, das Zwangssterilisierungen bei psychisch kranken Personen, Gefängnisinsassen und den Armen vorsah. In 28 weiteren Staaten wurden in der Folgezeit entsprechende Gesetze erlassen. Diese führten zu der Sterilisation von 60.000 genetisch defizienten Personen.<sup>169</sup>

Im Jahre 1927 bestätigte der United States Supreme Court im Fall *Carrie Buck v. James Hendren Bell, Superintendent of State Colony for Epileptics and Feeble Minded*<sup>170</sup> ein entsprechendes Gesetz in dem US-Bundesstaat Virginia als verfassungsgemäß. Zu diesem Verfahren vor dem höchsten amerikanischen Gericht kam es, nachdem *Albert Sidney Priddy*, der im Verlaufe des Gerichtsverfahrens verstorbene Vorgänger von *Bell*, beim Verwaltungsrat des Heimes für Menschen mit geistigen Behinderungen den Antrag auf Sterilisation von *Carrie Buck* gestellt hatte.<sup>171</sup> *Buck* sei, so die Argumentation, eine genetische Gefahr für die Gesellschaft, da ihr geistiger Entwicklungsstand trotz ihres Alters von 18 Jahren dem einer Achtjährigen entspräche. Darüber hinaus war sie Mutter einer unehelichen Tochter, die, so die Argumentation weiter, ebenfalls eine geistige Behinderung aufwiese.<sup>172</sup> Auch *Carrie Bucks* Mutter, die in derselben Anstalt lebte, galt als geistesschwach, ihr Entwicklungsstand soll dem einer Neunjährigen entsprochen haben.<sup>173</sup> Sowohl der Circuit Court of Amherst County als auch der Supreme Court of Appeals of the State of Virginia ordneten die Sterilisation *Bucks* an.<sup>174</sup> Der United States Supreme Court wurde sodann unter Berufung auf den 14. Zusatz zu der US-amerikanischen Verfassung (*XIV. Amendment to the United States Constitution*) angerufen: Die Urteile der Vorinstanzen würden die darin verankerte *due process clause* sowie die *equal*

<sup>167</sup> *Kevles*, In the Name of Eugenics, S. 61–63.

<sup>168</sup> *Kevles*, In the Name of Eugenics, S. 89.

<sup>169</sup> *Sandel*, The Case against Perfection, S. 65 f.

<sup>170</sup> *Buck v. Bell*, 274 U.S. 200 (1927), 47 S.Ct. 584 (1927), 71 L.Ed. 1000 (1927).

<sup>171</sup> *Buck v. Bell*, 143 Va. 310, 314 (1925), 130 S.E. 516, 517 (1925).

<sup>172</sup> Allerdings galt sie in späteren Jahren unter ihren Lehrern, die sie, bevor sie im Jahre 1932 an einer Erkrankung starb, bis in die zweite Klasse hinein unterrichtet hatten, als sehr intelligent; vergleiche *Kevles*, In the Name of Eugenics, S. 112.

<sup>173</sup> *Buck v. Bell*, 143 Va. 310, 315 (1925), 130 S.E. 516, 517 f. (1925).

<sup>174</sup> *Buck v. Bell*, 143 Va. 310 (1925), 130 S.E. 516, 51 A.L.R. 855 (1925).

*protection clause* verletzen.<sup>175</sup> Während letztere den Grundsatz „*all men are created equal*“ auch auf die Situation vor Gericht erweitert,<sup>176</sup> gewährleistet die *due process clause* die Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze, insbesondere der Zuständigkeit des angerufenen Gerichts als auch der Gewährung rechtlichen Gehörs.<sup>177</sup> Am 2. Mai 1927 bestätigte der United States Supreme Court jedoch mit einer Mehrheit von acht der neun Richter die Urteile der Vorinstanzen und stellte die Rechtmäßigkeit des Verfahrens und die Verfassungsmäßigkeit des der Sterilisierung zugrunde liegenden Gesetzes fest. In der Urteilsbegründung führte Justice *Oliver Wendell Holmes* aus, dass das staatliche Interesse eines reinen Gen-Pools das individuelle Interesse der körperlichen Integrität überwiege. Wenn zugunsten des Allgemeinwohls schon das Leben der wertvollen Bürger („*best citizens*“) zurückzustehen habe, dann müsse dies auch für Menschen mit geistigen Behinderungen gelten, insbesondere dann, wenn es nicht um deren Leben, sondern lediglich um deren Fortpflanzungsfähigkeit gehe. *Holmes* verglich weiter die Sterilisierung durch Durchtrennung der Eileiter mit der Praxis der Pflichtimpfungen, denen dasselbe Prinzip zugrunde läge: So sei es im Hinblick auf Zwangssterilisationen begrüßenswert, die Fortpflanzung von Kriminellen oder Menschen mit Behinderungen zu unterbinden, bevor sie beispielsweise aufgrund ihrer Straffälligkeit zum Tode verurteilt werden müssten.<sup>178</sup>

Das letzte US-amerikanische Gesetz, das wie eben dieses Urteil des United States Supreme Court eine negative Eugenik lobt und die Volksgesundheit durch die Eliminierung von Sträflingen oder Behinderten aus dem Gen-Pool zu gewährleisten sucht, blieb bis 1974 in Kraft, allerdings wurde die Ausführung unter dem Eindruck der nationalsozialistischen Sterilisationspolitik eingestellt.<sup>179</sup>

### III. Die Eugenik des Nationalsozialismus

Eine grausame Steigerung erfuhren die geschilderten US-amerikanischen, aber auch die in der Weimarer Republik<sup>180</sup> vorangegangenen eugenischen Entwicklungen im deutschen Nationalsozialismus unter *Adolf Hitler*.<sup>181</sup>

*Hitler* sah es als Aufgabe des Staates an, dafür Sorge zu tragen, dass das „Wohl der Gesellschaft“ gefördert werde, was primär mittels Sterilisation der „kranken“

<sup>175</sup> Buck v. Bell, 274 U.S. 200, 205 (1927), 47 S.Ct. 584 (1927).

<sup>176</sup> Buck v. Bell, 143 Va. 310, 321 (1925), 130 S.E. 516, 519 f. (1925).

<sup>177</sup> Buck v. Bell, 143 Va. 310, 317 (1925), 130 S.E. 516, 518 (1925).

<sup>178</sup> Buck v. Bell, 274 U.S. 200, 207 (1927), 47 S.Ct. 584, 585 (1927).

<sup>179</sup> Bock, Sterilisationspolitik im Nationalsozialismus, S. 99.

<sup>180</sup> Zur Eugenik-Politik in der Weimarer Republik siehe *Kuhlmann*, Politik des Lebens – Politik des Sterbens, S. 48 ff.

<sup>181</sup> Einige der im Rahmen der folgenden Ausführungen verwendeten Begriffe stehen in Anführungszeichen. Dies liegt damit begründet, dass es sich einerseits zum Teil um *termini technici* handelt, dass sie sich aber andererseits häufig auch nicht in eine angemessene, kritisch-humane Sprache übersetzen lassen. Ausführlich zu diesem Themenkomplex: *Weingart/Kroll/Bayertz*, Rasse, Blut und Gene.

und „minderwertigen“ Bevölkerung erreicht werden sollte. Die von ihm verfolgte „Rassenhygiene“ setzte aber auch bei denjenigen Teilen der Bevölkerung an, die als „wertvoll“ angesehen wurden. So wurde etwa von *Fritz Lenz* eine Liste mit Kriterien erstellt, die Anleitung zur Wahl eines angemessenen Ehepartners geben sollte. Der Kandidat oder die Kandidatin sollte demzufolge beispielsweise anhand des „persönlichen Wertes“, auf den geistige und körperliche Gesundheit, Charaktereigenschaften wie Güte, Willensstärke, „Opfertum“, Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit und Tapferkeit, sowie Tüchtigkeit, Begabung und Bildung von Einfluss sein sollten, beurteilt werden. Auch das Vermögen und das Ansehen der Familie sowie deren Anlagen hinsichtlich physischer oder psychischer Fähigkeiten oder Krankheiten sollten bei der Beurteilung berücksichtigt werden.<sup>182</sup> Für derart „wertvolle“ Menschen sahen die nationalsozialistischen Gesetze Sterilisationsverbote vor.<sup>183</sup> *Hitler* schrieb in dem Buch *Mein Kampf*: „Er [der „völkische Staat“] hat die Rasse in den Mittelpunkt des allgemeinen Lebens zu setzen. Er hat für ihre Reinhaltung zu sorgen. Er hat das Kind zum kostbarsten Gut eines Volkes zu erklären. Er muß dafür Sorge tragen, daß nur wer gesund ist, Kinder zeugt; daß es nur eine Schande gibt: bei eigener Krankheit und eigenen Mängeln dennoch Kinder in die Welt zu setzen, doch eine höhere Ehre: darauf zu verzichten. Umgekehrt aber muß es als verwerflich gelten: gesunde Kinder der Nation vorzuenthalten.“<sup>184</sup> Durch die Einrichtung des von *Heinrich Himmler* gegründeten *Lebensborn e. V.*, Verschärfungen der Strafbarkeit von Abtreibungen durch Frauen „guten Blutes“ – im Gegensatz zu denen durch Frauen unerwünschter Gruppen, die ohne Weiteres abtreiben durften – oder das Setzen von Anreizen, die von Steuerbegünstigungen bis hin zum Mutterkreuz reichten, wurde eine Bevölkerungspolitik betrieben, die nicht nur qualitative, sondern auch quantitative Ziele verfolgte.

Sterilisationszwang bestand entsprechend aber für Menschen, die als „minderwertig“ befunden worden waren. So *Hitler*: „Wer körperlich und geistig nicht gesund und würdig ist, darf sein Leid nicht im Körper seines Kindes verewigen.“<sup>185</sup> Hierunter fielen zehn bis 30% des „deutschen Volkes“.<sup>186</sup> Nach der Machtergreifung am 30. Januar 1933 wurde zur Erreichung dieses Zieles am 14. Juli 1933 das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses<sup>187</sup> erlassen. Hierauf gestützt wurden innerhalb eines Jahrzehnts zehn Mal so viele Menschen zwangssterilisiert wie in den USA in dem gesamten Zeitraum von 1907 bis 1945.<sup>188</sup> Während mittelfristig zwischen einer halben und zwei Millionen Menschen sterilisiert werden sollten,

<sup>182</sup> *Becker*, Zur Geschichte der Rassenhygiene, S. 158 ff.

<sup>183</sup> *Bock*, Sterilisationspolitik im Nationalsozialismus, S. 95.

<sup>184</sup> *Hitler*, *Mein Kampf*, S. 446 (Ergänzungen Welling); vergleiche auch *Becker*, Zur Geschichte der Rassenhygiene, S. 139.

<sup>185</sup> *Hitler*, *Mein Kampf*, S. 447; vergleiche auch *Becker*, Zur Geschichte der Rassenhygiene, S. 139.

<sup>186</sup> *Bock*, Sterilisationspolitik im Nationalsozialismus, S. 88.

<sup>187</sup> Abgedruckt in: Reichsgesetzblatt, Jahrgang 1933, Teil I, Nr. 86 – Tag der Ausgabe: Berlin, den 25. Juli 1933, S. 529.

<sup>188</sup> *Bock*, Sterilisationspolitik im Nationalsozialismus, S. 99.

wurden als Nahziel 400.000 Sterilisationen festgelegt, welches auch alsbald erreicht wurde.<sup>189</sup>

§ 1 I des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses sah die Sterilisation von „Erbkranken“ vor. Diese waren in § 1 II legaldefiniert. Hierunter fiel, wer an angeborenem Schwachsinn, Schizophrenie, manisch-depressivem Irrsein, erblicher Fallsucht, Huntington Chorea oder erblicher Blindheit oder Taubheit beziehungsweise schweren erblichen körperlichen Missbildungen litt. Auch Alkoholismus war gemäß § 1 III Grund zur Sterilisation. Voraussetzung hierfür war zunächst ein Antrag, der gemäß § 2 auch von der Person gestellt werden konnte, die „unfruchtbar gemacht werden soll“, was bei den auf dieses Gesetz gestützten Sterilisationen freilich beinahe nie vorkam. Von Bedeutung hingegen war die in § 3 geregelte Antragsbefugnis von Amtsärzten oder den Leitern von Pflege- oder Krankenanstalten sowie von Strafanstalten. Dies hing insbesondere mit der Auffassung, „Minderwertigkeit“ sei vererblich, zusammen. Die bloße äußere, phänotypische Heilung belasse es bei dem Genotyp und damit auch der „Krankheit“. Dies mache eine Sterilisation umso dringlicher, als dass durch die Gesundung eine größere „Fortpflanzungsgefahr“ bestünde. Anstaltsbewohner wurden seit 1933 somit in der Regel nur noch nach erfolgter Sterilisation entlassen.<sup>190</sup>

Dass die Sterilisationen auch durch Staatsgewalt durchgesetzt werden konnten, regelte § 12 des Gesetzes zur Vermeidung erbkranken Nachwuchses. Zunächst konnte die Vorführung beim Amtsarzt durch die Polizei erzwungen werden. Die Fahndung nach geflohenen Sterilisanden sowie die Verbringung in eine psychiatrische Anstalt zur Diagnose einer Erbkrankheit oder zur Verhinderung von Flucht und Geschlechtsverkehr fielen ebenfalls in den polizeilichen Zuständigkeitsbereich. Schließlich sicherte die Polizei auch die Durchführung der eigentlichen Sterilisierung.<sup>191</sup>

Die Entscheidung über den bestehenden „Wert“ einer Person oder über ihre „Minderwertigkeit“ und damit über deren Fortpflanzung oblag den eigens dafür eingerichteten Gesundheitsämtern und etwa 220 Sterilisationsgerichten, die neben Juristen auch mit Medizinern, Psychiatern und Anthropologen besetzt waren.<sup>192</sup>

Diese Sterilisationspolitik wurde primär in der ersten Hälfte des nationalsozialistischen Unrechtsregimes verfolgt. Später stand die Mordpolitik im Vordergrund,<sup>193</sup> worauf aber einschließlich der Vernichtung „lebensunwerten Lebens“ und der Kinder-Euthanasie hier nicht weiter eingegangen werden soll. Gleiches gilt für weitere im Zusammenhang stehende Praktiken wie etwa Eheverbote oder Zwangsabtreibungen. Das ursprüngliche Ziel der Eugenik, eine „Aufartung“, also eine Selektion gesunder und „hochwertiger“ Erbanlagen, zu erreichen, wurde im Nationalsozialis-

<sup>189</sup> Bock, Sterilisationspolitik im Nationalsozialismus, S. 88; Weingart/Kroll/Bayertz, Rasse, Blut und Gene, S. 470 f.

<sup>190</sup> Bock, Sterilisationspolitik im Nationalsozialismus, S. 88 f., 92.

<sup>191</sup> Bock, Sterilisationspolitik im Nationalsozialismus, S. 89.

<sup>192</sup> Bock, Sterilisationspolitik im Nationalsozialismus, S. 95.

<sup>193</sup> Bock, Sterilisationspolitik im Nationalsozialismus, S. 88.

mus in die Züchtung einer „arischen Rasse“, einer „Herrenrasse“ verkehrt. Mit Eugenik im eigentlichen Sinne hatten diese Bestrebungen gänzlich nichts mehr zu tun.

#### IV. Jüngere staatliche Eugenik-Programme am Beispiel Singapur

Auch in der jüngsten Geschichte sind weiterhin eugenische Bemühungen zu verzeichnen. Unterschiede zu den Entwicklungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bestehen jedoch insofern, als dass aktuellere Bemühungen keinesfalls mittels Zwang durchgesetzt wurden. Vielmehr entwickelte sich etwas, das *Sandel* als „*free-market eugenics*“ bezeichnet. In den 1980-er Jahren führte beispielsweise Singapur zahlreiche staatliche Programme ein, die die sich abzeichnende Entwicklung der sinkenden Geburtenraten bei Frauen mit guter Ausbildung, die deutlich hinter den Geburtenraten bei Frauen mit mangelnder Ausbildung zurückblieben,<sup>194</sup> einzudämmen suchten. Der damalige stellvertretende Premierminister *Goh Keng Swe* stellte ein Maßnahmenpaket vor, das die „*Verwässerung*“ menschlicher Fähigkeiten, die er für Singapur befürchtete und als Bedrohung der wirtschaftlichen Kraft des Stadtstaates wahrnahm,<sup>195</sup> umkehren sollte. Hierzu zählte die Einrichtung staatlicher Dating-Services, an Hochschulen wurden Flirt-Kurse in das Curriculum aufgenommen, Absolventinnen und Absolventen auf Staatskosten auf „love boat“-Kreuzfahrten geschickt und Hochschulabsolventinnen für den Fall der Heirat und Geburt eines Kindes finanzielle Anreize in Aussicht gestellt. Später wurde Frauen mit geringem Einkommen und ohne Abitur ein Zuschuss in Höhe von \$ 4.000 zu einem Apartment angeboten – vorausgesetzt, dass sie in ihre Sterilisierung einwilligten. Während die betroffenen Personen keinem Zwang hierzu im engeren, eigentlichen Sinne ausgesetzt waren, was den Befürwortern einer solchen Praxis zufolge den bedeutenden Unterschied zu den oben geschilderten US-amerikanischen und deutschen Maßnahmen des frühen und mittleren 20. Jahrhunderts ausmacht, führen die Kritiker ins Feld, dass derartige Angebote effektiv wie Zwang wirken, wenn die betroffenen Frauen sich die Ablehnung in wirtschaftlicher Hinsicht vernünftigerweise nicht leisten können.<sup>196</sup>

<sup>194</sup> Die Sicht der Regierung, namentlich des Premierministers Singapurs, *Lee Kuan Yew*, auf diese Entwicklung ist beispielhaft dargelegt in *Desilets/Vining*, *Quality Considerations in Population Policy*, S. 754 ff.

<sup>195</sup> *Chan*, *Eugenics on the Rise*, S. 165: „*In Lee's view, these trends, if left unchecked, could only lead to a dilution of human talent in Singapore, a prelude to the certain demise of the island's hitherto vibrant economy.*“

<sup>196</sup> *Chan*, *Eugenics on the Rise*, S. 164 ff.; *Sandel*, *The Case against Perfection*, S. 68 ff.



## V. Die Abgrenzung zwischen Eugenik und Enhancement

Gleichzeitig werden anhand dieser Beispiele jedoch die Unterschiede zu dem deutlich, was heute unter Enhancement verstanden und worüber heute unter dieser Bezeichnung debattiert wird.

Während bislang eugenische Bestrebungen von staatlicher Seite initiiert und durchgesetzt wurden, geht es bei den heute in Frage stehenden Enhancement-Maßnahmen vielmehr um medizinische Eingriffe, die Privatpersonen freiwillig an sich beziehungsweise im Hinblick auf ihre (noch zu zeugenden) Kinder vornehmen lassen wollen. Die Rolle des Staates ist hierbei eine gänzlich untergeordnete, wenn nicht sogar restriktiv regulierende, das heißt gegebenenfalls sogar die entsprechenden Maßnahmen gesetzlich verbietende. Dass eine staatlich betriebene, im Sinne einer vorgeschriebenen und gegebenenfalls auch erzwungenen Eugenik, handle es sich nun um eine sogenannte negative Eugenik, bei der unerwünschte Eigenschaften eliminiert werden sollen durch Maßnahmen im gesamten Handlungsspektrum zwischen therapeutischen Keimbahneingriffen bis hin zu dem Ausschluss der Träger dieser Eigenschaften aus dem reproduktiven Prozess, oder um positive Eugenik, also genetisches Enhancement, unzulässig ist, ist konsentiert. Unabhängig davon bleibt aber zu erörtern, wie ein hierauf gerichtetes Handeln Privater zu beurteilen ist.<sup>197</sup>

Des Weiteren ist zwischen der sogenannten negativen Eugenik, deren Ziel es war, unerwünschte Eigenschaften aus dem Gen-Pool zu eliminieren, um so die genetische Ausstattung der Menschheit als Ganzes zu verbessern, und dem heute in Frage stehenden Enhancement zu unterscheiden, bei dem es um die Optimierung von Individuen im Gegensatz zur gesamten Menschheit geht, die durch die Ergänzung erwünschter Gene zu der natürlichen genetischen Disposition der betroffenen Person erreicht werden soll. Keinesfalls geht es dabei um den Ausschluss bestimmter Personen von der Möglichkeit der eigenen Fortpflanzung. Entsprechend stellt Robert L. Sinsheimer fest: *„The old eugenics would have required a continual selection for breeding of the fit, and a culling of the unfit. The new eugenics would permit in principle the conversion of all the unfit to the highest genetic level. The old eugenics was limited to a numerical enhancement of the best of our existing gene pool. The horizons of the new eugenics are in principle boundless [...]“*<sup>198</sup> Das heute diskutierte Enhancement, die „new eugenics“, wäre hiernach ein humaneres<sup>199</sup> Verfahren zur Perfektionierung des Menschen. Auch sein Potential geht über das der historischen Eugenik-Programme hinaus: Deren Wirkung war beschränkt auf eine quantitative Verbesserung, sie konnten nur die ohnehin schon im menschlichen Erbgut vorhandenen positiven Eigenschaften in der Bevölkerung verbreiten.

Erschwerend kommt hinzu, dass ein historisches Eugenik-Programm nur unter der Voraussetzung erfolgsversprechend sein konnte, dass es sich der Zustimmung

<sup>197</sup> So auch schon Isensee, Die alten Grundrechte und die biotechnische Revolution, S. 258 ff.

<sup>198</sup> Sinsheimer, The Prospect of Designed Genetic Change, S. 145.

<sup>199</sup> Vergleiche auch Sandel, The Case Against Perfection – What’s wrong with designer children, bionic athletes, and genetic engineering, S. 9.

einer stabilen Mehrheit der Bevölkerung erfreut, die ihr reproduktives Verhalten anhand des Programmes für einen hinreichend langen Zeitraum, das heißt über mehrere Generationen hinweg, ausrichtet. Im Gegensatz hierzu könnte ein modernes Enhancement die gewünschten Eigenschaften binnen einer Generation implementieren.<sup>200</sup>

Dem kurzen Zeitraum seiner Umsetzung entsprechend könnten jedoch auch die sozialen Restriktionswirkungen öffentlicher Debatten und Reflexionen gering ausfallen.<sup>201</sup> Die Resultate von Enhancement-Maßnahmen zeigen sich unmittelbar und sind nicht reversibel. Eine soziale Kontrolle und Reflexion, die sonst den gesamten Prozess der Um- und Durchsetzung eines Eugenik-Programmes begleitet hätte, liefe nun, da die Fakten schnell geschaffen werden können, in vielen Fällen Gefahr, zu spät zu kommen.

Auch wenn das heutige Enhancement aufgrund der beiden letztgenannten Aspekte wirkmächtiger zu sein scheint als die zu verurteilende staatliche Eugenik des vergangenen Jahrhunderts, so erscheint es vor dem Hintergrund der zuvor geschilderten bedeutenden Unterschiede dennoch fraglich, inwiefern die in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen auf die aktuelle Diskussion übertragen und als Argument gegen ein Enhancement verwendet werden können. Entsprechende Überlegungen werden zu einem späteren Zeitpunkt in der vorliegenden Arbeit anzustellen sein.

---

<sup>200</sup> *Sinsheimer*, The Prospect of Designed Genetic Change, S. 144 f.

<sup>201</sup> *Sinsheimer*, The Prospect of Designed Genetic Change, S. 144 f.



## Teil II

# Einfachgesetzliche Bewertung *de lege lata*

„Will man der Frage nach dem Regelungsbedarf nachgehen, so ist vorab das bestehende Regelungsgeflecht zu betrachten; denn nur, wenn genau feststeht, was bereits konkret gewährleistet oder zumindest durch richterliche oder administrative Entscheidungspraxis konkretisiert ist, läßt sich beurteilen, ob ein juristischer Handlungsbedarf zum gegenwärtigen Zeitpunkt überhaupt besteht.“<sup>202</sup> Im Folgenden soll daher zunächst die aktuelle einfachrechtliche Lage hinsichtlich der im Vorgang erläuterten Techniken des genetischen Enhancements, konkret der Eingriffe in die Keimbahn und der somatischen Genmanipulation, erläutert werden.

---

<sup>202</sup> Riedel, EuGRZ 1986, 469.

## Kapitel 5: Eingriffe in die Keimbahn

Eine explizite Regelung erfuhr der gentechnische Eingriff in die Keimbahn in § 5 des Embryonenschutzgesetzes<sup>203</sup>, das am 13. Dezember 1990 erlassen wurde und am 1. Januar 1991 in Kraft trat. Bis dato waren den Embryo betreffende, insbesondere schädigende Handlungen in der Pränidationsphase, das heißt dem Zeitraum zwischen der Verschmelzung von Samen- und Eizelle und der Einnistung in die Gebärmutter Schleimhaut, strafgesetzlich in Deutschland nicht geregelt: Als Schwangerschaftsabbruch galten gemäß § 219 d StGB a. F. beziehungsweise gelten gemäß § 218 I 2 StGB keine Handlungen, deren Wirkung vor der Nidation eintreten. Die §§ 218 ff. StGB finden somit für den Zeitraum, in dem Maßnahmen zur Modifizierung der Keimbahnzellen spätestens stattfinden können, keine Anwendung; sie schützen lediglich die Leibesfrucht ab der Einnistung. Auch können die §§ 211 ff. StGB ebenso wenig einen Schutz des Embryos vor dessen Einnistung gewähren, denn deren Schutzgut ist ein (anderer) geborener Mensch.<sup>204</sup> Selbiges trifft auf die Körperverletzungstatbestände der §§ 223 ff. StGB zu.<sup>205</sup> Auch wird nach ganz herrschender Meinung das Leben des Embryos *in vitro* nicht durch die Straftatbestände zum Schutze des Eigentums geschützt, denn diese setzen voraus, dass es sich bei einem Embryo um eine Sache handelt. Die Sacheigenschaft einer Keimzelle wird jedoch spätestens mit deren Befruchtung als beendet angesehen.<sup>206</sup> Dies liegt darin begründet, dass sich Sachen und Personen bereits begrifflich ausschließen. Es ist weder rechtlich noch philosophisch einleuchtend, wie sich eine Sache zu einem Menschen entwickeln können soll.

---

<sup>203</sup> BGBl. I S. 2746.

<sup>204</sup> Lackner/Kühl, StGB, Vor § 211 Rdnr. 1, 3; Fischer, StGB, Vor § 211 Rdnr. 2 f., 4.

<sup>205</sup> Schönke/Schröder-Eser, StGB, § 223 Rdnr. 1.

<sup>206</sup> Schönke/Schröder-Eser, StGB, § 242 Rdnr. 10; die Auffassung, dass Embryonen sehr wohl Sachen seien, vertrat *Bilsdorfer*, MDR 1984, 803 (804 f.).

## I. Die Entstehungsgeschichte des Embryonenschutzgesetzes

Im Kontext zahlreicher Stellungnahmen und Richtlinien seitens der Bundesärztekammer, des Deutschen Juristentages, der Kirchen sowie diverser Arbeitsgruppen in Reaktion auf die rasanten Entwicklungen der Reproduktionsmedizin und Humangenetik der 70er- und 80er-Jahre des 20. Jahrhunderts, beruht das heutige Embryonenschutzgesetz primär auf dem Bericht der sogenannten Benda-Kommission:<sup>207</sup>

Von Bundesjustizminister *Hans Arnold Engelhard* und Bundesforschungsminister *Heinz Riesenhuber* eingesetzt, setzte sich die *Arbeitsgruppe „In-vitro-Fertilisation, Genomanalyse und Gentherapie“* ab Mai 1984 unter ihrem Vorsitzenden, dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts *Ernst Benda*, mit vielfältigen, im Zusammenhang mit Humangenetik und Reproduktionsmedizin stehenden Problemen auseinander. Ihren Abschlussbericht legten die Naturwissenschaftler, Ärzte, Moraltheologen, Philosophen und Juristen, aus denen sich die Kommission zusammensetzte, am 25. November 1985 vor.<sup>208</sup>

Besondere Aufmerksamkeit kam dabei auch der Keimbahngentechnik zu, wobei die Gefahren, die als mit einem vorzeitigen Einsatz etwa von Verfahren zur Keimbahntherapie verbunden erkannt wurden, Betonung fanden. Eine etwaige Inkaufnahme dieser Risiken wurde als ein unverantwortliches Experimentieren mit menschlichem Leben angesehen, das dem Verfassungsgrundsatz des Art. 1 I GG sowie dem objektiv-rechtlichen Gehalt des Grundrechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit in Art. 2 II 1 GG nicht gerecht wird.<sup>209</sup> Es wurde befürchtet, dass aufgrund der bislang nicht kontrollierbaren genetischen Veränderung und somit der zu erwartenden hohen Fehlerquote im Zuge der Selektion der erfolgreich transformierten Embryonen die Vernichtung menschlichen Lebens erforderlich werden würde. Einer derartigen Selektion stünde jedoch der Lebensschutz entgegen, der auch dem Embryo zu gewähren sei,<sup>210</sup> da artspezifisches menschliches Leben bereits mit der Verschmelzung der Gameten entstehe.<sup>211</sup>

Entsprechend entschied man sich, dem Gesetzgeber das Verbot des Gentransfers in die Keimbahn zu empfehlen, wobei nicht übersehen wurde, dass zukünftig auch eine Lockerung im Interesse des Lebens- und Gesundheitsschutzes notwendig werden könnte.<sup>212</sup> Jedoch wollten die Mitglieder der Benda-Kommission derartige Eingriffe auf nur schwerste monogene Erbkrankheiten begrenzt sehen; nicht-therapeutische, sondern, so der Duktus der Benda-Kommission, eugenische Maßnahmen galten ihnen hingegen, da sie dazu dienten, Menschen an einer vermeintlich rich-

<sup>207</sup> Günther/Taupitz/Kaiser-Taupitz, Embryonenschutzgesetz, Einführung B Rdnr. 1, 3.

<sup>208</sup> Bundesminister für Forschung und Technologie, Benda-Kommission, Vorwort, S. 1.

<sup>209</sup> Bundesminister für Forschung und Technologie, Benda-Kommission, S. 46.

<sup>210</sup> Bundesminister für Forschung und Technologie, Benda-Kommission, S. 45 f.

<sup>211</sup> Bundesminister für Forschung und Technologie, Benda-Kommission, S. 6.

<sup>212</sup> Bundesminister für Forschung und Technologie, Benda-Kommission, S. 46.

tigen Norm zu messen und sie genetisch auf diese Norm hin zu manipulieren, als „den Menschen zutiefst in seiner Würde verletzen[d]“. <sup>213</sup>

Auf den Entwurf eines Gesetzes zum Schutz von Embryonen<sup>214</sup> sowie das spätere Gesetz waren darüber hinaus der Abschlussbericht der Enquete-Kommission „Chancen und Risiken der Gentechnologie“ des Deutschen Bundestages vom Januar 1987<sup>215</sup> sowie die Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Fortpflanzungsmedizin“<sup>216</sup> einflussreich.

## II. Die Verbotstatbestände

### 1. Das Verbot des § 5 I, IV ESchG

§ 5 I ESchG stellt ausweislich seines Wortlautes die künstliche Veränderung der in einer menschlichen Keimbahnzelle enthaltenen Erbinformation unter bis zu fünfjährige Freiheits- oder entsprechende Geldstrafe. Der Versuch ist gemäß § 5 III ESchG strafbar. Er kommt insbesondere dann in Betracht, wenn es sich bei der manipulierten Zelle entgegen der tätereigenen Vorstellung nicht um eine Zelle der Keimbahn gehandelt hat oder deren Erbinformationen mangels erfolgreicher Integration der eingebrachten DNA-Sequenz nicht wie beabsichtigt verändert worden ist.<sup>217</sup>

#### a) Ratio legis

Dem umfassenden Verbot nach § 5 I, IV ESchG unterliegen Eingriffe in die menschliche Keimbahnzellen, wodurch auch Versuche einer Keimbahntherapie, also der Heilung genetisch bedingter Krankheiten durch eine Modifizierung der zur Keimbahn gehörigen Zellen untersagt sind. Ebenso ist die Verwendung genetisch veränderter Keimzellen zur Befruchtung durch § 5 II ESchG strafbewehrt. Hintergrund dieser weitreichenden Restriktion sind die bislang lediglich begrenzten medizinisch-technischen Möglichkeiten der gezielten Integration und kontrollierten Expression einer erwünschten DNS-Sequenz in der Zielzelle. Einbau sowie Folgewirkungen und Wechselwirkungen sind zurzeit mitnichten vorhersehbar, weswegen, wenn schon die „Ethik des Heilens“ wegen eines inadäquaten Chance-Risiko-Verhältnisses als verletzt anzusehen ist, erst recht ein Enhancement, dessen Alternative das Fortdauern eines in gesundheitlicher Hinsicht normalen Zustandes, nicht aber

<sup>213</sup> Bundesminister für Forschung und Technologie, Benda-Kommission, S. 46.

<sup>214</sup> Deutscher Bundestag, Drucksache 11/8057.

<sup>215</sup> Deutscher Bundestag, Drucksache 10/6775.

<sup>216</sup> Bundesanzeiger vom 6. Januar 1989 (Nr. 4a).

<sup>217</sup> Günther/Taupitz/Kaiser-Günther, Embryonenschutzgesetz, § 5 Rdnr. 24.

ein weiteres Leiden unter einer Krankheit ist, um das es zu beseitigen sich erheblichere Risiken einzugehen lohnen würde, an den im Vergleich zu den bestehenden Chancen nicht hinzunehmenden Risiken scheitern muss. Beweggrund für das strikte und umfassende Verbot des § 5 ESchG ist somit das für die Keimbahneingriffe negative Resultat einer Risiko-Nutzen-Abwägung. Entsprechend heißt es in der Begründung des Regierungsentwurfes zum Embryonenschutzgesetz, dass, da die Entwicklung der Methode eines Gentransfers in menschliche Keimbahnzellen auch vorheriger Versuche am Menschen bedürfe, die jedoch in der experimentellen Phase Fehlschläge erwarten ließen, deren Folgen irreversibel wären, derartige Experimente nach aktuellem Kenntnisstand nicht zu verantworten wären.<sup>218</sup>

## b) Der Tatbestand des § 5 I ESchG

Fraglich ist, ob die Durchführung des genetischen Enhancements gegen § 5 I ESchG verstößt. Hierzu müssten der objektive sowie der subjektive Tatbestand in rechtswidriger und schuldhafter Weise erfüllt sein.

### aa) Der objektive Tatbestand

#### (1) Taugliches Tatobjekt

Als taugliche Tatobjekte nennt § 5 I ESchG die Erbinformationen einer menschlichen Keimbahnzelle.

Fraglich ist hier zunächst, was unter „Keimbahnzelle“ zu verstehen ist. Ausweislich der Legaldefinition in § 8 III ESchG fallen hierunter *„alle Zellen, die in einer Zell-Linie von der befruchteten Eizelle bis zu den Ei- und Samenzellen des aus ihr hervorgegangenen Menschen führen, ferner die Eizelle vom Einbringen oder Eindringen der Samenzelle an bis zu der mit der Kernverschmelzung abgeschlossenen Befruchtung.“* Während in der Literatur keine Einigkeit darüber besteht, ob mit der Keimbahn die Weitergabe der Art- und Individueneigentümlichkeit des Lebewesens in ununterbrochener Folge bezeichnet ist<sup>219</sup> oder ob bei Säugetieren und somit auch beim Menschen die Pluripotenz der Blastomeren des Embryos eine Unterbrechung dieser Folge darstellt<sup>220</sup>, geht der Gesetzgeber des Embryonenschutzgesetzes offensichtlich von einer ununterbrochenen Folge aus.<sup>221</sup> Die im letzten Halbsatz vorgenommene Ergänzung und Ausweitung des Begriffes der Keimbahnzelle auch auf die Eizelle ab Eindringen oder Einbringen der Samenzelle bis zur Kernverschmelzung, das heißt die imprägnierte Zelle mit ihren Vorkernen, zielt auf einen möglichst umfassenden Schutz vor Eingriffen ab. Hintergrund ist, dass in diesem

<sup>218</sup> Deutscher Bundestag, Drucksache 11/5460, S. 11.

<sup>219</sup> Lexikon der Biologie, Band 8, Eintrag „Keimplasma“.

<sup>220</sup> Günther/Taupitz/Kaiser, Embryonenschutzgesetz, Anhang C – Glossar, Eintrag „Keimbahn“.

<sup>221</sup> Günther/Taupitz/Kaiser-Taupitz, Embryonenschutzgesetz, § 8 Rdnr. 66.

Stadium nicht festgestellt werden kann, ob sich der Eingriff auf die Keimbahn oder nur auf sonstige Zellen auswirkt.<sup>222</sup>

Die Keimbahnzelle ist des Weiteren als eine menschliche zu betrachten, wenn das in ihr enthaltene Erbgut menschlichen Ursprungs ist. Die Keimbahnzelle muss, anders ausgedrückt, in einer Zell-Linie aus zwei von Menschen stammenden Keimzellen hervorgegangen sein. Liegen hingegen hybride Keimbahnzellen vor, also solche, die artfremdes, insbesondere tierisches Erbgut aufweisen, ist § 7 ESchG einschlägig.<sup>223</sup>

Schließlich muss die Erbinformation dieser menschlichen Keimbahnzelle betroffen sein. Beachtlich ist hier, dass § 5 I ESchG ein Gefährdungsdelikt darstellt, das die gesamte DNS jeder Keimbahnzelle in seinen Schutz einbezieht. Bislang ist lediglich bekannt, dass die Gene, die etwa 25 % der DNS ausmachen, Erbinformationen enthalten. Ob allerdings die übrigen 75 % des Zellkernes ebenfalls Erbinformationen enthalten, die jedoch noch nicht gelesen werden können, oder ob sie schlicht uncodiert sind, kann hingegen mit dem aktuellen Kenntnisstand nicht beantwortet werden. Aus dem Charakter des Gefährdungsdeliktes ergibt sich vor diesem Hintergrund, dass der Schutz des § 5 I ESchG nicht nur die den Genen zugeordneten DNS-Sequenzen umfasst, sondern sich auf die gesamte DNS erstreckt.<sup>224</sup>

Wie eingangs erläutert, können Enhancement-Maßnahmen sowohl an somatischen Zellen als auch an Zellen der Keimbahn durchgeführt werden. Nur in letztgenanntem Fall könnte ein taugliches Tatobjekt im Sinne des § 5 I ESchG vorliegen. Da beim genetischen Enhancement – unabhängig davon, ob Zielobjekt eine somatische Zelle oder eine Zelle der Keimbahn ist – gerade die genetische Ausstattung verbessert werden soll, ist stets auch die Erbinformation der manipulierten Keimbahnzelle betroffen, sodass ein taugliches Tatobjekt gegeben ist.

## *(2) Die Tathandlung*

Nach § 5 I ESchG ist das künstliche Verändern dieser Erbinformation untersagt. Dieses Tatbestandsmerkmal ist erfüllt, sobald auch nur ein Basenpaar des gesamten Genoms von dem ursprünglichen, ererbten Zustand abweicht, diese Abweichung aber nicht auf natürlichen Vorgängen wie spontanen Mutationen oder Umwelteinflüssen beruht, sondern durch einen menschlichen Eingriff hervorgerufen wurde. Vollendet ist die Tat mit der tatsächlichen Veränderung der Erbinformation. Integriert sich jedoch ein eingeschleustes Gen nicht oder kommt es auf anderweitige Weise nicht zu der erwünschten Neukombination der DNS, so liegt unter Umständen ein von § 5 III ESchG erfasster Versuch vor.<sup>225</sup>

Bei einem genetischen Enhancement versucht der Arzt, die natürlich in dem Genom der Zielzelle vorkommenden Gene zu modifizieren, das heißt etwa zu ersetzen, zu ergänzen oder ihre Expression zu blockieren. Hierbei handelt es sich – den Er-

<sup>222</sup> Günther/Taupitz/Kaiser-Taupitz, Embryonenschutzgesetz, § 8 Rdnr. 67.

<sup>223</sup> Günther/Taupitz/Kaiser-Günther, Embryonenschutzgesetz, § 5 Rdnr. 10.

<sup>224</sup> Günther/Taupitz/Kaiser-Günther, Embryonenschutzgesetz, § 5 Rdnr. 11.

<sup>225</sup> Günther/Taupitz/Kaiser-Günther, Embryonenschutzgesetz, § 5 Rdnr. 12 f.

folg dieser Maßnahmen vorausgesetzt – um eine Veränderung der Erbinformationen der Zielzelle, die auch künstlich induziert wird. Die Tathandlung ist somit eine im Sinne des § 5 I ESchG.

Der Wortlaut des § 5 I ESchG ist jedoch einer der am meisten kritisierten Schwachstellen des Embryonenschutzgesetzes. So ist insbesondere unklar und daher umstritten, ob es sich bei der Kerntransplantation, also der Entkernung einer Eizelle und Ersetzung durch den Kern einer anderen Zelle, um eine Veränderung der Erbinformation oder um deren Austausch handelt. Begründet liegt diese Unsicherheit in dem Umstand, dass trotz des Austausches des Zellkernes noch 0,001 % des Gesamtgenoms der entkernten Zelle, nämlich die Mitochondrien mit ihren 16569 Basenpaaren, erhalten bleiben. Dies veranlasst einige dazu, anstelle von einer Veränderung von einem Austausch zu sprechen. Die Auslegungsgrenze des möglichen Wortlautes sei hier erreicht, eine Substitution in diesem Umfang würde nicht die bestehende Erbinformation modifizieren, sondern sie mit einem *aliud* ersetzen.<sup>226</sup> Da es sich bei einer entkernten Eizelle nicht mehr um eine Keimzelle,<sup>227</sup> sogar nicht um eine Zelle handele, da sie nunmehr nicht mehr in der Lage sei, die genetische Information des Zellkernes weiterzugeben, wurde ihre Erbinformation nicht verändert, was voraussetzen würde, dass das Objekt erhalten bliebe, sondern beseitigt.<sup>228</sup> *Hans-Ludwig Günther* zieht hier einen anschaulichen Vergleich zu den Urkundsdelikten: Hier wäre eine Urkunde nicht gefälscht im Sinne des § 267 StGB, sondern gemäß § 274 StGB unterdrückt.<sup>229</sup> Dies würde dazu führen, dass der Tatbestand des § 5 I ESchG ins Leere läuft, wenn, anders als bei einer normalen Zellkerntransplantation, zunächst die Somazelle, die im Rahmen des § 5 I ESchG kein taugliches Tatobjekt darstellt, gentechnisch verändert würde, bevor sie zur Transplantation auf eine Eizelle verwendet und diese dann zur Erzeugung neuen menschlichen Lebens genutzt wird.<sup>230</sup> Dieses Verfahren einer Genmanipulation, die zu Zwecken des genetischen Enhancements genutzt werden könnte, unterfiele hiernach nicht dem strafrechtlichen Verbot des § 5 I ESchG.

Entgegengehalten wird dem jedoch, dass eine Veränderung im Sinne des § 5 I ESchG bereits mit dem Entkernen erfolgt ist, wodurch die Eizelle wegen des weiterhin in ihr enthaltenen Zytoplasmas jedoch nicht den Status einer Eizelle und damit einer Keimbahnzelle verliere. Eine Ausnahme bestehe nur für den Fall, dass sie zugrunde ginge.<sup>231</sup> In der Regel wäre demzufolge § 5 I ESchG erfüllt.

Diese streitige Frage bedürfte jedoch keiner Entscheidung, wenn selbst nach zweitgenannter Auffassung eine Strafbarkeit wegen eines Eingreifens der Regelung des § 5 IV ESchG ausscheidet. Unabhängig von der Frage, ob es sich dabei um

<sup>226</sup> Günther/Taupitz/Kaiser-Günther, Embryonenschutzgesetz, § 5 Rdnr. 14; auch unter Verweis auf Ingo Hansmann in einer dpa-Meldung vom 3. März 1997 von Bülow, DÄBl 1997, A-718 (A-720).

<sup>227</sup> von Bülow, DÄBl 1997, A-718 (A-723).

<sup>228</sup> Deutscher Bundestag, Drucksache 13/11263, S. 16.

<sup>229</sup> Günther/Taupitz/Kaiser-Günther, Embryonenschutzgesetz, § 5 Fn. 21.

<sup>230</sup> Günther/Taupitz/Kaiser-Günther, Embryonenschutzgesetz, § 5 Rdnr. 15.

<sup>231</sup> Deutscher Bundestag, Drucksache 13/11263, S. 16.

ein negatives Tatbestandsmerkmal oder eine objektive Bedingung der Strafbarkeit handelt, kann hier jedoch bereits gesagt werden, dass diese Vorschrift einschlägig ist: Gemäß § 5 IV Nr. 1 ESchG findet § 5 I ESchG keine Anwendung auf eine künstliche Veränderung der Erbinformation einer sich *ex vivo* befindlichen Keimzelle, wenn ihre Verwendung zur Befruchtung ausgeschlossen ist, was objektiv und nicht aus subjektiver Sicht des Täters zu beurteilen ist. Die Gamete muss somit für einen sachverständigen Beobachter entweder aufgrund ihrer Beschaffenheit, etwa mangels In-vitro-Aufarbeitung und Kultivierung, eine Befruchtung nicht mehr ermöglichen, oder der Täter muss die Verwendung zur Befruchtung ausschließende Vorkehrungen getroffen haben. Bei einer somatischen Kerntransplantation handelt es sich jedoch nicht um eine Befruchtung im Sinne dieses Gesetzes, sodass eine solche ausgeschlossen ist. Gleichwohl ist ein neuer Embryo aber entstanden.<sup>232</sup>

Dieses spezielle Verfahren zur Durchführung des genetischen Enhancements, nämlich die Kerntransplantation mittels eines zuvor genmodifizierten Zellkernes, unterfällt somit nicht dem Verbot des § 5 I ESchG. Im Übrigen ist jedoch eine taugliche Tathandlung im Sinne dieser Strafnorm gegeben.

### (3) Die Ausnahmen des § 5 IV ESchG

Unter den Voraussetzung des § 5 IV ESchG würde eine Strafbarkeit nach § 5 I ESchG jedoch ausscheiden. § 5 IV ESchG trägt der Forschungsfreiheit des Art. 5 III GG Rechnung und schränkt zu diesem Zweck § 5 I ESchG ein.<sup>233</sup>

§ 5 IV Nr. 1 ESchG nimmt daher solche Experimente von der Strafbarkeit aus, die den Schutzzweck des § 5 I ESchG, nämlich die Vermeidung einer Gefährdung des Individuums, nicht berühren, also von vornherein nicht hierzu führen können. Insbesondere Experimente mit sich *ex vivo* befindlichen Samen- und unbefruchteten Eizellen sind daher von § 5 I ESchG ausgenommen, wenn deren Verwendung zu Zwecken der Befruchtung ausgeschlossen ist (vergleiche oben). Sobald eine Eizelle imprägniert ist, ist diese Voraussetzung jedoch nicht mehr erfüllt, da sie bereits Befruchtungshandlungen unterzogen wurde.<sup>234</sup>

Genau wie die anderen Ziffern des § 5 IV ESchG stellt auch diese Nr. 1 nach den Motiven des Regierungsentwurfes eines Gesetzes zum Schutz von Embryonen ein negatives Tatbestandsmerkmal dar, fungiert somit nicht als bloße objektive Strafbarkeitsbedingung. Die Gefährdung sei, so der Regierungsentwurf, durch die nicht auszuschließende Befruchtung für den Unrechtsgehalt der Tat bedeutsam.<sup>235</sup>

§ 5 IV Nr. 2 ESchG betrifft weiter sonstige, das heißt nicht von Nr. 1 erfasste körpereigene Keimbahnzellen, also die Zellen, aus denen sich Ei- und Samenzellen bil-

<sup>232</sup> Günther/Taupitz/Kaiser-Günther, Embryonenschutzgesetz, § 5 Rdnr. 19 f.; *Deutscher Bundestag*, Drucksache 13/11263, S. 16; *Eser/Frühwald/Honnfelder/Markl/Reiter/Tanner/Winnacker*, Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik 2, 357 (369 f.).

<sup>233</sup> *Deutscher Bundestag*, Drucksache 11/5460, S. 11.

<sup>234</sup> *Deutscher Bundestag*, Drucksache 11/5460, S. 11; Günther/Taupitz/Kaiser-Günther, Embryonenschutzgesetz, § 5 Rdnr. 16, 19 f.

<sup>235</sup> *Deutscher Bundestag*, Drucksache 11/5460, S. 11.



den. Die *in vivo* befruchtete Eizelle, die sogenannte Zygote, sowie Ei- und Samenzellen gehören nicht hierzu. Die betreffende Keimbahnzelle muss ausweislich des Wortlautes von einer toten Leibesfrucht, einem Menschen oder einem Verstorbenen stammen und es muss weiterhin ausgeschlossen sein, dass die hinsichtlich ihrer Erbinformationen künstlich veränderte Keimbahnzelle auf einen Embryo, Fötus oder Menschen übertragen wird (§ 5 IV Nr. 2 a) ESchG) oder aus ihr eine Keimzelle entsteht (§ 5 IV Nr. 2 b) ESchG). Ebenso wie im Rahmen von § 5 IV Nr. 1 ESchG ist dies rein objektiv zu beurteilen: Getroffene Sicherheitsvorkehrungen oder der biologische Zustand der Zelle muss für einen sachverständigen Beobachter den Schluss zulassen, dass Transfer und Keimzellenentstehung ausgeschlossen sind.<sup>236</sup>

§ 5 IV Nr. 3 ESchG schließlich nimmt bestimmte Praktiken, die typischerweise mit einem bedeutenden Risiko für das Erbgut von Keimbahnzellen des Patienten einhergehen, aus dem Anwendungsbereich des § 5 I ESchG heraus. Hierzu gehören Impfungen, strahlen-, chemotherapeutische und solche Behandlungen, mit denen eine Veränderung der Erbinformation nicht beabsichtigt ist. Schädlich ist hier lediglich die Absicht der genetischen Veränderung, das heißt *dolus directus* ersten Grades. Solange es dem die in Nr. 3 genannten Verfahren Durchführenden jedoch nicht auf die Veränderung gerade ankommt, sondern er diese lediglich als mögliche Folge erkennt und billigt (*dolus eventualis*/bedingter Vorsatz) oder sogar als sicher voraussieht (*dolus directus* zweiten Grades/direkter Vorsatz), steht dies der Ausnahme des § 5 IV Nr. 3 ESchG nicht entgegen.<sup>237</sup>

Im Hinblick auf Keimbahnmodifikationen, die mit dem Ziel der Erreichung eines genetischen Enhancements durchgeführt werden, ist allerdings keine der genannten Ausnahmen des § 5 IV ESchG einschlägig: Hierbei ist vielmehr eine Veränderung der Erbinformation beabsichtigt. Aus der modifizierten Zelle soll gerade ein Individuum entstehen, das die beabsichtigten genetischen Merkmale aufweist. Die Zelle soll somit gerade der Befruchtung dienen.

Mangels Eingreifens dieses negativen Tatbestandsmerkmals ist daher bei der Durchführung des genetischen Enhancements mittels Keimbahnmodifikation, wie erläutert, mit Ausnahme der somatischen Kerntransplantation nach genetischer Veränderung der anfänglichen Somazelle, der objektive Tatbestand des § 5 I ESchG erfüllt.

#### bb) Der subjektive Tatbestand: Vorsatz in Bezug auf den objektiven Tatbestand

Gemäß § 15 StGB, der ausweislich des Art. 1 EGStGB auch für das Nebenstrafrecht von Bund und Ländern gilt, ist zur Verwirklichung des Tatbestandes vorbehaltlich spezieller, anderes vorsehender Vorschriften stets Vorsatz erforderlich. Unter Vorsatz versteht man die Kenntnis der den Tatbestand ausmachenden Umstände

<sup>236</sup> Günther/Taupitz/Kaiser-Günther, Embryonenschutzgesetz, § 5 Rdnr. 21.

<sup>237</sup> Günther/Taupitz/Kaiser-Günther, Embryonenschutzgesetz, § 5 Rdnr. 22; zu den unterschiedlichen Arten des Vorsatzes siehe sogleich.

und der Wille zu deren Verwirklichung.<sup>238</sup> Diesbezüglich sind folgende Abstufungen denkbar: Hat der Täter Absicht (*dolus directus* ersten Grades), dann kommt es ihm gerade auf die Tatbestandsverwirklichung an.<sup>239</sup> Handelt er hingegen mit direktem Vorsatz (*dolus directus* zweiten Grades), so weiß er, dass sein Handeln die Tatbestandsverwirklichung zur Folge haben wird.<sup>240</sup> Beim Eventualvorsatz (*dolus eventualis*) liegt nach herrschender Meinung Vorsatz vor, wenn der Täter den Erfolgseintritt als möglich und nicht ganz fern liegend erkennt und billigt.<sup>241</sup> Bei der Durchführung von an der menschlichen Keimbahn ansetzenden Enhancement-Maßnahmen kommt es den handelnden Subjekten gerade auf eine Veränderung der ihr zugehörigen Zellen an. Der subjektive Tatbestand des § 5 I ESchG ist mithin ebenfalls erfüllt.

Das an der Keimbahn ansetzende genetische Enhancement ist also mit Ausnahme der Kerntransplantation nach vorheriger genetischer, verbessernder Modifizierung der Somazelle, deren Zellkern in die entkernte Eizelle eingebracht werden soll, tatbestandlich von dem Verbot des § 5 I, IV ESchG erfasst.

## 2. Das Verbot des § 5 II ESchG

Das Verbot der künstlichen Veränderung der Erbinformation einer menschlichen Keimbahnzelle gemäß § 5 I, IV ESchG wird mittels der in § 5 II ESchG getroffenen Regelung um das Verbot ihrer Verwendung zur Befruchtung ergänzt. Dabei liegt eine Verwendung zur Befruchtung bereits dann vor, wenn der Täter die Absicht hat, Ei- und Samenzelle, wovon mindestens eine künstlich verändert worden sein muss, zu einer Zygote zu vereinigen. Da es für die Vollendung der Tat somit nicht der tatsächlichen Befruchtung bedarf, ist in diesem Fall für die Versuchsstrafbarkeit, die in § 5 III ESchG angeordnet wird, nur wenig Raum.<sup>242</sup>

Im Hinblick auf Maßnahmen, die zum Zwecke eines genetischen Enhancements an der Keimbahn durchgeführt werden, ist auch der § 5 II ESchG stets erfüllt, da das Ziel darin liegt, einen Embryo zu schaffen, der die gewünschte genetische Disposition aufweist. Gerade hierum geht es den handelnden Personen. Entsprechend weisen sie sogar Absicht im Sinne eines *dolus directus* ersten Grades auf, der die geschilderten, zum objektiven Tatbestand gehörenden Umstände umfasst, weswegen auch der subjektive Tatbestand des § 5 II ESchG bei der Vornahme einer Keimbahnmanipulation zur Erreichung eines genetischen Enhancements erfüllt ist.

<sup>238</sup> RGSt 51, 305 (311); BGHSt 36, 1 (9 ff.); Lackner/Kühl, StGB, § 15 Rdnr. 3 f.; Fischer, StGB, § 15 Rdnr. 3 f.; Roxin, Strafrecht AT I, § 12 Rdnr. 4.

<sup>239</sup> Schönke/Schröder-Cramer/Sternberg-Lieben, StGB, § 15 Rdnr. 66; Fischer, StGB, § 15 Rdnr. 6; Roxin, Strafrecht AT I, § 12 Rdnr. 7 ff.; Wessels/Beulke, Strafrecht AT, Rdnr. 211.

<sup>240</sup> Schönke/Schröder-Cramer/Sternberg-Lieben, StGB, § 15 Rdnr. 68; Fischer, StGB, § 15 Rdnr. 7; Roxin, Strafrecht AT I, § 12 Rdnr. 18 ff.; Wessels/Beulke, Strafrecht AT, Rdnr. 213.

<sup>241</sup> RGSt 76, 115 (116); BGHSt 36, 1 (9 f.); 44, 99 (101 ff.); zu den unterschiedlichen Meinungen bezüglich der Voraussetzungen des *dolus eventualis* siehe exemplarisch Wessels/Beulke, Strafrecht AT, Rdnr. 217 ff.

<sup>242</sup> Günther/Taupitz/Kaiser-Günther, Embryonenschutzgesetz, § 5 Rdnr. 26 f.

Werden sowohl Absatz 1 als auch Absatz 2 des § 5 ESchG durch denselben Täter verwirklicht, so liegt nur ein einheitliches Delikt vor. Handeln dabei hingegen zwei Personen, etwa ein Humangenetiker und ein Arzt, so ist neben einer Mittäterschaft auch an eine Anstiftung durch den Arzt gegenüber dem Humangenetiker zur Begehung einer Tat nach § 5 I ESchG sowie an eine Beihilfe des Humangenetikers zu der Tat gemäß § 5 II ESchG des Arztes zu denken. Hinter der täterschaftlich begangenen Variante tritt die Teilnahmehandlung dann jedoch als subsidiär zurück.<sup>243</sup>

### **3. Zwischenergebnis**

Die Durchführung genetischer Enhancements erfüllt mit Ausnahme der Kerntransplantation mittels eines zuvor genmodifizierten Zellkernes somit den objektiven sowie den subjektiven Tatbestand des § 5 I, V und des § 5 II ESchG.

## **III. Die möglichen Rechtfertigungsgründe**

Obschon das genetische Enhancement der Keimbahn gegen diese Verbote verstößt, wird es von der Rechtsordnung nicht missbilligt, soweit es auf einen Rechtfertigungsgrund gestützt werden kann.

### **1. § 3 S. 2 ESchG**

Als spezieller Rechtfertigungsgrund für die Durchführung eines genetischen Keimbahnenenhancements könnte die Ausnahmegvorschrift des § 3 S. 2 ESchG in Frage kommen. Dieser Vorschrift zufolge wird nicht bestraft, wer unter mehreren Samenzellen eine Auswahl trifft, um eine schwerwiegende Krankheit, die geschlechtsgebunden vererbt wird, zu vermeiden. Ob diese Norm allerdings rechtfertigend wirkt, ist unklar. Der Gesetzesfassung zufolge ist sie als Tatbestandseinschränkung, konkret als Strafunrechtsausschluss konzipiert. Allerdings bleibt dadurch offen, ob sich der Täter materiell im Rahmen des Rechts bewegt und sein Verhalten daher nicht missbilligt wird, oder ob er zwar Unrecht begeht, das aber nicht strafbar ist.<sup>244</sup>

Im Falle des genetischen Keimbahnenenhancements könnte dies jedoch dahinstehen, wenn § 3 S. 2 ESchG ohnehin nicht erfüllt wäre: Hierbei geht es nämlich mitnichten um die Vermeidung einer Krankheit, die von dieser Norm erfasst wäre. Hierunter fällt ausweislich des Gesetzeswortlautes eine Erkrankung an einer Muskeldystrophie vom Typ Duchenne oder eine ähnlich schwerwiegende Krankheit. Bei einem Enhancement geht es jedoch noch nicht einmal um die Vermeidung ir-

<sup>243</sup> Günther/Taupitz/Kaiser-Günther, Embryonenschutzgesetz, § 5 Rdnr. 28.

<sup>244</sup> Günther/Taupitz/Kaiser-Taupitz, Embryonenschutzgesetz, § 3 Rdnr. 15 f.

gendeiner Krankheit, sondern um die Verbesserung des – *ex ante* erwartet: gesunden – Zustandes, den der noch zu entstehende Embryo natürlicherweise aufweisen würde. Darüber hinaus geht dies nicht zwangsläufig mit einer Selektion der Samenzellen anhand des Geschlechts des zu zeugenden Embryos einher. Der Sachverhalt ist somit ein grundlegend anderer als der von § 3 S. 2 ESchG erfasste: Während die Vorschrift letztlich dazu dienen soll, vermeidbares Leid schon im Vorfeld durch Spermien Selektion auszuschließen,<sup>245</sup> soll beim Enhancement die genetische Disposition, unter der das zukünftige Individuum, da sie von einer normalen, gesunden Disposition nicht negativ abzuweichen droht, vermutlich nicht leiden würde, lediglich optimiert werden.

Aus diesen Überlegungen folgt schließlich: Sollte bei der Durchführung des Enhancements die Samenzelle geschlechtsspezifisch selektiert werden, so ist § 3 S. 2 ESchG dennoch nicht erfüllt, da es nicht um die Vermeidung einer schweren geschlechtsgebundenen Erbkrankheit geht. Eine analoge Anwendung einer Norm auf einen von ihrem Tatbestand abweichenden Sachverhalt, die vorliegend, da sie tätergünstig wäre, auch nicht dem Analogieverbot des Art. 103 II GG und § 1 StGB widerspräche,<sup>246</sup> setzt jedoch das Vorliegen einer planwidrigen Regelungslücke bei Vergleichbarkeit des normierten Falles und der nicht geregelten Fallkonstellation voraus. Hinsichtlich der Lücke kann es sich um eine primäre, dem Gesetz von Anfang an anhaftende, oder eine sekundäre, also eine erst später durch eine Änderung der Verhältnisse entstandene, Lücke handeln.<sup>247</sup>

Obschon das Gesetz keine Normierung des Falles, dass das Geschlecht zu einem verbessernden und nicht zu einem präventiven Zweck selektiert werden soll, und somit eine Regelungslücke enthält, die aufgrund des biotechnologischen und medizinischen Fortschrittes nach Erlass des Gesetzes entstanden ist, steht jedoch der analogen Anwendung der eindeutig vom Gesetzgeber intendierte Ausnahmecharakter des § 3 S. 2 ESchG<sup>248</sup> und in diesem Zusammenhang der wertungsmäßig bedeutende Unterschied zwischen Vermeidung von Leiden – der Pflicht –, und Optimierung der Gesundheit – der Kür –, entgegen. Ungeachtet des Vorliegens einer Lücke ist eine über die bloße Auslegung hinausgehende Einengung oder Erweiterung der betreffenden Vorschrift im Rahmen einer Analogie dann unzulässig, wenn ein entsprechender Wille des Gesetzgebers der Norm entnommen werden kann.<sup>249</sup> Auch eine analoge Anwendung auf den Fall, dass eine geschlechtsspezifische Selektion der Samenzellen nicht stattfindet, kommt mithin aus den genannten Gründen nicht in Frage.

<sup>245</sup> Günther/Taupitz/Kaiser-Taupitz, Embryonenschutzgesetz, § 3 Rdnr. 17.

<sup>246</sup> Fischer, StGB, § 1 Rdnr. 10; Wessels/Beulke, Strafrecht AT, Rdnr. 52, 54; Jescheck/Weigend, Lehrbuch des Strafrechts, § 15 III 2. d).

<sup>247</sup> Schönke/Schröder-Eser, StGB, § 1 Rdnr. 24; Lackner/Kühl, StGB, § 1 Rdnr. 5.

<sup>248</sup> Das grundsätzliche Verbot und die nur ausnahmsweise Zulässigkeit ergeben sich aus der Überschrift der Norm, die mit „Verbotene Geschlechtswahl“ betitelt ist, vergleiche Günther/Taupitz/Kaiser-Taupitz, Embryonenschutzgesetz, § 3 Rdnr. 15 unter Verweis auf *Deutscher Bundestag*, Drucksache 11/8057, S. 15.

<sup>249</sup> Schönke/Schröder-Eser, StGB, § 1 Rdnr. 35.

## 2. Notwehr, § 32 StGB, und rechtfertigender Notstand, § 34 StGB

Auch die rechtfertigenden Tatbestände der Notwehr gemäß § 32 StGB und des Notstandes gemäß § 34 StGB vermögen ein die Keimbahn modifizierendes genetisches Enhancement mangels Notwehr-, respektive Notstandslage nicht zu rechtfertigen.

§ 32 StGB würde hierfür zunächst einen gegenwärtigen und rechtswidrigen Angriff voraussetzen. Hierunter ist jede tatsächliche, unmittelbar bevorstehende oder gerade stattfindende Bedrohung rechtlich geschützter Individual-Interessen des Verteidigers oder eines anderen durch menschliches Verhalten zu verstehen, das der Betroffene aufgrund seines Erfolgsunwertes nicht zu dulden braucht beziehungsweise das im Widerspruch zur Rechtsordnung steht und somit neben dem Erfolgs- auch einen Handlungsunwert aufweist.<sup>250</sup> § 34 StGB würde verlangen, dass aufgrund von tatsächlich vorliegenden Umständen bei objektiver Beurteilung *ex ante* der Eintritt eines Schadens für ein rechtlich anerkanntes Interesse des Täters oder eines Dritten wahrscheinlich ist, also eine Gefahr dafür vorliegt, die gegenwärtig sein, also jederzeit in einen Schaden umschlagen können müsste, wenn nicht alsbald Abwehrmaßnahmen ergriffen würden.<sup>251</sup>

Bei einem Keimbahneingriff, der zu Zwecken des genetischen Enhancements vorgenommen wird, liegt der handelnden Person, deren weiteres Verhalten zu rechtfertigen wäre, also des Gentechnikers oder Arztes beziehungsweise des Paares, das die genetische Ausstattung seines künftigen Kindes optimieren möchte, eine Ei- oder Samenzelle, eine Zygote oder embryonale Stammzelle vor. Von ihnen müssten somit Umstände ausgehen, die zu der geschilderten Notwehr- beziehungsweise Notstandslage beitragen müssten. Betroffen sein könnten von dieser Lage sodann das (noch zu zeugende) Kind beziehungsweise die (künftigen) Eltern. Dabei ist jedoch davon auszugehen, dass das Eingriffsobjekt gesund ist, das heißt keine erblich bedingten Krankheiten oder anderweitige Chromosomenaberrationen aufweist. Ansonsten befände man sich nämlich nicht mehr im Bereich des Enhancements, sondern vielmehr in dem der Präimplantationsdiagnostik beziehungsweise der pränidativen Gentherapie. So jedoch ist davon auszugehen, dass aus den Eingriffsobjekten ein gesunder Embryo hervorgehen wird, dessen – wenn auch nur biologisch-zufällig kombinierten – genetische Anlagen mithin nicht negativ von dem speziestypischen funktionalen Normalmaß<sup>252</sup> abweichen.

Gesund zu sein ist jedoch schon dem allgemeinen Begriffsverständnis zufolge mitnichten gleichbedeutend mit einem Schaden; seitens des konkreten (noch zu zeugenden) Embryos kann somit nicht von einer Gefährdung gesprochen werden.

<sup>250</sup> Fischer, StGB, § 32 Rdnr. 4 ff., 11, 16 ff., 21; Lackner/Kühl, StGB, § 32 Rdnr. 2 ff.; Roxin, Strafrecht AT I, § 15 Rdnr. 6, 14 ff., 21 ff.; Wessels/Beulke, Strafrecht AT, Rdnr. 325 ff.

<sup>251</sup> Fischer, StGB, § 34 Rdnr. 3, 4; Lackner/Kühl, StGB, § 34 Rdnr. 2, 4; Roxin, Strafrecht AT I, § 16 Rdnr. 12 ff.; Wessels/Beulke, Strafrecht AT, Rdnr. 299 ff.

<sup>252</sup> Meiner Einschätzung zufolge ist es berechtigt, in diesem Zusammenhang ausschließlich hierauf Bezug zu nehmen. Zumindest im frühen Embryonalstadium können subjektive Empfindungen von Gesundheit noch ungeachtet bleiben. Auch sind etwaige schädliche Umwelteinflüsse hier noch nicht vorhersehbar und daher nicht zu berücksichtigen.

Da ein gesunder Embryo darüber hinaus auch für die Mutter während der Schwangerschaft kein besonderes gesundheitliches Risiko oder danach keine über das Normalmaß hinausgehende Belastung der Eltern darstellt, ist auch hier die Gefahr eines Schadens abzulehnen. Ein Angriff wird zudem häufig schon deswegen nicht zu erblicken sein, da zu dem Zeitpunkt, auf den im Hinblick auf das Bestehen einer Notwehrlage abzustellen ist, nämlich der Zeitpunkt der zu rechtfertigenden Tat, das heißt hier der künstlichen Veränderung einer Keimbahnzelle, respektive Nutzung dieser veränderten Zelle zur Befruchtung, ein Rechtsgüter bedrohendes menschliches Verhalten noch nicht stattfinden kann. Sind von der Tat Samen- oder Eizellen oder eine Zygote betroffen, so liegt schon kein Individuum vor. Selbst einem Embryo in einem derart frühen Stadium kann kein Verhalten im Sinne eines Willküraktes, der beherrschbar wäre, zugeschrieben werden.

Weder § 32 StGB noch § 34 StGB tragen somit zur Rechtfertigung eines Verstoßes gegen § 5 I und § 5 II ESchG bei.

### **3. Rechtfertigende Einwilligung**

Die Handlungen im Sinne der § 5 I und § 5 II ESchG könnten jedoch mangels Rechtswidrigkeit nicht strafbar sein, wenn sie durch eine Einwilligung gerechtfertigt wären.

Dies setzt voraus, dass die Einwilligung zunächst überhaupt rechtlich zulässig, das Rechtsgut, auf dessen Schutz verzichtet werden soll, also disponibel ist, und die Einwilligung von einer hinsichtlich dieses Rechtsguts Verfügungsberechtigten und einwilligungsfähigen Person vor der Tat explizit oder konkludent erklärt wurde und diese nicht an wesentlichen Willensmängeln leidet. Die durch die Einwilligung zu rechtfertigende Tat dürfte weiter nicht gegen die guten Sitten verstoßen und müsste in Kenntnis und aufgrund der Einwilligung vorgenommen worden sein.<sup>253</sup>

#### **a) Proxy consent**

Da das Individuum, welches später von dem Keimbahn-Enhancement betroffen sein wird und dessen Leben und körperliche Integrität primäres Schutzgut der § 5 I, II ESchG ist,<sup>254</sup> zu dem Zeitpunkt, auf den es für eine Einwilligungserklärung ankommt, nämlich der Zeitraum vor der Tathandlung, rein tatsächlich noch nicht einwilligungsfähig und unter Umständen noch nicht einmal existent ist, wäre als Rechtfertigungsgrund lediglich die Einwilligung der zukünftigen Eltern des (noch zu zeugenden) Kindes denkbar.

<sup>253</sup> Schönke/Schröder-Lenckner, StGB, Vorbem §§ 32 ff. Rdnr. 35 ff.; Jescheck/Weigend, Lehrbuch des Strafrechts, § 34 IV, V; Wessels/Beulke, Strafrecht AT, Rdnr. 372 ff.

<sup>254</sup> Günther/Taupitz/Kaiser-Günther, Embryonenschutzgesetz, § 5 Rdnr. 2 ff.

Zunächst ist diesbezüglich festzuhalten, dass eine etwaige Einwilligungsbefugnis der Gametenspender nicht aus deren Grundrecht aus Art. 2 I in Verbindung mit Art. 1 I GG resultiert.<sup>255</sup> Hat eine Verschmelzung von Ei- und Samenzelle bereits stattgefunden, so ist damit eine neue Identität entstanden, die, vage formuliert und vorbehaltlich später anzustellender detaillierter Analysen, eine eigene rechtliche Stellung innehat und aus dem Persönlichkeitsbereich der Gametenspender herausgenommen ist. Aber auch zuvor sind diese nicht die originär Einwilligungsbefugten. Zwar manipulieren sie, da mangels Verschmelzung von Ei- und Samenzelle noch kein anderweitiges Individuum entstanden ist, nicht an einer Entität, die schon als ihr im Embryonalstadium vorliegendes Kind charakterisiert werden könnte, sondern vielmehr an den bloßen Gameten und damit an sich selbst. Soll jedoch die Rechtswidrigkeit einer strafatbestandlichen Handlung durch eine rechtfertigende Einwilligung beseitigt werden, so ist hinsichtlich der Frage, auf wessen Einwilligung es ankommt, auf den Schutzzweck der jeweiligen Norm, aufgrund derer eine Strafbarkeit gegeben sein könnte, abzustellen. Vorliegend ergibt sich aus diesen Überlegungen, dass, da § 5 I, II ESchG nicht die Gametenspender, sondern die sich aus den Gameten entwickelnde Entität schützen will, es auf die Rechtspositionen des künftigen Kindes ankommt, die schützenswert sind und die gegebenenfalls ein staatliches Verbot verlangen. Eine Einwilligung durch die zukünftigen Eltern wäre damit nur als ein Fall des *proxy consent* im Rahmen der §§ 1626 ff. BGB möglich, denen zufolge die Eltern zur Wahrung und Förderung des Kindeswohl verpflichtet sind. Dies jedoch konfrontiert den Rechtsanwender im Zusammenhang mit genetischen Modifikationen mit immensen Schwierigkeiten.

Fraglich ist zunächst einmal, ob die bürgerlich-rechtlichen Vorschriften über die elterliche Sorge überhaupt schon vor Entstehung des künftigen Kindes, das heißt lediglich im Hinblick darauf, dass aus der Ei- und einer Samenzelle einmal ein Kind entstehen wird, oder in Ansehung dieses Kindes, beziehungsweise im frühen Stadium der Zygote überhaupt anwendbar sind:

Ist es noch nicht zur Verschmelzung von Ei- und Samenzelle gekommen, ist also noch keine neue Entität, die Träger irgendwelcher Rechte sein könnte, also noch kein zu berücksichtigendes Rechtssubjekt entstanden. Eindeutig ist hier der Anwendungsbereich der §§ 1626 ff. BGB nicht eröffnet.

Ist jedoch bereits eine Zygote entstanden, liegt grundsätzlich auch ein neues Rechtssubjekt vor. Ausweislich des Wortlautes des § 1 BGB beginnt die zivilrechtliche Rechtsfähigkeit jedoch erst mit Vollendung der Geburt. Erst ab diesem Zeitpunkt findet eine zivilrechtliche Berücksichtigung statt. Vorgeburtliche Sachverhalte sind grundsätzlich vom BGB nicht erfasst. Davon abweichende Ausnahmen werden im Gesetz explizit genannt. So bestimmt beispielsweise § 1923 II BGB, dass auch jemand, der zum Erben eingesetzt ist, aber zum Zeitpunkt des Erbfalls noch nicht geboren, wohl aber gezeugt war, als vor dem Erbfall geboren und somit als erbfähig im Sinne des § 1923 I BGB gilt. Eine solche Ausnahmeregelung fehlt aber in den §§ 1626 ff. BGB. Insbesondere ist zu betonen, dass über den § 1923 II BGB lediglich die Geburt fingiert wird, nicht jedoch die Zeugung, derer es weiterhin be-

<sup>255</sup> Lorenz, Embryonenforschung als Humanexperiment, S. 450.



darf. Auch die Anwendung des § 823 I BGB auf Gesundheitsschädigungen des *na-sciturus* spricht nicht für eine vorgeburtliche Anwendung zivilrechtlicher Vorschriften. Grund für die Zuerkennung eines Schadensersatzanspruches eines geborenen Kindes aufgrund eines Sachverhaltes, der sich noch vor dessen Geburt zugetragen hat, ist nämlich nach ganz herrschender Meinung dessen Manifestation in der Geburt als kranker Mensch. Es reicht aus, dass sich die schädigende Handlung irgendwann einmal an einem geborenen und damit rechtsfähigen Menschen im Sinne des § 1 BGB auswirkt.<sup>256</sup> Ein Schadensersatzanspruch entsteht konsequenterweise daher auch nicht bereits zum Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses, sondern erst mit Geburt. Auch hier ist die Geburt somit *conditio sine qua non* für eine zivilrechtliche Rechtsposition des lebenden (das heißt hier: geborenen) Menschen, wenn auch im Hinblick auf einen vor der Geburt stattgefunden habenden Sachverhalt. Schließlich ergeben sich auch aus dem thematisch nahen Art. 6 II 1 GG keine anderweitigen Implikationen. Wie später festgestellt werden wird, ist dessen Schutzbereich ebenfalls erst mit Geburt des Kindes eröffnet.

Die §§ 1626 ff. BGB sind somit vor Geburt nicht anwendbar. Eine rechtfertigende Einwilligung der künftigen Eltern im Rahmen ihrer elterlichen Sorge kommt somit nicht in Betracht.

Wollte man hier Gegenteiliges annehmen, würde sich darüber hinaus auch die Tatsache als äußerst problematisch erweisen, dass *das* Kind, dessen Rechtsgüter aufgrund der genetischen Veränderung verletzt werden könnten, nie zur Entstehung gelangt, sondern immer nur in der modifizierten Form. Ob der in Frage stehende genetische Eingriff für das Kindeswohl förderlich ist oder Rechtsgüter des Kindes beeinträchtigt, kann somit nicht festgestellt werden, eine Zurechnung kann nicht vorgenommen werden. Das Kind, welches geboren wird, kann, so die Logik, den Eltern nicht vorwerfen, so geboren zu sein, denn dies würde den Vorwurf der eigenen Existenz bedeuten.<sup>257</sup> Ob jemand durch die eigene Existenz geschädigt ist, also ob es für dieses Individuum besser gewesen wäre, gar nicht erst geboren worden zu sein, wird aber zu Recht nur in ganz seltenen Ausnahmen diskutiert.<sup>258</sup> Aufgrund dieses sogenannten Problems der Nichtidentität<sup>259</sup> ist die Vergleichbarkeit der Situation des tatsächlich erzeugt werdenden Kindes nach seiner Erzeugung und dem Kind, das ohne die Genmodifikation gezeugt worden wäre, nicht möglich. Man könnte höchstens sagen, dass es jemandem gut oder schlecht geht, nie aber, dass es

<sup>256</sup> BGHZ 8, 243 (248 f.); 86, 240 (253); BeckOK BGB-Spindler, S. 823 Rdnr. 34; Deutsch, NJW 1986, 757.

<sup>257</sup> Anderer Meinung ist Spaemann, DZPhil 50, 105 (107).

<sup>258</sup> Diskutiert wird dies zum Beispiel bei Kindern, die mit der genetisch bedingten Hautkrankheit *Epidermolysis bullosa* geboren werden. Der Krankheitsverlauf des Subtyps *Epidermolysis bullosa atrophicans letalis* (Typ Herlitz) wird geschildert von Merkel, JZ 1996, 1145 (1150 f.).

<sup>259</sup> Dieses geht auf Derek Parfit und das von ihm konzipierte *Non-Identity Problem* zurück: Parfit, Reasons and Persons, S. 351 ff.; Roberts, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Eintrag „The Nonidentity Problem“.



jemandem besser oder schlechter gegangen wäre, hätten die Eltern keine Genmodifikation durchführen lassen.<sup>260</sup>

Eine rechtfertigende Einwilligung ist in direkter Anwendung der Vorschriften über die elterliche Sorge somit nicht möglich.

## **b) Analogie der personensorgerechtlichen Vorschriften**

Eine Einwilligung durch die zukünftigen Eltern wäre dementsprechend nur analog der in § 1626 I 2 1. Alt. BGB vorgesehenen, altruistischen Personensorge konstruierbar.<sup>261</sup> Hierbei handelt es sich weniger um eine rechtsgeschäftliche Einwilligung als vielmehr um die Gestattung des Eingriffs als tatsächliche Handlung durch die gesetzlichen Vertreter in Personensorgesachen.<sup>262</sup>

Wie bereits festgestellt, enthält die Rechtsordnung keine expliziten Vorschriften, die sich auf einen solchen Sachverhalt beziehen. Eine Regelungslücke liegt mithin vor. Diese müsste darüber hinaus auch nachträglich, also nach Erlass des Gesetzes entstanden, und planwidrig, das heißt nicht vom Gesetzgeber intendiert sein. Schließlich müssten auch die geregelte sowie die zu regelnde Interessenlage vergleichbar sein. Auch im Hinblick hierauf ist problematisch, dass das Individuum, das von § 5 I, II ESchG geschützt wird, zum Zeitpunkt des genverbessernden Eingriffs in die Gameten noch nicht einmal existent, beziehungsweise im Falle der genetischen Modifizierung der Zygote noch nicht geboren ist. Andererseits gilt es zu bedenken, dass auch das Embryonenschutzgesetz seinen Schutzzweck auf noch nicht existierende (und entsprechend auch auf noch nicht geborene) Individuen erstreckt, indem es, eben in § 5 I und II ESchG, zu vermeiden sucht, dass Menschen aus medizintechnologischen Verfahren hervorgehen werden, die bislang unkontrollierbare Folgen für ihre Gesundheit und sogar Lebensfähigkeit haben können und – so legt es zumindest vorläufig der Stand der Forschung nahe – wahrscheinlich auch haben werden. Dass auch die Einwilligung in Vertretung für diese ungeborene oder gar nur zukünftige Person in Analogie zu § 1626 I 2 1. Alt. BGB erklärt werden könnte, erscheint somit nur folgerichtig.

Nähme man hiermit die Möglichkeit der Vertretung einer noch nicht bestehenden oder ungeborenen Person an, so ist jedoch fraglich, ob das Rechtsgut, auf dessen Schutz verzichtet werden soll, disponibel ist. In Frage stehen hier die körperliche Unversehrtheit und das Leben des Individuums, bei dem sich das an einer Keimbahnzelle vorgenommene genetische Enhancement auswirken wird, welche über

<sup>260</sup> Glover, *Choosing Children*, S. 74. Glover schlägt zur Lösung dieses Problems eine Abwandlung des Mill'schen *harm principles* vor und will dieses auch auf transpersonale Schädigungen anwenden. Demzufolge wäre zu fragen, so Glover, *Choosing Children*, S. 75, ob es den Personen, die aufgrund der Durchführung der einen Handlungsalternative existieren, schlechter geht, als es den Personen, die bei Untätigkeit oder dem Verfolgen einer anderen Handlungsoption in Existenz gelangt wären, gegangen hätte.

<sup>261</sup> Lorenz, *Embryonenforschung als Humanexperiment*, S. 451.

<sup>262</sup> Schönke/Schröder-Lenckner, *StGB*, Vorbem §§ 32 ff. Rdnr. 41.

Art. 2 II 1 GG geschützt sind. Umstritten ist schon, ob der Schutz des Art. 2 II 1 GG<sup>263</sup> bereits mit der Befruchtung der Eizelle einsetzt oder erst, wenn die Nidation, das heißt die Einnistung in die Gebärmutter, abgeschlossen ist.<sup>264</sup> Erst recht ist man sich uneins, ob auch extrakorporal erzeugtes Leben geschützt ist.<sup>265</sup> Eine Entscheidung könnte allerdings vorerst dahinstehen, wenn ohnehin eine Einwilligung aufgrund mangelnder Dispositionsbefugnis des Rechtsgutsträgers oder seines Vertreters nicht in Frage kommt. Bei den durch die §§ 1 I Nr. 2 und 5, 2 I, II sowie 6 I ESchG geschützten Rechtsgütern handelt es sich um das Leben und die Menschenwürde. Insbesondere diese untersteht aufgrund ihrer hervorgehobenen Bedeutung besonderem Schutz, der sich unter Umständen sogar gegen den Grundrechtsträger selbst richtet. So verbietet Art. 1 I GG, dass sich das durch diese Norm geschützte Individuum freiwillig beispielsweise einer Situation aussetzt, in der es anderen in einer Weise hilflos ausgeliefert ist, die es als Objekt fremden Willens und fremden Handelns erscheinen lässt. Eine Einwilligung in eine Würdeverletzung durch einen Dritten und auch ein die eigene Würde verletzendes eigenes Verhalten scheiden somit aufgrund der überragenden Bedeutung des Art. 1 I GG aus. Gleiches muss auch hinsichtlich des Grundrechts auf Leben gelten. Zwar ist dies nicht unumstritten und freilich lässt sich im Hinblick auf einen wertenden Vergleich mit den anderen verfassungsrechtlichen Freiheitsrechten, welche stets auch das jeweils negative Recht, d. h. beispielsweise das Recht, keinem Verein anzugehören (Art. 9 I GG) oder keine Ehe einzugehen und keine Kinder zu bekommen (Art. 6 I GG), und die damit korrespondierende Freiheit von entsprechendem Zwang umfassen, auch für ein Recht auf Tod argumentieren. Allerdings ist das Recht auf Leben nicht nur die vitale Basis aller weiterer Grundrechte und der (wie soeben dargestellt: unverzichtbaren) Menschenwürde, sondern die Ausübung eines etwaigen negativen Rechts auf Leben auch stets – und hierin liegt der bedeutende Unterschied zu den übrigen negativen Grundrechten – endgültig und unumkehrbar. Zumindest aber ein Recht, andere über das eigene Leben verfügen zu lassen, scheidet aus. Die durch die §§ 1 I Nr. 2 und 5, 2 I, II sowie 6 I ESchG geschützten Grundrechte, jedenfalls aber die Menschenwürde, sind daher der Dispositionsbefugnis des Rechtsträgers grundsätzlich entzogen.<sup>266</sup> Eine rechtfertigende Einwilligung durch Dritte kann daher in jedem Fall und erst recht nicht erfolgen.<sup>267</sup>

Es besteht somit keine Möglichkeit, Verstöße gegen das Embryonenschutzgesetz bei Durchführung eines genetischen Enhancements an Keimbahnen durch eine Einwilligung zu rechtfertigen.

<sup>263</sup> Für das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit gilt nichts anderes, vergleiche *Jarass/Pieroth*, GG, Art. 2 Rdnr. 85.

<sup>264</sup> Das Bundesverfassungsgericht hat Letzteres bejaht, Ersteres indes offengelassen: BVerfGE 39, 1 (37); 88, 203 (251 f.).

<sup>265</sup> *Jarass/Pieroth*, GG, Art. 2 Rdnr. 82.

<sup>266</sup> Vergleiche *Jarass/Pieroth*, GG, Vorb. vor Art. 1 Rdnr. 36, Art. 1 Rdnr. 9, Art. 2 Rdnr. 86; ebenfalls ein negatives Recht auf Leben, das heißt auf die Selbsttötung, ablehnend *Dreier-Schulze-Fielitz*, GG, Art. 2 II Rdnr. 32.

<sup>267</sup> *Böckenförde-Wunderlich*, Präimplantationsdiagnostik, S. 142.

#### 4. § 218a II StGB analog

Da zum Zeitpunkt der zu rechtfertigenden Handlung, der Durchführung des genetischen Enhancements durch Modifizierung der Erbinformation der Keimbahnzellen, keine Schwangerschaft vorliegt, scheidet eine unmittelbare Anwendung des § 218a II StGB aus. In Frage kommt somit nur eine analoge Anwendung dieser Vorschrift. Richtigerweise ist für die Analogie die aktuell geltende Rechtslage zu beachten, das heißt also die neue Fassung des § 218a II StGB heranzuziehen und nicht dessen alte Fassung, wie sie zum Zeitpunkt des Erlasses des Embryonenschutzgesetzes galt. Dort sah § 218a II Nr. 1 StGB noch die Strafflosigkeit eines Schwangerschaftsabbruches bei embryopathischer Indikation vor, nämlich dann, wenn *„nach ärztlicher Erkenntnis dringende Gründe für die Annahme sprechen, daß das Kind in Folge einer Erbanlage oder schädlicher Einflüsse vor der Geburt an einer nicht behebbaren Schädigung seines Gesundheitszustandes leiden würde, die so schwer wiegt, dass von der Schwangeren die Fortsetzung der Schwangerschaft nicht verlangt werden kann.“*<sup>268</sup> Dennoch bleibt auch nach der neuen Fassung der Schwangerschaftsabbruch bei einer durch die Geburt eines schwerstbehinderten Kindes zu befürchtende Beeinträchtigung der psychischen und physischen Gesundheit der Mutter möglich.

Auch hier stünden Art. 103 II GG sowie § 1 StGB einer Analogie nicht entgegen, da es sich um eine Analogie zu Gunsten des Täters handeln würde.<sup>269</sup> Voraussetzung wäre aber weiterhin das Vorliegen einer planwidrigen Regelungslücke bei vergleichbarer Interessenlage des normierten Falls und der nicht geregelten Sachlage<sup>270</sup> sowie dass einer über die bloße Auslegung hinausgehenden Einengung oder Erweiterung der betreffenden Vorschrift nicht erkennbar der Wille des Gesetzgebers beziehungsweise Teleologie und Wertung des Embryonenschutzgesetzes entgegenstehen.<sup>271</sup>

Wie oben bereits festgestellt, enthält die Rechtsordnung keinerlei unmittelbare und nicht bloß akzidentielle Regelung bezüglich der verbessernden genetischen Modifikation von Zellen der Keimbahn. Diese Lücke ist mit den wachsenden medizinischen und bio-technologischen Möglichkeiten entstanden und stellt somit eine sekundäre, nachträglich entstandene Lücke dar. Da der Gesetzgeber des Embryonenschutzgesetzes derart weitreichende Eingriffsmöglichkeiten im Jahre 1990 noch nicht vorhergesehen hat, ist die Lücke auch eine unbeabsichtigte. Jedoch gilt es nicht, diese im Wege einer Analogie zu schließen. Vielmehr obliegt die Erörterung, Würdigung und Bewertung des genetischen Keimbahn-Enhancements dem Gesetzgeber. § 218a II StGB beruht auf der Erwägung, dass eine Schwangere in

<sup>268</sup> Zitiert nach Böckenförde-Wunderlich, Präimplantationsdiagnostik, S. 144.

<sup>269</sup> Vergleiche Fischer, StGB, § 1 Rdnr. 10; Wessels/Beulke, Strafrecht AT, Rdnr. 52, 54; Jescheck/Weigend, Lehrbuch des Strafrechts, § 15 III 2. d).

<sup>270</sup> Schönke/Schröder-Eser, StGB, § 1 Rdnr. 24; Lackner/Kühl, StGB, § 1 Rdnr. 5.

<sup>271</sup> Vergleiche Schönke/Schröder-Eser, StGB, § 1 Rdnr. 35.

menschlich unzumutbarer Weise überfordert wäre, würde man von ihr das Austragen einer Schwangerschaft gar auf Kosten ihres Lebens oder ihrer physischen und psychischen Gesundheit verlangen.<sup>272</sup> Der Fall der genetischen Modifizierung einer Keimbahnzelle ist hingegen vollständig anders gelagert. Eine Unzumutbarkeit, die auf einer Belastung beruht, die drastisch über das mit einer Schwangerschaft und dem Aufziehen eines Kindes üblicherweise verbundene Maß hinausgeht, ist in der Schwangerschaft beziehungsweise dem späteren Leben mit einem „nur“ gesunden, nicht aber optimierten Kind keinesfalls zu erkennen. Der Interessenausgleich, wie ihn § 218a II StGB trifft, ist somit im Rahmen des Keimbahn-Enhancements nicht sachgerecht, die Interessenlagen sind keineswegs vergleichbar. Da diese Bewertung jedoch dem Gesetzgeber obliegt, verbietet sich eine Analogie.

Auch § 218a II StGB kann mithin nicht zur Rechtfertigung eines verbessernden Eingriffes in eine Keimbahnzelle herangezogen werden.

## IV. Ergebnis

Es ist somit festzuhalten, dass Maßnahmen des genetischen Enhancements, die an Keimbahnzellen durchgeführt werden, dem Regelungsbereich des § 5 I, IV ESchG und § 5 II ESchG unterfallen und mangels Eingreifens eines Rechtfertigungsgrundes verboten sind.

---

<sup>272</sup> Schönke/Schröder-Eser, StGB, § 218a Rdnr. 26.

# Kapitel 6: Modifizierung somatischer Zellen

Auch im Hinblick auf die verbessernde Veränderung somatischer Zellen existieren keine Vorschriften, die erlassen wurden, um diesen konkreten Sachverhalt zu erfassen. Hingegen sind Eingriffe in ausdifferenzierte Zellen mit therapeutischer Zielsetzung durchaus Gegenstand verschiedener Regelungsvorhaben gewesen. Daneben wird zu prüfen sein, ob die Verfahren, die zum Zwecke des genetischen Enhancements an somatischen Zellen durchgeführt werden, von bestehenden Tatbeständen des Strafgesetzbuches erfasst werden und daher strafbewehrt sind.

## I. Strafrechtliche Legitimation somatischer Enhancements?

Hinsichtlich der Straftaten gegen das Leben oder die körperliche Unversehrtheit enthält das Strafgesetzbuch in den §§ 211 ff. und §§ 223 ff. StGB grundsätzlich nur andere Personen schützende Tatbestände. Nach ganz herrschender Meinung sind dies ausschließlich geborene Personen, da sich aus der Gesetzssystematik ergibt, dass das ungeborene, aber bereits in der Gebärmutter implantierte Leben, also die Leibesfrucht, allein Schutzgut der Regelungen über den Schwangerschaftsabbruch in den §§ 218 ff. StGB ist. Diese Exklusivität für pränatale Stadien gilt auch in Bezug auf Körperverletzungsdelikte.<sup>273</sup> § 218 I 2 StGB nimmt dabei Handlungen, deren Wirkung vor Abschluß der Einnistung des befruchteten Eies in der Gebärmutter eintritt, aus dem Anwendungsbereich der §§ 218 ff. StGB und damit auch des Strafgesetzbuches als solchen aus. Diese Zurückhaltung des Strafrechts in Bezug auf den Zeitraum vor Einnistung in die Gebärmutter ist auch nur sinnvoll, ist das Ereignis der Befruchtung vor der Etablierung einer Schwangerschaft aufgrund deren Unsicherheit kaum zu beweisen.<sup>274</sup>

---

<sup>273</sup> BeckOK StGB-Eschelbach, § 223 Rdnr. 12 m.w.N.

<sup>274</sup> Wagner, Der gentechnische Eingriff in die menschliche Keimbahn, S. 59.

## 1. §§ 218 ff. StGB

Genetische Eingriffe, die vor der Geburt des Kindes an bereits ausdifferenzierten Zellen des Embryos *post nidationem* vorgenommen werden, sind anhand der §§ 218 ff. StGB zu bewerten. Bislang stellen Genverbesserungen eine immense Gefahr für die Entität, an der diese vorgenommen werden, dar. An Embryonen angewendet könnte es durchaus zu unabsehbaren Folgen und gegebenenfalls auch zum Abgang der Leibesfrucht als Folge der Einwirkung kommen. Gemäß § 15 StGB ist zur Verwirklichung des Tatbestandes vorbehaltlich spezieller, anderes vorsehender Vorschriften jedoch stets Vorsatz erforderlich. Unter Vorsatz versteht man die Kenntnis der den Tatbestand ausmachenden Umstände und der Wille zu deren Verwirklichung.<sup>275</sup> Da die §§ 218 ff. StGB kein Erfordernis einer besonderen Vorsatzform enthalten, ist auch Eventualvorsatz (*dolus eventualis*) ausreichend. Dieser liegt nach herrschender Meinung vor, wenn der Täter den Erfolgseintritt als möglich und nicht ganz fern liegend erkennt und billigt.<sup>276</sup> Das voluntative Element umfasst dabei nicht eine positive Bewertung des Erfolgseintrittes. Vielmehr genügt ein In-Kauf-Nehmen. Genetische Enhancements werden zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach vorausgehender anderweitiger intensiver Forschung am Menschen angewendet werden, jedoch keineswegs Verfahren sein, bei denen der Tod der Patienten dergestalt in das Handlungskalkül einbezogen werden wird. Vielmehr kommt es ja gerade auf ein Ausbleiben einer anderweitigen Schädigung des Patienten an, welches durch vorherige Forschung ausreichend sichergestellt sein wird; in Summe könnte sonst auch wohl kaum von einer Verbesserung die Rede sein. Wie sogleich zu zeigen sein wird, sind somatische Enhancements auch bis zur Gewährleistung der Sicherheit des Verfahrens gemäß § 5 und § 40 I 3 Nr. 2 AMG verboten. Ist diese Hürde jedoch genommen, wird davon auszugehen sein, dass die Gefahr einer Schädigung und des Abgehens des Embryos erkannt, aber auf das Ausbleiben ihrer Realisierung vertraut wird. Bewusste Fahrlässigkeit erfüllt jedoch nicht den subjektiven Tatbestand eines Vorsatzdeliktes, weswegen eine Strafbarkeit nach den §§ 218 ff. StGB durch die Vornahme von genetischen Enhancements an ausdifferenzierten Zellen postnidationaler Embryonen ausscheidet.

## 2. Unvorhergesehene Schädigungen als Straftaten

Eben diese Überlegungen gelten auch im Hinblick auf postnatal durchgeführte somatische Enhancements. Auch hier scheidet, sollte ein Enhancement aufgrund unerwarteter Folgen zu einem pathologischen Zustand oder gar zum Tod des Pa-

<sup>275</sup> RGSt 51, 305 (311); BGHSt 36, 1 (9 ff.); Lackner/Kühl, StGB, § 15 Rdnr. 3 f.; Fischer, StGB, § 15 Rdnr. 3 f.; Roxin, Strafrecht AT I, § 12 Rdnr. 4.

<sup>276</sup> RGSt 76, 115 (116); BGHSt 36, 1 (9 f.); 44, 99 (101 ff.); zu den unterschiedlichen Meinungen bezüglich der Voraussetzungen des *dolus eventualis* siehe exemplarisch Wessels/Beulke, Strafrecht AT, Rdnr. 217 ff.

tienten führen, mangels Vorsatz eine Strafbarkeit nach den §§ 211 ff. sowie den §§ 223 ff. StGB aus. Virulent könnten hingegen § 222 und § 229 StGB werden.

### **3. Die Durchführung somatischer Enhancements als Straftat**

Die Durchführung somatischer Enhancements setzt entweder die vorherige Gewinnung der *in vitro* genetisch zu verändernden und sodann zurück zu übertragenden Zellen voraus oder geschieht durch die Injektion der Zubereitung in das Gewebe, dessen Zellen genetisch verbessert werden sollen. In beiden Fällen aber liegt ein substanzverletzender Eingriff<sup>277</sup> in die körperliche Integrität vor. Je nach Grad des dazu erforderlichen Aufwandes und Schwere des Eingriffes ruft dieser einen Zustand hervor, der einer längeren Abheilung bedarf und somit pathologisch und daher eine Gesundheitsschädigung<sup>278</sup> im Sinne des § 223 I 2. Alt. StGB ist. Zumindest aber die Injektion stellt eine üble, unangemessene Behandlung, die das Wohl des Betroffenen mehr als nur unerheblich beeinträchtigt,<sup>279</sup> und somit eine körperliche Misshandlung im Sinne des § 223 I 1. Alt. StGB dar.<sup>280</sup>

Fraglich ist jedoch, ob diese Tatbestandverwirklichungen auch rechtswidrig sind, denn sie könnten durch eine rechtfertigende Einwilligung der Person, an der das somatische Enhancement durchgeführt wird, gedeckt sein. Als Individualrechtsgut ist die körperliche Unversehrtheit grundsätzlich disponibel. Anders als beispielsweise im Hinblick auf die Tötung (§ 216 StGB – ein Bestimmen des Täters zur Tötung durch das Opfer selbst stellt nach der einen Auffassung keine rechtfertigende Einwilligung dar, sondern führt lediglich zu einer Privilegierung gegenüber §§ 211, 212 StGB oder stellt nach der anderen Auffassung einen selbständigen Straftatbestand mit geringerem Strafmaß dar<sup>281</sup>), die Sterilisation (§ 1631c BGB – eine Einwilligung ist weder durch die Eltern, S. 1, noch durch das Kind, S. 2, möglich) oder die Lebendorganspende (§ 8 I 1 Nr. 1 a) TPG – eine Stellvertretung ist nicht möglich), bestehen zudem keine objektiven Grenzen, sodass die allgemeinen Regeln über die rechtfertigende Einwilligung, unter Umständen stellvertretend, Anwendung finden.

Dispositionsberechtigt ist hierbei grundsätzlich der jeweilige Patient des somatischen Enhancements selbst. Seine Einwilligungsfähigkeit erfordert jedoch, dass er über die natürliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit verfügt, aufgrund derer er nach seiner geistigen und sittlichen Reife das Wesen, die Bedeutung und die Tragweite des Eingriffs, etwa mittels einer subjektiven Kosten-Nutzen-Abwägung, zu erfassen und sich entsprechend dieser Erkenntnis zu verhalten in der Lage ist. Sie richtet

<sup>277</sup> Vergleiche BeckOK StGB-Eschelbach, § 223 Rdnr. 21.

<sup>278</sup> BGHSt 36, 262 (265); 43, 346 (354); BeckOK StGB-Eschelbach, § 223 Rdnr. 24.

<sup>279</sup> BGHSt 14, 269 (271); 25, 277 (278); BeckOK StGB-Eschelbach, § 223 Rdnr. 17 f.

<sup>280</sup> Vergleiche BeckOK StGB-Eschelbach, § 223 Rdnr. 22.

<sup>281</sup> Zu diesem Meinungsstreit BeckOK StGB-Eschelbach, § 216 Rdnr. 1 m.w.N.



sich nicht nach fixen Altersgrenzen.<sup>282</sup> Ist dies der Fall, wirkt die vor der Tat explizit oder konkludent erklärte und nicht an wesentlichen Willensmängeln leidende Einwilligung rechtfertigend, wenn die Tat sodann in Kenntnis und aufgrund der Einwilligung vorgenommen wird.<sup>283</sup>

Ist die vom Enhancement betroffene Person hingegen nicht einwilligungsfähig, etwa weil das Enhancement neonatal oder im Kindesalter durchgeführt wird, so kommt nur eine stellvertretende rechtfertigende Einwilligung durch die Personensorgeberechtigten in Frage, auf die die Verfügungsbefugnis des Rechtsgutsinhabers übergeht. Bei Minderjährigen sind dies die Eltern gemäß der §§ 1626 ff. BGB. Dabei haben sie das Wohl des Kindes zu achten und zu fördern.

Wie dieses im Kontext einer strafrechtlichen Einwilligung der Eltern in Stellvertretung für ihr Kind ausgestaltet ist, hängt zentral von dem Grund der legitimierenden Wirkung der Einwilligung ab. Der liberalen Einwilligungstheorie zufolge ist diese dem Grundsatz nach Ausdruck der Handlungsfreiheit des Einwilligenden, zu der auch die Disposition über das jeweilige, der freien Entfaltung des Einzelnen dienende Rechtsgut gehört. Die Beeinträchtigung ist sodann nicht Beschränkung, sondern gerade Ausdruck dieser freien Entfaltung. Tritt anstelle der selbständigen Einwilligung nun eine stellvertretende, so wird zum Teil angenommen, dass es sich dabei faktisch aber um eine Fremdbestimmung handle, für die die Überlegungen einer notstandsähnlichen Interessenabwägung oder die Prinzipien der mutmaßlichen Einwilligung heranzuziehen seien. Andere wiederum verweisen darauf, dass die Einwilligung weiterhin Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts des von der Tat Betroffenen ist, seine Wahrnehmung – und das heißt: *nur* seine Wahrnehmung – jedoch auf die Personensorgeberechtigten übertragen wird.<sup>284</sup>

Auswirkungen haben diese beiden unterschiedlichen Ansätze insbesondere auf die Entscheidungsfreiheit der Eltern und deren Überprüfbarkeit. Erstgenannte Auffassung führt hierbei zu einem Erfordernis des *best interest*, also gewissermaßen einer Ermessensreduzierung zugunsten dessen, was, objektiv beurteilt, für das Kind das Beste ist. Ob dies mit dem grundrechtlichen Vorrang der elterlichen Sorge und den entsprechenden zivil- und strafrechtlichen Konkretisierungen ausreichend Rechnung trägt, mag jedoch bezweifelt werden. Art. 6 II GG gewährleistet den Eltern einen Vorrang ihrer Personensorge. Dem Staat obliegt daher nicht die Kontrolle der elterlichen Entscheidungen anhand des Maßstabes dessen, was für das Kind am besten ist, er ist somit nicht Wächter oder *parens patriae*. Vielmehr hat er sich darauf zu beschränken, die Entscheidungen der Eltern einer Unvertretbarkeitskontrolle zu unterziehen und so einen negativen Standard festzulegen, anhand dessen nicht festgestellt werden darf, was für das Kind objektiv betrachtet das Beste ist (positiver Standard), sondern die Ausübung der elterlichen Sorge ausgeschlossen wird,

<sup>282</sup> Fateh-Moghadam, RW 2010, 115 (124 f.).

<sup>283</sup> Schönke/Schröder-Lenckner, StGB, Vorbem §§ 32 ff. Rdnr. 35 ff.; Jescheck/Weigend, Lehrbuch des Strafrechts, § 34 IV, V; Wessels/Beulke, Strafrecht AT, Rdnr. 372 ff.

<sup>284</sup> M.w.N., auch in Bezug auf kollektivistische Einwilligungsmodelle, Fateh-Moghadam, RW 2010, 115 (128 f.).



die unter keinem vertretbaren Aspekt mehr als der Sicherung des Wohls des Kindes dienlich erachtet werden kann.<sup>285</sup>

Dementsprechend handelt es sich auch bei der stellvertretenden Einwilligung durch die Personensorgeberechtigten um einen Ausdruck der persönlichen Selbstbestimmung *des Kindes*, die lediglich von den Personensorgeberechtigten *wahrge-nommen* wird. Auf dieses Selbstbestimmungsrecht und diesen „*Freiheitsschutz im Bereich der leiblich-seelischen Integrität*“<sup>286</sup> kommt es in seiner körperbezogenen Ausprägung gerade auch im Rahmen der Einwilligung in medizinische Eingriffe an und stellt in Fällen, in denen der Rechtsgutsträger selbst (noch) nicht einwilligungsfähig ist, ebenso Grundlage der Beurteilung der (Un-)Vertretbarkeit der Ausübung der elterlichen Sorge dar. Als Ausprägung des Selbstbestimmungsrechts aber ist der Entscheidungsrahmen ein sehr weiter und nicht auf medizinisch gebotene Eingriffe beschränkt. Er umfasst vielmehr unter Umständen auch Impfungen, die Beschneidung von Knaben und zwar sowohl zu hygienischen Zwecken als auch aufgrund religiöser Motive, das Stechen von Ohrlöchern und sogar Schönheitsoperationen. Dementsprechend und aufgrund der Tatsache, dass zwar Freiheitsbetätigungen im Sinne von Handlungen objektiv bestimmbar sind, Zustände wie die durch Art. 2 II 1 GG gewährleistete und durch § 223 I StGB geschützte körperliche Integrität jedoch keiner vollständigen Objektivierbarkeit zugänglich sind, sondern stets ausfüllungsbedürftig bleiben, haben auch die Eltern bei der Ausübung der elterlichen Sorge einen weiten Ermessensspielraum, der erst bei evidentem Missbrauch ihres Sorgerechts nicht mehr eingehalten ist.<sup>287</sup> In einem solchen Fall wäre wohl aber ohnehin § 228 StGB einschlägig. Berücksichtigung zu finden haben hier neben der Schwere und den Risiken, aber auch den Vorteilen und Chancen, die der jeweilige Eingriff mit sich bringt, etwaige kindeswohlverletzende, eventuell gar entwürdigende Umstände.<sup>288</sup>

Auch hier gilt, dass, bevor Verfahren des genetischen Enhancements, sei es nun an somatischen oder Keimbahnzellen, angewendet werden dürfen, eine hinreichende Sicherheit durch intensive Forschung gewährleistet sein muss.<sup>289</sup>

Allerdings sind in die Bewertung nicht nur unmittelbar mit der Durchführung des Eingriffes verbundene Umstände, sondern auch mittelbare Wirkungen einzubeziehen, beispielsweise der Einfluss einer genetischen Ausgestaltung oder eines genetischen Designs durch die Eltern auf das Selbstverständnis und die Selbstwahrnehmung des Kindes als autonome, selbstbestimmte Person oder bloßes Artefakt, Produkt und Objekt des Willens einer anderen Person, die Möglichkeit des Kindes, sich über eine etwaige genetische Determination als Manifestation der elterlichen Erwartungen an das Kind hinwegzusetzen und sich hiervon im Wege einer retroaktiven Deliberation zu befreien und so Autor des eigenen Lebens zu sein. Verwiesen

<sup>285</sup> *Fateh-Moghadam*, RW 2010, 115 (131).

<sup>286</sup> BVerfGE 52, 131 (174); 89, 120 (130).

<sup>287</sup> *Fateh-Moghadam*, RW 2010, 115 (132).

<sup>288</sup> *Fateh-Moghadam*, RW 2010, 115 (133 f.).

<sup>289</sup> Wie sogleich festzustellen sein wird, scheitern somatische Enhancements andernfalls ohnehin an § 5 und § 40 I 3 Nr. 2 AMG.

sei hier auf die im zweiten Kapitel untersuchten Argumente zweiter Ordnung. Vorgehend sei an dieser Stelle jedoch angemerkt, dass besagte Überlegungen zwar Berücksichtigung finden müssen und im Rahmen eines genetische Enhancements explizit und nicht bloß akzidentiell regelnden Gesetzes sowohl aus juristischer Perspektive sowie im politischen deliberativen Prozess zu dem Bedürfnis einiger legislativer Vorkehrungen führen werden. Allerdings wiegen sie nicht so schwer, als dass sie ein gesetzliches Verbot genetischer Enhancements zu begründen oder, hier, die Entscheidung der Personensorgeberechtigten für die Durchführung als schlechthin missbräuchliche und unvertretbare Wahrnehmung des elterlichen Sorgerechts und des Selbstbestimmungsrechts ihres Kindes ausweisen würden. Eine Aussage ist damit lediglich über die grundsätzliche Dispositionsbefugnis und daher Wirksamkeit einer etwaigen stellvertretenden Einwilligung durch die Eltern getroffen. Ob und in welchem Umfang sie diese erteilen möchten, unterliegt dabei freilich weiterhin ihrem weiten Ermessensspielraum, in dessen Ausübung sodann oben genannte Aspekte die maßgebliche Determinante sein können – sie können lediglich nicht den Personensorgeberechtigten ihre Dispositionsbefugnis absprechen.

Die stellvertretende Einwilligung der Eltern ist somit zulässig und wirkt daher rechtfertigend. Eine hiermit vorgenommene Injektion einer Zubereitung oder Entnahme der genetisch zu modifizierenden Zellen sowie ihre spätere Rückübertragung zum Zwecke des somatischen Enhancements verwirklichen zwar den Straftatbestand des § 223 I StGB, sind aber grundsätzlich nicht rechtswidrig.

Gleiches gilt, wie dargelegt, auch für die Durchführung eines somatischen Enhancements bei einer einwilligungsfähigen Person, deren Einwilligung ebenfalls die Rechtswidrigkeit entfallen lässt.

## II. Spezialgesetzliches Regelungsregime

In diversen spezialgesetzlichen Regelungsvorhaben sind Eingriffe in ausdifferenzierte Zellen mit therapeutischer Zielsetzung mittlerweile ausführlich reglementiert und reguliert worden. Diese umfassen auch nicht unmittelbar rechtsverbindliche Empfehlungen oder Vorgaben wie beispielsweise die von der Bundesärztekammer erlassenen Richtlinien zum Gentransfer in menschliche Körperzellen<sup>290</sup> oder die Musterberufsordnung für die deutschen Ärzte<sup>291</sup>. Auf internationaler Ebene sind hier insbesondere die in Helsinki verabschiedete Deklaration des Weltärztebundes „Ethische Grundsätze für die medizinische Forschung am Menschen“<sup>292</sup> und das in Deutschland bislang nicht ratifizierte „Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und

<sup>290</sup> Richtlinien zum Gentransfer in menschliche Körperzellen der *Bundesärztekammer*, abgedruckt in: DÄBl 1995, A 789–794.

<sup>291</sup> Musterberufsordnung für die deutschen Ärzte der *Bundesärztekammer*, abgedruckt in: DÄBl 1997, A 2354–2363.

<sup>292</sup> *Weltärztebund*, Declaration of Helsinki.

Medizin: Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin“ des Europarates vom 4. April 1997<sup>293</sup> sowie der Entwurf eines Zusatzprotokolls zum Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin über biomedizinische Forschung vom 18. Juli 2001<sup>294</sup> zu nennen.

In der vorliegenden Arbeit soll die Untersuchung auf die formellen, unmittelbar<sup>295</sup> rechtsverbindlichen Regelungen von Eingriffen in somatische Zellen begrenzt werden. Das Embryonenschutzgesetz ist hier nicht einschlägig. Zwar ist es möglich, dass auch bei der somatischen Genmodifizierung Keimbahnzellen verändert werden, was gemäß § 5 I ESchG untersagt ist. Da dies jedoch beim Eingriff in somatische Zellen nicht beabsichtigt ist, greift der Ausnahmetatbestand des § 5 IV Nr. 3 ESchG. Der Gesetzgeber, so folgert *Fateh-Moghadam*, schützt daher die menschliche Keimbahn nicht absolut vor jeglichen künstlichen Veränderungen, sondern lediglich von intentionalen.<sup>296</sup> Auf rechtsverbindliche Vorschriften sind jedoch das Gentechnikgesetz<sup>297</sup>, das Arzneimittelgesetz<sup>298</sup>, die Verordnung über die Anwendung der Guten Klinischen Praxis bei der Durchführung von klinischen Prüfungen mit Arzneimitteln zur Anwendung beim Menschen (GCP-Verordnung)<sup>299</sup> sowie die Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 über Arzneimittel für neuartige Therapien<sup>300</sup> zu untersuchen.

## 1. Regelungen im Gentechnikgesetz

Zweck des Gesetzes zur Regelung der Gentechnik ist ausweislich seines § 1 unter anderem der Schutz vor und die Verhinderung der Entstehung von Gefahren, die mit schädlichen Auswirkungen gentechnischer Verfahren und Produkte zusammenhängen (Nr. 1), und die Bereitstellung eines rechtlichen Rahmens, in dem Forschung, Entwicklung, Nutzung und Förderung der Gentechnik ermöglicht werden (Nr. 3). Dabei umfasst es in zeitlicher Hinsicht aber nicht mehr die Teilschritte *in vivo*. Die somatische Gentherapie oder die direkte Anwendung von gentechnisch veränderten Organismen im Sinne des § 3 Nr. 3 GenTG am Menschen unterfallen daher nicht dem Regelungsbereich des Gentechnikgesetzes,<sup>301</sup> was ebenso für genetisches En-

---

<sup>293</sup> *Europarat*, Bioethik-Konvention.

<sup>294</sup> *Europarat – Lenkungsausschuss Bioethik*, Entwurf eines Zusatzprotokolls zum Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin über biomedizinische Forschung.

<sup>295</sup> Für europäische Verordnungen, die abstrakt-generelle Regelungen sind und auch in den Einzelstaaten unmittelbar gelten, ergibt sich dies aus Art. 288 I AEUV. Richtlinien bedürfen zwar der Umsetzung in nationales Recht, sind jedoch hinsichtlich ihrer Ziele verbindlich, Art. 288 II AEUV.

<sup>296</sup> *Fateh-Moghadam*, Rechtliche Aspekte der somatischen Gentherapie, S. 158 f.

<sup>297</sup> Bekanntgemacht am 16. Dezember 1993, BGBl. I S. 2066 ff.

<sup>298</sup> Bekanntgemacht am 12. Dezember 2005, BGBl. I S. 3394.

<sup>299</sup> Ausgefertigt am 9. August 2004, BGBl. I S. 2081.

<sup>300</sup> Amtsblatt der Europäischen Union vom 10.12.2007, L 324/121–137; auch ATMP-Verordnung genannt („Advanced Therapy Medical Products“).

<sup>301</sup> *Steinborn*, GenTG, Einleitung S. 3.

hancement an somatischen Zellen gelten muss. Vielmehr beschränkt es sich auf die vorab stattfindenden, präklinischen Schritte *in vitro*, bezüglich derer das Gentechnikgesetz Sicherheitsstufen festlegt und Sicherheitsmaßnahmen vorsieht, ein Anzeige-, Melde- und Genehmigungsverfahren vorschreibt, Genehmigungsvoraussetzungen benennt und Haftungsfragen regelt. Diesen Vorschriften unterfallen gentechnische Arbeiten, worunter die Erzeugung, Vermehrung und Lagerung gentechnisch veränderter Organismen ebenso gehören wie ihre Zerstörung, Entsorgung oder ihr (innerbetrieblicher) Transport, und deren Durchführung ausschließlich den zugelassenen gentechnischen Anlagen im Sinne des Gesetzes vorbehalten ist.<sup>302</sup> Zu erwähnen ist jedoch besonders, dass die Transduktion gemäß § 3 Nr. 3b b) GenTG nicht als Verfahren der Veränderung genetischen Materials im Sinne dieses Gesetzes gilt. In Zusammenschau mit § 3 Nr. 3 GenTG, demzufolge ein gentechnisch veränderter Organismus ein Organismus ist, dessen genetisches Material in einer Weise verändert wurde, wie sie unter natürlichen Bedingungen nicht vorkommt, liegt dies darin begründet, dass man sich bei der Transduktion die nur natürliche Eigenschaft von Viren, das eigene Erbmateriale in die Wirtszellen einzuschleusen, zunutze macht.

## 2. Arzneimittelrechtliche Regelungen

Das Recht der Arzneimittel, insbesondere derer für neuartige Therapien, gleicht „weniger ein[em] Regelungsgeflecht, als vielmehr ein[em] Regelungs-dickicht“, was zum einen durch die ständigen naturwissenschaftlichen Innovationen, zum anderen durch ein komplexes Verhältnis zwischen nationalen und europarechtlichen Vorschriften entsteht.<sup>303</sup>

Primäre Rechtsquelle zur Beurteilung der Zulässigkeit somatischer Gentherapie ist das Arzneimittelgesetz, dessen primäres Ziel<sup>304</sup> die Sicherheit und Unbedenklichkeit des Inverkehrbringens sowie der Anwendung von Arzneimitteln ist. Dieses stellt den rechtlichen Rahmen ihrer klinischen Prüfung und Anwendung und des Genehmigungsverfahrens zum Inverkehrbringen der Gentherapeutika sowie der Anzeige- und Erlaubnispflichten dar.

### a) Grundsätzliche Anwendbarkeit des Arzneimittelgesetzes

Hier stellt sich zunächst die Frage, ob das Arzneimittelgesetz auch auf somatische Enhancements Anwendung findet. Dazu müsste es sich bei genmodifizierten soma-

<sup>302</sup> Steinborn, GenTG, Einleitung S. 3 f.

<sup>303</sup> Bock, Der Rechtsrahmen für Arzneimittel für neuartige Therapien auf unionaler und nationaler Ebene, S. 2, 4. In ihrer Dissertation untersucht sie systematisch das Regelungsgeflecht der einschlägigen Normen, wobei sie nicht nur Regelungslücken und –defizite aufzeigt, sondern auch den Handlungsbedarf *de lege ferenda* skizziert.

<sup>304</sup> Rehmann, AMG, § 1 Rdnr. 1.

tischen Zellen beziehungsweise bei den zu der Modifizierung eingesetzten Substanzen um Arzneimittel im Sinne des § 2 AMG handeln. Da Enhancements jedoch, wie eingangs dargestellt, weder therapeutisch, noch diagnostisch, therapeutisch-substitutiv oder vorbeugend wirken, sind die § 2 I Nr. 1–4 AMG nicht einschlägig. Gemäß § 2 I Nr. 5 AMG jedoch fallen unter den Arzneimittelbegriff dieses Gesetzes auch Stoffe oder Zubereitungen von Stoffen, die dazu bestimmt sind, durch Anwendung am oder im menschlichen Körper die Beschaffenheit, den Zustand oder die Funktionen des Körpers oder seelische Zustände zu beeinflussen. Eine Zwecksetzung zur Heilung ist hier nicht erforderlich.<sup>305</sup> Daher ist der Anwendungsbereich des Arzneimittelgesetzes im Allgemeinen eröffnet.

## **b) Die Anzeigepflicht und Herstellungserlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz**

Als Arzneimittel im Sinne des § 2 I Nr. 5 AMG unterliegen die beim somatischen Enhancement zum Einsatz kommenden Zubereitungen der Herstellungserlaubnis des § 13 AMG, die durch die nachfolgenden Vorschriften näher ausgestaltet wird. § 14 I AMG enthält so beispielsweise eine abschließende Liste von Versagungsgründen, zu denen auch das Fehlen eines Sachkundenachweises nach § 15 AMG gehört. Dessen Absatz 3a sieht für Arzneimittel für neuartige Therapien verschärfte Voraussetzungen zur Erbringung des Nachweises der erforderlichen Sachkenntnis vor. Es stellt sich also die Frage, ob dazu auch im Rahmen des somatischen Enhancements verwendete Zubereitungen gehören. Gemäß Anhang I Teil IV der Richtlinie 2001/83/EG<sup>306</sup> ist eine Voraussetzung dafür, dass etwas als Gentherapeutikum klassifiziert wird, dass sein Wirkstoff eine rekombinante Nukleinsäure enthält, die therapeutische, prophylaktische oder diagnostische Wirkung entfaltet oder diese Wirkung im Zusammenhang mit dem Produkt, das aus der Expression dieser Sequenz resultiert, steht.<sup>307</sup> Eine vorbeugende, diagnostische oder therapeutische Zielsetzung ist jedoch, wie anfangs bereits erörtert, bei einem Enhancement nicht gegeben. Entsprechend sind die strengeren Voraussetzungen des § 15 IIIa AMG nicht einschlägig.

Dies führt jedoch zu der irritierenden Situation, dass strengere Maßstäbe angelegt werden, wenn ein im Übrigen sehr ähnliches Verfahren zu medizinisch im weitesten Sinne notwendigen Zwecken genutzt werden soll, als sie mangels Eingreifens der dies vorschreibenden gesetzlichen Regelung gelten, wenn es lediglich um eine Verbesserung geht. Dies gilt umso mehr, da beim genetischen Enhancement die Risiken gemeinhin noch höher bewertet werden als die bei der Gentherapie ohnehin sehr enormen. Im Hinblick auf somatische Enhancements besteht daher die herausgearbeitete Regelungslücke, weswegen eine Ausweitung des § 15 IIIa AMG im Wege der teleologischen Auslegung oder der Analogie zu erwägen ist. Zweck der über diese Norm verschärften Anforderungen ist abermals die Kontrolle des bereits

<sup>305</sup> *Rehmann*, AMG, § 2 Rdnr. 20.

<sup>306</sup> Amtsblatt der Europäischen Union vom 28.11.2001, L 311:67–128.

<sup>307</sup> Nach *Fateh-Moghadam*, Rechtliche Aspekte der somatischen Gentherapie, S. 161.

bei Gentherapien bestehenden großen Risikos, welches besondere Anforderungen an die Sachkenntnis der diese durchführenden Personen gebietet. Sinn ergibt dies erst recht mit Blick auf das mindestens ebenso risikoreiche somatische Enhancement, sodass die Interessenlagen des durch § 15 IIIa AMG geregelten Sachverhalts sowie des im Rahmen genetischer Enhancements betroffenen vergleichbar sind. Während allerdings die Grenze der Auslegung stets der Wortlaut der jeweiligen Norm ist, der sich vorliegend eindeutig auf Therapien beziehungsweise Therapeutika beschränkt, ist auch der Analogie durch die grundsätzliche Prärogative des Gesetzgebers Grenzen gezogen. Führte die Ausdehnung einer Norm über die Analogie zu einer Beschränkung einer grundrechtlich verbürgten Freiheit, wie es hier mit Blick auf die Forschungsfreiheit des Art. 5 III 1 GG der Fall wäre, ist es alleine dem Gesetzgeber belassen, die Regelungslücke zu schließen. Eine Analogie verbietet sich meiner Auffassung zufolge daher ebenfalls. Unabhängig davon bleibt diese aber auch vor dem Hintergrund des strafrechtlichen § 96 Nr. 4 AMG aufgrund des sich aus Art. 103 II GG ergebenden Analogieverbotes untersagt.

Daher bleibt es bei den allgemeinen Voraussetzungen an den im Rahmen des Verfahrens zur Erlangung der Herstellungserlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz erforderlichen Sachkundenachweis.

Des Weiteren sieht § 67 AMG eine umfassende Anzeigepflicht vor.

### **c) Erfordernis eines speziellen Genehmigungsverfahrens für das Inverkehrbringen?**

Auch das Inverkehrbringen unterliegt speziellen Genehmigungsverfahren. Seit dem 30. Dezember 2008 gilt in Deutschland die Verordnung (EG) 1394/2007 als unmittelbar geltendes Recht.<sup>308</sup> Diese sieht für das Inverkehrbringen von sogenannten Arzneimitteln für neuartige Therapien ein zentrales Genehmigungsverfahren bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) in London vor. Die hiervon erteilte Genehmigung wird gemäß § 21 AMG der Zulassung durch die oberste Bundesbehörde gleichgestellt, §§ 21 I, 37 AMG. Art. 2 I a) 1. Var. der Verordnung 1394/2007 umfasst die im Rahmen der somatischen Gentherapie eingesetzten Zubereitungen.<sup>309</sup> Wie aber bereits festgestellt, fallen die bei einem somatischen Enhancement verwendeten Zubereitungen nicht unter den Begriff des Gentherapeutikums im Sinne des Anhangs I Teil IV der Richtlinie 2001/83/EG. Die Verordnung 1394/2007 könnte jedoch über ihren Art. 2 I a) 3. Var. Anwendung auf somatische Enhancements finden. Dazu müssten die hierzu eingesetzten Zubereitungen biotechnologisch bearbeitete Gewebeprodukte gemäß Art. 2 I b) der Verordnung 1394/2007 sein. Wenn diese Vorschrift auch Klarheiten hinsichtlich der Zuordnung von genannten biotechnologisch bearbeiteten Gewebeprodukten zu Arzneimitteln

<sup>308</sup> *Fateh-Moghadam*, Rechtliche Aspekte der somatischen Gentherapie, S. 160.

<sup>309</sup> *Fateh-Moghadam*, Rechtliche Aspekte der somatischen Gentherapie, S. 160.

und nicht zu den Medizinprodukten, was zuvor umstritten war, schaffte,<sup>310</sup> so sieht sie dennoch die Zwecksetzung der Regeneration, Wiederherstellung oder des Ersatzes vor. Enhancements sind hierunter jedoch ausweislich der eingangs getroffenen Definition nicht subsumierbar. Ein besonderes Genehmigungsverfahren ist nach dem Wortlaut der Norm daher nicht vorgeschrieben.

Allerdings sind auf das Unionsrecht die Auslegungselemente der deutschen juristischen Methodenlehre übertragbar, sodass neben einer grammatischen, historischen oder systematischen auch die teleologische Auslegung Anwendung finden kann, bei der nach dem Sinn und Zweck der jeweiligen Regelung gefragt wird. Im Europarecht ist dabei stets der Effektivitätsgrundsatz (*effet utile*) zu berücksichtigen, wonach unter mehreren Auslegungsmöglichkeiten diejenige zu wählen ist, die zur größeren praktischen Wirksamkeit der Norm führt.<sup>311</sup> Vor diesem Hintergrund fällt auf, dass das oben gefundene, alleine am Wortlaut der Norm erarbeitete Ergebnis mit Blick auf Erwägungsgrund 9 der Verordnung (EG) 1394/2007, wonach dem Mangel an Fachwissen in der Gemeinschaft abgeholfen und ein hohes Niveau der wissenschaftlichen Beurteilung der von der Richtlinie erfassten Arzneimittel in der Gemeinschaft hinsichtlich ihrer Qualität, Unbedenklichkeit und Wirksamkeit sichergestellt werden sollte, widersprüchlich ist. Dass dies nicht nur für den therapeutischen Einsatz von Arzneimitteln gelten kann, sondern sinnvollerweise auch den Einsatz zu verbessernden Zwecken umfassen sollte, ergibt sich aus dem soeben benannten Telos der Norm und der Tatsache, dass Verfahren des genetischen Enhancements bis auf Weiteres weniger kontrollierbar und daher risikoreicher als Gentherapien sind. Erst recht müssten daher auch diese von den Sicherheit gewährenden Vorschriften erfasst sein.

Da die Erfüllung dieses Zwecks jedoch außerhalb des originären Anwendungsbereichs der Norm liegt, welcher sich, wie gezeigt, auf therapeutisch wirkende Produkte beschränkt, aber Bedarf für eine darüber hinausgehende Regelung besteht, liegt eine Regelungslücke vor, deren Materie darüber hinaus kompetenziell der Europäischen Union zugeordnet ist. Der von der Norm geregelte Sachverhalt und der des genetischen Enhancements sind zudem vor dem Hintergrund vergleichbar, dass gerade bei genverbessernden Maßnahmen, die bis auf Weiteres ein größeres Schädigungspotenzial als Gentherapien aufweisen, das durch das Genehmigungsverfahren geschützte Sicherheitsinteresse besteht. Insofern kommt eine rechtsfortbildende, das Erfordernis des Genehmigungsverfahrens begründende Anwendung dieser Vorschriften auf Produkte in Frage, welche nicht lediglich der Regeneration, Wiederherstellung oder dem Ersatz dienen, sondern verbessernde Wirkung haben.

<sup>310</sup> Bock, Der Rechtsrahmen für Arzneimittel für neuartige Therapien auf unionaler und nationaler Ebene, S. 37.

<sup>311</sup> Calliess, NJW 2005, 929; m.w.N. Bock, Der Rechtsrahmen für Arzneimittel für neuartige Therapien auf unionaler und nationaler Ebene, S. 42, 49.



#### d) Die klinische Prüfung und Anwendung nach dem Arzneimittelgesetz

Während, wie oben dargestellt, das Gentechnikgesetz dem Risiko der Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen solange Rechnung tragen soll, wie diese sich im präklinischen Stand der Entwicklung *in vitro* befinden, greift das Arzneimittelgesetz hinsichtlich aller Arzneimittel im Sinne dieses Gesetzes ein, sobald die klinische Prüfung im Sinne des § 4 XXIII AMG beginnen soll. Hierunter versteht man Versuchsbehandlungen, deren primäre Motivation das Forschungsinteresse ist.<sup>312</sup> Abzugrenzen ist dies dabei stets vom individuellen Heilversuch.<sup>313</sup> Gegen eine Qualifizierung genetischer Enhancements als einen solchen sprechen jedoch zwei bedeutende Umstände: Zunächst einmal ist, abermals, die Zielsetzung des Enhancements nicht die des Heilens. Des Weiteren ist der Handlungszweck, nach dem die Klassifizierung erfolgt, objektiv zu bestimmen. Dabei ist ein überwiegendes Forschungsinteresse und daher eine klinische Prüfung schon dann anzunehmen, wenn aus der Sicht eines objektiven Dritten die durchzuführende Versuchstätigkeit strukturell so angelegt ist, dass die Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse gewährleistet ist. Referenzpunkte sind dabei die Zielgerichtetheit, Planmäßigkeit und die Standardisierung des Vorgehens.<sup>314</sup> Zu Recht verweist *Fateh-Moghadam* in diesem Zusammenhang auf den Entwicklungsstand der Gentherapie (und dies muss ebenso für genetische Enhancements und andere gentechnologischen Verfahren gelten) und darauf, dass eine Weiterentwicklung nur dann realistisch möglich ist, wenn wissenschaftliche Strukturen zu einem Erkenntnisgewinn in klinischen Prüfungen führen,<sup>315</sup> weswegen es sich beim somatischen Enhancement auch um eine ebensolche und gerade nicht um einen individuellen Heilversuch handelt.

Hinsichtlich der materiellen Voraussetzungen der §§ 40–42 AMG für die klinische Prüfung wird zwischen rein wissenschaftlichen Experimenten mit nicht einschlägig erkrankten Probanden gemäß § 40 AMG sowie heilkundlichen Experimenten mit einschlägig erkrankten Patienten beziehungsweise gruppennützigen Experimenten mit einschlägig erkrankten Patienten gemäß §§ 41, 40 AMG unterschieden.<sup>316</sup> Mit Blick auf die genetische Verbesserung eines im Allgemeinen vollkommen gesunden Menschen kommt ausschließlich die erstgenannte situative Variante hinsichtlich der an die Zulässigkeit der Prüfung zu stellenden Voraussetzungen in Frage. Gemäß § 40 I 3 Nr. 2 AMG ist hierfür erforderlich, dass die vorhersehbaren Risiken und Nachteile gegenüber dem Nutzen für die betroffene Person und der voraussichtlichen Bedeutung des Arzneimittels für die Heilkunde ärztlich vertretbar sind. Es ist aber weithin anerkannt, dass aufgrund dieser Voraussetzung eine Heran-

<sup>312</sup> *Fateh-Moghadam*, Rechtliche Aspekte der somatischen Gentherapie, S. 164 f.

<sup>313</sup> *Rehmann*, AMG, § 4 Rdnr. 25.

<sup>314</sup> *Fateh-Moghadam*, Rechtliche Aspekte der somatischen Gentherapie, S. 165. Folgt die Prüfung hingegen nicht einem Prüfplan, sondern lediglich der ärztlichen Praxis mit dem Ziel der Behandlung des Patienten, liegt keine klinische Prüfung vor: *Rehmann*, AMG, § 4 Rdnr. 25.

<sup>315</sup> *Fateh-Moghadam*, Rechtliche Aspekte der somatischen Gentherapie, S. 165.

<sup>316</sup> Ausführlich zu den unterschiedlichen Situationen *Fateh-Moghadam*, Rechtliche Aspekte der somatischen Gentherapie, S. 167 ff.



ziehung gesunder Menschen zu Arzneimittelstudien nur dann in Betracht kommt, wenn die dadurch entstehenden Belastungen gering und nicht von Dauer sind und keine ernsthaften Gefahren für die Gesundheit bestehen.<sup>317</sup> Schon der Einsatz von Gentherapeutika ist jedoch zumindest zurzeit noch mit Risiken behaftet, die so groß sind, dass sie nur durch einen etwaigen heilkundlichen Nutzen für die Allgemeinheit nicht gerechtfertigt werden.<sup>318</sup> Im Hinblick auf Enhancements schlägt umso mehr zu Buche, dass ein therapeutischer oder heilkundlicher Nutzen noch nicht einmal gegeben ist. Dieser ist aber zentral, sollen die Risiken aufgewogen werden. Geht es jedoch nicht um die Beseitigung eines pathologisch auffälligen, negativ abweichenden Zustandes, sondern soll insofern nur eine Verbesserung eines gesunden Zustandes erreicht werden, hat dies durchschlagende Bedeutung auf das Ausmaß der Risiken, die zur Erreichung des jeweiligen Ziels eingegangen werden dürfen. Allgemein lässt sich formulieren, dass die Vermeidung gravierender Übel grundsätzlich der Erreichung möglicher Vorteile vorzuziehen ist.<sup>319</sup> Der Sicherung des *status quo* wird somit mehr Gewicht eingeräumt als der Gewinnung weiteren Nutzens, was umso mehr gelten muss, wenn die Ausgangssituation keine pathologisch auffällige, sondern eine im Allgemeinen gesunde ist.<sup>320</sup> Die bedeutenden Risiken somatischer Enhancements lassen sich daher nicht mit den sich hiervon versprochenen Nutzen aufwiegen. Diese sind nämlich einerseits keine therapeutischen und sind andererseits wertungsmäßig, da sie an einen ohnehin schon gesunden und daher prinzipiell guten Zustand anknüpfen, bedeutend geringer einzustufen als es die mit dem Verfahren verbundenen Risiken und die etwaig resultierenden massiven gesundheitlichen Schädigungen sind. Diese sind somit gemessen an den (nicht bestehenden heilkundlichen) Nutzen ärztlich nicht vertretbar. Eine klinische Prüfung somatischer Enhancementstechniken nach § 40 AMG ist somit unzulässig.

### e) Allgemeines arzneirechtliches Verbot

Schließlich lässt sich fragen, ob ein Verbot nicht schon aus der Anwendung des § 5 AMG resultiert. Hiernach ist es untersagt, Arzneimittel in Verkehr zu bringen, die bedenklich sind. Eine Zuwiderhandlung ist gemäß § 95 I Nr. 1 AMG mit Strafe bewehrt. Das Arzneimittelgesetz versteht unter dem Begriff des Inverkehrbringens nicht nur die Abgabe und den Verkauf, sondern auch dem vorausgehende Vorbereitungshandlungen, sofern sie mit der Absicht geschehen, das Arzneimittel im Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes in Verkehr zu bringen.<sup>321</sup> Abgabe bedeutet in diesem Zusammenhang die körperliche Überlassung des Arzneimittels und daher Einräumung von Verfügungsgewalt, wofür die Anwendung des Arzneimittels am

<sup>317</sup> Fateh-Moghadam, Rechtliche Aspekte der somatischen Gentherapie, S. 168.

<sup>318</sup> Fateh-Moghadam, Rechtliche Aspekte der somatischen Gentherapie, S. 168.

<sup>319</sup> Vergleiche auch Green, Babies by Design, S. 91.

<sup>320</sup> Vergleiche Brock, The Journal of Political Philosophy 13 (4), 377 (395); Daniels, Modifying Human Nature?, S. 38.

<sup>321</sup> Rehmann, AMG, § 4 Rdnr. 16.

Patienten durch den Arzt nicht ausreicht, wozu aber auch keine Eigentumsverschaffung notwendig ist.<sup>322</sup> Gemäß § 5 II AMG ist ein Arzneimittel bedenklich, wenn bei ihm nach dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse der begründete Verdacht besteht, dass sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch unvertretbar schädliche Wirkungen haben. Hierbei sind die Wirksamkeit und die Schädlichkeit des Arzneimittels in Relation zu setzen. Der Eintritt einer schädlichen Wirkung muss allerdings nicht nachgewiesen werden, es reicht der plausibel begründete Verdacht aus, der auf praktische Erkenntnisse ebenso gestützt werden kann wie auf theoretische Überlegungen. Die Unvertretbarkeit ist mittels einer Abwägung von Risiko und Nutzen festzustellen und liegt vor, wenn das Arzneimittel objektiv geeignet ist, bei bestimmungsgemäßer Anwendung mehr schädliche Wirkungen zu erzeugen, als nach Berücksichtigung aller Umstände nach den Regeln der ärztlichen Wissenschaft vertreten werden kann. Dies kann zum einen absolut, aber auch in Relation zu anderen Behandlungsmethoden betrachtet werden. Zentral ist hierbei aber der Umfang des medizinischen Nutzens.<sup>323</sup> Zur Bestimmung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses ist gemäß § 4 XXVIII AMG eine Bewertung der positiven therapeutischen Wirkungen im Verhältnis zu den Risiken nach § 4 XXVII a) AMG zu treffen. Gerade solche werden bei einem Enhancement weder erreicht noch beabsichtigt. Da definitionsgemäß bei der sich einem Enhancement unterziehenden Person keine pathologischen Auffälligkeiten vorliegen, die mittels des Enhancements beseitigt werden sollen, ist der Eingriff durch das Enhancement auch nicht medizinisch geboten. Gleichzeitig aber sind die damit verbundenen Risiken immens und bislang der Ausgang keineswegs abzusehen. Schon Gentherapien sind nur bei Patienten zugelassen, deren Erkrankung, sofern sie unbehandelt bliebe, terminal ist und für die anderweitige Therapien nicht in Frage kommen oder keine Erfolgsaussichten versprechen.<sup>324</sup> Wenn aber im Falle anderweitiger, nicht schwerster Erkrankung schon die Abwägung von Risiken und Nutzen der Gentherapie negativ ausfällt und ein Verbot begründet, dann muss dies erst recht für genetische Enhancements ohne jeglichen therapeutischen Nutzen gelten. § 5 AMG ist somit einschlägig und spricht ein über § 95 I Nr. 1 AMG strafrechtlich bewehrtes Verbot des somatischen Enhancements aus.

## f) Ergebnis

Nach aktuell geltendem Recht ist genetisches Enhancement an Somazellen somit nach § 5 AMG sowie als Verstoß gegen § 40 I 3 Nr. 2 AMG untersagt. Dabei ist zu betonen, dass beide Normen – ebenso wie auch die anderen, in diesem Kapitel zitierten Normen – nicht vor dem Hintergrund eines (demnächst) möglichen verbessernden Eingriffes in das menschliche Genom erlassen wurden. Sie regeln diese Fälle vielmehr lediglich akzidentiell mit. Die Anwendung bestehender Gesetze

<sup>322</sup> Rehmann, AMG, § 4 Rdnr. 19.

<sup>323</sup> Rehmann, AMG, § 5 Rdnr. 2.

<sup>324</sup> Vergleiche *Fateh-Moghadam*, Rechtliche Aspekte der somatischen Gentherapie, S. 171.

führt, wie dargestellt, häufig zu nicht befriedigenden oder kohärenten Ergebnissen. Wenn das somatische Enhancement sich auch unter die gesetzlich geregelten Fälle subsumieren lässt, so wird doch deutlich, dass das aktuell geltende Recht diesen speziellen Fall eigentlich an keiner Stelle adressiert und daher sinnvollerweise eigentlich von einer Regelungslücke ausgegangen werden müsste. Die eher zufälligerweise einschlägigen Normen begründen vorerst aber ein Verbot somatischer Enhancements.

Legt man diese aktuell geltende Rechtslage zugrunde, so besteht ein Verbot genetischen Enhancements an somatischen Zellen nur solange fort, wie dieses nicht sicher durchzuführen möglich ist. Sobald dies aber der Fall sein wird, wird es sinnvoll sein, das aktuell geltende dichte europarechtliche und deutsche Regelungskonzept von Genehmigungsverfahren und Arzneimittelzulassung in interessengerechter Weise auch auf somatische Enhancements auszudehnen.

### Teil III

## ***De lege ferenda* – Regelungsgehalt eines Enhancement-Gesetzes**

Wie sich gezeigt hat, ist keine der einschlägigen Normen vor dem Hintergrund der Möglichkeit verbessernder genetischer Manipulationen erlassen worden. Dennoch sind sie zum Teil auf Fälle des genetischen Enhancements anwendbar, generieren hierdurch allerdings ebenso Probleme und stellen Rechtsanwender wie Gesetzgeber gleichermaßen vor die Frage, ob und inwieweit damit den Bedürfnissen nach gesetzlicher Regulierung von Enhancement-Praktiken Rechnung getragen wird sowie wie zukünftige Regelungsoptionen ausgestaltet sein können. Am Anfang dieses Prozesses der Entstehung einer solchen neuer normativen Ordnung stehen zwei zentrale Überlegungen.

## Kapitel 7: Der liberale Rechtsstaat – Einordnung in den verfassungsrechtlichen Anforderungszusammenhang

Erstens: Nur ein *rechtliches* Verbot vermag es, eine stabile Verhaltenserwartung zu begründen. Soll menschliches Verhalten vorhersehbar und verlässlich gesteuert werden, vermag nur eine Regelung im Medium des Rechts, den Adressaten zu verpflichten, ihre Einhaltung durchzusetzen und Verstöße zu sanktionieren.

Zweitens ist individuellen Freiheitsrechten in einem liberalen Rechtsstaat *prima facie* ein Vorrang eingeräumt. Entsprechend stellt *Di Fabio* mit Blick auf die verfassungsrechtlich korrespondierende Erkenntnis fest: „[Die Bestimmung des Art. 2 I GG] schlägt die Brücke von den überpositiven Fundamenten der Verfassung hin zu der positiven Freiheitsgewährleistung: von der schon vorrechtlich jedem Menschen zukommenden Würde (Art. 1 Abs. 1 GG) und dem Bekenntnis zu den überstaatlichen Menschenrechten (Art. 1 Abs. 2 GG) hin zu der – damit unlösbar verbundenen – Idee einer von der staatlichen Rechtsordnung anerkannten und dieser Ordnung zu Grunde liegenden Freiheit des Menschen. [...] Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit ist von ihrem grundsätzlichen Gehalt her die wegweisende Konkretisierung der Menschenwürde. Es legt die öffentliche Gewalt und die von ihr hervorgebrachte Rechtsordnung auf eine prinzipielle Freiheitsvermutung fest. Dieses in seinem personalen Bezug grundlegende Freiheitsrecht knüpft an naturrechtliche Traditionen an und bestimmt mit der Verbindung von Menschsein und Freiheit einen Vorrang der Freiheit vor jeder kollektiv definierten Ergebnisgleichheit.“<sup>325</sup> Das rechtsstaatliche Verteilungsprinzip als das Verhältnis zwischen Grundfreiheiten und Grundrechtsschranken ist derart ausgestaltet, dass nicht die Ausübung von Freiheiten und Rechten der Rechtfertigung bedarf, sondern die Restriktion derer durch den Staat.<sup>326</sup> Die Verfassung geht davon aus, dass erwachsene Menschen in der Lage sind und das Recht haben, und zwar sowohl das moralische als auch das juristische, über die grundlegendsten Fragen des menschlichen Le-

<sup>325</sup> Maunz/Dürig-*Di Fabio*, GG, Art. 2 Abs. 1 Rdnr. 1 f.

<sup>326</sup> *Isensee*, Die alten Grundrechte und die biotechnische Revolution, S. 250; *Harris*, Enhancing Evolution, S. 72 ff.

bens, insbesondere über dessen Bedeutung und Sinn sowie deren Ausprägungen, zu denen auch die Modalitäten der Fortpflanzung gehören, selbst zu entscheiden.<sup>327</sup>

Die Tatsache, dass diese Rechte gewährt und ausgeübt werden, bedarf mithin keiner besonderen Begründung. Vielmehr ist es die Einschränkung eines solchen Freiheitsrechts, etwa durch ein teilweises oder gar umfassendes Verbot, welche einer *rechtlichen* Rechtfertigung bedarf.

Dies bedeutet jedoch mitnichten, dass es auch einen diesen Freiheitsrechten korrespondierenden, über das Unterlassen von Eingriffen hinausgehenden, sondern Teilnahme gewährenden Anspruch gibt.<sup>328</sup> In der vorliegenden Arbeit geht es nicht um die Frage eines Leistungs- oder Teilhaberechts angesichts der Ressourcenallokation auf medizinischem Gebiet und der Rationierung ärztlicher Leistungen. Das Problem eines etwaigen Anspruchs gegen die Krankenkasse und somit auch gegen die Gesellschaft auf Bezahlung der Durchführung eines genetischen Enhancements stellt sich zumindest zunächst nicht.<sup>329</sup> Dies wäre erst im Anschluss an die Frage, ob eine solche Praxis – wie restriktiv auch immer – überhaupt zulässig ist, zu klären.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit möchte ich mich darauf beschränken, zunächst kurz zu erörtern, welche grundgesetzlich verbrieften Rechtspositionen für die Zulässigkeit eines genetischen Enhancements sprechen beziehungsweise durch ein Verbot dessen betroffen wären, bevor zur Verfügung stehende (rechtliche) Begründungsressourcen für ein solches Verbot zu evaluieren sein werden.

## I. Recht auf reproduktive Autonomie

Die Frage, welchem Grundrecht die Fortpflanzungsfreiheit oder reproduktive Autonomie richtigerweise zuzuordnen ist, ist umstritten. Ob sie sich aus dem Schutz von Ehe und Familie des Art. 6 I GG, dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Art. 2 I i. V. m. Art. 1 I GG, der allgemeinen Handlungsfreiheit des Art. 2 I GG oder aus einer Kombination dieser Grundrechte ergibt,<sup>330</sup> kann jedoch dahingestellt bleiben: Jedenfalls besteht ein solches Grundrecht auf Fortpflanzungsfreiheit, das wie ande-

<sup>327</sup> Vergleiche *Enquete-Kommission „Recht und Ethik“*, S. 95; *Gutmann*, Rechtliche und rechtsphilosophische Fragen der PID, S. 63 f.; *Heun*, Menschenwürde und Lebensrecht als Maßstäbe für PID?, S. 106; *Hufen*, MedR 2001, 440 (442); vergleiche auch mit Blick auf die Präimplantationsdiagnostik *Ipsen*, JZ 2001, 989 (995).

<sup>328</sup> Mit Hinblick auf eine Präimplantationsdiagnostik, im Ergebnis aber ebenso *Hufen*, Individuelle Rechte und die Zulassung der PID, S. 132 f.

<sup>329</sup> Dass Enhancement-Maßnahmen in Zukunft als eine Kassenleistung ersatzfähig wären, scheint mir allerdings vor dem Hintergrund knapper Ressourcen zumindest solange illusorisch, wie soziale und regionale Unterschiede in der basalen Gesundheitsversorgung bestehen. Enhancement wäre somit ein rein privatwirtschaftliches Angebot, welches nur von zahlungskräftigen Kunden zu erlangen wäre (vergleiche auch *drze*, Enhancement, S. 39; *Lenk*, Therapie und Enhancement, S. 59 f.).

<sup>330</sup> Zu der moralischen Basis dieses Rechts *Brock*, The Journal of Political Philosophy 13 (4), 377 (382 ff.).

re Freiheitsrechte auch als Abwehrrecht gegen den Staat ausgestaltet ist.<sup>331</sup> Es ist auch in der angloamerikanischen Debatte nicht nur als bloßes Freiheitsrecht, sondern als fundamentales Menschenrecht anerkannt, das die eigenständige Definition und Ausgestaltung der eigenen reproduktiven Rolle erlaubt.<sup>332</sup>

In den Schutzbereich dieses Grundrechts fällt die Entscheidung bezüglich des Ob, Wann, Warum und Wie der Fortpflanzung.<sup>333</sup> Dabei bezieht es sich jedoch nicht ausschließlich auf die sexuelle Intimsphäre des Paares, das heißt die Zeugung eines Kindes auf natürlichem Weg, sondern umschließt vielmehr auch die Inanspruchnahme medizinischer Möglichkeiten zur Erfüllung des Kinderwunsches.<sup>334</sup> Paaren im Allgemeinen und im Besonderen Paaren, bei denen zumindest ein Partner behindert ist oder bei denen bei zumindest einem Partner das Risiko der Vererbung einer schweren Krankheit begründet liegt, obliegt damit die freie Entscheidung darüber, ob sie eben dieses Risiko eingehen und ein unter Umständen schwerstbehindertes Kind aufziehen oder den Kinderwunsch aufgrund dieses Risikos zurückstellen wollen. Die Durchführung einer Präimplantationsdiagnostik, die diese Entscheidung ermöglicht und eine medizinische Technik zur Verhinderung der Geburt eines behinderten Kindes bei gleichzeitiger Eröffnung der Möglichkeit der Geburt eines gesunden Kindes darstellt, würde somit in den Schutzbereich des Rechts auf reproduktive Autonomie fallen.<sup>335</sup>

Ein anderes Ergebnis ist auch hinsichtlich einer Verbesserung des zukünftigen Nachwuchses nicht angezeigt.<sup>336</sup> Selbst mit dem traditionellen Verständnis der Ehe als ein auf Fortpflanzung angelegtes Institut<sup>337</sup> sind die Techniken des genetischen Keimbahn-Enhancements vereinbar. Immerhin handelt es sich dabei um eben zu diesem Zweck vorgenommene Behandlungen von Keimzellen. Freilich sind davon nur die Modalitäten der Produktion und mithin das Wie der Fortpflanzung betroffen, indem nun das sonst Zufällige verfügbarer gemacht wird. Auch eine solche Veränderung der Erbanlagen des Nachwuchses unterfällt aber dem weiten Schutzbereich des Rechts auf reproduktive Autonomie<sup>338</sup> und plädiert somit für die Zulässigkeit des genetischen Keimbahn-Enhancements.

<sup>331</sup> von Münch/Kunig-Coester-Waltjen, GG, Art. 6 Rdnr. 32.

<sup>332</sup> Unter Berufung auf *Ronald Dworkin* und *Julian Savulescu*: *Harris*, *Enhancing Evolution*, S. 75 f.

<sup>333</sup> BVerfGE 66, 84 (94); Dreier-Gröschner, GG, Art. 6 Rdnr. 65; von Mangoldt/Klein/Starck-Robbers, GG, Art. 6 Abs. 1 Rdnr. 92; Jarass/Pieroth, GG, Art. 6 Rdnr. 4; *Stern*, Staatsrecht IV/1, § 100 IV 4 a) α), S. 409; *Ramm*, JZ 1989, 861 ff.

<sup>334</sup> *Enquete-Kommission „Recht und Ethik“*, S. 111; von Münch/Kunig-Coester-Waltjen, Art. 6 Rdnr. 32; *Hufen*, MedR 2001, 440 (442 f.).

<sup>335</sup> *Gutmann*, Rechtliche und rechtsphilosophische Fragen der PID, S. 64.

<sup>336</sup> Freilich geht es vorliegend aufgrund der zeitlichen Begrenzung des Rechts auf reproduktive Autonomie auf die präkonzeptionelle und pränatale Phase nur um die Modifikation der Gameten oder der Zygote.

<sup>337</sup> Dreier-Gröschner, GG, Art. 6 Rdnr. 66.

<sup>338</sup> Vergleiche auch *Harris*, *Enhancing Evolution*, S. 76 ff.; *Siep*, *Wissen – Vorbeugen – Verändern*, S. 84.

## II. Berufsfreiheit des Arztes, Art. 12 I GG

Primärer Adressat eines Verbots genetischen Enhancements wäre der Arzt, der entsprechende Maßnahmen durchführen möchte. Ausweislich des Wortlautes des Art. 12 I GG haben alle Deutschen das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Entsprechend könnte der Arzt, der Deutsche im Sinne des Art. 116 I GG oder zumindest EU-Ausländer ist<sup>339</sup> und dem die Durchführung eines genetischen Enhancements an Keimbahnzellen oder an somatischen Zellen untersagt wird, in seinem durch diese Verfassungsnorm verbürgten Recht auf freie Berufswahl verletzt sein.

Die Berufsfreiheit schützt die Ausübung der gewählten beruflichen Tätigkeit frei von staatlichen Beeinträchtigungen. Bei der Durchführung eines genetischen Enhancements müsste es sich mithin um eine berufliche Tätigkeit im Sinne dieser Verfassungsnorm handeln. Hierunter versteht man eine auf Dauer angelegte, sich also nicht in einem einzelnen Erwerbsakt erschöpfende Tätigkeit, die der Schaffung oder Erhaltung einer Lebensgrundlage dient.<sup>340</sup> Zum Teil wird des Weiteren verlangt, dass die Tätigkeit auch wirtschaftlich sinnvoll sein beziehungsweise einen Beitrag zur gesellschaftlichen Gesamtleistung darstellen muss.<sup>341</sup> Bei der Durchführung von genetischen Enhancements wird es sich in besonderem Maße um eine spezialisierte Tätigkeit handeln, der nur wenige Mediziner und Gentechniker nachzugehen befähigt sein werden, die dies dann aber vermutlich, ebenso wie andere Reproduktionsmediziner, exklusiv und daher sogar wiederkehrend tun werden. Darüber hinaus kann erwartet werden, dass sich der Grundrechtsträger mit dieser Tätigkeit ein Auskommen schafft, weswegen sie auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Dass sie zudem einen Beitrag zur wirtschaftlichen Gesamtleistung erbringt, ist bei beruflichen Tätigkeiten in der Regel anzunehmen.<sup>342</sup>

Fraglich und umstritten ist jedoch, ob die etwaige berufliche Tätigkeit weiterhin erlaubt sein muss oder zumindest nicht sozial- oder gemeinschaftsschädlich sein darf. Während einer Auffassung zufolge es hierauf nicht ankommt, möchten Befür-

<sup>339</sup> Die Geltung des Art. 12 GG für EU-Ausländer ist umstritten, bedarf vorliegend jedoch keiner weiteren Erörterung. Lediglich der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Vertreter der gegen- teiligen Auffassung auf Art. 2 I GG verweisen: Dreier-Wieland, GG, Art. 12 Rdnr. 70, 72; Isensee/ Kirchhof-Breuer, HStR VII, § 147 Rdnr. 43; Jarass/Pieroth, GG, Art. 12 Rdnr. 10; von Mangoldt/ Klein/Starck-Manssen, GG, Art. 12 Abs. 1 Rdnr. 266 f.; von Münch/Kunig-Gubelt, GG, Art. 12 Rdnr. 5; Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf-Hofmann, GG, Art. 12 Rdnr. 6.

<sup>340</sup> St. Rspr., z. B. BVerfGE 7, 377 (397 ff.); 68, 272 (281); 97, 228 (252 f.); 105, 252 (265); 115, 276 (300); BVerwGE 1, 269 (279); 71, 183 (189); Dreier-Wieland, GG, Art. 12 Rdnr. 55 ff., 72; Jarass/Pieroth, GG, Art. 12 Rdnr. 4 ff.; von Mangoldt/Klein/Starck-Manssen, GG, Art. 12 Abs. 1 Rdnr. 37 ff.; Maunz/Dürig-Scholz, GG, Art. 12 Rdnr. 29 ff.; von Münch/Kunig-Gubelt, GG, Art. 12 Rdnr. 8 ff.

<sup>341</sup> Sachs-Mann, GG, Art. 12 Rdnr. 50 f.

<sup>342</sup> Vergleiche BVerfGE 50, 290 (362); daher wird häufig auch kritisiert, dass das Kriterium des Beitrags zugunsten der wirtschaftlichen Gesamtleistung kein konstituierendes für den Berufsbe- griff ist, sondern lediglich ein deskriptives Merkmal darstellt: von Mangoldt/Klein/Starck-Manss- en, GG, Art. 12 Abs. 1 Rdnr. 38; Sachs-Mann, GG, Art. 12 Rdnr. 51.



worter der anderen Auffassung den Berufsbegriff auf erlaubte Tätigkeiten beschränken.<sup>343</sup> Ein Streitentscheid könnte jedoch dahinstehen, wenn die Durchführung des genetischen Enhancements erlaubt und damit das Kriterium des Erlaubtseins für den Fall, dass es als Voraussetzung begriffen werden würde, ohnehin erfüllt wäre. Allerdings verstößt eine Manipulation der Keimbahn wie oben gezeigt gegen § 5 ESchG, und auch die Modifizierung von somatischen Zellen bleibt untersagt. Entsprechend kommen beide Ansichten zu unterschiedlichen Ergebnissen: Nach der ersten Auffassung läge kein Beruf im Sinne des Art. 12 I GG vor, mit der zweiten Auffassung stünde ein einfachgesetzliches Verbot, gegen das die Tätigkeit verstößt, ihrer Klassifizierung als Beruf im Sinne des Art. 12 I GG nicht im Wege. Für letztgenannte Auffassung spricht jedoch, dass andernfalls der Berufsbegriff zur Disposition des einfachen Gesetzgebers stünde. Der Schutzbereich des Art. 12 I GG könnte durch ein allgemeines Gesetz eingeschränkt werden.<sup>344</sup> Zu befürchten sei daher eine einfachgesetzliche Aushöhlung der Berufsfreiheit. Vielmehr komme dem Grundrecht aus Art. 12 I GG die Funktion zu, darüber zu entscheiden, ob und inwieweit eine Tätigkeit durch einfaches Gesetz verboten werden darf. Dürfte das Kriterium des Erlaubtseins schon den Schutzbereich begrenzen, könnte der einfache Gesetzgeber über Inhalt und Reichweite des durch Art. 12 I GG gewährleisteten Grundrechtsschutzes disponieren.<sup>345</sup> Dies würde jedoch der Vorschrift des Art. 79 II GG widersprechen. Systematisch ist eine solche Begrenzung des Art. 12 I GG daher verfehlt. Es ist somit unbeachtlich, ob die Tätigkeit eine erlaubte sein muss, um ein Beruf im Sinne dieser Verfassungsnorm sein zu können. Entsprechend kann die Durchführung von genetischen Enhancements durch (Reproduktions-)Mediziner und Gentechniker als ein solcher bejaht werden. Wird dies jedoch untersagt, ist der Schutzbereich des Art. 12 I GG berührt.

### III. Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit, Art. 5 III GG

Zudem könnte ein Verbot des genetischen Enhancements eine Verletzung der Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit des Art. 5 III GG darstellen. Diese gewährt jedem, der ernsthaft und planmäßig die Wahrheit zu ermitteln versucht, Freiheit von staatlichen Beeinträchtigungen.<sup>346</sup> Insoweit es nicht um die Anwendung einer

<sup>343</sup> Gegen diese weitere Voraussetzung: BVerfGE 115, 276 (300 f.); *Jarass/Pieroth*, GG, Art. 12 Rdnr. 7; *Sachs-Mann*, GG, Art. 12 Rdnr. 52 f.; für eine Beschränkung auf lediglich erlaubte Tätigkeiten hingegen: BVerfGE 68, 272 (281); 81, 70 (85); BVerwGE 87, 37 (40); *Pieroth/Schlink*, Grundrechte, § 21 II 1 Rdnr. 879; *Maunz/Dürig-Scholz*, GG, Art. 12 Rdnr. 39; für eine Beschränkung auf Betätigungen, die nach den jeweils herrschenden gesellschaftlichen Vorstellungen nicht absolut gemeinschaftsschädlich sind: *Maunz/Dürig-Scholz*, GG, Art. 12 Rdnr. 37.

<sup>344</sup> *Jarass/Pieroth*, GG, Art. 12 Rdnr. 7.

<sup>345</sup> *Sachs-Mann*, GG, Art. 12 Rdnr. 52, BVerfGE 115, 276 (301); BVerwGE 22, 286 (288); 96, 293 (296 f.); 96, 302 (308); *Stein/Frank*, Staatsrecht, § 43 II 1.

<sup>346</sup> BVerfGE 35, 79 (113); 47, 327 (367); *Dreier-Pernice*, GG, Art. 5 III Rdnr. 17, 24; *Jarass/Pieroth*, GG, Art. 5 Rdnr. 121; *Maunz/Dürig-Scholz*, GG, Art. 5 Abs. 3 Rdnr. 91, 99, 101; *Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf-Kannengießer*, GG, Art. 5 Rdnr. 30.

bekannten Methode, sondern um deren Verbesserung beziehungsweise die Erforschung noch unbekannter Aspekte des genetischen Enhancements oder, allgemeiner gesprochen, der Reproduktionsmedizin geht, ist in das Grundrecht des Arztes aus Art. 5 III GG eingegriffen.<sup>347</sup>

Allerdings darf nicht außer Acht gelassen werden, dass diese Forschung sich nicht mehr ausschließlich im persönlichen Bereich des Forschers befindet. Da zwangsläufig die ersten Anwendungen von Techniken des genetischen Enhancements beim Menschen unsicher und die Resultate nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorhersehbar sein werden, aber zur Verbesserung dieser Methoden die Durchführung an menschlichen Zellen erforderlich wird, verlässt die Forschung aber auch den internen Bereich des Forschers und berührt dadurch zwangsläufig Rechte Dritter, nämlich des frühen Embryos beziehungsweise der Person, die an sich eine Modifizierung somatischer Zellen vornehmen lässt. Dieser Konflikt *„zwischen der Gewährleistung der Wissenschaftsfreiheit und dem Schutz anderer verfassungsrechtlich garantierter Rechtsgüter“* muss daher *„nach Maßgabe der grundgesetzlichen Wertordnung und unter Berücksichtigung der Einheit dieses Wertsystems durch Verfassungsauslegung gelöst werden“*<sup>348</sup>. Eine Einschränkung der Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit aus Art. 5 III GG kann daher, um entgegenstehende Grundrechte Dritter oder anderer Werte von Verfassungsrang zu berücksichtigen, nicht ausgeschlossen werden.<sup>349</sup>

#### IV. Schutzaussagen des Elternrechts, Art. 6 II 1 GG

Aus Art. 6 II 1 GG ergibt sich, dass Eltern nicht nur subjektive Rechte, etwa die klassischen Abwehrrechte gegen nicht von Absatz 3 gedeckte staatliche Eingriffe, zustehen, sondern dass sie ebenso verschiedene Fürsorgepflichten gegenüber ihren Kindern treffen. Diese sind nicht Schranken des Elternrechts, sondern dessen wesensbestimmender Bestandteil. Die durch Art. 6 II 1 GG verbürgte Rechtsstellung der Eltern stellt sich als *„komplexe und integrale Verknüpfung von Recht und Pflicht“*<sup>350</sup> dar. Das Elternrecht ist somit eigentlich Elternverantwortung. Grund des derart ausgestalteten Elternrechts ist nicht die Freiheitsentfaltung der Eltern. Vielmehr sind es Wohl, Interesse und Persönlichkeitsentfaltung des Kindes. Die Entscheidungen der Eltern haben sich daher stets am Kindeswohl zu orientieren. Sind die Eltern zwar Grundrechtsträger, so ist das Kind doch Grundrechtsbegünstigter.

<sup>347</sup> Hufen, Individuelle Rechte und die Zulassung der PID, S. 132; Hufen, MedR 2001, 440 (444).

<sup>348</sup> BVerfGE 47, 327 (369).

<sup>349</sup> Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf-Kannengießner, GG, Art. 5 Rdnr. 32, 20; Kirchhof, Genforschung und die Freiheit der Wissenschaft, S. 17.

<sup>350</sup> Jestaedt in Bonner Kommentar zum GG, Art. 6 Abs. 2 und 3, Rdnr. 29.

Dem Kind gegenüber ist die Gewährleistung des Art. 6 II GG „*ein dienendes, ein treuhänderisches, ein fiduziarisches Grundrecht*“.<sup>351</sup>

Im Hinblick auf ein genetisches Enhancement ergibt sich hieraus, dass in Fällen eines Eingriffes in somatische Zellen, der bei einem noch minderjährigen Kind vorgenommen werden soll, unzweifelhaft der Entscheidungs- und Zuständigkeitsbereich dessen Eltern eröffnet ist, die ihre Entscheidung Art. 6 II 1 GG zufolge jedoch am Kindeswohl orientieren müssen.

Fraglich ist jedoch, ob Art. 6 II 1 GG auch einschlägig ist, wenn von der genetischen Modifikation lediglich die Gameten betroffen sind oder diese an der Zygote vorgenommen wird. Zum Teil wird bereits eine pränatale Wirkung des Art. 6 II 1 GG angenommen, wobei die sich hieraus ergebenden Rechte und Pflichten in zeitlicher Hinsicht bis auf den Moment der Zeugung zurückgehen sollen.<sup>352</sup> Hierfür könnte insbesondere die Möglichkeit eines die Leibesfrucht gefährdenden Verhaltens der Eltern schon während der Schwangerschaft, beispielsweise durch Suchtmittelkonsum, sprechen. Derartige Befürchtungen werden auch vorgebracht, wenn die Anwendung des § 1666 BGB auf vorgeburtliches Leben diskutiert wird. Als verfassungsrechtlicher Hintergrund dieser zeitlichen Ausdehnung werden sodann die in Art. 1 I und Art. 2 II 1 GG verbürgten Positionen genannt.<sup>353</sup> Insbesondere Art. 2 II 1 GG vermag es hierbei, den *nasciturus* vor schädigenden pränatalen Einflüssen ausreichend zu schützen, sodass es einer Extension der Wirkung des Art. 6 II 1 GG auf den vorgeburtlichen Zeitraum zumindest in Bezug auf gesundheitsrelevantes Verhalten nicht mehr bedarf.

Gegen eine vorgeburtliche Ausdehnung sprechen weiterhin Wortlaut und Regelungszusammenhang der Verfassungsnorm des Art. 6 II 1 GG. Pflege und Erziehung, zu denen Art. 6 II 1 GG die Eltern sowohl berechtigt als auch verpflichtet, sind erst nach der Geburt möglich. Während unter Pflege sowohl die Gesundheits- als auch die Vermögenspflege verstanden wird, ist der Erziehungsbegriff im Sinne einer Verantwortung der Eltern für eine menschenwürdeadäquate Entfaltung der Persönlichkeit des Kindes unter Vermittlung beispielsweise von Wissen und Werten zu interpretieren.<sup>354</sup> Beides ist erst mit Erlangung eines direkten Zuganges zum Kind, das heißt also mit dessen Geburt, möglich.<sup>355</sup>

Zwar wird der Begriff „Kind“ im allgemeinen Sprachgebrauch häufig auch für den *nasciturus* verwendet. In derlei Zusammenhängen handelt es sich jedoch nicht um eine objektive, etwa naturwissenschaftlich korrekte Bezeichnung, sondern vielmehr um einen subjektiven Ausdruck einer bereits entstehenden emotiona-

<sup>351</sup> BVerfGE 59, 360 (376 f.); 64, 180 (189); 72, 122 (137); 107, 104 (121); von Mangoldt/Klein/Starck-Robbers, GG, Art. 6 Abs. 2 Rdnr. 140, 145 ff.; Jarass/Pieroth, GG, Art. 6 Rdnr. 36; Maunz/Dürig-Badura, GG, Art. 6 Abs. 2, 3 Rdnr. 109; von Münch/Kunig-Coester/Waltjen, GG, Art. 6 Rdnr. 81.

<sup>352</sup> von Mangoldt/Klein/Starck-Robbers, GG, Art. 6 Abs. 2 Rdnr. 155; Brohm, JuS 1998, 197 (201).

<sup>353</sup> Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfau-Hofmann, GG, Art. 6 Rdnr. 42a.

<sup>354</sup> Dreier-Gröschner, GG, Art. 6 Rdnr. 109 f.; Sachs-Schmitt-Kammler/von Coelln, GG, Art. 6 Rdnr. 52; Maunz/Dürig-Badura, GG, Art. 6 Abs. 2, 3 Rdnr. 107 plädiert für eine einheitliche Auffassung von Pflege und Erziehung.

<sup>355</sup> Sachs-Schmitt-Kammler/von Coelln, GG, Art. 6 Rdnr. 53 spricht dem entsprechend anschaulich auch von „Einwirkung“.

len Bindung der (werdenden) Eltern gegenüber dem Embryo oder, ab der neunten Schwangerschaftswoche, dem Fötus. Der Gesetzgeber differenziert hingegen deutlich zwischen befruchteten Eizellen<sup>356</sup>, Embryonen, Föten und Menschen,<sup>357</sup> die sowohl im ursprünglichen als auch im übertragenen Wortsinn den Gattungsbegriff für beispielsweise eben auch Kinder und Erwachsene darstellen. Ist in anderen Fällen von „Kind“ oder „Kinder[n]“ die Rede, so beziehen sich diese Begriffe soweit ersichtlich stets auf bereits geborene Nachkommen.<sup>358</sup> So wird konstatiert, dass die Elternverantwortung „*buchstäblich vom ersten Schrei des Säuglings an*“ besteht.<sup>359</sup>

Für dieses Ergebnis spricht auch der Regelungszusammenhang des Art. 6 GG, dessen Absätze 3 und 5 ebenfalls erst ab Geburt des Kindes relevant werden. Lediglich Absatz 4 bezieht sich mit dem Schutz der Schwangeren und somit auch eines anderen Grundrechtsbegünstigten auf die pränatale Phase. Im Hinblick auf ein genetisches Enhancement ergibt sich hieraus, dass in Fällen, in denen lediglich die Gameten oder die Zygote genetisch modifiziert werden, Art. 6 II 1 GG noch nicht einschlägig ist.

Ein Verbot des genetischen Enhancement würde den Schutzbereich dieser Verfassungsnorm somit nur beeinträchtigen, sofern es die Manipulation von somatischen Zellen eines geborenen Kindes im Sinne des Art. 6 II 1 GG betrifft.

## V. Art. 2 II 1 GG als Grundrecht des (zukünftigen) Kindes

Ein originär und unmittelbar dem Kind zukommendes Grundrecht, welches ebenfalls durch ein Verbot des genetischen Enhancements betroffen sein könnte, ist das freiheitsschützende Grundrecht aus Art. 2 II 1 GG. Dieses gewährleistet nicht nur die Unversehrtheit des Menschen nach Maßgabe seines jeweiligen konkreten Gesundheitszustandes, sondern bietet auch Freiheitsschutz hinsichtlich der leiblich-seelischen Integrität des Menschen<sup>360</sup> und eine diesbezügliche Selbstbestimmung.<sup>361</sup> „*Den einzelnen will diese Vorschrift nicht davon abhalten, über seine körperliche Unversehrtheit selbst zu bestimmen.*“<sup>362</sup>

<sup>356</sup> Zum Beispiel § 218 I 2 StGB.

<sup>357</sup> So etwa § 5 IV Nr. 2 a) ESchG.

<sup>358</sup> Vergleiche hierzu §§ 1618a, 1619, 1620, 1624 I, 1625S. 1, 1626, 1627, 1924 I, 2068 BGB; die deutliche Trennung von post- und pränatalem Leben wird auch in § 1923 II BGB deutlich.

<sup>359</sup> Dreier-Gröschner, GG, Art. 6 Rdnr. 98; im Ergebnis ebenfalls Jarass/Pieroth, GG, Art. 6 Rdnr. 38; von Münch/Kunig-Coester-Waltjen, GG, Art. 6 Rdnr. 68; Isensee/Kirchhof-Zacher, HStR VI, § 134 Rdnr. 3 hingegen spricht wenig präzise davon, „*daß Kinder vom ersten Augenblick ihres Lebens auf Hilfe und Sorge angewiesen sind.*“ Wann im Kontext des Art. 6 II 1 GG jedoch der Beginn des Lebens zeitlich verortet werden soll, wird zunächst nicht weiter ausgeführt, später jedoch zumindest als Frage aufgeworfen (Isensee/Kirchhof-Zacher, HStR VI, § 134 Rdnr. 59).

<sup>360</sup> BVerfG NJW 1979, 1925 (1931).

<sup>361</sup> BVerfGE 128, 282 (302).

<sup>362</sup> BGHZ 79, 131 (142).

Unumstritten ist dies freilich nicht. So wird teilweise vorgebracht, dass sowohl das Recht auf Leben als auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit ausschließlichen Abwehrcharakter haben und mit dem Recht auf Leben kein negatives Freiheitsrecht als das Recht „es bleiben zu lassen“ korrespondiert sowie dass aus dem Recht auf körperliche Unversehrtheit kein Recht folgt, nach Gutdünken über seinen Körper zu verfügen. Eine solche Freiheit wird dann aber über Art. 2 I GG bejaht.<sup>363</sup>

Dabei ist allerdings zu bedenken, dass es eine Sache ist, ob der Staat sich schützend und fördernd vor das Leben und die Gesundheit seiner Bürger stellt, um diese vor rechtswidrigen Eingriffen Dritter zu schützen, es aber gleichwohl etwas ganz anderes ist, wenn es nicht um eine Gefährdung oder Schädigung durch Dritte, sondern durch den jeweiligen Rechtsgutsinhaber selbst geht. Art. 2 II 1 GG beinhaltet zwar umstrittenermaßen, aber nach herrschender Auffassung keine Pflicht des Staates, das Individuum vor einer Gefährdung oder Schädigung seiner selbst zu schützen.<sup>364</sup> Der Gedanke der Freiheit zur Selbstgefährdung und sogar zur Selbstschädigung knüpft an die Staatstheorien der Aufklärung an. Als Reaktion auf die staatliche Bevormundung und Willkür des Absolutismus wurde anschließend der Freiheit des Menschen zum Glück nach eigener Wahl eine prominente Rolle in einer gerechten Staats- und Gesellschaftsordnung beigemessen und der Gestaltung des eigenen Lebens unter Vorbehalt der gleichen Freiheit anderer ohne staatliche Bevormundung Vorrang eingeräumt.<sup>365</sup> Die gegenläufige Vorstellung, aus Art. 2 II 1 GG folge eine Pflicht des Einzelnen zur gesundheitsfördernden Lebensweise, verkennt dabei die Freiheitszusage des Art. 2 I GG. Grundsätzlich handelt nicht derjenige, der zu Lasten seiner Gesundheit lebt, rechtswidrig.<sup>366</sup> Jeder mag am Wochenende trotz der Gefahr einer Schädigung seines Gehörs in der Diskothek zu lauter Musik tanzen, dabei rauchen und alkoholische Getränke konsumieren, bevor er sich auf dem Heimweg noch einen fettigen Mitternachtssnack gönnt, während ein anderer es vorzieht, einer Extremsportart nachzugehen, bei der ein – wenn nicht gerade tödlich endender – Unfall in aller Regel schwerste körperliche Schäden mit sich bringen könnte, oder ein Dritter zwar eine weniger gefährliche Sportart betreibt, diese aber so exzessiv, etwa weil er Berufssportler ist oder fragwürdige Schönheitsideale hegt, dass auch diese nicht mehr gesundheitsfördernd ist. Gleiche Freiheiten müssen ebenfalls für die gesamte Lebensgestaltung gelten.

Kritisch wird gegen die Vorstellung, dem liberalen Rechtsstaat käme die Aufgabe zu, erwachsene, einsichtsfähige und hinreichend informierte Menschen gegen ihren Willen vor sich selbst zu schützen, vorgebracht, sie nähme die betreffenden Menschen nicht als Personen ernst und verkenne die primäre Aufgabe der Grundrechte, Spielräume für eigenverantwortliches Handeln zu schaffen und dem Einzelnen zu gewährleisten. Der gesetzgeberische Paternalismus sieht sich daher allenthalben mit einem grundsätzlichen Legitimitätsdefizit konfrontiert, denn die freiheitliche

<sup>363</sup> Schwabe, JZ 1998, 66 (69).

<sup>364</sup> Dreier-Schulze-Fielitz, GG, Art. 2 II Rdnr. 84; Steiner, NJW 1991, 2729 (2734).

<sup>365</sup> Hillgruber, Der Schutz des Menschen vor sich selbst, S. 20 ff., 45 ff.; Singer, JZ 1995, 1133 (1134).

<sup>366</sup> Dreier-Schulze-Fielitz, GG, Art. 2 II, Rdnr. 84; Steiner, NJW 1991, 2729 (2734).

Konzeption der Grundrechte ermöglicht es, die eigene Person Risiken auszusetzen und für sich selbst Schäden in Kauf zu nehmen – zumindest insoweit, als dass kein Dritter oder die Allgemeinheit in Mitleidenschaft gezogen wird.<sup>367</sup> So ist ein Rauchverbot in öffentlichen Räumen beispielsweise auch nicht mit einem Schutz der Raucher zu begründen, sondern lediglich vor dem Hintergrund der Schädigung der anderen Anwesenden zu legitimieren.<sup>368</sup> Hinsichtlich der Personen, die sich dazu entschieden haben, zu rauchen und sich somit dem Risiko einer Gesundheitsschädigung auszusetzen, kommt ein Schutz durch Aufklärung und Warnung mittels Hinweisen auf Zigarettenpackungen oder Werbung in Betracht.<sup>369</sup>

Fraglich ist nunmehr aber, was diese Erkenntnisse für die vorliegende Situation eines genetischen Enhancements implizieren. Auch hier muss wiederum anhand des Entwicklungsstadiums des Individuums, an dem das genetische Enhancement durchgeführt werden soll, differenziert werden. Entscheidet sich ein einsichts- und einwilligungsfähiger Mensch dazu, sich selbst einem Enhancement einer Gruppe somatischer Zellen zu unterziehen, so wird man, wenn man obiger Argumentation folgt, vor dem Hintergrund der sich daraus ergebenden Selbstgefährdung nichts einwenden können.

Etwas anderes könnte sich aber dann ergeben, wenn das Kind, an dem das Enhancement durchgeführt werden soll, noch nicht einwilligungsfähig ist und daher die Eltern die entsprechende Willenserklärung für das Kind abgeben. Hierin liegt eine stellvertretende Ausübung des Grundrechts des Kindes durch die Eltern, das heißt, dass weiterhin das Grundrecht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit beziehungsweise das dem entsprechende Selbstbestimmungsrecht betroffen ist, dass aber nicht das Kind selbst dieses ausübt, sondern die Eltern seine Interessen anstelle des Kindes für dieses wahrnehmen.

Gleiches müsste dann auch schon im Hinblick auf die Zygote oder den Embryo gelten, an dem Maßnahmen des genetischen Enhancements durchgeführt werden sollen. Wie später ausführlich zu erörtern sein wird, vertrete ich in vorliegender Arbeit die Auffassung, dass das Grundrecht aus Art. 2 II 1 GG mit der Befruchtung der Eizelle durch die Verschmelzung der jeweils haploiden Chromosomensätze von Ei- und Samenzelle entsteht. Sowohl die Zygote, als auch der spätere Embryo und natürlich jeder geborene Mensch sind daher davon umfasst, während die Gameten nicht in den Schutzbereich dieses Grundrechts fallen. Dieses Ergebnis muss auch bei einer Zeugung in der Petrischale gelten, denn das Vorliegen menschlichen Lebens muss unabhängig von den Umständen seines Zustandekommens bleiben. Daraus folgt, dass theoretisch schon die Eltern des pränatalen Kindes dessen, aus dem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit folgendes Selbstbestimmungsrecht stellvertretend für dieses ausüben könnten.

<sup>367</sup> Gutmann, NJW 1999, 3387 (3388).

<sup>368</sup> BVerfGE 121, 317 (359); vgl. auch BVerfGE 59, 275 (278 f.); Maunz/Dürig-Di Fabio, GG, Art. 2 Abs. 2 Rdnr. 82.

<sup>369</sup> Maunz/Dürig-Di Fabio, GG, Art. 2 Abs. 2 Rdnr. 82, 89; vergleiche dazu auch BVerfG NJW 1998, 2961 f.



Indes scheint dies nicht angemessen und auch nicht dem Begründungszusammenhang der freiheitsrechtlichen Komponente des Art. 2 II 1 GG zu entsprechen. Das aus dieser Grundrechtsnorm resultierende Selbstbestimmungsrecht soll ja gerade aus der Überlegung folgen, dass es grundsätzlich jedem anheimgestellt sein kann, welche Risiken er für sich beziehungsweise seine eigene Gesundheit in Kauf nehmen möchte und mit welcher Motivation er dies tut und ob er sich damit gegebenenfalls selbst an der Gesundheit schädigt. Würde man ihm diese Freiheit der Entscheidung verwehren, sähe sich die entsprechende Norm als paternalistische zu Recht scharfer Kritik ausgesetzt. Grund dafür ist, dass man die jeweilige Person als solche ernst nimmt, weil man ihr die Fähigkeit und das Recht zubilligt, diese Entscheidungen zu treffen und eine entsprechende Wertung vorzunehmen, aufgrund derer sie zu der Auffassung gelangt, dass sie die Gefährdung oder die Schädigung ihrer Gesundheit – aus welchem nachvollziehbaren und vernünftigen oder eben auch unverständlichen und unvernünftigen Grund auch immer – will. Zentral ist bei dieser Überlegung aber, dass es sich dabei gerade um die je eigene Wertung, die darauf beruhende eigene, das heißt selbst getroffene Entscheidung und mithin um die jeweils persönliche Selbstbestimmung geht. Dass diese aber von Dritten stellvertretend für den Selbstbestimmten ausgeübt werden könnte, widerspricht schon dem eigentlichen Verständnis des Wortes selbst. Charakteristisch ist für die Selbstbestimmung, dass sie gerade nur dem Selbst unterliegt. Insofern ist es zwar denkbar – und *optimaliter* auch der Fall –, dass Eltern sich bei Entscheidungen bezüglich ihres Kindes, welches aufgrund seines noch jungen Alters noch nicht über die erforderliche Einsichtsfähigkeit verfügt, ausschließlich daran orientieren, was für das Kind das Beste ist, und sich gegebenenfalls auch fragen, wie das Kind vernünftigerweise entscheiden würde. Hier liegen nun aber gleich zwei Probleme verborgen: Zum einen ist doch gar nicht klar, dass das Kind sich auch tatsächlich für die vernünftige Handlungsalternative entscheiden würde, vorausgesetzt es würde schon über seine später eintretende Einsichts- und Erkenntnisfähigkeit verfügen, denn schließlich steht es ihm im Rahmen seines auch körperlichen Selbstbestimmungsrechts frei, gerade nicht die risikoarme und unschädliche Variante zu wählen und seine Entscheidung auf vollkommen unberechenbare Überlegungen zu stützen. Zum anderen aber würde, wollte man die Ausübung eines Selbstbestimmungsrechts auf andere als den Selbstbestimmten an dessen Stelle in Stellvertretung übertragen, dies große Missbrauchsgefahren in sich bergen.

Dies ließe sich natürlich immer auch beispielsweise dann einwenden, wenn Eltern für ihr nicht einwilligungsfähiges Kind einer Operation zustimmen, die im medizinischen Sinne notwendig ist. Natürlich ist es denkbar, dass das Kind, könnte es die Entscheidung schon vollständig informiert und reflektiert treffen, sich, aus welchem Grund auch immer, gegen die Operation entscheiden und die daraus folgenden Konsequenzen hinnehmen würde. In dieser Konstellation aber ist es anerkannt und auch richtig, dass die Eltern diese Entscheidung treffen. Allerdings gibt es hierbei auch einen bedeutenden Unterschied zu der Situation des genetischen Enhancements, denn hier streitet für die parentale Entscheidungskompetenz die körperliche Unversehrtheit des Kindes als solche, bezüglich derer es nicht nur vertretbar, sondern auch wünschenswert ist, dass Dritte sich, sofern es sich nicht um

Fälle handelt, in denen der Betreffende sich schon informiert und reflektiert dazu geäußert hat, wie er möchte, dass in bestimmten Situationen mit ihm verfahren wird, wie es etwa bei Patientenverfügungen der Fall ist, daran orientieren, was der Betreffende, hätte er die jeweilige Frage bedenken und reflektieren können, vermutlich wollen würde. Liegen hierfür jedoch keine Anhaltspunkte vor, etwa weil der Betroffene als Kind noch nicht einwilligungsfähig ist und die für die Tragweite der Entscheidung relevanten Aspekte nicht begreifen und angemessen gewichten kann, sodass er nicht in der Lage ist, diesbezüglich einen Willen im juristischen Sinne zu bilden, an welchem sich Dritte bei der Entscheidung orientieren könnten, so ist der Rückgriff auf das Vernünftige sinnvoll. Entscheidungen in Fragen der Gesundheit beziehungsweise deren Herstellung also sind durchaus unproblematisch auf die Eltern übertragbar. Im Falle genetischer Enhancements jedoch geht es, wie die eingangs gefundene Definition von Enhancement in Abgrenzung zur Therapie gezeigt hat, gerade nicht darum. Wertungsmäßig muss dann aber folgen, dass im Hinblick auf die Entscheidung, ob Risiken für die Gesundheit eingegangen werden oder diese geschädigt wird, dann, wenn alles in allem die jeweilige Maßnahme nicht der Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit dient und daher nicht als Therapie klassifiziert werden kann, die Eltern dem Vernünftigen verpflichtete Dritte im Hinblick auf das nur von dem jeweils Betroffenen persönlich ausübbarer Selbstbestimmungsrecht sein müssen.<sup>370</sup> Wie jedoch bereits festgestellt, ist es dem Staat aber belassen, Leben und Gesundheit seiner sowohl prä-, als auch postnatalen Bürger vor Eingriffen Dritter zu schützen. Insoweit wäre dann Art. 2 II 1 GG als freiheitsschützendes Grundrecht des (zukünftigen) Kindes nicht von einem Verbot genetischen Enhancements betroffen.

Dies steht auch nicht etwa in einem Widerspruch zu der später detailliert diskutierten Annahme, dass, sofern sich das Enhancement auf Eigenschaften oder Umstände bezieht, die als *primary goods* im Sinne *John Rawls'*, das heißt solche Güter, von denen man vernünftigerweise stets mehr als weniger haben möchte, weil sie in der Lage sind, die Verwirklichung eines jeden individuellen Lebensplans prinzi-

---

<sup>370</sup> Dies führt jedoch nicht zu der zwingenden Annahme, dass eine stellvertretende Einwilligung der Eltern in nicht medizinisch indizierte Eingriffe andernorts ebenfalls nicht in Frage kommt. Beispielhaft sei hier die religiös motivierte Beschneidung angeführt, die neonatal oder bis zum Beginn der Pubertät durchgeführt wird. Die dortige Situation ist mit der hiesigen nämlich nicht ohne Weiteres zu vergleichen. Bei der Einwilligung in medizinische Eingriffe erscheint es zwar nicht zwingend, dass sich die Eltern ausschließlich an dem medizinisch Gebotenen orientieren. So lassen sich auch die lebensweltliche Umgebung des Kindes und deren religiöse und kulturelle Prägung in den Blick nehmen und der weitreichende Spielraum der Eltern im Rahmen ihrer Erziehungsprärogative berücksichtigen. Beides spricht aber eher für eine Zulässigkeit der parentalen Einwilligung in eine religiöse Zirkumzision als in einen genverbessernden Eingriff, da die Beschneidung ein nur leichter und risikoarmer Eingriff ist, der weder unmittelbar zu negativen gesundheitlichen Folgen noch zu einer Beeinträchtigung des Sexuallebens beschnittener Männer führt. Darüber hinaus ist in diesem Zusammenhang, nicht jedoch bei einem genetischen Enhancement, dem durch Art. 4 GG geschützten Recht der Eltern zur Erziehung ihres Kindes und Entscheidung über dessen Religionszugehörigkeit Rechnung zu tragen (ausführlich zur Beschneidung von Knaben im Spannungsfeld zwischen Strafrecht, Religionsfreiheit und elterlichem Sorgerecht *Fateh-Moghadam*, RW 2010, 115 ff.).



piell zu fördern, klassifiziert werden können, eine Grundrechtsverletzung (später: des Art. 1 I GG) in sachlicher Hinsicht nicht in Frage kommt. Denn im Hinblick auf Art. 2 II 1 GG kommt es nicht darauf an, ob das Ergebnis des genetischen Enhancements, welches später als sicher und so, wie es intendiert war, eingetreten angenommen wird. Hier geht es um die Frage, ob das Risiko, welches auf dem Weg dahin besteht, von Dritten in Stellvertretung für den Grundrechtsträger in Kauf genommen werden kann. Es geht also nicht um die Frage, ob das planmäßige Ergebnis dem Grundrechtsträger schaden und somit einen Eingriff in dessen Rechte darstellen würde, sondern um die dem vorgelagerte und isoliert zu beantwortende Frage der Gefährdung, die in dem Versuch, das Ergebnis zu erreichen, liegt, sodass es bei oben gefundenem Ergebnis bleibt.

## VI. Allgemeines Persönlichkeitsrecht und informationelle Selbstbestimmung, Art. 2 I i. V. m. Art. 1 I GG

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht findet als Produkt richterlicher Rechtsfortbildung des Bundesverfassungsgerichts und nach dessen ständiger Rechtsprechung seine Grundlage in Art. 2 I in Verbindung mit Art. 1 I GG.<sup>371</sup> Trotz Bezugnahme auf den Menschenwürdesatz ist Art. 1 I GG jedoch keinesfalls die etwaig betroffene Norm. Dies wäre mit den grundsätzlich möglichen Einschränkungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts unvereinbar. Vielmehr dient Art. 1 I GG hier als programmatische, objektiv-rechtliche Leit- und Auslegungsrichtlinie, die dem hohen Wert „der Integrität der menschlichen Person in geistig-seelischer Beziehung“ Rechnung zu tragen vermag.<sup>372</sup> Die Hinzuziehung des Art. 1 I GG zwecks inhaltlicher Bestimmung des Art. 2 I GG führt aber zu einer Verstärkung dessen Schutzes, da es nicht mehr lediglich um das Verhalten, sondern das Sein eines Menschen geht.<sup>373</sup>

Schutzgut des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist ein ganzes Bündel einzelner Persönlichkeitsausprägungen, die meist im Wege richterlicher Rechtsfortbildung einen besonderen, fallgruppenorientierten<sup>374</sup> Schutz aus Art. 2 I GG erfahren haben.

<sup>371</sup> BVerfGE 6, 389 (433); 27, 1 (6); 27, 344 (351); 32, 373 (378 f.); 33, 367 (374); 34, 205 (208); 34, 238 (245); 34, 269 (282); 35, 35 (39); 35, 202 (219 f.); 42, 234 (236); 44, 353 (372); 47, 46 (73); 49, 286 (298); 54, 148 (153); 54, 208 (217); 60, 123 (134); 63, 131 (142); 64, 261 (280); 67, 100 (142 f.); 72, 155 (167, 170); 75, 201 (217); 78, 77 (84); 79, 51 (63); 79, 256 (268 f.); 80, 367 (373 f.); 82, 236 (269); 84, 192 (194); 84, 239 (279); 89, 69 (82); 90, 255 (259); 90, 263 (270); 92, 191 (197); 95, 220 (241); 96, 56 (61); 96, 171 (181); 97, 391 (399); 99, 185 (193); 100, 271 (284); 100, 313 (358); 101, 106 (121); 101, 361 (379); grundlegend insbesondere das sog. Volkszählungs-urteil in BVerfGE 65, 1 (41).

<sup>372</sup> BVerfGE 27, 344 (350 f.); vergleiche auch BVerfGE 34, 238 (245); Dreier-Dreier, GG, Art. 2 I Rdnr. 68; von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 2 Abs. 1 Rdnr. 56 f., 89; Jarass, NJW 1989, 857; von Münch/Kunig-Kunig, GG, Art. 2 Rdnr. 30.

<sup>373</sup> von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 2 Abs. 1 Rdnr. 15, 89; Sachs-Murswiek, GG, Art. 2 Rdnr. 62; Jarass, NJW 1989, 857.

<sup>374</sup> BVerfGE 72, 155 (170).

Entsprechend ist der Schutzbereich prinzipiell entwicklungs offen. Dies erleichtert zwar nicht die Abgrenzung zu anderen Grundrechten,<sup>375</sup> ermöglicht aber auch flexiblere Reaktionen auf zwischenzeitlich auftretenden Regelungsbedarf sowie die Anpassung an durch den Wertewandel bedingte Maßstäbe.<sup>376</sup>

Der Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts umfasst Elemente, die nicht schon Gegenstand spezieller Freiheitsrechte sind. Entsprechend tritt es diesen gegenüber aber auch als nachrangig zurück.<sup>377</sup> Das allgemeine Persönlichkeitsrecht verfolgt dabei als Schutzzweck die Sicherung personaler Autonomie im Sinne eines Integritätsschutzes.<sup>378</sup> Es garantiert die autonome Selbstentfaltung, indem es einen privaten Bereich abschirmt und die Vertraulichkeit der dortigen Interaktion sichert, aber ebenso die nach außen gerichtete Selbstdarstellung und daher insbesondere einen Schutz vor verfälschender, entstellender oder auch schlichtweg nur unautorisierter Präsentation der eigenen Person in der Öffentlichkeit gewährleistet. Darüber hinaus unterfallen dem Schutzbereich auch alle Komponenten der Persönlichkeit, die für diese konstituierend sind, aber nicht den besonderen Freiheitsgarantien unterfallen.<sup>379</sup>

Das heißt, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht mit dem Schutz der personalen Integrität und der Freiheit vor Beeinträchtigung dieser durch andere das eher passive Element der Persönlichkeit betrifft, während die allgemeine Handlungsfreiheit deren aktive Entfaltung umfasst.<sup>380</sup>

## 1. Eingriffe in Gameten oder die Zygote

Vorliegend könnte als Einzelausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts im Falle von genetischen Modifizierungen der Gameten oder der Zygote das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung der zukünftigen Eltern betroffen sein. Dieses Grundrecht schützt die Autonomie eines jeden Menschen bezüglich der Kenntnis der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, des Ausschlusses anderer von ebendieser Kenntnis sowie der Verwendung der Daten.<sup>381</sup> Hierunter fällt auch das Recht, „nicht mehr über sich wissen zu müssen, als man selber will“<sup>382</sup>. In Fällen, bei denen es um die Selektion von gesunden Embryonen wegen zu be-

<sup>375</sup> Epping/Hillgruber-Lang, GG, Art. 2 Rdnr. 32, 34.

<sup>376</sup> von Münch/Kunig-Kunig, GG, Art. 2 Rdnr. 31

<sup>377</sup> Maunz/Dürig-Di Fabio, GG, Art. 2 Abs. 1 Rdnr. 127; Sachs-Murswiek, GG, Art. 2 Rdnr. 66.

<sup>378</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 2 I Rdnr. 68.

<sup>379</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 2 I Rdnr. 69, Epping/Hillgruber-Lang, GG, Art. 2 Rdnr. 34

<sup>380</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 2 I Rdnr. 23 f.; von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 2 Abs. 1 Rdnr. 15, 87; Sachs-Murswiek, GG, Art. 2 Rdnr. 59 ff.

<sup>381</sup> Beispielsweise BVerfGE 65, 1 (43); 78, 77 (84); 80, 367 (373); Dreier-Dreier, GG, Art. 2 I Rdnr. 78; Epping/Hillgruber-Lang, GG, Art. 2 Rdnr. 45; Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf-Hofmann, GG, Art. 2 Rdnr. 26; Hufen, Individuelle Rechte und die Zulassung der PID, S. 134; grundlegend BVerfGE 65, 1 ff.

<sup>382</sup> Benda, Erprobung der Menschenwürde am Beispiel der Humangenetik, S. 229.

fürchtender schwerer Erkrankung geht, also im einschlägigen Anwendungsbereich der Präimplantationsdiagnostik, deren Wertung für die Beurteilung des genetischen Enhancements herangezogen werden könnte, ließe sich argumentieren, dass zu schützende Grundrechtsträger zunächst einmal die Eltern hinsichtlich ihres eigenen genetischen Materials seien.<sup>383</sup> Wäre beispielsweise eine zu erwartende Behinderung des Kindes genetisch bedingt, bestünde eine unmittelbare Verbindung zu der genetischen Disposition der Eltern und damit dem Kern ihrer eigenen Identität, sodass die Kenntnis der genetischen Identität des Kindes auch zumindest teilweise Kenntnis der eigenen bedeuten würde.<sup>384</sup>

Zudem könnte die genetische Struktur des *in vitro* vorliegenden Embryos auch schwerwiegende Konsequenzen für die Lebenssituation der Familie, sowie die physische und psychische Gesundheit der Frau haben, sodass auch der Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts betroffen sein könnte, wenn die Verfügung über so bedeutsame Informationen eingeschränkt würde.<sup>385</sup>

Beide Erwägungen sind meines Erachtens jedoch auf Fälle des genetischen Enhancements nicht übertragbar. Aufgrund der zu erwartenden genetisch-pathologischen Unauffälligkeit des Kindes sind die Konsequenzen, die sich aus dessen Geburt für die Familie und die Gesundheit der Frau ergeben werden, keine anderen als diejenigen, die stets mit einer Schwangerschaft und der Geburt eines Kindes einhergehen. Freilich unterfällt die Entscheidung des Paares für oder gegen ein Kind dem Schutzbereich des durch Art. 1 I in Verbindung mit Art. 2 I GG gewährten Grundrechts. Auch mag dieses Grundrecht betroffen sein, wenn das Kind aufgrund einer schwerwiegenden Erkrankung besonderer Aufmerksamkeit und Pflege bedarf und die entstehende Lebenssituation für die Eltern daher sowohl physisch als auch psychisch eine besondere Belastung darstellt. Der verbessernde Eingriff in die genetische Ausstattung eines vollkommen gesunden Kindes hingegen erscheint mir keine Tätigkeit zu sein, die primär als Ausfluss des allgemeinen Persönlichkeitsrechts *der Eltern* zu qualifizieren wäre. Eine Verletzung des Grundrechts der zukünftigen Eltern aus Art. 2 I in Verbindung mit Art. 1 I GG ist mithin nicht ersichtlich.

## ***2. Als Recht geborener Personen bei Modifizierung somatischer Zellen***

Art. 2 I in Verbindung mit Art. 1 I GG könnte jedoch bei der Modifizierung somatischer Zellen Relevanz erlangen. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht gewährleistet auch Schutz gegen umfassende Einschränkungen der personalen Entfaltung beziehungsweise der Privatautonomie.<sup>386</sup> Entsprechend unterfällt auch die eigenverantwortliche Gestaltung des eigenen Erscheinungsbildes dem Schutzbereich des

<sup>383</sup> Hufen, Individuelle Rechte und die Zulassung der PID, S. 134 f.

<sup>384</sup> Hufen, MedR 2001, 440 (443).

<sup>385</sup> Hufen, MedR 2001, 440 (443).

<sup>386</sup> Jarass/Pieroth, GG, Art. 2 Rdnr. 50.

allgemeinen Persönlichkeitsrechts.<sup>387</sup> Beispielsweise ist somit die Frage, ob ein Beamter zu seiner Dienstkleidung privaten Ohrschmuck oder andere private Accessoires tragen darf oder wie die Haartracht zu gestalten sei, anhand des allgemeinen Persönlichkeitsrechts bewertet worden,<sup>388</sup> was zunächst einmal vermuten lassen könnte, dass auch die genetische Ausgestaltung im Lichte dieser verfassungsrechtlichen Vorkehrung zu betrachten sei.

Allerdings ist das durch Art. 2 I in Verbindung mit Art. 1 I GG geschützte Rechtsgut immer auch der Geltungsanspruch des Menschen, den er gegenüber und in der sozialen Welt hat, die ihn einerseits prägt, die andererseits aber auch durch ihn geprägt wird, indem er durch sein Handeln von ihr anerkannt werden möchte.<sup>389</sup> Es geht mithin immer um einen Drittbezug, um das Bild eines Dritten vom Betroffenen, um seine Ehre, aber auch um eine seinem individuellen Persönlichkeitsentwurf entsprechende Selbstdarstellung nach außen und optisch wahrnehmbar.<sup>390</sup> Vorliegend stellt sich demnach nun die Frage, ob es sich bei einem somatischen Enhancement um einen Akt der Selbstdarstellung, der freien Entfaltung nach außen handelt.

Zwar ließe sich vorbringen, dass es sich bei derart genverbessernden Maßnahmen um die Ausgestaltung des eigenen Körpers und seiner genetischen Ausstattung entsprechend des eigenen Selbstbildes und der subjektiv empfundenen Persönlichkeit handelt. Allerdings erschöpft sich dies in dem bloßen Durchführen-Lassen des Enhancements der eigenen Körperzellen, also einer auf den Genotyp gerichteten Tätigkeit, deren Auswirkungen auf den Phänotyp, also das nach außen hin Sichtbare, keineswegs unmittelbare sein müssen. Auch deren Forum, in dem eine etwaige Selbstdarstellung erfolgen könnte, ist ein auf den durchführenden Arzt beschränktes. Dieser Aspekt erscheint daher von nur geringer Relevanz. Entsprechend ließe sich der Durchführungsakt auch begreifen als ein Prozess, der nicht Ausdruck aktueller Persönlichkeit ist, sondern erst zu dieser hinführt. Nicht die Tätigkeit, wohl aber ihr Resultat ist dann aber Schutzgut des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes. Die Behandlung, der sich eine bereits geborene Person zum Zwecke der genetischen Verbesserung ihrer somatischen Zellen unterzieht, ist mithin nicht durch Art. 2 I in Verbindung mit Art. 1 I GG geschützt.

<sup>387</sup> Maunz/Dürig-*Di Fabio*, GG, Art. 2 Abs. 1 Rdnr. 130 mit Fn. 3.

<sup>388</sup> BVerfG, Kammerbeschluss vom 10.01.1991, 2BvR 550/90, NJW 1991, 1477 f.; BVerfG, Urteil vom 15.01.1999, 2 C 11/98, NJW 1999, 1985 f.; zum Tragen von Anstaltskleidung bei gerichtlichen Vorführungen BVerfG, Einstweilige Anordnung vom 3.11.1999, 2 BvR 2019/99, NJW 2000, 1399 (1400).

<sup>389</sup> Maunz/Dürig-*Di Fabio*, GG, Art. 2 Abs. 1 Rdnr. 127, *Jarass/Pieroth*, GG, Art. 2 Rdnr. 40.

<sup>390</sup> Vergleiche etwa Maunz/Dürig-*Di Fabio*, GG, Art. 2 Abs. 1 Rdnr. 132, 166; *Graf Vitzthum*, Gentechnologie und Menschenwürdeargument, S. 130.

## VII. Recht der Frau auf körperliche Unversehrtheit und auf Leben, Art. 2 II 1 GG

Das Recht auf körperliche Unversehrtheit und Leben aus Art. 2 II 1 GG schützt seinen Träger vor allen Einwirkungen, die seine Gesundheit im biologisch-physiologischen Sinne beeinträchtigen.<sup>391</sup> Da jede Schwangerschaft Auswirkungen auf die physische Integrität der Frau hat, gewährt es der Mutter daher einen Anspruch auf medizinischen und rechtlichen Schutz vor körperlichen Gefahren, die im Zusammenhang mit ihrer Schwangerschaft bestehen. Der Kern dieses Rechts ist auch schon durch die Menschenwürdegarantie des Art. 1 I GG geschützt.<sup>392</sup>

Bezeichnend ist hierbei, dass der Gesundheitsschutz der Mutter bis zur Geburt des Kindes in besonderem Maße berücksichtigt wird und so oft auch Vorrang vor dem fötalen Recht auf Leben hat.<sup>393</sup> Beispielhaft sind hier generell der Schwangerschaftsabbruch, insbesondere aber die Fälle der Spätabtreibungen noch im 9. Monat der Schwangerschaft zu nennen. Tatsächlich stellt ein genetisch kranker und nicht entwicklungsfähiger Embryo, der im Wege eines Spontanabortes auf natürliche Weise vom Körper der Mutter abgestoßen wird, ein ernst zu nehmendes Risiko für deren Gesundheit dar, vor dem diese medizinisch bestmöglich zu schützen ist.<sup>394</sup>

Im Hinblick auf ein genetisches Enhancement ist jedoch genau dieser Umstand nicht aus den Augen zu verlieren: Bei einem Keimbahn-Enhancement geht es, anders als etwa bei einer Präimplantationsdiagnostik<sup>395</sup>, gerade nicht um ursprünglich kranke Embryonen, sondern um gesunde, „normale“ Zygoten beziehungsweise Gameten, die für sich betrachtet jeweils nicht Veranlagungen aufweisen, die ein besonderes Risiko einer embryonalen Erkrankung und die somit eine Gefahr für die durch Art. 2 II 1 GG geschützten Interessen der Mutter begründen würden. Es ist zwar richtig, dass jede Schwangerschaft immer auch gewisse Risiken birgt und eine besondere körperliche Belastung für die Mutter darstellt, weswegen etwa auch grundsätzlich alle Maßnahmen, die im Hinblick auf eine oder im Rahmen einer Schwangerschaft ergriffen werden sollen, nur mit ihrer Zustimmung zulässig sind. Allerdings würde ein Verbot verbessernder genetischer Modifikationen nicht auch zu einem Anstieg dieser natürlichen Risiken führen. Vielmehr würden sie, dem aktuellen Stand medizinischer Forschung entsprechend zumindest vorerst, ein gesteigertes Risiko sogar begründen. Das Recht der Frau aus Art. 2 II 1 GG wäre entsprechend also nicht von einem Verbot des genetischen Enhancements betroffen.

<sup>391</sup> Dreier-Schulze-Fielitz, GG, Art. 2 II Rdnr. 33 ff.; Sachs-Murswiek, GG, Art. 2 Rdnr. 147 ff.

<sup>392</sup> Hufen, MedR 2001, 440 (444); Hufen, Individuelle Rechte und die Zulassung der PID, S. 136 f.

<sup>393</sup> So zum Beispiel BVerfGE 39, 1 (48 ff.); 88, 203 (265 f.); 98, 265 (323).

<sup>394</sup> Hufen, Individuelle Rechte und die Zulassung der PID, S. 136.

<sup>395</sup> Kloepper, JZ 2002, 417 (424).

## VIII. Schutz der Menschenwürde der Frau, Art. 1 I GG

In den Schutzbereich der in Art. 1 I GG als unantastbar ausgestalteten Menschenwürde fällt auch der Schutz der persönlichen Identität, zu der auch Fragen der Reproduktion zu zählen sind<sup>396</sup> und die im Hinblick auf ein Verbot des genetischen Keimbahnenenhancements betroffen sein könnte. Freilich unterfällt der persönlichen Identität auch die Entscheidung der Frau über die Aufnahme eines *in vitro* erzeugten Embryos in ihren Körper. Würde man eine Pflicht zum Transfer statuieren, so würde dies in der tatsächlichen Umsetzung die Degradierung der Frau zum Objekt einer Zwangsschwangerschaft bedeuten. Im Hinblick auf Art. 1 I GG darf es daher weder einen Implantationszwang noch eine Zwangs- „Adoption“ von Embryonen geben. Der Frau kommt hinsichtlich der Wahl zwischen Implantation und Nicht-Implantation mithin Entscheidungsfreiheit zu.<sup>397</sup>

Gilt dies für Reproduktionstechniken wie die Präimplantationsdiagnostik uneingeschränkt, ist eine solche „Entscheidung in Würde“ doch nur aufgrund ausreichender und adäquater Informationen möglich, die mittels Präimplantationsdiagnostik gewonnen werden können,<sup>398</sup> erweist sich die Situation des genetischen Enhancements als eine gänzlich andere. Hier kommt es zentral nicht auf die Frage an, ob ein (noch zu erzeugender) Embryo in die Gebärmutter transplantiert werden soll, sondern darauf, ob dessen natürlich kontingentes, aber pathologisch unauffälliges Genom modifiziert werden darf. Anders ausgedrückt würde, wollte man dies mit Blick auf die Frau an Art. 1 I GG messen wollen, hier also relevant, ob die Veränderung der genetischen Identität des *Kindes* Ausdruck der persönlichen Identität der *Frau* ist. Die Antwort liegt auf der Hand.

Gegen die Zulassung eines genetischen Enhancements mag des Weiteren vorgebracht werden, dass dessen Erlaubnis die Entscheidungsfreiheit und Autonomie der Frau keinesfalls vergrößere, sondern ihre Selbstbestimmung vielmehr einschränke und somit auch die Menschenwürde der Frau verletze, da sich diese einem psychischen und gesellschaftlichen Druck ausgesetzt sehen könnte. Ähnlich der gesellschaftlichen Erwartungshaltung gegenüber der Durchführung pränataler Diagnostik könnte aus der bloßen Möglichkeit eines genetischen Enhancements so ein subjektiv empfundener gesellschaftlicher Zwang erwachsen. Dies lässt jedoch außer Acht, dass bisweilen mitnichten absehbar ist, ob größere Teile der Gesellschaft jemals ein genetisches Keimbahn-Enhancement für ihre Nachkommen, welches wohl nie eine Kassenleistung sein wird, werden finanzieren können. Doch selbst wenn eine entsprechende Erwartungshaltung entstünde, weil wider Erwarten die Techniken sich als preislich günstiger erweisen, wäre ein generelles Verbot keineswegs angezeigt: Es wäre Kennzeichen einer patriarchalischen und voraufklärerischen Auffassung der Selbstbestimmung und spräche den Adressaten des Verbots jedwede

<sup>396</sup> Hufen, Individuelle Rechte und die Zulassung der PID, S. 138; zum ebenfalls durch Art. 1 GG geschützten Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung BVerfGE 79, 256 (268).

<sup>397</sup> Hufen, Individuelle Rechte und die Zulassung der PID, S. 138.

<sup>398</sup> Hufen, Individuelle Rechte und die Zulassung der PID, S. 139.

Entscheidungskompetenz und Fähigkeit zur Selbstreflexion ab.<sup>399</sup> Schließlich muss man sich auch in diesem Zusammenhang erneut verdeutlichen, was Schutzziel der über Art. 1 I GG geschützten Selbstbestimmung ist. Dabei geht es um die Eigenverantwortlichkeit in Lebensentscheidungen und den Kern individueller Selbstdarstellung des Einzelnen.<sup>400</sup> Die Entscheidung über die Durchführung eines genetischen Enhancements betrifft aber unmittelbar nicht das Leben der Mutter, sondern das des Kindes.

Schließlich ist die Durchführung eines genetischen Enhancements an ihrem (noch zu zeugenden) Kind auch, wie bereits angeklungen, mitnichten eine Darstellung der Mutter nach außen in der Weise, als dass es für ihre eigene Persönlichkeit konstituierend oder wesensbestimmend wäre. Auch dieser Aspekt mag eine Betroffenheit der Menschenwürde der Frau aus Art. 1 I GG durch ein gesetzliches Verbot mithin nicht begründen.

## IX. Fazit

Wie gezeigt, wären von einem Verbot des genetischen Enhancements die grundgesetzlich verbrieften Rechtspositionen des Rechts auf reproduktive Autonomie aus Art. 6 I GG beziehungsweise Art. 2 I GG (in Verbindung mit Art. 1 I GG), der Berufsfreiheit des Arztes gemäß Art. 12 I GG, möglicherweise der Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit des Art. 5 III GG sowie im Hinblick auf ein Enhancement ausdifferenzierter Körperzellen des Elternrechts im Sinne des Art. 6 II 1 GG und hinsichtlich eines Enhancement somatischer Zellen von einwilligungsfähigen Personen auch Art. 2 II 1 GG betroffen. In einem liberalen Rechtsstaat wie der Bundesrepublik Deutschland wäre ein solches Verbot verfassungsrechtlich nur zulässig, wenn die soeben festgestellten Eingriffe im Medium des Rechts gerechtfertigt werden könnten. Ob dies möglich ist soll nun im Folgenden Erörterung finden, ebenso wie die Frage des Umfangs sowie des Designs und der Ausgestaltung konkreter Regelungsgehalte, sollte sich ein Verbot als grundsätzlich möglich erweisen.

---

<sup>399</sup> Bezugnehmend auf die Präimplantationsdiagnostik *Hufen*, Individuelle Rechte und die Zulassung der PID, S. 139.

<sup>400</sup> Maunz/Dürig-Herdegen, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 84.



## Kapitel 8: Rechtfertigung eines gesetzlichen Verbotes des genetischen Enhancements

Das Embryonenschutzgesetz dient, wie bereits erwähnt, den gesetzgeberischen Motiven zufolge nicht dazu, einer positiven Eugenik vorzubeugen und die Züchtung „besserer“ Menschen zu vermeiden. Leben und Gesundheit sowie Menschenwürde von Patienten und dessen Nachkommen sollten vielmehr vor dem Hintergrund der noch keinesfalls ausgereiften Techniken und daher der Unbeherrschbarkeit der noch erforderlichen Experimente geschützt werden. Vor allem aber wollte sich der Gesetzgeber mit den erlassenen Regelungen keinesfalls in dem philosophischen Disput über die ethische Zulässigkeit von Eingriffen in das menschliche Erbgut aus fundamental-kategorischen Gründen positionieren.<sup>401</sup> Entsprechend ist eine weitergehende Diskussion ergebnisoffen möglich und auch wünschenswert. In diesem Rahmen, der im Ergebnis zu einer expliziten und nicht bloß akzidentiellen Regelung des genetischen Enhancements führen sollte, wird jedoch nicht ausschließlich dem verfassungsrechtlichen Anforderungszusammenhang Rechnung getragen werden müssen. Vielmehr sind auch philosophisch-ethische und soziologische Aspekte zu berücksichtigen. Aus dieser Gemengelage ergibt sich für vorliegende Arbeit folgendes Rangverhältnis der verschiedenen Kriterien, welches den weiteren Ausführungen zugrundeliegen wird:

Bei den Argumenten erster Ordnung handelt es sich um normative und kategorische. Sie beziehen sich auf die Frage, ob genetisches Enhancement kategorial rechtswidrig oder gegebenenfalls an sich schlecht ist. Im Falle des Eingreifens eines dieser Argumente erster Ordnung wäre das genetische Enhancement unzulässig, ohne dass es für diese Beurteilung noch auf weitere Erwägungen, etwa rechtfertigende Güterabwägungen oder die Argumente zweiter Ordnung, ankäme. Unter den Argumenten erster Ordnung sind beispielsweise die Fragen der Menschenwürde des Embryos zu verstehen, aber auch weitere Ansätze, die ein absolutes Verbot genetischen Enhancements zu errichten suchen, wie etwa die Konzeption einer Gattungswürde oder explizit religiöse Begründungen, soweit sich diese in rechtlicher Form darstellen ließen.

---

<sup>401</sup> Günther, Lexikon der Bioethik, Band 2, Eintrag „Keimbahnintervention“, S. 351.



Argumente zweiter Ordnung sind hingegen nicht kategorisch, sondern folgenorientiert und empirisch. Sollte sich das genetische Enhancement als nicht kategorial verwerflich und daher grundsätzlich zulässig herausstellen, so wird hier danach gefragt, ob sein Verbot unter Berücksichtigung weiterer Faktoren wie etwa gesellschaftlicher Folgeabschätzungen dennoch empfehlenswert wäre.

## I. Argumente erster Ordnung

Da also die Argumente erster Ordnung gegenüber denen zweiter Ordnung höherrangig sind und es zunächst einmal diese zu überwinden gilt, sollen im Folgenden zunächst diese genauer analysiert werden.

### 1. Menschenwürde i. S. d. Art. 1 I 1 GG

Zuvorderst, da häufig als „Höchstwert“<sup>402</sup>, „höchsten Rechtswert“<sup>403</sup>, obersten Verfassungswert oder „obersten Wert im System der Grundrechte“<sup>404</sup> bezeichnet und als „Wurzel aller Grundrechte“<sup>405</sup> sowie „oberstes“<sup>406</sup> oder „tragendes Konstitutionsprinzip“<sup>407</sup> der Verfassung anerkannt, deren „Mittelpunkt [sich in der] frei entfaltenden menschlichen Persönlichkeit und ihrer Würde findet“<sup>408</sup>, könnten Praktiken des genetischen Enhancements den Menschenwürdesatz des Art. 1 I 1 GG berühren. Eine exponierte Stellung kommt diesem Verfassungssatz schon wegen seiner Unverletzlichkeit, seiner Abwägungsresistenz zu: Als „oberste[r] Zweck allen Rechts“<sup>409</sup> ist die Möglichkeit eines Güterausgleichs nicht existent.

In diesem Zusammenhang wird jedoch nicht nur zu erörtern sein, ob ein Eingriff und somit eine Verletzung vorliegt. Vielmehr stellt sich bereits die Frage, ob in den unterschiedlichen Entwicklungsstadien, in denen das genetische Enhancement ansetzen kann, überhaupt ein Träger der Menschenwürde zu identifizieren ist.

<sup>402</sup> Maunz/Dürig-Herdeggen, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 4; ähnlich BVerfGE 75, 369 (380).

<sup>403</sup> BVerfGE 6, 32 (41); 27, 1 (6); 30, 173 (193); 45, 187 (227); 96, 375 (399).

<sup>404</sup> BVerfGE 33, 25 (29); 32, 98 (108); vergleiche auch BVerfGE 30, 173 (193).

<sup>405</sup> BVerfGE 93, 266 (293); BVerfGE 36, 174 (188): „Als Träger der aus der Menschenwürde folgenden und ihren Schutz gewährleistenden Grundrechte (...)“.

<sup>406</sup> BVerfGE 79, 256 (268); 95, 220 (241).

<sup>407</sup> BVerfGE 96, 375 (399), 72, 105 (115); 79, 209 (228); 96, 375 (398); auch BVerfGE 45, 187 (227);

<sup>408</sup> BVerfGE 7, 198 (205).

<sup>409</sup> BVerfGE 12, 45 (51); 37, 57 (65).

### a) Schutzgehalt des Menschenwürdesatzes

Der unbestimmte, offene Art. 1 I 1 GG stellt den Rechtsanwender insbesondere wegen seines ethisch-philosophischen Gehalts vor Probleme. Dies gilt selbst dann, wenn es, wie nun zunächst erst einmal, nur um ein klassisches, aller rechtlichen Erkenntnis zufolge gesichertes und somit auf breiten Konsens stößendes Verständnis des Menschenwürdesatzes des Art. 1 I 1 GG gehen soll. Weitaus problematischere und umstrittenere Ausweitungen dieser verfassungsrechtlichen Garantie sollen an dieser Stelle noch nicht erörtert werden. Vielmehr soll es um eine verfassungsrechtliche Bewertung des genetischen Enhancements anhand der traditionellen, in der praktischen Rechtsanwendung, insbesondere der Rechtsprechung, inhaltlich anhand einer umfassenden Kasuistik weitgehend deutlich umrissenen und mittlerweile gefestigten Vorstellungen des Menschenwürdegehaltes gehen.

#### aa) Ideengeschichte

Als positivierte Verfassungsnorm beansprucht Art. 1 I GG unabhängig von Glauben, Ethik oder Philosophie Geltung in einer weltanschaulich neutralen Rechtsordnung. Dennoch ist im Hinblick auf Verständnis und Interpretation dieses unbestimmten Begriffes eine zumindest kurze Betrachtung der Ideengeschichte erforderlich.<sup>410</sup> Wenn an dieser Stelle auch kein vertiefter Einblick vermittelt werden soll, so ist der Satz der Menschenwürde doch mit zweieinhalbtausend Jahren Philosophiegeschichte belastet. Nur allzu häufig versuchen daher auch partikuläre Philosophien oder Glaubensüberzeugungen, diesen für die eigenen normativen Zwecke und Regulationsbestrebungen nutzbar zu machen.<sup>411</sup>

Sowohl in der griechischen Antike als auch im Römischen Reich bezeichnete Würde stets Ruhm, Verdienst, persönliche Ehre und Ansehen. So beschrieb das lateinische Wort *dignitas* einen Status, der nach Amt, Rang und persönlicher Bedeutung abgestuft war, und bezog sich so auf die Geltung einer Person im öffentlichen Leben.<sup>412</sup> Eine entsprechende Bedeutung hat der Würdebegriff auch im Alten Testament.<sup>413</sup>

Ein universalistisches Verständnis von Würde entwickelte sich erst in der Philosophie der mittleren Stoa.<sup>414</sup> So spricht *Cicero* von der „*menschlichen Würde*“ im

<sup>410</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 1.

<sup>411</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 2; Pieroth/Schlink, Grundrechte, § 7 II Rdnr. 368; Riedel, EuGRZ 1986, 469 (473).

<sup>412</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 3; Wetz, ARSP 87 (2001), 311 (312 f.).

<sup>413</sup> Krüger, „Wie der Wind verfliegt meine Würde...“, S. 273, 275 spricht davon, dass Würde Rechte und Ansprüche gegenüber Dritten begründet und aus dem Respekt besteht, der ihrem Träger aufgrund seiner Macht entgegengebracht wird.

<sup>414</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 4; Maunz/Dürig-Herdeggen, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 8.

Allgemeinen, die allen Menschen zustehe.<sup>415</sup> Cicero begreift Würde jedoch nicht als Recht oder Anspruch. Vielmehr stelle sie eine Verpflichtung dar.<sup>416</sup>

In der Spätantike und im Mittelalter dominierten die christlichen Naturrechtslehren, insbesondere die thomistischer Tradition, über den Menschen als Kreatur Gottes, die, gestützt auf Gen. 1, 26 ff. und Petr. 1, 15 f. sowie Eph. 4, 24, die Vorstellung von einer besonderen Auszeichnung des Menschen im Vergleich zur sonstigen Schöpfung verbreiteten.<sup>417</sup> Dadurch, dass der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen sei, komme ihm ein unverfügbarer, unverlierbarer Eigenwert zu,<sup>418</sup> der ihn von allen anderen Geschöpfen abhebe, aus dem aber auch eine Pflichtgebundenheit sowohl gegenüber dem Schöpfer als auch gegenüber der von ihm geschaffenen Ordnung resultiere. Der Mensch nimmt in dieser *imago Dei*-Lehre<sup>419</sup> aufgrund seines Geistes, Verstandes und freien Willens eine Sonderstellung unter Gottes Geschöpfen ein. Auch nach diesen Lehren war aber eine politische und soziale Stufung der Menschen weiterhin möglich, was jedoch dem egalitären Charakter der Menschenwürde, wie wir sie – darüber besteht Einigkeit – heute verstehen, widerspricht.<sup>420</sup>

Häufig wird dennoch angenommen, dass diese christliche Lehre die Grundlage der verfassungsrechtlichen Menschenwürdegarantie ist, die so eine von Aufklärung und Humanismus getragene, säkularisierte Form der *imago Dei*-Lehre darstellt.<sup>421</sup> Dem stehen allerdings Bedenken entgegen.<sup>422</sup> Diese Annahme würde eine nicht-christliche oder gar nichtreligiöse Begründung der Menschenwürde ausschließen.<sup>423</sup> Auch die Opposition der katholischen Kirche gegen die Grundsätze von Freiheit und Gleichheit, die liberal-egalitäre Gesellschaftsordnung und die Menschenrechtserklärung der Französischen Revolution, die bis in das 20. Jahrhundert anhielt, spricht gegen diese Auffassung.<sup>424</sup> Des Weiteren war von der Menschenwürde im universellen Sinne in den christlichen Lehrentscheidungen erst unter Johannes XXIII. die Rede. Zuvor bezog sie sich ausschließlich auf den Erlösten oder den Christen.<sup>425</sup> Die gleiche Würde aller Menschen stellt sich somit nicht als Säkularisat

<sup>415</sup> Cicero, De officiis, III 27 (*quicumque sit, ob eam ipsam causam, quod is homo sit*: wer er auch immer sei, nur aus dem Grunde, weil er ein Mensch ist).

<sup>416</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 4.

<sup>417</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 4; von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 5; Merki, Reallexikon für Antike und Christentum, Eintrag „Ebenbildlichkeit“, Sp. 459 ff. (464 ff.).

<sup>418</sup> von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 5.

<sup>419</sup> Pannenberg, Christliche Wurzeln des Gedankens der Menschenwürde, S. 64 ff.; Koch, Imago Dei, S. 5 ff.; Koch, Perspektiven biblischen Menschenverständnisses im Zeitalter der Technologie, S. 52 ff.

<sup>420</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 5.

<sup>421</sup> So z. B. in Auseinandersetzung mit dem Dürig'schen Würdebegriff Graf Vitzthum, JZ 1985, 201 (206).

<sup>422</sup> Hilgendorf, NJW 1997, 3074; kritisch auch Fechner, JZ 1986, 653 (653 f.).

<sup>423</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 7.

<sup>424</sup> Hofmann, JuS 1988, 841 (842 f.).

<sup>425</sup> Cancik, „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, S. 76 ff.; v. Nell-Breuning, Gerechtigkeit und Freiheit, S. 101.

christlicher Glaubenssätze dar. Vielmehr erwächst sie antiker, humanistischer und aufklärerischer Traditionen.<sup>426</sup>

Auch die Renaissance hatte bedeutenden Einfluss auf das moderne Verständnis von Menschenwürde. Hier entwickelte sich das Bild des sündhaften und gefallenen, durch Gottes Gnade geretteten Menschen hin zur Auffassung des Menschen als dynamisches, Welt, Natur und Gesellschaft gestaltendes Individuum, dessen Würde in seiner Vernunft gründete.<sup>427</sup> Auch *Giovanni Pico della Mirandola*<sup>428</sup> sprach von der Einzigartigkeit und schöpferischen Potenz des Menschen und beschrieb ihn als einen Mikrokosmos aller Seinsmöglichkeiten, die zu realisieren der Mensch frei und fähig sei. Seine Würde liege in seinem Vermögen zur freien Selbstfindung und Identitätsbildung.<sup>429</sup> Auch *Blaise Pascal* betont, dass die Würde des Menschen auf seiner Fähigkeit zu denken gründet.<sup>430</sup> Die Fähigkeit zu vernunftgemäßem Handeln und die Fähigkeit freier Selbstbestimmung stellen auch in der Philosophie der Neuzeit, insbesondere bei den Vertretern des Vernunftnaturrechts, den Grund für die Würde des Menschen dar.<sup>431</sup>

Schließlich findet sich auch in der Philosophie *Immanuel Kants* eine entsprechende Begründung der Menschenwürde, die primäres Fundament des Würdekonzepts der deutschen Verfassungsordnung werden sollte.<sup>432</sup> *Kant* sieht in der Autonomie, also der dem Menschen eigenen und innewohnenden Fähigkeit zu eigenverantwortlichen ethischen Entscheidungen, den Grund für die Würde des Menschen. Er umschreibt den Menschenwürdesatz begrifflich als Behandlung des Menschen niemals bloß als Mittel, sondern stets als Zweck an sich selbst und als absoluten inneren Wert des Menschen als Person.<sup>433</sup> Besonderes Augenmerk ist hier jedoch auf seinen Zusammenhang zwischen Personalität und Würde zu richten, welche bei *Kant* als Konzept des Respekts für Personen zu begreifen ist, wobei hiervon mitnichten sämtliche der Gattung *homo sapiens* angehörige Wesen erfasst sind. Der restriktive Charakter des kantischen Begriffs vom Menschen oder der Menschheit ergibt sich aus dem Versuch, ohne Rückgriff auf anthropologische Annahmen aus dem Begriff der reinen praktischen Vernunft die Grundlagen der Moralphilosophie zu gewinnen, deren moralisches Prinzip für alle vernünftigen Wesen Geltung beanspruchen und nur deswegen und nur insoweit auch für den menschlichen Willen Gesetz sein müsse.<sup>434</sup> „Die Klasse der (handlungsfähigen) vernünftigen Menschen ist deshalb nicht

<sup>426</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 8.

<sup>427</sup> Punt, Die Idee der Menschenrechte, S. 48 ff.; Cancik, „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, S. 78 ff.); Enders, Die Menschenwürde in der Verfassungsordnung, S. 180 ff., 184 ff.

<sup>428</sup> Zu *Pico* umfassend Reinhardt, Freiheit zu Gott.

<sup>429</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 9.

<sup>430</sup> *Pascal*, Pensées, Nr. 146.

<sup>431</sup> Enders, Die Menschenwürde in der Verfassungsordnung, S. 186 ff.; Maunz/Dürig-Herdeggen, GG, Art. 1 I Rdnr. 10.

<sup>432</sup> Gutmann, Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik 15, S. 26.

<sup>433</sup> *Kant*, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, S. 427 ff.

<sup>434</sup> Vergleiche *Kant*, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, S. 425; Gutmann, Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik 15, S. 7 f.

mit der biologischen Spezies Mensch identisch.“<sup>435</sup> Zweck an sich ist demnach nicht die Natur, sondern nur die vernünftige Natur des Menschen; nur vernünftige Wesen sind Personen,<sup>436</sup> deren Handlungen ihnen aufgrund ihrer aktuell vorhandenen Fähigkeit zu an moralischen Grundsätzen orientierter Selbstbestimmung zurechenbar sind.<sup>437</sup> Diese Bestimmung des eigenen Willens anhand moralischer Gesetze, die Moralität, erst ist „die Bedingung, unter der allein ein vernünftiges Wesen Zweck an sich selbst sein kann“<sup>438</sup> und stellt nach Kant den „eigentliche[n] Gegenstand der Achtung“<sup>439</sup> dar. Entsprechend stellt Thomas Gutmann fest, dass „die moralische Dignität [...] in der Fähigkeit zu praktischer Selbstbestimmung nach vernünftigen Normen [liegt]“,<sup>440</sup> dass Kant also gerade nicht mit einer aristotelischen Metaphysik menschlicher Substanz arbeite, an der Mitglieder der menschlichen Spezies auch dann teilhätten, wenn sie ihnen akzidentiell fehle. Eine „allgemeine Menschenwürde“, die schon bei einer bloßen, nicht realisierten Anlage zur Selbstbestimmung einen Anspruch auf Achtung begründe, existiere nicht.<sup>441</sup> Ein Wesen ist nur dann und nur so lange frei und damit vernünftig, wie es seine Handlungen an Maximen des eigenen Willens ausrichtet. Die Orientierung an heteronomen Gesetzen, also an äußeren Umständen, andererseits steht dem entgegen.<sup>442</sup> Während also lediglich zu vernünftiger moralischer Selbstbestimmung fähige Menschen auch Personen sind und exklusiv ihnen Würde zugesprochen wird, verfährt Kants Ethik innerhalb dieses begrenzten Kreises moralischer Subjekte jedoch egalitär: Es gibt „keine meritorischen Abstufungen, es gibt keine Aristokraten der Würde.“<sup>443</sup>

Der Übernahme der kantischen Philosophie für die Interpretation des Art. 1 I 1 GG stehen jedoch nicht zuletzt aufgrund der dargelegten Umstände Bedenken entgegen.<sup>444</sup> Zuvorderst führen, wie soeben beschrieben, die kantischen Qualifikationsbedingungen bei konsequenter Anwendung zu einem Ausschluss von beispielsweise Kleinkindern, Menschen mit schweren geistigen Behinderungen, komatösen oder dementen Menschen von jeglichem Anspruch auf Achtung.<sup>445</sup> Im Hinblick auf Embryonen oder Kleinkinder ließe sich zwar noch vorbringen, dass eine Zuschreibung der Menschenwürde hier als präventiver Schutz einer zukünftigen Vernunftfähigkeit und Selbstbestimmung dieser zukünftigen Menschen fungieren könnte. Auch dieses Konstrukt jedoch würde etwa bei menschlichen Lebewesen an seine Grenzen stoßen, die aufgrund einer besonders gravierenden geistigen Be-

<sup>435</sup> Gutmann, Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik 15, S. 8.

<sup>436</sup> Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, S. 428.

<sup>437</sup> Kant, Metaphysik der Sitten, S. 223.

<sup>438</sup> Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, S. 435.

<sup>439</sup> Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, S. 440.

<sup>440</sup> Gutmann, Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik 15, S. 8.

<sup>441</sup> Gutmann, Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik 15, S. 10.

<sup>442</sup> Zünke, Das Subjekt der Würde, S. 74.

<sup>443</sup> Gutmann, Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik 15, S. 13.

<sup>444</sup> Bedenken äußert z. B. Fechner, JZ 1986, 653 (654 f.).

<sup>445</sup> Eine vertiefte Analyse dieser Konsequenz und etwaiger Auswege findet sich in Gutmann, Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik 15, S. 5-34; Hörnle, ARSP 89 (2003), 318 (323); Lenk, Therapie und Enhancement, S. 94 f.

hinderung diese Fähigkeit niemals erlangen werden oder die diese Fähigkeit aufgrund von fortgeschrittener Demenz oder anderweitiger irreversibler Erkrankungen nicht wiedererlangen werden. Hier ließe sich die Frage stellen, welchen Gehalt in derlei Fällen dann eine Menschenwürdenorm habe, deren Kern und deren Schutzgut den etwaigen Trägern schlechterdings nie zukommen können.<sup>446</sup> Dieses „*Exklusionspotential der Kantischen Ethik*“ ist jedoch „für das Recht dysfunktional“ und markiert trotz ihrer immensen Bedeutung für das deutsche Verfassungsrecht eine Grenze dessen Rekonstruktion mit den Mitteln der kantischen Moralphilosophie.<sup>447</sup> Der Rechtsbegriff der Würde muss vielmehr zumindest hinsichtlich geborener Menschen inklusiv ausgestaltet sein, statuiert doch das Bundesverfassungsgericht, dass jeder Menschwürde besitze und zwar „ohne Rücksicht auf seine Eigenschaften, seine Leistungen und seinen sozialen Status. Sie ist auch dem eigen, der aufgrund seines körperlichen oder geistigen Zustands nicht sinnhaft handeln kann.“<sup>448</sup>

Darüber hinaus stellt der Umstand, dass Kants Ausführungen zur Menschenwürde in der Moralphilosophie und nicht in der Rechtsphilosophie zu finden sind, eine unmittelbare Übertragung auf die staatliche Rechtsorganisation in Frage. Kant selbst hob den Unterschied zwischen Tugendpflichten und Rechtspflichten, zwischen Moralität und Legalität hervor.<sup>449</sup> In moralischer Hinsicht sei der Mensch sich selbst gegenüber zu bestimmten Handlungen und Unterlassungen verpflichtet und könne nicht beliebig über sich verfügen; Rechtspflichten begründeten diese rein moralischen Pflichten jedoch nicht.<sup>450</sup>

Die beschriebene Betonung selbstbezoglicher Pflichten des Individuums und die diskutierte Grundkonstellation der Menschenwürde als Abgrenzung zwischen Natur und Geist änderte sich grundlegend nach den Erfahrungen mit den totalitären Ordnungen des 20. Jahrhunderts. Die Konzeption der Menschenwürde wandelte sich vor dem Hintergrund dieser historischen Erfahrungen hin zu einer individualistisch-konkreten und wurde zunehmend als geradezu „*substanzontologisch-axiologisches Attribut des einzelnen Menschen*“ betrachtet.<sup>451</sup> Diente die Menschenwürde bislang dazu, den vernunftbegabten, durch Geistigkeit und Fähigkeit zur sittlichen Autonomie charakterisierten Menschen von Natur- und Triebwesen abzugrenzen und seine Höherrangigkeit gegenüber dieser außermenschlichen Natur festzustellen, wird die Menschenwürde unter dem Eindruck der rechtshistorisch vergleichsweise jüngeren Erfahrungen nach 1945 als Schutz gegen die Staatsgewalt<sup>452</sup> und Sicherung von Selbstbestimmung und Selbstentfaltung aufgefasst.<sup>453</sup> Unter dem

<sup>446</sup> Zusammenfassend Werner, Menschenwürde in der bioethischen Debatte, S. 210.

<sup>447</sup> Gutmann, Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik 15, S. 26.

<sup>448</sup> BVerfGE 87, 209 (228).

<sup>449</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 13.

<sup>450</sup> Gutmann, „Gattungsethik“ als Grenze der Verfügung des Menschen über sich selbst?, S. 245 f.

<sup>451</sup> Hofmann, JZ 1986, 243 (259).

<sup>452</sup> Gleichwohl waren die Väter und Mütter des Grundgesetzes sich des auch zukunftsgerichteten Gehalts der Norm bewusst und erkannten, dass der Menschenwürdesatz auch zwischen Privaten gelten müsse: Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 16, 22 f.

<sup>453</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 16, 22 f.; Gutmann, „Gattungsethik“ als Grenze der Verfügung des Menschen über sich selbst?, S. 246.

Einfluss einer freiheitlichen Verfassung wie des Grundgesetzes lässt sich fortan der Rechtsstatus eines Individuums nicht mittels Rechtspflichten definieren, sondern macht vielmehr die Individualisierbarkeit und konkrete Zuordnung des Menschenwürdesatzes zu konkreten Subjekten erforderlich.<sup>454</sup>

## bb) Verfassungsrechtlicher Begriff und Inhalt der Menschenwürde

Obschon die religiöse und philosophische Ideengeschichte der Menschenwürde für deren Interpretation von Bedeutung ist, hat sich die Auslegung des Art. 1 I 1 GG an den Kunstregeln juristischer Methodik zu orientieren. Was unter dem Begriff der Menschenwürde zu verstehen ist und wie dieser definiert werden kann, ist zunächst jedoch unklar.

### (1) Nichtdefinition, Negativdefinition

Zum Teil wird vertreten, dass die Menschenwürde sich nicht definieren lasse, keiner näheren Bestimmung bedürfe oder einer allgemeingültigen, abstrakten Erfassung unzugänglich sei. So traf *Theodor Heuss* die Aussage, bei der Menschenwürde handle es sich um eine „*nicht interpretierte These*“<sup>455</sup>. Dies ermöglicht es, die Menschenwürde in fallweiser Konkretisierung, grundrechtsdogmatisch gesprochen nicht vom Schutzbereich, sondern vom Eingriff her argumentiert,<sup>456</sup> zu erschließen. Einer solchen Negativdefinition hat sich auch das Bundesverfassungsgericht des Öfteren bedient.<sup>457</sup>

Dieses Vorgehen hat den Vorteil der größeren Flexibilität gegenüber definitio- nistischen Festlegungen und somit der besseren Möglichkeit, neue Bedrohungen zu erfassen. Nachteil einer solchen Nicht- oder Negativdefinition ist jedoch, dass sie im konkreten Fall nicht die erforderliche Evidenz und den nötigen Konsens zu be- gründen vermag. In einschlägigen Fällen, wie etwa denen der Folter, stellen sich sowohl Nicht- als auch Negativdefinition als problemlos dar. Beide betonen hier die Basisfunktion der Menschenwürde und deren Unabhängigkeit von weltanschau- lichen oder politischen Positionen. In neueren, subtileren Fällen vermögen diese Definitionen jedoch keinen Erfolg zu versprechen.<sup>458</sup>

### (2) Objektformel

Häufig wird vertreten, dass ein Eingriff in die Menschenwürde mit der so genannten Objektformel festzustellen ist, die *Günter Dürig* entscheidend geprägt hat<sup>459</sup> und

<sup>454</sup> *Gutmann*, „Gattungsethik“ als Grenze der Verfügung des Menschen über sich selbst?, S. 246.

<sup>455</sup> von Doemming/Füsslein/Matz, JöR 1 (1951), S. 49.

<sup>456</sup> *Pieroth/Schlink*, Grundrechte, § 7 II Rdnr. 373.

<sup>457</sup> BVerfGE 30, 1 (25); 72, 105 (115 ff.).

<sup>458</sup> *Dreier-Dreier*, GG, Art. 1 I Rdnr. 52.

<sup>459</sup> *Dürig*, AöR 81 (1956), 117 ff.



die an *Kants* Instrumentalisierungsverbot<sup>460</sup> angelehnt ist.<sup>461</sup> Danach liegt eine Verletzung des Art. 1 I GG dann vor, wenn der konkrete Mensch zum Objekt, einem bloßen Mittel oder zur vertretbaren Größe herabgewürdigt wird, er zum bloßen Objekt des Staates gemacht beziehungsweise seine Subjektqualität prinzipiell in Frage gestellt wird.<sup>462</sup> Auch das Bundesverfassungsgericht hat sich häufig dieser Formel bedient,<sup>463</sup> die sich gewissermaßen als „*Konzentrat*“ der langjährigen *Rechtsprechung*<sup>464</sup> herauskristallisiert hat.

Die Objektformel ist aber lediglich zur Identifizierung von evidenten Menschenwürdeverletzungen geeignet. Sie erweist sich sonst häufig als zu vage und unbestimmt, wenig fassbar, gegebenenfalls sogar als Leerformel, Rückfall in eine naive Begriffsjurisprudenz oder leere Hülse, für eine floskelhafte Handhabung anfällig und droht, zu dezisionistischer Handhabung zu verführen,<sup>465</sup> soweit sie nicht durch eine ausgeprägte Kasuistik anwendbar gemacht wird. Bei wörtlichem Verständnis versagt sie zur Bestimmung von Verletzungen der Menschenwürde, denn jeder Mensch wird unvermeidlich als Mittel und nicht als Zweck von anderen Menschen und auch dem Staat behandelt.<sup>466</sup> Gegen die Anwendung ausschließlich der Objekt-

<sup>460</sup> Kant, *Metaphysik der Sitten*, S. 462: „Die Menschheit selbst ist eine Würde; denn der Mensch kann von keinem Menschen (weder von Anderen noch sogar von sich selbst) bloß als Mittel, sondern muß jederzeit zugleich als Zweck gebraucht werden, und darin besteht eben seine Würde [...]“. Und Kant, *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, S. 433: „Denn vernünftige Wesen stehen alle unter dem Gesetz, daß jedes derselben sich selbst und alle anderen niemals bloß als Mittel, sondern jederzeit zugleich als Zweck an sich selbst behandeln solle“.

<sup>461</sup> Gutmann, *Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik* 15, S. 26: „Dass sich dieser rechtliche Zusammenhang [zwischen dem Würdegrundsatz und der Achtung vor Menschen als Rechtspersonen], will man ihn philosophisch analysieren, im wesentlichen nur mit Mitteln der Kantischen Tradition explizieren lässt, bedarf keiner weiteren Erläuterung.“

<sup>462</sup> Dürig, AöR 81 (1956), 117 (127); Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 53; Epping/Hillgruber-Hillgruber, GG, Art. 1 Rdnr. 13; Jarass/Pieroth, GG, Art. 1 Rdnr. 7; Maunz/Dürig-Herdeggen, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 36; von Münch/Kunig-Kunig, GG, Art. 1 Rdnr. 22; Sachs-Höfling, GG, Art. 1 Rdnr. 15 f.; Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfau-Hofmann, GG, Art. 1 Rdnr. 7; Laufs, NJW 2000, 2716 (2717).

<sup>463</sup> BVerfGE 9, 89 (95); 27, 1 (6); 28, 386 (391); 45, 187 (228); 50, 166 (175); 50, 205 (215); 57, 250 (275); 87, 209 (228); auch BVerwGE 1, 159 (161).

<sup>464</sup> Isensee/Kirchhof-Häberle, HStR II, § 22 Rdnr. 8.

<sup>465</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 53; Maunz/Dürig-Herdeggen, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 36.; von Münch/Kunig-Kunig, GG, Art. 1 Rdnr. 23; Sachs-Höfling, GG, Art. 1 Rdnr. 15; Pieroth/Schlink, *Grundrechte*, § 7 III Rdnr. 376 f.; Herdeggen, JZ 2001, 773 (775); Hilgendorf, NJW 1996, 758 (759 f.); Hillgruber, JZ 1997, 975; Hoerster, JuS 1983, 93 (95); Hilgendorf, *Jahrbuch für Recht und Ethik* 7 (1999), 137 (146 f.); Nettesheim, AöR 130 (2005), 71 (79 ff.); auf die Gefahr der plakativen und leerformelhaften Argumentation mit Art. 1 I GG hinweisend Isensee/Kirchhof-Häberle, HStR I, § 20 Rdnr. 10.

<sup>466</sup> BVerfGE 30, 1 (25 f.): „Der Mensch ist nicht selten bloßes Objekt nicht nur der Verhältnisse und der gesellschaftlichen Entwicklung, sondern auch des Rechts, insofern er ohne Rücksicht auf seine Interessen sich fügen muß.“; BVerfGE 109, 279 (312); Badura, JZ 1964, 337 (342); Hofmann, AöR 118 (1993), 353 (360).



formel spricht zudem, dass sich ihre scheinbar weltanschaulich indifferente Fassung als Passepartout für jegliche subjektive Wertungen entpuppt.<sup>467</sup>

Nichtsdestoweniger gilt die Objektformel heute als der überzeugendste Ansatz, wenn es darum geht, die Vorschrift des Art. 1 I GG handhabbar zu machen: Sie fungiert als Merkposten für Gehalte und Spezifizierungen, auf die sie richtungsweisend hindeutet und die sie assoziieren lässt.<sup>468</sup> Von seiner ideengeschichtlichen und philosophischen Herleitung hat sich dieser Ansatz in zahlreichen Entscheidungen und durch seine damit einhergehende ausdifferenzierte, fallweise Entfaltung, Konkretisierung und Aktualisierung mittlerweile emanzipiert.<sup>469</sup>

### (3) Wert- oder Mitgifttheorien

Die Wert- oder Mitgifttheorien begreifen die Würde als eine menschliche Eigenschaft und eine den Menschen auszeichnende Qualität. In der christlichen Variante wird unter Berücksichtigung der *imago Dei*-Lehre auf die besondere Auszeichnung des Menschen im Rahmen der göttlichen Schöpfung und der Gottesebenbildlichkeit des Menschen verwiesen. In der naturrechtlich-idealistischen Variante wird die Würde des Menschen mit dessen Vernunft und seiner Fähigkeit zur freien Selbstbestimmung und sittlicher Autonomie begründet.<sup>470</sup>

Beide Formen der Wert- oder Mitgifttheorien erkennen die Menschenwürde ohne Rücksicht auf etwaige Abweichungen an und sprechen sie jedem Menschen zu. Allerdings kommen auch sie nicht ohne Theologie und Metaphysik aus.<sup>471</sup> Ob und gegebenenfalls inwiefern dieser Umstand zu Kritik veranlassen muss, soll an dieser Stelle zwar noch nicht beleuchtet werden. Vielmehr soll es hier zuvorderst auf eine klassische, gesicherte Auslegung des Art. 1 I 1 GG gehen, anhand derer die Verfahren des genetischen Enhancements nur unter Zuhilfenahme des juristischen Handwerkszeugs analysiert werden sollen, ohne dass es eines Rückgriffes auf anderweitige als die klar juristischen Kriterien und Bewertungsmaßstäbe bedarf.

### (4) Leistungstheorien

Den Leistungstheorien, etwa von Niklas Luhmann oder Eberhard Grabitz, zufolge handelt es sich bei Menschenwürde nicht um etwas, das dem Einzelnen seit jeher zusteht, sondern um etwas, das erst erlangt werden muss.<sup>472</sup> Würde sei in einem gelingenden Prozess der Identitätsbildung und Selbstdarstellung zu verdienen.<sup>473</sup>

Gegen die Anwendung dieser Theorie spricht jedoch, dass sie die Würde denjenigen Menschen abspricht, die zur Erbringung der geforderten Leistung nicht oder

<sup>467</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 53.

<sup>468</sup> von Münch/Kunig-Kunig, GG, Art. 1 Rdnr. 23.

<sup>469</sup> Isensee/Kirchhof-Häberle, HStR II, § 22 Rdnr. 43.

<sup>470</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 55.

<sup>471</sup> Hofmann, AöR 118 (1993), 353 (361); Stöcker, JZ 1968, 685 (685 f.).

<sup>472</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 56.

<sup>473</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 56.

nicht mehr in der Lage sind,<sup>474</sup> somit für heute konsensual anerkannte Bedürfnisse nicht inklusiv genug ist und in Widerspruch zu den Verfassungs- und Menschenrechtstexten steht, die Würde grundsätzlich als angeboren erkennen. Ohne Notwendigkeit begründet sie somit Gefahren für einen umfassenden rechtlichen Menschenwürdeschutz.<sup>475</sup>

### (5) Kommunikationstheorie

Die Kommunikationstheorie stellt auf die strukturelle Seite der Menschenwürde ab.<sup>476</sup> Ihr zufolge handelt es sich bei Menschenwürde um einen Relations- und Kommunikationsbegriff. Während *Habermas* das zugrundeliegende Anerkennungs- und Interaktionsverhältnis mit der Geburt begründet sieht, verweist *Spaemann* (der im Übrigen diesem Ansatz jedoch kritisch gegenübersteht) darauf, dass eine Interaktion schon viel früher stattfindet.<sup>477</sup> Würde erwachse aus sozialer Anerkennung durch positive Bewertung von sozialen Ansprüchen und stehe so im Zusammenhang mit einer konkreten Anerkennungsgemeinschaft. Ihr Schutzgut sei daher die mitmenschliche Solidarität.<sup>478</sup> Insbesondere zur Bestimmung der Träger der Menschenwürde ist diese Theorie geeignet, denn sie umfasst auch geistig und psychisch Schwerstgeschädigte. Gleichwohl kommt im Rahmen dieser Theorie der Teilnehmereigenschaft an der Gesellschaft besondere Bedeutung zu. Diese ist jedoch für die frühesten Stadien menschlichen Lebens, in denen, sofern sie *in utero* stattfinden, noch nicht einmal die Frau davon Kenntnis haben muss oder auch nur kann, höchst problematisch. Es ist schwerlich vorstellbar, dass bereits ein Zellverband von weniger als einem Millimeter Größe, der nur unter dem Mikroskop erkennbar ist und nur von Spezialisten als menschlicher Embryo identifiziert werden kann, sich mit uns in einem Kommunikations- und Anerkennungsverhältnis befindet.<sup>479</sup>

### (6) Allgemein anerkannte Grundaussagen der Menschenwürde

Die diskutierten Theorien stehen keinesfalls in einem Verhältnis strikter Alternativität oder des wechselseitigen Ausschlusses. Vielmehr besteht im Kernbereich des Art. 1 I 1 GG Einigkeit über drei Grundaussagen:<sup>480</sup>

<sup>474</sup> *Hofmann*, AöR 118 (1993), 353 (362); gegen eine solche Schlussfolgerung auch *Umbach/Clemens-Robbers*, GG, Art. 1 Rdnr. 17 f.; implizit diese Theorie ablehnend auch BVerfGE 87, 209 (228): Die Würde des Menschen sei „auch dem eigen, der aufgrund seines körperlichen oder geistigen Zustandes nicht sinnhaft handeln kann.“

<sup>475</sup> *Isensee/Kirchhof-Häberle*, HStR II, § 22 Rdnr. 45.

<sup>476</sup> *Hofmann*, AöR 118 (1993), 353 (366 f.); eine biblisch-theologische Kommunikationstheorie, in der die Gottesebenbildlichkeit als Kommunikationsverhältnis gedeutet wird, vorlegend *Koch*, *Imago Dei*, S. 6 f.

<sup>477</sup> *Spaemann*, DZPhil 50, 105 (108).

<sup>478</sup> *Hofmann*, AöR 118 (1993), 353 (364, 369 f.).

<sup>479</sup> *Dreier*, *Bioethik zwischen gesellschaftlicher Pluralität und staatlicher Neutralität*, S. 16.

<sup>480</sup> *Dreier-Dreier*, GG, Art. 1 I GG, Rdnr. 58 ff.; *Jarass/Pieroth*, GG, Art. 1 Rdnr. 6; *Hofmann*, AöR 118 (1993), 353 (363); *Pieroth/Schlink*, Grundrechte, § 7 II Rdnr. 372; *Birnbacher*, *Menschenwürde und Lebensrecht als Maßstäbe für PGD?*, S. 19 ff.

Art. 1 I 1 GG schützt als egalitäres Prinzip gegen massive Verletzungen des Gleichheitsgedankens und vor der Herabstufung bestimmter Personengruppen zu Menschen zweiter Klasse. Die Menschenwürde umfasst also das Recht, von Verächtlichmachungen und Demütigungen verschont zu bleiben.

Individualität, Identität, physische, psychische und moralische Integrität des Menschen ist als Ausdruck verfassungsrechtlicher Freiheit zu respektieren und seine Subjektqualität zu wahren. Dies schließt das Recht auf ein Minimum an Handlungs- und Entscheidungsfreiheit ein und verbietet zumindest die eindeutige und krasse Instrumentalisierung zu fremden Zwecken.

Als soziale Komponente wird durch Art. 1 I 1 GG auch ein materielles Existenzminimum garantiert. Der Mensch hat daher ein Recht auf Hilfe in unverschuldeten Notlagen.

## **b) Grundrechtsträgerschaft im Hinblick auf Art. 1 I 1 GG**

Um einen Verstoß gegen Art. 1 I 1 GG durch Techniken des genetischen Enhancements bejahren zu können, müssten die unterschiedlichen Eingriffsobjekte überhaupt Träger der Menschenwürde, also Menschen im Sinne dieser Verfassungsnorm sein. Konkret ist hier zu differenzieren zwischen den Gameten, der Zygote, der geborenen Person, deren somatische Zellen modifiziert werden sollen, und embryonalen Stammzellen.

### **aa) Modifizierung somatischer Zellen**

Unbestritten ist, dass Würde allen natürlichen Personen, also zumindest allen bereits geborenen, vom Menschen abstammenden Lebewesen, zusteht; *„der geborene Mensch ist der ‚Normalfall‘ der Menschenwürdegarantie des Art. 1 Abs. 1 S. 1 GG.“*<sup>481</sup> Schon das natürliche Verständnis des Begriffes „Mensch“ umfasst mindestens Geborene. Unabhängig ist dies, für einen universellen Humanitätsstandard selbstverständlich, auch von der Frage einer Staatszugehörigkeit oder der Legalität des Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland.<sup>482</sup> *„Voraussetzung ist allein die Existenz eines geborenen Menschen mit prinzipieller (nicht aktueller) Fähigkeit zur vernünftigen Selbstbestimmung, wie wir sie jedenfalls jedem lebenden menschlichen Wesen konzederen müssen.“*<sup>483</sup> Entsprechend ist der persönliche Schutzbereich des Art. 1 I 1 GG zumindest dann eröffnet, wenn die Modifizierung von Körperzellen eines bereits geborenen Menschen zu evaluieren ist.

<sup>481</sup> Dederer, AöR 127 (2002), 1 (10); Jarass/Pieroth, GG, Art. 1 Rdnr. 8; Sachs-Höfling, GG, Art. 1 Rdnr. 54; Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf-Hofmann, GG, Art. 1 Rdnr. 10.

<sup>482</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 62.

<sup>483</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 64.

## bb) Keimbahnmodifizierung bei Zygoten

Ungleich problematischer ist jedoch die Eröffnung des persönlichen Schutzbereiches des Art. 1 I GG in Bezug auf frühe und früheste Formen menschlichen Lebens.

*(1) Ideen- und verfassungsgeschichtliche Bedenken*

Gegen die Erstreckung der Menschenwürde auf pränidatives Leben könnte sprechen, dass diese sich ihrer Ideen- und Verfassungsgeschichte nach ausschließlich auf bereits geborene Personen zu beziehen scheint.<sup>484</sup> Ziel der Regelung war es schließlich zuvorderst, die Behandlung von Menschen als Tiere oder Untermenschen durch Folter, Stigmatisierung oder Demütigung zu verbieten,<sup>485</sup> was ungeborenes oder gar pränidatives Leben schon vom Schutzzweck her nicht umfasst. Die historische Auslegung führt dennoch nicht zu einem eindeutigen Ergebnis:

Der Verlauf der Diskussion im Parlamentarischen Rat belegt keineswegs, dass sich die Mitglieder über die Stellung des vorgeburtlichen Lebens generell uneinig waren. Mit Blick auf ein etwaiges Lebensrecht aus Art. 2 II 1 GG, zu dem die Ausführungen aber auch im Rahmen der Grundrechtsträgerschaft aus Art. 1 I GG herangezogen werden können, knüpft doch an die Menschenwürde ein genuin eigenes Lebensrecht an, ohne dass die Schutzbereiche sich in persönlicher oder zeitlicher Hinsicht zwingend identisch sein müssen. Schon im Rahmen der Verhandlungen im Parlamentarischen Rat war unklar, ob das „*keimende Leben*“ ohnehin von einer Gewährleistung eines Rechts auf Leben erfasst ist oder ob es zu diesem Zweck der expliziten Nennung im Gesetzestext bedarf. Nachdem der Abgeordnete *Seehofer* der DP-Fraktion statuiert hatte, das Recht auf Leben müsse nicht notwendigerweise auch das keimende Leben einschließen, weswegen dies ausdrücklich festzustellen sei, erklärte die Abgeordnete *Weber* für die CDU/CSU-Fraktion, das Recht auf Leben schütze „*das Leben schlechthin*“, wovon auch das keimende Leben umfasst sei und worin der Abgeordnete *Heuß* ihr zustimmte. Da diese Äußerungen un widersprochen blieben, ging der Abgeordnete *Seehofer* von einer entsprechenden, einhelligen Meinung aus und zog den DP-Antrag auf Aufnahme eines klarstellenden und einen Schutz des keimenden Lebens begründenden Satzes in den Text des Grundgesetzes zurück, griff ihn jedoch erneut auf, als einige Abgeordnete gegen die Feststellung einer einhelligen Meinung Verwahrung einlegten. Der Antrag wurde mit sieben Stimmen dafür und elf Stimmen dagegen abgelehnt. Vor dem Hintergrund des vorangegangenen Diskurses, insbesondere aufgrund der ausdrücklichen Verwahrung gegen die Annahme, es bestünde einhellige Meinung, dass jegliches, also auch das frühe und ungeborene, Leben geschützt werde, kann jedoch diesen letztgenannten elf Stimmen nicht unterstellt werden, sie würden mit der durch die Stimmabgabe erklärten Ablehnung der Aufnahme eines den Schutz explizierenden Satzes lediglich ausdrücken wollen, sie hielten diesen, da ohnehin verbürgt, für überflüssig. Wenn man nicht so weit gehen und die Konsequenz ziehen will, dies

<sup>484</sup> *Dederer*, AöR 127 (2002), 1 (11 f.).

<sup>485</sup> *Dreier-Dreier*, GG, Art. 1 I Rdnr. 82 geht von dieser Annahme aus.

lege gerade den Schluss nahe, vorgeburtliches Leben solle nicht erfasst sein, so muss man doch immerhin zu dem Ergebnis kommen, der historischen Auslegung ein *non liquet* attestieren zu müssen.<sup>486</sup>

## (2) Rezeption in der Rechtsprechung und der juristischen Literatur

In der Literatur wird verbreitet angenommen, dass sich die Menschenwürdegarantie des Art. 1 I GG nicht nur auf das ungeborene, pränatale menschliche Leben, sondern auch auf das pränidative frühembryonale Leben erstreckt.<sup>487</sup> Auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts<sup>488</sup> kann sich diese Auffassung jedoch nicht berufen: Im Jahr 1975 urteilte das Gericht, dass menschlichem Leben stets auch Menschenwürde zukommt, und zwar unabhängig davon, ob der Träger sich dieses Umstandes bewusst sein und seine Würde schützen kann. Die bloß abstrakte Potentialität hierzu genüge.<sup>489</sup> Demzufolge würde der zeitliche Beginn der Menschenwürde mit dem menschlichen Leben übereinstimmen. Im Hinblick hierauf stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass dieses jedenfalls mit der Nidation beginnt; das Gericht sprach also jedenfalls dem *nasciturus*, dem Embryo nach der Nidation, Menschenwürde zu. Die Frage der Trägerschaft des Grundrechts aus Art. 1 I 1 GG vor der Einnistung ließ das Gericht aber offen,<sup>490</sup> da es sich bei seiner Entscheidung auf den Zeitraum nach der Nidation beschränken konnte, da erst ab dem Zeitpunkt eine Abtreibung im Sinne der §§ 218 ff. StGB in Frage kommt. Auch auf das Wort „*jedenfalls*“<sup>491</sup> kann eine andere Annahme nicht gestützt werden.<sup>492</sup> Das gleiche gilt für das zweite Abtreibungsurteil aus dem Jahr 1993, in dem das Gericht sein früheres Urteil bestätigte.<sup>493</sup> Jedoch merkte das Gericht in einem *obiter dictum* an, dass medizinanthropologisch die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle als der Zeitpunkt des Beginns menschlichen Lebens naheliegt.<sup>494</sup>

Entsprechend wird in der juristischen Literatur vorgebracht, dass menschliches Leben schon dann beginnt und ihm schon dann Menschenwürde zuzuerkennen ist, sobald die genetische Ausstattung der zukünftigen Person feststeht, was mit Abschluss der Befruchtung der Fall ist. Ab diesem Zeitpunkt entwickelt sich der Em-

<sup>486</sup> Merkel, Forschungsobjekt Embryo, S. 26 ff.

<sup>487</sup> von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 1 Abs. 1 Rndr. 19; Benda, NJW 2001, 2147 (2148); Fechner, JZ 1986, 653 (660); Kloepfer, JZ 2002, 417 (420); Laufs, JZ 1986, 769 (774); Lorenz, ZfL 2001, 38 (43); a. A.: Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 81 ff.; Heun, JZ 2002, 517 ff.; Hofmann, AöR 118 (1993), 353 (375 f.); Ipsen, JZ 2001, 989 (993) spricht von einer Vorwirkung, die ausschließlich Schutzpflichten des Staates, aber keine damit korrespondierenden Schutzrechte begründet.

<sup>488</sup> BVerfGE 39, 1; 88, 203.

<sup>489</sup> BVerfGE 39, 1 (41).

<sup>490</sup> Hufen, ZRP 2002, 372.

<sup>491</sup> BVerfGE 39, 1 (37).

<sup>492</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Fn. 257; Heun, JZ 2002, 517; Jerouschek, JZ 1989, 279 (281).

<sup>493</sup> BVerfGE 88, 203 (251 f.).

<sup>494</sup> BVerfGE 88, 203 (251).

bryo nicht *zum* Menschen; er entwickelt sich *als* (und ist mithin schon) Mensch.<sup>495</sup> Die Tatsache, dass das Strafrecht<sup>496</sup> den Embryo erst ab der Nidation schützt und auch § 1 BGB die Vollendung der Geburt als den Beginn der Rechtsfähigkeit des Menschen postuliert, führt dabei jedoch ebenso wenig zu dem Erfordernis, den verfassungsrechtlichen Beginn menschlichen Lebens zu überdenken, wie die Bezeichnung der vorgeburtlichen Stadien als „*Ungeborene[s]*“ in § 219 StGB oder „*Embryo*“ im Embryonenschutzgesetz anstelle der Bezeichnung als Mensch eine gegenteilige Bewertung rechtfertigt. Zwar mag das Verfassungsrecht als höherrangiges Recht eine Auslegungshilfe für die Interpretation einfachen Rechts darstellen. Dies gilt jedoch nicht *vice versa*, da sich andernfalls ein Wandel in der Interpretation des einfachen Rechts effektiv wie eine Verfassungsänderung auswirken und die Anforderungen, die an eine Änderung des Grundgesetzes, etwa das Erreichen einer Zwei-Drittel-Mehrheit sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat, umgehen würde. Schließlich ist eine Zurückhaltung des Strafrechts in Bezug auf den pränidationalen Zeitraum auch nur sinnvoll, ist das Ereignis der Befruchtung vor der Nidation, das heißt vor Etablierung einer Schwangerschaft, aufgrund deren Unsicherheit kaum zu beweisen.<sup>497</sup>

Nichtsdestoweniger vermag man aus der aktuell geltenden und höchststrichterlich als verfassungsgemäß erkannten Rechtslage mittelbare Rückschlüsse auf den Status von Embryonen im Hinblick auf die Menschenwürdeträgerschaft ziehen. Will man nicht Inkonsistenzen unterstellen, so verbleiben lediglich die Möglichkeit, dass entweder der Embryo bereits Träger von Menschenwürde ist, weswegen die Abtreibungsregelungen verfassungswidrig sein müssten, sowie die Variante der Verfassungsmäßigkeit aufgrund mangelnder Grundrechtsträgerschaft im Hinblick auf Art. 1 I 1 GG.<sup>498</sup> Knüpft an die Menschenwürde jedoch ein genuin eigenes Lebensrecht an und hat hiernach doch jeder Mensch den Anspruch, als Rechtssubjekt behandelt zu werden und würde diese Rechtssubjektivität durch die Disposition der Mutter über seine Existenz beseitigt werden, so wäre die Verfassungskonformität der §§ 218 ff. StGB konsequenterweise zu verneinen gewesen.<sup>499</sup> Freilich stellt nicht jegliche Tötung eines Menschen eine Verletzung dessen Würde dar. Dies gilt soweit ersichtlich jedoch nur in Fällen der Notwehr und Nothilfe, keineswegs aber, wird das Leben eines Menschen der Disposition eines anderen unterstellt. Wird das Rechtssubjekt selbst beseitigt, wird ihm auch seine Rechtssubjektivität nicht zuerkannt und mithin seine Würde verletzt. Soweit das Bundesverfassungsgericht jedoch das geltende Beratungs- und Fristenmodell als verfassungsgemäß erkannt

<sup>495</sup> Hufen, Individuelle Rechte und die Zulassung der PID, S. 141; Ipsen, NJW 2004, 268 (269).

<sup>496</sup> §§ 218 ff. Strafgesetzbuch.

<sup>497</sup> Wagner, Der gentechnische Eingriff in die menschliche Keimbahn, S. 59.

<sup>498</sup> Vergleiche auch Gutmann, Rechtliche und rechtsphilosophische Fragen der Präimplantationsdiagnostik, S. 71.

<sup>499</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 70; Ipsen, JZ 2001, 989 (991 f.); Dreier, Bioethik zwischen gesellschaftlicher Pluralität und staatlicher Neutralität, S. 21 beklagt ausdrücklich den unaufheb-  
baren Widerspruch zwischen den leitthesenhaften Sentenzen des Urteils und die konkreten Ent-  
scheidungsgehalten.

hat, kann es sich daher bei den Ausführungen des Gerichts zu Art. 1 I GG nur um bloße Würderhetorik handeln, die, wenn Grundrechtsrechtsträgerschaft postuliert, aber schließlich nicht durchgehalten wird, negative Rückwirkungen auf den Würde- und Lebensschutz allgemein entfalten kann.<sup>500</sup> Anderes könne, so argumentiert etwa *Jörn Ipsen*, nur gelten, wenn Art. 1 I 1 GG im Hinblick auf Embryonen lediglich eine objektiv-rechtliche Schutzpflicht begründen würde, also nur das ungeborene menschliche Leben an sich, nicht aber den konkreten Embryo, der dann ja gerade nicht Träger der Menschenwürde sei, schützt.<sup>501</sup>

Darüber hinaus stehen der Auffassung, der pränidative, extrakorporale Embryo sei Träger der Menschenwürde, mehrere, im Folgenden zu erörternde Bedenken entgegen.

Schon jetzt sei allerdings angemerkt, dass die häufig für die Grundrechtsträgerschaft von Embryonen im Hinblick auf Art. 1 I 1 GG vorgetragene Schlussfolgerung, menschlichem Leben komme immer auch Menschenwürde zu, weil das menschliche Leben „*die vitale Basis der Menschenwürde*“<sup>502</sup> sei, nicht überzeugen kann. Diese Schlussfolgerung sagt nämlich das genaue Gegenteil aus. Es stimmt, dass nur menschlichem Leben auch Menschenwürde zukommen kann. Ein Tier oder eine bloße Sache kann nicht Träger des Rechts aus Art. 1 I 1 GG sein. Deswegen kann aber nicht *per se* jedem menschlichem Leben auch Menschenwürde zugesprochen werden. Dies gilt es ja gerade zu klären. Das Faktum des Lebens und das empirisch damit im Kontext stehende Faktum der Grundrechtsausübung lassen jedoch keinen normativen Zusammenhang zwischen dem Recht auf Leben und der Gewährleistung der Menschenwürde begründen. Dasjenige menschliche Leben, dem Menschenwürde zukommt, ist, wie sich zeigen wird, lediglich eine Teilmenge allen menschlichen Lebens. Der biologischen Zuordnung alleine kommt keine alleinige normative Definitionsmacht zu. Richtig ist daher die Schlussfolgerung, dass ein Träger der Menschenwürde auch stets menschliches Leben sein muss; einen naturalistischen Fehlschluss hingegen begeht, wer diesen empirischen Kausalzusammenhang unmittelbar in einen normativen Ableitungszusammenhang transformiert.<sup>503</sup> Auf das bloße Vorliegen von menschlichem Leben kann sich die Begründung der Menschenwürde mithin nicht stützen.

### (3) *Biologische Entwicklung menschlichen Lebens und Individuumsbezogenheit der Menschenwürde*

Weitere Probleme bereitet der Umstand, dass sich sowohl die Zygote als auch der Embryo in seinem pränidativen Stadium in einer Frühphase des embryonalen Lebens befindet. Beiden fehlt es nicht nur an Ich-Bewusstsein oder Autonomie. Mangels Ausbildung eines Nervensystems oder eines Gehirns ist auch beides zu jeg-

<sup>500</sup> *Gutmann*, Rechtliche und rechtsphilosophische Fragen der Präimplantationsdiagnostik, S. 71.

<sup>501</sup> *Ipsen*, JZ 2001, 989 (991 f.).

<sup>502</sup> BVerfGE 39, 1 (42).

<sup>503</sup> So wohl auch *Dreier-Dreier*, GG, Art. 1 I Rdnr. 66; *Neumann*, Die Menschenwürde als Menschenbürde, S. 50.



lichen Empfindungen, das heißt auch zu Schmerzempfindungen, nicht in der Lage. Außerdem ist bis zur Ausbildung des so genannten Primitivstreifens, die um den 14. Tag nach der Befruchtung erfolgt, noch eine Mehrlingsbildung möglich. Daraus folgt, dass zunächst zwar artspezifisches, aber noch nicht individuiertes Leben vorliegt.<sup>504</sup> Es handelt sich sozusagen nicht um ein Individuum, sondern um ein Dividuum.<sup>505</sup> Anschaulich machen diese Differenzierung auch die englischen Begriffe: Bei einer Zygote oder einem pränidativen Embryo handele es sich, so *Horst Dreier*, nicht um ein *human being*, wohl aber um *human life*.<sup>506</sup> Problematisch kann dies vor dem Hintergrund erscheinen, dass sämtliche Grundrechte – und so auch der Menschenwürdesatz – Rechte des Einzelnen und daher individualbezogen sind, vor Ausbildung des Primitivstreifens jedoch gerade kein solches Individuum vorliegt.<sup>507</sup>

#### (4) Kontinuitäts-, Potentialitäts- und Identitätsargument

##### (a) Kontinuitätsargument

Dem Ergebnis, dass die Zygote oder der Embryo *in vitro* nicht Träger der Menschenwürde ist, steht auch nicht das Kontinuitätsargument<sup>508</sup> entgegen. Dieses spricht auch menschlichem Leben in den frühesten Entwicklungsstadien Menschenwürde zu, weil sich hieraus durch kontinuierliches Wachstum ein geborener Mensch entwickelt.<sup>509</sup> Diese Annahme beruht jedoch auf einem klassischen Fehlschluss, dem Sôritês-Paradoxon. Hiernach macht ein Sandkorn für sich alleine noch keinen Sandhaufen aus. Ein Sandkorn und ein weiteres ebenso wenig. Dies gilt für jedes weitere Sandkorn, welches man hinzufügt. Dennoch stellen eine Million Sandkörner einen Haufen dar. Dies zeigt, dass neue qualitative Stufen trotz Abwesenheit von klaren Zäsuren im Prozess kontinuierlicher Entwicklung<sup>510</sup> erreicht werden können. Hiermit lässt sich jedoch nicht begründen, dass die höchste qualitative Stufe, das heißt im Beispiel das Vorliegen eines Sandhaufens und angewendet auf die Evaluierung des genetischen Keimbahnenhancements die Trägerschaft der Menschenwürde, von Anfang an dem ersten Sandkorn beziehungsweise der befruchteten Eizelle zuzu-

<sup>504</sup> *Hofmann*, JZ 1986, 253 (259).

<sup>505</sup> *Dreier*, Bioethik zwischen gesellschaftlicher Pluralität und staatlicher Neutralität, S. 24; *Dreier*, Bioethik, S. 83.

<sup>506</sup> *Dreier-Dreier*, GG, Art. 1 I Rdnr. 83; *Dreier*, Bioethik, S. 83.

<sup>507</sup> *Dreier-Dreier*, GG, Art. 1 I Rdnr. 83.

<sup>508</sup> Dieses Argument begegnet in BVerfGE 39, 1 (37); in der Literatur vertreten es z. B. von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 18; *Böckenförde*, JZ 2003, 809 (812 f.).

<sup>509</sup> *Böckenförde*, JZ 2003, 809 (812) formuliert: „Nachdem der individuelle Chromosomensatz fixiert ist, gibt es nämlich keinen Einschnitt in die Qualität dessen, was sich entwickelt.“

<sup>510</sup> Bereits gegen diese Annahme bestehen Zweifel im Hinblick auf die herausragende Bedeutung der Einnistung in die Gebärmutter, die bei auf natürlichem Wege gezeugten Embryonen nur in einem Drittel aller Fälle stattfindet und die bei künstlicher Befruchtung noch der Handlung eines Dritten, nämlich der Implantation, bedarf. Die Nidation als wesentliche Zäsur sehen auch an *Hofmann*, JZ 1986, 253 (259); *Dreier*, ZRP 2002, 377 (379 f.).



sprechen ist.<sup>511</sup> Seit *David Hume* weisen Philosophen darauf hin, dass aus dem Sein noch kein Sollen abgeleitet werden kann, dass also aus einem deskriptiven Satz als einer naturwissenschaftlichen Tatsache nicht notwendigerweise eine bestimmte Wertung oder Norm fließen muss.<sup>512</sup>

### (b) Potentialitätsargument

Auch das Potentialitätsargument vermag kein anderes Ergebnis zu begründen. Dieses stellt ab auf die bereits im frühembryonalen Leben angelegte Möglichkeit der Fortentwicklung zu einem geborenen Menschen. Die Tatsache, dass diesem dann die volle Menschenwürde zukommt, soll auch die Menschenwürde des Embryos begründen.<sup>513</sup> Der Status *ad quem* soll also zur Rechtszuschreibung schon im *status quo* führen.<sup>514</sup> Es wird also aus der Feststellung, jedes Wesen, das aktuell  $\phi$  ist, habe Würde, gefolgert, dass jedes Wesen, das potentiell  $\phi$  ist, ebenfalls Würde habe. Und abhängig davon, was genau  $\phi$  in diesem Fall ist.<sup>515</sup>

Erste Schwierigkeiten bestehen hier schon bei der genaueren Begriffsbestimmung von Potentialität. Zum einen könnte hierunter eine allgemeine Möglichkeit verstanden werden. Ein Embryo hätte also dann Potentialität, wenn es möglich wäre, dass er sich zu einem geborenen Menschen entwickelt. Konkret kommt dabei sowohl die bloß logische als auch die praktisch-reale Möglichkeit in Frage. Intuitiv erscheint jedoch wohl die letztgenannte Möglichkeit zur Begründung eines auch gegenwärtigen moralischen Status als tauglicher, sagt erstgenannte Variante doch nichts über die empirische Evaluation der embryonalen Situation aus. Die Bedeutung der Wahrscheinlichkeit tatsächlicher Entwicklung bliebe demnach weiterhin zu analysieren.<sup>516</sup>

Gleichzeitig ließe sich Potentialität auch weiter differenzieren in aktives Potential, welches vorliegt, wenn der in Frage stehende Entwicklungsprozess von der jeweiligen Entität selbst veranlasst, durchgeführt und gesteuert wird, und lediglich passives Potential, bei dem es für die Entwicklung der Bearbeitung oder der

<sup>511</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 85; Dreier, Bioethik zwischen gesellschaftlicher Pluralität und staatlicher Neutralität, S. 24; Hilgendorf, NJW 1996, 758 (761); den Vergleich mit dem Sôritês-Paradoxon ablehnend Starck, JZ 2002, 1065 (1068).

<sup>512</sup> Hilgendorf, NJW 1996, 758 (761).

<sup>513</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 85.

<sup>514</sup> Heun, JZ 2002, 517 (520).

<sup>515</sup> Schöne-Seifert, Contra Potentialitätsargument, S. 170 ff.: Interessant ist in diesem Zusammenhang zunächst die Frage, wie der Übergang zwischen der Voraussetzung zur Prämisse erfolgt. Zur Erörterung der grundsätzlichen (Un-)Plausibilität des Potentialitätsargumentes bedarf es hierzu keiner definierenden oder präzisierenden Ausführung, wenn auch angemerkt sein soll, dass gerade in der angloamerikanischen Diskussion hierunter in der Regel ein Person-Sein, zuweilen aber auch eine dispositionelle Moralfähigkeit verstanden wird, wobei die Annahme letztgenannten Begriffs das Rekurren auf ein Potentialitätsargument zur Tautologie macht, da  $\phi$  hiernach schon bei bloßer Latenz und noch erforderlicher Entwicklung gegeben und nicht bloß potentiell möglich ist.

<sup>516</sup> Merkel, Forschungsobjekt Embryo, S. 161 f.

Disposition einer anderen Entität bedarf.<sup>517</sup> Häufig wird, um diesen Unterschied deutlich zu machen, das Beispiel des Marmorblockes vorgebracht, der nur dann zu einer Statue werden kann, wenn er entsprechend vom Künstler bearbeitet wird. Die Eichel hingegen ist in der Lage, sich selbst zu einem Baum zu entwickeln, wenn auch freilich die Umgebung bestimmte, beispielsweise klimatische, Bedingungen erfüllen muss.<sup>518</sup> Hier bliebe zu hinterfragen, inwiefern eine nur passive Potentialität einen auch nur eingeschränkten Status zu begründen vermag. Als allgemeiner Anknüpfungspunkt könnte hier die nicht mehr als allzu entfernt erscheinende Möglichkeit dienen, aus somatischen Körper-, also Beispielsweise Hautzellen nicht nur iPS-Zellen, sondern sogar totipotente Zellen zu gewinnen, die sich ihrerseits zu einem neuen Individuum entwickeln können. Würde man nicht zwischen aktiver und passiver Potentialität differenzieren, müsste man, obschon noch intensive Manipulationen von außen erforderlich sind, der somatischen Zelle Menschenwürde und Lebensschutz zusprechen. Das erscheint jedoch vollständig abwegig und sinnlos.<sup>519</sup> Gleichwohl sind auch die Mühen, die erforderlich sein mögen, mit einer befruchteten menschlichen Eizelle *in vivo* eine Schwangerschaft zu etablieren, enorm. Fraglich ist aber, was diese Mühen von denen zur Reprogrammierung von Körperzellen unterscheidet.<sup>520</sup>

Die empirische Wahrscheinlichkeit, mit der sich die aktive oder passive Potentialität auch tatsächlich realisiert, ist nach diesem Konzept hingegen unbeachtlich. Dass der Marmorblock, der bereits in das Atelier des Künstlers transportiert wurde, eine größere Wahrscheinlichkeit zur Entwicklung hat als die Eichel, soll hierbei nichts an der Zuordnung ändern.<sup>521</sup> Was mit der Entität gewollt ist kann richtigerweise für die Evaluation des moralischen Status und des Umfanges des darauf gründenden Schutzes nicht von Relevanz sein. Ein solcher äußerer Umstand, der kausal von menschlichen Entscheidungen über den Umgang mit dem Embryo beeinflusst ist, kann nicht statusrelevant sein.<sup>522</sup> Angewandt auf den konkreten Fall des Embryos würde dies ansonsten zu dem nicht hinnehmbaren Ergebnis führen, dass in diesem Stadium nur Wunschkinder in den Genuss von Menschenwürde und Lebensschutz kommen, während es doch gerade die nicht gewollten Kinder sind, die eines besonderen Schutzes bedürfen.

Betrachtet man den natürlichen, im Sinne von herkömmlichen Zeugungsakt, verläuft die Entwicklung entlang eines naturkausalen Programms. Zwar gelingt

<sup>517</sup> Vergleiche *Schöne-Seifert*, Contra Potentialitätsargument, S. 175 ff.

<sup>518</sup> Angewiesen auf bestimmte Rahmenbedingungen ist auch die befruchtete Eizelle *in vivo*. *Schöne-Seifert*, Contra Potentialitätsargument, S. 176 bezeichnet diese Voraussetzungen als „zahlreich und labil“.

<sup>519</sup> Auch *Schöne-Seifert*, Contra Potentialitätsargument, S. 175 f. kommt richtigerweise nicht zu einem solchen Ergebnis.

<sup>520</sup> Vergleiche auch *Schöne-Seifert*, Contra Potentialitätsargument, S. 176.

<sup>521</sup> *Merkel*, Forschungsobjekt Embryo, S. 162 f.

<sup>522</sup> Zu diesem Ergebnis kommt auch *Merkel*, Forschungsobjekt Embryo, S. 165; *Schöne-Seifert*, Contra Potentialitätsargument, S. 179 f. stellt fest, dass bei Zugrundelegung von unter Einbeziehung menschlicher Absichten und Handlungen ermittelten Entwicklungschancen Potentialität zu einem extrinsischen und so unplausiblen Konzept wird.

nur etwa einem Drittel der befruchteten Eizellen auch die Einnistung in die Gebärmutter Schleimhaut,<sup>523</sup> was die Potentialität mit dem zuerst erörterten Konzept der praktisch-realen Möglichkeit mit Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit herabsetzt, was aber auch bedeutet, dass die weitere Entwicklung keines Eingriffs von dritter Seite bedarf. Die Einnistung ist zunächst aber unabdingbare Voraussetzung zur weiteren Entwicklung des Embryos, was umso deutlicher wird, wenn man sich nicht den natürlichen Prozess der Fortpflanzung, sondern die In-vitro-Fertilisation mit anschließender Implantation mittels ärztlicher Unterstützungsmaßnahmen vor Augen hält, die nicht nur eine Abhängigkeit von in ihrem Erfolg nicht besonders wahrscheinlicher natürlicher Abläufe, sondern gar von einem Eingriff von außen offenlegt.<sup>524</sup> Aus medizinischer Sicht handelt es sich daher, so könnte man schlussfolgern, bis zu diesem Zeitpunkt weniger um eine Entwicklung *als* Mensch, sondern vielmehr um eine Entwicklung *zum* Menschen.<sup>525</sup> Und selbst nach erfolgter Einnistung ist umstritten, ob der Status des postnidationalen Embryos nicht ein immanent passiver<sup>526</sup> ist, da seine Entwicklung stets eines Trigger-Impulses durch den mütterlichen Körper bedarf.<sup>527</sup> Könnte mit dieser Begründung sogar die Potentialität in diesem späteren Stadium angezweifelt werden, so muss dies *a maiore ad minus* erst recht für den Embryo vor der Nidation gelten.

Bei einem Embryo *in vitro* wird dies noch einmal deutlicher, bedarf es dazu doch eines Eingriffes Dritter, was eine nur passive Potentialität bedeuten würde, die nur (vorbehaltlich soeben aufgeführter Bedenken) durch die Transplantation in eine aktive Potentialität überführt werden könnte.<sup>528</sup> Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Übertragung in einen Uterus erfolgt, die, sofern man das Risiko der erfolglosen Nidation außer Acht lässt, direkt äquivalent zu der Wahrscheinlichkeit der Weiterentwicklung ist, da diese hierfür unabdingbare Voraussetzung ist, vor dem Hintergrund embryonenschützender gesetzlicher Regelungen, die dann zwar keine Umwelt der in Frage stehenden Entität im Sinne von bestimmten klimatischen Bedingungen oder ausreichender Nährstoffzufuhr, wohl aber im Sinne eines normativen Umfeldes darstellen, sehr groß.<sup>529</sup> Allerdings stellt sich mir dies als ein

<sup>523</sup> Rosenau, Reproduktives und therapeutisches Klonen, S. 771.

<sup>524</sup> Vergleiche Herdegen, JZ 2001, 773 (775).

<sup>525</sup> Hufen, Individuelle Rechte und die Zulassung der PID, S. 141; Ipsen, NJW 2004, 268 (269); anderer Auffassung ist Schöne-Seifert, Contra Potentialitätsargument, S. 179, die hierin eine normative Auszeichnung eines „naturbelassenen“ Verlaufes sieht.

<sup>526</sup> So Bettina Schöne-Seifert im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages zur Präimplantationsdiagnostik am 25. Mai 2011, <http://dbtg.tv/cvid/1151849> (zuletzt aufgerufen am 27.12.2012).

<sup>527</sup> Dies bedarf vorliegend, geht es ohnehin erst um die Zygote als *nondum conceptus*, freilich keiner weiteren Erörterung. Verwiesen sei aber auf die soeben getätigten Ausführungen hierzu.

<sup>528</sup> Zwischen dem wesenhaften Potential einer Entität selbst und denjenigen Potentialen, die zu deren Entstehen erst geführt haben, unterscheidet auch Schöne-Seifert, Contra Potentialitätsargument, S. 177.

<sup>529</sup> Merkel, Forschungsobjekt Embryo, S. 164 f., was jedoch nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass auch Merkel dem Potentialitätsargument im Ergebnis kritisch gegenübersteht.

merkwürdig zirkulärer Schluss dar.<sup>530</sup> Es soll ja gerade festgestellt werden, ob ein Embryo vor der Nidation einen normativ relevanten, Schutzansprüche begründenden moralischen Status hat, was nun unter Heranziehung von juristisch-normativen Argumenten zu belegen versucht wird. Dies ist gleich in doppelter Hinsicht mindestens schwierig:

Zum einen soll über die Hintertür eines einfachen Gesetzes der Inhalt von Verfassungsrecht spezifiziert werden. Dieser Weg ist jedoch, wie schon dargelegt, gesperrt. Darüber hinaus wird doch gerade die Frage nach dem moralischen Status des Embryos gestellt. An diesem wird sich sodann die gesetzliche Ausgestaltung dessen, wie mit ihm umgegangen werden muss und darf, ausrichten. Die Deduktion erfolgt also genau der entgegengesetzten Richtung als sie es müsste, wollte man eine Ausstrahlungswirkung der Situation *de lege lata* auf den, je nach Blickwinkel, vorgeschalteten oder übergeordneten Topos des moralischen Status annehmen.

Stimmt man mit dieser Beurteilung jedoch nicht überein, so wird man die Potentialität des *nondum conceptus in vitro*, also des extrakorporalen Embryos vor Transplantation und Nidation, annehmen und kommt sodann nicht umhin, sich mit einem weiteren problematischen Aspekt auseinanderzusetzen. Konsequenterweise müsste man dann auch dem Pronukleus nach In-vitro-Fertilisation volle Potentialität zubilligen, da die imprägnierte Eizelle im Vorkernstadium sich vollständig naturkausal über die Verschmelzung der Kerne zur Zygote<sup>531</sup> und somit zum Embryo entwickelt. Zu diesem Zeitpunkt jedoch sind die beiden haploiden Chromosomensätze noch getrennt, sodass noch kein neues menschliches Individuum mit einem distinkten, eigenen Genom entstanden ist. Grundrechtsstatus kann jedoch stets nur Individuen zukommen.<sup>532</sup> Entsprechend ist diese ansonsten konsequente Ausdehnung nicht einsehbar.

Das Potentialitätsargument könnte nach alledem nur unter Hinnahme von beträchtlichen Inkonsistenzen aufrecht erhalten werden<sup>533</sup> und vermag mithin nicht zu überzeugen.

### (c) Identitätsargument

Auch das Identitätsargument, das auf die Identität zwischen der jeweiligen pränatalen Entität *in vitro* und *in vivo* sowie dem späteren geborenen Menschen abstellt und hiermit Menschenwürde begründet,<sup>534</sup> steht dem Ergebnis, dass die Zygote oder der pränidative Embryo nicht Träger der Menschenwürde ist, nicht entgegen.<sup>535</sup> Diese Identität besteht nämlich nur ab der Individuation, das heißt ab der Ausbildung des Primitivstreifens, bis zu der noch eine Mehrlingsbildung möglich ist und bis zu der

<sup>530</sup> So auch *Schöne-Seifert*, Contra Potentialitätsargument, S. 180.

<sup>531</sup> Zu deren Potentialität *Schroth*, JZ 2002, 170 (176).

<sup>532</sup> *Heun*, JZ 2002, 517 (521).

<sup>533</sup> *Merkel*, Forschungsobjekt Embryo, S. 176 f.

<sup>534</sup> *Epping/Hillgruber-Hillgruber*, GG, Art. 1 Rdnr. 4.

<sup>535</sup> Zu einem anderen Ergebnis gelangt von *Mangoldt/Klein/Starck-Starck*, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 21.

daher von einer ausgebildeten Individualität nicht gesprochen werden kann.<sup>536</sup> Hierfür ist auch die genetische Identität eineiiger Zwillinge unschädlich. Diese macht zwei Zwillinge schließlich nicht zu einem einzigen Menschen oder einem einzigen Individuum.<sup>537</sup> Es handelt sich sozusagen zwar um den genetisch *gleichen*, jedoch nicht um *denselben* Menschen. Versteht man Identität des Weiteren nicht nur in diesem engen, sondern einem über die bloße genetische Identität hinausgehenden und die jeweilige Persönlichkeit umfassenden Sinne, so wird dies umso deutlicher.<sup>538</sup> Der gegen diese Kritik am Identitätsargument vorgebrachte Einwand, ein Identitätsbruch finde lediglich bei tatsächlicher, nicht aber bei bloß möglicher Mehrlingsbildung statt, vermag ein anderes Ergebnis nicht zu begründen. *Ex ante* ist unbekannt, ob eine Mehrlingsbildung eintritt. Es kann aber nicht sein, dass dem pränidativen und noch nicht individuierten Embryo die Menschenwürde gewissermaßen auf Probe zugesprochen wird und ihm mit einer Teilung zu eineiigen Zwillingen bis zu dem Zeitpunkt der Mehrlingsbildung rückwirkend wieder aberkannt wird.<sup>539</sup>

Der pränidative Embryo und somit auch die vorangehende Zygote sind daher nicht Träger der Menschenwürde im Sinne des Art. 1 I 1 GG.<sup>540</sup>

Selbst wenn man aber davon ausgeht, dass Zygoten oder pränidative Embryonen mit dem geborenen, voll entwickelten Menschen identisch sind, heißt dies nicht, dass diese ebenso schutzwürdig sein müssten wie der geborene Mensch. Es heißt aber auch nicht, dass der geborene Mensch so schutzlos ist wie die Zygote oder der Embryo. Die Schutzwürdigkeit als eine normative Eigenschaft hängt vielmehr von den deskriptiven Eigenschaften des Trägers ab, die variieren können. Weil weder der Zygote noch dem Embryo in vollem Umfang die deskriptiven Eigenschaften zukommen wie einem erwachsenen Menschen, weist er auch nicht notwendig dieselben normativen Eigenschaften auf. Dies bedeutet aber nicht, dass sie keinerlei Schutzanspruch hätten, sondern spricht vielmehr für einen differenzierten, abgestuften Schutz.<sup>541</sup> Auf diese Konzeption ist im Folgenden einzugehen.

### (5) Theorie des gestuften Schutzes der Menschenwürde

Die Vertreter der Theorie eines gestuften Schutzes der Menschenwürde<sup>542</sup> sprechen zwar auch den frühesten Erscheinungsformen menschlichen Lebens Menschenwürde zu. Deren Schutz soll sich jedoch dem Grad nach an dem Leitbild natürlicher Entwicklungsprozesse orientieren. Dies ermöglicht eine Differenzierung zwischen

<sup>536</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 83; Dreier, Bioethik zwischen gesellschaftlicher Pluralität und staatlicher Neutralität, S. 26; *Nationaler Ethikrat*, Genetische Diagnostik, S. 127.

<sup>537</sup> Heun, Menschenwürde und Lebensrecht als Maßstäbe für PID?, S. 116.

<sup>538</sup> Im Ansatz so wohl auch Schroth, JZ 2002, 170 (176).

<sup>539</sup> Heun, Menschenwürde und Lebensrecht als Maßstäbe für PID?, S. 118 f.

<sup>540</sup> So im Ergebnis u. a. auch Schroth, JZ 2002, 170 (177).

<sup>541</sup> Birnbacher, Menschenwürde und Lebensrecht als Maßstäbe für PGD?, S. 18 und in Bezug auf das Lebensrecht des Embryos S. 31 f.

<sup>542</sup> Etwa Kloepfer, JZ 2002, 417 (420 f.); hierzu auch *Enquete-Kommission „Recht und Ethik“*, S. 97 f.; *Nationaler Ethikrat*, Genetische Diagnostik, S. 125.

den unterschiedlichen Entwicklungsstufen des frühen menschlichen Lebens.<sup>543</sup> Auch *Aristoteles* unterschied in seinen embryologischen Spekulationen drei Entwicklungsstufen des Embryos, nämlich die vegetativ-pflanzliche, die tierisch-sensitive und die menschlich-rationale, welche der organomorphologischen Ausbildung des Embryos entsprachen. Nach Erlangung des sensitiven Lebens sollte eine Abtreibung nicht mehr zulässig sein. Diese Sukzessivbeseelung findet sich ebenfalls in der Septuaginta-Übertragung des Alten Testaments vom Hebräischen ins Griechische wieder. Der Passus 2. Mos. 21, 22-25 wurde von der Septuaginta dahingehend formuliert, dass eine Abtreibung erst dann einen Totschlag verwirkliche, wenn der Fötus bereits ein phänotypisch menschliches Erscheinungsbild aufweise. Begründet wurde dies damit, dass erst zu diesem Zeitpunkt die *infusio animae*, die Einflößung der Seele, stattgefunden habe. Erst hiermit beginne der Fötus zu leben.<sup>544</sup> Des Weiteren findet die Theorie eines gestuften Schutzes der Menschenwürde auch in der Geistesgeschichte ihre Begründung, in der Würde in engem Zusammenhang mit dem Heranreifen im Mutterleib steht und in der die Nidation einen qualitativen Sprung des Embryos im Hinblick auf seinen Status bedeutet. Denn erst nach erfolgter Implantation und Nidation beginnt der Entwicklungsprozess, der von ärztlicher Unterstützung unabhängig ist. Der Embryo ist nach dieser Auffassung daher bereits mit Befruchtung der Eizelle Träger von Menschenwürde, die aber nur graduellen Schutz erfährt.<sup>545</sup>

Gegen diese Auffassung spricht jedoch entschieden der verfassungsrechtlich hohe Rang der Menschenwürde. Diese hat im Vergleich zu jedem anderen Schutzgut stets stärkeres Gewicht und kann damit nicht abgewogen werden.<sup>546</sup> Die Annahme eines nur gestuften Schutzes würde diese Unantastbarkeit, wie sie der Wortlaut des Art. 1 I 1 GG proklamiert, jedoch aufweichen<sup>547</sup> und die Funktion des Würdeschutzes „im Grunde schon unterlaufen“, soll die Würde doch einen fixen Rechtszustand darstellen, der nicht zur Disposition durch die Rechtsgemeinschaft steht, sondern stets deren Anerkennung unabhängig jeglicher kulturell-sozialer Zuschreibungen fordert.<sup>548</sup> Ein Recht, das zwar gegeben, aber nicht geschützt ist, ist in seinem Bestand darüber hinaus unsicher. Der mangelnde Schutz wird früher oder später zu dem zumindest faktischen Wegfall dieses Rechts führen. Die Rechtsposition eines Eigentümers wäre beispielsweise vollständig ausgehöhlt, wenn diese nicht oder nur in geringem Umfang durch die §§ 985-1007 BGB geschützt wäre, beziehungsweise wenn der Eigentümer sich hierauf prinzipiell nicht berufen könnte. Die Annahme eines gestuften Schutzes würde daher zu einer faktisch gestuften Menschenwürde führen, was jedoch mit Art. 1 I 1 GG und dessen Bedeutung nicht vereinbar ist. Drastisch gesprochen: „(...) die nur bedingte Anerkennung der Menschenwürde

<sup>543</sup> Herdegen, JZ 2001, 773 (774); Hufen, JZ 2004, 313 (315).

<sup>544</sup> Jerouschek, JZ 1989, 279 (284).

<sup>545</sup> Herdegen, JZ 2001, 773 (774); Hufen, JZ 2004, 313 (315).

<sup>546</sup> Enquete-Kommission „Recht und Ethik“, S. 106.

<sup>547</sup> Heun, Menschenwürde und Lebensrecht als Maßstäbe für PID?, S. 107.

<sup>548</sup> Stein, DZPhil 50, 855 (867).



[trägt] *bereits den Keim ihrer völligen Erosion in sich.*<sup>549</sup> Dieser Ansatz wird daher verworfen.

#### (6) Fazit

Wie gezeigt wurde, gelingt mit keinem der klassisch-juristischen Interpretationen des Art. 1 I 1 GG eine Ausdehnung dieser Verfassungsnorm auf die Zygote beziehungsweise den pränidativen Embryo. Hierfür bedürfte es somit eines extensiveren Ansatzes, der später zu diskutieren sein wird.

#### cc) Keimbahnmodifizierung bei Gameten

Obschon es zurzeit als praktikabler erachtet wird, Methoden des genetischen Enhancements unmittelbar nach Abschluss der Befruchtung anzuwenden, erscheint es wahrscheinlich, dass früher oder später auch die Gameten, das heißt die Ei- oder Samenzellen, Objekt genetischer Modifizierungen werden können. Entsprechend wird teilweise befürwortet, dass der Schutzbereich des Art. 1 I 1 GG auch Eizellen umfassen soll, die nach ihrer genetischen Modifizierung befruchtet werden.

Derlei Vorschläge sind jedoch auf deutliche Kritik gestoßen. Nicht nur bestünde, folgte man ihnen, weiterhin die Möglichkeit des verändernden gentechnischen Eingriffs in Samenzellen. Vielmehr würde die Zuschreibung von Menschenwürde allzu umfangreiche Schutzmaßnahmen erforderlich machen. Betrachtet man die große Anzahl von Eizellen, die über die fertile Lebenszeit einer Frau produziert werden, erscheint diese Konsequenz als unmöglich erfüllbar.<sup>550</sup>

Widerspricht zudem die Entstehungsgeschichte des deutschen Grundgesetzes schon der Anwendung des Menschenwürdesatzes auf pränidatives Leben, so muss dies *a fortiori* auch für Gameten gelten. Hiernach bezieht sich, wie schon oben ausgeführt, die Menschenwürde ausschließlich auf Personen, die schon geboren wurden, da Stoßrichtung die Vermeidung von Folter, Demütigung und Stigmatisierung oder einer Behandlung wie Tiere oder „Untermenschen“ war und zu diesem Zweck an ungeborenes Leben nicht gedacht war.<sup>551</sup> Die im Grundgesetz enthaltenen Grundrechte stellen hiernach und auch ihrer traditionellen Interpretation entsprechend negative Rechte dar, die dem Individuum Freiheit von staatlichen Eingriffen gewähren.<sup>552</sup>

Entgegen anderer Auffassung führen auch die oben diskutierten Kontinuitäts-, Potentialitäts- und Identitätsargumente zu keiner anderen Erkenntnis, letzteres schon aus den bereits genannten Gründen nicht. Auch die beiden anderen Thesen in weiterer Ausdehnung kritisch analysierend und schließlich den Grundrechtsstatus des Embryos verneinend, das heißt im Ergebnis zwar richtig, in der dahin führenden

<sup>549</sup> Stein, DZPhil 50, 855 (866).

<sup>550</sup> Spiekerkötter, Verfassungsfragen der Humangenetik, S. 91.

<sup>551</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 82.

<sup>552</sup> Pieroth/Schlink, Grundrechte, § 4 I 2 Rdnr. 76.



Argumentation zeitweilig jedoch wenig überzeugend führt etwa *Heun*<sup>553</sup> aus, dass man über diese Argumente konsequenterweise gar zu einer Ausdehnung der Menschenwürde auf die einzelne Ei- oder Samenzelle gelangen müsse. *Heun* sieht die Kontinuität über die gesamte Dauer von der Entstehung der Ei- oder Samenzelle bis über den Herz- oder Hirntod hinaus, mit dem noch nicht sämtliche Lebensprozesse beendet sind, gewahrt. Ebenso weisen auch die einzelne Ei- oder Samenzelle Potentialität auf, die durch deren Fusion nicht gesteigert würde, da lediglich die größere Wahrscheinlichkeit der späteren Entstehung eines bestimmten Menschen kein geeignetes Abgrenzungskriterium sei.

Dem kann so jedoch nicht zugestimmt werden. Freilich ist der Entwicklungsprozess von der Gamete über die Zygote und den Embryo hin zu einem geborenen Menschen ein kontinuierlicher. Ebenso vermögen sich beide zu einem solchen Menschen zu entwickeln. Dies gilt nichtsdestoweniger lediglich unter der Voraussetzung des Hinzutretens bestimmter Voraussetzungen wie dem Eintreten der Fertilisation, dem Vorliegen entsprechender, die weitere Entwicklung fördernder äußerer Umstände oder der Nidation. Diese Voraussetzungen treten jedoch nur bei einer geringen Zahl der während der fertilen Phase eines Menschenlebens produzierten Ei- und Samenzellen hinzu; ihre ganz überwiegende Mehrheit wird nicht zur Fortpflanzung beitragen. Betrachtet man jedoch schon die Logik der Kontinuität oder der Potentialität, so ist ein Entwicklungsziel schon Begriffsnotwendigkeit. Beidem liegt der Blick auf ein bestimmtes Ziel, welches über eine Verknüpfung fortschreitender Stadien zu erreichen das betreffende Objekt gerade in der Lage ist, zugrunde. Von einer solchen Verbindung kann aber bei einer bloßen Ei- oder Samenzelle nicht ausgegangen werden, weil die hierzu erforderlichen Zwischenschritte zu wesentlich sind und nicht aus der einzelnen Gamete selbst generiert werden können, sondern externe Faktoren darstellen. Insofern ist das Potential zur Weiterentwicklung kein nur aus den Merkmalen der jeweiligen separaten Gamete resultierendes. Da es nur aktualisiert werden kann, sofern bestimmte weitere Umstände hinzutreten, ist es durchaus gerechtfertigt, die Wahrscheinlichkeit des Eintrittes dieser Umstände in die Bewertung der Potentialität mit einzubeziehen. Dass sich jedoch aus einem konkreten Ovum und einem konkreten Spermium ein Individuum entwickelt, welchem unbestrittenermaßen Menschenwürde zuzuerkennen ist, ist grob unwahrscheinlich. Im Hinblick auf die konkrete Gamete ist die Potentialität im Sinne einer realistischen Chance nahezu verschwindend gering. Diese empirischen Annahmen mögen zwar differieren in Abhängigkeit davon, ob eine zielgerichtete In-vitro-Fertilisation erfolgt oder der natürliche und im Vergleich mit der künstlichen Befruchtung geradezu verschwenderische<sup>554</sup> Fortpflanzungsprozess abläuft. Eine normative Differenzierung von Gameten im Verfahren der In-vitro-Fertilisation und solchen sich im natürlichen Fortpflanzungsprozess befindlichen im Hinblick auf die Trägerschaft

<sup>553</sup> *Heun*, JZ 2002, 517 (520 f.).

<sup>554</sup> Es wird bei Weitem nicht jede produzierte Eizelle befruchtet, geschweige denn, dass auch nur ein signifikanter Anteil der Spermien zur Befruchtung beitragen würde. In der Vornidationsphase betreibt die Natur einen beinahe verschwenderischen Umgang mit befruchteten Eizellen; ein erheblicher Teil gelangt nie zur Nidation, sondern geht mit der nächsten Monatsblutung ab.

der Menschenwürde lässt sich überzeugend jedoch nicht begründen. Der Anwendungsbereich des Art. 1 I GG kann somit weder mittels des Potentialitäts-, noch des Kontinuitätsarguments eröffnet werden.

Doch selbst wenn man annähme, dass menschlichem Leben in jeglichem, auch noch so frühem Stadium seiner Entwicklung Menschenwürde zuzusprechen ist, bedürfte es doch stets auch eines konkreten Würdeträgers, namentlich einer Person, die sich aus der vorliegenden Zygote oder Zellansammlung entwickeln wird. Grundrechtsgarantien beziehen sich stets auf nur auf einen bereits, zumindest embryonal, vorhandenen Menschen.<sup>555</sup> Zwar mag ein etwaiger moralischer, weder Rechtspflichten noch Rechte im Sinne juristisch durchsetzbarer Interessen begründender Status auch einem in diesem engen Sinne individualisierten Wesen zugesprochen werden. Da Grundrechtsstatus aber immer nur einer Individualperson zukommt, folgt daraus, dass, um Grundrechtsschutz zuordnen zu können, individuelles und identisch bleibendes Leben bestehen muss.<sup>556</sup> Freilich sind sowohl Ei- als auch Samenzelle für die Entstehung neuen menschlichen Lebens eine notwendige Voraussetzung. Dennoch folgt hieraus nicht, dass schon die separate Eizelle oder die separate Samenzelle jeweils für sich betrachtet (neues) menschliches Leben ausmacht. Dies wird deutlich, wenn man andere Arten von im menschlichen Körper vorkommenden Zellen bedenkt:<sup>557</sup> Auch die einzelne Hautzelle ist Teil des Menschen, aber niemand käme wohl auf die Idee, eine solche als neues menschliches Leben zu bezeichnen, wenn sie vom Körper getrennt wird,<sup>558</sup> beziehungsweise eine einzelne Haut- oder auch sonstige Zelle, selbst wenn man diese als menschliches Leben klassifizieren wollte, grundrechtlich zu schützen.<sup>559</sup> Dies wäre schon angesichts der großen Zahl von Hautschuppen, die der Mensch täglich verliert und die jeweils aus mehreren hundert Zellen bestehen können, auch praktisch vollkommen sinnlos. Die bloße Tatsache, dass sich aus einer Ei- und eine Samenzelle gemeinsam unter bestimmten Voraussetzungen neues menschliches Leben entwickeln mag, begründet außerdem zumindest mittlerweile keinen exklusiven Status dieser Zellen mehr, ist es doch gelungen, aus somatischen Zellen durch künstliche Reprogrammierung sogenannte induzierte pluripotente Stammzellen herzustellen, von denen vermutet wird, dass sie ebenso wie Gameten reproduktive Funktionen erfüllen können. Hier eine Unterscheidung zu treffen ist somit hinfällig geworden. Was aber für vom Körper getrennte somatische Zellen gilt, muss dann auch für Gameten gelten, die demzufolge keine tauglichen Träger der Menschenwürde mehr sind. Der persönliche Schutzbereich des Art. 1 I 1 GG ist mit Blick auf diese folglich nicht eröffnet.

<sup>555</sup> Grimm, NJW 1989, 1305 (1310).

<sup>556</sup> Heun, JZ 2002, 517 (521).

<sup>557</sup> Ähnlich Zippelius in Bonner Kommentar zum GG, Art. 1 Abs. 1 u. 2, Rdnr. 51.

<sup>558</sup> Dies trifft zumindest auf unangetastete und unveränderte somatische Zellen zu. Allerdings mag man zu einem unterschiedlichen Ergebnis kommen, wenn man induzierte pluripotente Stammzellen (iPS-Zellen), die aus nicht mehr pluripotenten Zellen wie somatischen Zellen gewonnen werden können, betrachtet. Dies soll vorliegend jedoch nicht Gegenstand der weiteren Analyse sein.

<sup>559</sup> Heun, JZ 2002, 517 (519); Hofmann, JZ 1986, 253 (259).

## dd) Zwischenergebnis

Es wurde gezeigt, dass zwar der geborene Mensch, dessen somatische Zellen modifiziert werden, vom personalen Schutzbereich des Art. 1 I 1 GG umfasst ist, dass aber weder die Zygote noch die einzelne Gamete Würdeträger im Sinne dieser Verfassungsnorm sein können. Hinsichtlich letzterer scheidet somit eine Verletzung der Menschenwürde durch Verfahren des genetischen Enhancements schon mangels Eröffnung ihres persönlichen Schutzbereiches aus. Im Folgenden bleibt nun jedoch zu fragen, ob mit Blick auf die verbessernde somatische Genmanipulation auch der sachliche Schutzbereich des Art. 1 I 1 GG betroffen ist.

## c) Eingriff in die Menschenwürde durch genetisches Enhancement

Art. 1 I 1 GG erklärt die Menschenwürde für unantastbar. Gemäß Art. 1 I 2 GG darf sie auch nicht durch Gesetz, ausweislich des Wortlautes des Art. 79 III GG noch nicht einmal durch verfassungsänderndes Gesetz, berührt werden. Notwendigerweise ist die Äußerung von der Unantastbarkeit der Menschenwürde eine präskriptive und keine deskriptive, eine Nichtachtung der Würde lässt die Integrität der jeweiligen Person unberührt: Verletzt werden kann nur der Achtungsanspruch eines jeden Menschen, die Würde selbst bleibt jedoch bestehen.<sup>560</sup>

Aus der Unantastbarkeit der Menschenwürde folgt weiterhin ein kategorisch wirkendes Verletzungsverbot, demzufolge im Gegensatz zu anderen Grundrechten bei Beeinträchtigungen der Menschenwürde keinerlei Raum für rechtfertigende Güterabwägungen, auch nicht im Sinne von verfassungsimmanenten Schranken, besteht. Der ansonsten übliche Mechanismus, wonach Eingriffe in den Schutzbereich von Rechten auch von Verfassungsrang nicht *per se* deren Verletzung darstellen müssen, sondern verfassungsrechtlich gerechtfertigt werden können, greift im Hinblick auf Art. 1 I 1 GG nicht. Die Menschenwürde ist vielmehr unabwägbar; ihre Gewährleistung ist eine absolute. Daher liegt nach ganz herrschender Meinung in jeder Beeinträchtigung ihres Schutzbereiches auch immer ihre Verletzung:<sup>561</sup> „*Gewährleistungsbereich und Verletzungsgrenze der Würde-Norm sind identisch.*“<sup>562</sup>

<sup>560</sup> BVerfGE 87, 208 (228); 115, 118 (152); von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 33; Maunz/Dürig-Herdeggen, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 73; Dreier-Dreier, GG, Art. 1 Rdnr. 131; Wetz, ARSP 87 (2001), 311 (319).

<sup>561</sup> Siehe beispielsweise nur BVerfGE 75, 369 (380); Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 44, 132; Dreier, Bioethik zwischen gesellschaftlicher Pluralität und staatlicher Neutralität, S. 14 f.; Epping/Hillgruber-Hillgruber, GG, Art. 1 Rdnr. 10; Jarass/Pieroth, GG, Art. 1 Rdnr. 16; von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 34; Sachs-Höfling, GG, Art. 1 Rdnr. 11; Geddert-Steinacher, Menschenwürde als Verfassungsbegriff, S. 81 ff.; Thomas, ARSP 87 (2001), 299 (301); Schmidt-Jortzig, DÖV 2001, 925 (926, 931); Classen, DVBl 2002, 141 (144); Heun, JZ 2002, 517 (518); Hörnle, ARSP 89 (2003), 318 (320, 337 f.); Wittreck, DÖV 2003, 873 (874, 877 f.); für verfassungsimmanente Schranken auch der Menschenwürde hingegen argumentierend Kloepfer, Leben und Würde des Menschen, S. 97 f.

<sup>562</sup> Geddert-Steinacher, Menschenwürde als Verfassungsbegriff, S. 83; kritisch dieser Gleichsetzung von Eingriff in den Schutzbereich und Würdeverletzung gegenüber aufgrund ihres geringen heuristischen Wertes Maunz/Dürig-Herdeggen, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 73: Erforderlich bleibe eine Konkretisierung des Achtungsanspruches, da erst die präzisierte Würde auch absolute Geltung habe.

Dies gilt selbst in Fällen, in denen der Würdeträger auf diese zu verzichten wünscht, denn Würde ist weder verwirkbar noch verzichtbar. Jedoch ist in diesem Zusammenhang relevant, dass ein zentraler Aspekt der Menschenwürde auch die Autonomie des Einzelnen ist, somit die Entscheidung, was seiner Würde entspricht, vom Einzelnen selbst in Abhängigkeit dessen, wie er sich in seiner Individualität selbst begreift, getroffen werden kann und adäquate Berücksichtigung bei der Beantwortung der Frage nach dem Vorliegen einer Würdeverletzung finden muss.<sup>563</sup>

Schließlich bezieht sich der umfassende Schutz des Art. 1 I 1 GG nicht nur auf das Verhältnis zwischen einer Person und der Staatsgewalt, die Unantastbarkeit der Menschenwürde gilt auch Dritten gegenüber.<sup>564</sup> Als Richtschnur für die Normauslegung oder die Auffüllung von Gesetzeslücken gestaltet sie im Wege einer mittelbaren Drittwirkung so auch private Rechtsverhältnisse aus, etwa bei der Frage, ob ein Rechtsgeschäft gegen die guten Sitten verstößt und daher gemäß § 138 I BGB nichtig ist oder eine Vertragserfüllung wegen des ihr inhärenten Menschenwürdeverstoßes unzumutbar und daher nach Treu und Glauben im Sinne von § 242 BGB abzulehnen ist.<sup>565</sup> Da der Schutz über eine nur mittelbare Drittwirkung unzureichend ist, ist allgemeine Auffassung, dass die Verfassungsnorm des Art. 1 I 1 GG nicht nur dem staatlichen Akteur Bürden auferlegt, sondern auch im Verhältnis der Bürger untereinander gilt.<sup>566</sup> Dies ergibt schon die Entstehungsgeschichte<sup>567</sup> der Norm und auch das Bundesverfassungsgericht führt aus: *„Eine Verfassung, welche die Würde des Menschen in den Mittelpunkt ihres Wertsystems stellt, kann bei der Ordnung zwischenmenschlicher Beziehungen grundsätzlich niemandem Rechte an der Person eines anderen einräumen, die nicht zugleich pflichtgebunden sind und die Menschenwürde des anderen respektieren.“*<sup>568</sup>

Hierfür spricht auch die Unterscheidung zwischen der Deklaration ihrer allgemeinen und jedermann gegenüber geltenden Unantastbarkeit in Satz 1 des Art. 1 I GG und der Verpflichtung konkret des Staates auf ihren Schutz und die Achtung ihrer in Satz 2.<sup>569</sup>

<sup>563</sup> Zippelius in Bonner Kommentar zum GG, Art. 1 Abs. 1 u. 2, Rdnr. 39; vergleiche auch BVerfGE 49, 286 (298).

<sup>564</sup> BVerfGE 24, 119 (144); von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 33.

<sup>565</sup> Zippelius in Bonner Kommentar zum GG, Art. 1 Abs. 1 u. 2 Rdnr. 36; vergleiche auch Merkel, Forschungsobjekt Embryo, S. 37.

<sup>566</sup> Zippelius in Bonner Kommentar zum GG, Art. 1 Abs. 1 u. 2 Rdnr. 34 f.; Epping/Hillgruber-Hillgruber, GG, Art. 1 Rdnr. 8; Maunz/Dürig-Herdeggen, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 74; von Münch/Kunig-Kunig, GG, Art. 1 Rdnr. 27.

<sup>567</sup> Süsterhenn führte in der 32. Sitzung des Ausschusses für Grundsatzfragen vom 11.01.1949 aus, Art. 1 I 1 GG sei eine *„absolute Feststellung, die sich gegen jedermann wendet, sowohl gegen die staatliche Gewalt wie auch gegen jeden Privaten und gegen jede Institution“*, von Doemming/Füsslein/Matz, JöR 1 (1951), 51.

<sup>568</sup> BVerfGE 24, 119 (144).

<sup>569</sup> von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 33; von Münch/Kunig-Kunig, GG, Art. 1 Rdnr. 27.

Mit Blick auf Techniken des genetischen Enhancements stellt sich nunmehr die Frage, ob, nachdem die Eröffnung des persönlichen Schutzbereiches im Falle von verbessernden Eingriffen in somatische Zellen festgestellt wurde, auch der sachliche Schutzbereich des Art. 1 I 1 GG betroffen, die Menschenwürde des jeweiligen Patienten also verletzt ist. Nichtsdestoweniger sollen hier auch solche Erwägungen angestellt werden, die grundsätzlicher Natur sind und daher ebenfalls Fälle des Keimbahn-Enhancements betreffen, würde man anders in vorliegender Arbeit von der Grundrechtsträgerschaft von Gameten beziehungsweise der Zygote ausgehen.

#### aa) Objektformel

Nach der oben beschriebenen Objektformel liegt eine Verletzung des Art. 1 I GG dann vor, wenn der konkrete Mensch zum Objekt, einem bloßen Mittel oder zu einer vertretbaren Größe herabgewürdigt oder er zum bloßen Objekt des Staates (oder, wie oben bereits gezeigt, eines Dritten) gemacht wird, was zu bejahren ist, sofern seine Subjektqualität in Frage gestellt wird,<sup>570</sup> etwa weil *„die Behandlung durch die öffentliche Gewalt [oder durch Dritte] die Achtung des Wertes vermissen lässt, der jedem Menschen um seiner selbst willen zukommt.“*<sup>571</sup> *„Schlechthin verboten ist damit jede Behandlung des Menschen durch die öffentliche Gewalt, die dessen Subjektqualität, seinen Status als Rechtssubjekt, grundsätzlich in Frage stellt, indem sie die Achtung des Wertes vermissen lässt, der jedem Menschen um seiner selbst willen, kraft seines Personseins, zukommt.“*<sup>572</sup> Zu beurteilen ist dies immer nur bezogen auf die jeweilige Entscheidungssituation und den konkreten Lebenssachverhalt, sodass auch in spezifischen Unterordnungs- oder Abhängigkeitsverhältnissen der Subjektstatus des Individuums noch durch etwaige Kompensationsmechanismen gesichert sein kann.<sup>573</sup>

Im Falle der Gentherapie an Somazellen ist konsentiert Meinung, dass Art. 1 I GG zu keinerlei besonderen Bewertungsproblemen führt,<sup>574</sup> beispielsweise weil, ohne dass es dabei zu einer vollständigen Entkopplung beider Verfassungsnormen kommen würde, Art. 1 I GG gegenüber Art. 2 II GG als subsidiär zurück-

<sup>570</sup> Dürig, AöR 81 (1956), 117 (127); Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 53; Epping/Hillgruber-Hillgruber, GG, Art. 1 Rdnr. 13; Jarass/Pieroth, GG, Art. 1 Rdnr. 7; Maunz/Dürig-Herdegen, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 36; von Münch/Kunig-Kunig, GG, Art. 1 Rdnr. 22; Sachs-Höfling, GG, Art. 1 Rdnr. 15 f.; Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf-Hofmann, GG, Art. 1 Rdnr. 7; Laufß, NJW 2000, 2716 (2717), Ergänzungen Welling.

<sup>571</sup> BVerfGE 109, 279 (313), Ergänzungen Welling.

<sup>572</sup> BVerfGE 115, 118 (153).

<sup>573</sup> BVerfGE 109, 279 (311 f.); Sachs-Höfling, GG, Art. 1 Rdnr. 16.

<sup>574</sup> Maunz/Dürig-Herdegen, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 108; Sachs-Höfling, GG, Art. 1 Rdnr. 29; Isensee/Kirchhof-Häberle, HStR I, § 20 Rdnr. 91; Neumann, Die Menschenwürde als Menschenbürde, S. 42; Benda, NJW 1985, 1730 (1733).

tritt.<sup>575</sup> Bereits aufgrund der Autonomiebetonung der Menschenwürde kann schon begrifflich nicht von einer Gen-Manipulation gesprochen werden, ist der in den gentechnologischen Eingriff einwilligende Patient doch gerade der sich bewusst dafür entschieden habende Initiator.<sup>576</sup> Eine Instrumentalisierung ist bereits dem gängigen Wortverständnis zufolge nur im Hinblick auf andere Personen, nicht aber im Hinblick auf sich selbst und gleichzeitig auch durch sich selbst möglich. Gleiche Überlegungen tragen auch im Rahmen genetischer Enhancements an somatischen Zellen. Hierbei ist aber dennoch zu berücksichtigen, dass aktuell immense Risiken bei der Durchführung von Enhancements drohen, die selbständig im Rahmen des Art. 2 II GG diskutiert werden, die jedoch auch zur Feststellung einer etwaigen Entwürdigung heranzuziehen sind. Solange die erforderlichen Techniken nicht hinreichend sicher sind, ist somatisches Enhancement nicht nur – so viel sei bereits hier vorweggenommen, aber später noch näher zu erörtern – aufgrund der staatlichen Schutzpflicht aus Art. 2 II GG verboten, sondern stellt, wäre es eher ein Frankenstein-Experiment oder mit dem russischen Roulette vergleichbar, eine Entwürdigung dar.

Keimbahneingriffe, auch solche therapeutischer Art, hingegen treffen auch abseits bloßer Risikoerwägungen auf einige deutliche Vorbehalte. Wenn auch zumeist im Kontext der Menschenwürde<sup>577</sup>, so wird doch pauschal von verfassungsrechtlichen Bedenken gesprochen, die damit begründet werden, dass die Keimbahntherapie bei Ei-, Samen- und deren Vorläuferzellen ansetzt und somit intergenerative Implikationen hat sowie Menschenzüchtungen befürchten lässt<sup>578</sup> – eine Feststellung die eine dezidierte Auseinandersetzung mit und juristische Analyse anhand von Art. 1 I GG oder anderen Verfassungsnormen weiterhin als Desiderat zurücklässt. Höfling beispielsweise distinguert hingegen zwischen „negative[r] (kurative[r], präventive[r]) Eugenik“, die er als schwerlich menschenwürde verletzend einstuft, und „positive[r] (meliorative[r]) Eugenik“, eines „optimierenden Zugriff[s] auf die Gattung Mensch“, dem gegenüber sich „Art. 1 I als letzte und unübersteigbare Hürde [...] erweisen“ könne.<sup>579</sup> Ähnlich referiert Zippelius Meinungen, denen zufolge bei der genetischen Veränderung menschlicher Keimbahnzellen entweder die Menschenwürde des Keimes oder abstrakt die der Menschheit betroffen sei und die den Vorwurf einer Hybris, des Ausbruchs des Menschen aus seiner Rolle als Geschöpf und seinem biologisch präskribierten Schicksal auf sich zögen.<sup>580</sup> Freilich werfen

<sup>575</sup> Sachs-Höfling, GG, Art. 1 Rdnr. 29, 67.

<sup>576</sup> Vergleiche Neumann, Die Menschenwürde als Menschenbürde, S. 46; Neumann, Die Tyrannei der Würde, S. 156.

<sup>577</sup> Vergleiche etwa Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 107; Maunz/Dürig-Herdegen, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 108; Neumann, Die Menschenwürde als Menschenbürde, S. 42; anscheinend, da von einem Tabu, also einem absoluten Verbot, wie es nur durch die Menschenwürde generiert werden kann, sprechend, auch Kaufmann, Der entfesselte Prometheus, S. 274; Benda, NJW 1985, 1730 (1733); Isensee/Kirchhof-Häberle, HStR I, § 20 Rdnr. 92; Hofmann, JZ 1986, 253 (259 ff.); Arbeitsgruppe „In-vitro-Fertilisation“, S. 46.

<sup>578</sup> Sachs-Höfling, GG, Art. 1 Rdnr. 30; Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf-Hofmann, GG, Art. 1 Rdnr. 34.

<sup>579</sup> Sachs-Höfling, GG, Art. 1 Rdnr. 30.

<sup>580</sup> Zippelius in Bonner Kommentar zum GG, Art. 1 Abs. 1 u. 2 Rdnr. 78.



diese Formulierungen weitere Fragen auf, etwa inwieweit der Mensch als Gattungswesen, also die Gattung selbst, bestimmte Vorstellung von der menschlichen Gattung oder zentrale gattungstypische Charakteristika Schutzgut des Art. 1 I 1 GG sind. Dieser Frage soll hier jedoch noch nicht nachgegangen werden.<sup>581</sup>

Starck proklamiert, das verfassungsrechtliche Hauptproblem der Genterapie liege darin, dass mit der Erlangung der dazu erforderlichen Fähigkeiten gleichzeitig auch die Möglichkeit zu einer „positive[n] Eugenik“ eröffnet werde, welche wertungsmäßig nicht mehr im Rahmen der typisch ärztlichen Tätigkeit liege, sich hiervon im Einzelfall aber nur schwerlich abgrenzen ließe. „Positive eugenische Eingriffe“ jedoch stellten eine Menschenzüchtung dar, „die die totale Herrschaft des Genchirurgen oder seines Auftraggebers über den Menschen bedeuten würde.“ Das Resultat, zu dem Starck gelangt, lautet somit: „Menschenzüchtung widerstreitet der Menschenwürde.“<sup>582</sup> Nicht weiter ausgeführt wird in diesem Zusammenhang jedoch, was im Hinblick auf die vorzunehmende Wertung der ausschlaggebende Unterschied zwischen einer auch im, so Starck, „frühesten Stadium der Menschwerdung“<sup>583</sup> ansetzenden Genveränderung ist, die eine Erbkrankheit unterdrückt beziehungsweise beseitigt, und einer solchen, die nicht therapeutisch, sondern verbessernd wirkt. Anknüpfungspunkt für die Kritik ist anscheinend die Unabänderlichkeit genetischer Interventionen, die genetische Festlegung der Person, auch der sich im Entstehen befindlichen, von der diese sich nicht befreien kann, mögen die ihr zugewiesenen genetischen Merkmale ihren Vorstellungen auch widersprechen. Diese Konstellation ist jedoch unabhängig vom Vorliegen eines pathologischen Zustandes. Dem genetisch pathologischen menschlichen Lebewesen wird im Rahmen eines gentherapeutischen Eingriffes ein neues Genom ebenso zugewiesen wie dem pathologisch unauffälligen, an dem ein genetisches Enhancement vorgenommen wird. In letztgenanntem Fall auf einmal soll es sich jedoch um eine Form totaler Herrschaft handeln, die eine Würdeverletzung konstituiert. Dieselbe Handlung, also die Veränderung der genetischen Ausstattung, soll, so scheint Starck zu werten, also in dem einen Fall verfassungsrechtlich unbedenklich sein, im anderen aber gleich gegen den Höchstwert des Grundgesetzes verstoßen. Der distinguierende Faktor soll somit ein Krankheitsbefund sein: Handelt der Gentechniker entsprechend dem klassischen Rollenverständnis des heilenden, maximal Prävention betreibenden Arztes – welches mittlerweile ohnehin zumindest kritisch zu hinterfragen wäre – ist Art. 1 I GG nicht verletzt. Eine derartige Konnexion von Menschenwürde und Art. 6 I GG erscheint jedoch fraglich und weiterhin begründungsbedürftig.

Es bleibt mithin zu untersuchen, welcher Umstand ausschlaggebend für diese unterschiedlichen Wertungen ist. Konkret geht es also um die Frage, welcher

<sup>581</sup> Zippelius in Bonner Kommentar zum GG, Art. 1 Abs. 1 u. 2 Rdnr. 55 beispielsweise plädiert für die Beschränkung des personalen Schutzbereiches des Art. 1 I GG auf konkrete Menschen. Die Würde der Menschheit im Sinne eines normativen gedachten Bildes des Menschen sei hiervon nicht umfasst.

<sup>582</sup> von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 101 m.w.N.

<sup>583</sup> von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 101, gemeint ist bei Starck der Zeitpunkt nach der Befruchtung der Eizelle, das heißt Genveränderungen bei der Zygote.



Umstand die Herabwertung zum Objekt konstituiert, die Infragestellung seiner Subjektqualität manifestiert und die Achtung des Wertes des Menschen um seiner selbst willen vermissen lässt, welche Eigenschaft genetischer Veränderungen beim Menschen diesen zum Gegenstand von Demütigung, Verächtlichmachung, Brandmarkung oder Stigmatisierung macht. Was konstituiert den instrumentalisierenden Charakter von Genmodifikationen und zwar in einem angeblich höheren Maße, wenn seine Keimbahnzellen betroffen sind, als wenn Eingriffsobjekt somatische Zellen wären, sowie wenn der Eingriff verbessernden Absichten anstelle von therapeutischen entspricht?

Im Hinblick auf das Individuum, dem die in Art. 1 I GG verbürgte Menschenwürde zukommt, wird zum Teil vorgebracht, dass jegliche Art der Veränderung des Genoms eine Verletzung der Würde des betreffenden Menschen ist, weil die Hin- nahme der „*Kontingenz genetischer Kombination*“ ein dieser Würde zugehöriges, aber entsprechend missachtetes Gebot ist.<sup>584</sup> Garantiegehalt der Menschenwürde- norm sei, so wird behauptet, auch ein „*Recht auf Zufall*“ oder auf „*vom Menschen unberührte Faktizität*“, gar Schicksal.<sup>585</sup> Die Freiheit des Menschen beruhe auch darauf, dass ihm seine Eigenschaften und Anlagen nicht durch andere Menschen zugeteilt würden. Andernfalls wäre seine Selbstachtung gefährdet sowie das Selbst- Verständnis als ein Wesen der Gattung Mensch.<sup>586</sup> Auch die *Enquete-Kommission „Chancen und Risiken der Gentechnik“* geht davon aus, dass sich seine Mensch- lichkeit auf dem natürlichen Werden mit seiner Geburtlichkeit und Naturwüchsig- keit gründet.<sup>587</sup>

Diese Präsuppositionen sind jedoch einigen kritischen Überlegungen zu unter- ziehen. Zunächst einmal stellt sich, soll es für die Eigenschaft des Trägers von Men- schenwürde auf die Natürlichkeit oder Unangetastetheit der in Existenz gelangen- den Entitäten ankommen, die Frage nach dem distinguierenden Faktor zwischen Menschen und anderen Wesen, deren genetische Disposition zwar auch kontingent und in dem Sinne naturwüchsig ist, die aber schon dem ursprünglichen Begriffsver- ständnis zufolge nie als Menschenwürdeträger in Betracht kommen würden. Die oben referierten Grundannahmen tragen zu einer Differenzierung nicht weiter bei.

Die Tatsache, dass die genetische Kontingenz ebenso gut zu defekten Gen- konstellationen führen kann, würde weiterhin bedeuten, dass, wenn man die pos- tulierte Unverfügbarkeit ernst nimmt und konsequent umsetzt, ebenso genetische Aberrationen als unabänderlich zu klassifizieren seien, weil die Weitergabe von fehlerhaften Genkombinationen ein Gebot der Menschenwürde wäre. *Dreier* kri- tisiert die hieraus resultierende „*Inhumanität einer blinden Genfixierung*“. Ebenso wenig wie es einen Anspruch auf eine bestimmte, jedenfalls aber gesunde geni-

<sup>584</sup> *Isensee*, Die alten Grundrechte und die biotechnische Revolution, S. 261 f.; *Dreier-Dreier*, GG, Art. 1 I Rdnr. 107.

<sup>585</sup> *Baumgartner*, MedEthik 39 (1993), 257 (259).

<sup>586</sup> *Hofmann*, JZ 1986, 253 (260).

<sup>587</sup> *Enquete-Kommission „Chancen und Risiken“*, S. 187; kritisch hingegen *Honnfelder*, Human- genetik und Menschenwürde.

sche Disposition gäbe, da andernfalls schon der menschliche Zeugungsakt mit all seiner Kontingenz und Prädetermination ein Paradebeispiel für Fremdbestimmung und Menschenwürdeverletzung sein müsse, gehöre schweres Leid zum unveräußerlichen Bestand einer personalen Identität oder zur unverfügbaren Menschenwürde.<sup>588</sup> Mit der allgemein geteilten Auffassung, die Menschenwürde diene der Wahrung vernünftiger Selbstbestimmung, ist die oben ausgeführte These ohnehin kaum vereinbar. Der Schutz der „*nackte[n] Faktizität des Schicksals*“ steht (auch und gerade in bioethischen Kontexten) in eklatantem Widerspruch zur vernünftigen Selbstbestimmung.<sup>589</sup> Auch *Herdegen* erachtet einen hieraus folgenden und durch Art. 1 I GG gewährleisteten Bestandsschutz von Erbkrankheiten als „*nicht nachvollziehbar*“.<sup>590</sup> Ebenso möchte *Hofmann*, obschon er zuvor postuliert, es dürfe nichts unternommen werden, was den konkreten Menschen daran hindere, die Kontingenz ihrer Körperlichkeit als Moment ihrer Individualität zu kultivieren und sich so als Gattungswesen Mensch zu begreifen, von diesem zunächst absoluten Ausschluss jeglichen Eingriffs in das Genom insofern eine Ausnahme machen, als dass schwere Erbleiden zu einem erheblichen Leidensdruck führten. Alles andere wäre gar unmenschlich.<sup>591</sup> Warum jedoch eine derartige, nämlich therapeutische Zuweisung eines Genoms einen wertungsmäßig so eklatanten Unterschied macht, wird jedoch nicht weiter beleuchtet. Krankheiten sind stets auch Teil der Persönlichkeit und Individualität, stellen aber nicht deren konstituierenden Faktor dar. Diese können vielmehr und gerade auch durch einen therapeutischen oder verbessernden Eingriff gefördert werden, wenn dieser der betreffenden Person erst ermöglicht, sich entsprechend zu entfalten.

Der Rekurs auf die Erkenntnis, das Genom des individuellen Menschen sei kontingent und – mit welcher weiteren Begründung auch immer – unverfügbar, führt mithin zu keiner zufriedenstellenden Diagnose im Lichte einer klassischen, auf das Individuum bezogenen Anwendung des Art. 1 I GG.

Eine ähnliche Stoßrichtung weist das Vorbringen auf, der Eingriff in das menschliche Erbgut und dessen irreversible Veränderung verletze ein Recht des Individuums auf eine naturbelassene genetische Identität. Anknüpfungspunkt dieser These soll eine Modifizierung der Erbsubstanz sein, die sich erst bei einem künftigen Individuum auswirkt. *Flämig* etwa konstatiert, der „*Eingriff in das Erbgut des Menschen*“ sei „*ein Eingriff in die Natur des Menschen; dieser Eingriff negiert dessen menschliche Natur, zu der aber seine Würde gehört*“.<sup>592</sup> Jedoch stellt genau dies wiederum Anlass zur Kritik dar. Ein Recht auf ein bestimmtes Genom, eine bestimmte genetische Identität des künftigen Individuums ist denklogisch nicht möglich. Das Individuum gelangt ausschließlich mit der durch den gentechnologischen

<sup>588</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 107 m.w.N.

<sup>589</sup> Werner, Menschenwürde in der bioethischen Debatte, S. 216.

<sup>590</sup> Maunz/Dürig-Herdegen, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 108.

<sup>591</sup> Hofmann, JZ 1986, 253 (260).

<sup>592</sup> Flämig, Die genetische Manipulation des Menschen, S. 57.

Eingriff geprägten Identität in Existenz.<sup>593</sup> Eine andere Identität, worauf sein etwaiges Recht verletzt werden könnte, hat es nie besessen. Das Individuum ist verknüpft mit seinem gestalteten Genom, ohne das es als solches, als dasjenige konkrete Individuum nicht existieren würde; hätte es ein anderes Genom, wäre es ein anderes Individuum. Ein Recht auf etwas, das bei seiner Durchsetzung jedoch dazu führt, dass der Rechtsträger gar nicht erst in Existenz gelangt und sich somit nicht nur die Frage stellt, wer dieses Recht durchsetzt, sondern auch, um wessen Recht es sich tatsächlich handelt, ist logisch nicht denkbar.

Auch die Befürchtung, die genetisch modifizierte Person würde ihrer einmaligen und unverfälschten Individualität und damit ihrer Fähigkeit, eine eigene Identität entwickeln zu können, beraubt werden und würde ihre Steuerungsfähigkeit ebenso einbüßen wie ein durch entsprechende Psychopharmaka manipulierter Mensch, vermag nicht zu überzeugen.<sup>594</sup> Sofern nicht der Staat die genetische Verbesserung anordnet und dabei vorschreibt, wie sie beschaffen sein muss, was aber ohnehin vorliegend nicht in Frage steht, sondern die Eltern nach ihren jeweils eigenen Vorstellungen und Präferenzen handeln, ist eine Gefahr der genetischen Gleichschaltung schon empirisch nicht gegeben. Darüber hinaus gründet dieser Einwand auf einem ebenfalls empirisch nicht belegbaren genetischen Determinismus. Die Identität einer Person, womit in diesem Zusammenhang anscheinend die über die bloße genetische Ausstattung hinausgehende, umfassende Persönlichkeit gemeint ist, wird nur zu einem geringen Teil durch genetische Faktoren bedingt. Einen größeren Anteil daran haben Umwelt- und Umfeldbedingungen der jeweiligen Person und ihre spezifische Sozialisierung. Hinzukommend lässt sich die Frage stellen, ob das betroffene Individuum nicht in der Lage wäre, sich von etwaigen genetischen Vorgaben, die ein bestimmtes Leben vorgeben sollen, zu lösen oder, wie *Habermas* es formuliert, „retroaktiv zu befreien“<sup>595</sup>. Hierauf wird aber später einzugehen sein.

Als Lösungsansatz im Rahmen einer klassischen Interpretation des Art. 1 I GG als individualschützendes Grundrecht versagen diese Thesen somit. In Frage käme lediglich die menschliche Erbmasse als solche, also das Erbgut der Menschheit und mithin diese als Schutzgut beziehungsweise Rechtsträger zu betrachten.

Zentral von Interesse scheint in diesem Zusammenhang in der Tat nicht das Individuum, sondern das menschliche Kollektiv beziehungsweise ein gewisses Bild, eine gewisse Vorstellung hiervon zu sein. So räumt *Herdegen* ein, dass eine Verletzung der Menschenwürde durch Maßnahmen der genetischen „Veredelung“ als „positive Eugenik“ oder „Menschenzüchtung“ subjektiv-rechtlich nicht konstruierbar ist, wohl aber das herkömmliche Menschenbild von natürlicher Unvollkommenheit und aleatorischer Genausstattung zu erschüttern vermöge.<sup>596</sup> *Herdegens*

<sup>593</sup> *Neumann*, Die Menschenwürde als Menschenbürde, S. 46.

<sup>594</sup> Vergleiche etwa *Graf Vitzthum*, MedR 1985, 249 (256).

<sup>595</sup> *Habermas*, Die Zukunft der menschlichen Natur, S. 107.

<sup>596</sup> *Maunz/Dürig-Herdegen*, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 109; *Lerche*, Verfassungsrechtliche Aspekte der Gentechnologie, S. 106; anders hingegen *Graf Vitzthum*, MedR 1985, 249 (256); von Münch/Kunig-Kunig, Art. 1 Rdnr. 36 Stichwort „Gentechnik“; von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 88.

Schlussfolgerung lautet daraufhin: „In der Schrankenziehung liegt eine verfassungsrechtlich schwach determinierte Gestaltungsaufgabe des Gesetzgebers.“<sup>597</sup> Die Analyse der Bedeutung des Menschenbildes im Rahmen des Art. 1 I GG soll hier jedoch zunächst einmal auf später vertagt werden.

Zur Beantwortung der Frage, welcher dem genetischen Enhancement inhärente Umstand nun konkret eine Instrumentalisierung des Menschen ausmachen soll, an dem sich die jeweilige Maßnahme auswirkt, könnte es sich als sinnvoll erweisen, den Unterschied zwischen der an *Kant* anschließenden Interpretation der Menschenwürde als Instrumentalisierungsverbot und einem naturalistischen Ansatz wie dem soeben diskutierten zu beleuchten. Während letzterer die Integrität der biologischen Basis menschlicher Existenz betont, ist mit dem Verbot der Instrumentalisierung des Menschen eher eine soziale Komponente angesprochen und maßgebliches Kriterium die soziale Bedeutung der als menschenwürdewidrig in Frage stehenden Handlung.<sup>598</sup> Am Beispiel des (reproduktiven) Klonens, aber stellvertretend für alle Eingriffe in die menschliche Erbsubstanz, die der Instrumentalisierung eines künftigen Menschen dienen, wozu er auch die Erzeugung von Menschen mit bestimmten Eigenschaften, etwa von, so sein Beispiel, gentechnisch produzierten Olympiasiegern, zählt, führt *Neumann* aus, dass es ausschließlich um die Zeugung eines Menschen mit diesem konkreten und zwar nur mit genau diesem Genom geht, weswegen dem zukünftigen Individuum auch nur ein Lebenswert zugesprochen würde, wenn es eben diese genetische Identität aufweise.<sup>599</sup> *Dederer* bezieht sich auf das therapeutische Klonen, bei dem er ein Interesse an dem Klon an sich vermisst und nur das Interesse an dessen „Verbrauchswert“ als vorliegend erkennt. Der Embryo werde alleine um der „Ersatzteillieferung“ an den Patienten willen erzeugt und zu diesem Zwecke verbraucht.<sup>600</sup> Dass zu dem Zeitpunkt der Handlung der betroffene Mensch nicht geboren geschweige denn gezeugt war, steht dem nicht entgegen, genügt es doch, wenn sich die Handlung *ante natum* einmal *post natum* auf einen Mitmenschen auswirkt.<sup>601</sup> Dessen Existenz beruhe schließlich aber von Anfang an und vollständig auf den Interessen anderer. Eine gewisse Instrumentalisierung sei zwar stets Bestandteil sozialen Lebens,<sup>602</sup> die *Neumann* als alltäglich und auch unverzichtbar charakterisiert, aber sie sei eine lediglich partielle. Dies sei mit dem Prinzip der Menschenwürde, welches verbiete, den Menschen *nur* als Mittel zum Zweck zu gebrauchen, jedoch vereinbar. Ein Verstoß liege erst vor, wenn die gesamte Existenz in fremdem Interesse stünde, etwa weil es auf ein genetisches Programm reduziert und ihn nur im Hinblick hierauf ein Lebenswert und -Recht zugesprochen würde. Kritisch wird von *Neumann* entsprechend nicht der gentechnologische Eingriff als

<sup>597</sup> Maunz/Dürig-Herdeggen, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 109.

<sup>598</sup> *Neumann*, Die Menschenwürde als Menschenbürde, S. 51 f.

<sup>599</sup> *Neumann*, Die Menschenwürde als Menschenbürde, S. 54.

<sup>600</sup> *Dederer*, AöR 127 (2002), 1 (4 f.).

<sup>601</sup> *Neumann*, Die Menschenwürde als Menschenbürde, S. 52.

<sup>602</sup> Gängiges Beispiel ist in diesem Zusammenhang der Taxifahrer, der dazu benutzt wird, um von einem zum anderen Ort gefahren zu werden. Dennoch wird man vernünftigerweise keine Verletzung seiner Menschenwürde annehmen können.

solcher gesehen, sondern dessen soziale Bedeutung und die mit ihm verbundene Zielsetzung: „Die gentechnische Produktion von Olympiasiegern ist um nichts problematischer als deren Züchtung auf dem sogenannten natürlichen Weg.“<sup>603</sup> Andererseits sind aber auch gentechnische Eingriffe denkbar, die gerade aus Achtung der Persönlichkeit des künftigen Individuums vorgenommen werden. Unter Berufung auf Jürgen Habermas führt Neumann aus, dies träfe stets auf gentherapeutische Maßnahmen zu, durch die Leid und Krankheit vermieden werden können.<sup>604</sup>

Diese Ausführungen jedoch weisen Schwachpunkte auf. Zum einen ist der Verweis auf Habermas fachlich nicht einschlägig. Wenn Habermas auch von Würde spricht und das übrige verwendete Vokabular ebenfalls vermuten lassen könnte, dass er sich argumentativ im System des Rechts bewegt, so sollen seine Ausführungen in „Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?“<sup>605</sup> keinen Beitrag zum Diskurs über die Interpretation des Art. 1 I GG leisten.<sup>605</sup>

An diesem Diskurs beteiligt sich hingegen Neumann. Dieser führt, wenn auch im Hinblick nur auf bestimmte experimentelle Keimbahneingriffe, bezüglich der Argumentation, dass mit der Degradierung menschlichen Lebens zum bloßen Mittel die Subjektqualität und mithin der Kernpunkt menschlicher Würde tangiert sei,<sup>606</sup> darüber hinaus aus, dass diese Annahme davon ausginge, dass bereits der befruchteten Eizelle Menschenwürde zuzuerkennen ist und sich daraus ein „Verbot der totalen Objektivierung“ ableite. Kritisch merkt er an, dass die Anwendung der Mittel-Zweck-Formel in diesem Kontext fraglich erscheint, setze sie doch die personale Existenz des Gegenübers voraus. Als bloßes Mittel zum Zweck kann jedoch nur der behandelt werden, der auch als Subjekt, als Person behandelt werden kann – und gerade deshalb so behandelt werden muss.<sup>607</sup>

Darüber hinaus stellt sich die Frage, inwiefern ein genetisches Enhancement eine egoistische Maßnahme ist oder, wie Braun es formuliert, hiermit ein anderer Träger der Menschenwürde „zur Realisation fremder Zwecke benutzt“ wird.<sup>608</sup> Handelt es sich um ein Enhancement an somatischen Zellen, so werden hiermit selbstredend egoistische Ziele verfolgt werden, aber eben solche des sich selbst dieser Maßnahme unterwerfenden Individuums. Der Interessenkonflikt, der genetischem Enhancement vorgeworfen wird, liegt hier also nicht vor.

Bei einem an Keimbahnzellen ansetzenden und sich so erst bei einem zukünftigen Individuum auswirkenden Enhancement könnte sich dies anders gestalten. Hier könnte das Enhancement auch getragen sein von, im Hinblick auf die zukünftigen Eltern, egoistischen Motiven und Zwecken. In Frage kommen könnte hier etwa eine

<sup>603</sup> Neumann, Die Menschenwürde als Menschenbürde, S. 54.

<sup>604</sup> Neumann, Die Menschenwürde als Menschenbürde, S. 55.

<sup>605</sup> Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur, S. 56 ff., 61, 73 f.; Gutmann, „Gattungsethik“ als Grenze der Verfügung des Menschen über sich selbst?, S. 254.

<sup>606</sup> Etwa Laufs, JZ 1986, 769 (774); Häberle, JZ 1971, 145 (151).

<sup>607</sup> Neumann, Die „Würde des Menschen“ in der Diskussion um Gentechnologie und Befruchtungstechnologien, S. 149.

<sup>608</sup> Braun, Die besten Gründe für eine kategorische Auffassung der Menschenwürde, S. 89.

persönliche Aufwertung und Darstellung, weil mit der Inanspruchnahme solcher nicht erstattungsfähigen, *high end* medizinischen Möglichkeiten immer auch etwas über die eigene finanzielle Situation kommuniziert wird, oder vielleicht auch der Wunsch nach finanzieller Absicherung im Alter, die eher erreichbar scheint, wenn das Kind alle Eigenschaften aufweist, derer es bedarf, um einen entsprechend lukrativen Beruf ergreifen zu können. Gleichzeitig aber geht es schließlich um eine Verbesserung der genetischen Ausstattung des Kindes, dem dadurch mehr oder bessere Fähigkeiten und Möglichkeiten eingeräumt werden sollen. Vielleicht mögen die Eltern auch hier lediglich darauf abzielen, dass das Kind die Eigenschaften trägt, die es etwa benötigt, um, wie von den Eltern gewünscht, den Familienbetrieb erfolgreich fortzuführen. Nichtsdestoweniger steht es dem Kind frei, dies schließlich entweder zu nutzen und wahrzunehmen oder eben zu missachten oder zu anderen, von den Eltern nicht intendierten Zwecken zu (gemessen an den elterlichen Intentionen zu miss-)brauchen. Ebenso ließe sich argumentieren, dass gerade eine – wenn auch genetisch ermöglichte – Horizonterweiterung die Persönlichkeit des Kindes im Blick hat und diesem größtmöglichen Entwicklungs- und Entfaltungsspielraum ermöglichen und zur Verfügung stellen will. Dies wäre für das Kind schließlich zumindest neutral, ließe es dies ungenutzt, wenn nicht gar positiv, was dann schon rein intuitiv betrachtet als seine Würde verletzend ausscheidet.

Hiermit klingt sodann auch der bedeutende Unterschied zu Fällen des therapeutischen Klonens an, in Bezug auf die stets angemahnt wird, dass auch der gute Zweck der Behandlung einer eventuell gar letalen und nicht anderweitig heilbaren Krankheit des Patienten, zu dem der Klon gezeugt wurde, dessen Würdeverletzung nicht entschuldigen, rechtfertigen oder gar ausschließen könne.<sup>609</sup> Während die Verwendung des geklonten Embryos dessen Interessen gänzlich zuwiderläuft, weil die Therapie eben nicht ihm selbst dienlich ist oder zumindest ihre Auswirkungen auf den Embryo nicht lediglich neutrale sind, ist von einem genetischen Enhancement doch gerade nicht ein Dritter, sondern der Embryo selbst betroffen und dies, die Sicherheit und den Erfolg des Eingriffs vorausgesetzt, in, wie soeben argumentiert, wenigstens neutraler, wenn nicht gar positiver Weise. Ein Verweis auf die durch die Abwägungsfestigkeit der Menschenwürde bedingte wertungsmäßige Trennung einer etwaigen, als gegen Art. 1 I GG verstößend klassifizierten Behandlung von dem mit ihr verfolgten, als solcher jedoch guten Zweck vermag mangels Parallelität in Fällen des genetischen Enhancements somit nicht zu überzeugen.

Auch *Braun* kommt im Hinblick auf (noch) nicht zu Willensbildung fähige menschliche Entitäten zu dem Ergebnis, dass diese so lange nicht zum bloßen Objekt einer Handlung gemacht werden, wie zumindest *auch* sie Zweck dieser Handlung sind, das heißt solange diese Handlung zumindest *auch* ihrem Überleben oder Wohl dient. Eine Instrumentalisierung und somit eine Würdeverletzung liege nur dann vor, wenn einziger Zweck der eines anderen ist, wie *Braun* es etwa im Falle der Organentnahme bei Hirntoten, der fremdnützigen Forschung an nichteinwilligungsfähigen Personen oder der verbrauchenden Embryonenforschung bejaht,<sup>610</sup> wenn

<sup>609</sup> So etwa *Dederer*, AöR 127 (2002), 1 (5).

<sup>610</sup> *Braun*, Die besten Gründe für eine kategorische Auffassung der Menschenwürde, S. 89.



also die Handlung in keiner Weise dem Interesse des Betroffenen entspricht. Geht man nun hinsichtlich eines genetischen Enhancements davon aus, dass das (noch zu zeugende) Individuum pathologisch unauffällig ist, dient der Eingriff nicht seinem Überleben. Allerdings könnte vorgebracht werden, dass das Wohl des Kindes durch ein Enhancement gesteigert wird. Es ließe sich durchaus argumentieren, dass etwa ein breites Spektrum an Fähigkeiten und Entwicklungschancen das sowohl objektiv zu beurteilende als auch subjektiv empfundene Wohl zu steigern vermag.

Differenzierend ließe sich hier nun fragen, ob diese Diagnose auf alle genetisch verbesserbaren Eigenschaften zutrifft. Im Folgenden soll dies anhand der *Rawls'schen* Konzeption der *primary goods* einer Analyse unterzogen werden.

#### bb) Rawls' primary goods

Die bloße Eröffnung des personalen Schutzbereiches des Art. 1 I GG impliziert nicht sogleich auch eine Verletzung der Menschenwürde. In der Tat ist es, betrachtet man die Begrifflichkeiten alleine, fraglich, wieso ein Enhancement, also eine, je nach Übersetzung, Verbesserung, Vergrößerung oder Vermehrung, also etwas, dessen Konnotation zunächst einmal eine grundsätzlich positive ist, eine Verletzung dieses Grundrechts darstellen sollte.<sup>611</sup>

Dies gilt, so die These, zumindest im Hinblick auf die *Rawls'schen primary goods*, die durch den Eingriff entweder unmittelbar vermehrt werden oder deren Erwerb durch den Eingriff zumindest vereinfacht wird. Zu diesen Grundgütern im Sinne *John Rawls'* gehören zunächst Güter, die jede rationale Person schätzen würde oder könnte, da es niemandem ohne diese Güter oder mit einer geringeren Menge dieser Güter besser geht, die Güter also stets zum Wohl jeder Person beitragen,<sup>612</sup> weswegen jeder diese Güter vernünftigerweise erstrebt. Später modifizierte *Rawls* sein Konzept dahingehend, dass *primary goods* im Zusammenhang mit dem politischen Konzept der Person nicht Güter sind, die jede so verstandene Person vernünftigerweise haben möchte, sondern dass es vernünftig ist, die Person so zu behandeln, als wolle sie diese Güter, wenn davon ausgegangen wird, dass sie eine bestimmte Vorstellung vom Guten beziehungsweise einen vernünftigen Plan hat, den sie verfolgt.<sup>613</sup> Hierunter fasst *Rawls* zum Beispiel Rechte, Freiheiten, Freizügigkeit, Möglichkeiten und Chancen sowie Einkommen, Besitz und Vermögen ebenso wie Selbstachtung.<sup>614</sup> Sinnvollerweise lassen sich aber auch Gesundheit, Intelligenz, Talente oder Vorstellungsgabe inkludieren.<sup>615</sup> Auch Freizeit oder be-

<sup>611</sup> Vergleiche schon *Wellington*, Limited Sources of Normative Justification in the Secular Constitutional State?, S. 48 f.

<sup>612</sup> *Rawls*, Eine Theorie der Gerechtigkeit, z. B. S. 112, 285, 438; *Rawls*, Politischer Liberalismus, S. 274 f.

<sup>613</sup> *Nussbaum*, Ratio Juris 2011, 1 (4).

<sup>614</sup> *Rawls*, Eine Theorie der Gerechtigkeit, z. B. S. 112, 285, 438; *Rawls*, Politischer Liberalismus, S. 274 f.

<sup>615</sup> *Allhoff*, Journal of Evolution & Technology 18(1), 10 (20 ff.).



stimmte mentale Zustände wie die Abwesenheit von Schmerzen lassen sich hierunter fassen.<sup>616</sup> Unabhängig davon, welcher Gestalt die vernünftigen Pläne eines Menschen sind oder was ein vernünftiger Mensch im Übrigen haben möchte, so möchte er doch zumindest diese gesellschaftlichen Grundgüter und zwar hiervon lieber mehr als weniger haben, da sie allgemein mehr Erfolg bei der Erreichung seiner wie auch immer ausgestalteten Vorhaben versprechen.<sup>617</sup>

Die *primary goods* sind somit Güter, die das Wohl der über sie verfügenden Individuen fördern, welches sich wiederum danach bemisst, was für besagtes Individuum der vernünftige Lebensplan ist. Gut ist bei *Rawls* anders als im theologischen Sinne zunächst etwas dann, wenn es zu ebendieser Lebensform passt (die ihrerseits mit dem Rechten übereinstimmen, also den öffentlich anerkannten Grundsätzen des Rechten entsprechen muss). Deren Vorbedingung sowie Vorbedingung für deren Ausübung stellen sodann die Grundgüter dar. Diese *Rawls*'sche schwache Theorie des Guten erklärt also die Vernünftigkeit des Wunsches nach Grundgütern.<sup>618</sup> Aus dem Lebensplan eines Menschen folgt, was sich dieser wünscht und was daher für diesen gut ist;<sup>619</sup> er ist ausschlaggebend für die jeweils immer subjektive<sup>620</sup> Definition des Guten und grundlegender Aspekt, anhand dessen die Werturteile in Verbindung mit dieser Person getroffen werden.<sup>621</sup> Ist der Lebensplan als solcher ein vernünftiger, ist auch die daraus resultierende Vorstellung der Person vom Guten eine vernünftige.<sup>622</sup>

Bei der Herleitung dieser Annahme im Rahmen des Grundsatzes der gleichen Freiheit für alle und des Vorrangs der von ihm festgelegten Rechte betont *Rawls* unter Rückgriff auf *Kants* Deutung von Gerechtigkeitsvorstellungen auch die in dessen Sinne begriffene Autonomie des Individuums. *Kant* geht davon aus, dass Vernunftentscheidungen die Grundlage moralischer Grundsätze und des moralischen Gesetzes seien, die, so *Kants* Annahme, unter Bedingungen angenommen werden müssen, welche die Menschen als freie und gleiche Wesen kennzeichnen. *Rawls* selbst bedient sich in dem Versuch, diese Vorstellung zu konkretisieren, sei-

<sup>616</sup> *Rawls*, Politischer Liberalismus, S. 275 f.

<sup>617</sup> *Rawls*, Eine Theorie der Gerechtigkeit, S. 112, 166, 285, 434. Ohne sich auf *primary goods* im Sinne *Rawls*' zu beziehen, kommt auch *Köbl*, Gentechnologie zu eugenischen Zwecken, S. 187 ff. zu dem Ergebnis, dass eine Vermehrung und Stärkung von Eigenschaften (in *Rawls*' Diktum: Güter), die die überwiegende Mehrheit der Menschen des jeweiligen Kulturkreises (nach *Rawls* vernünftigerweise und unabhängig ihres individuellen Lebensplans) hochschätzen, nicht allein dadurch verwerflich werden könne, dass sie nunmehr im Wege biotechnologischer Eingriffe erreicht werden soll und nicht wie bisher nur möglich und üblich durch die bewusste oder unbewusste Partnerwahl, (Selbst-)Erziehung und Bildung oder körperliches Training.

<sup>618</sup> *Rawls*, Eine Theorie der Gerechtigkeit, S. 433 ff.

<sup>619</sup> *Rawls*, Eine Theorie der Gerechtigkeit, S. 437, 446.

<sup>620</sup> Eine Einigung braucht nur über das Rechte, also etwa auch über Gerechtigkeitsgrundsätze, getroffen zu werden; der Lebensplan hingegen ist ein rein subjektiver, in Bezug auf den eine Einmütigkeit zwischen den Menschen, solange sie jeweils mit öffentlichen Gerechtigkeitsgrundsätzen vereinbar sind, noch nicht einmal wünschenswert ist, in dessen Rahmen aber der Zugriff auf eine möglichst große Anzahl von Grundgütern stets vorteilhaft ist.

<sup>621</sup> *Rawls*, Eine Theorie der Gerechtigkeit, S. 447.

<sup>622</sup> *Rawls*, Eine Theorie der Gerechtigkeit, S. 446.

ner Konstruktion des *Urzustandes*,<sup>623</sup> dessen Beschreibung dem Blickwinkel einer intelligiblen Person, einem freien und gleichen, vernünftigen Wesen ähnelt.<sup>624</sup> Er geht dabei davon aus, dass auch *Kant* seiner Aufforderung, man möge seine *Maxime* prüfen, indem man sie als allgemeines Naturgesetz hinterfragt, voraussetzt, dass die eigene Stellung in dem vorgestellten System der Natur nicht bekannt ist.<sup>625</sup> Dessen Natur bestmöglich zu entsprechen versteht *Rawls* als eine im Sinne Kants autonome, im Gegensatz zu einer heteronomen, das heißt an der jeweiligen gesellschaftlichen Stellung, an natürlichen Gaben, oder der Eigenart der Gesellschaft, in der das Individuum lebt, orientierten Handlung. Menschen im *Urzustand* vermögen dabei ausschließlich autonome Grundsätze zu wählen, fehlen ihnen aufgrund des *Schleier des Nichtwissens*<sup>626</sup> doch diejenigen Kenntnisse, aufgrund derer sie sich für heteronome Grundsätze entscheiden könnten. Sie treffen ihre Entscheidung über Gerechtigkeitsgrundsätze als freie und gleiche Vernunftwesen:<sup>627</sup> „Denn als Wesen besonderer Art zu handeln heißt nach Grundsätzen handeln, die man gerade aufgrund dieser Eigenart wählen würde.“<sup>628</sup> Der *Schleier des Nichtwissens* nimmt gemeinsam mit Bedingungen der Partizipation die Rolle ein, die ansonsten dem *kategorischen Imperativ* zukommt.<sup>629</sup>

Da diese Gerechtigkeitsgrundsätze für alle freien und gleichen Vernunftwesen gelten könnten und gerade nicht auf besonderen Zielen oder Wünschen fußen, handele es sich hierbei *Rawls* zufolge selbst um kategorische Imperative und nicht bloß um hypothetische, die lediglich bestimmte Schritte als Mittel zur Erreichung konkreter Zwecke, die nicht alle Menschen gleichermaßen verfolgen müssen, bezeichnen. Die Gerechtigkeitsgrundsätze<sup>630</sup> setzen nur den Wunsch nach besagten Grundgütern voraus, die zu wünschen im Rahmen der menschlichen Natur zu deren

<sup>623</sup> *Rawls*, Eine Theorie der Gerechtigkeit, S. 283 f.

<sup>624</sup> *Rawls*, Eine Theorie der Gerechtigkeit, S. 288.

<sup>625</sup> *Rawls*, Eine Theorie der Gerechtigkeit, S. 159 f., Fn. 11.

<sup>626</sup> *Rawls*, Eine Theorie der Gerechtigkeit, S. 159 ff.: Um zu verhindern, dass die um eine Übereinkunft über gesellschaftliche Grundsätze verhandelnden Parteien gesellschaftliche oder natürliche Umstände zu ihrem Vorteil nutzen, befinden sie sich hinter dem, wie *Rawls* ihn nennt, *Schleier des Nichtwissens*: Ihnen ist ihr jeweiliger Platz in der Gesellschaft, ihr Status oder ihre Klasse ebenso wenig bekannt wie ihre natürlichen Talente, Gaben, Intelligenz oder sonstige Fähigkeiten, Vorstellungen vom Guten oder des eigenen konkreten Lebensplanes. Über ein so garantiertes faires Verfahren sollen die Grundsätze, zu denen die Parteien gelangen, gerecht sein. Die für diese Entscheidung erforderlichen, aber auch verfügbaren Erkenntnisse werden so als immer die gleichen konstruiert, sodass sie ebenfalls davon unabhängig sind, welcher Generation die verhandelnden Parteien angehören, da mangels Kenntnis auch ihrer Stellung in der Zeit keine Grundsätze festgelegt werden können, die auf den besonderen Vorteil konkret einer Generation gerichtet sind.

<sup>627</sup> *Rawls*, Eine Theorie der Gerechtigkeit, S. 284.

<sup>628</sup> *Rawls*, Eine Theorie der Gerechtigkeit, S. 285.

<sup>629</sup> *Habermas*, *Journal of Philosophy* 92 (1995), 109 (117).

<sup>630</sup> *Rawls*, Eine Theorie der Gerechtigkeit, S. 336 f. (beziehungsweise in einer vorläufigen Formulierung auf S. 81): 1. „Jedermann hat gleiches Recht auf das umfangreichste Gesamtsystem gleicher Freiheiten, das für alle möglich ist.“ Und 2. „Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten müssen folgendermaßen beschaffen sein: a) sie müssen unter der Einschränkung des gerechten Spargrundsatzes dem am wenigsten Begünstigten den größtmöglichen Vorteil bringen, und b) sie

Vernünftigkeit gehört und zwar unabhängig von irgendwelchen Vorstellungen des Guten oder den jeweiligen Zielen des Einzelnen.<sup>631</sup> Bei den Grundgütern handelt es sich somit um eine Klasse von Gütern, die auch unter Zugrundelegung verschiedenartigster, aber vernünftiger Lebenspläne gewünscht ist und welche die betreffenden Personen ebenso wenig auf bestimmte menschliche Interessen festlegt, wie die auf ihr aufbauenden Gerechtigkeitsvorstellungen.<sup>632</sup>

Wollte man *Kants Kategorischen Imperativ* nun in die einfachere Fassung übersetzen, der zufolge Individuen nur auf diejenige Art und Weise behandelt werden dürfen, in die sie vernünftigerweise einwilligen würden, wären Methoden des genetischen Enhancements im Hinblick auf oben genannte Güter, deren Ablehnung unabhängig von den Zielen, die das betreffende Individuum im Leben verfolgt, grundsätzlich irrational wäre, durchaus als moralisch erlaubt zu betrachten.<sup>633</sup>

Freilich ist der intrinsische Wert der Maximierung dieser Güter nicht unumstritten. So mag bezweifelt werden, dass etwa besondere Intelligenz vernünftigerweise erstrebenswert ist, dürften vielfach mit ihr auch besondere Erwartungen und hiermit ein erhöhter Druck einhergehen. Ebenso könnten sich Individuen mit großem Reichtum Begehrlichkeiten ausgesetzt und mit einer (durch externe Faktoren suggerierten) Notwendigkeit der optimierten Geldanlage konfrontiert sehen. Jedoch ist auch hier nicht der Unterschied zwischen Ursache und Wirkung aus den Augen zu verlieren. Das Gut selbst, also im Beispiel eine besondere Intelligenz oder Vermögen, ist dabei nicht der Ursprung dieser negativen Begleiterscheinungen, es selbst trägt nicht zu einer Verschlechterung des Wohles des betroffenen Individuums bei: Wenn vielleicht der aufgrund erhöhter Intelligenz ebenfalls erhöhte Erwartungsdruck auch nicht erstrebenswert sein mag, so ist es das Gut, also die Intelligenz, für sich alleine genommen doch allemal.<sup>634</sup>

Auch mag das Argument, dass einige Menschen zum Beispiel die Anhäufung materieller Güter ablehnen, nicht zu überzeugen. Zwar ist die etwa religiös motivierte Entscheidung, auf persönliches Vermögen weitgehend zu verzichten, eine durchaus zu respektierende. Dennoch würde ein größeres Maß an finanziellen Mitteln oder sonstigen materiellen Gütern diesen Individuen zumindest nicht schaden. Sie könnten sie stets derelinquieren oder sie, eventuell unter Verfolgung wohltätiger Zwecke, auf Dritte übertragen. Ihrer Entscheidungskompetenz und –Freiheit ist durch die ursprüngliche Zuschreibung von den Grundgütern Vermögen und Einkommen keinesfalls beeinträchtigt; eine Entledigung oder einfach Nicht-Beachtung und Nicht-Nutzung derer ist weiterhin möglich.

Die Argumentation lässt sich sodann mit *Allhoff* durchaus einen Schritt weiter gehen: *Kant* selbst spricht von einer Pflicht zur Weiterentwicklung der eigenen Talente; eine Forderung, die wohl breite Unterstützung finden dürfte, wird eine

---

*müssen mit Ämtern und Positionen verbunden sein, die allen gemäß fairer Chancengleichheit offenstehen.“*

<sup>631</sup> Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, S. 285 f.

<sup>632</sup> Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, S. 293.

<sup>633</sup> Allhoff, Journal of Evolution & Technology 18(1), 10 (20 ff.).

<sup>634</sup> Allhoff, Journal of Evolution & Technology 18(1), 10 (Fn. 12).

autonome Entwicklung und die Erweiterung des Fähigkeiten- und Möglichkeiten-spektrums doch allgemein befürwortet. Zwar beziehen sich *Kants* Überlegungen ausschließlich auf die eigene Entwicklung und nicht die anderer wie der eigenen Nachkommen. Dennoch scheint es nicht abwegig, dass ein Unterlassen der Verbesserung nicht im vernünftigen Interesse der Nachkommenschaft stünde und entsprechend nicht deren (hypothetische) Einwilligung erfahren würde. Auch *Rawls* zufolge schulden frühere Generationen geradezu den ihnen nachfolgenden eine faire und bestmögliche Güterverteilung. *Allhoff* interpretiert die Parteien im *Urzustand* also als für ihre Nachfahren die vernünftigerweise bestmögliche genetische Ausstattung sichern wollend.<sup>635</sup>

Freilich soll es vorliegend keineswegs um die Begründung einer (rechtlichen, moralischen oder anderweitigen) Pflicht zu genetischem Enhancement zukünftiger Generationen gehen. Aber sofern die aufgezeigte Argumentation nicht gänzlich unplausibel ist, erweist es sich als umso schwieriger, entgegen einer Möglichkeit der Ableitung gar einer Pflicht zur Verbesserung ein Verbot dessen zu konstruieren.<sup>636</sup>

Entsprechend kann festgestellt werden, dass das genetische Enhancement, gerade ein an Keimbahnen vorgenommenes und sich auf Dritte wie nur zukünftige Personen auswirkendes, zumindest sofern es sich auf Grundgüter im Sinne *Rawls*' bezieht, zulässig ist. Es legt den Betroffenen nicht auf einen Lebensplan fest – es ist sogar denkbar, dass es die Auswahl der zur Verfügung stehenden Lebenspläne vergrößert –, sondern ermöglicht oder vereinfacht ihm die Verfolgung eines jeglichen von ihm selbst gefassten Planes und fördert so seine Autonomie. Indem die durch das Enhancement erreichte Vermehrung der Grundgüter die Verfolgung dieses Plans begünstigt, entspricht es der individuellen Konzeption des Guten und fördert das Wohl des Betroffenen, dessen Zustimmung vernünftigerweise angenommen werden darf. In diesem Umfang kann von einer Verletzung der Menschenwürde dann aber auch nicht mehr die Rede sein.

Art. 1 I GG steht in seiner traditionellen Interpretation als individualschützendes Grundrecht den Praktiken des genetischen Enhancements mithin nicht im Wege.

## 2. Extension des Menschenwürdesatzes

Wie gezeigt führt eine Anwendung der traditionellen und weitgehend unbestrittenen Grundsätze aus Art. 1 I GG nicht zu einer Rechtfertigungsmöglichkeit des Verbots von Enhancement-Maßnahmen. Gleichzeitig scheint jedoch ein besonderes Bedürfnis fortzubestehen, gentechnische Eingriffe im Allgemeinen und beim Menschen im Besonderen zu regulieren und zwar möglichst umfassend, unumkehrbar und unabänderlich. Es stellt sich somit die Frage, ob eine von den Kritikern zu diesem Zwecke angestrebte Extension des Anwendungsbereiches des Art. 1 I GG zulässig und zielführend ist.

<sup>635</sup> *Allhoff*, Journal of Evolution & Technology 18(1), 10 (20 ff.).

<sup>636</sup> Vergleiche bereits *Welling*, Limited Sources of Normative Justification in the Secular Constitutional State?, S. 49; dazu, dass Enhancement-Technologien nicht nur unausweichbar, sondern auch begrüßenswert sind *Baylis/Robert*, Bioethics 18 (1), 1 (18 ff.).

### a) Motivlage: Die Versuchung des Menschenwürde-Arguments

Als Kerngehalt und zentrales rechtliches Konzept des Grundgesetzes wird die Menschenwürde in extensivem Maße auch und gerade in bioethischem Kontext bemüht.<sup>637</sup> Ihr wird in der Debatte um die Grenzen der Gentechnologie und Befruchtungsmedizin eine „entscheidende Bedeutung“ zugesprochen und zwar sowohl in dem Sinne, dass die Würde in nahezu jeder Erörterung als Prüfungsmaßstab herangezogen wird, als auch vor dem Hintergrund, dass sie das „Gewinnargument“ *par excellence* ist.<sup>638</sup> In der Tat ist der argumentatorische Griff zu diesem höchsten Konstitutionsprinzip ein durchaus verlockender.<sup>639</sup>

Zunächst einmal erscheint das Konzept der Menschenwürde als interpretations- und gar ideologieoffenes, das heißt eines, das verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten selbst dann offensteht, wenn es sich um explizit religiöse, metaphysische oder anderweitig partikuläre Moralvorstellungen handelt.<sup>640</sup> Es läuft allenthalben Gefahr, zu deren Einfallstor zu werden,<sup>641</sup> und wird von den Befürwortern zahlreicher unterschiedlichster Lebenswelten und -entwürfe mit den damit zusammenhängenden unterschiedlichen Wertskalen, Normsystemen oder ethischen Theorien herangezogen, um die eigenen normativen Bestrebungen als vom Grundgesetz befürwortet zu inszenieren. Die Norm werde, so Neumann, mit ihrem weltanschaulichen Hintergrund philosophisch und theologisch ausgeleuchtet.<sup>642</sup>

Darüber hinaus erklärt Art. 1 I GG die Menschenwürde für unantastbar und verurteilt somit alle hiermit konfligierenden Handlungen als verfassungswidrig. Da es sich bei dem Schutz aus Art. 1 I GG um einen absoluten handelt, ist dieses Urteil zwingend und immer schon dann zu fällen, sobald die Menschenwürde auch nur berührt ist: Im Gegensatz zu anderen Grundrechten wie etwa dem Recht auf freie Berufswahl aus Art. 12 I 1 GG, die Meinungsfreiheit aus Art. 5 II GG oder dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit aus Art. 2 II 3 GG existiert im Hinblick auf die Menschenwürde nicht die Möglichkeit der rechtfertigenden Interessenabwägung. Sie ist einem Eingriff auch zugunsten konkurrierender Rechtsgüter mit Verfassungsrang entzogen.<sup>643</sup> Die Menschenwürde ist höherrangig als jedes andere rechtlich geschützte Interesse und genießt diesem gegenüber entsprechend

<sup>637</sup> Dreier bezeichnet die Berufung auf die Menschenwürde und die Behauptung ihrer Verletzung als „geradezu endemisch“ und warnt vor einer „Inflationierungsgefahr“: Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 48 f., 77.

<sup>638</sup> Neumann, Die „Würde des Menschen“ in der Diskussion um Gentechnologie und Befruchtungstechnologien, S. 139.

<sup>639</sup> Vergleiche Gutmann, „Gattungsethik“ als Grenze der Verfügung des Menschen über sich selbst?, S. 237 ff.

<sup>640</sup> Welling, Limited Sources of Normative Justification in the Secular Constitutional State?, S. 44.

<sup>641</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 49.

<sup>642</sup> Neumann, Die „Würde des Menschen“ in der Diskussion um Gentechnologie und Befruchtungstechnologien, S. 139.

<sup>643</sup> BVerfGE 75, 369 (380); 93, 266 (293); BVerfGE JZ 2003, 622 (623); mit Bezug auf den Kern des allgemeinen Persönlichkeitsrechts BVerfGE 34, 238 (245); 75, 369 (380); 80, 367 (373); Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 44; Jarass/Pieroth, GG, Art. 1 Rdnr. 16; von Mangoldt/Klein/

vorrangigen Schutz.<sup>644</sup> Jeder Eingriff in die Menschenwürde stellt mangels Rechtfertigungsmöglichkeit somit stets ihre Verletzung dar, die Menschenwürde entzieht sich jeder Verrechnung. Sobald Konsens darüber besteht, dass eine bestimmte Technik diese Würde beeinträchtigt, folgt daraus ohne eine Möglichkeit der Rechtfertigung zwingend deren Verletzung. Die Argumente für den Einsatz dieser Technik bleiben dann ungeachtet ihrer Gewichtigkeit ohne Erfolg.<sup>645</sup> Entsprechend könnte Art. 1 I GG als materielle Grenze der Kompetenz des demokratisch legitimierten Gesetzgebers allein über die rechtliche Unzulässigkeit genetischen Enhancements entscheiden. Gegner des genetischen Enhancements versuchen daher, sich dieser Verfassungsnorm als *discussion stopper* zu bedienen, um damit die weitere Diskussion abzuschneiden.<sup>646</sup> Art. 1 I GG soll so, gewissermaßen als „*verfassungsrechtliche Notbremse*“<sup>647</sup> fungierend, die Gesellschaft davor bewahren, die Grenze zum Sperrgebiet des genetischen Enhancements zu überschreiten, welches unter Umständen betreten werden würde, könnten mit nicht absoluten Argumenten keine strikten und dauerhaften<sup>648</sup> Verbote begründet werden, sondern gegebenenfalls nur solche, die den im Hinblick auf humangenetische Technologien international zu verzeichnenden Aufweichungstendenzen nicht standhalten könnten.<sup>649</sup>

Da Art. 1 I 2 GG alle staatliche Gewalt dazu verpflichtet, die Menschenwürde zu achten und zu schützen, beschränkt die Verfassungsnorm darüber hinaus und zugleich die Autorität und Legitimität der Legislative. Ausweislich der sogenannten Ewigkeitsgarantie des Art. 79 III GG ist eine die unter anderem in Art. 1 GG enthaltenen Grundsätze berührende Verfassungsänderung unzulässig, sodass keinerlei, andernfalls zu Verfassungsänderungen fähige (politische) Mehrheit eine Verletzung oder gar die Abschaffung des Art. 1 I GG legalisieren könnte. Indem sie sich auf die Menschenwürde berufen, suchen Gegner des genetischen Enhancements dieses aus dem demokratischen Prozess zu exkludieren und als *off limits* zu charakterisieren.<sup>650</sup> In dem Bemühen, die demokratische Genese einer neuen normativen Ordnung zu restringieren, wird sich der Menschenwürde zugewandt, die, gleichsam einer Schleuse, diejenigen Argumente hindurch und am demokratischen Prozess

---

Starck-Starck, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 34; Sachs-Höfling, GG, Art. 1 Rdnr. 11; vergleiche auch Böckenförde, JZ 2003, 809 (810).

<sup>644</sup> Von einer gesteigerten Valenz der Menschenwürde gegenüber anderen Belangen von Verfassungsrang im Sinne einer hierarchischen Überordnung spricht Maunz/Dürig-Herdeggen, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 4; vergleiche auch von Münch/Kunig-Kunig, GG, Art. 1 Rdnr. 4.

<sup>645</sup> Neumann, Die „Würde des Menschen“ in der Diskussion um Gentechnologie und Befruchtungstechnologien, S. 139.

<sup>646</sup> Gutmann, „Gattungsethik“ als Grenze der Verfügung des Menschen über sich selbst?, S. 238 f.; ähnlich auch Bayertz, Sanctity of Life and Human Dignity, xi.

<sup>647</sup> Graf Vitzthum, JZ 1985, 201 (209).

<sup>648</sup> Der Befund etwa, dass genetisches Enhancement mit den Prinzipien eines angemessenen Risikomanagements nicht übereinstimmt, ist ein lediglich temporärer, da davon auszugehen ist, dass früher oder später sichere Methoden des *genetic engineering* gefunden werden.

<sup>649</sup> Gutmann, „Gattungsethik“ als Grenze der Verfügung des Menschen über sich selbst?, S. 238 f.

<sup>650</sup> Gutmann, „Gattungsethik“ als Grenze der Verfügung des Menschen über sich selbst?, S. 238 f.



partizipieren lässt, die sich in das rechtliche System einfügen, und diejenigen außen vor lässt, auf die dies gerade nicht zutrifft.

Vor dem Hintergrund dieser zur Ubiquität des Rekurses auf Art. 1 I GG beitragenden Motivlage über die im Rahmen der traditionellen Interpretation des Menschenwürdesatzes erblickte Reichweite hinaus sollen im Folgenden die diskutierten Ansätze dargestellt und im Hinblick auf die Anforderungen des säkularen Rechtsstaates hinterfragt werden. Hierbei sollen der Vollständigkeit halber sowohl die Versuche beleuchtet werden, die lediglich den zeitlichen Anwendungsbereich des Art. 1 I GG ausweiten wollen, an einem auf das konkrete Individuum beschränkten und festgelegten personalen Schutzbereich jedoch festhalten, als auch Konzeptionen, die einen überindividuellen und insofern zeitlich auch nicht festgelegten Anwendungsbereich proklamieren.

## b) Vorwirkung der Menschenwürde?

Zum Teil wird vertreten, dass die Menschenwürde nicht nur postmortale Nachwirkung entfaltet, sondern dass ihre Vorwirkung auch frühe Stadien des menschlichen Lebens erfasst, was *Dreier* als antizipierte Rückwirkung<sup>651</sup> und *Kloepfer* als Grundrechtsanwartschaft<sup>652</sup> bezeichnet.

Hierbei ist jedoch schon die diesem Ausdehnungsversuch zugrunde liegende Konstruktion umstritten, ist man sich doch uneins, was genau Schutzgut der über den Tod einer Person andauernden Respektierung der Menschenwürde ist. Zumeist wird vertreten, dass die Rechtsfähigkeit und somit auch die Rechtssubjektivität eines Menschen mit dessen Tod endet und Art. 1 I GG somit postmortal mangels eines ihr zuzuordnenden Rechtsträgers keine Schutzansprüche, wohl aber Schutzpflichten des Staates als eine Art „*postmortale Reflexwirkung der Würde bzw. des persönlichkeitsprägenden Lebensbildes des Verstorbenen*“<sup>653</sup> entfaltet, was also die Differenzierung zwischen Grundrecht und Schutzgut des Grundrechts besonders betont. Die Menschenwürde würde hiernach keinen subjektiv-rechtlichen Gehalt mehr entfalten, sondern wäre nur noch als Prinzip anwendbar, das zwar eine Schutzpflicht des Staates begründet, die unabhängig von einer korrespondierenden subjektiv-rechtlichen Position Bestand hat, das aber auch der Abwägung zugänglich und zeitlich begrenzt ist.<sup>654</sup> Als Motiv für die Begründung einer Nachwirkung der Menschenwürde wird hierbei in einer zwangsläufigen Rückwirkung auf die Ach-

<sup>651</sup> *Dreier-Dreier*, GG, Art. 1 I Rdnr. 79.

<sup>652</sup> *Kloepfer*, JZ 2002, 417 (420).

<sup>653</sup> *Sachs-Höfling*, GG, Art. 1 Rdnr. 62.

<sup>654</sup> *Ipsen*, JZ 2001, 989 (993); *Jarass/Pieroth*, GG, Art. 1 Rdnr. 10; von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 31; zu den zeitlichen Grenzen des postmortalen Würdeschutzes in Bezug auf den postmortalen Persönlichkeitsschutz vergleiche *Dreier-Dreier*, GG, Art. 1 I Rdnr. 75: „das Bild des Verstorbenen in der Nachwelt verblaßt, das Echo wird leiser“ sowie BGHZ 107, 384 (392) – Emil Nolde: „Die Dauer des postmortalen Persönlichkeitsschutzes läßt sich nicht generell festlegen. [...] Das Schutzbedürfnis schwindet [...]“; *Maunz/Dürig-Herdegen*, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 69 hingegen plädiert für eine Korrelation zwischen subjektiv-rechtlichem Würdeanspruch



tung der Menschenwürde von Lebenden gesehen und auf aus anderen Kulturen und Epochen bekannte sozialpsychologische Prozesse verwiesen, in denen sich das lebzeitige Ansehen des Toten in dessen Bestattung und im Andenken an ihn ausdrückt. Hieraus ließe sich sodann die reziproke These herleiten, dass eine Vernachlässigung der Sepulkralkultur nicht nur Rückschlüsse auf die Achtung der Menschenwürde unter Lebenden,<sup>655</sup> sondern auch Rückwirkungen hierauf zulässt, was die Notwendigkeit von strafrechtlichen Vorschriften etwa zum Schutze der Totenruhe (§ 168 StGB) oder über Organtransplantation (§§ 17 ff. TPG) begründet.<sup>656</sup> Eine Vernachlässigung eines adäquaten Würdeschutzes nach dem Ableben könnte dieser als Verrohungsargument zu kategorisierenden These zufolge also eine dezimierende Wirkung für das Ansehen und den Schutz der Menschenwürde Lebender haben. Entsprechend geht auch *Hofmann* davon aus, dass „die Ehrung des Andenkens derjenigen, die einmal unter uns oder vor uns waren, zur eigenen, wechselseitig anzuerkennenden Identität und Selbstachtung gehört.“<sup>657</sup> Das Bundesverfassungsgericht stellt bei der Begründung der postmortalen Wirkung der Menschenwürde auf das Pietätsgefühl der Angehörigen und der Allgemeinheit ab und überhöht diese soziale Anschauung verfassungsrechtlich.<sup>658</sup>

Vor diesem Hintergrund wird vorgebracht, dass eine Vorerstreckung der Menschenwürde auf die Zeit vor traditionell anerkannter Trägerschaft dieses Grundrechts, also auf die pränatale und gegebenenfalls gar auf die pränidationale Phase, nur logisch sei,<sup>659</sup> wobei sowohl die Anknüpfung an einen konkreten Rechtsträger im Sinne eines subjektiven Schutzanspruchs als auch die Ausgestaltung als eine bloß objektive Schutzpflicht in Betracht gezogen werden könnte.

Dieser Auffassung stehen aber zwei zentrale Bedenken entgegen, verkennt sie doch zentrale Unterschiede zwischen einer über das geborene Leben hinausgehenden Ausdehnung der Würde und ihrer Vorerstreckung:

Der postmortale Würdeschutz stellt die Verlängerung der Würde derjenigen da, die gelebt haben und deren Würde zur Zeit ihres Lebens auch schon durch Art. 1 I 1 GG geschützt war. Bei einem prävitalen Würdeschutz fehlt es aber gerade an einem vergleichbaren Substrat.<sup>660</sup> Vielmehr bedarf es stets auch dann eines konkreten Würdeträgers,<sup>661</sup> wenn man annähme, dass menschlichem Leben in jeglichem, auch noch so frühen Stadium seiner Entwicklung Menschenwürde zuzusprechen sei, namentlich einer Person, die sich aus der vorliegenden Zygote oder Zellansammlung entwickeln wird. Selbst für den Fall, dass man Art. 1 I GG ledig-

---

und objektiv-rechtlichem Würdeschutz: Eine verfassungsrechtliche Wertentscheidung gegen einen Würdeschutz sich entwickelnden Lebens sei auch auf objektiv-rechtlicher Ebene zu respektieren.

<sup>655</sup> *Maurer*, DÖV 1980, 7 (9) formuliert: „Die Achtung, die dem Verstorbenen entgegengebracht wird, spiegelt die Achtung vor dem Lebenden wider.“

<sup>656</sup> *Ipsen*, JZ 2001, 989 (993).

<sup>657</sup> *Hofmann*, AöR 118 (1993), 353 (375); ähnlich auch *Bizer*, NVwZ 1993, 653 (655).

<sup>658</sup> BVerfGE 30, 173– Mephisto; von Münch/Kunig-Kunig, GG, Art. 1 Rdnr. 15.

<sup>659</sup> Vergleiche Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Rdnr. 79 mit FN 253.

<sup>660</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 1 I Fn. 253.

<sup>661</sup> Vergleiche exemplarisch nur *Heun*, JZ 2002, 517 (519); *Hufen*, JZ 2004, 313 (314).

lich als eine objektive Schutzrichtung entfaltend begreift, bleibt ein individualisiertes zu schützendes Objekt erforderlich. Auch in diesem Punkt wird ein deutlicher Unterschied zu der postmortalen Wirkung eines Rechts deutlich, welches im Interesse des früheren Lebenden über seinen Tod hinausreicht und sodann weiterhin von dritter Seite geltend gemacht werden kann, weswegen insofern sehr wohl ein entsprechendes Substrat auch nach dem Tode fortbesteht, welches sich nicht auf das bloße menschliche Leben als solches beschränkt, wie etwa *Dederer* es annimmt,<sup>662</sup> während bei einer Ausdehnung der Menschenwürde in die prävitale Phase zumindest bis zur Ausbildung des Primitivstreifens noch keine Individuation des Lebens und entsprechend auch keine Individualisierung des Rechts stattgefunden hat.<sup>663</sup> Die Vorerstreckung gelingt daher nicht bis zur Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, sondern lediglich bis zur Nidation beziehungsweise bis zur Individuation.<sup>664</sup>

Für die Beurteilung der Frage nach einem Würdeverstoß gelangt man über die beschriebenen Versuche einer Ausdehnung des Anwendungsbereiches des Art. 1 I GG zu keinem anderen Ergebnis.

### c) Würde als Ausdruck einer objektiv-rechtlichen Werteordnung

Geht man davon aus, dass es sich bei Art. 1 I GG ebenso wie bei den Art. 2–19 GG um ein Grundrecht handelt, könnte man sich auf eine objektive Wertordnung stützen, die in den basalen Aussagen der Grundrechte implizit enthalten, aber von dem individuellen Grundrechtsträger losgelöst ist. Könnte sodann eine grundrechtliche Emanzipierung vom Individuum gelingen und gleichzeitig ein entsprechender objektiv-rechtlich gebotener Schutzgehalt substantiiert werden, aufgrund dessen ein Verbot genetischen Enhancements in Frage käme, so ließe dies die fehlende Erstreckung des klassisch interpretierten Art. 1 I GG auf früheste menschliche Lebensformen obsolet werden.

Dem Bundesverfassungsgericht zufolge stellen die Grundrechte nicht nur negative Freiheiten und Rechte dar, die ihren jeweiligen Träger vor staatlichen Eingriffen schützen sollen, sondern enthalten darüber hinaus eine objektive Wertordnung, die sämtliche rechtlichen Bereiche beeinflusst und der sowohl die Legislative als auch die Exekutive und Judikative unterliegen.<sup>665</sup> Das Verhältnis zwischen objektiv-rechtlicher Wertedimension und subjektiv-rechtlichen Schutz- und Freiheitsrechten ist jedoch Gegenstand andauernder Debatten.

*Rupp* beispielsweise erkennt zwar die subjektive Dimension der Grundrechte als Freiheitsrechte an, die das Subjekt des Grundrechtsbegünstigten schützen. Gleich-

<sup>662</sup> *Dederer*, AöR 127 (2002), 1 (13) verkehrt das Substrat-Argument, indem er statuiert, das den Schutz bedingende Substrat sei das menschliche Leben selbst und entfalle nun einmal mit dem Tod.

<sup>663</sup> *Heun*, JZ 2002, 517 (519 mit Fn. 34).

<sup>664</sup> *Dederer*, AöR 127 (2002), 1 (9, 14 ff.); *Hufen*, Individuelle Rechte und Zulassung der PID, S. 141 f.; *Schroth*, JZ 2002, 170 (177).

<sup>665</sup> Vergleiche BVerfGE 39, 1 (41 f.); ebenso BVerfGE 7, 198 (205); 21, 362 (371 f.); 25, 256 (263); 35, 79 (114); vergleiche auch von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 1 Abs. 3 Rdnr. 153.

wohl argumentiert er für einen primär objektiv-rechtlichen Charakter der Grundrechtsverbürgungen in der Verfassung, die „*alles Recht in ihren Bann zwingen und zugleich als Kontrollmaßstäbe dienen*.“<sup>666</sup> Auch Dürig hat aus dem Menschenwürdesatz und den anderen Grundrechten ein geschlossenes Wert- und Anspruchssystem abgeleitet, welches eine analytische Richtlinie für die Bestimmung staatlicher Schutzpflichten sein soll.<sup>667</sup>

Zu Recht verweist hingegen das Bundesverfassungsgericht neben der Geschichte auf den Inhalt der Einzelgrundrechte (sic!) und betont, dass diese „*in erster Linie individuelle Rechte, Menschen- und Bürgerrechte [sind], die den Schutz konkreter, besonders gefährdeter Bereiche menschlicher Freiheit zum Gegenstand haben*.“ Die Funktion der Grundrechte als objektive Prinzipien, so stellt das Gericht explizit fest, „*besteht in der prinzipiellen Verstärkung ihrer Geltungskraft*“ ihrer subjektiv-rechtlichen Dimension<sup>668</sup> und gründet auch in dieser primären Bedeutung.<sup>669</sup> Hieraus ergibt sich ein klares Rangverhältnis des vorgeordneten individualrechtlichen vor dem objektiv-rechtlichen Aspekt der Grundrechte.<sup>670</sup>

Ein anderes Ergebnis folgt auch nicht aus der grundsätzlichen Einschränkung der Grundrechte im Wege der ausdrücklich vorgesehenen Schranken wie dem Gesetzesvorbehalt oder der verfassungsunmittelbaren Schranke. Schranken selbst sind stets aus einem Rechtsgut eines Einzelnen oder der Gemeinschaft zu rechtfertigen. Hier vermag zwar die objektiv-rechtliche Seite der Grundrechte die Schranke eines Freiheitsrechts auszuformen und näher zu definieren, diese Einschränkung der subjektiv-rechtlichen Seite ist aber stets eine lediglich ganz punktuelle und nur restriktiv gehandhabte. Andernfalls wären die in den Artikeln des Grundgesetzes formulierten Schrankenbestimmungen überflüssig, wären die Freiheiten sonst ohnehin nur in dem objektiv vorbestimmten Rahmen gewährleistet.<sup>671</sup>

Diese Problematik thematisieren auch die Richterinnen *Rupp-v. Brünneck* und der Richter *Simon* in ihrem abweichenden Sondervotum zum Zweiten Abtreibungsurteil, wenn sie darauf hinweisen, dass eine auf derartigen Erwägungen begründete Pflicht des Gesetzgebers zum Erlass von Strafnormen einer Verkehrung der Grundrechtsfunktion als Abwehrrecht in ihr Gegenteil gleichkomme.<sup>672</sup> *Jéand'Heur* kritisiert ebenfalls die Zurückdrängung des primär freiheitssichernden Gehalts der Grundrechte, in Bezug auf das Abtreibungsurteil des Art. 1 I und Art. 2 II GG, als umso delikater, je deutlicher eine Grundrechtskollision vorliegt, die im Wege der

<sup>666</sup> *Rupp*, AöR 101 (1976), 161 (165 f.).

<sup>667</sup> *Dürig*, AöR 81 (1956), 117 (119 ff.); Maunz/Dürig-Herdeggen, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 21.

<sup>668</sup> BVerfGE 7, 198 (205); 50, 290 (337); von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 1 Abs. 3 Rdnr. 175.

<sup>669</sup> von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 1 Abs. 3 Rdnr. 175.

<sup>670</sup> Dreier-Dreier, GG, Vorb. Rdnr. 84, 94; von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 1 Abs. 3 Rdnr. 175; Pieroth/Schlink, Grundrechte, § 6 I Rdnr. 218; *Jéand'Heur*, JZ 1995, 161 (163 f.).

<sup>671</sup> von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 1 Abs. 3 Rdnr. 178.

<sup>672</sup> BVerfGE 39, 1 (73 ff.).

Herstellung praktischer Konkordanz aufzulösen ist. Die Folge ist, so *Jeand'Heur*, eine „*Paralysierung des Abwägungsvorgangs*“.<sup>673</sup>

Auch eine Interpretation der Grundrechte dahingehend, dass sie nur werthafte Betätigungen schützen, aufgrund derer unabhängig von der Eröffnung eines personalen oder sachlichen Schutzbereiches diskutiert werden könnte, ob die in Frage stehende Handlung, hier die Durchführung eines genetischen Enhancements, werttheoretisch als für sich betrachtet gut zu beurteilen ist, kann nicht überzeugen. Diese würde verfassungsrechtlich geschützte Rechtsgüter nicht im Rahmen der Grundrechtsschranken berücksichtigen, sondern sie zu verbindlichen, verpflichtenden positiven Anleitungen für die Ausübung von Freiheitsrechten und die verfassungsrechtlichen Freiheitsgarantien aushöhlen.<sup>674</sup>

Daher lässt sich festhalten, dass eine objektive Dimension der Grundrechte nicht deren subjektiv-rechtlichen Charakter verdrängen und über die Tatsache, dass deren primäres Schutzziel der individuelle Träger des jeweiligen Grundrechts ist, hinwegtäuschen kann. Vielmehr verstärkt der objektiv-rechtliche Aspekt die individual-schützende Funktion.<sup>675</sup> Der Schutz von Gemeinwohlgütern kann und darf daher nicht auf dem Wege der Umdeutung der Grundrechte erreicht werden. Dieses zu gewährleisten ist Aufgabe der Grundrechtsschranken.<sup>676</sup> Entsprechend ist der Staat zum Schutze eines spezifischen und individuellen Grundrechtsträgers verpflichtet. Ein Schutz aber, der vollständig von einem bestimmten Träger losgelöst ist, vermag nicht über den objektiven Gehalt und die in den Grundrechten wie dem Menschenwürdesatz zum Ausdruck kommende Werteordnung begründet zu werden.<sup>677</sup> Mit hin gereicht auch dieser Ansatz nicht zu einer Ausweitung der Menschenwürde auf die Gameten.

#### **d) Das Konzept der Gattungswürde**

Wie erörtert, kommt man mit den bislang diskutierten, dem klassischen Anwendungsrahmen unterfallenden und der gängigen Interpretation entsprechenden Ansätzen ebenso wenig über das Erfordernis einer Individualisierung hinweg wie mit Versuchen, ein Verbot über eine grundrechtliche Vorwirkung oder eine objektiv-rechtliche Werteordnung zu begründen. Während bei somatischen Enhancements die subjektive Trägerschaft der Menschenwürde eindeutig zu beurteilen ist, deren Verletzung jedoch ausgeschlossen werden kann, ist die Beurteilung bei verbessernden Keimbahneingriffen zwar ungleich problematischer, führte im Ergebnis jedoch ebenfalls zu einer Verneinung der Eröffnung sowohl des subjektiven als auch des objektiven Schutzbereiches des Art. 1 I GG. Gleichwohl scheint weiterhin ein starkes Bedürfnis nach einer gesetzlichen Restriktion genverbessernder Eingriffe zu

<sup>673</sup> *Jeand'Heur*, JZ 1995, 161 (164).

<sup>674</sup> von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 1 Abs. 3 Rdnr. 180.

<sup>675</sup> So auch *Ossenbühl*, NJW 1976, 2100 (2104).

<sup>676</sup> von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 1 Abs. 3 Rdnr. 171.

<sup>677</sup> Im Ergebnis so auch *Wagner*, Der gentechnische Eingriff in die menschliche Keimbahn, S. 62.

bestehen, die möglichst umfassend und unumstößlich ist. In der juristischen Literatur wird daher versucht, das Konzept einer individualschützenden Menschenwürde auf die Gattung Mensch auszudehnen, sodass es auch die Menschheit oder, wie zuweilen formuliert wird, das Menschengeschlecht in den Blick nimmt. Schutzgut wird somit ein abstraktes Menschenbild und das Wesen der Menschheit, der sie ausmachende Kern.<sup>678</sup>

Der Gedanke, die Würde der Menschheit insgesamt könnte durch Handlungen gegenüber einzelnen Menschen verletzt werden, ist keineswegs ungeläufig. Bereits Kant sprach sich gegen Strafen aus, die so drastisch waren, dass sie, wenn auch der Täter selbst sich durch die Tat der Achtung seines Menschseins unwürdig gemacht hat, immer noch den Zuschauern „*Schamröthe abjagen, zu einer Gattung zu gehören, mit der man so verfahren darf*.“<sup>679</sup> Jedoch ist dieser Ansatz keineswegs unkritisiert geblieben. Der Umdefinition der ursprünglich individualschützenden Grundrechtsnorm des Art. 1 I GG wird zuvorderst entgegengehalten, dass sie auf nicht hinreichender (juristischer) Begründung und Herleitung fußt, sondern sich durch einen Ad-hoc-Charakter auszeichnet.<sup>680</sup> Eine Untersuchung dieser Konzepte im Hinblick auf die herkömmlichen Funktionen des Menschenwürdesatzes wäre jedoch zumindest wünschenswert. Thomas Gutmann stellt in diesem Zusammenhang fest, dass ein Konzept, welches den von Art. 1 I GG gewährten Schutz auf die Gattung ausweitet, dem klassischerweise absoluten Würdeschutz ein Kollektivgut gegenüberstellt, welches in der Lage ist, die Abwägungsfestigkeit der Menschenwürde zu durchbrechen und sich „*gegen den fundamentalen Achtungsanspruch Einzelner durchzusetzen*.“ Resultat wäre eine Degradierung eines absoluten zu einem abwägbaren, verhandelbaren Wert und eine Destruktion des fundamentalen Verfassungsprinzips der Menschenwürde.<sup>681</sup> Für das bisherige und konsenterte Verständnis der Menschenwürde ist eine solche extensive Interpretation des Art. 1 I GG in hohem Maße dysfunktional. Ein solcher Ansatz disqualifiziert sich alleine schon deswegen für die Berücksichtigung in einem spezifisch juristischen Kontext.

Daneben widerspricht diese Interpretation sowohl dem Wortlaut als auch der Entstehungsgeschichte der Verfassungsnorm, auf die er sich bezieht.<sup>682</sup> Dies entspricht ebenso der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung: Wann auch immer das Bundesverfassungsgericht sich auf einen Menschen als Angehörigen der Gattung Mensch bezieht, beruft es sich nicht auf eine etwaige Würde dieser Gattung selbst, sondern spricht der spezifischen Person bereits aus dem Grund Würde zu, dass sie eben dieser Gattung angehört.<sup>683</sup> Zentrale Erwägung hierbei ist jedoch nicht eine von der Gattung auf das ihr zugehörige Individuum herab strahlende Würde, son-

<sup>678</sup> Vergleiche nur etwa Benda, Erprobung der Menschenwürde am Beispiel der Humangenetik, S. 210 f.; Grimm, NJW 1989, S. 1310; Graf Vitzthum, Gentechnologie und Menschenwürdeargument, S. 119 f., 138.

<sup>679</sup> Kant, Metaphysik der Sitten, Ethische Elementarlehre, § 39, S. 463.

<sup>680</sup> Gutmann, „Gattungsethik“ als Grenze der Verfügung des Menschen über sich selbst?, S. 242.

<sup>681</sup> Gutmann, „Gattungsethik“ als Grenze der Verfügung des Menschen über sich selbst?, S. 243.

<sup>682</sup> Seelmann, Menschenwürde als Würde der Gattung – ein Problem des Paternalismus?, S. 213.

<sup>683</sup> Gutmann, „Gattungsethik“ als Grenze der Verfügung des Menschen über sich selbst?, S. 242.

dern der Umstand, dass an die Eröffnung des Schutzbereiches des Art. 1 I GG lediglich minimale Anforderungen gestellt und die Norm besonders inklusiv ausgestaltet werden soll.

Darüber hinaus wird in der Literatur aus einer solchen Würde der Gattung ein Unantastbarkeitsgebot hinsichtlich des menschlichen Genoms hergeleitet, welches Ausdruck der Achtung ist, die sich die Gattungswesen untereinander als jeweils einzigartige schulden. Das Schutzrecht, welches dem individuellen Träger zugutekommen soll, würde so aber in eine Pflicht gegenüber dem *humanum* gewandelt werden, welche die jeweils persönliche Autorität zur Verfügung über den eigenen Körper und somit zugleich Art. 1 I GG als Grundnorm personaler Autonomie in ihr Gegenteil verkehrt. Das Konzept einer Gattungswürde hätte sich somit nicht nur vom individualschützenden Ursprung der Menschenwürde emanzipiert sondern diesen sogleich gegen sich selbst ausgespielt.<sup>684</sup>

Solch massiv dysfunktionale, destruktive Rückwirkungen auf von breitem Konsens getragene Schutzzwecke des Art. 1 I GG sind mitnichten erträglich. Erwägungen, die sich auf eine besondere Schutzwürdigkeit von Menschenbildern und einen menschengeschlechtlichen Wesenskern beziehen, sind keine überzeugende und noch nicht einmal eine zulässige Verfassungsinterpretation.

### 3. Zwischenergebnis

In juristischer Hinsicht ist somit das Ende der auf Art. 1 I GG gestützten Argumentation gegen die Zulässigkeit genetischer Enhancements erreicht. Der Würdesatz der Verfassung vermag daher ein Verbot nicht zu rechtfertigen.

Inwiefern solche Interpretationsvarianten aber außerhalb der juristischen Dimension des Art. 1 I GG als bloßes politisches Ziel im demokratischen Prozess berücksichtigt werden dürfen, wird in einem letzten Abschnitt des vorliegenden Dissertationsvorhabens zu diskutieren sein.

## II. Argumente zweiter Ordnung

Wie dargelegt, gelingt es den Argumenten erster Ordnung nicht, eine absolute Grenzziehung hinsichtlich der Techniken eines genetischen Enhancements zu rechtfertigen. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass derart gentechnologische Eingriffe vollumfänglich zulässig bleiben müssen.<sup>685</sup> Zahlreiche weitere Aspekte begründen

<sup>684</sup> Eine tiefgehende Analyse findet sich bei Gutmann, „Gattungsethik“ als Grenze der Verfügung des Menschen über sich selbst?, S. 243 ff.; Gutmann, Säkularisierung und Normenbegründung, S. 247 f. So auch Neumann, ARSP 84 (1998), 153 (157).

<sup>685</sup> Ähnlich differenziert auch Greely, Of Nails and Hammers, S. 503 m.w.N. zwischen einer kategorischen Ablehnung biologischen Enhancements beim Menschen und nichtsdestoweniger bestehenden Folgeproblemen, wobei er sich auf Sicherheitserwägungen, den sozialen oder wirtschaftlichen Druck, durch den die sogenannte Wunsch-Medizin *de facto* zu einer Zwang-Medizin werden könnte sowie Fairness beschränkt.



weithin ein Bedürfnis restriktiver Regulierung und bedürfen der Berücksichtigung, Aushandlung und des Austarierens im Rahmen eines Gesetzgebungsprozesses, an dessen Ende ein im Wege der politischen Deliberation gefundener Ausgleich der konfligierenden Interessen steht, der jedoch keine unwiderrufliche Festschreibung enthält, sondern unter Umständen rein temporärer Natur sein kann und dem Wechsel politischer Mehrheiten unterliegt.

## 1. Risk-Management

Zumindest zurzeit stellen Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Techniken des genetischen Enhancements eine zentrale Kritik dar. Diese ist beispielsweise in dem Vorbringen impliziert, die Evolution hätte mit dem menschlichen Körper über Jahrtausende ein Meisterstück erschaffen, welches der heutige Mensch nicht innerhalb einiger weniger Jahre medizinischer und technischer Forschung zu verbessern in der Lage ist. In Analogie zu einem „*Master Engineer*“<sup>686</sup> wird der Evolution große Weisheit<sup>687</sup>, planvolle Gestaltung und fehlerfreie Perfektion unterstellt.<sup>688</sup> Unabhängig von der sich ebenfalls hieran anknüpfenden Forderung, demgegenüber Respekt zu wahren, und der Verwerfung von diesen durch die Evolution geschaffene „Werke“ verändernden Eingriffen als biologische Hybris, die ihrerseits problematische personale Zuschreibungen von Einstellungen und Werten wie Respekt und Würde zu nicht-personalen, noch nicht einmal körperlichen Vorgängen wie der Evolution enthalten und den Anschein der Anrufung einer höheren Wahrheit erwecken, sei sie nun auf religiösen Erwägungen begründet oder liege sie in einer mystischen, eventuell metaphysischen Erhöhung der Natur, drückt dieses Argument zugleich auch die Befürchtung aus, rein faktisch könne ein Eingriff in das menschliche Genom aufgrund dessen Komplexität und des bislang nur begrenzten menschlichen Verständnisses hiervon zu gravierenden Schädigungen desjenigen kommen, bei dem oder im Hinblick auf den dieser Eingriff vorgenommen wird.<sup>689</sup> Auch der *President's Council on Bioethics* führt aus, dass menschliche Physis und Psyche das ausbalancierte, in seinem Gleichgewicht aber delikate Resultat von Äonen präzisieren-

<sup>686</sup> Diesen Begriff nutzt – ebenfalls kritisch – etwa *Buchanan*, *Beyond Humanity?*, S. 155 ff.; *Buchanan*, *Better than Human*, S. 27.

<sup>687</sup> So zum Beispiel *Resnik*, *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics* 9 (2000), 365 (370): „*nature's wisdom*“.

<sup>688</sup> Andere wiederum verwischen die Grenzen zwischen der in Frage gestellten intellektuellen Fähigkeit des Menschen, aufgrund erworbenen Wissens genetische Eingriffe vorzunehmen und die Folgen abzuschätzen, und einer Allwissenheit und Allgegenwärtigkeit Gottes. Vor dem Hintergrund des Glaubenssatzes der planvollen Gestaltung der Welt durch Gott wird die These begründet, dass das zu derartigen Eingriffen erforderliche Wissen und die notwendigen Fähigkeiten außerhalb der Reichweite des Menschen bleiben *sollen* (eine solche These beschreiben etwa *Baylis/Roberts*, *Bioethics* 18 (1), 1 (6)). So eine Argumentation jedoch vermischt zwei unterschiedliche und zu trennende Fragen, nämlich einmal, ob die Durchführung (gefahrlos oder vertretbar) möglich ist, und sodann, ob dies daneben anderweitige Grenzen, etwa religiös gesetzte, überschreitet.

<sup>689</sup> *Buchanan*, *Beyond Humanity?*, S. 157; *Baylis/Robert*, *Bioethics* 18 (1), 1 (7).



der und perfektionierender Evolution sind, die mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit durch, da unser Wissen und Verständnis von der Evolution nur oberflächlich sind, notwendigerweise schlecht durchdachten „Verbesserungen“ gefährdet sind.<sup>690</sup> Die Befürchtung ist, das Streben nach einer Veränderung menschlicher Gene werde mit dem natürlichen Prozess der Evolution und natürlichen Selektion kollidieren, die, prä-darwinistisch betrachtet, teleologischen Wert hat und das, was aus ihr hervorgeht, *per se* gut ist.<sup>691</sup>

Der vergleichende Verweis auf eine Unfehlbarkeit der Natur und Evolution hingegen ist schlicht nicht zutreffend. Unter Verweis auf *Darwins* Ausruf von den unbeholfenen, verschwenderischen und grausamen Werken, die die Natur gleich einem Pfusch hervorbringt, führt *Buchanan* beispielhaft die im Gegensatz zu den meisten anderen Säugetieren bestehende und keine anderweitigen Vorteile generierende, durch eine Genmutation bedingte menschliche Unfähigkeit, Vitamin C zu bio-synthetisieren, den Umstand, dass der Geburtskanal durch das Becken führt und die Geburt so lebensbedrohlich sein kann, die Anfälligkeit der Nebenhöhlen oder die Tatsache, dass bei männlichen Säugetieren die Harnwege durch die Prostata anstatt um diese herum verlaufen, was bei deren Anschwellen zu einer Blockierung, Infektion und einem Funktionsverlust der Harnwege führen kann, an.<sup>692</sup> Aus einer Weisheit der Natur und einer Interpretation der Evolution als „*Master Engineer*“<sup>693</sup> lassen sich daher überzeugender Weise keine Strategien, zumindest keine des Verbotes, zum Umgang mit den der Gentechnologie inhärenten Risiken ableiten.

Auch begrifflich ist es schwierig, vom Menschen – oder anderen Organismen – als Meisterstücke zu sprechen. Dieser Begriff impliziert Perfektion und Vollendung, Stabilität und Konstanz, die so rein tatsächlich nicht existieren. Er steht dem der Evolution geradezu diametral gegenüber, ist die Anpassung an die veränderte – und seien sie durch den jeweiligen Organismus gegebenenfalls selbst veränderte – Lebenswelt doch gerade deren zentrales Merkmal. Eine Formulierung, ein evolutionär entwickelter Organismus sei vorsichtig austariert, impliziert daher eine Persistenz, die nicht vorhanden ist. Dabei geht die Evolution, anders als ein Ingenieur, nicht von einem vorab aufgestellten und durchdachten Plan aus, sondern reagiert, mitunter lediglich kurzfristig, auf Umweltveränderungen, ohne dabei unter Umständen negative Langzeitfolgen zu berücksichtigen.<sup>694</sup>

Auch wenn das Bild des „*Master Engineer*“<sup>695</sup> und seines Meisterstücks nicht einzuleuchten vermag, lassen sich die besagten Risiken nicht leugnen. Angesichts der bis *dato* wenig absehbaren Nebeneffekte, überraschenden Folgen sowie deren eventueller Unumkehrbarkeit stellt sich daher die von jeglichen Vorannahmen losgelöste Frage, ob das immense Risiko mit Blick auf Art. 2 II 1 GG, ausweislich dessen Wortlautes „*jeder [...] das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit*“

<sup>690</sup> *The President's Council on Bioethics*, *Beyond Therapy*, S. 288.

<sup>691</sup> *Buchanan*, *Better than Human*, S. 16 f.

<sup>692</sup> *Buchanan*, *Beyond Humanity?*, S. 157; *Buchanan*, *Better than Human*, S. 30 f.

<sup>693</sup> *Buchanan*, *Beyond Humanity?*, S. 155 ff.; *Buchanan*, *Better than Human*, S. 27.

<sup>694</sup> *Buchanan*, *Better than Human*, S. 29.

<sup>695</sup> *Buchanan*, *Beyond Humanity?*, S. 155 ff.; *Buchanan*, *Better than Human*, S. 27.

hat, vereinbar ist. Hierunter wird das Recht auf körperliches Dasein und biologisch-physiologische Existenz,<sup>696</sup> sowie Gesundheit im biologisch-physiologischen Sinn verstanden.<sup>697</sup>

### **a) Schutz des Lebens, Art. 2 II 1, 1. Alt. GG**

Zunächst sollen die Implikationen des Grundrechts auf Leben gemäß Art. 2 II 1, 1. Alt. GG untersucht werden.

#### **aa) Der Schutzbereich des Art. 2 II 1, 1. Alt. GG**

Verfahren des genetischen Enhancements könnten gegen das Recht des Embryos auf Leben und körperliche Unversehrtheit aus Art. 2 II 1 GG verstoßen, was ihr Verbot rechtfertigen könnte. Dies setzt voraus, dass die Eingriffsobjekte beim genetischen Enhancement, also die Gameten, die Zygote oder der spätere Embryo beziehungsweise die Person, deren somatische Zellen modifiziert werden sollen, Träger der Grundrechte aus Art. 2 II 1 GG sind und genetisches Enhancement einen nicht gerechtfertigten Eingriff in diese Rechte darstellt.

#### *(1) Lebensbeginn aus naturwissenschaftlicher Sicht*

In biologischer Hinsicht ist heute unumstritten, dass das Leben eines Menschen zu dem Zeitpunkt beginnt, in dem sein genetisches Programm erstmals vorliegt. Dies geschieht mit der Befruchtung, die mit der Konjugation, das heißt der Verschmelzung von männlichem und weiblichem Vorkern, abgeschlossen ist. Erst zu diesem Zeitpunkt – und nicht etwa bereits mit der Imprägnation, also dem Eindringen des Spermiums in das Plasma der Eizelle – ist das genetische Programm des Embryos geschrieben, da der mütterliche haploide Chromosomensatz der Eizelle sich erst dann mit dem väterlichen haploiden Chromosomensatz der Samenzelle zu dem diploiden Chromosomensatz der Zygote vereinigt.<sup>698</sup> Hiermit liegt artspezifisches menschliches Leben im Gegensatz zu sonstigem vegetativen Leben vor.<sup>699</sup>

Diese den deskriptiven Lebensbegriff ausmachenden naturwissenschaftlichen Erkenntnisse haben jedoch keine präjudizielle Wirkung auf den Beginn des verfassungsrechtlichen Lebensschutzes. Diesem liegt vielmehr ein normativer Le-

<sup>696</sup> Dreier-Schulze-Fielitz, GG, Art. 2 II Rdnr. 25; von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 2 Abs. 2 Rdnr. 192.

<sup>697</sup> BVerfGE 56, 54 (73); von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 2 Abs. 2 Rdnr. 193.

<sup>698</sup> Richtlinien zur Forschung an frühen menschlichen Embryonen der Bundesärztekammer, abgedruckt in: DÄBl 1985, A 3757–3764.

<sup>699</sup> Giwer, Präimplantationsdiagnostik, S. 62 f.

bensbegriff zu Grunde, der im Hinblick auf die jeweilige Schutznorm – vorliegend Art. 2 II 1, 1. Alt. GG – zu bestimmen ist.<sup>700</sup>

### (2) Wortlautinterpretation

Art. 2 II 1, 1. Alt. GG erwähnt nicht den Embryo als Zurechnungssubjekt des Grundrechts auf Leben. Diese Verfassungsnorm verwendet vielmehr den Begriff „jeder“. Dies steht im Kontext des Art. 2 II 1 GG für „jeder Mensch“. Ist von einem ungeborenen, sich noch im Mutterleib und in einer frühen Phase seiner Entwicklung befindlichen menschlichen Lebewesen die Rede, so spricht man von „Embryo“, „Fötus“, „befruchtete Eizelle“ oder „Leibesfrucht“. Die Bezeichnung „Mensch“ tritt im gewöhnlichen Sprachgebrauch kaum auf, wenn auch zuweilen vom „*werdenden Menschen*“ gesprochen wird oder davon, „*ein Kind zu erwarten*“.<sup>701</sup>

Im juristischen Sprachgebrauch, insbesondere in den §§ 218 ff. StGB, wird der Embryo nicht als Mensch bezeichnet. Eine Ausnahme stellt jedoch § 219 StGB dar: § 219 I StGB spricht vom „*ungeborenen Leben*“ und § 219 II StGB vom „*Kind*“.

Der Begriff „jeder“ lässt sich daher nicht eindeutig mit Hilfe der Wortlautinterpretation bestimmen.<sup>702</sup>

### (3) Entstehungsgeschichte

Hinsichtlich der Frage, ob der Schutz des Lebens aus Art. 2 II 1, 1. Alt. GG auch das keimende Leben umfasst, bestand, so bereits oben ausgeführt, im Parlamentarischen Rat keine Einigkeit. Wie dargestellt kann auch aus der Entstehungsgeschichte der Verfassungsnorm nicht auf den Inhalt des normativen Begriffs „jeder Mensch“ geschlossen werden.<sup>703</sup> Hierfür spricht auch, dass der Parlamentarische Rat sich der semantischen Unbestimmtheit der Norm bewusst war, man diese Frage jedoch nicht für die Zukunft präjudizieren wollte.<sup>704</sup>

### (4) Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts

Der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zufolge ist jedenfalls der Embryo nach der Einnistung in die Gebärmutter von der Lebensschutzgarantie des Art. 2 II 1, 1. Alt. GG erfasst. In dem sogenannten Ersten Abtreibungsurteil<sup>705</sup> aus

<sup>700</sup> Dreier-Schulze-Fielitz, GG, Art. 2 II Rdnr. 26; Isensee/Kirchhof-Lorenz, HStR VI, § 128 Rdnr. 8; Hilgendorf, NJW 1997, 3074 (3075); Giwer, Präimplantationsdiagnostik, S. 63.

<sup>701</sup> Giwer, Präimplantationsdiagnostik, S. 63.

<sup>702</sup> Zu diesem Ergebnis kommt auch Giwer, Präimplantationsdiagnostik, S. 63; zur Wortlautinterpretation weiter BVerfGE 39, 1 (37 ff.); Lübke, KritVj 76 (1993), 313 (314); Hoerster, JR 1995, 51 ff.; Hoerster, JuS 1989, 172 f.; a. A. Weiß, JR 1992, 182 (183 f.), der vertritt, dass sich „jeder“ auch auf das ungeborene Leben bezieht.

<sup>703</sup> Esser, JZ 1975, 555 (556); Herzog, JR 1969, 441 f.; Kriele, JZ 1975, 222 (224 f.); Merkel, Forschungsobjekt Embryo, S. 26 ff.; a. A. Weiß, JR 1992, 182 (183 f.).

<sup>704</sup> Hoerster, JR 1995, 51.

<sup>705</sup> BVerfGE 39, 1.

dem Jahre 1975 hat der Erste Senat des Gerichts judiziert, dass Art. 2 II 1, 1. Alt. GG auch das sich im Mutterleib entwickelnde Leben als „*selbständiges Rechtsgut*“ erfasst.<sup>706</sup> Dabei ging das Gericht jedoch davon aus, dass von Leben im Sinne der geschichtlichen Existenz eines menschlichen Individuums jedenfalls erst nach der Empfängnis, also der Nidation und Individuation, gesprochen werden könne. „Jeder“ im Sinne des Art. 2 II 1, 1. Alt. GG sei daher auch der *nasciturus*.<sup>707</sup>

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat diese Rechtsprechung im Zweiten Abtreibungsurteil<sup>708</sup> aus dem Jahre 1993 übernommen. Jedenfalls nach erfolgter Nidation handle es sich bei dem ungeborenen um ein individuelles, in seiner genetischen Identität festgelegtes, nicht mehr teilbares Leben, das sich spätestens von diesem Zeitpunkt an nicht mehr erst zum Menschen, sondern als Mensch entwickle.<sup>709</sup> Ob die Lebensgarantie auch schon den pränidativen Embryo umfasst, ließ das Gericht jedoch auch in diesem Urteil offen, da es diese Frage nicht für entscheidungserheblich hielt. Allerdings merkte es an, dass die Erkenntnisse der medizinischen Anthropologie es nahe legten, dass menschliches Leben bereits mit der Verschmelzung von Ei und Samen entstehe.<sup>710</sup> Dies könnte zumindest als Indiz für eine Tendenz des Bundesverfassungsgerichts gedeutet werden, auch dem pränidativen Embryo das Recht auf Leben aus Art. 2 II 1, 1. Alt. GG zuzusprechen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass den Naturwissenschaften und der Medizin kein Definitionsmonopol hinsichtlich des normativen Verfassungsbegriffs des Lebens zukommt. Trotz der einheitlichen Antwort auf die Frage nach dem naturwissenschaftlichen Beginn menschlichen Lebens bleibt sein verfassungsrechtlich-tatbestandlicher Beginn umstritten, handelt es sich hierbei doch nicht um einen naturwissenschaftlichen Sachverhalt, sondern um eine vom Verfassungsgesetzgeber und Verfassungsinterpreten normativ-wertend zu entscheidende Frage.<sup>711</sup>

### (5) Zäsuren in der Ontogenese

Häufig wird zur Beantwortung der Frage, ab welchem Zeitpunkt die Lebensschutzgarantie des Art. 2 II 1, 1. Alt. GG eingreift, auf verschiedene Zäsuren in der Entwicklung des Embryos und des Fötus hin zum späteren geborenen Menschen, beziehungsweise von der Zygote zu einem differenzierten Organismus verwiesen.<sup>712</sup>

<sup>706</sup> BVerfGE 39, 1 (36).

<sup>707</sup> BVerfGE 39, 1 (37).

<sup>708</sup> BVerfGE 88, 203.

<sup>709</sup> BVerfGE 88, 203 (251 f.).

<sup>710</sup> BVerfGE 88, 203 (251).

<sup>711</sup> Dreier-Dreier, GG, Art. 2 II Rdnr. 26 f.; Sachs-Murswiek, GG, Art. 2 Rdnr. 144 glaubt zu erkennen, dass die Verwendung des Begriffs „Leben“ eine deskriptive Interpretation nahelegt und somit auf das biologische Leben verweist.

<sup>712</sup> Einen Überblick liefert etwa Dreier-Schulze-Fielitz, GG, Art. 2 II Rdnr. 28.

*(a) Nidation oder Individuation*

Zum Teil wird angenommen, dass der Schutz des Art. 2 II 1, 1. Alt. GG erst mit der Nidation, die etwa am 14. Tag nach der Befruchtung der Eizelle abgeschlossen ist, einsetzt. Dies entspreche der Regelung des § 218 I 2 StGB, der zufolge Handlungen, deren Wirkung vor Abschluss der Einnistung eintreten, wie etwa die Einnahme der „Pille danach“, nicht als Schwangerschaftsabbruch gelten.<sup>713</sup> In der Vornidationsphase *in vivo* betreibe die Natur zudem selbst eine verschwenderische Embryonenselektion, weswegen 70 % der Embryonen überhaupt nicht zur Einnistung gelangen. Erst ab dem Zeitpunkt der Nidation hat ein Embryo *in vivo* daher eine reale Lebenschance.<sup>714</sup>

Gegen diese Auffassung spricht jedoch, dass das Abstellen auf eine Lebenschance zu dem Schluss führen könnte, lebenden Menschen, deren natürliche Lebenschance verringert ist, ebenfalls ein Lebensrecht abzuerkennen. Auch der Hinweis auf den verschwenderischen Umgang der Natur mit Embryonen vor der Einnistung kann nicht überzeugen. Solche Naturereignisse können den Menschen nicht dazu berechtigen, selbst diese Ereignisse herbeizuführen. Ebenso streitet eine hohe Verlustrate keineswegs für eine Verringerung des Schutzes der Embryonen. Mit einer erhöhten Säuglingssterblichkeit lässt sich schließlich auch nicht eine Rücknahme des Lebensschutzes von Säuglingen begründen.<sup>715</sup> Der Verweis auf § 218 I 2 StGB vermag diese Auffassung ebenso nicht zu stützen. Das einfache Recht kann grundsätzlich nicht zur Definition eines grundrechtlichen Schutzbereiches herangezogen werden. Diese Strafrechtsnorm enthält zudem keine Definition des Lebensbeginns. Sie legt lediglich fest, ab welchem Zeitpunkt ein Handeln einen Schwangerschaftsabbruch darstellt. Dies ist im Lichte der Beweisschwierigkeiten zu sehen, die sich daraus ergeben, dass sich *in vivo* weder eine etwaige Kausalität einer Verhütungsmaßnahme aufgrund der natürlich hohen Sterblichkeitsrate noch die Befruchtung und die Entwicklung eines Embryos bis zur Nidation nachweisen lassen.<sup>716</sup> Zur Festlegung des Beginn menschlichen Lebens im Sinne des Art. 2 II 1, 1. Alt. GG sind diese Kriterien jedoch untauglich.

Wird auf die Individuation als Beginn des durch Art. 2 II 1, 1. Alt. GG geschützten Lebens abgestellt, so wird dies damit begründet, dass bis zu diesem Zeitpunkt noch eine eineiige Mehrlingsbildung möglich sei und daher nicht von einem menschlichen Einzelwesen gesprochen werden könne. Der Zeitpunkt der Individuation – etwa 14 Tage nach Befruchtung – ist auch in England und den USA der Moment, ab dem der Embryo als zu schützendes Leben betrachtet wird. Dennoch besteht während der Präembryonalphase vor der Individuation keine absolute Verfügbarkeit über Embryonen. Vielmehr handele es sich hierbei um latentes menschl-

<sup>713</sup> Giwer, Präimplantationsdiagnostik, S. 66.

<sup>714</sup> Giwer, Präimplantationsdiagnostik, S. 66 f.; Rosenau, Reproduktives und therapeutisches Klonen, S. 771.

<sup>715</sup> Giwer, Präimplantationsdiagnostik, S. 68.

<sup>716</sup> Eser, Lexikon der Bioethik, Band 2, Eintrag „Lebensbeginn“, S. 540.

ches Leben, dem ein Schutz zukommt, dessen Intensität zwischen der des Schutzes realen und bloß potenziellen menschlichen Lebens anzusiedeln sei.<sup>717</sup>

Gegen diese Auffassung lässt sich jedoch einwenden, dass die Tatsache, dass sich aus einer befruchteten Eizelle nicht bloß ein Mensch, sondern mehrere entwickeln können, den Schutzanspruch nicht verringern kann. Mit diesem Argument könne man ebenso auch für einen erhöhten Schutzanspruch argumentieren, da eventuell sogar mehrere (spätere) Individuen bedroht seien.<sup>718</sup>

Auch dieses Kriterium führt somit nicht zu konsequenten und widerspruchsfreien Ergebnissen und ist daher zu verwerfen.

### *(b) Beginn der Hirntätigkeit*

Als weiterer Anknüpfungspunkt für den Beginn des Lebens im Sinne des Art. 2 II 1, 1. Alt. GG wird der Beginn der Hirntätigkeit als Parallele zum Hirntod diskutiert. Hierbei wird darauf verwiesen, dass die Grundlagen menschlicher Personhaftigkeit mit der Entwicklung des Gehirns verbunden sind. Im Lichte dieses Personseins werde in der Tradition der abendländischen Kultur menschliches Leben verstanden und bewertet. So schlägt der Philosoph *Hans-Martin Sass* vor, dem werdenden menschlichen Leben ab dem 57. Tag nach der Befruchtung den verfassungsrechtlichen Lebensschutz zukommen zu lassen. Zwar beginne die Hirntätigkeit erst nach dem 70. Tag, aber bereits am 57. Tage sei biologisch schon das Zellmaterial vorhanden, aus dem später funktionierendes Organleben entstehe. Dies begreift er als „*ethisches Sicherheitsnetz*“.<sup>719</sup>

Gegen diese Meinung spricht jedoch, dass der Beginn der Hirntätigkeit keinesfalls ein so unverrückbarer Anfangspunkt ist, wie der Hirntod einen irreversiblen biomedizinischen Endpunkt des Individuallebens darstellt. Stellt man auf den Beginn der Hirntätigkeit als Lebensbeginn ab, so bedeutet dies lediglich eine Zuweisung des Menschen auf eine Funktion, die er im späteren Leben erfüllen wird, nämlich denkender Mensch zu sein. Identitäts- und existenzbegründend ist der Beginn der Hirntätigkeit jedoch keinesfalls.<sup>720</sup>

### *(c) Erste Kindsbewegungen*

Zum Teil wird vertreten, dass ein durch Art. 2 II 1, 1. Alt. GG geschütztes Leben erst dann beginne, wenn die Mutter die ersten Bewegungen des Kindes spürt. Dies ist zwischen der 16. und 18. Woche der Fall. Zu diesem Zeitpunkt entwickle sich das körperliche Bewusstsein der Frau von der Existenz des Kindes als ein eigenständiges Wesen. Ebenso entstehe eine intensivere Bindung.<sup>721</sup>

<sup>717</sup> *Coester-Waltjen*, FamRZ 1984, 230 (235).

<sup>718</sup> *Hirsch*, MedR 1987, 12 (15); *Sternberg-Lieben*, JuS 1986, 673 (677).

<sup>719</sup> *Giwer*, Präimplantationsdiagnostik, S. 68 f.

<sup>720</sup> *Giwer*, Präimplantationsdiagnostik, S. 69.

<sup>721</sup> *Giwer*, Präimplantationsdiagnostik, S. 69 f.

Auch in der Strafrechtsgeschichte haben die ersten Kindsbewegungen Bedeutung, da ein Schwangerschaftsabbruch bis zu diesem Zeitpunkt milder bestraft wurde. So wurde in der mittelalterlichen christlichen Lehre *Thomas von Aquins* vertreten, dass die Beseelung der Leibesfrucht mit den ersten wahrnehmbaren Bewegungen des Kindes zusammenfalle.<sup>722</sup>

Diese Auffassung vermag jedoch ebenfalls nicht zu überzeugen. Zunächst nimmt das werdende Leben schon vor diesem Zeitpunkt menschliches Aussehen an. Die Fähigkeit der Mutter, die Bewegungen ihres Kindes zu spüren, ist für die Beurteilung des Lebensbeginns des Kindes daher nicht sachgerecht. Auch das psychologische Argument der intensiveren Bindung zwischen Mutter und Kind lässt keine andere Beurteilung zu. Schließlich ermöglichen modernste Ultraschallaufnahmen von Beginn der Schwangerschaft an die Beobachtung des Kindes.<sup>723</sup> Des Weiteren weicht der Zeitpunkt, in dem die Frau erstmals Bewegungen des Kindes wahrnimmt, von Fall zu Fall beachtlich ab. Es gibt sogar Fälle, in denen die Frau von ihrer Schwangerschaft bis zum Einsetzen der Wehen, die auch dann noch häufig als starke Bauchschmerzen interpretiert wurden, nicht wusste. Ein Abstellen auf die Wahrnehmung der Frau ist daher für die Beantwortung der Frage nach dem Beginn des Lebensschutzes untauglich.

#### (d) *Extrauterine Lebensfähigkeit*

Im Jahre 1973 sprach der US-amerikanische *Supreme Court* im Fall *Roe v. Wade*<sup>724</sup> Frauen ein weitreichendes Recht zur Entscheidung über einen Schwangerschaftsabbruch zu. Bis zum Ende des ersten Drittels der Schwangerschaft sollte diese Entscheidung alleine der Frau überlassen sein. Bis zur Lebensfähigkeit des Kindes außerhalb des Mutterleibes darf der Staat ausschließlich solche Regelungen treffen, die dem Schutz der Gesundheit der Mutter dienen. Erst ab individuell zu bestimmender extrauteriner Lebensfähigkeit des Kindes darf der Staat dieser Entscheidung zufolge Schwangerschaftsabbrüche unter Berücksichtigung der Gesundheit der Frau verbieten, sofern nicht Leben oder Gesundheit der Frau gefährdet ist. Begründet wurde dies mit dem *right of privacy* der Frau. Ein dieses Recht der Frau und deren Entscheidungsfreiheit einschränkendes Lebensrecht des Embryos besteht laut dieser Entscheidung bis zur extrauterinen Lebensfähigkeit nicht, da bis dahin der Fötus keine Person im Sinne des *Fourteenth Amendment*, des 14. Zusatzartikels der US-amerikanischen Verfassung, ist, der vorschreibt „*nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law*“<sup>725</sup>. Die meisten Vorschriften der Verfassung verwendeten den Begriff der Person nur im Hinblick

<sup>722</sup> BVerfGE 39, 1 (31).

<sup>723</sup> Gíwer, Präimplantationsdiagnostik, S. 70.

<sup>724</sup> 410 U.S. 113 (22. Januar 1973); dieses Urteil mit denen des Bundesverfassungsgerichts zum Schwangerschaftsabbruch vergleichend Brugger, NJW 1986, 896 ff.; zu dieser Entscheidung sowie deren Auswirkungen auf Gesellschaft, Politik und spätere Gerichtsentscheidungen [http://en.wikipedia.org/wiki/Roe\\_v.\\_Wade](http://en.wikipedia.org/wiki/Roe_v._Wade) (zuletzt aufgerufen am 11.12.2012); eine deutsche Übersetzung von Bleckmann findet sich in: EuGRZ 1974, 52 ff.

<sup>725</sup> Zit. nach Brugger, NJW 1986, 896.



auf bereits geborene Menschen, sodass es sich hiernach bei einem Fötus zwar nur, aber auch schon um potentielles Leben handelt.<sup>726</sup>

Angesichts der erheblichen gesellschaftlichen<sup>727</sup> sowie verfassungsrechtlich-methodischen<sup>728</sup> Kritik, die diese Entscheidung in den USA ausgelöst hat, kann sie keine umfassende Interpretationshilfe für das deutsche Verfassungsrecht darstellen. Unterschiedliche soziale Strukturen, Mentalitäten, religiöse Bindungen und Verhaltensweisen ließen zudem eine Übertragung ausländischer Erfahrungen auf die Bundesrepublik Deutschland nicht zu.<sup>729</sup> Der *U.S. Supreme Court* stellte bei seiner Entscheidung zudem auf die seelischen und körperlichen Beeinträchtigungen der Frau ab, die durch eine ungewollte Schwangerschaft ausgelöst werden können.<sup>730</sup> Wie das Gericht jedoch im Falle einer extrakorporalen Befruchtung entschieden hätte, ist ungewiss. Die Auffassung, der zufolge dem Embryo ein Lebensrecht erst mit extrauteriner Lebensfähigkeit zuzusprechen ist, erscheint auch im Hinblick auf die fortschreitenden Entwicklungen der Medizin willkürlich,<sup>731</sup> was der Annahme dieser Zäsur als normative Antwort auf die Frage nach dem Beginn des Lebens entgegensteht.

#### *(e) Geburt oder Fähigkeit zur autonomen Entschlussfassung*

Zum Teil wird als Beginn des durch Art. 2 II 1, 1. Alt. GG geschützten Lebens auch erst die Geburt oder die Fähigkeit zur autonomen Entschlussfassung angenommen.

Der australische Philosoph *Peter Singer* etwa sieht in dem Embryo zwar ein menschliches Wesen.<sup>732</sup> Für die Frage nach der Lebensschutzgarantie sei dies jedoch aus ethischer Sicht ohne Bedeutung.<sup>733</sup> Entscheidend sei hierfür vielmehr die Person-Qualität eines Menschen, die von der Ausprägung bestimmter Merkmale wie einem Mindestmaß an Intelligenz, Selbstbewusstsein, Gedächtnis und Zukunftssorge abhängig sei.<sup>734</sup> Diese These steht im Zusammenhang mit der von *Singer* vertretenen utilitaristischen Ethik, die Handlungen im Blick auf ihre Folgen betrachtet und bewertet<sup>735</sup> und dabei die Interessen der Betroffenen berücksichtigt. Moralisches Handeln im Sinne dieser utilitaristischen Ethik setzt daher voraus, dass jedes Individuum die Interessen all derjenigen zu berücksichtigen hat, die von seinem Handeln betroffen sind. Diese hat er abzuwägen und den Handlungsverlauf zu wählen, der die Interessen der Beteiligten optimal realisiert.<sup>736</sup> Embryonen und

<sup>726</sup> Brugger, NJW 1986, 896 (897); Stürner, JZ 1990, 709 (714).

<sup>727</sup> Kuhlmann, Abtreibung und Selbstbestimmung, S. 49 ff.

<sup>728</sup> Brugger, NJW 1986, 896 (897).

<sup>729</sup> BVerfGE 39, 1 (60).

<sup>730</sup> Zit. nach Kuhlmann, Abtreibung und Selbstbestimmung, S. 52.

<sup>731</sup> Stürner, JZ 1990, 709 (715).

<sup>732</sup> Singer, Praktische Ethik, S. 179 ff.

<sup>733</sup> Singer, Praktische Ethik, S. 121 ff.

<sup>734</sup> Singer, Praktische Ethik, S. 118 ff.

<sup>735</sup> Honnefelder, Lexikon der Bioethik, Band 1, Eintrag „Ethik“, S. 658.

<sup>736</sup> Singer, Praktische Ethik, S. 30.

auch Neugeborene seien jedoch nicht fähig, Leiden oder Freude als elementare Voraussetzung für das Vorliegen von Interessen zu empfinden. Weder Interessen noch die beschriebene Person-Qualität seien daher bei ihnen vorhanden und könnten folglich auch nicht frustriert werden. Deswegen sei Embryonen und auch Neugeborenen für eine kurze Zeitspanne nach der Geburt von etwa einer Woche ein volles legales Recht auf Leben abzusprechen.<sup>737</sup> *Singer* stellt jedoch die moralische Forderung, Wesen, die kein Überlebensinteresse entwickeln können, keine Schmerzen zuzufügen.<sup>738</sup>

Auch der Rechtsphilosoph *Norbert Hoerster* vertritt die Auffassung, dass ein ständiges Lebensrecht eines Menschen erst mit dessen Geburt anzuerkennen ist.<sup>739</sup> Grund für ein Tötungsverbot und damit korrespondierend ein Lebensrecht sei die Personalität der Menschen. Um ein personales Wesen handle es sich jedoch nur bei einem solchen, das Ichbewusstsein und Rationalität besitze und Interessen und Bedürfnisse habe, die über sein momentanes Dasein im Sinne eines bloßen Überlebensmechanismus hinausgehen. Ein solches Interesse könne etwa der Wunsch sein, möglichst lange zu leben.<sup>740</sup> Ein solches Interesse habe der *nasciturus* als bloße potentielle Person im Gegensatz zu einer aktuellen Person jedoch nicht.<sup>741</sup> Unter einer Freigabe zur Tötung leide ein Embryo daher ebenso wenig wie eine unbefruchtete Eizelle.<sup>742</sup> Zwar setze die relevante Bewusstseinsbildung erst im Laufe des zweiten Lebensjahres ein. *Hoerster* wählt dennoch die Geburt als Beginn eines absoluten Lebensrechts, da diese die einzige Grenze sei, die einen effizienten Lebensschutz zulasse.<sup>743</sup>

Vereinzelte weitere Stimmen in der deutschen rechtswissenschaftlichen Literatur, die ebenfalls erst die Geburt als den Beginn der verfassungsrechtlichen Lebensschutzgarantie sehen, wollen jedoch auch bereits das vorgeburtliche Leben über die Ausstrahlungswirkung<sup>744</sup> oder den objektivrechtlichen Gehalt<sup>745</sup> des Art. 2 II GG geschützt wissen.

Problematisch im Hinblick auf die von *Singer* und *Hoerster* vertretene Auffassung ist jedoch, dass man, würde man ihre Gedanken konsequent zu Ende führen, auch Menschen mit schwerster geistiger Behinderung oder irreversibel Komatösen

---

<sup>737</sup> *Singer*, Praktische Ethik, S. 85, 221 ff.; zu der Annahme, dass ein Lebensrecht nur demjenigen Wesen zuzusprechen ist, das in der Lage ist, auf die eigene Zukunft bezogene Wünsche und Interessen zu besitzen, und beim Fehlen eines Tötungsverbotes unter ständiger Todesangst leiden würde, auch *Brohm*, Jus 1998, 197 (200).

<sup>738</sup> *Singer*, Praktische Ethik, S. 85.

<sup>739</sup> *Hoerster*, JuS 1989, 172 (178).

<sup>740</sup> *Hoerster*, JuS 1989, 172 (175); *Hoerster*, JZ 1982, 265 (269 f.); *Hoerster*, Abtreibung im säkularen Staat, S. 13 ff., 19 ff.

<sup>741</sup> *Hoerster*, Abtreibung im säkularen Staat, S. 79 f.

<sup>742</sup> *Hoerster*, JuS 1989, 172 (175 f.).

<sup>743</sup> *Hoerster*, JuS 1989, 172 (178).

<sup>744</sup> *Jerouschek*, JZ 1989, 279 (285), allerdings in Bezug auf den Schwangerschaftsabbruch und Art. 2 i. V. m. Art. 1 GG.

<sup>745</sup> *Lübbe*, KritVj 76 (1993), 313 (315).

ein Recht auf Leben absprechen müsste.<sup>746</sup> Dies widerspräche allerdings neben der moralischen Unvertretbarkeit auch dem Diskriminierungsverbot des Art. 3 III 2 GG. Schon im Hinblick auf das Prinzip der Einheit der Verfassung, demzufolge die Verfassungsnormen so auszulegen sind, dass sie nicht in Konflikt miteinander geraten, kann die Relativierung des Schutzes aus Art. 2 II 1, 1. Alt. GG nicht Bestand haben.<sup>747</sup> Auch ist diese Meinung mit dem Willen des historischen Gesetzgebers unvereinbar. Dieser wollte das Recht auf Leben nach den Erfahrungen mit dem nationalsozialistischen Regime grundrechtlich verbürgen<sup>748</sup> und den Menschen vor missbräuchlicher Verwendung staatlicher Definitionsgewalt schützen. Menschliche Existenz sollte daher unabhängig vom Wert des konkreten Lebens aufrechterhalten werden.<sup>749</sup> Zwar ist, wie bereits dargelegt, unsicher, ob der Parlamentarische Rat diesen Schutz auch dem ungeborenen und insbesondere dem pränativen menschlichen Leben zukommen lassen wollte. Macht man den Lebensschutz aber abhängig von der intellektuellen Leistungsfähigkeit des jeweiligen Menschen, so wird dies den Intentionen des Verfassungsgesetzgebers nicht gerecht, sondern stellt ein Einfallstor für missbräuchliche Relativierungen des Lebensrechts dar. Diese Gefahr könnte auch Kinder in den ersten Lebensmonaten und zum Teil noch in den ersten Lebensjahren betreffen, da diese die erforderliche Rationalität und das erforderliche Ich-Bewusstsein ebenfalls noch nicht aufweisen.<sup>750</sup>

Darüber hinaus ist auch nicht einzusehen, warum die Schutzwürdigkeit des soeben geborenen Menschen größer sein soll als diejenige des unmittelbar vor der Geburt stehenden. Beide sind grundsätzlich in der Lage, sich weiter zu entwickeln und außerhalb des Mutterleibes zu leben. Allerdings bedürfen beide hierzu noch intensiver Hilfe. Auch wäre es nicht zu begründen, wenn man einem nach dem achten Monat geborenen Frühchen ein Lebensrecht zuspricht, dieses aber einem nach dem neunten Monat geborenen Kind bis zu seiner Geburt und somit noch im achten Schwangerschaftsmonat verwehrt, in dem ein geborenes Kind mit zum Zeitpunkt seiner Frühgeburt gleichem Entwicklungsstand wie das noch ungeborene Kind doch bereits von der Lebensschutzgarantie erfasst ist.<sup>751</sup>

Auch diese Auffassung führt somit, wendet man sie konsequent an, nicht zu befriedigenden Ergebnissen.

#### (6) Zwischenergebnis

Bedenkt man die Kritikpunkte eines Abstellens auf Zäsuren, die nach der Befruchtung der Eizelle liegen, erscheint jeder Bruch in der Entwicklung eines Menschen willkürlich. Mit der Vereinigung des mütterlichen und des väterlichen haploiden

<sup>746</sup> Holderegger, MedEthik 40 (1994), 275 (286); Wildfeuer, Lexikon der Bioethik, Band 3, Eintrag „Person“, S. 8.

<sup>747</sup> Giwer, Präimplantationsdiagnostik, S. 74 f.

<sup>748</sup> BVerfGE 39, 1 (36).

<sup>749</sup> Alternativkommentar zum GG-Podlech, Art. 2 II Rdnr. 10.

<sup>750</sup> Giwer, Präimplantationsdiagnostik, S. 75 f.

<sup>751</sup> So auch Spaemann, DZPhil 50, 105 (107).

Chromosomensatzes ist die genetische Identität eines Menschen angelegt. Bereits in diesem Zeitpunkt liegt menschliches Leben vor. Diese Erkenntnis ist unabhängig von der Frage, ob das soeben entstandene Wesen bereits ein Mensch oder Individuum ist, dem Menschenwürde zukommt. Sobald jedoch menschliches Leben besteht, kommt dem menschlichen Wesen auch ein Recht auf Leben zu. Dass der Embryo nach erfolgter Einnistung noch wichtige und entscheidende Informationen und Steuerungsimpulse der Mutter erhält, ist für das Vorliegen menschlichen Lebens unerheblich. Es handelt sich dabei lediglich um Triggerinformationen, die das in seiner Gänze bereits vorhandene Programm der Ontogenese auslösen, nicht aber das Programm vervollständigen oder gar die genetische Identität (mit-)prägen. Maximal ist dadurch etwa während ausgeprägten Hungerzeiten, wie sie während der Weltkriege vorkamen, eine Beeinflussung der Epigenetik möglich. Diese Steuerungsimpulse sind daher nicht konstitutiv für das Vorliegen menschlichen Lebens, denn vorher kann man es nicht als tierisches oder pflanzliches bezeichnen. Die Lebensschutzgarantie des Art. 2 II 1, 1. Alt. GG setzt daher mit Befruchtung der Eizelle ein und erfasst somit auch den pränidativen Embryo, an dem beispielsweise eine PID vorgenommen wird. Zu diesem Ergebnis ist auch der verfassungskonkretisierende Gesetzgeber gekommen. § 8 I 1. HS ESchG zufolge ist bereits die menschliche Eizelle vom Zeitpunkt der Kernverschmelzung an ein durch das Gesetz geschützter Embryo.<sup>752</sup>

Für diesen Zeitpunkt spricht zudem die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, nach der im Zweifel derjenigen Auslegung Vorzug zu geben ist, bei der sich die Wirkungskraft der betreffenden Norm am stärksten entfalten kann.<sup>753</sup> Aufgrund dieses Grundsatzes der Grundrechtseffektivität ist die weite Auslegung vorzuziehen, bei der unterschiedliche Abstufungen hinsichtlich der Dringlichkeit des Schutzes noch auf Schrankenseite und als Ergebnis von Abwägungsvorgängen vorgenommen werden können.<sup>754</sup>

Den Beginn menschlichen Lebens im Sinne des Art. 2 II 1, 1. Alt. GG setze ich somit bei der Befruchtung der Eizelle durch die Verschmelzung der jeweils haploiden Chromosomensätze von Ei- und Samenzelle an. Die Gameten selbst sind von dieser Verfassungsnorm mithin nicht umfasst. Soll im Wege des genetischen Enhancements aber die Zygote, ein späterer Embryo oder gar ein geborener Mensch zellulär modifiziert werden, so handelt es sich bei diesen Eingriffsobjekten um Träger des Grundrechts aus Art. 2 II 1, 1. Alt. GG.

Wird der Embryo nicht auf natürlichem Weg, sondern in der Petrischale gezeugt, steht dieser Umstand genanntem Ergebnis auch nicht entgegen.<sup>755</sup> Der Weg der Entstehung neuen menschlichen Lebens kann keinen qualitativen Unterschied im Hinblick auf den Embryo und die Wertigkeit dessen Lebens ausmachen. Entsteht

<sup>752</sup> Giwer, Präimplantationsdiagnostik, S. 77 ff, 80 f.; Hufen, MedR 2001, 440 (447).

<sup>753</sup> BVerfGE 6, 55 (72); 32, 54 (71).

<sup>754</sup> Alexy, Theorie der Grundrechte a), S. 290 ff.

<sup>755</sup> Isenec/Kirchhof-Lorenz, HStR VI, § 128 Rdnr. 12.

menschliches Leben, so ist dieses Leben in seinem weiteren Verlauf unabhängig vom Ort und den Umständen der Zeugung.<sup>756</sup>

#### bb) Art. 2 II 1, 1. Alt. GG als Grundlage einer staatlichen Schutzpflicht

Dass staatliche Schutzpflichten auf der objektiv-rechtlichen Dimension der Grundrechte gründen, stellte das Bundesverfassungsgericht in seinem ersten Urteil zum Schwangerschaftsabbruch fest.<sup>757</sup> Diese Rechtsprechung wurde in weiteren Urteilen bestätigt.<sup>758</sup> Hiernach stellen die Grundrechte „*nicht nur subjektive Abwehrrechte des Einzelnen gegen den Staat [dar], sondern [...] verkörpern zugleich eine objektive Wertordnung, die als verfassungsrechtliche Grundentscheidung für alle Bereiche des Rechts gilt und Richtlinien und Impulse für Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung gibt.*“<sup>759</sup> Nach der Wertordnungstheorie des Bundesverfassungsgerichts stellt der gesamte Grundrechtsabschnitt des Grundgesetzes eine objektive Wertordnung dar, die staatliche Schutzpflichten begründen kann.<sup>760</sup> Das Gericht betonte zudem, dass die Schutzpflichten des Staates im Hinblick auf das menschliche Leben umfassend sind und nicht nur in Fällen relevant werden, in denen eine Gefährdung der durch Art. 2 II 1 GG geschützten Rechtsgüter dem Staat zugerechnet werden kann, sondern auch, wenn diese Dritte geschaffen haben.<sup>761</sup> Darüber hinaus gebietet sie nicht lediglich die Unterlassung von Eingriffen in das ungeborene Leben. Vielmehr verpflichten sie den Staat auch dazu, dieses zu schützen, zu fördern und vor rechtswidrigen Angriffen Dritter zu bewahren.<sup>762</sup>

In der Literatur werden diese Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts insbesondere im Hinblick auf deren dogmatische Herleitung kritisiert. Zum Teil wird daher angenommen, dass ein eigenes Rechtsinstitut der Schutzpflichten entbehrlich sei, da ein Rückgriff auf die abwehrrechtliche Bedeutung der Grundrechte genügen würde. Verwiesen wird hierbei auf das Gewaltmonopol, das in einer Friedensordnung alleine dem Staat zusteht. Dieses Verbot privater Gewalt stelle eine staatlich verordnete Duldungspflicht dar, weswegen ein Nicht-Verbieten dem Staat als Eingriff zugerechnet werden müsse.<sup>763</sup> Andere sehen die grundrechtlichen Schutzpflichten des Staates in seiner Aufgabe der Gewährleistung der Sicherheit

<sup>756</sup> Beschluss des 56. DJT, NJW 1986, 3069 (3070); anders sieht dies *Losch*, NJW 1992, 2926 (2930).

<sup>757</sup> BVerfGE 39, 1 (41).

<sup>758</sup> BVerfGE 46, 160 (164); 49, 89 (141 f.); 53, 30 (57); 56, 54 (73); 77, 170 (214).

<sup>759</sup> BVerfGE 39, 1 (41).

<sup>760</sup> BVerfGE 7, 198 (205); 35, 79 (114); *Jarass*, AöR 110 (1985), 363 ff.

<sup>761</sup> *Dreier-Schulze-Fielitz*, GG, Art. 2 II Rdnr. 76.

<sup>762</sup> BVerfGE 39, 1 (42); 46, 160 (162); 53, 30 (57 ff.); 88, 203 (251).

<sup>763</sup> *Schwabe*, Probleme der Grundrechtsdogmatik, S. 211 ff.; in Bezug auf das Immissionsschutzgesetz *Murswiek*, NVwZ 1986, 611 (612 f.).

begründet und in den Grundrechten konkretisiert.<sup>764</sup> Wieder andere ziehen zur dogmatischen Begründung einer staatlichen Schutzpflicht das Sozialstaatsprinzip heran. Schutzpflichten seien hiernach die objektive Kehrseite eines subjektiven Teilhabe- und Leistungsrechts, da derjenige, der staatlichen Schutz fordert, gleichzeitig eine staatliche Leistung erstrebt.<sup>765</sup> Des Weiteren wird eine Pflicht des Staates zum Tätigwerden auch mit den Schrankenbestimmungen der Grundrechte begründet. Diese haben nicht nur rechtsbegrenzende Wirkungen. Vielmehr entfalten sie auch begünstigende Rechtswirkungen zu Gunsten der Rechtsgüter, die die Schrankenregelungen ausfüllen.<sup>766</sup> Schließlich wird eine Begrenzung der Schutzpflicht des Staates auf den Menschenwürdekern der Grundrechte für vorzugswürdig erklärt. Diese Schutzpflicht ergebe sich schon aus dem Wortlaut der Art. 1 I 2 und 6 I, IV GG, die ausdrücklich schon von „Schutz“ beziehungsweise „schützen“ sprechen. Dies erschwere es jedoch, dem Grundgesetz weitere Ansprüche auf Schutz zu entnehmen, soweit dieser nicht ausweislich des Wortlauts der betreffenden Verfassungsnorm angeordnet ist.<sup>767</sup> Diese Interpretation sei im Hinblick auf Wortlaut, System und Entstehungsgeschichte enger an das Grundgesetz angelehnt.<sup>768</sup> Zudem gewähre dies dem Gesetzgeber mehrere Möglichkeiten der politischen Gestaltung.<sup>769</sup>

All diesen Theorien gelingt es jedoch nicht, das Vorliegen von staatlichen Schutzpflichten ohne Rückgriff auf den objektiv-rechtlichen Geltungsgehalt der Grundrechte zu begründen. Insbesondere lässt sich die Friedens- und Sicherheitsfunktion des Staates nicht ohne die Anerkennung von sich aus dem objektiv-rechtlichen Grundrechtsgehalt ergebenden Schutzpflichten begründen.<sup>770</sup> Auch aus dem Fehlen eines öffentlich-rechtlichen Eingriffsverbotes für Private kann nicht auf eine Duldungspflicht für Dritte geschlossen werden. Insoweit übersieht der abwehrrechtliche Ansatz das im Zivilrecht geltende allgemeine Nichtschädigungsgebot. Auch vermag dieser Lösungsversuch in methodischer Hinsicht nicht zu überzeugen, da er die Existenz der zu beweisenden Schutzpflicht voraussetzt, indem er dem Staat die schädigenden Handlungen eines Privaten zurechnet.<sup>771</sup> Ebenso wenig kann die Ableitung von Schutzpflichten aus den Grundrechtsschranken überzeugen. Diese ermöglichen den Eingriff in den Schutzbereich des jeweiligen Grundrechts und stellen Befugnisnormen dar. Eine Pflicht des Staates zum Tätigwerden oder eine Aufgabenzuweisung lässt sich hieraus nicht ableiten.<sup>772</sup> Auch die Ableitung der Schutzpflichten aus dem Sozialstaatsprinzip kann nicht Bestand haben.

<sup>764</sup> Isensee/Kirchhof-Isensee, HStR V, § 111 Rdnr. 83; Stern, Staatsrecht III/1, § 69 IV 2, S. 932; Klein, NJW 1989, 1633 (1636).

<sup>765</sup> Scholz, JuS 1976, 232 (234).

<sup>766</sup> Seewald, Zum Verfassungsrecht auf Gesundheit, S. 80.

<sup>767</sup> Giwer, Präimplantationsdiagnostik, S. 89, Starck, Praxis der Verfassungsauslegung, S. 70.

<sup>768</sup> Starck, Praxis der Verfassungsauslegung, S. 74 f.

<sup>769</sup> Starck, Praxis der Verfassungsauslegung, S. 78.

<sup>770</sup> Giwer, Präimplantationsdiagnostik, S. 90.

<sup>771</sup> Starck, Praxis der Verfassungsauslegung, S. 74; Unruh, Zur Dogmatik der grundrechtlichen Schutzpflichten, S. 47.

<sup>772</sup> Unruh, Zur Dogmatik der grundrechtlichen Schutzpflichten, S. 49.

Diese übersieht, dass die Funktion der Grundrechte als Leistungsrechte eine ganz andere ist als bei den grundrechtlichen Schutzpflichten. Dies wird bereits durch die andere Fallkonstellation deutlich. Die Leistungsrechte beziehen sich auf eine bipolare Beziehung zwischen Bürger und Staat, während die Schutzpflichten eine Dreiecks-Struktur aufweisen: Der Staat hat das Opfer vor dem Störer zu schützen.<sup>773</sup> Schließlich vermag auch die Beschränkung der Schutzpflichten auf einen grundrechtlichen Menschenwürdekern nicht zu überzeugen. Nach dem Willen des Verfassungsgesetzgebers sollte Art. 1 I GG die Rechte des Einzelnen stärken und keinesfalls schwächen.<sup>774</sup> Des Weiteren ergeben sich bei der Feststellung des normativen Gehalts des Menschenwürdesatzes erhebliche Probleme.<sup>775</sup>

Daher ist im Grundsatz der Schutzpflichtenjudikatur des Bundesverfassungsgerichts zu folgen. Aufgrund der objektiven Dimension der Grundrechte und der in ihnen zum Ausdruck kommenden Werturteile ist das Vorliegen staatlicher Schutzpflichten zu bejahen.

### cc) Beeinträchtigung des Rechts auf Leben

Das Ergreifen von Schutzmaßnahmen durch den Staat wäre jedoch dann nicht erforderlich und auch schon nicht geboten, wenn ein genetisches Enhancement nicht in das Recht aus Art. 2 II 1, 1. Alt. GG eingreifen würde, welches die Zygote, den späteren Embryo oder den schließlich geborenen Menschen schützt, wenn also eine die staatliche Schutzpflicht auslösende Beeinträchtigung dieses Rechts nicht vorliegt.

Anders als bei der Präimplantationsdiagnostik, bei der der *nondum conceptus* eventuell verworfen, das heißt also weggeschüttet, mit einer toxischen Flüssigkeit beträufelt oder schlichtweg stehengelassen und nicht kryokonserviert, aber auch nicht weiter mit den zu seiner fortwährenden Existenz notwendigen Nährstoffen versorgt und ihm so sein Leben entzogen wird, geht es beim genetischen Enhancement nicht um ein Aussortieren bestimmter Entitäten. Sowohl bei einer in diesem frühen Stadium ansetzenden, als auch bei einer auf somatische Zellen beschränkten Modifikation ist Ausgangspunkt die ein durch zufällige Kombination entstandenes Genom enthaltende Zelle. Diese soll wie gewünscht verändert, dabei aber nicht abgetötet oder anderweitig zerstört werden. Ein zielgerichteter Eingriff in Art. 2 II 1, 1. Alt. GG kommt somit nicht in Betracht.

Allerdings könnte das genetische Enhancement eine Gefahr für das Leben der geschützten Entitäten darstellen, die genügen könnte, um ein Verbot zu rechtferti-

<sup>773</sup> Isensee/Kirchhof-Isensee, HStR V, § 111 Rdnr. 5; Stern, Staatsrecht III/1, § 69 IV 5, S. 948.

<sup>774</sup> Murswiek, Staatliche Verantwortung, S. 125.

<sup>775</sup> Unruh, Zur Dogmatik der grundrechtlichen Schutzpflichten, S. 43 ff.; Gwiger, Präimplantationsdiagnostik, S. 89 f.



gen.<sup>776</sup> Bislang stellen bereits die Gewährleistung der Integration des transferierten Gens am exakten Genlokus sowie die der Stabilität der Genexpression, aber auch die Kontrolle des Krebsrisikos die Forschung vor immense Herausforderungen. Doch selbst, wenn diese grundlegenden Probleme gelöst sein werden, sind noch zahlreiche sicherheitsrelevante Fragen ungeklärt. Aufgrund der immensen Komplexität des menschlichen Genoms und der Interdependenz der genetischen Merkmale sind die Auswirkungen einer gentechnologischen Modifizierung mit heutigem Erkenntnisstand kaum in vollem Ausmaß absehbar. Wie diffizil die genetischen Verknüpfungen und wie vielschichtig die Auswirkungen einzelner genetischer Codierungen sind, lässt sich erahnen, wenn man sich vor Augen hält, dass es beispielsweise Erkrankungen gibt, die zwar als solches nicht wünschenswert sind, die aber, wenn sie als nur heterozygote Variante vorliegen, ebenso positive Effekte haben können. So weisen Träger nur eines Sichelzellallels zuweilen eine verbesserte Resistenz gegen Malaria auf. Gleiches gilt auch für Zystische Fibrose und Cholera sowie für das Tay-Sachs-Syndrom und Tuberkulose.<sup>777</sup> Auch wenn die Medizin in der Lage sein wird, konkrete Gene mit hinreichender Sicherheit zu verändern oder einzufügen, so werden die möglichen Folgen für die empfindliche Balance des Genoms aufgrund dieser Wechselwirkungen ein enormes Sicherheitsrisiko darstellen, welches sich auch erst längerfristig verwirklichen kann.

Mithin besteht eine sowohl kürzer- als auch längerfristig enorme und bislang nicht kontrollierbare Gefahr, die sich im Tod der Zygote, des weiteren Embryos sowie des später geborenen Menschen realisieren kann. Genetisches Enhancement beeinträchtigt daher deren Recht auf Leben, was eine staatliche Schutzpflicht begründet.

#### dd) Reichweite der Schutzpflicht aus Art. 2 II 1, 1. Alt. GG

Es stellt sich weiter die Frage, welchen Umfang die staatliche Schutzpflicht hat. Zu beachten ist dabei, dass sich diese nicht wie ein Abwehrrecht nur auf die Beziehung zwischen Staat und einem einzelnen Bürger erstreckt. Vielmehr betrifft die Schutzpflicht eine Dreiecks-Beziehung zwischen Staat, Opfer und Störer. Intervenierte der Staat im Interesse des Opfers, ist damit zugleich ein Eingriff in Rechte des Störers verbunden. Neben den Grundrechten des Opfers hat der Staat daher auch die

<sup>776</sup> Dass hierzu schon eine Gefahr für das geschützte Rechtsgut ausreicht, erkennt auch *Giwer*, Präimplantationsdiagnostik, S. 91 f. vor dem Hintergrund an, dass, sollte beim Embryo im Rahmen einer Präimplantationsdiagnostik eine pathologische Auffälligkeit festgestellt werden, die Entscheidung über seine Verwerfung mit der Entscheidung über die Durchführung der Präimplantationsdiagnostik bereits getroffen ist und aufgrund dieses Automatismus bereits die Diagnose eine Gefahr für das Leben des Embryos darstellt. Vergleiche auch BVerfGE 88, 203 (291), wonach das Geschlecht des ungeborenen Kindes dann vom Arzt oder seinem Personal nicht bekannt gegeben werden darf, wenn die Gefahr eines Schwangerschaftsabbruchs wegen des Geschlechts des Kindes besteht; im Anschluss an diese Entscheidung hat der Gesetzgeber jedoch „*mangels praktischer Relevanz*“ kein Verbot der Mitteilung des Geschlechts erlassen: *Deutscher Bundestag*, Drucksache 13/1850, S. 26.

<sup>777</sup> *Green*, *Babies by Design*, S. 96 f.; vergleiche bezüglich der Konnexion von Sichelzellanämie und Malariaresistenz *Ashley-Koch/Yang/Olney*, *American Journal of Epidemiology* 151, 839 (843).

des Störers zu berücksichtigen.<sup>778</sup> Von einem Abwehrrecht unterscheidet sich die Schutzpflicht des Staates weiterhin darin, dass ersteres auf ein staatliches Unterlassen, letztere hingegen auf ein staatliches Tun gerichtet ist. In Erfüllung dieser Pflicht stehen dem Staat in aller Regel mehrere geeignete Handlungsmöglichkeiten zur Auswahl.<sup>779</sup> Sowohl Legislative als auch Exekutive und Judikative sind dazu berufen, in ihrem jeweiligen Funktionskreis geeignete und ausreichende Mittel einzusetzen, um einen effektiven Grundrechtsschutz zu gewährleisten.<sup>780</sup> Für den Gesetzgeber bedeutet dies die Pflicht, Normen bereitzustellen, die geeignet und hinreichend sind, um das jeweilige Grundrecht vor Eingriffen von privaten Dritten zu schützen.<sup>781</sup> Obschon dem Gesetzgeber bei Erfüllung dieser Pflicht ein weiter Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zukommt,<sup>782</sup> hat er seine Schutzpflicht in möglichst hohem Maße zu realisieren.<sup>783</sup> Im Rahmen des Untermaßverbotes hat er also sicherzustellen, dass der Schutz effizient ist.<sup>784</sup> Die Bestimmung der konkreten Schutzpflicht bedarf einer grundrechtsspezifischen Differenzierung und der Berücksichtigung von Art und Schwere der drohenden Gefahr für das Schutzgut. Grundsätzlich gilt dabei, dass der Bereich der Schutzpflicht mit der Sensibilität des Schutzgutes und der Größe der Gefahr wächst.<sup>785</sup>

An dieser Stelle sei jedoch klargestellt, dass zwar das Rechtsgut Leben unteilbar ist. Entweder steht dieses Recht einem Träger zu oder nicht. Das Lebensrecht ist also nicht abstufbar. Der Lebensschutz ist jedoch differenzierbar.<sup>786</sup> Im Gegensatz zur Menschenwürde, die durch Art. 1 I GG schrankenlos gewährt und absolut geschützt wird, kann der Schutz der Entwicklung des Embryos entsprechend gestuft werden, denn das Recht aus Art. 2 II 1 GG steht unter dem Gesetzesvorbehalt des Satzes 3 dieser Verfassungsnorm.<sup>787</sup> Bei der vorzunehmenden Abwägung ist das Recht auf Leben ein „*Schwerstgewicht*“.<sup>788</sup> Dennoch darf und muss im Rahmen des Lebensschutzes zwischen den unterschiedlichen zeitlichen Stadien der Entwicklung des menschlichen Lebens differenziert werden.<sup>789</sup> Zum Teil wird vertreten,

<sup>778</sup> Isensee, HStR V, § 111 Rdnr. 170.

<sup>779</sup> Alexy, Theorie der Grundrechte a), S. 421.

<sup>780</sup> Isensee, HStR V, § 111 Rdnr. 90, 139.

<sup>781</sup> Isensee, HStR V, § 111 Rdnr. 153.

<sup>782</sup> BVerfGE 77, 170 (214); 79, 174 (202); 85, 191 (212).

<sup>783</sup> Isensee, HStR V, § 111 Rdnr. 138.

<sup>784</sup> BVerfGE 88, 203 (254); Isensee, HStR V, § 111 Rdnr. 165; Sachs-Sachs, GG, Vor Art. 1 Rdnr. 36.

<sup>785</sup> Isensee/Kirchhof-Isensee, HStR V, § 111 Rdnr. 141.

<sup>786</sup> Dreier-Schulze-Fielitz, GG, Art. 2 II Rdnr. 25, 61 ff.; Faßbender, NJW 2001, 2745 (2748); Frommel, KJ 35 (2002), 411 (422); allgemein von der Schutzwürdigkeit des Embryos in den ersten Entwicklungsstadien, die gering sei und gegenüber anderen rechtlichen Interessen eher zurückstehe, sprechend Enquete-Kommission „Recht und Ethik“, S. 103.

<sup>787</sup> Dreier-Schulze-Fielitz, GG, Art. 2 II Rdnr. 61; Heun, Menschenwürde und Lebensrecht als Maßstäbe für PID?, S. 107; Hufen, MedR 2001, 440 (447).

<sup>788</sup> Heun, JZ 2002, 517 (518).

<sup>789</sup> BVerfGE 88, 203 (251, 256 f.); Dreier-Schulze-Fielitz, Art. 2 II Rdnr. 61; Dreier, ZRP 2002, 377 (378 ff.); Birnbacher, Menschenwürde und Lebensschutz als Maßstäbe für PGD?, S. 31 f.;

dass insbesondere dann zu differenzieren ist, wenn das Lebensrecht eines geborenen Menschen nicht mit dem eines Embryos *in utero*, sondern *in vitro* verglichen werde, zwischen denen nochmals kategoriale Unterschiede bestünden.<sup>790</sup> Während die Annahme eines abgestuften Schutzes der Menschenwürde aufgrund der absoluten Garantie dieses Grundrechts oben als unzulässig erachtet wurde, ist eine Differenzierung des Lebensschutzes des Embryos möglich und angebracht.

Dem steht auch nicht das Kontinuitätsargument entgegen, das auch auf die Frage nach dem Lebensrecht des Embryos angewendet wird. Die Tatsache, dass sich das menschliche Leben naturwissenschaftlich betrachtet in einem kontinuierlichen Prozess entwickelt, in dem rein *tatsächlich* also keine schärferen Zäsuren vorkommen, bedeutet jedoch nicht, dass aus *rechtlicher* Sicht solche Differenzierungen nicht vorgenommen werden können.<sup>791</sup>

Auch das Potentialitätsargument führt zu keinem anderen Ergebnis. Soll dieses nämlich für den Menschen gelten, muss es auch auf andere Wesen anwendbar sein. Man würde jedoch, so die Gegner des Potentialitätsargumentes, einer Buchecker oder einem Ei nicht dieselbe Schutzwürdigkeit zuschreiben, wie der Buche oder dem Huhn. Vielmehr durchlaufe ein Lebewesen in seiner Entwicklung unterschiedliche Stadien, die nicht scharf voneinander abgegrenzt werden können, die aber mit unterschiedlichen normativen Merkmalen verknüpft sind. So tritt man beim Spaziergang im Wald ohne es zu bemerken und/oder ohne jegliche Skrupel auf eine Buchecker und zerstört sie so. Auch einen Buchensprössling reißt man – oftmals aber nur schweren Herzens – dann aus, wenn er andere Zierpflanzen an deren Entwicklung hindert. Eine emporgewachsene Buche darf man jedoch oft ohne behördliche Erlaubnis nicht fällen.<sup>792</sup>

Belegt wird diese Differenzierung hinsichtlich des Schutzes dadurch, dass in allen Rechtssystemen dem werdenden Leben weniger Respekt entgegengebracht wird als dem bereits geborenen.<sup>793</sup> Auch das Bundesverfassungsgericht stellte in seinen beiden Urteilen zum Schwangerschaftsabbruch den § 219d StGB a. F. nicht in Frage. Dieser entspricht dem heutigen § 218 I 2 StGB und nimmt den frühen menschlichen Embryo bis zur Nidation, also bis zum Ablauf von 14 Tagen nach der Befruchtung, ausdrücklich von dem von den §§ 218 ff. StGB n. F. gewährten Schutz aus.<sup>794</sup>

Entsprechend ist die Reichweite der staatlichen Schutzpflicht aus Art. 2 II 1, 1. Alt. GG im Rahmen einer Abwägung zwischen dem Recht der Zygote oder des Embryos beziehungsweise des geborenen Menschen auf Leben und den von einem Verbot betroffenen Grundrechten der Eltern beziehungsweise des Arztes zu determinieren. Wie oben festgestellt, wären, würde man das genetische Enhance-

---

Kloepfer, JZ 2002, 417 (420 f.).

<sup>790</sup> Vergleiche Ipsen, JZ 2001, 989 (996); Losch, NJW 1992, 2926 (2930); Dreier-Schulze-Fielitz, GG, Art. 2 II Rdnr. 70.

<sup>791</sup> Hilgendorf, NJW 1996, 758 (761).

<sup>792</sup> Birnbacher, Menschenwürde und Lebensschutz als Maßstäbe für PGD?, S. 31.

<sup>793</sup> Dreier-Schulze-Fielitz, GG, Art. 2 II Rdnr. 67.

<sup>794</sup> Birnbacher, Menschenwürde und Lebensschutz als Maßstäbe für PGD?, S. 32.

ment untersagen, das Recht der Eltern auf reproduktive Autonomie aus Art. 6 I GG beziehungsweise Art. 2 I GG (in Verbindung mit Art. 1 I GG), die Berufsfreiheit des Arztes gemäß Art. 12 I GG, möglicherweise die Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit des Art. 5 III GG sowie im Hinblick auf ein Enhancement ausdifferenzierter Körperzellen das Elternrecht im Sinne des Art. 6 II 1 GG betroffen.

Trotz grundsätzlicher Abwägbarkeit des Lebensrechts, stellt dieses jedoch ein Schwerstgewicht unserer Verfassungsordnung dar. Ein derart sensibles Rechtsgut verlangt schon bei alltäglichen, erst recht aber bei Gefahren von besonderem Ausmaße extensiven Schutz. Diesem Grundsatz trägt auch die medizinische Ethik Rechnung. Diese verlangt, dass dem Patienten zu nützen und nicht zu schaden ist, so etwa auch die Prinzipien der *nonmaleficence* und *beneficence* von *Beauchamp* und *Childress*, also dem Gebot, anderen nicht zu schaden und darüber hinaus auch zu deren Wohlergehen beizutragen, was sich aufspaltet in das Verbot, Schaden selbst aktiv und willentlich zuzufügen, und die Gebote, von dritter Seite drohenden Schaden zu verhindern und, soweit sich dieser schon realisiert hat, zu beseitigen sowie Wohlergehen zu fördern.<sup>795</sup>

Auch dem *Precautionary Principle*<sup>796</sup> zufolge ist jegliche Aktivität zu unterlassen, die zu einem Schaden führen *könnte*. Sofern hiernach nicht bewiesen ist, dass die in Frage stehenden Handlungen, von denen vermutet wird, dass sie gewisse Risiken aufweisen, ohne dass dies mit Sicherheit gesagt werden kann, tatsächlich ungefährlich sind, trifft die Beweislast der Unschädlichkeit diejenigen, welche die Handlungen auszuführen wünschen. Kritisiert wird dieses Prinzip zuweilen jedoch, da es nur Schädigungen und Gefahren berücksichtigt, nicht jedoch die Vorteile und Nutzen, die aus diesen Handlungen resultieren könnten. Daher wird vorgeschlagen, die Frage, ob eine Handlung oder eine neue Technologie Risiken in sich birgt beziehungsweise bergen könnte, dahingehend zu modifizieren, dass sie sich darauf bezieht, ob die Risiken akzeptabel sind. Entsprechend ließe sich nicht nur untersuchen, welche Handlungsoption die schlechtmöglichsten Resultate hervorbringen könnte, sondern mit dem *Maximin Prinzip* feststellen, in welchem dieser Fälle dennoch der relativ beste Nutzwert eintritt.<sup>797</sup>

Diese Überlegungen entsprechen im Hinblick auf die Wertungen auch der verfassungsrechtlichen Praxis der Herstellung praktischer Konkordanz und Güterabwägung, die im Folgenden vorzunehmen sein wird. Vorliegend vermögen die konfligierenden Freiheiten und Rechte es aber nicht, das hochrangige Recht auf Leben zu verdrängen. Hier ist im Hinblick auf die schrankenlos gewährleistete Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit die Einheit der verfassungsrechtlichen Wertordnung zu beachten. Durch sie betroffene Werte von Verfassungsrang ermöglichen darüber nicht nur ihre Einschränkung, sondern verlangen sie unter Umständen auch. Verlässt die berufliche oder forschende Tätigkeit den engen Rechte- und Pflicht-

<sup>795</sup> *Beauchamp/Childress*, Principles of Biomedical Ethics, S. 149 ff., 197 ff.

<sup>796</sup> Wenn auch in dem Wissen um die vielgestaltigen Ausprägungen, so soll hier doch, da es sich nicht um ein zentrales Argument handelt, nur von einer pauschalisierten These ausgegangen werden.

<sup>797</sup> *Buchanan*, Better than Human, S. 90 ff.

tenkreis des Trägers dieser Rechte und betrifft sie Dritte, so ist deren Interessen ebenfalls Rechnung zu tragen. Beides darf nicht um jeden Preis verfolgt werden. Entsprechend sind medizinische Studien einfachgesetzlichen Regelungen zufolge erst dann am Menschen durchzuführen, wenn anderweitig, etwa durch Versuche an Tieren, eine in dem jeweiligen Stadium größtmögliche Sicherheit erreicht wurde. Hiervon ist die Medizin aber im Falle genetischer Enhancements noch weit entfernt. Eine Anwendung beim Menschen entspräche zurzeit noch dem potentiell tödlichen Glücksspiel des russischen Roulettes und ist daher vorerst unzulässig. Die gleichen Wertungen gelten auch im Rahmen der Berufsfreiheit des Arztes.

Freilich ist es Personen darüber hinaus weitgehend freigestellt, ob, mit wem und wann sie sich fortpflanzen möchten. Sie haben auch einen großen Spielraum, wenn es um Aufzucht und Erziehung der eigenen Kinder geht. Dennoch erfahren diese Freiheiten dann eine Grenzziehung, sobald Kindesinteressen missachtet oder in unzulässiger Weise den Präferenzen der Eltern unterstellt werden. Geht dies soweit, dass gar das Leben gefährdet wird, ist dies zweifelsohne unzulässig, wenn dadurch nur elterliche Wünsche nach Kindern mit besonderen genetischen Dispositionen, die aber im Übrigen pathologisch unauffällig sind, erfüllt werden sollen. Anders könnte dies jedoch zu beurteilen sein, wenn dem Risiko ein so großer Nutzen für das gefährdete Objekt gegenüberstünde, der dieses ausgleichen oder sogar übertreffen würde. Diese Überlegung soll im Folgenden vertieft werden.

Hinsichtlich der Methode der Risiko-Nutzen-Abwägung ist stets zu berücksichtigen, dass das Ergebnis, da es blind gegenüber sämtlichen anderen, für die Beurteilung des in Frage stehenden Sachverhalts relevanten Kriterien ist, keine abschließende Stellungnahme über diesen ermöglicht. Dies erweist sich vorliegend jedoch nicht als eine Schwäche dieser Herangehensweise, da ohnehin weitere für eine umfassende Analyse notwendigen Umstände in den Blick genommen werden. Voraussetzung für eine Risiko-Nutzen-Abwägung ist, dass beide Seiten in vergleichbarer Weise quantifizierbar sein müssen, was vorliegend der Fall ist. Bei der Risiko und Nutzen in Abwägung bringenden Analyse sind zunächst die Schwere und die Wahrscheinlichkeit des etwaig eintretenden Schadens festzustellen. Dem wird sodann das Ausmaß des möglichen Nutzens gegenübergestellt. Schließlich werden Überlegungen anzustellen sein, ob es Methoden gibt, das Risiko zu beseitigen oder zumindest zu begrenzen, sodass es in einem vernünftigen Verhältnis zu dem versprochenen Nutzen steht.<sup>798</sup>

Mit Blick auf eine Lebensgefährdung von Zygote, Embryo oder geborenem Menschen ist die Gefahr einer Schädigung in zweierlei Hinsicht besonders hoch: Zum einen sind Medizin und Technik noch nicht in der Lage, den Lokus und die Expressierung eingefügter oder veränderter Gene hinreichend zu kontrollieren, sodass die Folgen insbesondere von Eingriffen in die Keimbahn, aber auch von Modifizierungen somatischer Zellen völlig unabsehbar sind und katastrophale Ausmaße haben könnten. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist, die Komplexität des menschlichen Genoms und die Interdependenzen unterschiedlicher Gensequenzen bedenkend, ausgesprochen hoch. Eine Rechtfertigung dieses immensen Risikos ist also nur dann

<sup>798</sup> Vergleiche zum methodischen Vorgehen *Buchanan, Beyond Humanity?*, S. 175 f.

möglich, wenn es den durch genetische Enhancements versprochenen Nutzen derart übersteigen würde, dass es angemessen wäre, das Risiko einzugehen. Allgemein lässt sich hierzu jedoch sagen, dass es stets erstrebenswerter ist, gravierende Übel zu vermeiden, als mögliche Vorteile zu erreichen.<sup>799</sup> Der Sicherung des *status quo* wird ungeachtet rationaler Wahrscheinlichkeiten in der Regel mehr Gewicht eingeräumt als der Gewinnung weiteren Nutzens, was umso mehr gelten muss, wenn die Ausgangssituation keine pathologisch auffällige, sondern eine im Allgemeinen gesunde ist.<sup>800</sup> Entsprechend muss die Risiko-Nutzen-Relation im Hinblick auf die konkrete in Frage stehende Maßnahme eine vertretbare sein.

Gerade dies scheint jedoch im Hinblick auf Techniken des genetischen Enhancements ungünstiger als bei gentherapeutischen Maßnahmen zu sein, bei denen den Risiken ein echter medizinischer, fundierter Nutzen im Sinne der Linderung oder Heilung von Krankheit und Leid gegenübersteht. So lässt sich feststellen, dass mit zunehmender Bedeutung der intendierten Veränderung für die objektiv und gegebenenfalls auch subjektiv zu beurteilende Gesamtsituation der betroffenen Person die Toleranz gegenüber etwaigen Risiken wächst. Ist die Veränderung hingegen nur eine marginale beziehungsweise ist der medizinische Nutzen nur ein geringer, so sind besondere Anforderungen an die Sicherheit der Maßnahme zu stellen.<sup>801</sup>

Freilich werden diese Limits bereits heute mit einigen rein ästhetischen Zielen dienenden schönheitschirurgischen Eingriffen ausgereizt. Gerade dies macht jedoch deutlich, dass es stets auch eine individuell zu beantwortende Frage ist, ein wie großes Risiko man für die Erfüllung eines Wunsches einzugehen bereit ist.<sup>802</sup> Es bedarf also ebenfalls einer Abwägung zwischen der grundsätzlichen Freiheit des Individuums, auch unvernünftige Entscheidungen zu treffen, deren Umsetzung Gefahren birgt, und einem staatlichen Schutzauftrag. Wenn auch grundsätzlich das Freiheitsrecht und damit die Möglichkeit, sich selbst zu schaden, hierbei obsiegen dürften und die Rechtsordnung den Menschen nicht vor sich selbst schützt,<sup>803</sup> so steht doch im Falle besonders gefährlicher Unternehmungen einem gesetzlichen Verbot nichts im Wege, welches auch oder ausschließlich auf Sicherheitserwägungen und dem Grundsatz beruht, dass eine wirksame Einwilligung in eine die Gesundheit oder gar das Leben in exzessivem Maße gefährdende Maßnahme nicht möglich ist.<sup>804</sup>

Diesen verfassungsrechtlichen Anforderungen und Gegebenheiten entspricht auch die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu der Reichweite der rechtfertigenden Wirkung einer vom Opfer einer Körperverletzung erklärten Einwilligung. Soweit die Tat trotz der Einwilligung gegen die guten Sitten verstößt, welche nicht außerrechtlich oder ethisch-moralisch zu bestimmen sind und bezüglich deren Feststellung die Wertvorstellungen einzelner gesellschaftlicher Gruppen

<sup>799</sup> Daniels, *Modifying Human Nature?*, S. 28; Green, *Babies by Design*, S. 91.

<sup>800</sup> Vergleiche Daniels, *Modifying Human Nature?*, S. 38; ähnlich *The President's Council on Bioethics*, *Beyond Therapy*, S. 280.

<sup>801</sup> Lenk, *Therapie und Enhancement*, S. 68 f.

<sup>802</sup> Diese Annahme teilt auch *The President's Council on Bioethics*, *Beyond Therapy*, S. 280.

<sup>803</sup> Vergleiche Isensee, *Die alten Grundrechte und die biotechnische Revolution*, S. 260.

<sup>804</sup> Entsprechend §§ 216, 228 StGB.



nicht genügen, sodass diese dem Begriff nach auf ihren rechtlichen Kern zu beschränken sind, ist und bleibt sie rechtswidrig.<sup>805</sup> Während ein Teil der Literatur, gestützt auf die Rechtsprechung des Reichsgerichts<sup>806</sup>, auch die mit der Tat verfolgten Zwecke und Ziele sowie die Beweggründe des Täters insbesondere dann berücksichtigen will, wenn diese sittlich-moralisch verwerflich sind, beurteilt die herrschende Literatur und die heutige Rechtsprechung unter Hinweis, dass die erstgenannte Auffassung zu nur unklaren Abgrenzungen führt und keinen ausreichenden Bezug zu dem geschützten Rechtsgut aufweist, die Sittenwidrigkeit der Körperverletzung danach, ob diese wegen des besonderen Gewichts des tatbestandlichen Rechtsgutsangriffs unter Berücksichtigung des Umfangs der eingetretenen Körperverletzung und den damit verbundenen Gefahren für Leib und Leben des Opfers trotz der Einwilligung nicht mehr von der Rechtsordnung hinnehmbar ist. Der mit der Tat verfolgte Zweck wird dabei nur ausnahmsweise zur Kompensation einer anhand der genannten Kriterien festgestellten Sittenwidrigkeit herangezogen. Teilweise wird zudem eine Abwägung der betroffenen Interessen vorgenommen.<sup>807</sup> Dies zeigt, dass trotz zu respektierender Freiheitsrechte des jeweils Betroffenen und der daraus resultierenden grundsätzlichen Zulässigkeit der Selbstgefährdung und –schädigung ein entsprechender Wille von der Rechtsordnung nicht zu berücksichtigen, das heißt die individuelle Autonomie insofern begrenzt ist,<sup>808</sup> und es, wenn die kausale Handlung durch einen Dritten ausgeführt wurde, bei dessen Strafbarkeit bleiben muss. Ist dies der Fall, ist es auch nur konsequent, dass neben der nur nachträglich relevant werdenden strafrechtlichen Begutachtung die Schutzpflicht des Staates auch gegen den Willen des Betroffenen oder der für diesen stellvertretend beziehungsweise im Wege der Personensorge Handelnden fortbesteht und schon dann zu berücksichtigen ist, wenn spezialgesetzliche Regelungen geschaffen werden sollen.

#### ee) Ergebnis und Ausblick

Solange ein genetisches Enhancement nicht mit hinreichender Sicherheit durchgeführt werden kann und auch unbeabsichtigte Resultate und Nebenwirkungen unkontrollierbar bleiben, rechtfertigen, wie die Analyse gezeigt hat, alleine schon die großen Risiken für den Patienten und im Falle der Veränderung von Keimbahnzellen auch für nachfolgende Generationen ein umfassendes gesetzliches Verbot. Allerdings ist diese Argumentationslinie eine nur temporäre und nur solange gültig,

<sup>805</sup> BGHSt 49, 166 (169); die Frage, ob der Rechtsordnung überhaupt Wertungsmaterial zur Konkretisierung der Sittenwidrigkeit zur Verfügung steht, und somit verfassungsrechtliche Bedenken in den Blick nehmend: *Lackner/Kühl*, StGB, § 228 Rdnr. 11; *Schönke/Schröder-Stree*, StGB, § 228 Rdnr. 6; *Kindhäuser/Neumann/Paeffgen-Paeffgen*, StGB, § 228 Rdnr. 33.

<sup>806</sup> RGSt 74, 91 (94).

<sup>807</sup> BGHSt 49, 166 (170 ff.); *Fischer*, StGB, § 228 Rdnr. 9 f.; *Kindhäuser/Neumann/Paeffgen-Paeffgen*, StGB, § 228 Rdnr. 37, 40 ff.; *Lackner/Kühl*, StGB, § 228 Rdnr. 10 f.; *Schönke/Schröder-Stree*, StGB, § 228 Rdnr. 5 ff.

<sup>808</sup> *Fischer*, StGB, § 228 Rdnr. 8.



wie noch keine sicheren Methoden gefunden sind.<sup>809</sup> Bis dahin gilt sie jedoch für sämtliche Enhancement-Maßnahmen, also, weil die Risikobewertung stets gleich ausfallen muss, unterschiedslos für solche, denen sich das moralische Subjekt selbst zu unterziehen entscheidet, als auch erst recht für solche, von denen Nicht-Zustimmungsfähige betroffen sind.<sup>810</sup>

Eine Möglichkeit, um die Risiken überschaubar zu halten, könnte darin bestehen, eine Reversibilität anfangs zunächst unumkehrbarer gentechnologischer Eingriffe herzustellen und diesen Zwischenschritt gesetzlich vorzuschreiben. Als besonders attraktiv könnten sich derartige Sicherheitsvorkehrungen gestalten, sobald die Techniken des genetischen Enhancements selbst hinreichend sicher durchgeführt werden können, aber aufgrund der Komplexität des menschlichen Genoms die Auswirkungen auf die gesamte funktionale Einheit noch nicht voll überblickt werden können. Eine solche Reversibilität könnte erreicht werden, indem die eingefügte DNA-Sequenz von einem Enzym eingerahmt wird, welches die sich zwischen ihm befindlichen Sequenzen zu löschen beziehungsweise unleserlich zu machen vermag, sobald es durch ein Medikament aktiviert wird. Soweit sich dieser Vorgang erneut rückgängig machen lässt, bestünde für folgende Generationen neben der weitgehenden Eliminierung von Risiken durch Inaktivierung der gefährdenden Sequenzen die freie Wahlmöglichkeit, ob sie selbst die durch die Genmodifikation eingeführten Merkmale aufweisen möchten und ob sie diese an ihre Nachkommen vererben möchten.<sup>811</sup> Dies wäre auch eine Option zur Lösung der weiter unten aufgezeigten Probleme der Autonomie und des Selbstverständnisses sowie der Autorschaft des eigenen Lebens.

## **b) Schutz der körperlichen Unversehrtheit, Art. 2 II 1, 2. Alt. GG**

Genetisches Enhancement könnte auch in das durch Art. 2 II 1, 2. Alt. GG gewährte Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit eingreifen. Dies könnte eine Schutzpflicht des Staates begründen und ein Verbot verbessernder gentechnischer Modifizierungen rechtfertigen.

### **aa) Schutzbereich des Art. 2 II 1, 2. Alt. GG**

Die körperliche Unversehrtheit umfasst tatbestandlich drei Ebenen: die körperliche Gesundheit im engeren biologisch-physiologischen Sinne, die vor Verletzungen schützt, die psychisch-seelische Gesundheit, die vor nichtkörperlichen Eingriffen schützt, deren Wirkungen aber mit denen körperlicher Eingriffe gleichzustellen sind, sowie die körperliche Integrität als solche, die unabhängig von der Zufügung

<sup>809</sup> So gehen etwa auch *Reiss/Straughan*, *Improving Nature?*, S. 217 davon aus, dass in Zukunft genannten Sicherheitsbedenken ausreichend Rechnung getragen werden kann.

<sup>810</sup> *Lenk*, *Therapie und Enhancement*, S. 69; vergleiche auch, *Green*, *Babies by Design*, S. 92.

<sup>811</sup> *Green*, *Babies by Design*, S. 93 f.

körperlicher oder seelischer Schmerzen geschützt wird.<sup>812</sup> Relevant ist vorliegend der letztgenannte Punkt.

Zum Teil wird angeführt, dem Embryo fehle es an einer schutzwürdigen körperlichen Gestalt, weswegen ein Anspruch auf körperliche Unversehrtheit sachlogisch ausscheide.<sup>813</sup> Dies lässt jedoch unbeachtet, dass auch ein Embryo in den Anfängen seiner Entwicklung sehr wohl einen Körper hat, der verletzt werden kann. Dieser gleicht zwar nicht dem eines weiter entwickelten Embryos oder gar eines geborenen Menschen, bei dem Torso, Kopf, Arme und Beine auszumachen sind. Aber auch der soeben entstandene Embryo hat eine körperliche Gestalt im naturwissenschaftlichen Sinne, denn er verflüchtigt sich nicht etwa wie Gas. Zwar besteht er nur aus wenigen Zellen, diese sind jedoch – freilich nur unter Zuhilfenahme entsprechender medizinischer Geräte – sicht- und fühlbar. Auch hat dieser Körper die Gestalt eines menschlichen Wesens, nämlich eines solchen in den ersten Lebenstagen. Der Embryo wird daher und aufgrund des engen logischen, dogmatischen und systematischen Zusammenhangs mit dem Lebensschutz des Art. 2 II 1, 1. Alt. GG im Hinblick auf seine körperliche Unversehrtheit ab Befruchtung der Eizelle geschützt. Das Recht aus Art. 2 II 1, 2. Alt. GG schützt nicht nur vor Beeinträchtigungen, die beim geborenen Menschen fortwirken, sondern auch vor solchen, die für diesen keine erkennbaren Folgen haben.<sup>814</sup>

Vom personalen Schutzbereich sind auch Zygoten und Embryonen sowie ohnehin geborene Menschen erfasst. Der Schutz der körperlichen Unversehrtheit setzt mit dem des Lebens ein,<sup>815</sup> ist doch nicht einzusehen, warum dasselbe Wort „*jeder*“ in Art. 2 II 1 GG einen unterschiedlichen Inhalt in Bezug auf das Lebensrecht wie auf das Recht auf körperliche Unversehrtheit haben soll.

#### bb) Art. 2 II 1, 2. Alt. GG als Grundlage einer staatlichen Schutzpflicht

Auch Beeinträchtigungen des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit drohen beim genetischen Enhancement nicht vom Staat, sondern vielmehr von Seiten privater Dritter. Daher stellt sich die Frage, ob Art. 2 II 1, 2. Alt. GG ein Handlungsgebot an den Staat enthält, sodass ein Verbot von Genverbesserungen gerechtfertigt oder sogar gefordert wäre.

Aufgrund des engen dogmatischen und systematischen Zusammenhangs zwischen dem Grundrecht auf Leben und dem auf körperliche Unversehrtheit sei auf die zu Art. 2 II 1, 1. Alt. GG angestellten Überlegungen verwiesen. Der Schutz der

<sup>812</sup> Dreier-Schulze-Fielitz, GG, Art. 2 II Rdnr. 33 ff.; Sachs-Murswiek, GG, Art. 2 Rdnr. 147 ff.; Isensee/Kirchhof-Lorenz, HStR VI, § 128 Rdnr. 16 ff.

<sup>813</sup> Dreier-Schulze-Fielitz, GG, Art. 2 II Rdnr. 40.

<sup>814</sup> Giwer, Präimplantationsdiagnostik, S. 113 f.

<sup>815</sup> Isensee/Kirchhof-Lorenz, HStR VI, § 128 Rdnr. 21.

körperlichen Unversehrtheit ist eine Vorstufe des Lebensschutzes und enthält einen objektiv-rechtlichen Gehalt. Dieser begründet eine Schutzpflicht des Staates.<sup>816</sup>

### cc) Beeinträchtigung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit

Diese Pflicht des Staates wäre zudem dann aktualisiert und der Staat zur Ergreifung von Maßnahmen zum Schutze der in Art. 2 II 1, 2. Alt. GG gewährleisteten Rechte der Zygote, des späteren Embryos oder des schließlich geborenen Menschen gehalten, wenn genetisches Enhancement darin eingreift. Dass dieser etwaige Eingriff nicht von staatlicher Seite drohen würde, steht dem nicht entgegen. Aus dem objektiv-rechtlichen Gehalt dieser Verfassungsnorm folgt die Pflicht des Staates, die genannten Rechtsgüter zu schützen und vor rechtswidrigen Eingriffen Dritter zu bewahren.<sup>817</sup>

Beim genetischen Enhancement wird der Code der Zielzellen mittels der oben beschriebenen Verfahren verändert. Dies kann sowohl *in vitro* als auch *in vivo* geschehen und durch den jeweiligen Patienten, sofern dieser bereits geboren und zu einer entsprechenden Entschlussfassung in der Lage ist, oder Dritte, in der Regel dann die (zukünftigen) Eltern, initiiert sein. Relevanz erlangt darüber hinaus, dass es nicht nur zu einem tatsächlichen Einwirken auf die Zellsubstanz kommt, sondern auch beachtliche Risiken, die sowohl bei der Vornahme des Enhancements als auch im Anschluss daran als Nebenwirkungen bestehen, Berücksichtigung finden müssen.

Entscheidet sich nun ein geborener, einwilligungsfähiger Mensch dazu, an sich selbst einen genverbessernden Eingriff vornehmen zu lassen, und soll dieser Eingriff *ex vivo* geschehen, so müssen ihm zunächst die zu modifizierenden Zellen entnommen werden. Dies setzt eine Einwirkung auf seinen Körper zum Zwecke der Extrahierung voraus, was eine Beeinträchtigung seiner körperlichen Integrität, bei der es auf die Zufügung körperlicher Schmerzen nicht ankommt, darstellt.

Auch bei der eigentlichen Durchführung des das Genom verändernden Eingriffs könnte der Schutzbereich der Art. 2 II 1, 2. Alt. GG betroffen sein. Allerdings sind die Zellen, auf die zugegriffen wird, aus dem Körper des Patienten herausgelöst und damit nicht mehr durch eine unmittelbare körperliche Verknüpfung Teil des Gesamtkomplexes, welcher der Körper ist. Ein Körperteil, das vom Körper abgetrennt wird, wird nach der Rechtsprechung zu einer Sache mit der Folge, dass sich das Recht des Betroffenen an seinem Körper, nach herrschender Meinung analog § 953 BGB, in Sacheigentum am abgetrennten Körperteil umwandelt.<sup>818</sup> Dies hat einfachrechtlich sodann die Folge, dass von einer Körperverletzung nicht mehr die

<sup>816</sup> Dreier-Schulze-Fielitz, GG, Art. 2 II Rdnr. 76; von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 2 Abs. 2 Rdnr. 229.

<sup>817</sup> von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 2 Abs. 2 Rdnr. 190.

<sup>818</sup> BGHZ 124, 52 (54); Münchener Kommentar-Stresemann, BGB, § 90 Rdnr. 26 f.; Palandt-Ellenberger, BGB, § 90 Rdnr. 3; Staudinger-Jickeli/Stieper, BGB, § 90 Rdnr. 28 ff.; Taupitz, JZ 1992, 1089 (1092); anderer Auffassung hingegen ist Forkel, JZ 1974, 593 (595 f.), der für eine Fortdauer des Persönlichkeitsrechts auch nach Trennung vom Körper plädiert.

Rede sein kann. Vorliegend besteht jedoch die Besonderheit, dass nach erfolgter genetischer Veränderung der Zellen diese wieder in den Körper des Patienten zurückübertragen werden und dort wieder ihre ursprüngliche Funktion ausüben sollen. Im Zivilrecht ist im Hinblick auf einen Schadensersatzanspruch wegen einer Verletzung des § 823 I, 2. Var. BGB durch Zerstörung eingefrorenen Spermias, welches zum Zwecke der Befruchtung einer Eizelle kryokonserviert wurde, bevor der Patient sich einer Operation oder Therapie unterziehen musste, die zu seiner Unfruchtbarkeit führt oder führen könnte, geurteilt worden, dass das Recht am eigenen Körper eine einfachgesetzliche Ausformung des Persönlichkeitsrechts sei, weswegen dessen Verletzung auch eigens neben der der Gesundheit genannt werde. Daher sei Schutzgut des § 823 I, 2. Var. BGB auch das Seins- und Bestimmungsfeld der Persönlichkeit, welches sich in körperlicher Befindlichkeit und dem Körper selbst als Basis der Persönlichkeit materialisiert und von unbefugten, das heißt nicht von einer Einwilligung umfassten Eingriffen beeinträchtigt werde.<sup>819</sup>

Gerade im Zusammenhang mit neuen medizinischen Möglichkeiten gewinnt also der Aspekt der Selbstbestimmung anscheinend einen immer gewichtigeren Einfluss auf den ansonsten anhand rein dinglicher Kriterien zu beurteilenden Körper. Daher kommt es auch darauf an, mit welchem Zweck die Körperteile entnommen werden und was damit geschehen soll. Verwiesen sei hier insbesondere auf die zur Befruchtung *in vitro* entnommenen Eizelle, die Eigentransplantation von Haut oder Knochenbestandteilen, die Gewinnung von Stammzellen aus der Nabelschnur eines Neugeborenen für den Fall, dass diese später zu dessen Therapie notwendig werden könnten, oder die Eigenblutspende. Unter Berücksichtigung des zuvor Gesagten erscheint es somit in Fällen, in denen dem Körper Bestandteile entnommen werden, die nach dem Willen des Rechtsträgers diesem später wieder zugeführt werden sollen, um sodann Körperfunktionen zu bewahren, wiederherzustellen oder diese zu verwirklichen, angemessen, auch ausgegliederte Bestandteile als zum Körper gehörig und ihre Beschädigung oder Vernichtung somit als Körperverletzung im Sinne des § 823 I, 2. Var. BGB zu klassifizieren, der, sollte der Körperbestandteil aber nicht wieder dem ursprünglichen Körper hinzugefügt, sondern außerhalb dessen verwendet werden, wie es etwa bei der Kryokonservierung von Samenzellen zur späteren Befruchtung einer Eizelle der Fall ist, zumindest aber analog anzuwenden wäre. Hintergrund dieser Wertung ist, dass die Bestandteile zwar keine räumliche, aber dennoch weiterhin eine funktionale Einheit mit dem Körper bilden und die Zuordnung hierzu dem Schutzzweck der Norm entspricht.<sup>820</sup> Dies erschließt sich im Hinblick auf das kryokonservierte Sperma des eingänglichen Beispiels insofern unmittelbar, da dies die einzige Möglichkeit darstellt, die ursprüngliche Funktion seines Körpers, Nachkommen zu zeugen, zur Geltung zu bringen.

Im vorliegenden Zusammenhang bestehen gegen die Heranziehung dieser Überlegungen zur Beurteilung der Frage, ob ein durch den Staat ungehindertes, das heißt gesetzlich nicht untersagtes Einwirken auf aus dem körperlichen Zusammenhang

---

<sup>819</sup> BGHZ 124, 52 (54).

<sup>820</sup> Vergleiche BGHZ 124, 52 (54).

herausgelösten Zellen ein Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit aus Art. 2 II 1, 2. Alt. GG darstellt, gleich zwei Bedenken.

Zum einen sind diese Ausführungen vor dem Hintergrund des § 823 I, 2. Var. BGB gemacht worden. Hierbei handelt es sich jedoch um einfaches Recht, welches, wie schon mehrfach festgestellt, nicht zur Interpretation von höherrangigem Verfassungsrecht herangezogen werden darf. Allerdings rekurriert das Gericht im Rahmen seiner Überlegungen selbst auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht und die Interdependenzen hiervon und dem Recht auf körperliche Unversehrtheit, dessen einfachrechtliche Ausprägung § 823 I, 2. Var. BGB ebenso wie etwa § 123 I StGB ist. Das Gericht hat diese zivilrechtlichen Normen unter Rückgriff auf die Verfassungsauslegung interpretiert. Sich hierauf im Rahmen einer anderweitigen Interpretation derselben grundrechtlichen Vorschrift zu beziehen, steht wiederum nichts im Wege.

Werden Zellen – und dies ist der zweite problematische Aspekt – extrahiert, sodass an ihnen *in vitro* ein genetisches Enhancement durchgeführt werden kann, dann dient die Rückübertragung in den Körper des Patienten eben nicht der Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung von Fähigkeiten, die der Körper ursprünglich hatte, aber derer er verlustig geworden ist oder zu werden droht. Auch in der Zeit zwischen Entnahme und Rückübertragung werden andere Zellen desselben Typs die ihnen biologisch zugewiesenen Funktionen ausüben. Ein enger Funktionszusammenhang besteht in aller Regel somit also nicht faktisch, wohl aber dem Willen des Patienten zufolge. Es stellt sich somit die Frage, ob dies ausreicht, um den Schutzbereich des Art. 2 II 1, 2. Alt. GG zu eröffnen. Einerseits kommt es bedeutend auf den Willen und die Vorstellung des Patienten an. Andererseits ist der Schutzbereich des § 823 I BGB durch die Rechtsprechung in dem konkreten Fall deswegen ausgeweitet worden, weil die Kryokonservierung des Spermas die einzige Möglichkeit für den Patienten darstellte, ein genetisch „eigenes“ Kind zu zeugen und daher eine besondere Belastungssituation und ein besonderes Interesse an der Aufbewahrung des Spermas in kryokonservierter Form bestand. Dieses Interesse ist aber von grundlegenderer Bedeutung für und gesteigertem Einfluss auf den eigenen Lebensplan und somit ein elementarerer als das, sich über das ohnehin schon gesunde Maß hinaus zu verbessern.

Das bedeutet nun keineswegs, dass dieses Interesse gänzlich ungeschützt wäre, es sagt lediglich aus, dass kein Bedürfnis besteht, dem Persönlichkeitsrecht auch im Rahmen des Art. 2 II 1 GG ein Forum einzuräumen, zumal dies nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ohnehin ein Freiheitsrecht ist. Zwar ließe sich argumentieren, dass der Wunsch nach einem Enhancement so stark sein kann, dass die jeweilige Person sich mit ihrem bisherigen, ursprünglichen Körper nicht identifiziert, sich ihre Persönlichkeitsstruktur auch mittels des Enhancements körperlich materialisiert manifestieren soll und entsprechend die körperliche Befindlichkeit betroffen ist. Dennoch geht es bei den vom Gericht angestellten Überlegungen darum, dass durch die Möglichkeit der Rückübertragung der Körperbestandteile Nachteile vermieden werden sollen. Das heißt, dass in diesen Fällen ein pathologischer Zustand oder eine anderweitige Verschlechterung eintritt, wenn der Transfer der ausgelagerten Körperteile auf den Querkörper unterbleibt. Beim Enhancement führt dies jedoch nicht zu einem *malus* gegenüber dem bisherigen

Zustand, sondern es verbleibt bei dem jeweiligen *status quo*. Der verfassungsrechtlich angeordnete Gedanke, der das Gericht veranlasst hat, § 823 I, 2. Var. BGB als erfüllt anzusehen, wäre daher in Fällen des Enhancements verfehlt. Zum Zwecke der genetischen Verbesserung aus dem Körper ausgegliederte einzelne Zellen sind somit nicht mehr als zum Körper gehörig zu erachten. Ihnen gegenüber obliegt dem Staat somit keine Schutzpflicht aus Art. 2 II 1, 2. Alt. GG.

Sollen die Zellen hingegen nicht *in vitro*, sondern durch direkte Verabreichung eines Genvektors *in vivo* verändert werden, so ist auch diese Zuführung mit einer Einwirkung auf den Körper des Patienten verbunden und berührt zweifelsohne somit zunächst einmal den Schutzbereich des Art. 2 II 1, 2. Alt. GG.

Das gleiche gilt für die Veränderung von Zellen der Zygote oder des Embryos. Unabhängig davon, ob die zu bearbeitenden Zellen zuerst aus dem Zellverband herausgelöst werden oder die genetische Modifikation unter Fortbestand der körperlichen Verbindung zu dem Gesamtkomplex vorgenommen wird, erfolgt doch ein Eingriff in die physische Substanz der Zygote oder des Embryos.

In allen genannten Fällen, das heißt sowohl bei der Modifikation von somatischen Zellen als auch von Keimbahnzellen, und zwar sowohl bei der Durchführung *in vivo* als auch *in vitro*, bestehen zurzeit darüber hinaus noch nicht unbeachtliche medizinische Risiken, wie eingangs im Rahmen der medizinisch-biologischen Erörterungen dargelegt wurde.

Diese Risiken könnten jedoch ebenso wie soeben identifizierte Eingriffe dann rechtmäßig sein und somit keine Schutzpflicht des Staates begründen, wenn diese von einer Einwilligung des jeweiligen Patienten oder eines Dritten, etwa der (zukünftigen) Eltern, gedeckt ist. Anders als mit Hinblick auf das Recht auf Leben, welches in negativer Ausprägung nicht vorkommt, das heißt welches kein Recht auf die eigene (Selbst-)Tötung verleiht,<sup>821</sup> ist eine Selbstgefährdung beziehungsweise eine Einwilligung in die Gefährdung der eigenen Gesundheit durch Dritte in den oben geschilderten Grenzen<sup>822</sup> durchaus zulässig.<sup>823</sup> Sofern die jeweils betroffene Entität nicht zur Einwilligung selbst in der Lage ist, etwa weil sie noch nicht einmal geboren ist oder aufgrund ihrer fehlenden geistigen und sittlichen Reife, steht die Möglichkeit der Einwilligung grundsätzlich den gesetzlichen Vertretern, insbesondere den Eltern, zu.

Gerade hierbei wird jedoch deutlich, dass die Entscheidungs- und Vertretungskompetenz der Eltern durch das fiduziarische, zuvorderst dem Kindeswohl dienende Grundrecht (beziehungsweise die Pflicht) der Eltern aus Art. 6 II GG<sup>824</sup> begrenzt ist und ein Eingriff zum Zweck eines genetischen Enhancements durch sie

<sup>821</sup> von Mangoldt/Klein/Starck-Stark, GG, Art. 2 Abs. 2 Rdnr. 192.

<sup>822</sup> Hierzu BGHSt 49, 166 ff.; Fischer, StGB, § 228 Rdnr. 8; Kindhäuser/Neumann/Paeffgen-Paeffgen, StGB, § 228 Rdnr. 33, 37, 40 ff.; Lackner/Kühl, StGB, § 228 Rdnr. 10 f.; Schönte/Schröder-Stree, StGB, § 228 Rdnr. 5 ff.

<sup>823</sup> Entsprechendes regelt einfachgesetzlich auch § 228 StGB.

<sup>824</sup> BVerfGE 59, 360 (376 f.); 64, 180 (189); 72, 122 (137); 107, 104 (121); von Mangoldt/Klein/Starck-Robbers, GG, Art. 6 Abs. 2 Rdnr. 140, 145 ff.; Jarass/Pieroth, GG, Art. 6 Rdnr. 36; Maunz/Dürig-Badura, GG, Art. 6 Abs. 2, 3 Rdnr. 109; von Münch/Kunig-Coester/Waltjen, GG, Art. 6 Rdnr. 81.



nur genehmigt werden könnte, wenn dies im Hinblick auf Art. 2 II 1, 2. Alt. GG dem Kindeswohl entspräche. Aufgrund der bislang bestehenden Gefahren und der weitgehenden Unkontrollierbarkeit der Integration am exakten Genloкус und der korrekten Expressierung lassen sich die Gefahren noch nicht einmal vollständig überblicken, geschweige denn mit hinreichender Sicherheit beurteilen. Solange diese Voraussetzung jedoch nicht erfüllt ist, entspräche ein solcher Eingriff lediglich einem Humanexperiment.

Die Gefahren, die hiermit zusammenhängen, lassen sich, da ein pathologischer Zustand, welchen es gegebenenfalls zu beseitigen gilt, oder das Risiko eines solchen nicht besteht, nicht durch potentielle Nutzen, die, wenn sie den *status quo* zunächst auf ein als „gesund“ zu charakterisierendes Maß anheben, schwerer wiegen als diejenigen, die aus einer Verbesserung ohnehin schon im Allgemeinen guter und ausreichender Fähigkeiten resultieren, aufwiegen. Zumindest vorübergehend widerspricht die Durchführung eines genetischen Enhancements aus Sicherheits-erwägungen damit dem Kindeswohl und unterfällt somit nicht der Einwilligungsbefugnis der (zukünftigen) Eltern. In diesem Umfang liegt daher ein Sachverhalt vor, welcher die Schutzpflicht des Staates aktualisiert.

Des Weiteren stellt sich aber die Frage, ob eine geborene und einwilligungsfähige Person wirksam über ihr Recht aus Art. 2 II 1, 2. Alt. GG disponieren kann und so den Eingriff selbst beziehungsweise das Risiko einer Gesundheitsschädigung aus der grundsätzlichen Schutzpflicht des Staates ausklammern kann oder ob der Staat auch diesen gegenüber insofern eine Schutzpflicht zu erfüllen hat, als dass er, da sich in diesem Falle Schutzpflichten und Abwehrrechte auf denselben personalen Grundrechtsträger beziehen, die jeweilige Person vor sich selbst schützen muss. Art. 2 I GG gewährt grundsätzlich ein Recht auch auf Selbstschädigung,<sup>825</sup> Art. 2 II 1 GG begründet keine Pflicht des Staates, das Individuum in jedem Fall vor einer Schädigung zu schützen, sondern überlässt diesem selbst ein Wahlrecht hinsichtlich seiner – und sei es drum: pathologischen – Konstitution,<sup>826</sup> und gewährt entsprechend ebenso ein Recht auf Selbstgefährdung<sup>827</sup> als Minus gegenüber der Schädigung. Gleichzeitig ist aber anerkannt, dass Art. 2 II 1 GG dem Staat auch Schutzpflichten auferlegt. Während dem Staat hierbei in der Regel ein weiter Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zukommt, verengt sich dieser, so wird vertreten, umso mehr, je größer die Gefahr für Leben oder Gesundheit ist.<sup>828</sup> Ohne vertieft in die Paternalismusdebatte um staatliche (legislative) Tätigkeit unter dem „Mantel der Fürsorge“<sup>829</sup> einsteigen zu wollen, so sind doch zwei zentrale Einwände gegen eine staatlich verordnete gesundheitsgemäße Lebensfüh-

<sup>825</sup> Vergleiche Dreier-Schulze-Fielitz, GG, Art. 2 II Rdnr. 84.

<sup>826</sup> Auch Heileingriffe zur Wiederherstellung der Gesundheit stellen eine Verletzung der körperlichen Integrität dar, lassen sich also nicht durch ihren Zweck, die Therapie, rechtfertigen (Dreier-Schulze-Fielitz, GG, Art. 2 II Rdnr. 38), sodass dem Betroffenen in Konsequenz ein Recht auf Krankheit zuzuerkennen ist.

<sup>827</sup> Maunz/Dürig-Di Fabio, GG, Art. 2 Abs. 2, Rdnr. 82.

<sup>828</sup> Dreier-Schulze-Fielitz, Art. 2 II Rdnr. 86, 90.

<sup>829</sup> Steiner, MedR 2003, 1 (3).



rung zu bedenken. Zunächst einmal wird auch einem genetischen Enhancement wie jedem anderen medizinischen Eingriff eine entsprechende Aufklärung voranzugehen haben. Erst hierdurch wird eine selbstbestimmte Entscheidung, ob der Eingriff durchgeführt werden soll und man bereit ist, die damit einhergehenden Risiken zu tragen, ermöglicht. Darüber hinaus ist zu beachten, dass Grundrechte prinzipiell Freiheitsräume begründen sollen, in denen Menschen als Personen, die als solche ernst zu nehmen sind, eine eigenverantwortliche Suche nach individuellen Maßstäben und ein daran orientiertes gelungenes Leben ermöglicht wird. Wenn hierzu für ein Individuum gehört, für die eigene Person Risiken einzugehen und Schäden in Kauf zu nehmen, dann ist dies Teil seiner Persönlichkeit und Selbstbestimmung, die in Art. 2 II 1 GG besonders verbürgt wird.<sup>830</sup> Vor diesem Hintergrund scheidet eine Schutzpflicht des Staates gegenüber erwachsenen, einsichtsfähigen und hinreichend informierten Menschen gegen sich selbst und ihren erklärten Willen aus. Hiervon unberührt bleiben jedoch Regelungen bezüglich Umfang und Modalitäten der eine informierte Entscheidung wie eine Einwilligung erst möglich machenden Aufklärung.

Nach den angestellten Erwägungen ist die staatliche Schutzpflicht nur insofern ausgelöst, als nicht einsichts- und selbständig einwilligungsunfähige erwachsene Personen betroffen sind. In konkreter Anwendung auf Fälle des genetischen Enhancements bedeutet dies, dass lediglich die Zygote und der Embryo mit Hinblick auf Art. 2 II 1, 2. Alt. GG zu schützen sind. Sofern aber eine Einwilligung durch die von der Maßnahme betroffene Person vorliegt, was, da eine zwangsweise Durchführung von Enhancementmaßnahmen freilich nicht zur Debatte steht, bei der Modifikation von somatischen Zellen stets der Fall ist, würde sich ein staatlicher Schutz des Rechtsträgers gegen sich selbst dem Paternalismusvorwurf ausgesetzt sehen.

#### dd) Reichweite der Schutzpflicht aus Art. 2 II 1, 2. Alt. GG

Fraglich ist in diesen begrenzten, die staatliche Schutzpflicht auslösenden Fällen, wie weitreichend diese tatsächlich ausgestaltet ist. Beim Recht auf körperliche Unversehrtheit ist dabei zu berücksichtigen, dass Verletzungen dieses Grundrechts nicht von derselben Endgültigkeit sein müssen wie beim Recht auf Leben. Die Pflicht des Staates zum Schutz der körperlichen Unversehrtheit ist daher grundsätzlich schwächer.<sup>831</sup> Dennoch sind die Größe des Risikos und die Intensität des zu gewährenden Schutzes in ein angemessenes Verhältnis zu bringen, sodass mit wachsendem Risiko auch die Erforderlichkeit des Schutzes zunimmt.<sup>832</sup> Wie bereits festgestellt, sind die gesundheitlichen Risiken im Zusammenhang mit Maßnahmen des genetischen Enhancements jedoch erheblich. Nicht nur schwerste Schädigungen, sondern sogar der Tod der genetisch modifizierten Entität sind bislang zu befürchten und dabei auch nicht so unwahrscheinlich, dass sie vernachlässigt werden

<sup>830</sup> Gutmann, NJW 1999, 3387 (3388).

<sup>831</sup> Pieroth/Schlink, Grundrechte, § 9 III 2 Rdnr. 433.

<sup>832</sup> Dreier-Schulze-Fielitz, GG, Art. 2 II Rdnr. 86, 90.

könnten. Solange die medizinische Forschung keine signifikanten Fortschritte im Hinblick auf die Sicherheit der Genmodifizierung macht, erscheint daher ein gesetzliches Verbot auch als durchgriffsstärkste Form der Erfüllung der Schutzpflicht gerechtfertigt.

#### ee) Ergebnis

Auch mit Blick auf Art. 2 II 1, 2. Alt. GG ist – gegenwärtig – somit ein umfassendes gesetzliches Verbot von genmodifizierenden verbessernden Maßnahmen an Zygoten und Embryonen gerechtfertigt.

## **2. Verteilungsgerechtigkeit und Ressourcenallokation, Wettbewerb und Markt**

Auch wenn sich der Rahmen vorliegender Arbeit zunächst nur auf die Regulationssituation in Deutschland bezieht und freilich auch eine nationale Haltung gefunden werden muss, so ist doch aber final ein internationaler Regelungskonsens erstrebenswert.<sup>833</sup> Nicht selten kam und kommt es schon zum Zwecke anderer Eingriffe oder Behandlungen zu einer Art Medizin-Tourismus. Aufgrund der im Vergleich zu Deutschland und anderen Ländern geringeren Kosten zieht es viele Patientinnen und Patienten zu beispielsweise schönheitschirurgischen Eingriffen in osteuropäische Länder. Jedoch ist die Reise ins Ausland zum Zwecke eines im weitesten Sinne medizinischen Eingriffs nicht immer nur finanziell attraktiv. Zuweilen bestehen dort liberalere Rechtsordnungen, die Maßnahmen ermöglichen, die in Deutschland verboten und strafbewehrt sind. Die Niederlande waren so vor allem in den 1980er-Jahren für ihre permissivere Regelung bezüglich eines Schwangerschaftsabbruchs bekannt, weswegen viele der dort durchgeführten Abtreibungen an Frauen aus dem Ausland vorgenommen wurden. In Großbritannien regelt der 1990 erlassene *Human Fertilization and Embryology Act* die Durchführung der Präimplantationsdiagnostik implizit mit und lässt sie in lizenzierten Zentren zum Zwecke der Untersuchung auf schwerwiegende Erbkrankheiten oder chromosomale Störungen, der Geschlechtsselektion im Falle von geschlechtsgebundenen Erbkrankheiten sowie der Feststellung der Eignung als Gewebespender für ein bereits lebendes, erkranktes Geschwisterkind zu.<sup>834</sup>

Ein solcher Medizin-Tourismus kann nicht nur, soweit in Ergänzung zum vorangegangenen Abschnitt, weitere medizinische Risiken für die Patienten bedeuten, etwa weil die medizinische Expertise für die Nachsorge im Heimatland beispiels-

<sup>833</sup> Vergleiche *Fukuyama*, Das Ende des Menschen, S. 263 f.; auch *Buchanan*, Better than Human, S. 88 prophezeit die Abwanderung aus Ländern, die genetische Enhancements restriktiv regulieren, in Länder mit permissiveren Gesetzen; *Glover*, Choosing Children, S. 77.

<sup>834</sup> *Deutscher Ethikrat*, Stellungnahme Präimplantationsdiagnostik, S. 77.

weise mangels Erfahrung aufgrund eines gesetzlichen Verbotes ungenügend ist. Darüber hinaus könnte eine uneinheitliche Regelung das Problem der Verteilungsgerechtigkeit, welches sich ohnehin schon innerhalb einer Gesellschaft zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsschichten stellt, von denen sich nicht jede den Zugang zu neuen und teuren biotechnologischen Verfahren leisten können, auf die Makroebene zwischen den Gesundheitssystemen heben. Unterschiede zwischen Ländern hohen und solchen niedrigen Einkommens könnten sich weiter verschärfen.<sup>835</sup>

Vorliegend soll jedoch das Augenmerk auf Erwägungen der Gerechtigkeit zwischen mehreren Individuen beziehungsweise sozialstrukturell unterschiedlichen Gesellschaftsschichten gerichtet werden. Auch hier drängen Fragen der gerechten Verteilung und Ressourcenallokation.<sup>836</sup>

### a) Zugrundeliegende Annahmen

Um das Ausmaß dieser Problematik adäquat beurteilen zu können, ist es aber zunächst elementar, sich darüber klar zu werden, wie Ungleichheiten beschaffen sein müssen, damit sie zugleich auch Ungerechtigkeiten sind. Beklagt man die Ungerechtigkeit genetischer Enhancements, so liegen dem, analysiert man die Befürchtungen und gliedert sie in ihre Bestandteile und Voraussetzungen auf, vier vorausgehende Annahmen zugrunde.<sup>837</sup>

Zunächst einmal kann eine ungleiche Verfügbarkeit von genetischen Enhancements nur dann eine ungerechte Verteilung derer darstellen, wenn diese persönliche Güter, also solche Güter betreffen, die nur dem Individuum nützen, das sie hat, und die Verteilung zwischen mehreren Subjekten ein Null-Summen-Spiel ist. Das ist dann der Fall, wenn der Vorteil des einen gleichzeitig der Nachteil eines anderen ist, beide sich also gegeneinander aufwiegen. Anschauliches Beispiel hierfür ist der Kuchen, der unter mehreren Person aufgeteilt werden soll: Nehme ich mir ein besonders großes Stück und esse es alleine, so profitiere alleine ich, da nur ich das Geschmackserlebnis habe, hinterher nicht mehr hungrig bin und nur mir die Nährstoffe zugutekommen. Gleichzeitig ist mein Gewinn aber der Verlust der anderen, denn mein Stück ist der zu verteilenden Masse entzogen. Die zweite Voraussetzung ist, dass es sich bei genetischen Enhancements um Güter handelt, die dem – mehr oder weniger freien – Markt unterliegen, das heißt angeboten werden, um Profit zu generieren, nachgefragt und – so die dritte Voraussetzung – teuer gehandelt werden oder aufgrund anderer Umstände nicht allen Marktteilnehmern in gleichem Maße zugänglich sind. Schließlich wäre viertens zu fragen, welche Rolle der Staat und eine staatliche Regulierung auf diesem Markt spielen.

<sup>835</sup> Coenen/Schuijff/Smits, *The Politics of Human Enhancement and the European Union*, S. 527; Glover, *Choosing Children*, S. 79; Harris, *Enhancing Evolution*, S. 62.

<sup>836</sup> Vergleiche beispielsweise Baylis/Robert, *Bioethics* 18 (1), 1 (11 f.); Glover, *Choosing Children*, S. 78; *The President's Council on Bioethics*, *Beyond Therapy*, S. 281 ff.

<sup>837</sup> Hierzu sehr ausführlich Buchanan, *Better than Human*, S. 112 ff.

Fraglich ist jedoch, inwiefern diese Annahmen auch auf genetische Enhancements zutreffen. Die Techniken werden freilich ebenso wie andere medizinische Verfahren oder Produkte Teil eines Marktes werden, der auch durch Angebot und Nachfrage bestimmt ist und der, wie schon heute mit Blick auf sogenannte Life-style-Behandlungen deutlich wird, große Gewinne zu generieren in der Lage ist. Gleichzeitig kann davon ausgegangen werden, dass genetische Enhancements teure Verfahren sein werden, die sich nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung leisten können; dem Gros bleibt der Zugang hierzu aus finanziellen Gründen und aufgrund der sogleich festzustellenden Tatsache, dass es sich bei genetischen Enhancements keineswegs um von der gesetzlichen Krankenversicherung zu tragende Sozialleistungen handeln wird, hingegen verwehrt. Wie bereits oben festgestellt, unterscheidet sich die moderne, positive Eugenik von der negativen Eugenik des 20. Jahrhunderts gerade dadurch, dass diese von privater Seite angestrebt werden und der Staat hierbei keine beziehungsweise eine regulierende Rolle spielen wird. Inwiefern er aufgrund ansonsten verbleibender Ungerechtigkeiten die Ungleichheiten nivellierend eingreifen sollte, wird im Folgenden noch zu erörtern sein.

Zu bedenken ist dabei jedoch, dass die erste Grundannahme bei genetischen Enhancements nicht notwendigerweise erfüllt sein muss. Freilich kommen die verbesserten Eigenschaften und vermehrten Fähigkeiten dem genmodifizierten Individuum zugute. Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dass sie nicht ausschließlich diesem, sondern auch anderen, nicht genverbesserten Individuen nützen. So ist es durchaus möglich, dass der Enhancement-Patient aufgrund seiner gesteigerten Leistungsfähigkeit auch beruflich besonders erfolgreich ist, ein hohes Einkommen erzielt und entsprechend der von ihm zu zahlende Einkommenssteuersatz ansteigt, was für die gesamte Gesellschaft vorteilhaft ist. Auch die generelle Stärkung und Verbesserung des Immunsystems Einzelner kann auf eine Vielzahl von Personen positive Effekte haben, weil die immunologisch genverbesserte Person nicht mehr als Multiplikator für ansteckende Krankheiten fungieren kann. Derselbe Gedanke lag vor dem Hintergrund der pandemischen sogenannten Schweinegrippe in den Jahren 2009 und 2012 dem Aufruf an die breite Bevölkerung zugrunde, sich gegen das Influenza-A-Virus H1N1 impfen zu lassen. Ziel war neben dem Schutz des Einzelnen auch die Vermeidung der weiteren Ausbreitung und somit auch der Schutz derjenigen, die eventuell nicht geimpft waren. Unter solchen Voraussetzungen jedoch ist die Verteilung der Eigenschaften und Fähigkeiten kein Null-Summen-Spiel, weil die genverbesserte Person diese nicht anderen, nicht genmodifizierten Personen wegnimmt oder diese aufgrund der vorteilhaften Position des Enhancement-Patienten eine schlechtere Ausgangslage haben. Vielmehr hat das Enhancement der einen Person gleichzeitig positive Auswirkungen auch auf eine Vielzahl anderer Personen, die *Buchanan* als *network effects*<sup>838</sup> bezeichnet. Auch derartige *positive-sum*-Effekte müssen in Erwägung gezogen werden, wenn man determinieren möchte, inwiefern die durch ein Enhancement entstehenden Ungleichheiten zugleich auch Ungerechtigkeiten sind.

---

<sup>838</sup> *Buchanan*, *Better than Human*, S. 116.

## b) Bestehen eines sozialrechtlichen Anspruchs auf Enhancement

Inwiefern aber der Zugang zu genetischen Enhancements tatsächlich beschränkt sein wird und nicht allen offensteht, soll nunmehr in einem ersten Schritt geprüft werden. Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist dabei, dass es nur dann einer mit den notwendigen finanziellen Mitteln ausgestatteten Minderheit vorbehalten sein wird, derartige Eingriffe durchführen zu lassen,<sup>839</sup> wenn genetische Enhancements keine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung sein sollten, auf die der Versicherte dieser gegenüber einen Anspruch hat, und zu vermuten steht, dass sie auch längerfristig keine Kassenleistung sein werden.

Fraglich ist jedoch bereits, ob das SGB V, auf das ein solcher Anspruch gestützt werden könnte, überhaupt anwendbar ist. § 1 S. 1 SGB V sieht als Zielvorgabe<sup>840</sup> neben der Erhaltung und der Wiederherstellung der Gesundheit der Versicherten auch die Verbesserung des Gesundheitszustandes vor.

Eine Krankheit im sozialrechtlichen Sinne, deren Vorliegen die zentrale Voraussetzung für die Anwendbarkeit des SGB V darstellt, ist ein vom Leitbild des gesunden Menschen abweichender, „*regelwidrige[r] Körper- und Geisteszustand, der therapeutische Maßnahmen gebietet oder in Arbeitsunfähigkeit wahrnehmbar zutage tritt*.“<sup>841</sup> Das Leitbild des gesunden Menschen ist funktional zu bestimmen und es ist zu fragen, ob die jeweilige Person die als normal zu geltenden psychophysischen Funktionen ausüben kann.<sup>842</sup> Was in diesem Sinne als normal zu verstehen ist, in welchen Fällen, in welchem Umfang und in welcher Art und Weise regelwidrige Körper- oder Geisteszustände behandelt werden sollen, wird gemäß der §§ 91, 92 SGB V vom Gemeinsamen Bundesausschuss in den von ihm erlassenen Richtlinien bestimmt. Das Sozialrecht sieht von einer Legaldefinition des Krankheitsbegriffs ab, um ihn so dynamisch und entwicklungs offen untergesetztlich zu gestalten. Inwiefern die Konstitution derjenigen Personen, die sich einem genetischen Enhancement unterziehen möchten, beziehungsweise die des (noch zu zeugenden) Kindes eine regelwidrige, vom normalen Zustand negativ abweichende ist, kann also nicht anhand des SGB V abschließend beurteilt werden, sondern unterliegt der veränderlichen Beurteilung, auf die unterschiedliche, später noch darzustellende soziale Faktoren Einfluss haben wie etwa eine allgemeinen gesteigerte Erwartungshaltung aufgrund der bloßen Möglichkeit der genetischen Verbesserung oder eine faktische Gewöhnung mitsamt einer sich hieran anpassenden ethischen Bewertung aufgrund einer sich – wenn auch nur in begrenztem, da vertragsärztlichem Rahmen – ausbreitenden Praxis.

<sup>839</sup> Hiervon geht auch *Glover*, Choosing Children, S. 79 aus.

<sup>840</sup> Es handelt sich um keine Anspruchsgrundlage: Becker/Kingreen-Becker/Kingreen, SGB V, § 1 Rdnr. 1.

<sup>841</sup> BSGE 13, 134 (136); 16, 177 (179 f.); 19, 179 (181); 35, 10 (12); 39, 167 (168); 59, 119 (121); 93, 252 (252 f.) m.w.N.; Laufs/Uhlenbruck-Laufs, Handbuch des Arztrechts, § 2 Rdnr. 11; ähnlich Becker/Kingreen-Becker/Kingreen, SGB V, § 11 Rdnr. 13; BeckOK SGB V-Knispel, § 27 Rdnr. 5.

<sup>842</sup> Becker/Kingreen-Becker/Kingreen, SGB V, § 11 Rdnr. 13.

Nach aktuellem Verständnis sind im Falle von Enhancement jedoch Personen betroffen, deren physische und/oder psychische Konstitution nicht negativ von dem abweicht, was bislang als gesund qualifiziert wird; sie weisen keine pathologischen Zustände auf. Das SGB V ist auf sie und das genetische Enhancement somit nicht anwendbar, sodass hierüber kein allgemeiner Anspruch gegen die gesetzliche Krankenversicherung begründet werden kann.

Auch die in § 1 S. 1 SGB V genannte Zielvorgabe der Gesundheitsverbesserung vermag kein anderes Ergebnis zu begründen. Gemeint ist hiermit lediglich die Prävention im Sinne einer Stärkung gesundheitsfördernder Umstände zur Minimierung gesundheitsriskanter Faktoren in der Arbeits- und Lebenswelt.<sup>843</sup> Nun könnte man geneigt sein anzuführen, dass Gesundheitsverbesserung genau das ist, was durch ein Enhancement erreicht werden soll: Eine Verbesserung oder Vermehrung von Gesundheit ausmachenden Eigenschaften und Fähigkeiten. Allerdings ist dieses Ziel der Gesundheitsförderung nur vor dem originären Telos der §§ 20 ff. SGB V zu betrachten und dieser beschränkt sich, wie das SGB V überhaupt, auf die Vermeidung von Krankheiten. Eine Förderung der Gesundheit ist daher nur insofern durch das SGB V erfasst, wie dies erforderlich ist, um mehr oder weniger latenten Risiken und Bedrohungen für die Gesundheit entgegenzuwirken oder diese zu beseitigen. Bei einem Enhancement bestehen jedoch, auch wenn es beim bisherigen Verlauf und der unbeeinflussten Entwicklung bliebe, weder Risiken noch bereits angelegte Bedrohungen für Pathologien. Entsprechend ist auch über diese Normen kein Anspruch auf Übernahme der Kosten für ein genetisches Enhancement herzuleiten

### c) Art. 3 I GG

Ist genetisches Enhancement jedoch keine allen im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung zugängliche Technologie, so wirft dies die Frage auf, ob mit Blick auf gleichheitsrechtliche Vorschriften genetische Enhancements zu verbieten sind, weil diese selbst einen diskriminierenden Akt darstellen oder weil sie aufgrund der faktisch begrenzten Verfügbarkeit zu einer sozialen, mittelbare Diskriminierung führen.

In diesem Zusammenhang wird vorgebracht, dass die Entstehung einer genetischen Zweiklassengesellschaft drohe, wenn sich bereits bestehende soziale Unterschiede in geno- sowie phänotypischen Eigenschaften niederschlägen. *Lenk* beispielsweise verweist auf die Folgen der Ökonomisierung und Kommerzialisierung medizinischer Dienste in den USA, wo die soziale Stellung von Schwangeren, die in den USA faktisch häufig an Hautfarbe und ethnische Herkunft geknüpft ist, über das Ausmaß von medizinischer Versorgung bei der Geburt entscheidet, weswegen die Säuglingssterblichkeit unter farbigen Neugeborenen diejenige unter weißen Neugeborenen um 130% übersteigt. Bestehen, so *Lenk*, jedoch bereits in der Grundversorgung schichtenspezifische Missverhältnisse, die sich nicht auf das US-amerikanische Gesundheitssystem beschränken, in dem es bislang keine staatliche

<sup>843</sup> Kasseler Kommentar-*Becker*, Sozialversicherungsrecht I, § 20 Rdnr. 2.

Fürsorge oder eine gesetzliche Pflichtversicherung gab, so sei anzunehmen, dass diese im Hinblick auf den Zugang zu teuren Verfahren modernster Medizintechnik zunehmen werden. Hinsichtlich der dadurch entstehenden physischen und psychischen Unterschiede wirft *Lenk* auch die Frage auf, inwiefern der Umstand, dass diese nun nicht natürlich-biologischer Kontingenz, sondern der willentlichen Entscheidung unterliegen, eine neue Qualität der Diskriminierung bedeutet und zwar durchaus gemessen an der Feststellung, dass auch heute trotz aller, wenn auch lediglich natürlich-kontingenter bedingter Unterschiede alle Menschen in der politischen und juristischen Sphäre als gleiche zu behandeln sind.<sup>844</sup> Auch *Siep* formuliert diesen Aspekt wie folgt: Die „bisher zufällige Ausgangssituation für den sozialen Wettbewerb [wird] nunmehr selbst zum Gegenstand von Wettbewerb und Markt“, was im Vergleich zu den natürlichen, anlagebedingten Unterschieden zwischen Individuen eine qualitativ andere Ungerechtigkeit begründe.<sup>845</sup>

Prominent angesprochen ist also zunächst der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 I GG. Diese Grundrechtsnorm ist als subjektiv-öffentliches Recht und insoweit auch als Abwehrrecht ausgestaltet, dass es nicht Eingriffe in die individuelle Freiheitssphäre, sondern bestimmte Modalitäten von staatlichem Handeln abwehrt,<sup>846</sup> nämlich solche, die wesentlich Gleiches willkürlich, das heißt ohne auf vernünftigen Erwägungen zu beruhen, die der Eigenart des betroffenen Sachbereiches entsprechen oder anderweitig einleuchtend sind, ungleich oder wesentlich Ungleiches willkürlich gleich behandeln.<sup>847</sup> Nach der neuen Formel des Bundesverfassungsgerichts ist zu fragen, ob „eine Gruppe von Normadressaten im Vergleich zu anderen Normadressaten anders behandelt wird, obwohl zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, daß sie die ungleiche Behandlung rechtfertigen könnten“.<sup>848</sup> Während nach der Willkürformel also irgendein sachlicher Grund zur Rechtfertigung ausreicht, bedarf es durch die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprinzips schon im Rahmen der Ungleichbehandlung eines Grundes, der in einem angemessenen Verhältnis zur Ungleichbehandlung stehen muss.<sup>849</sup> Zu überlegen ist mit Blick auf Enhancements beziehungsweise auf die Rechtfertigung eines Verbotes derselben, ob ein nicht reglementierter Zugang, der nur den Gesetzen eines freien Marktes unterworfen ist, durch den faktisch begrenzten Zugang zu einer Diskriminierung führt, die durch ein für alle geltendes Verbot des Enhancements beseitigt werden müsste. Anders formuliert: Es ist zu fragen, ob und inwiefern den Staat Schutz- und Gewährungspflichten zugunsten der Gleichheit treffen.

<sup>844</sup> *Lenk*, Therapie und Enhancement, S. 83 f.; die genannten Zahlen beziehen sich auf das Jahr 1996.

<sup>845</sup> *Siep*, Wissen – Vorbeugen – Verändern, S. 85 (Ergänzungen Welling).

<sup>846</sup> Dreier-Heun, GG, Art. 3 Rdnr. 17.

<sup>847</sup> BVerfGE 1, 14 (52); 4, 143 (155); 27, 364 (371); 42, 64 (72); 67, 186 (195); mit umgekehrtem Vorzeichen BVerfGE 3, 58 (135 f.); 71, 255 (271).

<sup>848</sup> BVerfGE 55, 72 (88); 60, 123 (133 f.).

<sup>849</sup> Dreier-Heun, GG, Art. 3 Rdnr. 21 m.w.N.; Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf-Kannengießer, GG, Art. 3 Rdnr. 15, 17.



Hierbei können rechtliche und faktische Gleichheit differenziert werden. Rechtliche Gleichheit ist dabei Basis der Freiheit der Menschen. Sie geht davon aus, dass Menschen von Geburt an gleich und frei sind. Das Prinzip der rechtlichen Gleichheit ist für das Verfassungsrecht unverzichtbar.<sup>850</sup>

Faktische Gleichheit hingegen ist ein Konzept, welches nicht Ausgangspunkt staatlichen Handelns, sondern dessen Ziel ist. Umfasst kann hiervon über die faktische Durchsetzung rechtlicher Gleichheit hinaus auch eine soziale Gleichstellung sein.<sup>851</sup> Als solches würde faktische Gleichheit eine Umverteilung von Gütern verlangen, also zum Zwecke der Förderung einzelner Gruppen die Ungleichbehandlung anderer und zumeist auch Eingriffe in Freiheitsrechte voraussetzen,<sup>852</sup> weswegen, wollte man dem Konzept einer durch Art. 3 I GG gebotenen faktischen Gleichheit folgen, ein Gleichheits-Paradoxon entstünde: „*Wer faktische Freiheit herstellen will, muß rechtliche Ungleichheit in Kauf nehmen. Andererseits gilt, daß rechtliche Gleichheit wegen der faktischen Verschiedenheit der Menschen einige faktische Ungleichheiten stets bestehen läßt und diese oft verstärkt. [...] Was nach dem einen Prinzip eine Gleich-, ist nach dem anderen eine Ungleichbehandlung, und umgekehrt.*“<sup>853</sup> Beide Gleichheitsbegriffe können somit nicht nebeneinander bestehen. Ein und derselben Norm kann aus logischen Gründen und aus solchen der Einheitlichkeit des Rechts nicht ein Prinzip sowie gleichzeitig sein Gegenteil entnommen werden.<sup>854</sup> Gegen die Verpflichtung des Staates auf Herstellung sozialer Gleichheit über Art. 1 III GG und damit gegen eine egalitäre Gleichheitskonzeption spricht zudem eine historische Betrachtung der gesamten Sozialbewegung, deren Ziel jederzeit ein relatives Mehr an Gleichheit, nicht aber absolute Gleichheit der Subjekte war. Dies wäre auch nicht mit den eine moderne Gesellschaft konstituierenden Freiheitsrechten in Einklang zu bringen.<sup>855</sup> Nach dem grundgesetzlichen Verständnis hat die Gleichheit keinen Wert an sich, sondern übernimmt vielmehr eine dienende Funktion, indem sie die Voraussetzung für die freie Entfaltung menschlicher Einzigartigkeit ist. Die sich durch diesen Freiheitsgebrauch ergebenden Ungleichheiten werden aber von der Verfassung gestattet. Hieraus ergeben sich die grundgesetzliche Präponderanz der Freiheit und eine Absage an eine Egalisierung, Kollektivierung und Nivellierung.<sup>856</sup>

Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Versuch des Gesetzgebers, Ungleichheiten zu mindern, nicht zulässig wäre. Über das Sozialstaatsprinzip, nicht aber über Art. 3 I GG, können durch Leistungsgesetze Angleichungen faktischer Verhältnisse erreicht und so relative soziale Gerechtigkeit hergestellt werden. Zentral ist hier aber die Art und Weise der Wirkung solcher Leistungsgesetze, die beispielsweise

<sup>850</sup> von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 3 Abs. 1 Rdnr. 3; Alexy, Theorie der Grundrechte (b), S. 379.

<sup>851</sup> Dreier-Heun, GG, Art. 3 Rdnr. 66.

<sup>852</sup> von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 3 Abs. 1 Rdnr. 4.

<sup>853</sup> Alexy, Theorie der Grundrechte b), S. 378 f.

<sup>854</sup> Dreier-Heun, GG, Art. 3 Rdnr. 68.

<sup>855</sup> Isensee/Kirchhof-Zacher, HStR II, § 28 Rdnr. 39 f.

<sup>856</sup> Maunz/Dürig-Dürig, GG, Art. 3 Abs. 1 Rdnr. 135.

finanzielle Unterstützung für Kinder finanziell schwacher Familien bei der Schul- oder Universitätsausbildung gewähren: Das eingesetzte Mittel ist hierbei nicht die Beschneidung von gut situierten oder anderweitige Vorteile genießenden Gruppen in den sie privilegierenden Gütern. Vielmehr soll ein sozialer Ausgleich dadurch erreicht werden, dass das, die soziale Ungleichheit begründende Minus, welches bei den von einem Leistungsgesetz erfassten und begünstigten Personengruppen vorhanden ist, gleichsam aufgefüllt wird. Im Hinblick auf die Technologie des genetischen Enhancements könnte dies bedeuten, dass der Zugang dazu im Rahmen des Sozialsystems auch solchen Personen gewährleistet werden könnte, die nicht über die entsprechenden finanziellen Mittel verfügen. Inwiefern hierauf aber tatsächlich auch Teilhabeansprüche gestützt werden können, ist nicht Aufgabe des vorliegenden Dissertationsprojektes. Festzuhalten ist jedoch, dass ein Verbot des genetischen Enhancements nicht auf Art. 3 I GG, dessen Telos gerade nicht gleichmacherische Aspekte umfasst, gestützt werden kann.

#### **d) Strategien zum Umgang mit Ungleichheiten**

Dies allerdings lässt weiterhin die Frage offen, wie mit den resultierenden Ungleichheiten umzugehen ist. Zur Beantwortung ist sinnvollerweise zunächst ein Blick auf den Umgang mit bereits bestehenden Ungleichheiten. Diese können sich aus der genetischen Ausstattung ergeben, wobei sie aktuell mangels Eingriffs- und Steuerungsmöglichkeit natürlich entstanden sind, was hier bedeuten soll, dass sie Resultat der kontingenten Rekombination der DNS im Wege der Befruchtung einer Ei- mit einer Samenzelle ist, die ohne äußere, genverändernde Eingriffe erfolgt. Ungleichheiten können aber ebenso aus anderen, nicht genetisch bedingten Umständen resultieren. So besteht heute nahezu einhellig die Auffassung, dass besonders Frauen, Migranten sowie Menschen mit Behinderung gesellschaftlich benachteiligt sind oder zumindest nicht dieselben Chancen haben wie die Mehrheitsbevölkerung, deren männlicher oder deren gesunder Teil. Relevanz entfaltet dieser Umstand prominent bereits im Gleichbehandlungs- und Antidiskriminierungsrecht.

Das AGG als Umsetzung der europäischen Richtlinien des Rates 2000/43/EG vom 29. Juli 2000, 2000/78/EG vom 27. November 2000, 2002/73/EG vom 23. September 2002, 2004/113/EG vom 13. Dezember 2004 und 2006/54/EG vom 5. Juli 2006 beispielsweise lässt als Reaktion auf im sachlichen Anwendungsbe- reich des § 2 I AGG vorhandene gesellschaftliche Ungleichheiten und den sich daraus ergebenden Benachteiligungen in § 5 sogenannte positive Maßnahmen zu. Auch unter der Bezeichnung als *affirmative action*, positive Diskriminierung oder Förderung geläufig, sollen sie durch die Gewährung von Begünstigungen und Besonderstellungen der Angleichung der Situation von Trägern von Merkmalen, aufgrund derer nach § 1 AGG nicht diskriminiert werden darf, an die von Nicht-Merkmalsträgern dienen.<sup>857</sup>

---

<sup>857</sup> Rust/Falke-Raasch, AGG, § 5 Rdnr. 3 ff.

Interessant mit Blick auf genetische Enhancements ist hier das Merkmal der Behinderung. Dieses wird im AGG nicht alleine medizinisch/individuell verstanden, das heißt es werden nicht lediglich Probleme in den Blick genommen, die für Menschen mit Behinderungen aufgrund ihrer körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigung bestehen. Vielmehr ist die Rahmenrichtlinie 2000/ 78/EG durch die soziale Konzeption des Behinderungsbegriffes beeinflusst, die als Störungsursache auch soziale und Umweltbarrieren anerkennt.<sup>858</sup> Weder das Gemeinschaftsrecht noch das AGG enthält jedoch eine Legaldefinition des Begriffes der Behinderung.<sup>859</sup> Nach der Gesetzesbegründung jedoch soll dieser Begriff des AGG dem im SGB IX entsprechen. Hiernach gelten Menschen als behindert, wenn ihre körperlichen Funktionen, geistigen Fähigkeiten oder ihre seelische Gesundheit von dem alterstypischen Gesundheitszustand abweichen, dies mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate andauern wird und die Teilhabe der betroffenen Person am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.<sup>860</sup> Referenzgröße für die Beurteilung des Vorliegens einer Behinderung ist damit der gesunde Mensch.<sup>861</sup>

Wie eingangs jedoch im Rahmen der Definition des Enhancementbegriffs festgestellt, sind (zukünftige) Personen, an denen ein genetisches Enhancement durchgeführt werden soll, (voraussichtlich) pathologisch unauffällig, das heißt ebenso gesund wie Personen, an denen keines durchgeführt werden soll. Insbesondere ist diese Beurteilung letzterer durch die Durchführung bei ersteren nicht betroffen. Freilich ist nicht ausgeschlossen, dass langfristig nicht genverbesserte Menschen als gesundheitlich defizitär betrachtet werden, so wie dies *peu à peu* im Rahmen der evolutionären<sup>862</sup> Entwicklung immer wieder der Fall gewesen ist. Es steht jedoch zu vermuten, dass eine derart geänderte Beurteilung eine lange Zeitspanne in Anspruch nehmen wird, gehört dazu nicht nur eine quantitative, sondern auch eine qualitative Komponente: Neben einer zahlenmäßig bedeutenden Verbreitung des Enhancements müsste eine ebenfalls von einer breiten Mehrheit geteilte Evaluierung des genetischen Enhancements beziehungsweise des hiermit erreichten (Gesundheits-)Zustandes als gut und erstrebenswertes Ziel gegeben sein.<sup>863</sup>

Sollte dies langfristig eventuell eintreten, so ist bis dahin das AGG dennoch nicht einschlägig. Möchte man eine Annäherung der Chancen nicht genverbesserter Menschen an diejenigen, die einem genetischen Enhancement unterzogen wurden, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt erreichen, so ist ein anderer Weg zu finden beziehungsweise das AGG entsprechend dahingehend zu ergänzen, dass Arbeitgeber,

<sup>858</sup> Adomeit/Mohr, AGG, § 1 Rdnr. 123; Rust/Falke-Rust, AGG, § 1 Rdnr. 72.

<sup>859</sup> Rust/Falke-Rust, AGG, § 1 Rdnr. 4 f., 73.

<sup>860</sup> Deutscher Bundestag, Drucksache 16/1780, S. 31; Adomeit/Mohr, AGG, § 1 Rdnr. 125, 127; Bauer/Göpfert/Krieger, AGG, § 1 Rdnr. 38; Rust/Falke-Rust, AGG, § 1 Rdnr. 78 f.

<sup>861</sup> Rust/Falke-Rust, AGG, § 1 Rdnr. 79.

<sup>862</sup> Diese Äußerung soll lediglich verdeutlichen, dass sich der Wandel eines solchen Verständnisses in der Regel nicht kurzfristig vollzieht. Darüber, ob die enhancement-induzierte geno- und phänotypische Entwicklung des Menschen Teil der (natürlichen) Evolution wie wir sie heute begreifen ist, soll hier noch nicht geurteilt werden.

<sup>863</sup> Beides wird später („Wunsch-Medizin versus Zwang-Medizin“) noch ausführlich erörtert.

für die die Einstellung von ausschließlich genverbesserten und daher besonders intelligenten, effizient arbeitenden und dabei nur wenige Fehler machenden Arbeitnehmern attraktiv erscheinen müsste, zu einem bestimmten – unproblematisch, solange genetische Enhancements ohnehin nicht weit verbreitet sind, auch hohen – Prozentsatz Menschen beschäftigen müssen, deren Genom nicht durch einen gentechnischen Eingriff modifiziert wurde.

In diesem Punkt könnte eine solche Quotenregelung durchaus die befürchteten Probleme mindern. Zu betonen ist hier insbesondere, dass es in diesem Zusammenhang nicht um die Frage geht, wer, gemessen an seinen anlagebedingten Fähigkeiten, die bessere Leistung erbringt.<sup>864</sup> Dem Arbeitgeber kommt es lediglich auf die rein tatsächliche Leistung und ihren absoluten Wert an. Ähnliche Regelungen sind heute bereits bekannt: Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich mindestens 20 Arbeitnehmern sind dazu verpflichtet, einen gewissen Anteil ihrer Stellen mit schwerbehinderten Menschen zu besetzen (§§ 71 ff. SGB IX, wobei aber gemäß § 77 SGB IX eine Ausgleichsabgabe vorgesehen ist, soweit dieser Pflicht nicht nachgekommen wird). In den USA wird versucht, (gesellschaftsstratifikatorisch bedingte) finanzielle Unterschiede zumindest teilweise zu kompensieren, sodass ihr Einfluss auf den Zugang zu Schul- und Universitätsbildung reduziert wird: Kinder, die namhafte und gleichzeitig zumeist teure Privatschulen besuchen, werden zu einem deutlich höheren Prozentsatz auch entsprechend gute und teure Universitäten besuchen als dies Kinder tun werden, die ihre Schulbildung an einer ganz normalen High School erhalten. Dies hängt einerseits damit zusammen, dass Eltern, die ihr Kind bereits auf eine kostspielige Schule schicken, sich auch die Studiengelder für das universitäre Pendant aufgrund ihres in der Regel dann finanziell starken Hintergrundes eher leisten können als durchschnittlich verdienende Eltern. Ein anderer Faktor ist natürlich aber auch, dass diese Kinder an solchen Schulen eine besonders gute Bildung erhalten. Der Zugang zu solchen Schulen und Universitäten hängt aber nicht nur von den finanziellen Möglichkeiten ab, sondern auch von dem Ergebnis des sogenannten SAT-oder ACT-Tests<sup>865</sup>. Stipendienprogramme ermöglichen sodann auch solchen Schülern die Einschreibung etwa an einer Ivy League Universität, die zwar entsprechend intelligent und begabt sind, sich aber ein Studium an einer solchen Hochschule finanziell sonst nicht leisten können. Darüber hinaus achtet die Mehrheit der amerikanischen Hochschulen auch auf eine Förderung von ethnischen Minderheiten im Bewerbungsprozess um Studienplätze (sogenanntes „*Affirmative Action*“-Programm).

John Harris<sup>866</sup> schlägt hingegen vor, die gesamte Verteilung genverbessernder Ressourcen einer Art Gen-Lotterie zu überantworten, deren Hauptpreis es ist, sich für sein Kind erwünschte Gene und Eigenschaften zusammenstellen zu dürfen.

<sup>864</sup> Dies ist später unter „Authentizität, Zurechenbarkeit und Vergleichbarkeit von Leistungen“ zu diskutieren.

<sup>865</sup> Wegen der Uneinheitlichkeit des amerikanischen Schulsystems sind diese standardisierten Tests entwickelt worden, die die Hochschulreife der Absolventen einer High School evaluieren sollen.

<sup>866</sup> Harris, Clones, Genes and Immortality, S. 234.

Sollte aufgrund der Zielgerichtetheit und der willentlichen Planbarkeit des Eingriffs eine qualitativ neue und im Vergleich zu der aufgrund von natürlich-kontingenten, nicht beeinflussten genetischen Unterschieden größere Form der Ungerechtigkeit entstehen, so ist dieser Kritikpunkt mit *Harris'* Gen-Lotterie sicherlich abgegolten: Der Zugang zu Genverbesserungen ist zufällig und die Chance hierauf für jeden Menschen gleich. Auch wenn die genetische Ausstattung und die genetischen Unterschiede sodann weiterhin auf menschlichen Eingriffen beruhen, ist doch die Ausgangssituation für den sozialen Wettbewerb selbst wieder dem Wettbewerb im Sinne des Marktes entzogen und daher dem Zufall unterliegend. Die Ungleichheiten, die sich jedoch aus den unterschiedlichen Ausgangssituationen derjenigen, die Glück hatten und die mittels eines genetischen Enhancements verbessert wurden, und der anderen, die ohne diesen genetischen Vorteil auskommen müssen, ergeben und die soeben erörtert wurden, sind jedoch auch durch *Harris'* Lösungsvorschlag nicht behoben.

Mit Blick auf diese Asymmetrien unterschiedlicher Ausgangssituationen wird insbesondere das Problem der Chancenungleichheit angemahnt. Inwiefern dies jedoch tatsächlich gegeben ist, hängt davon ab, wie weit man den Begriff der Chancengleichheit fasst. Während zum Teil nur das Minimum einer lediglich formalen, auf die Beseitigung rechtlicher Schranken begrenzten Gleichheit verlangt wird, ließe sich auch die Abschaffung außerrechtlicher Diskriminierungen fordern. Am weitesten gehen schließlich diejenigen, die aufgrund von bestehenden Ungleichheiten etwa aufgrund des Geschlechts, der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder sexuellen Orientierung nicht nur eine Ungleichbehandlung verbieten, sondern darüber hinaus auch die Effekte von Glück und Pech in der sozialen Lotterie kompensieren wollen, die, zumeist über die Familienzugehörigkeit, determinieren, in welcher sozialen Ausgangslage sich die jeweilige Person befindet und wie gut und vielfältig ihre Chancen ausgestaltet sind.<sup>867</sup> Während eine rechtliche und auch außer-rechtliche Gleichbehandlung mit den dargestellten Konzepten weitgehend gewährleistet werden kann, stellt sich nunmehr die Frage, ob Gerechtigkeitstheorien schon ein früheres Eingreifen und die Schaffung eines „*level playing field*“, einer Startebene als gleiche Basis für alle, erforderlich machen. Dies kann beispielsweise im Segelsport dadurch geschehen, dass die Größe der Segel vorgeschrieben ist, im Fußball die Teams aus jeweils elf Spieler bestehen oder Skispringer von der gleichen Höhe der Sprungschanze starten. In edukativem oder beruflichem Rahmen lässt sich dies durch die Verpflichtung zur Beschäftigung oder zur Hochschulzulassung einer gewissen Anzahl von Frauen, Menschen mit körperlicher Behinderung, mit Migrationshintergrund oder – zukünftig – ohne den Vorteil eines genetischen Enhancements erreichen.

Zur Begründung der Bestrebung nach angeglichenen und daher gerechten Ausgangssituationen kann auf unterschiedliche Konzeptionen zurückgegriffen werden: Zum einen wird darauf rekuriert, dass ungerechte soziale Strukturen dazu führen, dass Pech in der sozialen Lotterie Chancen limitiert und so zu Chancenungleichheit führt. Unabhängig von der sozialen Startposition sollen Personen mit gleichem Ta-

<sup>867</sup> *Buchanan/Brock/Daniels/Wikler*, *From Chance to Choice*, S. 65.

lent, gleichen Fähigkeiten und gleicher Einsatzbereitschaft auch die gleichen Aussichten auf Erfolg, das heißt die gleichen Chancen haben. Der Schwerpunkt dieses Ansatzes liegt somit auf Limitationen durch soziale Strukturen und nicht durch natürliche Unterschiede zwischen Personen. Der *brute luck view* hingegen stellt darauf ab, dass Personen wegen etwas, das sie nicht kontrollieren können und worauf sie keinen Einfluss haben können, keine geringeren Chancen und Erfolgsaussichten haben sollen. Vorliegend führen beide zu unterschiedlichen Ergebnissen: Die unterschiedliche kontingent-natürliche genetische Ausstattung oder andere im Rahmen der natürlichen Lotterie zustande kommenden Ungleichheiten haben hinsichtlich der sozial-strukturellen Konzeption zunächst keine weiteren Implikationen. Soziale Strukturen haben auf das Ergebnis der natürlichen Lotterie keinerlei Einfluss. Nach dem *brute luck view* aber sind auch solche Ungleichheiten ungerecht, da sie nicht der Kontrolle der betreffenden Person unterliegen. Die natürliche genetische Ausstattung ist das Resultat genetischer und (bislang) zufälliger Kombination und ist daher der jeweiligen Person nicht zurechenbar. Daher verlangt unmittelbar nur der *brute luck view* ein kompensatorisches Eingreifen zugunsten derjenigen, die in der natürlichen Lotterie nur den Trostpreis gezogen haben.<sup>868</sup>

Zentrale Bestrebung, die beiden Ansätzen jedoch gemein ist, ist die Sicherung eines fairen Wettbewerbs. Diesem Zweck dient die Forderung nach Chancengleichheit. Dies kann zum einen bedeuten, dass der Wettbewerb als solcher fair sein muss, er also entlang eines entsprechend ebenfalls als fair zu bewertenden Regelwerkes stattfindet. Zum anderen kann dies aber auch die Forderung umfassen, Personen von Umständen zu befreien oder zu beschützen, die ihnen den Erwerb von Fähigkeiten, die sie zum Eintritt in den Wettbewerb oder dessen Fortführung benötigen, nicht erlauben. Dies ist besonders anschaulich und einsichtig, wenn es um das Erfordernis einer Gesundheitssorge im Sinne einer Krankheitsbekämpfung geht, die den betroffenen Personen die kompetitive Partizipation ermöglicht.<sup>869</sup> Angewandt auf das genetische Enhancement könnte man nun schlussfolgern, dass es entsprechend erforderlich ist, „normalen“ Menschen genetische Enhancements zu ermöglichen, sodass sie im Wettbewerb um Ausbildungs- und Arbeitsplätze oder auch um so private Dinge wie Sexual- oder Lebenspartner sinnvollerweise teilnehmen können.

Wettbewerb ist dabei stets ein soziales Phänomen, er findet immer im Rahmen einer sozialen Kooperation statt, innerhalb derer die einzelnen Personen „normale Wettbewerber“ sein sollen. Inwiefern relevante natürliche Unterschiede existieren und inwiefern diese nachteilig sind, das heißt welche Eigenschaften geschätzt werden und mit welchen Vorteilen beziehungsweise mit deren Fehlen Nachteile verknüpft sind, hängt dabei aber von den Rahmenbedingungen sozialer Kooperation ab. Insofern lässt sich das Erfordernis des kompensatorischen Eingriffes selbst dann begründen, wenn man dem *brute luck view* ansonsten kritisch gegenübersteht.<sup>870</sup>

<sup>868</sup> Buchanan/Brock/Daniels/Wikler, *From Chance to Choice*, S. 66 f.

<sup>869</sup> Buchanan/Brock/Daniels/Wikler, *From Chance to Choice*, S. 74.

<sup>870</sup> Buchanan/Brock/Daniels/Wikler, *From Chance to Choice*, S. 73 f.



In der Folge stellt sich allerdings die unter dem Stichwort „*Equality of What?*“ debattierte Frage, welche Umstände es genau sind, bezüglich derer Gleichheit und Gerechtigkeit herzustellen ist. Die Antwort hierauf, Ressourcen allgemein seien gerecht zu verteilen, ist weitestmöglich gehalten.<sup>871</sup> Zur Kompensation *natürlicher* (so auch: genetischer) Ungleichheiten kann sodann eine Umverteilung *sozialer* Ressourcen in den Blick genommen werden.<sup>872</sup> Dies wird, wie oben schon ausgeführt, beispielsweise zugunsten von Menschen mit Behinderungen bereits getan, indem Arbeitgeber dazu verpflichtet sind, einen bestimmten Anteil ihrer Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen zu besetzen. Andererseits kann zur Erreichung von Gleichheit und Gerechtigkeit einen direkt die Ungleichheiten selbst eliminierenden Eingriff in die natürliche Lotterie gefordert werden.<sup>873</sup>

Auch *Sandel* geht von der Annahme aus, dass privilegierte Mitglieder einer Gesellschaft denjenigen Mitgliedern, die nicht solche Vorzüge genießen, zum Ausgleich dieser Ungleichheit verpflichtet sind. Den Grund dafür sieht *Sandel* in der Tatsache, dass natürliche Talente und Fähigkeiten, die denjenigen Individuen, die das Glück hatten, damit ausgestattet zu werden, Erfolg ermöglichen, nicht auf einem Tun dieser Subjekte beruhen oder einen Verdienst derer darstellen. Vielmehr handele es sich um Geschenke. Diese jedoch seien aufgrund dieses Umstandes mit denen zu teilen, die, ohne etwas dafür zu können, ein solches Geschenk nicht erhalten haben.<sup>874</sup> Indem *Sandel* verlangt, dass die Güter, deren Verteilung auf reinem Glück basiert und keinen vernünftigen Grund wie die Überlegung, dass jemand sich im Vergleich zu anderen ein Mehr verdient habe, erkennen lässt, umzuverteilen sind, vertritt er einen Standpunkt des *luck-egalitarianism*. Im Gegensatz zu zahlreichen politischen Theorien wird hier jedoch nicht für eine Umverteilung dessen plädiert, was aufgrund der Geschenke, etwa solcher der Gen-Lotterie erarbeitet und verdient werden konnte,<sup>875</sup> sondern für eine Umverteilung der Geschenke selbst. Der Grund für Solidarität mit Menschen, die in der Gen-Lotterie nicht ein Gewinn-Los gezogen haben, und für eine moralische Verpflichtung zur Kompensation der daraus resultierenden schwächeren Stellung dieser Personen liegt aber nicht in der bloßen und kapitalistischen Überlegung, dass sie damit eine ökonomisch betrachtete Schuld einlösen wollen. Dies gründet vielmehr auf den Gedanken des *luck-egalitarianism*. Sollen jedoch nicht nur die aufgrund dessen, wozu die ungleich und gegebenenfalls auch ungerecht verteilten Geschenke (der Gen-Lotterie etwa) befähigt haben, erzielten Verdienste umverteilt werden, sondern gar ein Ausgleich hinsichtlich der Geschenke erreicht werden, so spricht dies am Ende des Tages nicht gegen, was *Sandel* schließlich beabsichtigt, sondern gerade für die Durchführung

<sup>871</sup> *Buchanan/Brock/Daniels/Wikler*, From Chance to Choice, S. 76 ff.

<sup>872</sup> *Rawls*, Eine Theorie der Gerechtigkeit, S. 92 ff., 121 ff.; *Allhoff*, Journal of Evolution & Technology 18, 10 (12 f.) unter Bezugnahme auf Rawls; *Buchanan/Brock/Daniels/Wikler*, From Chance to Choice, S. 78 f.

<sup>873</sup> *Buchanan/Brock/Daniels/Wikler*, From Chance to Choice, S. 79.

<sup>874</sup> *Sandel*, The Case against Perfection, S. 91.

<sup>875</sup> Beispielfhaft zu nennen wäre hier etwa die Einkommensteuer.



von Enhancements, die, so *Harris*, schließlich den Bedarf nach einer Umverteilung reduzieren, während sie mehr Güter hierfür generieren.<sup>876</sup>

Wenn ein Erfordernis eines derartigen Ausgleiches auch – im wahrsten Sinne des Wortes – prinzipiell vertreten wird, so wird zumeist aber vermieden, die praktische Umsetzung zu fordern. Dies liegt einerseits an dem Umstand, dass das, was als Gut, Fähigkeit oder Vorzug, beziehungsweise als Defizit oder Malus gilt, durch soziale Strukturen definiert wird. In Abhängigkeit von den veränderlichen Rahmenbedingungen sozialer Kooperation unterliegt ebenfalls der Wert bestimmter Eigenschaften Schwankungen. In unterschiedlichen sozialen Umgebungen, so ließe sich daraus folgern, werden die verschiedenen Eigenschaften stets auch unterschiedlich bewertet werden, sodass es keine Ressource gibt, die dies *per se* wäre. Gleichzeitig mag auch deren Bewertung divergieren. Wollte man ihre Verteilung egalisieren, bedeutete das eine Verleugnung des Wertpluralismus. Allerdings sind, wie bereits ausgeführt, Eigenschaften, Fähig- und Fertigkeiten denkbar, die so flexibel sind, dass ihre qualitative oder quantitative Vermehrung in sich weitgehend unterscheidenden Gesellschaften und zu unterschiedlichen Zeiten vernünftigerweise wertgeschätzt würde.<sup>877</sup>

Während *Buchanan et al.* davon ausgehen, dass diese Überlegungen das Reden von genetischer Gleichheit als irreführend erscheinen lassen, möchte ich das Gegenteil annehmen. Nimmt man *Rawls'* Konzept der *primary goods* ernst, so erscheint es durchaus als geboten, im Interesse eines fairen Wettkampfes keine allzu großen Differenzen hinsichtlich dieser Güter zuzulassen. Wenn sich diese Erwägungen auch außerhalb des Rechtssystems bewegen, das heißt keine rechtliche Pflicht des Gesetzgebers zur Anhebung aller auf ein *genetically level playing field* begründen, so sind sie doch Ausdruck des moralisch Wünschenswerten oder Gebotenen.

Nichtsdestoweniger geht es vorliegend um die Frage eines Verbots des genetischen Enhancements und nicht um ein etwaiges Erfordernis der sozialrechtlichen oder anderweitig wohlfahrtsstaatlichen Bereitstellung dieser Technologie zugunsten von Personen, denen ansonsten die finanziellen Mittel zur Durchführung eines genetischen Enhancement zu ihrem eigenen Vorteil oder dem ihrer Nachkommen fehlen. Zur Rechtfertigung eines in Frage stehenden, mehr oder weniger umfangreichen Verbotes sind sie nicht dienlich,<sup>878</sup> können aber von dringender Relevanz sein, sobald genetisches Enhancements einigen wenigen privilegierten Personen zugänglich sein wird, um ein weiteres, nunmehr genetisch fixiertes und vorangetriebenes Auseinanderklaffen der gesellschaftlichen Schichten zu vermeiden. Die Ausführungen mögen sodann Orientierung bei der Frage der Sozialverträglichkeit eines als solches aber zulässigen genetischen Enhancements bieten.

<sup>876</sup> *Harris*, *Enhancing Evolution*, S. 120.

<sup>877</sup> *Buchanan/Brock/Daniels/Wikler*, *From Chance to Choice*, S. 79 f.

<sup>878</sup> Ähnlich auch *Harris*, *Enhancing Evolution*, S. 30.

### 3. Authentizität, Zurechenbarkeit und Vergleichbarkeit von Leistungen

Enhancement-kritische Stimmen verweisen darüber hinaus auf etwaige Fragen, die Enhancement-Techniken in Bezug auf die Zurechenbarkeit von erreichten Leistungen zu dem handelnden Subjekt und deren Vergleichbarkeit mit anderen Leistungen, insbesondere solchen, die mit Hilfe von unterschiedlichen Enhancements oder gänzlich ohne diese erbracht wurden, aufwerfen. Hierbei stehen sich die Positionen diametral gegenüber: Während beispielsweise *Sandel* vorbringt, dass einem genverbesserten Individuum für das, was es tut, und diejenige Person, die es ist, weniger Lob und Anerkennung oder Kritik gebührt, weil es die Verantwortlichkeit dafür durch das Enhancement eingebüßt hat,<sup>879</sup> und *Birnbacher* ausführt, dass aus den Leistungen eines künstlich modifizierten Menschen nicht mehr seine „*ureigenste Natur*“ spricht,<sup>880</sup> stellt *Harris* fest, dass authentische menschliche Tätigkeit nicht proportional zu dem ist, was erforderlich ist, um die Zurechenbarkeit einer Handlung zu begründen.<sup>881</sup>

#### a) Der Wert der Anstrengung

Zu erstgenanntem Problembereich hat beispielsweise *Juengst* vorgebracht, Handlungen und ihre Ergebnisse würden abgewertet, soweit diese nicht nur durch die verfolgten Ziele, sondern auch durch die Eigentlichkeit oder Authentizität der eingesetzten Mittel bestimmt werden:<sup>882</sup> *Juengst* führt so aus, dass biomedizinische Abkürzungen<sup>883</sup> soziale Praktiken wie etwa Training unterwandern und so den gesellschaftlichen Wert der erstrebten Verbesserung mindern.<sup>884</sup> Auch *Sandel* adressiert diese Thematik, wenn er befürchtet, dass mit zunehmender Bedeutung von Enhancements, beispielsweise im Profisport, die Begeisterung und Bewunderung der Zuschauer für Höchstleistungen verblasst – oder sich aber vom Athleten weg und auf seinen Apotheker oder Arzt hin verlagert.<sup>885</sup>

Allerdings ist hier zu betonen, dass es *Juengst* in seiner Argumentation zunächst auf den Wert anzukommen scheint, den die Gesellschaft besonderen Anstrengungen wie Training, Meditation oder anderer, Disziplin fordernder Praktiken zumisst und in Form von Lob, Bewunderung, gar Ehrerbietung ausdrückt. Die Behauptung geht sodann so weit, dass ein Ergebnis E von den Modalitäten der zu ihm führenden

<sup>879</sup> *Sandel*, The Case against Perfection, S. 25.

<sup>880</sup> *Birnbacher*, Natürlichkeit, S. 123.

<sup>881</sup> *Harris*, Enhancing Evolution, S. 111 („*Authentic human agency is not proportional to the effort required to be an agent.*“)

<sup>882</sup> *drze* 2002, 28 f.

<sup>883</sup> *Juengst*, What Does Enhancement Mean?, S. 39: „*biomedical shortcut*“.

<sup>884</sup> *Juengst*, What Does Enhancement Mean?, S. 39.

<sup>885</sup> *Sandel*, The Case against Perfection, S. 25.

Handlung H insofern charakterisiert wird, als dass diese ein maßgeblich zur Beurteilung des moralischen Wertes von E heranzuziehender Faktor seien. Der angebliche Zusammenhang von E und H wird dabei von *Juengst* nicht weiter erörtert, sondern als gegeben angenommen. Richtet man seinen Blick allein auf die Ergebnisse und sind diese die gleichen und zwar unabhängig davon, ob sie mit oder ohne Zuhilfenahme von Enhancements erreicht wurden, so ist *per se* beiden Ergebnissen dieselbe Wertigkeit zuzusprechen. Ein Ergebnis, welches als solches gut und wünschenswert ist, wird nicht intrinsisch schlecht, weil die Modalitäten des Zustandekommens von denen der bisherigen gesellschaftlichen Praxis abweichen oder nicht vollständig „aus eigener Kraft“ und ohne äußere Einflüsse erreicht wurde. Gelingt es dem Studenten nur deswegen, seine Hausarbeit noch rechtzeitig vor Abgabefrist einzureichen, weil er in großen Mengen Kaffee konsumiert hat, um die Nächte durcharbeiten zu können, so kann man zwar sein Zeitmanagement kritisieren, ihm aber nicht vorwerfen, die mit der Hilfe von Koffein erstellte Arbeit sei schlechter als genau die gleiche Arbeit, wäre sie nur ohne Koffeineinfluss entstanden. Daher liegt der Verdacht nahe, dass es *Juengst* nicht um eine tatsächlich unterschiedliche Wertung des Ergebnisses geht, welches durch eine biomedizinische Abkürzung erreicht wird, sondern um die Konservierung der bisherigen Praxis, zumindest aber um die Betonung des psychologischen, gesellschaftlichen, pädagogischen, kompetitiv-evaluativen<sup>886</sup> oder sonstigen Ausmaßes des Nutzens einer Anstrengung.

Diese Aspekte sehe ich durch die Möglichkeit eines das Ergebnis erleichternden Enhancements jedoch keineswegs bedroht. Im Gegenteil scheint mir die Möglichkeit der Umgehung von Anstrengungen das Inkaufnehmen dieser als besonders lobens- und achtenswert und eine Person, die ihre Errungenschaft mit den ihr auch ohne Enhancement zur Verfügung stehenden Möglichkeiten erreicht hat, als ehrenhaft herauszuheben. 42,195 Kilometer lassen sich unter Zuhilfenahme eines Fahrrades problemlos bewältigen, erst Recht kann man diese Strecke mit einem Kraftfahrzeug weitestgehend mühelos hinter sich bringen. Umso bewundernswerter ist es jedoch, wenn jemand diese Strecke, die klassische Marathondistanz, laufend zurücklegt. Als weiteres Beispiel soll eine Besteigung des Mount Everest dienen: Wird der höchste Berg der Welt unter Rückgriff auf Sauerstoffflaschen bezwungen, so ist dies schon eine große Anstrengung und verdient großen Respekt. Gelingt dies jedoch ohne technische Hilfsmittel, so wird es, wenn auch manch einer die Vernünftigkeit eines solchen Vorhabens und die Geisteskraft desjenigen, der dies unternimmt, anzweifeln mag, zumindest in Bergsteigerkreisen weithin als herausragend betrachtet und die einzig wahre Form der Besteigung gelobt. Aber das Ergebnis ist dasselbe: Jemand steht auf dem Mount Everest.

Auch *Juengst* scheint sodann aber einen Unterschied zwischen einem Ergebnis und der Modalität dessen Zustandekommens einzusehen, wenn er ausführt, dass, freilich auch im Falle der Zuhilfenahme von erleichternden Mitteln wie Enhancements, das Individuum der Urheber seiner Leistungen ist. Allerdings unterwirft er seine getätigten Ausführungen zur Wertigkeit der Ergebnisse sogleich der Frage

<sup>886</sup> Dies ist sogleich Gegenstand ausführlicher Diskussion.

ihrer Vergleichbarkeit<sup>887</sup> und vermengt somit zwei unterschiedlich voneinander zu beurteilende Fragen. Auf Letztgenannte soll sogleich, nachdem für die Zuschreibung des gleichen Werts zu einerseits ohne, andererseits aber mit Zuhilfenahme von Enhancements erreichten, im Übrigen aber vollständig gleichen Ergebnissen plädiert wurde, eingegangen werden.

Zuvor soll aber noch eine Auseinandersetzung mit der Überlegung, Anstrengungen zur Erreichung eines bestimmten Ziels hätten deswegen einen besonderen, eigenen Wert, da sie Willenskraft fördern, die verloren ginge, wenn das Ziel auch mittels der erwähnten biologisch-medizinischen Abkürzung, das heißt ohne Mühen und Anstrengung, erreichbar wäre. *Chatterjee* beispielsweise proklamiert den Grundsatz „no pain, no gain“ und verweist darauf, dass dadurch, dass jemand sich Mühe machen, Anstrengungen auf sich nehmen und einige Leiden und Rückschläge überstehen muss, um das, was er will, zu erreichen, sein Charakter erst geformt werde.<sup>888</sup> Auch *Buchanan* befürchtet, durch eine pharmazeutische oder durch anderweitige Enhancements vermittelte Abkürzung entstünde eine „moralische Schwammigkeit“ oder „moralische Schlaffheit“.<sup>889</sup> Er führt dabei aus, dass Produkte dieser Wirkweise bereits heute zur Verfügung stehen, und verweist auf das Medikament *alli*, das die Fettaufnahme während der Verdauung minimiert, indem Fette in Klumpen gebunden und so weitestgehend ausgeschieden werden.<sup>890</sup> Präparate, die diese Wirkungen versprechen, sind heutzutage zahlreich vorhanden und mittlerweile freiverkäuflich und so ohne Rezept erhältlich. Dies gilt ebenso für Medikamente, die auf gleiche Art und Weise die Aufnahme von Kohlenhydraten reduzieren sollen. Personen, die ihr Gewicht reduzieren möchten, sind so nicht beziehungsweise nur in geringerem Umfang darauf angewiesen, mit viel Disziplin und Durchhaltevermögen auf fettiges Essen oder Süßigkeiten zu verzichten. Während *Buchanan* das Risiko einer Verkümmern der Willensstärke, eines Schwundes unserer „moralischen Stärke“<sup>891</sup> nach eigenen Worten auch nicht unterschätzen möchte,<sup>892</sup> so kritisiert er dennoch die Schlussfolgerung, daraus würde ein Schwund unserer „moralischen Stärke“ resultieren, weswegen sämtliche Formen von Enhancement verboten werden sollten. Er führt an, dass auch andere Enhancements und vereinfachende Abkürzungen, obschon sie ebenfalls eine Einschränkung einiger anderer Fähigkeiten oder Eigenschaften zur Folge hatten, heute gang und gäbe sind und niemand vernünftigerweise deren Beseitigung fordern würde. Beispielsweise führt die Verwendung von Taschenrechnern zu einer Abnahme der Fähigkeiten im Kopfrechnen und die Benutzung von GPS-Geräten häufig schon dazu, dass die Fertigkeit der Standortbestimmung, Orientierung und Navigation nur mittels traditioneller Instrumente wie etwa Karten, einem Kompass und Zirkel zumeist gar nicht erst erlernt wird. Die Alphabetisierung hatte zur Folge, dass, da man die benötigten Informatio-

<sup>887</sup> Juengst, What Does Enhancement Mean?, S. 39.

<sup>888</sup> Chatterjee, *Neurology* 63 (6), 968 (971).

<sup>889</sup> Buchanan, *Better than Human*, S. 158: „moral flabbiness“.

<sup>890</sup> Buchanan, *Better than Human*, S. 158.

<sup>891</sup> Buchanan, *Better than Human*, S. 159: „moral powers“; Birnbacher, *Natürlichkeit*, S. 114 spricht davon, dass man durch einen wiederholten oder gar ständigen Einsatz von künstlichen Mitteln die Fähigkeit einbüßt, die zur Bewältigung von Situationen, in denen diese Mittel nicht zur Verfügung stehen, erforderlichen psychischen Ressourcen zu mobilisieren.

<sup>892</sup> Buchanan, *Better than Human*, S. 160.

nen jederzeit nachschlagen kann, die Anforderungen an die Gedächtnisleistung abnehmen.<sup>893</sup> Potenziert wird dies heute durch die geradezu ubiquitäre Verfügbarkeit des Internet.<sup>894</sup> Nichtsdestoweniger ist *Buchanan* der Auffassung, dass aufgrund des Risikos eines Verlustes, eines Verkümmerns von Fähigkeiten und Eigenschaften die genannten nicht-medizinischen Enhancements ebenso wenig generell verboten und abgeschafft werden sollten wie genetische Enhancements. Richtigerweise verweist er darauf, dass Enhancements anderweitige Möglichkeiten eröffnen können, um Willenskraft und Anstrengungen gewinnbringend einzusetzen.<sup>895</sup>

Der bloße Umstand, dass mittels Enhancements Ziele schneller oder einfacher und mit weniger Mühen erreicht werden können, gereicht somit nicht, um ein Verbot dessen begründen zu können. Weder unterwandern Enhancements darüber hinaus den eigenen Wert und die Wertschätzung und Bewunderung von Anstrengungen, noch reduzieren sie die Qualität des unter Zuhilfenahme von Enhancements erreichten Zieles. Dies gilt jedenfalls, solange man die jeweilige Leistung absolut betrachtet, das heißt losgelöst und unabhängig von anderen Leistungen, seien sie nun ebenfalls mittels (des gleichen oder aber auch eines anderweitigen) Enhancements oder gänzlich ohne ein solches erzielt worden. Ob und gegebenenfalls inwiefern sich dies ändert, wenn diese auf unterschiedliche Weise erreichten Ergebnisse verglichen und in Relation zueinander gesetzt werden sollen, ist im Folgenden zu erörtern.

## b) Leistungsevaluation

Argumente gegen Enhancement, die Fairness betreffen, sind, wie bereits angeklungen, in aller Regel in einem kompetitiven Milieu angesiedelt. Es wird entsprechend befürchtet, dass, sofern Enhancement nur einer Person oder nur einer bestimmten Gruppe zur Verfügung steht, etwa weil die vermutlich immensen Kosten nur von ohnehin gut situierten Personen getragen werden können, diese anderen gegenüber über ungerechte Vorteile bei schulischen Leistungsüberprüfungen, auf dem Arbeitsmarkt oder bei sportlichen Wettkämpfen verfügen.<sup>896</sup>

Stellt man hier nicht mehr auf ein Gleichheitserfordernis hinsichtlich des Zugangs zu biotechnologischen Eingriffen, einer angemessenen Ressourcenallokation oder anderer die Verteilungsgerechtigkeit betreffender Fragen ab, sondern richtet das Augenmerk nun auf eine Vergleichbarkeit von Leistungen, stellt sich insbesondere in einem kompetitiven Zusammenhang die Frage, wie mit genannten Ungleichheiten im Hinblick auf die komparative Evaluation unterschiedlicher Leistungen umzugehen ist. Um sie hier handhabbar zu machen, kommen unterschiedliche, mehr oder weniger praktikable und aussichtsreiche Strategien in Frage.<sup>897</sup>

<sup>893</sup> *Buchanan*, *Better than Human*, S. 159 f.

<sup>894</sup> So heißt es in einem Werbespot für einen Mobilfunkanbieter treffend „*Wir denken nicht, wir googeln.*“

<sup>895</sup> *Buchanan*, *Better than Human*, S. 159 f.

<sup>896</sup> *Greely*, *Human Biological Enhancement and U.S. Policy Tools*, S. 515; *The President's Council on Bioethics*, *Beyond Therapy*, S. 280.

<sup>897</sup> *Greely*, *Human Biological Enhancement and U.S. Policy Tools*, S. 516.

Zunächst könnte man das Problem schlichtweg umgehen, indem man Enhancements verbietet und unterbindet. Dies mag zwar in einem rein privatrechtlich geprägten Bereich möglich sein. So kann die *World Anti-Doping Agency* in den Grenzen ihres Zuständigkeitsbereiches, das heißt für den Wettkampfsport betreibenden Athleten, der sich freiwillig dem für seinen Sport geltenden Reglement unterwirft, die Verwendung bestimmter Substanzen untersagen. Dass ein allgemeines, bundesgesetzliches Verbot als Beeinträchtigung eines subjektiven Freiheits- oder anderen Rechtes gleichzeitig ebenfalls gerechtfertigt wäre, besagt dies jedoch nicht *per se*. Vielmehr ist hierfür entsprechend dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz festzustellen, ob dies zum Schutze eines konkurrierenden Rechts oder eines anderen legitimen Ziels geeignet, notwendig und dem Träger des beeinträchtigten Rechts auch zumutbar ist. Dies bleibt jedoch gerade zu prüfen. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass es freilich bundesrechtliche Verbotsvorschriften wie § 6a AMG gibt, der das Inverkehrbringen, Verschreiben oder die Anwendung von Arzneimitteln im Sport bei anderen untersagt. Über § 95 AMG stellt der Verstoß gegen § 6a AMG sogar eine Straftat dar. Rechtfertigendes Ziel des Arzneimittelgesetzes und dieses Verbotes ist indes nicht die Befürchtung von Ungleichheiten und daraus resultierender Ungerechtigkeiten oder Probleme bei der Leistungsevaluation. Arzneimittelrecht ist Risikovororgerecht. Es soll die Verkehrssicherheit von Arzneimitteln gewährleisten, zentrales Konzept ist das der Risikobewertung und des Risikomanagements.<sup>898</sup> Die Existenz dieser Norm stellt somit kein auf dem Grundsatz der Einheitlichkeit des Rechts gründendes Argument gegen eine Ablehnung eines auf die hier angesprochenen Befürchtungen gestützten Verbotes von Enhancement für den Fall, dass andere, mildere Lösungsmöglichkeiten bestehen.

Eine weitere Möglichkeit, die entstehenden Ungleichheiten zu vermeiden, könnte sein, Enhancement umfassend zugänglich zu machen, ohne dass aber die Verwendung obligatorisch wäre. Diese Option jedoch wirft praktische Probleme auf. Unklar ist hierbei zunächst einmal, wie Enhancements einem breiteren Personenkreis ermöglicht werden sollen, konkret also, wer für die dadurch entstehenden Kosten aufkommen wird, die von einer großen Mehrheit von Individuen rein tatsächlich nicht getragen werden können. Dies wird dem Sozialsystem jedoch ebenfalls keineswegs möglich sein; aufgrund der zu erwartenden immensen Kosten ist es nicht absehbar, dass Enhancements in Zukunft eine Kassenleistung werden würden. Diese Option scheitert daher schon an der Umsetzung.<sup>899</sup> Ein weiteres

<sup>898</sup> Rehmann, AMG, § 1 Rdnr. 1.

<sup>899</sup> Diesem Ergebnis steht auch nicht der sogenannte Nikolaus-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 6. Dezember 2005, Aktenzeichen 1 BvR 347/98, entgegen. Hiernach gebieten Art. 2 I GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip sowie Art. 2 II GG die Kostenübernahme und zwar auch, wenn die Behandlungsmethode nicht allgemein wissenschaftlich anerkannt ist, aber eine nicht ganz fernliegende Aussicht auf Heilung oder positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf besteht. Die Höhe der Kosten ist beim Eingreifen der staatlichen Schutzpflicht für derart hochrangige Rechtsgüter unerheblich. Eine solche Schutzpflicht besteht jedoch in Fällen des Enhancements mangels Gefährdung, die durch das Enhancement abgewendet werden könnte, nicht. Daher bleibt es dabei, dass die grundsätzliche Orientierung des allgemeinen Leistungskatalogs am Wirtschaftlichkeitsgebot und an finanzwirtschaftlichen Erwägungen zulässig ist.



Problem stellt zudem der Umstand dar, dass freilich eine zwangsweise Einführung genetischer Enhancements nicht in Frage steht, aber auch die universale Verfügbarkeit zu *de facto* zwangsähnlichen Situationen führen könnte. Zwar stünde die Anwendung dann zur je individuellen Disposition, aber mit einer steigenden Anzahl von genoptimierten Mitmenschen könnte man sich ebenfalls zu Verbesserungen bei sich selbst oder bei seinen Nachkommen genötigt sehen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Dies wird sogleich gesondert zu erörtern sein.

Schließlich könnte auch versucht werden, nicht die Ursache, also den nur selektiven Zugang zu Enhancement-Techniken, zu beheben, sondern das Augenmerk auf die Anpassung der Folgen zu legen, das heißt die Beseitigung der dadurch entstehenden Chancenungleichheiten bei Leistungsvergleichen. Erreicht werden könnte dies durch angepasste Evaluationsmaßstäbe. Gedanklich ist dieses Konzept angelehnt an die Bewertungen sportlicher Erfolge bei Olympischen Spielen für Sportler mit Behinderungen, den Paralympics.<sup>900</sup> Die Sportler werden dabei entsprechend ihrer Behinderung und dem Einfluss derer auf die funktionellen Fähigkeiten hinsichtlich der jeweiligen Sportart in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Durch eine differenzierte Berücksichtigung der variierenden Einschränkungen und entsprechend variierender Leistungsfähigkeit kann so ein Sportler den Sieg erringen, obschon ein anderer schneller, weiter oder höher lief, warf oder sprang. Im Hinblick auf die bloße Vergleichbarkeit von Leistungen, insbesondere im Rahmen von Sportwettkämpfen oder schulischen Leistungsüberprüfungen, ist diese Option eine sicherlich praktisch gut umsetzbare. Sie erlaubt ein Ranking, ohne dass die Vorteile, die eine Person aufgrund eines Enhancements hat, sich auf das Ergebnis und im Verhältnis zu anderen konkurrierenden Personen, die lediglich über ihre natürlichen, nicht aber verbesserte Fähigkeiten verfügen, auswirken würde. Ähnlich können auch Segler unterschiedlicher Bootsklassen ihr Können in einer einzigen Regatta messen, indem die jeweils gesegelten Zeiten mittels des sogenannten Yardstick-Quotienten vergleichbar gerechnet werden.

Darüber hinaus wäre auch eine Möglichkeit, keine veränderten Maßstäbe anzulegen oder die erreichten Werte, Punkte oder Noten nach unten zu korrigieren, sondern stattdessen neben einer Offenbarungs- auch eine Deklarierungspflicht einzuführen. Demzufolge dürfte das Evaluationsergebnis nur mit einem Zusatz angegeben werden, aus dem ersichtlich wird, dass die erzielte Leistung zumindest auch Resultat eines Enhancements war. Dies würde das Problem umgehen, dass, anders als bei der physikalisch und mathematisch zu ermittelnden Fahrt durch das Wasser, die ein Boot aufgrund seiner Länge maximal machen kann, das Ausmaß, mit welchem der Beurteilungsmaßstab anzupassen ist, kaum präzise determiniert werden kann. Es dürfte sich als ausgesprochen schwierig erweisen, die konkrete Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit zu bestimmen und festzulegen, wie die erreichte Punktzahl oder die Note herabgestuft werden muss. Außerdem ist es denkbar, dass die Auswirkungen von Patient zu Patient unterschiedlich sind. Eine Offen-

---

<sup>900</sup> So auch schon *The President's Council on Bioethics*, Beyond Therapy, S. 133.



barungs- und Deklarationspflicht hingegen würde sodann auch transparent machen, zu welchen Leistungen eine Person absolut, das heißt mit Enhancement, fähig ist. Insbesondere bei berufsqualifizierenden Prüfungen könnte dies die Möglichkeit eröffnen, dass zwar die absolut, also unter Zuhilfenahme von Enhancements erreichten Ergebnisse berücksichtigt werden, aber dann, wenn es gerade auf die absolute Leistungsfähigkeit ankommt wie etwa bei einigen Stellenvergaben wie der Einstellung eines Chirurgen, bei dem es vorrangig darauf ankommt, dass er mit ruhiger Hand, hochkonzentriert und entsprechend sicher operiert, im Rahmen des rechtlich Zulässigen eine zukünftige Verpflichtung des Bewerbers zu weiterem Enhancement vereinbart werden könnte.<sup>901</sup>

Kritisch ist hinsichtlich beider Lösungsstrategien jedoch abermals die Frage der Chancengleichheit in Bezug auf eine auf der Leistungsbeurteilung beruhende Auswahl, etwa wenn es um die Vergabe von Studien- oder Arbeitsplätzen geht. Hierbei ist primär von Interesse, zu welchen absolut zu beurteilenden Leistungen ein Bewerber in der Lage ist, nicht jedoch, ob er im Vergleich zu anderen Bewerbern überhaupt die veranlagungsbedingten Voraussetzungen zu einer quantitativ oder qualitativ besseren Leistung hat und ob er, gemessen an seinen Möglichkeiten, viel oder wenig leistet. Hinsichtlich der zum Zwecke der kompetitiven Leistungsevaluation erforderlichen Vergleichbarkeit aber bestehen mit dieser Möglichkeit der Anpassung der Beurteilungsmaßstäbe somit keine ein generelles oder partielles Verbot genetischen Enhancements rechtfertigende Kritikpunkte mehr.

#### ***4. Selbstwahrnehmung und Selbstverständnis, persönliche Authentizität, Autonomie und asymmetrische Machtverhältnisse***

Mit dem Faktum, dass bei Keimbahnmodifikationen sowie bei embryonalen oder frühkindlichen Eingriffen stets eine Person oder eine Personenmehrzahl, nämlich die (zukünftigen) Eltern, über die genetischen Dispositionen eines anderen Individuums entscheiden, sehen enhancement-kritische Stimmen auch die Fragen verbunden, ob das genverbesserte Individuum sich selbst oder seine Umgebung das Individuum als selbstbestimmt, unabhängig und autonom begreifen werden, oder ob es als manipuliertes, identitätsloses Objekt des Willens Dritter wahrgenommen wird. Mit Blick auf reproduktives Klonen schreibt *Gertrud Nunner-Winkler*: „Diese [sozialwissenschaftlichen Argumente gegen das Klonen] fokussieren auf die Befürchtung, reproduktives Klonen bedrohe die Identität der Betroffenen: Individuelle Unverwechselbarkeit, biographische Gestaltungsmöglichkeit und ein unbeeinträchtigtes Autonomiebewusstsein seien an die Einmaligkeit und Naturwüchsigkeit der Gen-Ausstattung gebunden.“<sup>902</sup> Wenn es vorliegend auch nicht um die Klonierung

<sup>901</sup> Für die Anregung hierzu in einer Diskussion danke ich *Sandro Wiggerich*.

<sup>902</sup> *Nunner-Winkler*, Können Klone eine Identität ausbilden?, S. 265 mit einer folgenden kritischen Analyse (Ergänzungen Welling).

von Menschen geht, so sind ebendiese Befürchtungen auch in der Enhancement-Debatte präsent. Sowohl hier, als auch beim Klonen wird einem Individuum ein Genom zugeschrieben, sei es nun, dass dieses eine Kopie des Genoms eines anderen Menschen ist, oder dass das Genom durch Ergänzung oder Modifikation einzelner Gene eine Anpassung erfahren hat. Aufgrund dieser zentralen Gemeinsamkeit ist auch die Debatte um Humanklonierung ins Blickfeld zu nehmen.

So referiert auch *Sandel* als Kritikpunkt gegen das Klonen das vielfach vorgebrachte Argument, Eltern verwehren durch die Auswahl der genetischen Ausstattung ihres Kindes diesem das Recht auf eine offene, unverplante Zukunft („*right to an open future*“) und das Kind müsse sein Leben im Schatten einer zuvor dagewesenen Person leben. Designer-Kinder seien niemals frei und autonom, und das gelte selbst dann, wenn die ihnen zugeteilten Eigenschaften begrüßenswerte sind, da sie diese in der Wahl ihres Lebensplanes einschränken würden. Auch *Sandel* verweist dabei darauf, dass diese Einwände gegen das Klonen ebenso mit Blick auf jegliche Formen der Biotechnik gelten, die es Eltern erlauben, die genetische Ausstattung ihrer Kinder zu wählen.<sup>903</sup> Kritisch merkt *Sandel* hierzu jedoch an – und hier soll, *for the sake of the argument*, vorbehaltlich präzisierender Ausführungen von einer direkten Beeinflussung phänotypischer Eigenschaften durch das jeweils modifizierte Gen ausgegangen werden –, dass niemand auch in Abwesenheit von Eltern, die das Genom nach Gusto kreieren, seine genetische Ausstattung auswählen, sondern nur kontingent erben kann, die ihn dann aber ebenso in der Wahl seines Lebensplanes einschränkt. Der Gegenpol zum gentechnologisch verbesserten Kind ist somit nicht eines, dessen Zukunft gänzlich frei und hinsichtlich keines Lebensplanes eingenommen ist, sondern ein Kind, das seine genetische Zusammensetzung nur dem Zufall der natürlichen Gen-Lotterie zu verdanken hat.<sup>904</sup> Zu demselben Ergebnis gelangt in Auseinandersetzung mit dem despotische Herrschaftsverhältnisse<sup>905</sup> zwischen den designenden Eltern und humanklonierten (beziehungsweise, wie gezeigt, auch: genmodifizierten) Kindern anmahnen *Kass* auch *Harris*. Er kritisiert *Kass*' Befürchtungen als übertrieben und verweist auf die Tatsache, dass das kindliche Genom auch im Wege ursprünglich-geschlechtlicher Reproduktion in gewisser Weise, wenn auch zufällig bedingt, festgeschrieben wird. Auch dieses jedoch bedeutet einen Verlust an Freiheiten hinsichtlich der offenstehenden Lebenswege. Ein ebensolcher Spielraum steht aber auch für ein geklontes oder genverbessertes Kind bereit; alles andere würde den Irrtum eines genetischen Determinismus unterliegen. Richtigerweise müsse aber anerkannt werden, dass ein in jedem Fall

<sup>903</sup> *Sandel*, The Case against Perfection, S. 6 f.

<sup>904</sup> *Sandel*, The Case against Perfection, S. 7.

<sup>905</sup> Die Befürchtung, dass sich durch die Möglichkeit der genetischen Beeinflussung eine neue Qualität eines familiären Despotismus, der bereits heute durch ehrgeizige Erziehungsmethoden, in denen sich Wünsche und Erwartungen der Eltern widerspiegeln, existent ist, entwickeln könnte, teilt auch *The President's Council on Bioethics*, Beyond Therapy, S. 283.

aber festgeschriebenes Genom ebenso wenig die Autonomie des Kindes beeinträchtigt wie bloße Wünsche seitens der Eltern.<sup>906</sup>

Zentral sind Gedanken der Autonomie auch bei *Jürgen Habermas*.<sup>907</sup> Er geht zunächst einmal von einer Unterscheidung zwischen dem bloßen Leibsein und dem darauf aufbauenden Körperhaben aus. Die bloße Tatsache, dass ein Mensch stets einen Leib hat, erwächst mittels erworbener Selbst- und Körpererfahrung zur Subjektivität der menschlichen Person, die einerseits ihren Leib verobjektiviert betrachten kann.<sup>908</sup> Andererseits aber würde einem genetisch nicht kontingenten, sondern im Rahmen eines genetischen Enhancements bestimmten Kind die Teilnehmereigenschaft des eigenen Lebens insofern genommen, als dass der Eingriff einer Verfügung über eine Sache gleicht, das Kind zu etwas Gemachtem degradiert und ihm die Möglichkeit der revidierenden Stellungnahme gegenüber den mittels des Enhancements materialisierten Erwartungen an das Kind genommen wird.<sup>909</sup> Hierdurch würden Lebenspläne vorweggenommen und die Freiheit, der Autor des eigenen Lebens zu sein, also das Leben eigenbestimmt so zu führen, wie man es selbst als gut erachtet, beschränkt.<sup>910</sup> Erwartungen und die Richtungsweisungen, die Eltern gegenüber ihren Kindern haben und kommunizieren, sind üblicherweise, da Kommunikation stets interaktiv und Positionen somit anfechtbar sind, dem Kind abzulehnen möglich. Eine, wie *Habermas* es nennt, retroaktive Befreiung bleibt dem Kind unbenommen. Der Einfluss der Eltern und die kindliche Abhängigkeit von diesen kann so ausgeglichen werden, das Kind kann „*sich auf dem Wege einer kritischen Aufarbeitung der Genese von freiheitseinschränkenden Sozialisationsvorgängen befreien*.“<sup>911</sup> Ist dieser Einfluss jedoch genetisch manifestiert, so sei eine „*hadernde Auseinandersetzung mit der genetisch fixierten Absicht einer dritten Person [...] ohne Ausweg*.“<sup>912</sup> „*[J]ede Rebellion gegen unsere Natur [bleibt] ohnmächtig*.“<sup>913</sup> Die betroffene Person ist so durch ein für sie von Dritten vorgesehenes Genom in ihrem Lebensplan an die Vorstellungen dieser Dritten gebunden. Ihre genetische *Prädisposition* werde somit gewissermaßen zur *Prädestination*.<sup>914</sup>

Des Weiteren aber wird, so die Befürchtung, durch die Verfügung der einen über die andere Person, die in der Entscheidung über die Zusammensetzung deren Genoms gesehen wird, in der Hinsicht kritisiert, als dass durch die angebliche genetische Fixierung ein asymmetrisches Machtverhältnis zwischen diesen Personen entsteht, das heißt eine Beziehung, die von einseitiger Abhängigkeit gekennzeichnet ist. Der Grundsatz des gleichen normativen Status aller Personen, der auf ihrer reziprok-symmetrischen Anerkennung beruht und von einer Reversibilität zwischen-

<sup>906</sup> *Harris*, *Enhancing Evolution*, S. 124, 127 ff.

<sup>907</sup> *Habermas*, *Die Zukunft der menschlichen Natur*.

<sup>908</sup> *Habermas*, *Die Zukunft der menschlichen Natur*, S. 89.

<sup>909</sup> *Habermas*, *Die Zukunft der menschlichen Natur*, S. 90.

<sup>910</sup> *Habermas*, *Die Zukunft der menschlichen Natur*, S. 109.

<sup>911</sup> *Habermas*, *Die Zukunft der menschlichen Natur*, S. 107.

<sup>912</sup> *Habermas*, *Die Zukunft der menschlichen Natur*, S. 108.

<sup>913</sup> *Spaemann*, *DZPhil* 50, 105 (106), *Ergänzungen Welling*.

<sup>914</sup> Das Wortspiel stammt von *Zoglauer*, *Konstruiertes Leben*, S. 86.

menschlicher Beziehung ausgeht, werde so in Frage gestellt. Durch die Irreversibilität genealogischer im Gegensatz zu sozialer Abhängigkeit zwischen Eltern und ihren Kindern sei die Reziprozität zwischen Gleichen, Ebenbürtigen aufgehoben. *Habermas* geht sogar soweit, das entstehende Verhältnis mit dem zwischen einem Produkt<sup>915</sup> und seinem Designer zu vergleichen.<sup>916</sup>

Angesprochen sind in diesem Zusammenhang gleich mehrere Problemkreise. Zunächst einmal geht es um den Einfluss, den körperlich determinierende Eingriffe auf den subjektiven Begriff vom eigenen Körper und der eigenen Persönlichkeit, also auf die Identitätsbildung haben. Sodann ist die Frage angesprochen, inwiefern die betroffene Person in ihrer Persönlichkeitsentwicklung noch frei ist und ein selbstbestimmtes Leben zu führen vermag. Schließlich ist damit, weil Beziehungen stets interaktive, kommunikative Sachverhalte sind, auch die Wahrnehmung der Umwelt thematisiert. Diese Fragen sollen nunmehr systematisch beleuchtet werden.

Der bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts vorherrschenden Idee der Vererbungslehre stand im Hinblick auf die Frage, was eine Person auszeichne und sie zu derjenigen Person mache, die sie sei, im Gefolge der 68er-Debatten mit dem Behaviorismus ein nicht einflussloser Antagonist gegenüber, der das neugeborene Kind als *tabula rasa* erachtete und Umwelteinflüssen, konkret individuellen Lernprozessen, wie sie sich aus persönlichen Erfolgs- und Misserfolgserlebnissen sowie sozialer Belohnung und Bestrafung ergeben, eine entscheidende Rolle einräumte, bevor in der Soziobiologie Sozialverhalten auf biologische Grundlagen zurückgeführt wurde.<sup>917</sup> Heute ist man sich weitgehend einig, dass die Persönlichkeit eines Menschen aus dem Zusammenspiel zahlreicher Faktoren, die grob in genetische Einflüsse und solche des Umfeldes untergliedert werden können, entsteht. Die Bedeutung der Gene hierfür wird jedoch häufig unterschiedlich beurteilt. Allerdings sprechen die Ergebnisse zahlreicher Studien für eine Überschätzung ihrer persönlichkeitsdeterminierenden Kraft, während die Freiheit eines Menschen, dessen Genom im Wege des genetischen Enhancements verändert wurde, zur hiervon losgelösten Identitätsbildung weiterhin angenommen wird.<sup>918</sup> Hierbei mag es durchaus stimmen, dass rein physische Merkmale wie etwa die Größe einer Person auch von dem externen Faktor der Kalorien- und Nährstoffzufuhr abhängig ist. Allerdings wird dies einer besonders starken Determinierung durch die genetischen, von den eventuell besonders großen oder unterdurchschnittlich kleinen Eltern ererbten Ver-

<sup>915</sup> Während *Habermas* schon in diesem Vergleich Grund genug zur Ablehnung genetischer Eingriffe sieht, differenziert *Kass* hingegen zwischen der Frage, ob etwas oder jemand ein Produkt ist – was *Kass* auch in Bezug auf genmodifizierte Menschen bejaht, aber den Begriff des Produktes nicht als bloße Ware oder bloßen Gegenstand definiert, sondern klarstellt, dass Menschen trotz der Tatsache, dass sie von Dritten, in aller Regel den Eltern, kreiert worden sind, Respekt entgegengebracht werden muss –, und der Schlussfolgerung, dass die genetische Modifikation verboten sein soll, weil sie Menschen zu Produkten im soeben ausgeführten Sinne mache: *Kass*, *The American Journal of Bioethics* 5 (3), 5 (11).

<sup>916</sup> *Habermas*, *Die Zukunft der menschlichen Natur*, S. 110 ff.

<sup>917</sup> *Nunner-Winkler*, *Können Klone eine Identität ausbilden?*, S. 266 f.

<sup>918</sup> Ausführlich *Nunner-Winkler*, *Können Klone eine Identität ausbilden?*, S. 279.

anlagungen unterliegen. Gleiches wird man wohl auch von der Augen- oder der Haarfarbe sagen können.<sup>919</sup>

Allerdings ist hiervon nur ein kleiner Teil dessen betroffen, was gemeint ist, wenn von einer Person im Vergleich zum bloßen Menschen gesprochen wird, es also nicht nur um eine verwaltende Identifikation, sondern um die Beschreibung und Charakterisierung der Person als Persönlichkeit geht. Eine solche objektive Identitätsdefinition und subjektive Identitätskonstitution aber, zu denen die soeben genannten physischen Faktoren, wie gleich zu erläutern sein wird, nur wenig beizutragen scheinen, sind differenzierter zu betrachten. Wird personale Einzigartigkeit zu sichern gesucht, indem man ein Recht auf ein einzigartiges, da unangetastetes Genom postuliert, impliziert dies, dass Individualität nur mit einem solchen zu erlangen ist.<sup>920</sup> Intuitiv schon würde man hier jedoch auf eineiige Zwillinge verweisen, die ein vollständig gleiches Genom teilen, die man darüber hinaus aber nicht als identisch in dem Sinne bezeichnen würde, dass sie jeweils keine eigene, individuelle Identität besäßen. Genetische Einzigartigkeit erscheint eben nicht konstitutiv oder als notwendige Voraussetzung für Identität als persönliche Einzigartigkeit.

In der Tat belegen diese erste Intuition auch wissenschaftliche Studien.<sup>921</sup> Interviews, die 1968 mit Studenten an der Harvard Universität geführt wurden, die ihr Leben als sinnentleert und sich selbst als austauschbar bewerteten, zeigten, dass derartige Identitätsprobleme abnahmen, je mehr sie sich gegen den Vietnamkrieg engagierten oder ihre politische Überzeugungen in Aktivitäten umsetzten. Dies gründet darauf, dass auch Absichten und Handlungsmotive identifizierende Charakterisierungen ermöglichen. Darüber hinaus orientiert sich die subjektive Identitätskonstitution als reflexive Rückwendung auf sich selbst sowie die deskriptiv-registrierende Identifikation aus der Beobachterperspektive an der individuierenden Bezeichnung von singulären Exemplaren durch Namensgebung (Lioba Welling; Centennial Light Bulb<sup>922</sup>) und der dadurch geschaffenen numerischen Identität sowie an weiteren, etwa kategorischen (jemand ist ein Mensch; etwas ist eine Glühbirne), funktionalen (jemand ist Jurist; etwas ist ein Leuchtmittel) oder dispositionellen (jemand ist sportlich; etwas leuchtet hell) Zugehörigkeiten.<sup>923</sup>

Wie gering die Bedeutung der Gene als etwaige, das Identitätsangebot festlegende Eigenschaft eingeschätzt wird, welch große personendefinierende Rolle hingegen Wertvorstellungen, inhaltlichen Überzeugungen und geteilten Normen beigemessen wird, belegen unterschiedliche Altersgruppen vergleichende Studien, bei denen die Probanden sich dazu äußern sollten, ob und warum sie glaubten oder

<sup>919</sup> Detailliert hierzu *Buchanan/Brock/Daniels/Wikler*, *From Chance to Choice*, S. 347 ff.

<sup>920</sup> Vergleiche die Ausführungen hierzu bei *Nunner-Winkler*, Können Klone eine Identität ausbilden?, S. 279.

<sup>921</sup> Ausführlicher zu den erwähnten Studien *Nunner-Winkler*, Können Klone eine Identität ausbilden?.

<sup>922</sup> Dies ist die am längsten brennende Glühbirne der Welt. Sie wurde 1901 eingeschaltet und befindet sich in einer Feuerwache im kalifornischen Livermore, USA, wo sie über eine Webcam unter [www.centennialbulb.org](http://www.centennialbulb.org) (zuletzt aufgerufen am 27.12.2012) auch weltweit beobachtet werden kann.

<sup>923</sup> *Nunner-Winkler*, Können Klone eine Identität ausbilden?, S. 277 f.

nicht glaubten, dass sie eine andere Person (geworden) wären, hätten vorgegebene Merkmale eine andere Ausprägung gehabt. Während das Aussehen tendenziell als unbedeutend eingestuft wurde, wurden als auf die Persönlichkeitsbildung besonders einflussreiche Merkmale allgemeine Wert- und Rechtsvorstellungen, aber auch die Eltern und die eigene Geschlechtszugehörigkeit genannt. Anstelle in der Begründung für diese Einschätzung aber auf die von den Eltern erworbene genetische Ausstattung zu verweisen, wurde angeführt, dass primär Eltern die Wertvorstellungen prägen und auch die Geschlechtszugehörigkeit insofern charakterisierend sei, als dass hiermit die Erziehung des Kindes unter Umständen variieren kann und eine Geschlechterrolle die Einstellungen der jeweiligen Person prägen kann. Auch in derart biologisch aufgeladenen Kontexten also wird sozialen Faktoren eine weitaus größere Bedeutung beigemessen.<sup>924</sup>

Diese Einflüsse werden von gentechnologischen Eingriffen jedoch nicht betroffen, ihre persönlichkeitsprägende Wirkung bleibt unverändert. Entsprechend kann als Kritik gegen genetische Enhancements nicht vorgebracht werden, diese würden die Persönlichkeit des von ihnen betroffenen Menschen prädeterninieren, ihn festlegen und wie einen Gegenstand produzieren.

Ist dies wahr und der Mensch in seiner Persönlichkeit auch durch ein genetisches Enhancement nicht festgelegt, sondern weiterhin variabel in dem Sinne, dass er sich selbst gestalten und erfinden kann, bestünde kein Machtverhältnis, welches von dem üblichen, zwischen Eltern und Kindern bestehenden Machtverhältnis im Sinne eines zunächst einseitigen Einfluss durch Erziehung und die Vermittlung von Werten und Anschauungen so abweicht, dass sich das Kind hieraus nicht mehr lösen könnte. Eine unumkehrbare Zuschreibung von Persönlichkeit hätte also nicht stattgefunden.

Zentral für diese Argumentationslinie ist aber die Frage, was erforderlich ist, um eine Persönlichkeit als eine frei entwickelte, originäre, jeweils individuelle und eigene, oder: authentische, anzuerkennen. In Ergänzung zu dem Vorwurf, mittels Enhancement würden Persönlichkeiten von Dritten vor- und für immer festgeschrieben, ließe sich, wenn man sich darauf einigt, dass grundsätzlich eine – wie auch immer näher definierte und ausgestaltete – Authentizität der eigenen Persönlichkeit wichtig und als gut schützenswert ist, auch fragen, ob die Person, die sich aus freien und eigenen Stücken zu einem somatischen Enhancement entschlossen hat, hinterher weiterhin dieselbe Persönlichkeit hat und ist. Was unter einer authentischen Persönlichkeit zu verstehen ist, ist jedoch unklar und wird uneinheitlich beantwortet. Allgemein werden hierfür drei Anknüpfungspunkte genannt: Personalität, numerische Identität im Sinne eine diachronen oder persistenten Identität und Persönlichkeit.<sup>925</sup>

Hier wird zunächst eingewandt, dass Modifizierungen der menschlichen Physis durch Enhancements das verändern, was essentiell für die Beurteilung der jewei-

<sup>924</sup> Ausführlich *Nunner-Winkler*, Können Klone eine Identität ausbilden?, S. 283 ff.

<sup>925</sup> Eine sorgfältige und wertvolle Analyse dieser Thematik vor dem Hintergrund eines pharmazeutischen *mood enhancement* bieten *Beck/Stroop*, A Pharmaceutical Shortcut to (fraudulent) Happiness?, S. 13 ff.



ligen Entität als menschliche ist und so den Begriff der Personalität gefährdet.<sup>926</sup> Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass hier keine hinreichende Differenzierung vorgenommen wird. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass ein Mensch immer auch eine Person sein muss, es also keine Menschen gibt, die nicht schon auch, zugleich oder mehr Personen sind und diese Eigenschaft überhaupt erst oder erneut erwerben und verlieren können.<sup>927</sup> Darüber hinaus ist auch empirisch nicht ersichtlich, warum durch Enhancements die einen Menschen oder eine Person ausmachenden Charakteristika nicht mehr anwendbar würden.<sup>928</sup>

Unter der numerischen Identität im Sinne einer diachronen oder persistenten Identität wird der Umstand, dass eine Person ihre Identität über die Zeit hinweg behält, also diese Person war und auch weiterhin ist,<sup>929</sup> oder ihre Persistenz, also nach *Quante* die raum-zeitliche Ausdehnung eines Organismus,<sup>930</sup> verstanden. Enhancement-kritische Stimmen bringen vor, dass eine Person nach der Durchführung einer genetischen Verbesserung nicht mehr dieselbe sei.<sup>931</sup> Die Persistenzanalyse ist jedoch, so *Quante*, auf den Begriff des menschlichen Organismus angewiesen und kann lediglich darüber Auskunft geben, ob man es mit einem persistierenden oder zwei unterschiedlichen Menschen zu tun hat. Die Persistenz eines menschlichen Organismus wird dabei nicht durch eine Veränderung seiner Persönlichkeit oder den Verlust seiner Personalität betroffen. Diese beiden gehen über die bloße Feststellung der naturalistischen Persistenz hinaus.<sup>932</sup> Wollte man diesen Begriff zugrundelegen, so bedürfte es zur Ablehnung eines Fortbestehens der Identität eines kompletten Personenwechsels, der einem psychologischen Tod der zuerst dagewesenen Person gleichkommen müsste. Ein solches Ergebnis eines Enhancements ist jedoch nicht nur empirisch zweifelhaft. Darüber hinaus könnte dies noch nicht einmal als ein Enhancement gewertet werden, denn eine Verbesserung setzt immer eine Vergleichbarkeit des *status quo ante* und des *status quo post* voraus, die jedoch mangels Kontinuität der Person, auf die sich beide Status beziehen, nicht gegeben ist. Es gibt kein Subjekt, auf das sich die Verbesserung beziehen kann. Es könnte höchstens aus der Perspektive eines Beobachters festgestellt werden, dass die neue Person in Bezug auf bestimmte Eigenschaften der anderen Person überlegen ist.<sup>933</sup>

Als letzter Anknüpfungspunkt zur Beurteilung einer persönlichen Authentizität ist die Persönlichkeit selbst oder das, was beispielsweise *Chatterjee* Charakter oder Individualität nennt.<sup>934</sup> So ist es vorstellbar, dass einige psychologische Attribute

<sup>926</sup> *Chatterjee*, *Neurology* 63 (6), 968 (971).

<sup>927</sup> Dass beides zeitlich gerade nicht deckungsgleich sein muss, wurde im Zusammenhang mit den Schutzbereichen der Menschenwürde und des Grundrechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit bereits erörtert.

<sup>928</sup> *Beck/Stroop*, *A Pharmaceutical Shortcut to (fraudulent) Happiness?*, S. 14.

<sup>929</sup> Vergleiche etwa *DeGrazia*, *Journal of Medicine and Philosophy* 2005 (30), 261 (264).

<sup>930</sup> *Quante*, *Person*, S. 106.

<sup>931</sup> Die Wahrscheinlichkeit dieser Befürchtung erkennt auch *The President's Council on Bioethics*, *Beyond Therapy*, S. 211.

<sup>932</sup> *Quante*, *Personales Leben und menschlicher Tod*, S. 285.

<sup>933</sup> Vergleiche *Beck/Stroop*, *A Pharmaceutical Shortcut to (fraudulent) Happiness?*, S. 14 f.

<sup>934</sup> *Chatterjee*, *Neurology* 63 (6), 968 (971).



der Person verändert werden. Mittels Pharmazeutika können so das Selbstverständnis der Person, ihre Werte, psychologische Charakteristika oder ihre gesamte Art beeinflusst werden. Die Persönlichkeit ist allerdings ohnehin keine einmal und für immer gesetzte, statische Zusammenstellung von Eigenschaften, Charakterzügen und Wesensmerkmalen, sondern unterliegt auch ohne das Zutun von Eingriffen von außen im Laufe eines Lebens kontinuierlichen Veränderungen und Umformungen, die aber nicht jedes Mal eine neue Persönlichkeit hervorbringen oder ein Gefühl der Selbstentfremdung und des Selbstbetruges begründen. Anstelle einer derartigen kognitiven Dissonanz bleibt vielmehr eine narrative Identität gewahrt.<sup>935</sup> Während einerseits befürchtet werden könnte, dass die durch das „wer man (natürlicherweise) ist“, determinierte Persönlichkeit durch eine intentionale Beeinflussung ge- und am Ende gar zerstört wird,<sup>936</sup> ließe sich auch annehmen, dass dies gerade erst die Gestaltung des Selbst, wie es eigentlich ist und wie es nur subjektiv<sup>937</sup> durch die jeweilige Person unter Heranziehung ihrer individuellen Ideale, Präferenzen, Werte und Überzeugungen determiniert werden kann, ermöglicht und so ein hohes Maß an Autonomie begünstigt.<sup>938</sup> Authentisch ist und verhält sich eine Person diesem Ansatz zufolge dann, wenn ihre Eigenschaften oder Verhaltensweisen mit dem Bild, das sie selbst von sich hat, übereinstimmen. Auch vor dem Hintergrund dieser Ausführungen mag der Verzicht auf Enhancements zwar persönliches Ideal und die Handlungen der jeweiligen Person nur dann authentisch und dieser zurechenbar sein, wenn sie mit diesem Ideal (bei *Birnbacher*: der Natürlichkeit als Gegenteil des künstlichen Enhancements) in Einklang stehen, aber es vermag nicht, eine für alle bestehende Verbindlichkeit dieses Prinzips zu begründen.<sup>939</sup>

Zu keinem anderen Ergebnis gelangt man, wenn man als zentrales Evaluationskriterium den individuellen Lebensplan in den Blick nimmt. Dieser ist, wie bereits ausgeführt, zumindest dann, wenn durch das Enhancement Grundgüter im Sinne *John Rawls'* quantitativ und/oder qualitativ vermehrt werden sollen, ohne dass dadurch andere dieser *primary goods* beeinträchtigt<sup>940</sup> werden, nicht gefährdet. Vielmehr kann dadurch das Spektrum der möglichen Lebenspläne erweitert und die Entfaltungsfreiheit und Autonomie der jeweiligen Person gesteigert werden.

<sup>935</sup> Beck/Stroop, A Pharmaceutical Shortcut to (fraudulent) Happiness?, S. 15 f., 19 f.

<sup>936</sup> *The President's Council on Bioethics*, Beyond Therapy, S. 294 spricht von der Möglichkeit einer „self-alienation“, eines Verlustes, eines Verwischens oder eines Aufgebens unserer Identität. Der Council sieht den Menschen dann nicht mehr als handelndes Subjekt einer Selbst-Gestaltung, sondern als passiven Patienten formender Kräfte. Leistungen, die daher nicht persönlich erbracht werden, sind somit keine persönlichen Leistungen mehr und dem Individuum nicht zurechenbar.

<sup>937</sup> DeGrazia, Human Identity and Bioethics, S. 83 formuliert: „You are the individual who is realistically described in your self-narrative or inner story.“

<sup>938</sup> Beck/Stroop, A Pharmaceutical Shortcut to (fraudulent) Happiness?, S. 18 f.; *Parens*, Hastings Center Report 35 (3), 34 (46).

<sup>939</sup> *Birnbacher*, Natürlichkeit, S. 125, 129.

<sup>940</sup> Das heißt, ohne dass es dadurch zu einseitigen Begabungen oder Ausrichtungen führt, wie es beispielsweise vorstellbar ist bei einer bei weitem überdurchschnittlich intelligenten Person, die aber nur geringe Fähigkeiten zu Empathie oder eine unterdurchschnittliche physische Konstitution hat.

Es steht zu vermuten, dass diese die faktischen Auswirkungen betreffende Erkenntnis auch bedeutenden Einfluss auf das Bild hat, welches eine genetisch veränderte Person von sich selbst haben wird. Ist, wie oben festgestellt, weit verbreitete Ansicht, dass die Gene nur marginale Bedeutung bei der Formung und Ausgestaltung der Persönlichkeit und individuellen Identität haben, dann scheint es nicht angebracht zu sein, zu befürchten, dass jemand als fremdbestimmt, zur Sache degradiert, nicht Autor seines eigenen Lebens, bloßes Artefakt oder Produkt seiner Designer-Eltern gehalten wird beziehungsweise sich als dieses betrachtet.

Nach alledem muss man somit feststellen, dass, wollte man die angebliche genetische Festlegung kritisieren, man den Einfluss der Gene auf Persönlichkeit, Lebensgestaltung sowie Selbst- und Fremdrezeption der genmodifizierten Person überschätzt. Auch *Habermas* erkennt dies. Er erachtet die Prämissen des genetischen Determinismus als falsch und hebt als kritikwürdig die Intention hervor, mit der Eltern das Genom ihres (zukünftigen) Kindes modifizieren und die stets die Auswirkung auf den Phänotyp umfasst. Für *Habermas* ist es daher das Wissen um die genetischen Eingriffe, welches das Autonomiebewusstsein und die Symmetrie des Machtverhältnisses zwischen Eltern und Kind beeinträchtigt.<sup>941</sup> *Habermas* führt allerdings nicht aus, wieso die dargelegten Zwänge die vom Enhancement betroffene Person festlegen, wenn diese genetische Determinierung rein faktisch schon nicht stattfindet. Jedes auch nicht genmodifizierte Kind sieht sich in mehr oder weniger ausgeprägter Weise gewissen Hoffnungen und Erwartungen seiner Eltern ausgesetzt, was *Habermas* auch nicht bestreitet, aber davon ausgeht, dass ein Kind sich hiervon ebenso wie von tradierten Wertvorstellungen oder Habitus retroaktiv befreien, sie also nach kritischer Reflexion ablehnen kann. Wieso ihm dies aber bei entsprechenden Erwartungen im Kontext genetischer Enhancements nicht möglich sein soll, erörtert er jedoch nicht. Wenn er auch *Habermas* hinsichtlich des Problems der Asymmetrie von Machtverhältnissen grundsätzlich zustimmt, so kritisiert dennoch ebenfalls *Siepe* die Annahme *Habermas'* von der Unmöglichkeit einer hadernden Auseinandersetzung und führt richtigerweise aus, dass ein Kind sich unbeeindruckt beispielsweise einer von den Eltern ausgewählten genetischen Neigung zur Mathematik – und sei es nur aus Trotz – für ein Leben als Poet oder DJ entscheiden kann.<sup>942</sup>

Sind genetische Eingriffe für die Persönlichkeit(-sfindung) und die Wahlfreiheit bezüglich der zu verfolgenden Lebenspläne faktisch nicht determinierend, wovon vorliegend ausgegangen wird, so bleibt im Verhältnis der Eltern zu ihrem Kind auch für dieses nur die damit zum Ausdruck gekommene Erwartung übrig, sofern es um die fehlende Ursächlichkeit genetischer Modifikationen für die Person, als die es sich begreift und als die es von Dritten wahrgenommen wird, weiß. Die Situation des genverbesserten Kindes und eines Kindes, dessen Genom natürlich-kontingent belassen wurde, gleicht sich somit. Wendet sich *Habermas* nun aber lediglich gegen die mit dem Enhancement im Kontext stehende Erwartung, so lässt dies vermuten, dass auch er eine gewisse objektive Bestimmungskraft der Gene voraussetzt, ohne

<sup>941</sup> *Habermas*, Die Zukunft der Menschlichen Natur, S. 108 Fn. 66.

<sup>942</sup> *Siepe*, DZPhil 50, 111 (112).

die er nicht ohne extensiven, von ihm aber nicht geleisteten Begründungsaufwand von einem Autonomieverlust und einem asymmetrischen Machtverhältnis ausgehen könnte. Wie diskutiert, wird das Konzept eines solchen genetischen Determinismus jedoch abgelehnt und anscheinend, darauf deuten die genannten Studien hin, auch von einem signifikanten Teil der Gesellschaft nicht geteilt. Entsprechend können die erörterten Befürchtungen als hinfällig betrachtet werden.

Somit lässt sich als Zwischenergebnis festhalten, dass durch die Anwendung genverbessernder Eingriffe nicht der Verlust individueller Unverwechselbarkeit droht oder eine biographische Selbstbestimmungs- und Gestaltungsmöglichkeit beseitigt wird. Weder ist das Genom – im Gegensatz zu erworbenen Wertvorstellungen und sozialen Einflüssen und Bindungen – ein bedeutender identitätsbildender Faktor, noch führt seine zielgerichtete Gestaltung zu einer Fremdbestimmung des Lebens des betroffenen Individuums von einem Ausmaß, welches über das einer bloß natürlich-kontingenten Kombination der Gene hinausgeht. Ein Verbot des genetischen Enhancements ist aufgrund derartiger, widerlegter Befürchtungen somit nicht gerechtfertigt.

## 5. *Wunsch-Medizin versus Zwang-Medizin*

Des Weiteren wird vorgebracht, dass die bloße medizinisch-technische Möglichkeit, Enhancement-Technologien anzuwenden, zu einer gesteigerten Erwartungshaltung führt, aufgrund derer diejenigen, die sich hiermit konfrontiert sehen, was potentiell jeder ist, sich gezwungen fühlen, ein Enhancement zur Selbstverbesserung oder der Verbesserung zukünftiger Nachkommen anzuwenden, um den höheren, gegebenenfalls übermäßigen Erwartungen gerecht zu werden.<sup>943</sup> Die medizinische Technologie, die ursprünglich erschaffen wurde, um Hoffnungen und Wünsche nach Verbesserung zu erfüllen, könnte so bewirken, dass sich Personen dazu gedrängt fühlen, sich den nunmehr möglich gewordenen Eingriffen zu unterziehen. Aus der Wunsch-Medizin könnte so eine Zwang-Medizin werden,<sup>944</sup> wobei die Verpflichtung oder der Zwang, Enhancement-Maßnahmen an sich selbst oder zugunsten seiner Nachkommen vornehmen zu lassen, keine(r) im engeren juristischen Sinne wäre, sondern die/der einer gesellschaftlich-faktischen Natur.<sup>945</sup> Die Befürchtung scheint also zu sein, dass das Gros der Bevölkerung davon ausgeht und es für selbstverständlich erachtet, dass solche Möglichkeiten genutzt werden und dass an die Entscheidung dagegen gewisse Sanktionen geknüpft werden können, sollten oder dass sie faktisch schlicht geknüpft werden. Beschränken können sich diese freilich auf ein unverständliches Kopfschütteln, über das man sich leicht hinwegsetzen kann, sie könnten

<sup>943</sup> Vergleiche beispielsweise *Baylis/Robert*, *Bioethics* 18 (1), 1 (12); *Birnbacher*, *Natürlichkeit*, S. 115; *Chatterjee*, *Neurology* 63 (6), 968 (971).

<sup>944</sup> *DeGrazia*, *Human Identity and Bioethics*, S. 218; *Eberbach*, *MedR* 2008, 325 (336); *drze*, *Enhancement*, S. 40; *Sandel*, *The Case against Perfection*, S. 25; *The President's Council on Bioethics*, *Beyond Therapy*, S. 135 ff., 284.

<sup>945</sup> Vergleiche *Greely*, *Human Biological Enhancement and U.S. Policy Tools*, S. 513.

aber auch weiter reichen und beispielsweise den Arbeitgeber umfassen, der sich weigert, im Rahmen einer ansonsten vollkommen regulären krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit dem Arbeitnehmer, der sein Immunsystem nicht mittels eines Enhancements hat verbessern lassen, das Entgelt weiterhin auszuzahlen, oder nur Personen einstellt, die aufgrund eines Enhancements besonders intelligent sind und mehr Arbeit in kürzerer Zeit und mit einer geringeren Fehlerquote verrichten können. Wollte man polarisieren, ließen sich zahlreiche derartiger Bilder zeichnen.

Empirisch festgemacht wird diese Beunruhigung zuweilen an der Entwicklung, die die Diagnose von ADHS in den USA genommen hat. Vermutungen zufolge werden fünf bis sechs Prozent der US-amerikanischen Kinder unter 18 Jahren Ritalin oder andere Stimulantien verabreicht; die Produktion von Ritalin hat in den vergangenen 15 Jahren um 1700 % zugenommen.<sup>946</sup>

### **a) Entstehen einer gesellschaftlichen Erwartungshaltung**

Inwiefern diese Befürchtungen jedoch berechtigt sind, geschweige denn ob sie sich realisieren werden, hängt aber entscheidend auch von quantitativen Faktoren ab. Eine Erwartungshaltung entsteht ohne Weiteres, also ohne dass derjenige, von dem etwas erwartet wird, sich in einer bestimmten Weise verhält oder ein Versprechen abgibt, nur, wenn das, was erwartet wird, im Allgemeinen auch erwartet werden kann, weil es üblich ist, also wenn etwa ein bestimmtes Verhaltensmuster Usus ist. Wenn ich meinen Kollegen beispielsweise einen guten Morgen wünsche, erwarte ich, dass ich ebenfalls von ihnen begrüßt werde, weil dies schlicht der gesellschaftlichen Übung entspricht. Das würde aber voraussetzen, dass sich Enhancement zu einer weit verbreiteten Praxis entwickelt. Hiergegen bestehen jedoch zwei grundlegende Bedenken:

Zwar mögen diverse Enhancement-Techniken sich schon heute weitgehend etabliert haben. Die Tasse Kaffee, um den Tag über aufmerksam zu sein, kann streng genommen hierzu gezählt werden und auch Schönheitschirurgische Eingriffe zur Fettabsaugung, Brustvergrößerung oder Nasen-„Korrektur“ sind keine Seltenheit. Schon bei Letztgenanntem aber geht die Gesellschaft bei Weitem nicht davon aus, dass jemand, der mit seinem Körper unzufrieden ist, gerade die plastische Chirurgie zur Lösung seines „Problems“ wählt. Dies kann einerseits daran liegen, dass solche Operationen teuer und nicht stets Kassenleistungen sind, was sicherlich viele Personen davon abhält, einen solchen Eingriff durchführen zu lassen, und es somit schon an der quantitativen Basis einer Erwartung begründenden weitverbreiteten Übung fehlt. Noch deutlicher dürfte sich dieser Umstand bei genetischen Enhancements auswirken, von denen anzunehmen ist, dass sie vorerst schon aufgrund des noch größeren finanziellen Aufwandes und aufgrund der vermutlich fehlenden Erstattung durch die Krankenkassen die Ausnahme bleiben werden. Schon empirisch ist daher keine Grundlage für eine Erwartungshaltung vorhanden.

---

<sup>946</sup> Sandel, *The Case against Perfection*, S. 59.

Darüber hinaus würde eine Antizipation, die das Enttäuschen der Erwartung mit einer Sanktion bestraft, auch eine positive Bewertung dessen, was erwartet wird, voraussetzen. Es müsste also auch allgemeine Meinung sein, dass genetische Enhancements zu befürworten sind (was sich dann wiederum auf den erstgenannten Punkt der häufigen Anwendung auswirkt). Dass eine solche Bewertung üblich sein wird, lässt sich aber weder be- noch widerlegen. Inwiefern solche bloßen Mutmaßungen aber plausibel sind und einen ausreichenden Grund zu aktuellen gesetzlichen Maßnahmen sein können, soll später im Kontext der Dammbruchargumente gegen genetisches Enhancement erörtert werden.

## **b) Art. 2 I GG**

Wollte man diese Befürchtungen nunmehr juristisch einbinden, so wäre Anknüpfungspunkt der Art. 2 I GG. Hier ist zunächst festzustellen, dass es zwar Aufgabe staatlicher Gewalt ist, die Freiheit des einen vor der Freiheit des anderen zu schützen und hierzu entsprechendes, sowohl Über- als auch Untermaßverbot beachtendes Zivil- oder Strafrecht zu schaffen.<sup>947</sup> Regelungspflichten können jedoch nur durch verfassungsrechtliche Schutzaufträge ausgelöst werden. Rechtlich nicht gesicherte Ethik, bloße Umgangsformen oder gar, man denke an meine Erwartungshaltung Bekannten gegenüber, die ich grüße und von denen ich eine Antwort hierauf erwarte, Höflichkeiten sind hingegen unerheblich.<sup>948</sup>

Auch der Schutzbereich dieser Verfassungsnorm ist nicht unproblematisch. Während der Kernbereichstheorie zufolge nur der Bereich geschützt werden soll, den der Mensch benötigt, um seine Wesensanlage als geistige Persönlichkeit zu entfalten, möchte die herrschende Meinung alle Betätigungen oder Lebensbereiche umfasst sehen, die nicht einem spezifischen Freiheitsrecht unterfallen. Vermittelnd wird darüber hinaus vertreten, dass Art. 2 I GG nur gegenüber solchen Eingriffen Schutz gewähren soll, die von ihrer Intensität her dem Schutz der benannten Freiheitsrechte vergleichbar sind und sich auf Freiheitsbetätigungen beziehen, die für die Entfaltung der Persönlichkeit gewichtig sind. Davon wären dann nur Lebensbereiche erfasst, deren Regulierbarkeit durch den Staat die Autonomie des Einzelnen gefährdet und damit einem System Vorschub leistet, das nicht mehr beanspruchen könnte, auf der Achtung der Menschenwürde gegründet zu sein. Für die herrschende Meinung und somit die weite Auslegung spricht jedoch, dass die beiden anderen Auffassungen Probleme in der Abgrenzung zwischen erfassten und nicht mehr erfassten Bereichen produzieren. Eine Banalisierung dieses Grundrechts ist zudem aufgrund der umfassenden Schranken nicht zu befürchten. Schließlich streitet auch die historische Auslegung dafür, der herrschenden Meinung zu folgen: Der Entwurf des Parlamentarischen Rates, der schließlich, jedoch ohne eine inhaltliche Änderung zu beabsichtigen, alleine zum Zwecke von Ästhetik und Pathos umformuliert wurde, sah vor, dass jedermann die Freiheit verbürgt werden sollte „zu tun und zu

<sup>947</sup> von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 2 Abs. 1 Rdnr. 163.

<sup>948</sup> Vergleiche von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 2 Abs. 1 Rdnr. 165.

*lassen, was die Rechte anderer nicht verletzt und nicht gegen die verfassungsgemäße Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.*<sup>949</sup>

Im Zusammenhang mit dem genetischen Enhancement und der befürchteten Entwicklung von der Wunsch- zur „Zwang“-Medizin durch eine etwaig entstehende gesellschaftliche Erwartungshaltung und vor dem Hintergrund der aktuellen Fragestellung, ob ein Verbot des genetischen Enhancements gerechtfertigt wäre, könnte also die allgemeine Handlungsfreiheit dadurch verletzt werden, dass der Gesetzgeber untätig bleibt. Ein staatliches Verbot wäre freilich dann gerechtfertigt, wenn dieses zum Schutze von Grundrechten sogar erlassen werden müsste. Es stellt sich also wiederum die Frage, ob den Staat eine Schutzpflicht zugunsten der allgemeinen Handlungsfreiheit trifft, die er nicht erfüllen und diese Verfassungsnorm somit verletzen würde, würde er genetische Enhancements nicht verbieten, obgleich es, was zuvorderst zu prüfen ist, soweit es erlaubt bleibt, die allgemeine Handlungsfreiheit verletzt.

Im Rahmen des Art. 2 I GG erlangt die Feststellung des Eingriffs eine besondere Bedeutung. Unstrittig kann ein solcher mittels der klassischen Eingriffsdefinition festgestellt werden. Hiernach liegt ein Eingriff bei final-unmittelbaren Beeinträchtigungen durch einen Rechtsakt vor oder wenn die in Frage stehende Handlung dem wegen seiner Intensität nahekommt.<sup>950</sup> Der Rechtsakt selbst muss also konzipiert sein, um die Freiheit des Adressaten zu begrenzen. Bei Anwendung des weiten Eingriffsbegriffes hingegen genügt es schon, wenn eine faktische Beeinträchtigung durch eine hoheitliche Maßnahme vorliegt.<sup>951</sup>

Sieht sich eine Person dazu veranlasst, Verbesserungen an sich oder ihren (noch zu zeugenden) Nachkommen vornehmen zu lassen, weil sie sonst gesellschaftliche, berufliche oder anderweitige Nachteile fürchtet, dann liegt hier schon kein Rechtsakt oder eine sonstige staatliche Maßnahme vor, sondern lediglich eine Erwartungshaltung (eines Teils) der Mitmenschen. Auch die Beschränkung von Handlungsoptionen als solche ergibt sich lediglich aus der internen Reaktion desjenigen, der sich diesem Erwartungshorizont gegenüber sieht und sich zu dessen Erfüllung gedrängt oder gezwungen *fühlt*. Dies ist jedoch ein Umstand, dem wir uns alltäglich ausgesetzt sehen. Ohne Weiteres wäre man in der Lage, den Erwartungen nicht nachzugeben. Kommt man ihnen aber nach, so wird man dies in der Regel tun, weil es auf Basis einer Abwägung zwischen etwa dem Missfallen, welches man im Hinblick auf die erwartete Handlung verspürt, und den Folgen, die eintreten, wenn man sich den Erwartungen widersetzt, als gewinnbringendere Alternative analysiert wurde und man sich dementsprechend dazu entschieden hat. Eine solche kritische Reflexion wird von jedem erwartet werden dürfen, wenn man sie oder ihn als Person ernst nimmt. Es liegt somit schon nach keinem der Eingriffsbegriffe eine Be-

<sup>949</sup> von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 2 Abs. 1 Rdnr. 8 ff.; Maunz/Dürig-Di Fabio, GG, Art. 2 Abs. 1 Rdnr. 12 ff., bezüglich der Beratungen im Parlamentarischen Rat von Doemming/Füsslein/Matz, JöR 1 (1951), 59, 62.

<sup>950</sup> von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 2 Abs. 1 Rdnr. 19.

<sup>951</sup> von Mangoldt/Klein/Starck-Starck, GG, Art. 2 Abs. 1 Rdnr. 20.



einträchtigung des Schutzbereiches des Art. 2 I GG vor, die eine Schutzpflicht des Staates auslösen könnte.

Darüber hinaus wäre es dem Gesetzgeber auch weiterhin belassen, unerwünschten Folgen oder Sanktionen, mit denen die Nichterfüllung der gesellschaftlichen Erwartungshaltung belegt ist, durch entsprechende gesetzliche Provisorien vorzubeugen. Dies wäre ohnehin ein milderes Mittel als ein Verbot des genetischen Enhancements und würde konfligierenden Freiheitsrechten in umfassenderem Maße Rechnung tragen. Dies sind aber im Vergleich zur allgemeinen Handlungsfreiheit spezielle Erwägungen, die daher auch an entsprechender Stelle erörtert wurden und werden.

## 6. „Komplizenschaft“

Weitere Kritik an Enhancement verweist auf die Rolle, die dem ein solches durchführenden Mediziner zukommt. Anschaulicher Beispielsfall ist in diesem Zusammenhang häufig das Kind, welches in der Schule aufgrund seiner abstoßenden Segelohren gehänselt wird, die Frau, die ihren Brustumfang zu klein, ihren Bauchumfang hingegen zu groß findet, oder die Person dunkler Hautfarbe, die eine Reduzierung ihrer ethnischen Merkmale wie etwa eine Aufhellung der Haut, eine Verschlankung der Nase und eine Verkleinerung der Lippen wünscht. Die Überlegung der Kritiker ist hierbei, dass ein Schönheitschirurgischer Eingriff diesen Personen nur deswegen als Desiderat erscheint, weil sie sich einem gesellschaftlichen Umfeld gegenübersehen, welches mit bestimmten ästhetischen Eigenschaften bestimmte Wertungen verbindet, welche sich in verminderten Chancen bei der Bewerbung um einen Arbeitsplatz oder bei der Suche nach einer Wohnung manifestieren oder sich in Mobbing durch Dritte und dieses sich wiederum in Selbstzweifel und Minderwertigkeitskomplexen der betroffenen Person niederschlagen kann. Zentraler Kritikpunkt ist sodann, dass ein Mediziner, der aufgrund (psycho-)sozialer Probleme tätig wird, die diese verursachenden Umstände nicht beseitigt, sondern sogar noch perpetuiert und ihre Gültigkeit und Wirksamkeit weiter unterstreicht und dadurch gleichsam „zum Vollstrecker der gesellschaftlichen Norm am Körper der Patientin oder des Patienten“<sup>952</sup> wird. Dies helfe somit der einzelnen betroffenen Person nur vordergründig und nur auf den ersten Blick, schädige jedoch am Ende des Tages alle weiteren Personen, die Träger der gleichen Eigenschaft sind, und zwar umso mehr, sofern diese keinen Zugang zu den die Eigenschaft beseitigenden medizinischen oder biotechnischen Ressourcen haben.<sup>953</sup> Soziale Probleme würden, behielten diese Kritiker Recht, nicht gelöst, sondern verschärft.<sup>954</sup>

<sup>952</sup> Lenk, Therapie und Enhancement, S. 85.

<sup>953</sup> Brock, Enhancements of Human Function, S. 63 f.; DeGrazia, Human Identity and Bioethics, S. 215 f.; drze, Enhancement, S. 27 f.; Lenk, Therapie und Enhancement, S. 84 f.; Little, Cosmetic Surgery, Suspect Norms, and the Ethics of Complicity, S. 163 ff.

<sup>954</sup> So auch Birnbacher, Natürlichkeit, S. 115.



Parallele Erwägungen ließen sich über Schönheitschirurgische Eingriffe hinaus auch hinsichtlich eines breiteren Spektrums von Enhancement-Maßnahmen anstellen. So könnte man vermuten, dass die bloße Möglichkeit verbessernder genetischer Eingriffe eine diese befürwortende und gar verlangende gesellschaftliche Haltung generiert und fördert, die Individuen, die sich diesem Trend widersetzen, im weitesten Sinne sanktioniert. Konkret könnte dies ähnliche Auswirkungen haben wie in den geschilderten Beispielsfällen: Entstände eine solche allgemeine Meinung, könnten sich nicht genverbesserte Personen Mobbing ausgesetzt sehen, sich als weniger wert begreifen oder eine schwierigere Ausgangslage bei der Suche nach einem Arbeitsplatz haben. Der Enhancements betreibende Mediziner könnte so dann diese Entwicklung verstärken, wenn aus der bloßen Möglichkeit auch *realiter* eine Praxis wird.

Vorausgesetzt, dem wäre so,<sup>955</sup> ließe sich daraus nun aber keineswegs *tout court* schlussfolgern, dass Enhancements unzulässig sind, weil, so etwa *Lenk*, niemand aufgrund seiner körperlichen Merkmale, die etwa auf seiner ethnischen Herkunft basieren, diskriminiert werden darf.<sup>956</sup> Das Enhancement selbst ist für sich betrachtet eine neutrale Handlung. Als solches betrachtet enthält es keine unmittelbare Aussage hinsichtlich anderer, nicht verbesserter Personen. Somit käme höchstens eine mittelbare Diskriminierung in Frage, die sich aus der *Bedeutung* ergeben könnte, die einer solchen medizinischen Praxis beigemessen werden und die sie auf das gesellschaftliche Wertebild haben könnte, indem sie gegebenenfalls diskriminierende gesellschaftliche *Vorstellungen* inkorporiert, perpetuiert und intensiviert.<sup>957</sup> Dass dies ein häufiger Umstand und die beschriebene Folge eine zwingende ist, belegt *Lenk* jedoch nicht.

Eine solche Bedeutung ließe sich lediglich unter Berücksichtigung aller zum Handlungsumfeld gehörigen Faktoren feststellen, wozu auch innere Umstände wie die subjektive Haltung bezüglich der jeweiligen Handlung zumindest insoweit gehören, als dass sie für Dritte erkennbar nach außen treten.<sup>958</sup> *De facto* und empirisch mag dadurch eine Praxis des Enhancements zwar gefördert werden, ein Druck für Dritte, sich verbessern zu lassen, wird hingegen nicht entstehen oder intensiviert, soweit deutlich wird, dass ein Enhancement nicht stets die optimale Handlungsalternative ist und in manchen Fällen gar abzulehnen ist, weil deren verbessern der Charakter bezweifelt werden kann, etwa wenn dadurch die betreffende Person auf einen konkreten, spezialisierten Lebensplan wie beispielsweise die Karriere als Basketballer oder Mathematiker festgelegt wird oder ihr dadurch Eigenschaften zugeteilt werden, die eine bloße Modeerscheinung darstellen oder alleine darauf gründen, dass die Eltern zufälligerweise braune Haare blonden vorziehen.

<sup>955</sup> Ob diese Befürchtungen tatsächlich zutreffen, wird später unter dem Stichwort der *slippery slope* zu diskutieren sein. *For the sake of the argument* soll hier aber von der Richtigkeit dieser Mutmaßungen ausgegangen werden.

<sup>956</sup> So aber *Lenk*, Therapie und Enhancement, S. 85.

<sup>957</sup> Vergleiche *Little*, Cosmetic Surgery, Suspect Norms, and the Ethics of Complicity, S. 139.

<sup>958</sup> *Little*, Cosmetic Surgery, Suspect Norms, and the Ethics of Complicity, S. 169 ff.

Entsprechend wäre es begrüßenswert, Vorkehrungen zu treffen, die eine kritische Reflexion der biotechnischen Möglichkeiten fördern. So erscheint es sinnvoll, im konkreten Fall die Durchführung eines Enhancements von der Erfüllung bestimmter Voraussetzungen wie der vorausgehenden intensiven Beratung, die auch alternative Möglichkeiten beleuchten soll, wie Personen einer gesteigerten Erwartungshaltung gerecht werden können oder welche weiteren Optionen zur Förderung der Nachkommen offenstehen, oder der Zustimmung einer Ethikkommission abhängig zu machen. Dies würde sodann nicht nur zu dem Erfordernis einer kritischen Auseinandersetzung des Individuums führen. Darüber hinaus ist zu hoffen, dass eine solche Regelung gesamtgesellschaftlich insofern begrenzend wirkt, als die Hemmschwelle zur Durchführung von Enhancements angehoben wird und eine Erwartungshaltung in extensivem Ausmaß gar nicht erst entstehen kann, ist es doch nicht der Entscheidungsmacht des Einzelnen überlassen, ob und in welchem Umfang er sich einem Enhancement unterzieht oder dieses für seine Nachkommen will. Dass diese Einschätzung nicht eine gänzlich illusorische ist, belegen die Erfahrungen mit ähnlich konzipierten Normen. Die §§ 218 ff. StGB haben schließlich auch keineswegs zu einer breiten Zustimmung zu Abtreibungen, geschweige denn zu einer Erwartungshaltung gegenüber der Mutter, diese möge doch, sollte die Schwangerschaft nicht genau zu dem Zeitpunkt oder unter eben genau den Lebensumständen intendiert gewesen sein, diese beenden, geführt.

Eine solche Vorkehrungen schaffende gesetzliche Regelung wäre daher auch mit Hinblick auf genetische Enhancements ein milderes gesetzliches Mittel als ein Verbot jeglicher genverbessernder Maßnahmen, welches somit im Wege der aufgeführten Bedenken einer Komplizenschaft nicht mehr gerechtfertigt werden kann.

## **7. *Ärztliches Ethos und Arzt-Patienten-Verhältnis***

Teilweise wird darüber hinaus, aber ebenfalls mit Blick auf die Rolle des Arztes vorgebracht, dass neue biomedizinische Technologien und Machbarkeiten negative Effekte auf das ärztliche Ethos und Selbstverständnis sowie das Arzt-Patienten-Verhältnis haben könnten. So wird etwa befürchtet, dass die fragile Vertrauensbeziehung, die aufgrund der Expertise und Verschwiegenheitspflicht des Arztes sowie der berufsrechtlichen und -ethischen Reglements zumindest in basaler Weise bereits beim ersten Aufeinandertreffen von Patient und Arzt gegeben ist, empfindlich gestört werden könnte, wenn sich eine Machbarkeits- oder Dienstleistungsmedizin entwickle.<sup>959</sup> Sollte sich die Medizin als eine an der Gesundheit orientierte Kunst in Richtung eines kommerzialisierten Marktes entwickeln, in dem Medizin ökonomisiert und nach Machtstrukturen reorganisiert würde, werden nicht nur soziale Probleme im Sinne einer Marginalisierung von Bevölkerungsgruppen, für die Enhancement-Maßnahmen nicht finanzierbar sind, befürchtet, sondern auch das berufliche Ethos und mit diesem die Reputation der Ärzteschaft in Gefahr gesehen.<sup>960</sup>

<sup>959</sup> Lenk, Therapie und Enhancement, S. 81.

<sup>960</sup> Lenk, Therapie und Enhancement, S. 77 ff.

Der Arzt soll sich traditionell um die Herstellung und Erhaltung der Gesundheit des Patienten bemühen und sich an dessen wohlverstandenen Interesse orientieren. „Oberstes Gebot“ ärztlichen Handelns ist laut *Genfer Gelöbnis* des *Weltärztebundes*, „die Gesundheit [des] Patienten“.<sup>961</sup> Laut *Hippokratischem Eid* etwa beschränkt sich die Ärzteschaft selbst darauf, dem Patienten zu nützen, aber zu diesem Zweck nicht lediglich als ein Techniker zu fungieren, der die an ihn durch den Patienten herangetragenen Wünsche erfüllt, sondern ebenfalls die ethischen Konsequenzen seiner Tätigkeit zu reflektieren.<sup>962</sup> Die Grenze zulässigen ärztlichen Handelns verläuft dabei zumindest dort, wo es menschliches Leben beeinträchtigen würde, also die Gesundheit nicht, wenn auch nur erhaltend, fördert, sondern schädigt.<sup>963</sup> Abhängig von den Risiken, die bei genetischem Enhancement bestehen, könnte ein hierauf begründetes Unterlassungsgebot genetischen Enhancements jedoch hinfällig sein. Wird dessen Durchführung hinreichend sicher, ist es zumindest im Wege des Schädigungsverbotes beziehungsweise im Wege eines Gebotes, das Risiko einer Schädigung zu minimieren, nicht mehr untersagt.

Sich nicht ausschließlich im Rahmen eines Heilungs- und Erhaltungsauftrages zu bewegen, sondern darüber hinaus eine Verbesserung von physischen, psychischen oder kognitiven Eigenschaften des Patienten oder seiner Nachkommen anzustreben, könnte jedoch einer ärztlichen Selbstbeschränkung auf die Gesundheit als Fokus des ärztlichen Handelns widersprechen und daher ein „falsches Ziel“<sup>964</sup> darstellen. Hierbei ginge es lediglich um eine reduzierte Form von Glück, die sich nur auf den Genuss und die Freude bezieht, die bei der Befriedigung von Wünschen und Begehrlichkeiten auf einer bloßen Ebene des Konsums ausgelöst wird.<sup>965</sup> Verkämen medizinische Eingriffe, so ließe sich sodann folgern, zu bloßen Konsumgütern, handelte es sich bei der Ärzteschaft um Dienstleister, die einerseits im Interesse der Patienten, bei denen es sich sodann vielmehr um zahlende Kunden und Auftraggeber handeln würde, käuflich und instrumentalisierbar werden würden, die aber andererseits ebenso gut selbst ihre finanziellen Interessen und ihr Streben nach Gewinn und dessen Maximierung über das Gebot der primären Sorge um das Wohl des Patienten stellen könnten.

In diesem Zusammenhang stellt sich jedoch bereits unabhängig von neuesten medizinisch-technischen Möglichkeiten die Frage, ob solche Tendenzen nicht ohnehin schon erkennbar sind. Das breite Spektrum an von darauf spezialisierten Ärzten durchgeführten schönheitschirurgischen Eingriffen ist nur ein Beispiel hierfür. Während Zahnärzte mit dem Wunsch nach einer Zahnaufhellung, einem sogenannten Bleaching, konsultiert werden, bieten Dermatologen in ihren Praxen auch rein kosmetische, nicht-medizinische Behandlungen an. Der Berufsalltag von Ärzten ist bei Weitem nicht mehr auf die Herstellung und Erhaltung von Gesundheit beschränkt, sondern wird zunehmend von den Wünschen der Patienten nach darüber

<sup>961</sup> Zitiert nach *Williams* in *Weltärztebund*, Handbuch der ärztlichen Ethik, S. 19.

<sup>962</sup> *Lenk*, Therapie und Enhancement, S. 77 f.

<sup>963</sup> *Lenk*, Therapie und Enhancement, S. 78.

<sup>964</sup> „false goals“: zitiert nach *Lenk*, Therapie und Enhancement, S. 78.

<sup>965</sup> Zitiert nach *Lenk*, Therapie und Enhancement, S. 78.

hinausgehenden Leistungen, von denen sie sich ein gesteigertes Wohlbefinden oder Wohlergehen erhoffen, geprägt. Man denke zur Veranschaulichung der quantitativen Dimension nur an die Häufigkeit, mit der Gynäkologen Kontrazeptiva verschreiben. Konsequenter (aber nachdrücklich wertfrei) ausbuchstabiert handelt es sich auch hierbei ebenfalls nicht um Pharmazeutika in einem traditionell-medizinischen Sinne, sondern um Lifestyle-Präparate. Dies zeigt, dass Ärzte längst zu wirtschaftlichem Handeln gezwungen sind wie jede andere Berufsgruppe auch, was neben dem Bewerben der eigenen Leistungen auch das Offerieren von lukrativen, zumeist privat gezahlten Lifestyle-Behandlungen umfasst.

Im Hinblick auf derartige (para-medizinische) Tätigkeiten ist jedoch fraglich, inwiefern der Arzt hierbei als gerade solcher handelt, inwiefern also der Beruf des Arztes oder die Reputation der Ärzteschaft hiervon betroffen sein könnten. Einerseits vermag der Berufsträger eine besondere Qualifikation vorzuweisen, die zwar nicht für sämtliche in Frage stehenden Behandlungen erforderlich sein muss, die jedoch eine Vermutung für eine fachmännische und daher gegebenenfalls auch aufgrund der erworbenen medizinischen Fertigkeiten risikoärmere Behandlung begründet. Auch in diesem Kontext wird dem Arzt also ein besonderes, auf seinen fachlichen Kompetenzen gründendes Vertrauen entgegengebracht. Andererseits bewegt sich sein Handeln dabei nicht innerhalb der traditionell limitierten Zielsetzung ärztlichen Handelns. Dass dieser Umstand von Relevanz ist, wird dadurch deutlich, dass immer wieder die steuerrechtliche Bewertung von Einnahmen aus diesen Tätigkeiten oder die Einordnung eines Vertrages über die Erbringung derartiger Leistungen – oder: Ablieferung des bestellten Ergebnisses – als Dienst- oder als Werkvertrag<sup>966</sup> diskutiert wird.

Auch hier gilt jedoch, dass dies zwar ernstzunehmende Befürchtungen sind und dem Bedürfnis nach ethisch vertretbarem Handeln seitens der Ärzteschaft Rechnung zu tragen ist, eine entsprechende Einigung aber verhandelbar ist und im Wege von berufsrechtlichen Regularien und gegebenenfalls auch strafrechtlich bewehrten Verboten durchgesetzt werden kann. Es steht also nicht zu befürchten, dass die ärztliche Kunst mit der damit einhergehenden Reputation, dem ärztlichen Selbstverständnis und der Vertrauensbeziehung zwischen Arzt und Patient vollends entgleitet und zu einem bloßen „Handwerk zur Anfertigung des individuell bearbeiteten Körpers“<sup>967</sup> verkommt.

Herauszustellen ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Rolle des Arztes zwar normiert werden kann, ihr selbst jedoch keine normgenerierende Funktion zukommt. Es existiert jenseits der Diskussion um die Zulässigkeit bestimmten ärztlichen Handelns keine ärztliche Sondermoral, die das Ergebnis der rechtsphilosophischen und moraltheoretischen Abwägung der betroffenen Interessen unter Berücksichtigung aller Umstände unter Bezugnahme auf ein tradiertes ärztliches Ethos, basierend auf einem hergebrachte, korrespondierende Tugenden generieren-

<sup>966</sup> Siehe hierzu beispielsweise etwa Kern/Richter, Haftung für den Erfolgseintritt?.

<sup>967</sup> Kern/Richter, Haftung für den Erfolgseintritt?, S. 142.

den Rollenmodell, welches in modernen und komplexen Gesellschaften ohnehin Einbuße im Hinblick auf Prävalenz und Gültigkeit zu verzeichnen hat, kritisieren könnte.<sup>968</sup>

## 8. *Slippery slope*

Schließlich befürchten Gegner, dass die Gesellschaft mit der Möglichkeit genetischer Eingriffe eine abschüssige Bahn, auf der es kein Halten mehr gibt, eine sogenannte *slippery slope*, betritt.<sup>969</sup> Ein Schreckgespenst unmenschlicher eugenischer Praktiken ist sodann unter Verweis auf die deutsche Geschichte schnell an die Wand gemalt.

Dem Argument der schiefen Ebene liegt die Befürchtung zugrunde, mit der Zulassung oder Legalisierung einer Handlung begeben sich die Gesellschaft auf eine schiefe Ebene und gleite diese Ebene graduell, aber unaufhaltsam hinab, was final zu einem Resultat führe, welches hinzunehmen man nicht gewillt sei. Erlaube man heute die streitgegenständliche Handlung  $H_1$ , könnte morgen eine weitergehende Handlung  $H_2$ , für deren Zulässigkeit vorgebracht werden könnte, dass sie zwar immerhin, dennoch aber nur geringfügig über die Handlung  $H_1$  hinausgeht, erlaubt werden. Dies ließe sodann befürchten, dass am Ende einer Kette so verknüpfter Handlungen die aus heutiger Sicht abzulehnende Handlung  $H_n$  zugelassen würde, da diese ja schließlich nur ein geringfügiges Plus gegenüber der zuvor erlaubten Handlung  $H_{n-1}$  ist.<sup>970</sup>

Der Unterschied eines solchen Dammbrochs zu einem befürchteten Missbrauch, der, solange er als solcher gesellschaftlich identifizierbar ist, die Geltung der ihn als tadelnswert ausweisenden Norm nicht berührt, ist, dass sich bei Ersterem Inhalt und Reichweite der Norm selbst verschiebt, weil der Etablierung der jeweiligen Praxis eine normative Beglaubigung nachfolgt.<sup>971</sup>

Dem soll mit dem Argument der schiefen Ebene vorgegriffen werden, welches daher stets als konservatives Blockierungsargument dient. Diesem liegt nicht notwendigerweise eine Bewertung der in Frage stehenden Handlung als unerwünscht zugrunde, sondern das Argument wendet sich zumeist gegen die damit verbundenen Folgen. Deren Vermeidung bedürfe jedoch eines sofortigen Einschreitens, da der Übergang zwischen dem, was hingenommen werden kann, und dem Intolerablen ein fließender ist und ein exakter Einschnitt nicht identifiziert werden kann.<sup>972</sup>

<sup>968</sup> Mit Bezug auf die Präimplantationsdiagnostik, aber ebenso für alle neuen biotechnologischen Verfahren gültig Gutmann, Rechtliche und rechtsphilosophische Fragen der Präimplantationsdiagnostik, S. 83.

<sup>969</sup> Beispielsweise kritisch Lenk, Therapie und Enhancement, S. 82; Bayertz, Auf der Suche nach einer neuen Moral, S. 14.

<sup>970</sup> Guckes, Das Argument der schiefen Ebene, S. 5.

<sup>971</sup> Merkel, Forschungsobjekt Embryo, S. 196.

<sup>972</sup> Guckes, Das Argument der schiefen Ebene, S. 6.

Diese Argumentationslinie ist jedoch nicht unproblematisch. Es bedarf eines besonderen, aber meist nicht erbrachten Begründungsaufwandes, um zu erläutern, warum unter Rückgriff auf – wie schon anfangs anklang und noch zu erläutern sein wird: nicht vergleichbare – vergangene Ereignisse und historische Entwicklungen und unter Hinweis auf etwaige, sich häufig aber maximal vage andeutende Tendenzen der Gegenwart abzulehnende Entwicklungen in der Zukunft plausibilisiert werden können, im Hinblick auf deren Vermeidung schon gegenwärtig präventive Maßnahmen ergriffen werden sollen. *In concreto* ist diese Befürchtung in zweierlei Hinsicht wenig kohärent:

Zum einen stellt sich die Frage, warum die Möglichkeit, Kinder mit gewünschten Merkmalen auszustatten, notwendigerweise und gezwungenermaßen oder zumindest wahrscheinlich zu einem Dammbruch, konkret zu exzessiven eugenischen Praktiken, führen muss,<sup>973</sup> die *per se* abzulehnende, bei Weitem über die Verbesserung oder Vermehrung oben diskutierter *primary goods* im Sinne Rawls' hinausgehende Ausmaße annehmen. Zunächst einmal ist auch hier wieder zu betonen, dass mit diesem Argument nicht das genetische Enhancement als solches kritisiert werden kann, sondern dass es sich vielmehr auf befürchtete gesellschaftliche Entwicklungen bezieht. Nicht die Ursache müsste, um diese Sorgen zu zerstreuen, beseitigt werden. Es würde genügen, die Wirkung zu kontrollieren, also Vorkehrungen gegen unerwünschte soziale Folgen zu treffen. In der Vergangenheit wurden zahlreiche bio-medizinische Fortschritte und Durchbrüche als das Einfallstor verteuelt, das die abschüssige Bahn eröffne, die unmittelbar zu beispielsweise einer geschlechtsspezifischen Selektion, einem Aussortieren lebensunwerten Lebens oder der Kreation von Designer-Kindern nach elterlichem Gusto führe. Das Gros ist jedoch unterblieben und zwar häufig aufgrund von entsprechend restriktiven Gesetzen, die etwa dafür Sorge tragen, dass grundsätzlich die Auswahl der zur Befruchtung verwendeten Samenzelle anhand des in ihr enthaltenen Geschlechtschromosoms verboten ist (§ 3 ESchG), dass Eizellen nur zur Herbeiführung einer Schwangerschaft befruchtet werden und auch im Übrigen der Umgang mit menschlichen Keimzellen und Embryonen streng reglementiert und überwacht ist (§ 1 ESchG sowie zahlreiche weitere Vorschriften des Embryonenschutzgesetzes) sowie dass Schwangerschaftsabbrüche nur unter Einhaltung bestimmter, in den §§ 218a ff. StGB niedergelegter Voraussetzungen durchgeführt werden.

Freilich ist der Umgang mit einstmals neuen medizinischen Eingriffen in die menschliche Physis mit den Jahren und der durch Übung entstehenden Gewöhnung auch seitens der Gesellschaft ein sorgloserer geworden. Vieles, was einst argwöhnisch beäugt wurde, ist heute gang und gäbe. Operationen am offenen Herzen sowie Transplantationen, Frauen, die sich die sogenannte Antibabypille verschreiben lassen, Pränataldiagnostik und In-vitro-Fertilisation sind feste Bestandteile der

<sup>973</sup> Auch Zoglauer, *Konstruiertes Leben*, S. 73 referiert, dass ein Dammbruch keineswegs sicher ist und Kritiker dieses Arguments daher zu beruhigen versuchen, dass eine gesetzliche Handhabung, die eindeutig und strikt genug ist, eine Aufweichung und den Übergang von einem Ge- zu einem Missbrauch zu verhindern vermag. Auch Guckes weist darauf hin, dass die einem Schiefe-Ebene-Argument zugrundeliegende Vermutung, es komme zu einer bestimmten Ergebnisfolge, empirisch hinreichend gestützt sein muss: Guckes, *Das Argument der schiefen Ebene*, S. 10.



medizinischen Landschaft geworden, obschon sie zunächst scharf kritisiert wurden. Häufig aber dauert, wenn mittlerweile auch ein zumeist breiter Konsens gefunden ist, die kritische Auseinandersetzung hiermit weiterhin an. Dieses kann durchaus als ein Zeichen ethischer Reflexion und eines Ausbleibens einer Art der Verrohung oder eines Abgleitens die abschüssige Bahn hinab betrachtet werden. Gleichzeitig können wir heute feststellen, dass die Entwicklung gerade nicht die anfänglich befürchtete Richtung eingeschlagen hat. Eine Betrachtung des Querschnitts der gängigen medizinischen Praxis ist, auch wenn man persönlich einige Behandlungen oder Eingriffe bei sich oder seinen Kindern ablehnen würde, durchaus beruhigend. Abgesehen davon, dass, wie bereits erwähnt, mit dem Argument der abschüssigen Bahn nicht das genetische Enhancement als solches als intrinsisch schlecht bewertet werden kann, sondern lediglich dessen Folgen und Wirkung auf gesellschaftlicher Ebene, lässt sich mithin ebenso nicht begründen, warum gerade dieses bio-technische Verfahren eines ist, das endgültig zu einem Dammbruch und in der Folge zu eindeutig abzulehnenden Praktiken führt und auf das daher die Empfehlung „*Wehret den Anfängen!*“ anzuwenden ist.

Des Weiteren ist, da Gegner des genetischen Enhancements den Vergleich zu der nationalsozialistischen Eugenik-Politik, die zu einer grausamen und unmenschlichen Praxis auswuchs, nicht scheuen, die gezogene Parallele näher zu beleuchten. Dabei fällt auf, dass bedeutende Unterschiede zwischen beiden bestehen.

Während die Programme der NS-Zeit staatlich initiiert waren, sind die Initiatoren der heute in Frage stehenden genetischen Enhancements ausschließlich Privatpersonen als etwa zukünftige Eltern, die mit einem entsprechenden Wunsch an die hierauf spezialisierten Ärzte herantreten.<sup>974</sup> Der Staat tritt hierbei zunächst nicht in Erscheinung und nimmt sodann nur eine diese Aktivität begrenzende, reglementierende Funktion ein. Darüber hinaus sind auch die Ziele und die zu ihrer Erreichung eingeschlagenen Wege unterschiedliche. So ging es den NS-Eugenikern um die Verbesserung des gesamten Volkes durch die Eliminierung (daher auch die Bezeichnung als „negative Eugenik“) unerwünschter Eigenschaften aus dem gesamt-menschlichen Gen-Pool. Beim genetischen Enhancement hingegen soll das natürlich-kontingente Genom eines Individuums um erwünschte Eigenschaften ergänzt werden. Es geht gerade nicht um den Ausschluss aus dem Reproduktionsprozess, und zwar weder hinsichtlich einzelner Gensequenzen noch hinsichtlich konkreter Personen, die getötet oder sterilisiert würden. In dieser Hinsicht handelt es sich bei Gentechnik im Allgemeinen und genetischem Enhancement im Speziellen um sehr inklusive Technologien, die Betroffenen eine über die bisherigen Alternativen eines Verzichts auf eigene Kinder oder des Risikos von unter Umständen schwerstgeschädigten Abkömmlingen hinausgehende Möglichkeit eröffnen beziehungsweise nicht Genome aus dem Fortpflanzungsprozess ausschließen, sondern mit dem natürlich Gegebenen arbeiten und entsprechend der Wünsche modifizieren.

Aufgrund der prognostischen Unwägbarkeiten hinsichtlich der zukünftigen, durch ein unterlassenes Verbot genetischen Enhancements ausgelösten Entwicklungen und der fehlenden situativen Vergleichbarkeit vermag die Befürchtung eines

<sup>974</sup> Siehe auch *Sandel*, *The Case against Perfection*, S. 78.



Dammbruchs oder einer abschüssigen Bahn, auf der es kein moralisches Halten mehr gibt, nicht zu überzeugen. Dass gewisse Grenzen eingehalten werden müssen, bedingen schon die einschlägigen verfassungsrechtlichen Provisorien sowie die übrigen auf der Sekundärebene lokalisierten, ernstzunehmenden und zu berücksichtigenden Bedenken und Argumente. Darüber hinaus die nicht weiter substantiierten Befürchtungen einer *slippery slope* zum Anlass weitergehenden Regulierungsbedarfs im Sinne eines extensiven Verbotes zu nehmen, erscheint aus genannten Gründen nicht angemessen.<sup>975</sup> Es verbleibt somit bei dem Grundsatz „*abusus non tollit usus*“, und zwar umso mehr, als dass der Missbrauch kein Faktum ist, sondern lediglich eine theoretische Möglichkeit in der Zukunft.

Allenfalls könnte mittels einer eher symbolischen Gesetzgebung einer Formulierung Vorrang eingeräumt werden, die zwar den Handlungsrahmen nicht weiter begrenzt, aber mittel- bis längerfristig einer sich gegebenenfalls ausweitenden Praxis zumindest einen psychologischen Riegel vorschiebt. So ist es denkbar, die gesetzliche Kodifizierung als ein umfassendes Verbot auszugestalten, von dem aber Ausnahmen in Frage kommen, in denen das genetische Enhancement entweder erlaubt oder zumindest aber gerechtfertigt oder straflos wäre („Nein, es sei denn...“), und von einer grundsätzlichen Zulässigkeit, die aber wiederum beschränkt würde („Ja, aber...“) abzusehen. Wenn *de facto* beide Varianten auch zu einem gleich weiten Handlungsspielraum führen mögen, könnte erstere jedoch den zu schützenden und zu berücksichtigenden Rechten und Interessen den Anschein eines besonderen Gewichts und einer hervorgehobenen Bedeutung verleihen. Bestimmte verbessernde Eingriffe könnten sodann durch die Aufstellung eines abschließenden Kataloges ermöglicht werden, dessen *numerus clausus* die Inanspruchnahme eines genetischen Enhancements eng und streng beschränkt, indem er nur die Verbesserung bestimmter enumerierter Eigenschaften und/oder Fähigkeiten mittels konkreter Maßnahmen zulässt. Gleichzeitig wäre eine solche Aufzählung jedoch gänzlich unflexibel. Zum Anderen könnten Ausnahmen aber auch in einer Generalklausel vorgesehen werden, welche jedoch eine Ausweitung nur allzu leicht machen würde. Es erscheint somit sinnvoll, einen klar abgegrenzten Katalog durch einen möglichst präzise formulierten Auffangtatbestand zu ergänzen, dessen etwaiger Anwendungsbereich sich freilich an den enumerierten Fällen messen lassen muss, um die Vorteile beider Varianten nutzen zu können.

## 9. Fazit

Zusammenfassend lässt sich nunmehr festhalten, dass alleine die Grundrechte auf Leben und körperliche Unversehrtheit aus Art. 2 II 1 GG aktuell ein Verbot des genetischen Enhancements rechtfertigen können. Dies gilt jedoch nur, solange die Anwendung der beschriebenen Techniken unsicher und das ihnen inhärente Risiko

<sup>975</sup> Auch Warnock, BMJ 304, 1045 ist überzeugt, dass eine gesetzliche Regelung fähig ist, eine Entwicklung an jedem beliebigen Punkt zu stoppen, von dem die Gesellschaft der Auffassung ist, dass an ihm ein Hinabgleiten entlang der *slippery slope* beginnt.

unvertretbar ist. Die auf Sicherheitserwägungen, die schon dann teilweise obsolet werden könnten, wenn es gelingt, eine Reversibilität der Eingriffe einzuführen, gestützte Rechtfertigung eines Verbotes ist daher nur eine temporäre. Die anderen im Rahmen der Argumente zweiter Ordnung diskutierten Aspekte vermögen zuweilen rein faktisch nicht zu überzeugen<sup>976</sup> oder ein Verbot zu rechtfertigen, da anstelle dessen oftmals mildere Mittel<sup>977</sup> den Schutzziele ausreichen Rechnung tragen.

In jedem Fall aber bleibt die Gewichtung der analysierten Argumente dem Gesetzgeber, dem ein weiter Entscheidungs- und Ermessensspielraum zusteht, überlassen. Nicht nur kommt dem Gesetzgeber eine Einschätzungsprärogative zugute. Auch hat die Politik ein gewisses Irrationalitätsprivileg,<sup>978</sup> welches die Gestaltungsfreiheit und den Spielraum des Gesetzgebers bei dem Ausgleich zwischen konkurrierenden Gütern und Ansprüchen weiter vergrößert.<sup>979</sup> Trotz des grundsätzlichen Bestrebens, Folgerichtigkeit, Widerspruchsfreiheit und Konsistenz der Regelungen innerhalb des Rechtssystems zu erreichen und zu wahren, ist der Gesetzgeber nicht ausschließlich und nicht primär einem Rationalitätsideal verpflichtet,<sup>980</sup> weswegen es ihm unbenommen ist, einzelne Kriterien besonders zu gewichten und ihnen im Rahmen der hiesigen Debatte einen größeren Stellenwert als andernorts beizumessen, auch wenn dies zu Wertungswidersprüchen führt, solange er sich dabei nur im Rahmen der grundgesetzlichen Normen hält. Grund hierfür ist die „spezifisch institutionelle Rationalitätsdifferenz“ zwischen Politik und Wissenschaft, die sich daraus ergibt, dass Aktionsraum des Gesetzgebers der politische ist, in dem er multiplen Spannungsverhältnissen ausgesetzt ist. In politischen Mehrparteiensystemen, in denen Regierungen häufig erst durch Koalitionen gebildet werden, ist es unausweichlich, Kompromisse zu schließen, was jedoch stets zum einen lediglich eine temporäre, zum anderen aber auch eine gegebenenfalls nur bruchstückhafte, in aller Regel aber, gemessen am Kriterium der Systemreinheit, unvollkommene Regelung ermöglicht.<sup>981</sup>

Trotz des Wissens um diesen notwendigen Spielraum des Gesetzgebers und im Bewusstsein der politischen Unwägbarkeiten steht aber aus den entwickelten Er-

<sup>976</sup> So beispielsweise die empirisch widerlegte genetische Determination oder das empirisch nicht zwangsläufige Betreten einer abschüssigen Bahn, die Behauptung einer qualitativen Degradierung des mittels eines Enhancements erreichten Ziels oder einer Abwertung der zur Zielerreichung ohne Enhancement erforderlichen Anstrengungen und der historisch falsche Vergleich moderner Enhancements zur nationalsozialistischen Eugenik.

<sup>977</sup> Hierzu zählen die Einführung modifizierter Evaluationsmaßstäbe zur Gewährleistung einer Vergleichbarkeit von ohne und von mittels Enhancements erzielter Ergebnisse, die Option berufsrechtlicher Vorschriften zur Sicherung eines vernünftigen Arzt-Patienten-Verhältnisses oder die Erstellung eines Kataloges zur Begrenzung der verbesserungsfähigen Eigenschaften sowie die Einführung von eine kritische Reflexion über den Wunsch nach einem Enhancement fördernden Kontrollschritten zur Vermeidung einer ausufernden Enhancement-Praxis.

<sup>978</sup> Dreier, Bioethik zwischen gesellschaftlicher Pluralität und staatlicher Neutralität, S. 45.

<sup>979</sup> Dreier, Bioethik, S. 19 ff.

<sup>980</sup> Dreier, Bioethik, S. 71 f.

<sup>981</sup> Dreier, Bioethik, S. 71 ff.

wägungsgründen heraus zu vermuten, dass die diskutierten Argumente als nicht sonderlich gewichtig erkannt werden.

### III. Theologisch-politische Versuche einer Verbotsbegründung

Bislang ist es also nicht gelungen, im Medium des Rechts und unter Rückgriff auf soziologische, politische und philosophische Argumente ein umfassendes oder dauerhaftes Verbot zu rechtfertigen. Trotz der rationalen Begründungsschwäche ist dem Schrifttum weiterhin ein starkes Bedürfnis nicht nur irgendwelcher, sondern sowohl in sachlicher als auch in zeitlicher Hinsicht möglichst weitreichender Restriktionen genetischer Eingriffe, und zwar insbesondere solchen an Menschen, zu entnehmen. So wird allenthalben der Versuch unternommen, ein kategorisches Verbot, also ein Verbot, welches nicht nur jegliche und sämtliche genetische Enhancements untersagt, sondern welches auch, nachdem es einmal errichtet wurde, nicht mehr verhandelbar, sondern unumstößlich ist, zu etablieren. Entsprechend sind die vorgebrachten Argumente auch von – angeblichem – Schwergewicht: Sie verstehen sich dabei als kategorisch und ebenso notwendiger- wie auch fälschlicherweise als einen Beitrag zur Interpretation des Art. 1 I GG. Soweit ihre Vertreter auch anerkennen mögen, dass Art. 1 I GG in der herkömmlichen und weithin konsentierten Auslegungsvariante zur Erreichung dieser Ziele mangels Eröffnung des personalen Schutzbereiches beziehungsweise zumindest mangels Eingriffs in den sachlichen Schutzbereich nicht herangezogen werden *kann* – und richtigerweise aufgrund der erörterten dysfunktionalen Rückwirkungen auch nicht *darf* –, versuchen sie nun, die menschliche Gattung als solche und ein bestimmtes Menschenbild als von Art. 1 I GG geschützt zu erklären und gattungsbezogene Würdestandards zu proklamieren.<sup>982</sup>

Da, wie ausgeführt, der Rückgriff auf Art. 1 I GG als Anknüpfungspunkt dieser Thesen unzulässig ist und diese Argumente kategorischer Intention somit keine juristischen sein können, ließen sie sich nur als allgemein politische Argumente im Rahmen der demokratischen Deliberation vorbringen. Von Interesse sind in diesem Zusammenhang zunächst die Struktur, inhaltliche Ausgestaltung und Begründung der geschilderten Argumentation. Die anfängliche Vermutung besagt dabei, dass sie in Argumentationsstrukturen greifen, die früher explizit religiös waren und heute metaphysisch oder quasi-religiös sind sowie inhaltlich von Annahmen abhängen, die auf nicht allgemein vermittelbaren Offenbarungen und glaubenshaften Überzeugungen basieren. Sodann stellt sich die Frage, ob und inwieweit Argumente diesen Hintergrunds im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses in einem demokratischen und liberalen, der ethischen Neutralität verpflichteten Rechtsstaat vorgebracht werden und Berücksichtigung finden dürfen. Schließlich wird sich die Frage stellen, ob

<sup>982</sup> Maunz/Dürig-Herdeggen, GG, Art. 1 Abs. 1 Rdnr. 32; Isensee, Die alten Grundrechte und die biotechnische Revolution, S. 253 f., 261 f.; Hofmann, JZ 1986, 253 (260).

mit dem hierbei gefundenen Ergebnis eine Schwäche des politischen Liberalismus offenbart oder gerade eine Stärke hervorgehoben worden ist.

## 1. *De dignitate speciei*

Die Beiträge zu dem Versuch eines extensiven Verbotes genetischer Enhancements sind interdisziplinär. Einen – intendiert juristischen – Beitrag hierzu liefert auch der Staatsrechtler *Josef Isensee*, der von der Würde der „*Menschheit überhaupt*“, des „*Menschengeschlechts*“ spricht,<sup>983</sup> die verletzt werde, wenn die Zeugung eines Menschen ähnlich der Züchtung von Tieren von der Person der Erzeugenden abgelöst und das Genom entsprechend ausgewählt, verändert oder vervielfältigt wird. „*Die Würde des Menschen gebietet prinzipiell die Unantastbarkeit des menschlichen Erbgutes.*“ Als Ausnahmen erkennt *Isensee* lediglich die Intervention zur Behebung von genetisch bedingten schweren Behinderungen an. Als die abzuwägenden Güter benennt er hierbei ein Recht des *nasciturus* auf genetische Identität und die Verbesserung seiner späteren Lebensqualität durch die Ersparung von Leid.<sup>984</sup>

*Ernst Benda* will das Wesen des Menschen als zentrales Schutzgut des Art. 1 I GG erkennen und stützt sich hierbei darauf, dass der Mensch im Verhältnis zu anderen Lebewesen als seine distinguierende Eigenschaften sowohl Gemeinschaftsbezogenheit aufweist als auch einen Eigenwert, der verfassungsrechtlich als Würde bezeichnet wird und sich *Benda* zufolge auf das erstreckt, „*was für seine physische, psychische und seelische Existenz wesentlich ist*“ und den Kern seines Wesens ausmacht,<sup>985</sup> ohne dass er diesen näher beschreibt. Zwar erkennt *Benda* an, dass Art. 1 I GG nach bisherigem Verständnis alleine von dem konkreten einzelnen Menschen und nicht von der Menschheit als solcher handelt, hält es aber für notwendig, zum Zwecke der Evaluation der Folgen gentechnischer Entwicklungen eine Hilfskonstruktion anzuwenden, um den verfassungsrechtlichen Schutz auf noch nicht geborene Individuen auszudehnen. Dabei beruft er sich auf das aus Art. 20 I, Art. 28 I und Art. 23 I GG hergeleitete Sozialstaatsprinzip, welches nicht nur die Sorge für die heute Lebenden umfasst, sondern seinen Anwendungsbereich auch auf deren Nachkommen ausdehnt. Daraus leitet *Benda* ab, dass weder die Würde der heute lebenden Individuen zugunsten zukünftiger Generationen geopfert werden darf, noch heute Entwicklungen zulässig sein dürfen, die irreparable Manipulationen am Bild des Menschen vornehmen.<sup>986</sup> *Dieter Grimm* zufolge ist entsprechend Schutzgut des Art. 1 I GG auch die Gattung des Menschen mit ihren typischen und kennzeichnenden Charakteristika und Merkmalen.<sup>987</sup> Auch *Wolfgang Graf Vitzthum* führt unter Bezugnahme auf die Gentechnik aus, dass eine Aus-

<sup>983</sup> *Isensee*, Die alten Grundrechte und die biotechnische Revolution, S. 253.

<sup>984</sup> *Isensee*, Die alten Grundrechte und die biotechnische Revolution, S. 261 f.

<sup>985</sup> *Benda*, Erprobung der Menschenwürde am Beispiel der Humangenetik, S. 207 f.

<sup>986</sup> *Benda*, Erprobung der Menschenwürde am Beispiel der Humangenetik, S. 210 f.

<sup>987</sup> *Grimm*, NJW 1989, S. 1310.

dehnung der Menschenwürde als einzige verfassungsrechtliche Schutzvorkehrung in Frage kommt. Als hiervon geschützt sieht auch er den Kerngehalt dessen, was menschlich ist, an.<sup>988</sup>

Wenn auch die Genannten zweifelsohne und zu Recht hochreputable Juristen sind und wenn sie ihre Ausführungen auch vor dem Hintergrund des Art. 1 I GG machen, so muss doch erneut darauf hingewiesen werden, dass sie dies fälschlicherweise tun. Gleichwohl könnte es ihnen unbenommen sein, diese Überlegungen nicht als juristische Prinzipien, sondern politische Argumente in die Deliberation einzubringen. Zu ihren Gunsten sollen diese Anliegen daher auch als genau solche und losgelöst von der juristischen Zuordnung zu Art. 1 I GG gewertet werden. „Würde“ im Folgenden soll sich daher nicht auf den juristischen Terminus der verfassungsrechtlich verstandenen Menschenwürde beziehen.

Soll mit der Würde nun der Kern des Menschlichen oder der Menschheit geschützt werden, stellt sich die Frage, was genau unter diesem Wesenstypischen der Gattung Mensch zu verstehen ist.<sup>989</sup> Die dem Konzept einer Gattungswürde unterliegende Argumentation und seine spezifische Ausgestaltung sind dabei unabhängig von dem jeweiligen Vertreter stets sehr vage gehalten.<sup>990</sup> So wird beispielsweise von *Birnbacher* vorgetragen, die „*Idee des Menschen, ein Bild des Eigentümlichen und Unverwechselbaren des Menschen als Gattung*“ sei verletzt, wenn „*eine Norm der Gattungs- und Wesensangemessenheit [...] verletz[t]*“ ist.<sup>991</sup> Gleichzeitig aber gesteht *Birnbacher* ein, dass das Unwohlsein und der Widerwille, mit dem man einer Verletzung der Würde der menschlichen Gattung begegnet, reflexhaft und instinktiv ist, sich aber mit rationaler Ethik nicht begreifen oder begründen lässt, da diese und die moralischen Emotionen unterschiedlichen Richtlinien folgten.<sup>992</sup> Ein unverrückbares Verbot, welches von juristischer Seite lediglich über Art. 1 I GG erreicht werden könnte, oder, wie *Birnbacher* es nennt, ein Tabu lässt sich, ohne Paradoxien in Kauf zu nehmen, nicht rational begründen. Ein Tabu zeichne sich gerade durch seine Absolutheit und Sakrosanktheit aus, die durch Vernünfteln nur Schaden nehmen würden.<sup>993</sup> Unser spontanes Urteil richte sich beispielsweise danach, ob die zu bewertende Handlung „widernatürlich“ ist. Dieser Begriff bezieht sich bei *Birnbacher* jedoch nicht darauf, wie sich die Natur im tatsächlichen Lauf der Dinge darstellt – die Natur bringe vielmehr selbst Widernatürliches hervor –, sondern darauf, „*wie und was der Mensch sein sollte*“, sodass eine widernatürliche und daher der Würde der Gattung nicht entsprechende Handlung das Ideal der Natur verletzt.<sup>994</sup>

Dabei geht *Birnbacher* ohne weitere Begründung davon aus, dass diese Erwägungen zum Schutz des Menschlichen in zeitlicher Hinsicht nicht auf die Lebens-

<sup>988</sup> *Graf Vitzthum*, Gentechnologie und Menschenwürdeargument, S. 119 f., 138.

<sup>989</sup> Vorerst soll hier nicht auf biologische Aspekte wie das humane Genom eingegangen werden. Dies wird später Gegenstand gesonderter Überlegungen sein.

<sup>990</sup> *Welling*, Limited Sources of Normative Justification in the Secular Constitutional State?, S. 53.

<sup>991</sup> *Birnbacher*, Gefährdet die moderne Reproduktionsmedizin die menschliche Würde?, S. 79.

<sup>992</sup> *Birnbacher*, Gefährdet die moderne Reproduktionsmedizin die menschliche Würde?, S. 84 f.

<sup>993</sup> *Birnbacher*, Gefährdet die moderne Reproduktionsmedizin die menschliche Würde?, S. 77.

<sup>994</sup> *Birnbacher*, Gefährdet die moderne Reproduktionsmedizin die menschliche Würde?, S. 85.

dauer beschränkt sind, sondern darüber hinausgehen. Behandelte man vorpersonale und vorindividuelle Stufen nunmehr dadurch als zu manipulierende Sache, dass man Verfahren zur künstlichen Fortpflanzung anwendet, die nicht nur normalerweise ohne menschliche Eingriffe ablaufende Prozesse unterstützen oder substituieren, sondern „die die Existenz eines Menschen, seine genetische Konstitution oder beides tendenziell vollständig und gezielt determinieren“, stellte dies eine „verwirrende Inkongruität“ für „unsere moralische Sensibilität“ dar.<sup>995</sup>

Schließlich jedoch erkennt *Birnbacher* an, dass subjektive Emotionen nicht Grundlage eines Anspruchs auf Allgemeinverbindlichkeit und daher auch nicht Basis moralischer Normen sein können.<sup>996</sup> Obschon er dies verneint,<sup>997</sup> muss gleiches doch auch für juristische Normen wie ein gesetzliches Verbot genetischer Enhancements gelten,<sup>998</sup> die nicht nur Universalität innerhalb ihres Anwendungsbereiches beanspruchen, sondern zu diesem Zweck hinsichtlich der von ihnen betroffenen Personen ebenfalls universal argumentativ einsichtig gemacht werden können müssen. Trotz dieser, wenn auch nur auf moralische Normen bezogenen, Kenntnis bietet *Birnbacher* keine Antwort auf die Frage an, warum sein Konzept der Natur und Widernatürlichkeit normative Bedeutung entfalten sollte. Vielmehr gesteht er ein, dass es sich bei seinen Ausführungen um seine persönliche Meinung handelt, was bei einem Ethiker einem „Eingeständnis, dass die Anstrengung des Begriffs [der Würde des Menschen als Gattung] gescheitert ist“, gleichkomme.<sup>999</sup> Diese Erkenntnis entspricht, wie später zu zeigen sein wird, auch *Birnbachers* früherer These, dieser Begriff übernehme als absolute Grenze des Zumutbaren Funktionen ehemals religiöser Tabuierungen.

Die Autoren, die ein zentrales Charakteristikum des Menschlichen oder der Menschheit als solcher hingegen nicht nur an-, sondern auch auszuführen und inhaltlich zu benennen suchen, berufen sich auf Annahmen, die, wie nunmehr zu zeigen sein wird, religiös oder anderweitig partikular geprägt sind.

## 2. Die Unantastbarkeit der Schöpfung und Unverfügbarkeit über das Selbst

Im religiösen Kontext wird zur Begründung der Würde des Menschen unmittelbar auf die Lehre der Schöpfung des Menschen als das Ebenbild Gottes<sup>1000</sup> rekurriert. Als einziges der von Gott erschaffenen Geschöpfe ist der Mensch, so *Isensee*<sup>1001</sup>

<sup>995</sup> *Birnbacher*, Gefährdet die moderne Reproduktionsmedizin die menschliche Würde?, S. 85 f.

<sup>996</sup> *Birnbacher*, Gefährdet die moderne Reproduktionsmedizin die menschliche Würde?, S. 87.

<sup>997</sup> *Birnbacher*, Gefährdet die moderne Reproduktionsmedizin die menschliche Würde?, S. 87.

<sup>998</sup> Dieses wird später noch näher zu untersuchen sein.

<sup>999</sup> *Birnbacher*, Gefährdet die moderne Reproduktionsmedizin die menschliche Würde?, S. 87 (Ergänzungen Welling).

<sup>1000</sup> Gen 1, 27.

<sup>1001</sup> *Isensee*, AöR 131 (2006), S. 173 (199 ff.).



zum christlichen Bild vom Menschen und der Menschen- als Gattungswürde, nicht nur durch seine Natur determiniert, sondern aufgrund der Gabe der Vernunft zur Selbstbestimmung fähig. Ihm obliegt daher auch die Entscheidung für oder gegen die Erfüllung des Willens Gottes, was sich auch im Verhältnis zu Mitmenschen niederschlägt. Diese seien nicht bloßes Abstraktum der Menschheit, sondern ebenfalls von Gott geschaffen. Da der Mensch seine Würde nicht aus sich selbst hervorbringt, sondern von Gott empfangen und fortan zu verwalten hat, darf er dieser weder im Hinblick auf sich selbst noch auf andere Menschen zuwiderhandeln. Seine Würde ist unveräußerlich, ihn trifft eine Pflicht zur Selbstachtung und zur Annahme seiner selbst.<sup>1002</sup> Schon *Giovanni Pico della Mirandola* untersuchte, „warum der Mensch das glücklichste und demgemäß das Lebewesen ist, das jegliche Bewunderung verdient“,<sup>1003</sup> und kam, ganz der christlichen Tradition entsprechend, zu dem Ergebnis, dass es der Umstand sei, dass Gott ihm die Fähigkeit zugesprochen habe, über sich selbst zu verfügen und seinen Ort *in der religiös-sittlichen Welt* zu bestimmen.<sup>1004</sup>

### a) Das Geschöpf als Schöpfer seiner selbst

Schon hier werden aber auch die Grenzen dieser Verfügungsmacht deutlich. Sieht man den Grund der Würde in der zuvorkommenden Gnade Gottes begründet, so wird man auch ein göttliches Definitionsrecht bejahen müssen. Eine Ver zweckung des Menschen oder eine Verfügung über ihn widerspräche diesem.<sup>1005</sup> Was zunächst als Widerspruch erscheint – die Fähigkeit zur Verfügung über sich selbst als Grund der Würde bei *Pico* und *Körtner*s Annahme eines Verfügungsverbot es des Menschen über sich selbst –, ist jedoch nicht unbedingt unvereinbar. Sie sind vielmehr deckungsgleich, wenn man die Freiheit des Menschen als eine Auswahl zwischen den von Gott zur Verfügung gestellten Möglichkeiten und die Natur des Menschen somit nur als im Rahmen des göttlichen Plans veränderbar betrachtet.<sup>1006</sup> Diese und parallele Ausführungen scheinen allesamt gemein zu haben, dass bestimmte Tätigkeiten, Umstände oder Prozesse alleine der Zuständigkeit Gottes unterfallen und eine Einmischung des Menschen hierin eine Hybris wäre.

Im Rahmen der Anthropotechnik soll, so lautet die Schlussfolgerung, etwas geleistet werden, das nicht dem Menschen, sondern allein Gott zusteht. Doch hat Gott den Menschen nicht als sein Ebenbild erschaffen und wäre es daher nicht konsequent, dass der Mensch gerade deswegen nicht auch schöpfend tätig sein dürfte? *Daecke* differenziert hier: Neben dem Menschen ist auch die Welt in der Form, wie sie der Mensch gestaltet hat, weiterhin Resultat göttlicher Schöpfung. Hierunter

<sup>1002</sup> *Isensee*, AöR 131 (2006), S. 173 (199 ff.).

<sup>1003</sup> *Pico della Mirandola*, De hominis dignitate, S. 4/5, im lateinischen Original: „[...] cur felicissimum proindeque dignum omni admiratione animal sit homo [...]“.

<sup>1004</sup> *Pico della Mirandola*, De hominis dignitate, S. 8/9; *Isensee*, AöR 131 (2006), 173 (203); *Bayertz*, Human Dignity, S. 75.

<sup>1005</sup> Wie *Körtner*, Evangelische Kommentare 3/2000, 7 (9 f.).

<sup>1006</sup> *Bayertz*, Human Dignity, S. 75 f.



fällt auch die Technik. Die Gentechnologie und Reproduktionsmedizin kann hierbei zwar als „Mitarbeit am göttlichen Schöpfungsprozess“ begriffen werden. Nicht vom Willen des Schöpfers umfasst und daher nicht gerechtfertigt soll jedoch das sein, was der Würde, Unverfügbarkeit und Einmaligkeit des Geschöpfes widerspricht.<sup>1007</sup>

Zentraler Kritikpunkt von *Daeckes* und auch *Körtner*s Thesen ist eine etwaige durch das Enhancement stattfindende Wesensveränderung des und Verfügung über den Menschen. Kritisch lassen sich aber nun zwei Fragen stellen: Erstens, wie ist es möglich, dass, wenn der Mensch, so die Kritik an einem biologischen Reduktionismus, mehr ist als nur die Summe seiner Gene, der Kern dessen, was sein Wesen ausmacht, bereits durch eine Modifizierung seiner Gene gefährdet wird?<sup>1008</sup> Darüber hinaus betonen gerade auch evangelische Theologen, dass Lebensrecht und Würde nicht von intellektuellen Fähigkeiten und körperlicher Verfassung abhängt, sondern jedem Menschen, gerade und alleine weil er solcher ist, zusteht. Wenn aber klar ist, dass auch Personen, an denen ein genetisches Enhancement durchgeführt wurde, weiterhin Menschen, also Angehörige der Spezies *homo sapiens sapiens* sind, und diesen unabhängig von ihren jeweiligen Eigenschaften Würde zuzusprechen ist, dann dürfte der Umstand, dass eine oder mehrere dieser Eigenschaften nicht alleine durch den Einfluss natürlich-kontingenter kombinierter Gene oder durch Sozialisierung bedingt sind, sondern der biologische Aspekt gentechnisch beeinflusst wurde, ohne weiteren Belang sein. Anderes ließe sich jedoch dann annehmen, wenn man diesen Menschen nicht mehr als einen von Gott, sondern einen von anderen Menschen gemachten und wie ein Produkt hergestellten erachtet. Dies erscheint aber schon intuitiv nicht plausibel. Die im Rahmen der Fertilisation und der nachfolgenden Entwicklung ablaufenden Prozesse sind und bleiben weiterhin auf – undifferenziert gesprochen – die Natur angewiesen. Ihr Ablauf ist hochkomplex und wird auf absehbare Zeit vom Menschen nicht durchschaut geschweige denn sicher kontrolliert werden können.<sup>1009</sup> Gleichwohl ließe sich kritisch anmerken, dass das Programm zwar wie bisher auch natürlich abläuft, sein Inhalt aber verändert und daher unnatürlich ist. Inwiefern sich hieraus aber ein Argument gegen Techniken des genetischen Enhancements ergibt, wird später noch gesondert Gegenstand der Untersuchung sein.

Gewonnen ist auch darüber hinaus mit der These *Daeckes* nicht viel. Zumindest aber trägt sie der Kritik *Huppenbauers* Rechnung, anstelle einer unreflektierten Ethik des Sein-Lassens<sup>1010</sup> sei sinnvollerweise zu differenzieren, da freilich nicht mit guten Gründen bestritten werden kann, es sei fehlerhaft, wenn der Mensch Naturkatastrophen oder Krankheiten nicht als gottgegeben und gottgewollt hinnimmt, sondern die ihm von Natur oder Zufall angedienten Karten neu verteilt.<sup>1011</sup>

Zwar mag hiermit ein medizinischer Eingriff in den Lauf dessen, was ohne jeglichen Eingriff seitens des Menschen geschieht, als bloße Mitarbeit entlang der gött-

<sup>1007</sup> *Daecke*, Evangelische Kommentare 5/97, 286 (287).

<sup>1008</sup> *Huppenbauer*, Anthropotechnik und Humandesign, S. 192.

<sup>1009</sup> *Huppenbauer*, Anthropotechnik und Humandesign, S. 194.

<sup>1010</sup> *Körtner*, Evangelische Kommentare 3/2000, 7 (9).

<sup>1011</sup> *Huppenbauer*, Anthropotechnik und Humandesign, S. 189 ff.

lich vorgegebenen Richtlinien gerechtfertigt werden, denn immerhin hat Gott den Menschen dergestalt erschaffen, dass er Technik und Medizin zu entwickeln in der Lage war. Ab welchem Punkt jedoch dieser Pfad verlassen wird und der Eingriff nicht mehr vom Willen des Schöpfers umfasst ist, ab wann also die Würde verletzt wird, ist damit nicht expliziert, aber wohl auch nicht explizierbar. Die Ausführungen der Deutschen Bischofskonferenz belegen diese Vermutung: Ihr zufolge wohne Wissenschaft und Technik zwar nicht nur ein Gefahren- und Bedrohungspotenzial inne, sondern sie könnten darüber hinaus auch die menschliche Entwicklung zum Wohle aller fördern. Dabei sei aber zu beachten, dass sie nur durch den Menschen entstehen und sich nur durch ihn entwickeln können. Entsprechend bestehe eine Hinordnung auf den Menschen, was sie in ihrer Zielsetzung einschränkt und ihre moralischen Werte festlegt. Wissenschaft und Technik müssten daher im Dienste der menschlichen Person und ihrer unveräußerlichen Rechte sowie ihres „wahren“ Wohls entsprechend dem Plan Gottes stehen. Nur so könne sich die Person als geeinte Ganzheit entwickeln und der substantiellen Vereinigung zwischen seinem Körper und der Geistseele gerecht werden. Vor dem Weltärztebund sprach so *Johannes Paul II.* davon, dass jeder Mensch in seiner Einmaligkeit sowohl aus seinem Leib als auch aus Geist bestehe. Diese Identität des Menschen zu wahren gebietet die Achtung seiner Würde. Menschliche Würde ist dabei aber stets die Würde als Geschöpf Gottes. Über Ursprung und Ziele der Menschen entscheidet daher kein Arzt oder Wissenschaftler, sondern Gott als deren Schöpfer.<sup>1012</sup> Neben den aufgeworfenen und vorliegend bereits außerhalb eines theologischen Kontextes beantworteten Fragen des Einflusses eines genetischen Eingriffs auf die Identität der davon betroffenen Entität ergibt sich jedoch auch hieraus eine Explikation der inhaltlichen Ausgestaltung der Würde der Menschheit und den eine Verletzung konstituierenden Umständen nicht, sodass diese Frage nur unter Rückgriff auf spezifisch religiöse Überzeugungen zu beantworten ist. Dies jedoch soll nach dem soeben gewährten schlaglichtartigen Blick auf einige ihrer zentralen Thesen der theologischen Auseinandersetzung hierüber vorbehalten bleiben.

Gleiches gilt für die all den vorgetragenen Argumenten zugrundeliegende Annahme, dass der Mensch von Gott geschaffen und daher sein Leben sowie seine Natur als die Summe dessen, womit er von Gott ausgestattet wurde, heilig ist. Eine Modifizierung würde danach eine Hybris, ein Aufschwingen des Menschen, um Gott zu spielen, bedeuten.<sup>1013</sup>

Eindeutig und für vorliegende Ausarbeitung zentral ist jedoch die Erkenntnis, dass eine Argumentation, die darauf rekurriert, dass der Mensch Geschöpf einer höheren Macht ist und sich durch verbessernde Eingriffe in das Genom über die göttliche Rangordnung hinwegsetzt, auf nicht allgemein vermittelbaren Überzeugungen und glaubenshaften Offenbarungen beruht.

<sup>1012</sup> *Deutsche Bischofskonferenz*, Instruktion der Kongregation für die Glaubenslehre, S. 9 ff.

<sup>1013</sup> *Resnik*, Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 9 (2000), 365 (371).

## b) Gottesebenbildlichkeit

Dem christlichen Verständnis zufolge ist der Mensch darüber hinaus nicht nur von Gott, sondern ebenfalls, aber gleichzeitig auch *nur* als dessen Ebenbild erschaffen. Er wird daher Gott nie erreichen, der Mensch ist nicht perfektibel und ein Streben nach Perfektion, wie es etwa durch genetische Enhancements erreicht werden soll, gefährdet seine Humanität.<sup>1014</sup> Der Mensch ist nach theologischer Sicht daher durch Gott begrenzt, die Weigerung, die Begrenztheit des Menschen anzuerkennen, ist Sünde.<sup>1015</sup> Dem modernen Verständnis der Menschenwürde zufolge ist der Mensch hingegen sein eigenes Subjekt und sein eigener Herr oder Meister, da der Mensch alleine und frei sich selbst und seine Umwelt formt und gestaltet, ohne dabei von Gott, dem Schicksal oder einer limitierenden Natur bestimmt zu werden. Der Mensch ist, so ließe sich pointiert formulieren, nicht länger das Ebenbild Gottes, sondern selbst eine Art Gott geworden.<sup>1016</sup>

Freilich sind diese Annahmen nicht unkritisiert geblieben. *Birnbacher* beispielsweise führt aus, dass, da Gott selbst keine leibliche Natur besitzt, die menschliche Ebenbildlichkeit sich daher nur auf seine Rationalität, Autonomie und Moralfähigkeit beziehen, den Körper und auch das Genom hingegen nicht einschließen könne. Diese hingegen sind auch dem christlichen Verständnis zufolge nicht notwendigerweise vollkommen, einer Verbesserung nicht bedürftig und mit einer Aufwertung zu einem heiligen und würdevollen Sanktissimum verbunden. Entsprechend ließe sich mutmaßen, dass ein Gott, der das Glück seiner Geschöpfe wolle, es dem ihm ähnlichsten Geschöpf nicht verübeln könnte, wenn dieses seine Unzulänglichkeiten zu beseitigen versuche. *Birnbacher* fragt, warum der Mensch als „Freigelassener der Schöpfung“ seine exzeptionellen Begabungen nicht nur zur Selbsttranszendierung in geistiger, sondern auch in physischer Hinsicht nutzen sollte, wenn es doch ebenso gut möglich wäre, dass gerade dies die ihm zugewiesene Rolle und Bestimmung ist.<sup>1017</sup>

Spätestens hier wird jedoch deutlich, dass man an einem Punkt angelangt ist, an dem die vorgetragenen Argumente nicht mehr mit rationalen, selbst ethisch neutralen Erwägungen, die ihrerseits nicht wiederum auf religiösen oder anderweitig partikularen Vorstellungen beruhen, gestärkt oder entkräftet werden können. Während die zuvor diskutierten Ausführungen und aufgeworfenen Fragen – Unterliegen die Thesen einem biologischen Reduktionismus? Wird der Mensch durch ein genetisches Enhancement nunmehr wie eine Sache fabriziert? Ist damit seine Identität grundlegend verändert? – zumindest teilweise auch rational diskutiert werden können und so die Möglichkeit besteht, diese zu be- oder zu widerlegen, ist dies bei einem eindeutig stark-religiösen Argument nicht möglich. So basieren auch die am Beispiel *Birnbachers* referierten Gegenargumente ihrerseits auf der Annahme ebenfalls christlich geprägter Sätze. Diesem kann man zustimmen, wenn man die

<sup>1014</sup> *Lenk*, Therapie und Enhancement, S. 71.

<sup>1015</sup> *Köbl*, Gentechnologie zu eugenischen Zwecken, S. 178 f.

<sup>1016</sup> *Bayertz*, Human Dignity, S. 77.

<sup>1017</sup> *Birnbacher*, Natürlichkeit, S. 100 ff.

entsprechenden Glaubenssätze teilt, oder ablehnen, sofern man keiner oder einer anderen Religion angehört. Ein naheliegendes Gegenargument wäre daher auch die Verneinung der Existenz Gottes und jeglicher sich darauf beziehender Argumente. Allerdings wäre auch dies wiederum eine partikuläre Vorstellung. Eine Erklärung, die einsichtig und rationaler Weise weder zu be-, noch zu widerlegen ist, kann daher nicht anderen im Wege einer vernünftigen und rationalen Diskussion einsichtig gemacht werden, sondern bleibt eine Glaubensfrage.

### **3. Heiligkeit und Unantastbarkeit des Natürlichen**

Eine Unantastbarkeit des menschlichen Genoms wird zuweilen darüber hinaus aufgrund eines besonderen Wertes der Natürlichkeit oder der Natur des Menschen und eines sich daraus etwaig ergebenden Verbotes der Manipulation zu begründen versucht.<sup>1018</sup> Zumeist stellen diese Argumente eine Reaktion auf eine angenommene Gefährdung dar, der entgegengewirkt werden soll.<sup>1019</sup> Vorliegend soll jedoch darauf verwiesen werden, dass es hier nicht um eine Weisheit der Natur gehen soll, wie sie im Kontext unvorhersehbarer Risiken genetischer Enhancements, welche die scheinbar fehlerlos ablaufenden biologischen Prozesse und Entwicklungen des Menschen bedrohen, vorgebracht werden. Dabei handelt es sich um eine Risikofolgenabschätzung und -abwägung, die bereits eingangs des Kapitels über die Argumente zweiter Ordnung vorgenommen wurde.

#### **a) Natur und ethischer Naturalismus**

Natürlichkeit in vorliegendem Zusammenhang versteht sich zum einen als klassifikatorischer Begriff, der den Kontrast zwischen dem Menschen und der übrigen Natur betrifft und so Gattungszugehörigkeit *ex negativo* beschreibt. Andererseits kann anhand des Kriteriums der Natürlichkeit auch eine Unterscheidung zwischen dem natürlich Gewordenen (das vor und unabhängig vom Menschen da ist und eine bestimmte Beschaffenheit hat) und dem künstlich Gemachten (was nur durch den Menschen da ist und nur aufgrund dessen Wirken eine bestimmte Beschaffenheit hat) getroffen werden. Natürlichkeit in diesem Sinne ist somit ein komparativer Begriff.<sup>1020</sup>

Wollte man genetische Enhancements mittels eines Natur- oder Natürlichkeits-Begriffes definieren, so könnte man darunter Handlungen verstehen, „die darauf abzielen, das Funktionieren des menschlichen Organismus (unnatürlich) über das natürliche Maß hinaus zu erweitern.“<sup>1021</sup>

<sup>1018</sup> So etwa beschrieben von Baylis/Robert, *Bioethics* 18 (1), 1 (7).

<sup>1019</sup> Heilinger, *Anthropologie und Ethik des Enhancements*, S. 191.

<sup>1020</sup> Birnbacher, *Natürlichkeit*, S. 1, 6.

<sup>1021</sup> Heilinger, *Anthropologie und Ethik des Enhancements*, S. 72.

## aa) Natürlichkeit als universelle und gerechte Alltagsmoral

Dass eine solche Definition durchaus effizient ist, gründet schon darin, dass die Intuition oder die Alltagsmoral von einem Natürlichkeitsbonus<sup>1022</sup> geprägt ist, dessen Suggestivkraft sich diese Definition zunutze macht. Diese besondere Stellung der Natur zeigt sich, so führt *Birnbacher* beispielsweise aus, darin, dass in der sozialpsychologischen Risikoforschung festgestellt wurde, dass natürliche Risiken und Übel mit einer größeren Toleranz hingenommen werden als anthropogene Übel und Gefahren. Prävention gegen natürliche Widrigkeiten wird zudem als weniger dringend empfunden als die gegen von Menschen ausgehende.<sup>1023</sup> Auch in der Medizin wird ein Sein-Lassen, beispielsweise von weiteren Wiederbelebungsversuchen, noch einer weiteren Operation nach bereits mehreren erfolglosen, häufig als ein Ausdruck von Weisheit und Abgeklärtheit gelobt. All dies gilt selbst dann, wenn die natürlichen und anthropogenen Gefahren und Schäden gleich groß sind. Die Empfindung billigt der Natürlichkeit aber nur ein geringeres Maß an Negativem zu.<sup>1024</sup> Schon die sprachliche Verwendung der Begriffe „Natur“ oder „natürlich“ lassen, so *Birnbacher*, auf eine positive Konnotation schließen. So wird damit etwas gemeint, was vertraut, normal und selbstverständlich, authentisch und unverfälscht oder stimmig und harmonisch ist. Dieser Umstand bedingt, dass, wenn im Zusammenhang mit „Natur“ oder „natürlich“ etwas Negatives gemeint ist, es zu dessen Ausdruck stets eines zusätzlichen semantischen Aufwandes bedarf und so beispielsweise von der „rohen Natur“ die Rede sein muss<sup>1025</sup> oder eine nähere Beschreibung erfordert, wie sie beispielsweise *Lord Tennyson* vornimmt: „*Nature, red in tooth and claw*“.<sup>1026</sup>

Vor diesem Hintergrund, sei er im Einzelnen nun bewusst oder nur unbewusst wahrgenommen, wird daher vorgebracht, dass die Natürlichkeit des Menschen und so auch seines Genoms (wie die Menschenwürde des Art. 1 I GG auch) unantastbar (und somit ebenfalls absolut und umfassend geschützt) sei und eine künstliche Modifizierung gegen eine geradezu Heiligkeit der Natur verstieße.

Attraktiv scheinen Argumente eines solchen ethischen Naturalismus, hier verstanden in dem Sinne einer Positivbewertung des Natürlichen, einer Naturverbundenheit und gebotenen Achtung dessen, was durch die Natur gegeben ist, insbesondere, weil sie eine universale, stabile, objektive und egalitäre Begründung für Urteile und daraus folgende Anweisungen versprechen: Hinsichtlich der Universalität ist der ethische Naturalismus das funktionale Äquivalent für religiöse Überzeugungen, die angesichts der Vielfalt der Religionen und deren schwindender normativer Kraft für viele Personen rein faktisch schon keine taugliche Grundlage von Moral mehr sein können. Das Vakuum könnte nunmehr durch eine feststehende, unwandelbare und daher verlässliche universelle natürliche Ordnung gefüllt werden. Bestärkt wird

<sup>1022</sup> *Birnbacher*, Natürlichkeit, S. 21–28.

<sup>1023</sup> *Birnbacher*, Natürlichkeit, S. 22.

<sup>1024</sup> *Birnbacher*, Natürlichkeit, S. 23.

<sup>1025</sup> *Birnbacher*, Natürlichkeit, S. 30 ff.

<sup>1026</sup> *Tennyson*, In Memoriam A.H.H., canto LVI.

dies durch den anscheinend ewigen und unveränderlichen Charakter von Naturgesetzen, der den Universalitätsanspruch auch in zeitlicher Hinsicht unterstreicht. Objektivität der aus Naturgesetzen, vor denen alle Individuen gleich sind, abgeleiteten moralischen Vorschriften soll aus dem Fehlen natürlicher Privilegien und der Unabhängigkeit von kulturell geprägten Perspektiven in Interpretationen resultieren. Schließlich lassen sich die Naturgesetze auch bereits vorfinden. Sie stehen daher nicht zur Disposition kontingenter Herrscher, Priester oder anderweitig Mächtiger, sondern lassen sich grundsätzlich von jedermann erkennen, weil sie nicht mehr als Herrschaftswissen einem Potentaten vorbehalten sind.<sup>1027</sup>

#### bb) Kritik am ethischen Naturalismus

Trotz dieser für einen ethischen Naturalismus sprechenden Argumente ist dieser Ansatz keineswegs unkritisiert geblieben. *Neumann* etwa wirft vor dem Hintergrund der Annahme, dass ein Eingriff in das Erbgut des Menschen gleichzeitig ein Eingriff in dessen Natur sein und dies die Würde beeinträchtigen soll, gleich mehrere Fragen auf: Wessen Würde wird verletzt, die des jeweiligen Patienten oder die der Menschheit überhaupt? Wie kann dies ein Eingriff in die biologische Natur überhaupt bewerkstelligen, wenn die Natur, welche die Würde des Menschen konstituiert, gerade die vernünftig-sittliche ist, nicht aber in dem bloßen Genom begründet liegt?<sup>1028</sup>

Tatsächlich müssen Natürlichkeitsbehauptungen keineswegs moralfundierend sein. Dass in der Geschichte drastische Ungerechtigkeiten wie die Unterdrückung von Frauen oder Versklavung auf Natürlichkeitsargumente gestützt wurden, ist hierfür nur ein pragmatischer Grund.<sup>1029</sup> Darüber hinaus ist auch nicht einsichtig, warum „die Natur“ immer auch gut sein soll, bringt sie doch Krankheiten, Katastrophen und auch schreckliche menschliche Charakterzüge hervor. Andernfalls würde Hungersnöten, Erdbeben, Morden und Vergewaltigungen oder anderen Gräueltaten ein Wert beigemessen werden können.<sup>1030</sup>

Wenn wir unter dem Natürlichen die Welt verstehen, wie sie ist und sich darstellt, dann fallen darunter ebenfalls Naturkatastrophen und Krankheiten. Auch *Birnbacher* beschreibt die Natur als Moloch und das vermeintliche natürliche Gleichgewicht angesichts der Tatsache, dass 99 % aller biologischen Arten, die jemals gelebt haben, ausgestorben sind, als ein Gleichgewicht des Schreckens.<sup>1031</sup> Werden diese nun aber, weil sie ohne ein Zutun des Menschen auftreten, als gesollt angesehen, werden sie in einem starken, das heißt beispielsweise als explizit gottgewollt, göttli-

<sup>1027</sup> *Birnbacher*, Natürlichkeit, S. 42 f.; *Heiling*, Anthropologie und Ethik des Enhancements, S. 193 f.

<sup>1028</sup> *Neumann*, ARSP 84 (1998), 153 (156); *Neumann* geht davon aus, dass die Würde in der vernünftig-sittlichen Natur begründet liegt, nicht aber in der biologischen Ausstattung, S. 161.

<sup>1029</sup> *Heiling*, Anthropologie und Ethik des Enhancements, S. 197.

<sup>1030</sup> *Heiling*, Anthropologie und Ethik des Enhancements, S. 196 f.

<sup>1031</sup> *Birnbacher*, Natürlichkeit, S. 52.



cher Zorn oder als Aufzeigen göttlicher Macht, oder schwachen, dem menschlichen Leben Sinn gebenden, Verständnis heilig und unantastbar. Dann besteht das Gebot, diese Umstände hinzunehmen und zu ertragen. Der Bau von Dämmen, um Überflutungen zu verhindern, die wiederkehrend Ernte, Vieh und Menschen gefährden und vernichten, ist dann ebenso unzulässig wie die Therapie von Erkältungen oder Krebs und das Tragen von Brillen oder Hörgeräten. Dass all dies jedoch nicht sinnvoll gefordert werden kann, bedarf wohl keiner weitergehenden Ausführung. Die bloße Unterscheidung dessen, was natürlicherweise eintritt und was vom Menschen manipuliert wurde, ist somit zur normativen Bewertung bei Weitem nicht hinreichend. Somit ist stets zu hinterfragen, ob und warum der jeweils angelegte Wert ein guter ist.

Dies lässt sich jedoch ebenfalls nicht unter Rückgriff auf die Natur tun. Andernfalls wollte man aus dem bloßen Faktum des Seins ein Sollen fordern und unterläge so einem naturalistischen Fehlschluss.<sup>1032</sup> Was die Natur hervorbringt, mag oder, wie soeben angeklungen, mag nicht gut sein. Warum dies so ist, ergibt sich dabei aber nicht aus dem Umstand, dass das jeweilige Charakteristikum natürlich oder unnatürlich ist. Ansonsten ergäbe sich der Zirkelschluss, dass alles, was Natur ist, gut ist, und es gut ist, weil es Natur ist. Grundsätzlich lässt sich daher aus dem Sein ein Sollen nicht unmittelbar ableiten, ohne dass man einem naturalistischen Fehlschluss unterliegt. Aber das gilt auch nur für das bloße Faktum des Seins. Treten besondere Voraussetzungen hinzu, ist dies dennoch möglich. Nach theologischem Verständnis könnte dies die Vorstellung sein, dass Strukturen und Gesetzmäßigkeiten der Natur auf einen göttlichen Schöpfungsakt zurückgehen und daher als vom Schöpfergott gewollt zu respektieren sind.<sup>1033</sup> Aus rein deskriptiven Merkmalen ist die Ableitung von Wert- oder Sollensaussagen jedoch nicht schlüssig vorzunehmen.<sup>1034</sup> Auch Gene haben somit keine besondere ontologische Qualität, sondern sind als solche zunächst nur Lebensbausteine, die der Mensch in großem Umfang beispielsweise mit dem Schimpansen teilt und deren Kombination erst human- und auch individualspezifisch ist.<sup>1035</sup>

Schon der Begriff der menschlichen Natur stellt sich als zersplittert und keineswegs eindeutig greifbar dar. Eine Bestimmung der Natur (des Menschen) erweist sich immer als ein von kontingenten Entscheidungen und kontingenten kulturellen Einflüssen determiniertes Ideal.<sup>1036</sup> Als normatives Konzept, das bestimmten gesetzlichen Regularien zugrundegelegt werden soll, erweist sich „die Natur“ oder „das Natürliche“ daher als untauglich. Eine trennscharfe Unterscheidung zwischen dem natürlichen Gewordenen und dem künstlichen oder unnatürlichen Gemachten ist nicht möglich: Sind die Erdbeeren oder die Blumen, die bereits im Winter in beheizten und beleuchteten Gewächshäusern gezüchtet werden, wirklich vollständig natürlich, obschon sie so in der Natur und ohne den Einfluss des Menschen nie

<sup>1032</sup> Heilinger, *Anthropologie und Ethik des Enhancements*, S. 195.

<sup>1033</sup> Neumann, ARSP 84 (1998), 153 (158).

<sup>1034</sup> Birnbacher, *Natürlichkeit*, S. 45.

<sup>1035</sup> Honnefelder, *Humangenetik und Menschenwürde*, S. 169.

<sup>1036</sup> Heilinger, *Anthropologie und Ethik des Enhancements*, S. 89.



entstanden wären? Gleichzeitig sind die Spuren des Natürlichen auch nicht dort zu verwischen, wo der Mensch eindeutig den größeren Beitrag zur Entstehung eines Gegenstandes geleistet hat. Auch die *Kunstblume*, die als solche unzweifelhaft unnatürlich ist, wurde aus Materialien hergestellt, die entweder unmittelbar abgebaut werden konnten, wie etwa Baumwolle, aus der die Blätter der Kunstblume gewebt sind, oder die ihrerseits zwar vom Menschen kreiert wurden, aber aus natürlichen Rohstoffen bestehen, wie beispielsweise dem Plastik, aus dem der Stängel geformt ist.

Der normative Anspruch von Natürlichkeitskonzepten ist somit mangels inhaltlicher Bestimmtheit sowie mangels Legitimation ein überaus schwacher. Eine Unverfügbarkeit oder Unantastbarkeit „der Natur“ ließe sich nur aufgrund anderweitiger, dies auffangender Konzepte installieren, die sodann jedoch, um dies zu erreichen, der Natur in deistischer Personifizierung Heiligkeit beimessen.

Diese Erkenntnis ist schließlich auch mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts konsistent, dessen Beschluss<sup>1037</sup> über die Unvereinbarkeit des § 8 I Nr. 3 und 4 TSG mit Art. 2 I und II in Verbindung mit Art. 1 I GG nur auf einer normativen Bedeutungslosigkeit der Natur als das biologisch Zugewiesene beruhen kann. Hierin hielt das Bundesverfassungsgericht die Vorschrift des Transsexuellengesetzes, der zufolge in dem zu entscheidenden Fall die betroffene Mann-zu-Frau Transsexuelle mit ihrer Partnerin erst dann eine eingetragene Lebenspartnerschaft hätte begründen können, wenn sie sich zuvor einer geschlechtsumwandelnden Operation unterzogen hätte und dauerhaft zeugungsunfähig gewesen wäre, für verfassungswidrig.<sup>1038</sup> Sei diese Voraussetzung jedoch unzulässig und es daher möglich, dass ein biologischer Mann als eine Frau im personenstandsrechtlichen Sinne mit einer anderen Frau ein Kind zeugt, so habe ein solches Auseinanderfallen von rechtlicher Geschlechtszuordnung und Erzeuger- beziehungsweise Gebärendenrolle zwar beachtliche Konsequenzen hinsichtlich der rechtlichen Zuordnung des Kindes.<sup>1039</sup> Eine normative Aussage scheint das Bundesverfassungsgericht den biologischen Gegebenheiten für die rechtliche Bewertung dabei aber dennoch nicht entnommen zu haben.

Dies bestätigt die Erkenntnis, dass das Kriterium der Natürlichkeit mit Blick auf die Medizin, die als Ausprägung von Kultur ohnehin dazu berufen ist, der Natur gerade nicht ihren Lauf zu lassen, normativ belanglos ist und medizin-ethische oder medizin-rechtliche Relevanz nur im konkreten Fall aufgrund des Willens des jeweils Betroffenen, der dies gerade zu seiner persönlichen Präferenz gemacht hat, erlangt,<sup>1040</sup> eine solche aber nicht verallgemeinerbar und daher nicht taugliche Grundlage einer gesetzlichen Regelung ist.

---

<sup>1037</sup> BVerfGE 128, 109.

<sup>1038</sup> BVerfGE 128, 109 (insbesondere 133 ff.).

<sup>1039</sup> BVerfGE 128, 135 f.

<sup>1040</sup> Gutmann, Short Cuts to Happiness, S. 145.

## b) Schutz des menschlichen Wesenskernes und eines guten Lebens

Bei den Eingriffen des Menschen in „die Natur“ scheint es aber nicht ausschließlich um diese selbst zu gehen, sondern auch darum, ob die Eingriffe angemessen oder gerechtfertigt sind. So ist die Einnahme von Ritalin durch Patienten mit ADHS oder die Verabreichung des rote Blutkörperchen bildenden Hormons Erythropoetin (Epo) an Patienten mit Blutarmut aufgrund beispielsweise einer Dialyse- oder Chemotherapie allgemein positiv beurteilt. Soll mithilfe pharmazeutischer Unterstützung hingegen eine Prüfung be- oder die Tour de France überstanden werden, so bleibt dies keineswegs unkritisiert, sondern wird als vorwerfbar und drastischere Maßnahmen, zu denen wohl auch genetische Enhancements zählen, eventuell gar als abstoßend empfunden. Dies zeigt, dass nicht die Mittel und ihre (Un-)Natürlichkeit alleine beurteilt werden können, sondern das mittels ihres Einsatzes angestrebte Ziel ebenfalls berücksichtigt und in die Beurteilung der Angemessenheit der Mittel einbezogen werden muss.<sup>1041</sup>

### aa) Das Natürliche und das Gemachte

Häufig wird die Befürchtung geäußert, gentechnologische Eingriffe führten zu einer Abschaffung und Ablösung des Menschen und der Menschheit durch Artefakte. Auch wenn dies nicht überzeugend ist, da der bloße Umstand, dass einzelne Gene ausgewählt wurden, mit der Zugehörigkeit zur Gattung Mensch nicht inkompatibel ist, so steht dahinter doch die Aussage, dass es etwas Schützenswertes gibt, was aufgrund der großen Möglichkeiten der Medizintechnik gefährdet ist und was als Kern dessen begriffen wird, was den Menschen als solchen ausmacht und was daher so wertgeschätzt wird, dass es nicht riskiert werden soll. *Francis Fukuyama* sieht dies in der menschlichen Natur und damit meint er: in den speziestypischen Charakteristika und dem, was die menschliche Gattung einzigartig macht.<sup>1042</sup>

Was genau hierzu zählt, ist keineswegs eine neu gestellte Frage. In der Geschichte des Nachdenkens über den Menschen wurden so als wesentliche Charakteristika der Vernunftgebrauch des *animal rationale*, das gesellschaftliche Zusammenleben als *animal sociale*, der Gebrauch von Werkzeugen durch den *homo faber* und das Sprachvermögen des *homo loquax* genannt.<sup>1043</sup> Diese Eigenschaften sind jedoch mitnichten vollständig: Der Versuch einer Wesensbestimmung verfällt häufig in eine formelhafte Reduktion.<sup>1044</sup>

<sup>1041</sup> Auch *Birnbacher*, Natürlichkeit, S. 9 f. nennt als Determinanten unterschiedlicher Abstufungen von Natürlich- oder Künstlichkeit neben der Eingriffstiefe und der Ebene, auf der der Mensch natürliche Strukturen und Prozesse verändert, und den Wechselwirkungen zwischen natürlichem Substrat und Kultur auch die Intentionalität der Eingriffe.

<sup>1042</sup> *Glover*, Choosing Children, S. 82 f.

<sup>1043</sup> *Heilinger*, Anthropologie und Ethik des Enhancements, S. 85.

<sup>1044</sup> *Heilinger*, Anthropologie und Ethik des Enhancements, S. 85 Fn. 27.

## bb) Wesensbestimmung durch die ein gutes Leben ausmachenden Determinanten

Auch der Versuch, sich dem natürlichen Wesen des Menschen und dem, was es zu bewahren gilt, darüber zu nähern, was als Determinanten für ein gutes Leben identifiziert werden kann, vermag nicht zu verfangen. Nach der Konzeption des *human flourishing* fasst beispielsweise *Martha Nussbaum* hierunter die Fähigkeit, ein Leben von normaler Dauer und bis zu dessen Ende zu führen, körperliche Gesundheit und angemessene Ernährung und Unterkunft, Sicherheit vor körperlichen Übergriffen, Mobilität, sexuelle Befriedigung und freie Entscheidung hinsichtlich der Fortpflanzung, die Fähigkeit zu denken, sich Dinge vorzustellen und seine Sinne zu nutzen, eine basale Ausbildung zu genießen, die Fähigkeit, Bindungen einzugehen und Gefühle zu spüren, selbst eine individuelle Auffassung vom Guten zu bilden und darüber zu reflektieren, soziale Interaktion und das Empfinden einer Zugehörigkeit bei gleichzeitiger Freiheit von Demütigung und Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der ethnischen Zugehörigkeit, sexuellen Orientierung, Religion, nationaler Herkunft oder ähnlichem, Spiel und die Kontrolle über die eigene Umwelt im Wege der politischen Partizipation oder aufgrund der Fähigkeit, Eigentumsrechte zu haben, oder zu arbeiten.<sup>1045</sup> Gleichzeitig ist *Nussbaum* zufolge aber *auch* die Einschätzung der jeweiligen Person zu beachten.<sup>1046</sup> Hingegen ist diese einem utilitaristisch geprägten Ansatz zufolge entscheidend. Dabei kommt es *ausschließlich* darauf an, ob die betroffene Person ihr eigenes Leben als gut und sich als glücklich empfindet. *Jeremy Bentham* beispielsweise versteht unter Glück den Genuss von Freuden und die Sicherheit vor Schmerzen.<sup>1047</sup>

Diese utilitaristischen Konzeptionen wurden jedoch vielfach als zu eng kritisiert, genüge hiernach, wie von *Robert Nozick* angemahnt, für ein gutes Leben doch schon eine *experience-machine*, die den Vorlieben der jeweiligen Person angepasst werden kann und die dem Benutzer mittels Stimulation des Gehirns ein Leben frei von Schmerzen, aber voll von Freude und Glück verspricht.<sup>1048</sup>

Wenn diese Ansätze und primär der Ansatz *Nussbaums* auch dazu beitragen mögen, einen übergreifenden Konsens zwischen Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft oder Konfession darüber, welche Güter essentiell sind und welche Aspekte ein gutes Leben ausmachen, zu begründen, und insofern universeller Akzeptanz fähig sein könnten, da sie zu ihrer Begründung nicht metaphysischer Vorannahmen bedürfen, sondern es sich vielmehr um eine „*partielle moralische Konzeption*“ im Sinne *Rawls*' handelt,<sup>1049</sup> vermögen sie aus zwei Gründen dennoch keine Aussage darüber zu treffen, was der schützenswerte natürliche Kern des Menschen ist, der durch ein genetisches Enhancement berührt werden könnte.

Zum einen ist, sofern zentraler Maßstab das Bild der individuellen Person vom eigenen Leben ist, welches an den ganz subjektiven Vorstellungen dessen, was ein

<sup>1045</sup> *Nussbaum*, Die Grenzen der Gerechtigkeit, S. 112 ff.; *Glover*, Choosing Children, S. 87.

<sup>1046</sup> *Nussbaum*, Die Grenzen der Gerechtigkeit, S. 108; *Glover*, Choosing Children, S. 90.

<sup>1047</sup> *Glover*, Choosing Children, S. 90.

<sup>1048</sup> *Glover*, Choosing Children, S. 90.

<sup>1049</sup> *Nussbaum*, Die Grenzen der Gerechtigkeit, S. 105, 116.

gutes Leben ausmacht, gemessen wird und worauf auch „*adaptive Präferenzen*“ von Einfluss sind, dies weder empirisch noch normativ verallgemeinerbar, was auch *Nussbaum* betont.<sup>1050</sup> Die rein faktisch determinierten Kriterien, also das kulturelle oder soziale Umfeld, in dem man lebt, die Erfahrungswerte und die sich hieraus ergebenden Vergleichsmöglichkeiten, außer Acht gelassen, ist die individuelle Evaluierung ein stark wertgeladenes Unterfangen, bei dem religiösen Überzeugungen oder anderweitig partikularen Prämissen ein entscheidender Einfluss zukommt. Wollte man dies zum Maßstab der Evaluierung genverbessernder Eingriffe und somit zur Begründung eines staatlichen Gesetzes machen, ließe sich aufgrund mangelnder Allgemeingültigkeit der Kriterien das gefundene Ergebnis und somit auch die Geltung der Norm nicht allen Normadressaten argumentativ einsichtig machen. Dass hieraus ein Legitimationsdefizit folgt, wird sogleich festzustellen sein.

Zum anderen aber tragen diese Ansätze nichts oder nur sehr wenig zur Beurteilung der Zulässigkeit genverbessernder Eingriffe bei, werden die genannten Kritikern in signifikant bedeutenderem Umfang von der Umwelt und dem gesellschaftlichen Umfeld des Betroffenen und deren Einflüsse, der Versorgung sowohl in medizinischer als auch diätetischer Hinsicht oder anderen Faktoren bestimmt als durch das Genom. Eine Aussage darüber, was dasjenige ist, was durch einen Eingriff in das Genom verletzt oder gar abgeschafft würde, kann, selbst wenn zwischen diesem und dem guten Leben eine Korrelation bestünde, auch dem Ansatz *Nussbaums* nicht entnommen werden, da er sich selbst nicht auf die genetische Konstitution als eine Determinante bezieht, sondern lediglich deren Auswirkung insofern in den Blick nimmt, dass sich hieraus besondere Umstände ergeben können, aufgrund derer eine Ungleichverteilung<sup>1051</sup> von Gütern und Ressourcen nötig sein mag, um allen Individuen deren Nutzen und deren Übersetzung in Tätigkeit in gleichem Maße zu ermöglichen.

Auch diese Ansätze lassen sich, obschon sie in ihrer faktischen Dimension, das heißt zumindest soweit sie nicht auf die je individuelle Bewertung des eigenen Lebens abheben, eines universellen und daher von divergierenden Überzeugungen unabhängigen Konsenses fähig zu sein scheinen, zur Bestimmung eines natürlichen menschlichen Wesenskernes somit nicht heranziehen.

### cc) Das Genom als stoffliche Signatur der Seele

Ein Ansatz, der inhaltlich hierüber hinausgeht und dem Genom eine besondere Wertigkeit zuspricht, verweist dabei in der Regel auf dessen Unveränderlichkeit, wie sie zumindest bislang bestand. Innerhalb der menschlichen Natur stelle das Genom

<sup>1050</sup> *Nussbaum*, Die Grenzen der Gerechtigkeit, S. 109. Das Konzept der „*adaptiven Präferenzen*“ besagt, dass Menschen ihre Präferenzen an das anpassen, was sie aufgrund dessen, wie sich ihre Situation gemessen an dem Bild, wie sich die jeweilige Gesellschaft darstellt und welches die Gesellschaft von Menschen wie dem jeweiligen hat und was diese dem jeweiligen Menschen als angemessen zuspricht, glauben erreichen zu können. Im Ergebnis führt dies zu einer Legitimation des *status quo*.

<sup>1051</sup> *Nussbaum*, Die Grenzen der Gerechtigkeit, S. 105.

dabei den innersten Platz des Seins dar, dem gegenüber alle weiteren Charakteristika lediglich peripher seien. Als etwas Gegebenes, Determiniertes und Unveränderbares bestehe zwischen dem Genom und der Natur eine privilegierte Verbindung, die von Schicksalhaftigkeit geprägt sei. Darauf beruht sodann die der aristotelischen Metaphysik und deren zentralem Begriff des *eidos* als das die Materie erst Definierende, das heißt deren Form, entsprechende Annahme, dass das Genom der harte Kern des Organismus sei und das Programm enthalte, anhand dessen ein bestimmtes Lebewesen mit spezifischer Identität entstehe. Das Genom werde so zum „weltlichen Äquivalent“, der „stoffliche[n] Signatur der Seele.“<sup>1052</sup>

Hier ist es aber nun irrelevant, ob letzterer Begriff im Sinne des Holemorphismus oder in seiner theologischen Bedeutung verwendet wird. In jedem Fall trägt auch dieser Ansatz nicht zu einer Klärung des natürlichen Wesenskernes des Menschen bei, da zum einen, wie bereits erörtert, die persönliche Identität keineswegs der ausschließlichen und noch nicht einmal der prägenden Determination durch das Genom unterliegt und zum anderen, wie nunmehr zu zeigen sein wird, ein Abheben auf religiöse oder anderweitig partikuläre Wertvorstellungen in einem freiheitlichen und säkularen Rechtsstaat unzulässig ist.

#### 4. Kritik

Die Lektüre einiger bundes- und landesverfassungsrechtlicher Vorschriften lässt diesbezüglich zwar eine andere Vermutung zu, nämlich diejenige, dass ein christlich geprägtes Bild geradezu verfassungsrechtlich geboten ist, nimmt man nur die in den Präambeln einiger Verfassungen enthaltenen expliziten Gottesbezüge in den Blick. Die Landesverfassung des Landes Baden-Württemberg sieht darüber hinaus in ihrem Art. 1 I vor, dass der Mensch gehalten ist, seine Gaben in Freiheit und in der Erfüllung des christlichen Sittengesetzes zu entfalten, und Art. 12 I bestimmt, dass die Jugend in der Ehrfurcht vor Gott und im Geiste christlicher Nächstenliebe zu erziehen ist.<sup>1053</sup>

Auch noch in abgeschwächter Form könnte einem christlichen Überzeugungskanon als Säkularisat Relevanz zukommen. *Isensee* beispielsweise differenziert zwischen der Begründung und dem Inhalt der Menschenwürde: Der der Neutralität verpflichtete Staat mache sich lediglich den säkularen Inhalt der Menschenwürde zunutze. Die religiöse Begründung jedoch nehme er nicht an, wenn er auch vom christlichen Erbe zehre und sich diesem gegenüber daher nicht gänzlich neutral verhalten könne. Stark an das „Böckenförde-Diktum“<sup>1054</sup> erinnert *Isensees* Ausspruch: „Die Quellen seiner Energien, deren er bedarf, liegen außerhalb seines säkularen Machtbereichs.“<sup>1055</sup>

<sup>1052</sup> Dies referiert kritisch *Mauron*, Genom-Metaphysik, S. 241 ff.

<sup>1053</sup> *Huster*, Ethische Neutralität, S. 16 f.

<sup>1054</sup> *Böckenförde*, Staat, Gesellschaft, Freiheit, S. 60: „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.“

<sup>1055</sup> *Isensee*, AöR 2006, 173 (208).

Dass eine Trennung des Guten und des Rechten, das heißt religiöser und partikularer Wertvorstellungen des Einzelnen von staatlichen, in ihrem Geltungsbereich allgemein verbindlichen Regeln dennoch erforderlich und verfassungsrechtlich geboten ist, gilt es im Folgenden nunmehr zu bestätigen.

### a) Abstraktion der Geltung von der Genesis des Rechts

Ebenfalls die Differenzierung zwischen der Begründung beziehungsweise der Entstehung und dem Inhalt von Rechtsnormen sowie der ihr Fortgelten rechtfertigenden Begründung in den Blick nehmend führt *Gutmann* aus, dass, auch wenn, wie bereits *Hegel* erkannt habe, zentrale Aspekte der normativen Moderne im Rahmen einer Theologisierung herausgebildet worden seien, nunmehr die spezifisch christlichen oder theologischen Gehalte dieser Begriffe aus dem Recht zur Gänze verschwunden seien, da sie entweder ersatzlos entfernt oder vollständig transformiert wurden. Mit *Habermas* betont er, dass die Legitimationsgrundlagen des Rechts und der Politik säkular im Sinne von freistehend seien,<sup>1056</sup> auch wenn die Entstehung der jeweiligen Norm sich von christlichen Einflüssen nicht freisprechen kann. In dem Auseinanderfallen von Genesis und Geltung müsse nicht notwendigerweise eine Negation der Theologie durch die westliche Rechtswissenschaft gesehen werden. Vielmehr handele es sich um eine Loslösung auf der Ebene der Begründung.<sup>1057</sup> Die Menschenwürde beispielsweise habe sich von einer von der Stoa vorbereiteten und im Christentum als eine alle Menschen als Ebenbild Gottes umfassenden Würde, die, den diesem zugrundeliegenden Vorstellungen und Überzeugungen entsprechend, für den Einzelnen eine pflichtengeladene Bürde darstellte, zu der Grundnorm personaler Autonomie des heutigen Grundgesetzes entwickelt. Mangels Kompatibilität dieses Konzeptes mit einer religiösen Tradition seien, so *Gutmann*, die normativen Fundamente daher dem Bereich postkonventioneller Normenbegründung zugehörig<sup>1058</sup> und die Menschenwürde im Rechtssinne ein über diejenige im theologischen Sinne sowohl strukturell als auch funktionell hinausgehendes Konzept. *Gutmann* stellt ebenso knapp wie treffend fest: „*Christenmenschen darf man foltern, Rechtspersonen nicht.*“<sup>1059</sup>

Dem entsprechend und den oben beschriebenen Eindruck, welchen die Lektüre der Präambel der Verfassung des Bundes oder einiger Länder vermittelt, korrigierend soll die Präambel des Grundgesetzes bereits seinen Müttern und Vätern zufolge keine Verpflichtung des Staates auf das Christentum enthalten.<sup>1060</sup> Vielmehr soll die Präambel ausdrücken, dass Staat und andere menschliche Instanzen nicht letzter Bezugspunkt sind und totalitäre Machtgewalt zu begründen vermögen. Auch die Schweizer Bundesverfassung enthält ein solches „*Bekennnis zur Relativität aller*

<sup>1056</sup> *Gutmann*, Säkularisierung der Normenbegründung, S. 223.

<sup>1057</sup> *Gutmann*, Säkularisierung der Normenbegründung, S. 235.

<sup>1058</sup> *Gutmann*, Säkularisierung der Normenbegründung, S. 227, 229.

<sup>1059</sup> *Gutmann*, Säkularisierung der Normenbegründung, S. 228 f.

<sup>1060</sup> *Parlamentarischer Rat*, Akten und Protokolle, Band 5/1, S. 518 ff.

*staatlicher Macht*“, das als Chiffre für einen Verpflichtungshorizont gelten soll, der über alles Menschliche hinausgeht. Dies soll auf keine bestimmte Weltanschauung verpflichten, sondern nur Ausdruck dessen sein, dass sich weder der Mensch noch der Staat auf sich selbst gründen.<sup>1061</sup>

### **b) Implikationen eines Faktums des Pluralismus**

Schon rein praktisch begegnet darüber hinaus eine theologische oder allgemein weltanschauliche Begründung Schwierigkeiten und führt somit zu einem Anwendungsvorteil auf Seiten der hier zu begründenden Erforderlichkeit und Gebotenheit einer Trennung zwischen dem Guten und dem Rechten. Zwar ist, das einzelne Individuum betrachtet, es weitgehend unproblematisch, wenn Intuitionen oder auf der jeweiligen Überzeugung des Einzelnen gründende Annahmen individuelle fraglose Gewissheiten produzieren und diese derart im Einklang mit den Intuitionen anderer stehen, dass ein ethischer Konsens vorliegt. Diese können so oft verlässliche Indikatoren für die Geltung der von ihnen vorausgesetzten oder behaupteten Normen sein. Weniger eindeutig gestaltet sich jedoch die Beurteilung von ungewohnten oder seltenen Situationen, in denen erste, unreflektierte Einschätzungen und umso mehr deren Konsequenzen selbst mit den eigenen ethischen Fundamenten nicht schlüssig zu vereinbaren sind oder in denen unterschiedliche moralische Maximen oder ethische Prinzipien miteinander konfliktieren. Gestaltet sich die Auflösung solcher Normenkonflikte schon für den Einzelnen häufig schwierig und im Ergebnis als Resultat persönlicher Präferenzen, individueller Weltanschauungen oder anderweitiger unbeglaubigter Empfindungen, ist die Auseinandersetzung mit weiteren Diskussionsbeteiligten weitgehend zum Scheitern verurteilt, soweit die vorgebrachten Normen theologisch bestimmt sind oder auf religiösen Bekenntnissen oder metaphysischen beziehungsweise partikularen Weltanschauungen beruhen. Als Begründung für rechtliche Regelungen sind ein derartiges Fundament und die darauf aufbauenden Lehren in einer pluralistisch geprägten Gesellschaft untauglich,<sup>1062</sup> da diese neben dem beschriebenen Anwendungsnachteil gegenüber der Trennung des Rechten vom Guten auch, wie sich sogleich zeigen wird, ein Legitimationsdefizit aufweisen.

Das Rechte als die politische, von allen akzeptierbare, da ohne partikularen Überbau auskommende Minimalmoral<sup>1063</sup> steht so in grundlegendem Konflikt zu dem individuell und partikular beantwortbaren, nicht bindenden Guten.<sup>1064</sup> Ist das Gute zwar von jedem selbst und nur für sich zu beurteilen und müsste daher eigentlich ein konfliktloses Nebeneinander unterschiedlicher Konzeptionen des Guten problemlos möglich sein, so erheben jedoch die unterschiedlichen Konzeptionen des Guten

<sup>1061</sup> Paraphrasiert nach dem Zitat bei *Spinner*, Die Situation der Menschenwürde in der westlichen Kultur, S. 159 f.

<sup>1062</sup> *Merkel*, Forschungsobjekt Embryo, S. 15–17.

<sup>1063</sup> Vergleiche auch *Larmore*, Politischer Liberalismus, S. 133.

<sup>1064</sup> *Huster*, Ethische Neutralität, S. 11.



jeweils in aller Regel für sich selbst einen Universalitätsanspruch, sodass sie nicht nur die normative Grundlage dessen darstellen wollen, wie das die jeweilige Konzeption teilende Individuum sein Leben führen soll, sondern wie *man* sein Leben führen soll.<sup>1065</sup> Die unterschiedlichen, sich schon aufgrund ihres jeweiligen Universalitätsanspruchs gegenseitig ausschließenden Konzeptionen des Guten sind somit nicht homogenitätsverbürgend, sondern dissoziativ. Dies kennzeichnet aber nicht nur das Verhältnis zwischen unterschiedlichen theologischen Strömungen, sondern auch das innerhalb einer einzigen Kirche.<sup>1066</sup> Schon unter christlichen Akteuren bleiben bioethische Fragestellungen zu moderner Medizintechnik, insbesondere zur Fortpflanzungsmedizin, aber auch im Rahmen von *end of life decisions*, weithin kontrovers diskutiert. Während die römisch-katholische Kirche modernen biotechnologischen Praktiken umfänglich ablehnend gegenübersteht, ungeachtet dessen, ob es sich um eine bloße assistierte Reproduktion, die PID oder eine verbrauchende Embryonenforschung handelt, zeichnet sich in der Evangelischen Kirche Deutschlands etwa ein uneinheitlicheres, gespaltenes – oder eben: pluralistisches – Bild ab. Der auch innerhalb des Christentums herrschende Dissens liegt offen zutage, wenn in Ethikräten oder anderen Gremien, die zu einer Entscheidungsfindung oder Beratung berufen sind, eine Einigung nicht erzielt werden kann und es so zu abweichenden Voten kommt oder es bei bloßen Bestandsaufnahmen des Meinungsstreites bleibt. Abgesehen davon, dass das „christliche Menschenbild“ sich so selbst als notorisch unscharf und unbrauchbar disqualifiziert,<sup>1067</sup> birgt, da auch das Christentum ebenso wie andere Religionen oder sonst theologische, metaphysische oder anderweitig partikulare Weltanschauungen den Anspruch der universalen, aber exklusiven Gültigkeit erhebt, ein solcher *clash of universalisms*, wie historisch zutage getreten und belegt ist, ein gehöriges Gewaltpotential in sich, aufgrund dessen der Staat berufen ist, die Rolle eines „*Dompteurs*“ einzunehmen.<sup>1068</sup> Dies fordert dem Staat und den politischen Akteuren eine vermittelnde, ausgleichende und diplomatische Haltung ab, mit der keiner der konfligierenden Weltanschauungen Vorrang vor der anderen eingeräumt wird.

Trotz dieser dem Pluralismus an Weltanschauungen, religiösen, theologischen und anderweitig partikularen Überzeugungen inhärenten Konflikthanfälligkeit ist er durchaus gewünscht und normativ unterfangen.<sup>1069</sup> Gesichert wird dieser durch verfassungsrechtliche Vorkehrungen zugunsten der Neutralität, so etwa in Art. 4 I, 3 III, 33 III GG, sowie in Art. 136 I und IV, 137 I WRV i. V. m. Art. 140 GG und dem Gedanken, dass der Staat Heimstaat aller Bürger sein soll.<sup>1070</sup> Der Hintergrund dieser verfassungsrechtlichen Vorkehrungen ist mehrschichtig.

<sup>1065</sup> Huster, Ethische Neutralität, S. 21.

<sup>1066</sup> Dreier, Bioethik zwischen gesellschaftlicher Pluralität und staatlicher Neutralität, S. 6; Huster, Ethische Neutralität, S. 6.

<sup>1067</sup> Vergleiche Dreier, Bioethik zwischen gesellschaftlicher Pluralität und staatlicher Neutralität, S. 7 f.

<sup>1068</sup> Gutmann, Religiöser Pluralismus und liberaler Verfassungsstaat, S. 291.

<sup>1069</sup> Dreier, Bioethik zwischen gesellschaftlicher Pluralität und staatlicher Neutralität, S. 5 ff.; Huster, Ethische Neutralität, S. 5–7.

<sup>1070</sup> Huster, Ethische Neutralität, S. 43.

## aa) Historisch-strategische Begründung der ethischen Neutralität des Staates

Historisch gesehen ist die Zurückhaltung des Staates in weltanschaulichen Fragen durchaus strategisch. Indem der Staat sich hierzu neutral verhält, vermeidet er seine durch eine positive Bekenntnis entstehende Spaltung. Die Gefahr der Desintegration wird so durch die Entscheidung für eine Indifferenz gegenüber religiösen Wahrheitsansprüchen umgangen und ein breiter *modus vivendi* ermöglicht. Historisch wurden so Frieden zwischen religiös verfeindeten Glaubensgruppierungen und die Sicherung der politischen Macht erreicht. Grundlage des Neutralitätsgebotes waren somit schon machtpolitische Klugheitsabwägungen. Im Zuge der Säkularisierung der politischen Ordnung erfolgten auch die Beschränkung auf die Gewährleistung der Verträglichkeit der individuellen Freiheitsausübung und ein Verzicht auf deren inhaltliche Bewertung.<sup>1071</sup>

Vorteil dieses *modus vivendi*-Ansatzes ist die begründungstheoretische Simplizität. Die Neutralität scheint aus dem Staatsbegriff selbst zu folgen, geradezu vorkonstitutionell zu sein. *Huster* jedoch mahnt, dass dieser rein instrumentell orientierte Ansatz insofern kritisch ist, als dass er zum einen nicht erklärt, warum der Staat sich auch gegenüber Gruppierungen neutral zu verhalten hat, die nicht stark genug sind und dies vermutlich auch nie sein werden, um den inneren Frieden zu gefährden, und zum anderen nicht gewährleistet, dass unterschiedliche Gruppierungen auch *gleich* behandelt werden, sowie dass ein so begründetes Neutralitätsgebot davon abhängt, welches Konfliktpotenzial ein Unterscheidungskriterium hat. Insofern verliefen, so *Huster*, die Kritikpunkte parallel zu denen an kontraktualistischen Begründungen von Recht und Moral, und dem Vorwurf, diese Ansätze erfassen die originär normative Dimension des Problems nicht umfänglich.<sup>1072</sup>

## bb) Ethisch-politische Argumentation zugunsten der Neutralität

Von einem philosophischen Standpunkt aus betrachtet, argumentiert zugunsten der staatlichen Neutralität auch der ethische Liberalismus. Die Privilegierung der einen Vorstellung des Guten unter Diskriminierung der anderen muss sich jedoch epistemischer Kritik ausgesetzt sehen: Gibt es in Fragen der Weltanschauung keine Wahrheitskriterien, sind diese Fragen also nicht wahrheits- sondern nur glaubens-fähig, dann beruht eine staatliche Maßnahme, die sich diesen individuellen Entscheidungen gegenüber nicht neutral verhält, selbst auf einer irrationalen und wertabsolutistischen Haltung. Ein solcher, dieser Argumentation zugrundeliegende ethische Relativismus jedoch muss selbst nicht stets mit dem Neutralitätsgebot kompatibel sein, da er außer Acht lässt, dass es durchaus – und mittlerweile sicher nicht einmal nur vereinzelt – Personen gibt, die zwar eine individuelle und partikuläre Konzeption des Guten hegen, sich aber gleichzeitig auch bewusst sind, dass ihre Vorstellungen und Werte, auf denen ihre Anschauung fußt, historisch und somit kontingent

<sup>1071</sup> *Huster*, Ethische Neutralität, S. 47 ff.

<sup>1072</sup> *Huster*, Ethische Neutralität, S. 47 ff.

bedingt, was gleichzeitig heißt: kritisierbar, nicht einzig plausibel und erst recht nicht universal verbindlich, sind. Wenn relativistische Haltungen sich auch nicht auf den Inhalt der Vorstellungen des Guten beziehen mögen, so treffen sie jedoch eine Aussage darüber, was es bedeutet, eine solche Vorstellung zu haben. Diese ist jedoch ihrerseits weltanschaulicher Natur und daher umstritten. Zentral ließe sich an dieser Position und der Annahme, dass es in normativen Fragen keine Wahrheit und daher auch kein Wissen gibt, etwa kritisieren, dass konsequenterweise dann die Existenz normativer Vorgaben verneint werden müsse und das Neutralitätsgebot sodann selbst in der Luft hänge.<sup>1073</sup>

#### cc) Voraussetzung für persönlichkeitsidealistische Individualität

Schenkt man jedoch dem zentralen Anliegen, aus welchem die Forderung nach staatlicher Unparteilichkeit resultiert, nämlich die Gewährleistung der Ausübung individueller Freiheiten und Ausgestaltung der eigenen Lebensführung, weiter Beachtung, so liegt es nahe, als weiteres Konzept zur Begründung des Neutralitätsgebotes das Ideal der Individualität zu berücksichtigen. Bereits seit *Hobbes* war nicht mehr das objektive Urteil einer theologischen Vernunft leitendes Prinzip von Recht und Staat, sondern vielmehr die Vernunft des jeweils handelnden Einzelnen.<sup>1074</sup> Zentraler Beweggrund des Protests gegen eine staatliche Parteilichkeit in Fragen der Lebensführung und Weltanschauung war das Streben nach Freiheit zur je eigenen Suche nach dem guten Leben. Freilich birgt dies immer auch Gefahren des Sich-Irrrens, des Treffens der falschen Wahl und sogar der Selbstschädigung hierdurch. Dennoch hielten beispielsweise *Humboldt* wie auch *Mill* staatliche Eingriffe, die über den Zweck der Sicherung des Staates nach außen sowie des Schutzes vor Rechtsgutsverletzungen hinausgehen, für unzulässig. *Humboldt*<sup>1075</sup> sah die Freiheit als *conditio sine qua non* zur Erfüllung des Zwecks des Menschen, der Entfaltung seiner jeweiligen Eigentümlichkeit und Originalität sowie Erreichung der jeweiligen und individuellen Absichten. Einförmigkeit, etwa aufgrund staatlicher beschränkender Eingriffe, hingegen führe zu einer Reduzierung der Fähigkeiten und Kräfte, die ein Mensch ausbilden könne. Dies schließlich stelle eine Verfehlung des Zwecks des Menschen dar. *Mill*<sup>1076</sup> sieht als einzigen Grund, in die Freiheiten einer Person einzugreifen, den Schutz der Freiheiten und Rechte einer anderen Person, sodass allein das Prinzip der Kompatibilität individueller Freiheitssphären legitime Ressource positiver Rechtsordnungen sein kann. Für *Mill* ist der Hintergrund dessen die Fähigkeit des Menschen, Fehler zu korrigieren, mittels Erfahrungen und Diskurs zu berichtigen und entsprechend der Erkenntnisse richtigzustellen. Zentrales Instru-

<sup>1073</sup> *Huster*, Ethische Neutralität, S. 53 ff.

<sup>1074</sup> *Gutmann*, Religiöser Pluralismus und liberaler Verfassungsstaat, S. 292; *Gutmann*, Säkularisierung und Normenbegründung, S. 231 f.

<sup>1075</sup> *Humboldt*, Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen, S. 30 f.

<sup>1076</sup> *Mill*, Über die Freiheit, S. 103, 111 ff.

ment hierfür ist *Mill* zufolge die Meinungsfreiheit, der neben der Bedeutung für die Persönlichkeitsentfaltung zentral auch ein sozialer Nutzen zukommt. Unkritisiert sind jedoch auch diese persönlichkeitsidealistischen Ansätze nicht geblieben. *Huster* etwa stellt fest, dass das geradezu perfektionistische Persönlichkeitsideal *Humboldts* oder *Mills* seinerseits auf einem spezifischen und nicht notwendigerweise universalen Menschenbild und einer allgemeinverbindlichen Lebensweise beruht. Außerdem ist der Zusammenhang zwischen Individualität beziehungsweise freier Persönlichkeitsentfaltung und staatlicher Abstinenz in Fragen der Weltanschauung und Lebensführung bereits ein empirischer, aber eine Allgemeinverbindlichkeit des *Humboldt'schen* und *Mill'schen* Menschenbildes ist damit keineswegs begründet.<sup>1077</sup>

#### dd) Gerechtigkeitstheoretische Neutralitätskonzeption des politischen Liberalismus

##### *(1) Der politische Liberalismus*

Die Zersplitterung gesellschaftseinheitlicher Weltanschauungen und der damit einhergehende Verlust der allgemeinen Verbindlichkeit religiöser Annahmen bedingt die Notwendigkeit<sup>1078</sup>, staatliches Recht nicht weiterhin auf die sich aus glaubenshaften Überzeugungen ergebenden Prämissen zu stützen. Für den Rechtsstaat als „*Dompteur*“<sup>1079</sup> wurde es – schon zur Gewährleistung des eigenen Fortbestandes<sup>1080</sup> – erforderlich, zwischen den politischen Akteuren mit ihren jeweils divergierenden, sich gegenseitig ausschließenden, aber jeweils absolute Geltung für sich selbst reklamierenden Überzeugungen Ausgleich zu schaffen und deren Gewaltpotential<sup>1081</sup> einzudämmen. Er war somit berufen, seine Ressourcen selbst zu generieren, sich insbesondere hinsichtlich der Begründung seiner Rechtsnormen nicht auf partikuläre Glaubenssätze zu stützen und so einer Überzeugung Vorrang vor der anderen einzuräumen, sondern hierzu auf allgemeine und öffentlich einsehbare Gründe, die Vernunft, zu rekurrieren.<sup>1082</sup> Die dem Staat und seinen Maßnahmen und Regeln zugrundeliegenden Prinzipien müssten, so kann ebenfalls formuliert werden, auch

<sup>1077</sup> *Huster*, Ethische Neutralität, S. 59 ff.

<sup>1078</sup> Die hieraus folgende Neutralität des Staates erkennt auch *Larmore*, Strukturen moralischer Komplexität, S. 54 als die bessere Reaktion auf den Umstand, dass verschiedene Menschen unterschiedliche Auffassungen vom guten Leben vertreten, an und verwirft die Möglichkeit der zufälligen Auswahl des zu fördernden Ideals oder der Festlegung der Bürger auf ein Ideal mittels Repression.

<sup>1079</sup> *Gutmann*, Religiöser Pluralismus und liberaler Verfassungsstaat, S. 291.

<sup>1080</sup> Vergleiche *Ackermann*, *Journal of Philosophy* 91 (1994), 364 (365).

<sup>1081</sup> *Larmore*, Politischer Liberalismus, S. 132: „*Hundert Jahre Glaubenskriege waren eine Tatsache, die kein frühliberaler Denker ignorieren konnte.*“

<sup>1082</sup> *Habermas*, Richtigkeit versus Wahrheit, S. 324, 327, 332, 346.

dann gelten, wenn es keinen Gott gäbe.<sup>1083</sup> Diesen und den Gedanken *Hobbes*'<sup>1084</sup>, die Grundnormen des Rechts dürften sich nicht aus einer natürlichen Ordnung oder dem Willen Gottes entwickeln, sondern ihnen müsse eine Idee gleichberechtigt handelnder Personen als Träger von subjektiven Freiheitsrechten zugrundeliegen, sodass die Einschränkung der Freiheit einer Person durch staatliche Maßnahmen alleine mittels der Vernunft, anhand von Bedingungen der Reziprozität und Allgemeinheit gerechtfertigt werden können, aufgreifend und fortentwickelnd, entkoppelt sodann der politische Liberalismus die normativen Leitlinien der Politik und des Rechts von weltanschaulichen Prämissen.<sup>1085</sup> Der Staat soll hiernach nicht eine Auffassung des guten Lebens gegenüber einer anderen alleine aufgrund ihrer angeblichen intrinsischen Überlegenheit bevorzugen.<sup>1086</sup>

Neben der zentralen Aussage des politischen Liberalismus, staatliche Gewalt bedürfe der Rechtfertigung, ist dessen wesentliche Annahme, dass diese Rechtfertigung alleine im Wege der *public justification*, des öffentlichen Vernunftgebrauchs, erfolgen und nur auf Gründen beruhen kann, die im Prinzip jedermann diskursiv einsichtig gemacht werden können. Ein Staat, dessen Rechtsordnung dem Einzelnen die Entscheidung über die individuelle Lebensführung überlässt und, indem er eine Vielzahl divergierender Einstellungen und Weltanschauungen zulässt, ein *Faktum des vernünftigen Pluralismus* schafft, ist, wenn er den Einzelnen in seiner Freiheit und als Rechtsperson ernst nimmt, darauf verpflichtet, die Begründung seiner politischen Handlungen daran zu messen, was allgemein vernünftigerweise als Begründung anerkannt werden kann.<sup>1087</sup> Es ist ihm dabei untersagt, einzelne der umstrittenen Ideen des Guten zur Begründung politischer Prinzipien heranzuziehen und andere zu verwerfen; er muss diesen gegenüber neutral sein.<sup>1088</sup> Gleichfalls müssen die Bürger ihr politisches Handeln einander argumentativ darlegen können, was voraussetzt, dass sie sich dabei auf öffentliche, vernünftige, das heißt auf anderen vermittelbare und daher auf nicht auf bloß individuelle Glaubensvorstellungen beruhende Gründe stützen können.<sup>1089</sup> Rechtsnormen mit allgemeinem Geltungsanspruch ist es somit selbst dann untersagt, sich auf partikuläre Vorstellungen des Guten zu stützen, wenn diese den Überzeugungen der Majorität entsprechen. Das Prinzip der *public justification* fungiert mithin auch als Legitimationsgrenze des Mehrheitsprinzips.<sup>1090</sup>

Vor dem Hintergrund dieses Überblicks über die zentralen Aussagen des politischen Liberalismus sollen dessen Thesen im Folgenden zunächst detaillierter er-

<sup>1083</sup> *Grotius*, Vom Recht des Krieges und des Friedens, Vorrede Ziffer 11, S. 33.

<sup>1084</sup> *Hobbes* begreift die Freiheit der individuellen Person, alleine dem eigenen Urteil und der eigenen Vernunft unterworfen zu sein, als deren natürliches Recht: *Hobbes*, *Leviathan*, 14. Kapitel, S. 125 f.

<sup>1085</sup> *Gutmann*, Religiöser Pluralismus und liberaler Verfassungsstaat, S. 91 ff.

<sup>1086</sup> *Larmore*, Strukturen moralischer Komplexität, S. 46.

<sup>1087</sup> *Gutmann*, Religiöser Pluralismus und liberaler Verfassungsstaat, S. 93 ff.

<sup>1088</sup> *Larmore*, Politischer Liberalismus, S. 133.

<sup>1089</sup> *Ackermann*, *Journal of Philosophy* 91 (1994), 364 (366 f.).

<sup>1090</sup> *Gutmann*, Religiöser Pluralismus und liberaler Verfassungsstaat, S. 93 ff.

arbeitet und sodann, in einem letzten Schritt, deren Implikationen für die Beurteilung genverbessernder Eingriffe anhand der erörterten Argumente hiergegen und deren soeben getroffener Charakterisierung als auf partikularen Sondervorstellungen beruhend expliziert werden.

### *(2) Prozedurale Umsetzung politisch-liberaler Anforderungen*

*Rawls* hat im Rahmen seiner Gerechtigkeitstheorie versucht, eine in diesem Sinne ethisch neutrale Ordnung zu gründen, indem er ihr mit dem *Urzustand* und dem *Schleier des Nichtwissens* einen empirischen Rahmen gab und so *Kants kategorischen Imperativ* einer verfahrensmäßigen Deutung unterzog. Dieser *Schleier des Nichtwissens* schließt es aus, dass die Personen im *Urzustand* ihre Vorstellungen des Guten kennen,<sup>1091</sup> und erreicht so mittels einer Begrenzung<sup>1092</sup> des Pools zulässiger Gründe auf ausschließlich öffentliche, allen unabhängig von persönlichen Überzeugungen und Präferenzen verständliche und überzeugende Gründe eine gerechte Verteilung der Güter und eine größtmögliche Gewährleistung von Freiheiten. Hierdurch ermöglicht es *Rawls*, Grundsätze festzulegen, vor denen die Menschen freie, gleiche und vernünftige sind, und eine reine Klugheitswahl zu treffen, aus der zwingend eine größtmögliche Freiheit sowie der strikte Vorrang des Rechten vor dem Guten resultiert.<sup>1093</sup> Wenn die Parteien im *Urzustand* sich aber somit gegen einen Inhalt und gegen ein allgemein geltendes Wohl entscheiden, um sich die Freiheit der eigenen ungehinderten Wahl der jeweiligen Vorstellung zu erkaufen, so räumen sie dieser wiederum Priorität ein.<sup>1094</sup>

### *(3) Politisch-liberale Normenbegründung und -Rechtfertigung*

Aus den angestellten Erwägungen ergibt sich, wie oben hergeleitet, ein Bedürfnis nach einer Begründung für das Neutralitätsgebot, die ihrerseits unabhängig von partikularen Weltanschauungen als freistehend bestehen kann,<sup>1095</sup> weswegen eine ethische Begründung ausscheidet, um nicht vom Streit um die wahre Weltanschauung und das gute Leben erfasst zu werden. Inhaltlich hat dies zur Folge, dass die Begründung des staatlichen Neutralitätsgebotes keine umfassende Theorie sein kann,<sup>1096</sup> sondern sich auf die politische Ordnung und das Verhältnis zwischen Staat und Bürgern beschränken muss. In methodischer Hinsicht führt dies zu der Konsequenz, dass es genügen muss, das Gebot zu erläutern und zu explizieren, auf einen philosophischen Beweis und eine Letztbegründung im kantianischen Sinne aber zu verzichten. Eine Verknüpfung mit anerkannten normativen Ideen und intuitiven

<sup>1091</sup> *Rawls*, Eine Theorie der Gerechtigkeit, S. 160.

<sup>1092</sup> Kritisch *Ackermann*, Journal of Philosophy 91 (1994), 364 (367 ff.).

<sup>1093</sup> *Rawls*, Eine Theorie der Gerechtigkeit, S. 158 f.; *Huster*, Ethische Neutralität, S. 74 f.

<sup>1094</sup> *Huster*, Ethische Neutralität, S. 75 f.

<sup>1095</sup> Vergleiche auch *Huster*, Ethische Neutralität, S. 80; *Ackermann*, Journal of Philosophy 91 (1994), 364 (365 f.).

<sup>1096</sup> *Ackermann*, Journal of Philosophy 91 (1994), 364 (366); *Pogge*, John Rawls, S. 171 f.; *Larmore*, Politischer Liberalismus, S. 133.

grundlegenden Gedanken soll reichen und die grundsätzlich gegebene Möglichkeit, dass es eine andere einheitliche Konzeption als die *Rawls'* denkbar ist, nicht davon abhalten, aktuell einer Gerechtigkeitskonzeption zu folgen und an ihr unsere Entscheidungen zu bemessen, die wir für den Moment als die überzeugendste erachten.<sup>1097</sup>

*(a) Normenlegitimierende Wirkung von Rechtfertigung und Zustimmung*

Im Hinblick auf die Begründungsfähigkeit politischer Maßnahmen und staatlichen Handelns stellt sich so ein Rechtfertigungsprinzip dar, welches moderne politische Ordnungen gemein haben und demzufolge sowohl diese selbst als auch ihre einzelnen Maßnahmen jedermann gegenüber begründungs- und rechtfertigungsfähig sein müssen. Legitimitätsstiftend wirkt also alleine die Zustimmung der Betroffenen, nicht mehr die Gnade Gottes. Auch auf politischem Feld ist diese allgemeine Rechtfertigungsmöglichkeit wesentlich, was bereits die Ausgestaltung unseres Gemeinwesens als ein demokratisches bedingt. Wenn Entscheidungen aber auch mehrheitlich getroffen werden, sind sie dennoch an verfassungsrechtliche Grundverpflichtungen gebunden. Entsprechend sind die Freiheiten auch der Minderheiten als Teil des Gemeinwohls zu wahren. Nur dann ist noch freie Selbstbestimmung gewährleistet und Verbindlichkeit allen gegenüber gerechtfertigt. Dabei liegt dem politischen Liberalismus weder ein ethischer Relativismus noch ein Skeptizismus zugrunde: Es wird nicht bestritten, dass es eine wahre Konzeption des Guten geben mag und es wird auch nicht die Erkennbarkeit dieser Konzeption verneint. Zentrale These ist aber, dass diese partikularen Vorstellungen des Guten nicht so dargestellt und erklärt werden können, dass sie allen einsichtig und somit Grundlage staatlichen Handelns sein können.<sup>1098</sup>

Dabei lässt sich gerade dies als die prozedurale Seite der normativen Moderne bezeichnen, welche im Rahmen eines Säkularisierungsprozesses dem Einzelnen ein Recht darauf zuerkannt hat, dass sich Normen ihm gegenüber mit „*reziprok-allgemeinen Argumenten*“ rechtfertigen lassen. Religiöse und somit notwendigerweise partikulare Rechtfertigungsansätze scheiden somit von Anfang an aus.<sup>1099</sup> Umso mehr muss dieser Grundsatz der Normenbegründung im Hinblick auf strafrechtliche Normen gelten, als deren Eingriff von besonderer Schwere ist und sich somit einem besonderen Rechtfertigungsdruck ausgesetzt sieht.<sup>1100</sup>

Neutralität dient im Anschluss daran auch hier, wie bei den *modus vivendi*-Ansätzen, der Integration und Stabilisierung eines Gemeinwesens. Dies wird aber nicht über eine reine Kraftverteilung (Verhinderung von Aufständen etc.) erreicht, sondern dadurch normativ implementiert, dass die Bürger erkennen, dass der Staat unterschiedliche ethische Überzeugungen respektiert und als gleichberechtigt an-

<sup>1097</sup> Pogge, John Rawls, S. 171 f.

<sup>1098</sup> Huster, Ethische Neutralität, S. 80 ff.; Gutmann, Religiöser Pluralismus und liberaler Verfassungsstaat, S. 298.

<sup>1099</sup> Gutmann, Säkularisierung und Normenbegründung, S. 234.

<sup>1100</sup> Gutmann, Säkularisierung und Normenbegründung, S. 243.



erkennt. Der politische Skeptizismus ist insofern abgeschwächt, als dass der politische Liberalismus nicht eine prinzipiell mögliche Wahrheitsfähigkeit ethischer Überzeugungen bestreitet, sondern diese nur aus den Begründungsressourcen staatlichen Handelns ausklammert, da sie im politischen Kontext keiner hinreichenden Plausibilisierung zugänglich sind. Es wird also nur die politische Wirkung verneint, ohne die verbindliche Wirkung für den Einzelnen anzuzweifeln. Auch die Bedeutung von Autonomie und Individualität, die bereits im Rahmen anderer Konzepte diskutiert wurde, ist im politischen Liberalismus zwar auch zentral, nicht aber ein leitendes Menschheitsideal, an dem ein gutes Leben auszurichten ist, sondern lediglich der politischen Gerechtigkeitskonzeption immanent<sup>1101</sup> und bedingt die Normen des rationalen Dialogs und des gegenseitigen Respekts.<sup>1102</sup>

*(b) Der übergreifende Konsens im Sinne des politischen Liberalismus*

*Rawls* begreift moderne demokratische Gesellschaften parallel hierzu als von vielfältigen religiösen, philosophischen und moralischen, exklusiven, das heißt sich einander ausschließenden, Lehren und Doktrinen gekennzeichnet, die, wenn auch umfassende, gleichwohl vernünftige Lehren sein können, was er als das *Faktum des vernünftigen Pluralismus* bezeichnet.<sup>1103</sup> Der von ihm entwickelte politische Liberalismus versucht, vor dem Hintergrund einer solchen Pluralität vernünftiger Lehren, die nicht ungewollt, sondern lediglich das Resultat menschlichen Vernunftgebrauches ist,<sup>1104</sup> eine politische Gerechtigkeitskonzeption zu erarbeiten, die von allen diesen – wenn ansonsten auch exklusiven – Lehren bejaht werden kann. *Rawls* stellt zu diesem Zweck die Frage: „Wie kann eine stabile und gerechte Gesellschaft freier und gleicher Bürger, die durch vernünftige und gleichwohl einander ausschließende religiöse, philosophische und moralische Lehren einschneidend voneinander getrennt sind, dauerhaft bestehen? [...] Wie können einander zutiefst entgegengesetzte, aber vernünftige umfassende Lehren zusammen bestehen und alle dieselbe politische Konzeption einer konstitutionellen Ordnung bejahen? Wie müssen Struktur und Inhalt einer politischen Konzeption beschaffen sein, damit diese die Unterstützung eines übergreifenden Konsenses für sich gewinnen kann?“<sup>1105</sup> Ziel des politischen Liberalismus ist somit die unparteiliche, das heißt sich inhaltlich mit den vernünftigen Lehren nicht auseinandersetzen- de Offenlegung einer öffentlichen Basis der Rechtfertigung hinsichtlich grundlegender politischer Fragen, das heißt die Ausarbeitung einer politischen Gerechtigkeitskonzeption, die im Schnittpunkt eines übergreifenden Konsenses der von den Bürgern bejahten vernünftigen umfassenden Lehren liegt.<sup>1106</sup> Es soll sich daher um eine Gerechtigkeitskonzeption handeln, der von allen umfassenden, aber vernünftigen Lehren zugestimmt wer-

<sup>1101</sup> *Huster*, Ethische Neutralität, S. 91.

<sup>1102</sup> *Larmore*, Politischer Liberalismus, S. 141 ff.

<sup>1103</sup> *Rawls*, Politischer Liberalismus, S. 12 f.

<sup>1104</sup> *Rawls*, Politischer Liberalismus, S. 13, 22, 119.

<sup>1105</sup> *Rawls*, Politischer Liberalismus, S. 14 f., 67, 119.

<sup>1106</sup> *Rawls*, Politischer Liberalismus, S. 16, 75, 119.

den kann.<sup>1107</sup> Eine wertende Aussage über diese Lehren und insbesondere über ihre Richtigkeit oder Wahrheit enthält der politische Liberalismus als freistehende und ausschließlich politische Konzeption nicht, solange diese Lehren nur vernünftige sind (hierzu sogleich), und überlässt im Übrigen die Ausgestaltung dessen, was über das Politische hinausgeht, den Bürgern, wobei sie dabei durchaus auf ihre rein partikularen Überzeugungen rekurrieren können und dürfen. In dieser Hinsicht ist *Rawls'* politischer Liberalismus im Vergleich zu *Habermas'* Theorie prozeduraler Vorkehrungen eines idealen Diskurses über den politischen Bereich hinaus bei inhaltlicher Auseinandersetzung mit religiösen oder metaphysischen Lehren, was konkret heißt: bei Ablehnung dieser als unbrauchbar und mangelhaft hinsichtlich einer aus ihnen selbst heraus begründbaren Logik, limitierter.<sup>1108</sup>

Bei dem von *Rawls* sogenannten *übergreifenden Konsens* handelt es sich nicht um einen bloßen *modus vivendi*, ein bloßes öffentliches Einverständnis, das die Hoffnung auf eine politische Einheit nur wenig adäquat ersetzt. Anders als bei einem *modus vivendi*, dessen Einhalten für jede der beteiligten Parteien vorteilhaft ist, aber dies nur solange gilt, wie sich die Umstände nicht verändern und so die nur zufällige Konvergenz der Interessen auflöst, besteht im Rahmen des *übergreifenden Konsenses* tatsächlich Einigkeit zumindest hinsichtlich der Ziele. Während der *modus vivendi* also nur eine Form der Toleranz gegenüber etwas, das eigentlich abgelehnt, aber hingenommen wird, weil – aber auch nur solange – es Vorteile bringt, besteht hinsichtlich der im *übergreifenden Konsens* formulierten Ziele tatsächliche Akzeptanz, da diese auch stets die eigenen Ziele sind.<sup>1109</sup> Bedeutend ist dabei, dass zum einen der Inhalt des Konsenses, die herauszuarbeitende politische Gerechtigkeitskonzeption, selbst ein moralischer ist und zum anderen dieser aus ebenfalls moralischen, wenn auch vor unterschiedlichen Überzeugungen gebildeten, so doch aber zur Erreichung derselben, von diesen Überzeugungen unabhängigen Ziele beiträgenden Gründen bejaht wird. Dies bedingt eine größere Stabilität des *übergreifenden Konsenses* als des *modus vivendi*, der von einem Gleichgewicht relativer Kräfte abhängt.<sup>1110</sup>

Die dabei zu berücksichtigenden Überzeugungen als umfassende Lehren sind allerdings stets nur die vernünftigen. Das Vernünftige ist hierbei ein zentraler Begriff, den es zunächst zu beleuchten gilt. *Rawls* zufolge sind Menschen dann vernünftig, wenn sie – erstens – eine soziale und reziproke Welt der Kooperation entlang fairer Bedingungen, die von allen befürwortet werden können, anstreben, die sie um dieser sozialen Welt willen achten und nicht immer dann brechen, wenn dies ihnen auch nur einen kurzfristigen Vorteil verschafft. Vernünftig bedeutet in diesem Sinne nicht rational, denn rational kann jemand auch schon dann handeln, wenn er damit nur die jeweils eigene individuelle und unter Umständen vollkommen partikuläre Konzeption des gelungenen Lebens verwirklichen will. Welche Ziele rationale Menschen verfolgen, ist aufgrund der Tatsache, dass sie rational sind und

<sup>1107</sup> *Rawls*, *Journal of Philosophy* 92 (1995), 132 (133).

<sup>1108</sup> *Rawls*, *Journal of Philosophy* 92 (1995), 132 (135 ff.).

<sup>1109</sup> *Rawls*, *Politischer Liberalismus*, S. 234 f. mit Fn. 13.

<sup>1110</sup> *Rawls*, *Politischer Liberalismus*, S. 236.

handeln, nicht bekannt, sondern nur, dass sie dies auf intelligente Weise tun. Ob die Menschen und ihre Ziele hingegen auch vernünftig sind, das Wohlergehen anderer ebenfalls Berücksichtigung findet und die Grundlagen ihres Handelns argumentativ allen einsichtig gemacht werden könnten, ist damit noch nicht ausgesagt.<sup>1111</sup> Das Prädikat „vernünftig“ setzt nach *Rawls* darüber hinaus auch die Einsicht voraus, dass ein Urteil über den Wahrheitsgehalt einer Lehre nicht getroffen werden kann, und die Erkenntnis der Konsequenz, dass eine solche Lehre daher in der Theorie und dem öffentlichen Diskurs unberücksichtigt bleiben muss. Gerade dieser Umstand, dass die Erkenntnisse unzuverlässig und unzureichend sind, bedingt das *Faktum des vernünftigen Pluralismus*.

*(c) Legitimationsstiftende Rechtfertigung durch Allgemeingültigkeit*

Politische Macht und ihre Ausübung ist vor dem Hintergrund des politischen Liberalismus nur dann angemessen und legitim, wenn sie mit einer Verfassung übereinstimmt, von der vernünftigerweise erwartet werden kann, dass alle Bürger ihr vor dem Hintergrund ihrer wenn auch unterschiedlichen und exklusiven, so doch aber vernünftigen Überzeugungen zustimmen. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Verfassungsstruktur als auch im Hinblick auf die einzelnen Gesetze. Dem liberalen Legitimitätsprinzip zufolge darf eine vernünftige politische Konzeption nur diese Kriterien erfüllende Verfassungen rechtfertigen. Öffentliche Rechtfertigung und öffentliche Vernunft basieren auf einer Gerechtigkeitskonzeption, der alle Bürger mit konfligierenden, aber vernünftigen metaphysischen und/oder religiösen Überzeugungen zustimmen und sie als regulierende und formgebende Basis ihrer Gesellschaft akzeptieren können.<sup>1112</sup> Daher sind individuelle religiöse oder moralische Vorstellungen und Glaubenssätze zur Begründung oder Rechtfertigung eines modernen liberalen Staates oder dessen staatlicher Maßnahmen und insbesondere dessen Legislative nicht zugelassen. Legitimität wird hier dadurch gesichert, dass diese bestimmten Werte aus der Gruppe der zulässigen Gründe ausgeschlossen werden.<sup>1113</sup> Dies muss umso mehr gelten, wenn Freiheitsrechte einschränkende Gesetze und insbesondere Strafgesetze betroffen sind.<sup>1114</sup> Da extensive Interpretationen der Menschenwürde als Gattungswürde, die über einen nur ganz basalen Kern dessen, was ein menschliches Leben gelungen macht, hinausgehen, wie dargelegt auf metaphysischen oder theologischen Vorstellungen beruhen, dürfen diese (alleine) für die Legislative nicht instruktiv sein.

<sup>1111</sup> *Rawls*, Politischer Liberalismus, S. 120 ff.

<sup>1112</sup> *Rawls*, Politischer Liberalismus, S. 43 f., 223. *Freeman*, Philosophy & Public Affairs 2000, S. 396 ff. sieht den Umstand, dass Gründe, welche er als „*public reason*“ bezeichnet und worunter er solche Erwägungen versteht, die auf allgemein verständlichen Prämissen beruhen, die freiheits-einschränkende staatliche Macht – die ja vom Volke ausgeht – auch dem umfassenden Volk gegenüber zu rechtfertigen in der Lage sind, als konstitutiv für deliberative Demokratien an.

<sup>1113</sup> *Nagel*, Gleichheit und Parteilichkeit, S. 215.

<sup>1114</sup> *Gutmann*, „Gattungsethik“ als Grenze der Verfügung des Menschen über sich selbst?, S. 235 f.

Aufgrund der Erkenntnis des *Faktums eines vernünftigen Pluralismus* und der damit einhergehenden Einsicht, dass eine Konfrontation dieser, wenn auch vernünftigen, so doch aber umfassenden Lehren mit einer ebenfalls umfassenden liberalen philosophischen Lehre nicht erfolgversprechend ist, erarbeitet Rawls eine freistehende, keiner umfassenden Lehre entgegenstehende politische Konzeption, die mittels eines übergreifenden Konsenses stabilisiert wird.<sup>1115</sup> Rawls' politischer Liberalismus enthält daher keine metaphysische oder erkenntnistheoretische Lehre, sondern beruht alleine auf dem, was von der politischen Konzeption selbst vorausgesetzt wird.<sup>1116</sup>

Dass Bürger in ihren eigenen privaten Entscheidungen und der jeweils gewählten Lebensform ihren eigenen und jeweils exklusiven umfassenden Lehren folgen, ist eine Sache. Inwieweit sie sich aber im Rahmen einer öffentlichen Begründung hierauf stützen dürfen, ist hingegen eine ganz andere Frage. Rawls hat schließlich konstatiert, dass diese Lehren, solange sie nur vernünftig sind, jederzeit herangezogen werden könnten unter dem Vorbehalt (Rawls: „*proviso*“), dass sie zeitnah durch eine öffentliche Begründung einer vernünftigen politischen Konzeption zu ergänzen sind. Er versteht dies als weite Sichtweise des öffentlichen Vernunftgebrauchs.<sup>1117</sup>

Öffentlich- und insbesondere verfassungsrechtlich kommt diesen Grundlegungen in der Bundesrepublik Deutschland eine besondere Bedeutung zu. So besteht im Rechtsstaat nicht nur hinsichtlich der einzelnen Maßnahme das Erfordernis der Begründungsfähigkeit, sondern vielmehr stellt die moderne politische Ordnung an sich selbst den Anspruch, darüber hinaus in ihrer Existenz gegenüber jedermann begründungs- und rechtfertigungsfähig zu sein.<sup>1118</sup> Die Herausforderung hierbei liegt in dem Pluralismus der Lebenskonzeptionen begründet, bei dem es sich um eine nahezu konstitutive Eigenschaft moderner Gesellschaften handelt<sup>1119</sup> und der ein enormes Konfliktpotential in sich birgt. Die Neutralität stellt somit ein Konzept zur Bewältigung des weltanschaulichen Pluralismus dar, dessen unterschiedlichen Überzeugungen nur allzu häufig einen Universalitätsanspruch erheben und deren Träger diese nicht nur zur Beantwortung der Frage, wie *sie* selbst ihr Leben führen *wollen*, heranziehen, sondern zugleich präskriptive Äußerungen darüber, wie *man* sein Leben führen *soll*, tätigen.<sup>1120</sup>

Seit der Entkoppelung des politischen Ordnungssystems und staatlicher Machtlegitimation von Religion und anderen partikularen Überzeugungen ist die Frage der Weltanschauung und der Lebensführung, zwischen denen ein unmittelbarer Zusammenhang besteht, da die Art und Weise, wie jemand sein Leben gestaltet, davon abhängt, worin er dessen Sinn sieht und welche Werte ihn in seinen Beurteilungen leiten,<sup>1121</sup> in die individuelle Freiheit des Einzelnen entlassen. Folge

<sup>1115</sup> Rawls, Politischer Liberalismus, S. 45, 77 f.

<sup>1116</sup> Rawls, Politischer Liberalismus, S. 75, 78.

<sup>1117</sup> Rawls, Politischer Liberalismus, S. 50 f.

<sup>1118</sup> Huster, Die ethische Neutralität des Staates, S. 85.

<sup>1119</sup> Huster, Die ethische Neutralität des Staates, S. 5.

<sup>1120</sup> Huster, Die ethische Neutralität des Staates, S. 21.

<sup>1121</sup> Huster, Die ethische Neutralität des Staates, S. 6, 10 f.

dessen ist sodann aber konsequenterweise, dass ein Eingriff in diese Freiheit nicht mit der Begründung, seine weltanschauliche Auffassung sei falsch und die darin gründende Lebensführung verfehlt, gerechtfertigt werden kann. Dem freiheitlichen Verfassungsstaat ist es daher alleine unbenommen, eine Ordnung für das gerechte und friedliche Zusammenleben zwischen den Vertretern der widerstreitenden Überzeugungen zu schaffen und dabei auf die Bewertung dieser unterschiedlichen Konzeptionen des Guten zu verzichten, von denen er sich emanzipiert hat und denen gegenüber er verpflichtet ist, diese gleich und gerecht zu behandeln. Eine solche religiös-weltanschauliche und ethische Neutralität des Staates bedingt zugleich die bestmögliche Gewährleistung der Freiheitsrechte des Einzelnen und trägt den Vorschriften der Art. 4 I, 3 III und 33 III GG sowie des Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 136 I, IV, 137 I WRV Rechnung.<sup>1122</sup>

*(d) Demokratische Mehrheitsentscheidungen und ihre Grenzen*

Die moderne Demokratie sucht vor dem Hintergrund, dass die religiös oder anderweitig weltanschaulich begründeten Divergenzen und die damit verbundenen Konflikte der Freiheitssphären der Akteure sich „nicht im Zustand prästablierter Harmonie befinde[n]“<sup>1123</sup>, und angesichts der oben beschriebenen Notwendigkeit des regulierenden Einsatzes eines staatlichen „Dompteurs“<sup>1124</sup> diese Koordinierungsaufgabe durch den Erlass allgemeiner und für alle geltender Gesetze zu erfüllen.<sup>1125</sup> Diese wiederum werden entweder unmittelbar vom Volk durch Volksbegehren und -Entscheide oder vom durch das Volk gewählten Land- und Bundestag und somit, wenn auch nur mittelbar, ebenfalls vom Volk beschlossen. In jedem Fall aber findet darin – auch wenn der ein oder andere Stammtisch dies anders beurteilen mag – der Wille des Volkes seinen Ausdruck. Dabei fällt die individuelle Entscheidung des sich an der jeweiligen Wahl beteiligenden Bürgers und auch des abstimmenden Parlamentariers nach ganz unterschiedlichen Präferenzen und zwar auch nach solchen, die nicht altruistisch, sondern egoistisch motiviert sind, denen keine hohen moralischen Werte, sondern berechnende Interessesstrategien zugrunde liegen oder die nicht von jedermann geteilt werden können, weil sie partikular religiös geprägt sind. Die Stimmen zählen im demokratischen Entscheidungs- und Wahlsystem gleichviel. Gleichzeitig aber fällt die Entscheidung in der Sache, das heißt in der Frage, über die abgestimmt wird, aber nach dem Mehrheitsprinzip, auch wenn das bedeutet, dass ein Gesetz beschlossen wird, das eindeutig die Interessen eines bestimmten Klientel oder einer bestimmten Lobby bedient. Zumindest die Autonomie der Mehrheit ist so gewährleistet, indem sich, so *John Locke*, die staatliche

<sup>1122</sup> *Huster*, Die ethische Neutralität des Staates, S. 11 f., 43.

<sup>1123</sup> *Dreier*, Bioethik zwischen gesellschaftlicher Pluralität und staatlicher Neutralität, S. 8 (Ergänzungen Welling).

<sup>1124</sup> *Gutmann*, Religiöser Pluralismus und liberaler Verfassungsstaat, S. 291.

<sup>1125</sup> *Dreier*, Bioethik zwischen gesellschaftlicher Pluralität und staatlicher Neutralität, S. 8.

Gemeinschaft als ein Körper „*notwendigerweise dahin bewege[t], wohin die stärkste Kraft ihn treibt. Und eben das ist die Übereinstimmung der Mehrheit.*“<sup>1126</sup>

*(aa) Verfassungsrechtlicher Minderheitenschutz*

Die bloße demokratische Mehrheitsentscheidung ist im Rahmen einer politisch-liberalen Konzeption jedoch keine für die Legitimität von für alle Bürger verbindlichen Normen hinreichende Bedingung. Vielmehr unterliegt auch die Legislative den Schranken der Verfassung, vergleiche Art. 1 III GG. Aufgrund dieses Regulariums genügt die bloß zahlenmäßige Erfassung nach dem Mehrheitsprinzip nicht<sup>1127</sup>; darüber hinaus bedarf es auch der Umsetzung der Direktiven, die die Verfassung enthält, mithin also insbesondere der Wahrung der Grundrechte und der Rechtfertigung von Grundrechtseingriffen, zum Zwecke ihrer in Summe größtmöglichen Realisierung und Kompatibilisierung.<sup>1128</sup> In diesem Zusammenhang wiederum kommt der ethischen Neutralität insofern eine bedeutende Rolle zu, als dass im Rahmen der Rechtfertigung von Freiheitseinschränkungen aller die dazu herangezogenen Gründe dann nicht valide sind, wenn sie lediglich den Anschauungen und Glaubenssätzen einiger weniger entsprechen. Daher muss eine Rechtsnorm stets ohne Rückgriffe auf partikuläre Überzeugungen begründet oder zumindest begründbar sein. Das bedeutet allerdings keine inhaltliche Leere. Materiell mag es durchaus sein, dass einer Norm kausalgenetisch auch durch einen Wirkfaktor religiöser Art motiviert ist. Gleichwohl darf sich der Staat als negative Kehrseite der Religions- und Weltanschauungsfreiheit nicht mit einer Religion oder Weltanschauung identifizieren und sich bei der Begründung einer Rechtsnorm auf religiös-weltanschauliche oder anderweitig partikuläre Grundsätze stützen.<sup>1129</sup> Der Staat des Grundgesetzes ist daher kein christlicher, sondern als „*Heimstaat aller Staatsbürger*“<sup>1130</sup> gleich welcher Religion oder Weltanschauung ein säkularer.

*(bb) Freiheit des Mandats versus ethische Neutralität des Staates*

Welches konkrete, in der praktischen Umsetzung einzuhaltende Maß folgt daraus aber nun für den Akt der Gesetzesbegründung, welche im Regelfall vom Landtag oder Bundestag vorgenommen wird? Diese Frage stellt sich nicht nur hinsichtlich der Begründung selbst, sondern auch mit Blick auf den einzelnen Abgeordneten. Vom verfassungsrechtlichen Standpunkt aus ist dies recht eindeutig zu beantwor-

<sup>1126</sup> Dreier, Bioethik zwischen gesellschaftlicher Pluralität und staatlicher Neutralität, S. 8 f.; Locke, The Second Treatise of Government, S. 156/157 (Ergänzungen Welling), im englischen Original: „[...] it is necessary the Body should move that way whither the greater force carries it [...]“.

<sup>1127</sup> Nagel, Gleichheit und Parteilichkeit, S. 218 zufolge gebietet der jeweiligen Majorität schon die Klugheit, davon Abstand zu nehmen, anderen die eigene Konzeption des Guten aufzudrängen, da sie nur dann nach einem zukünftigen Verlust ihres Einflusses auf einen ebenfalls moderaten Umgang mit sich hoffen dürften.

<sup>1128</sup> Dreier, Bioethik zwischen gesellschaftlicher Pluralität und staatlicher Neutralität, S. 10 f.

<sup>1129</sup> Dreier, Bioethik zwischen gesellschaftlicher Pluralität und staatlicher Neutralität, S. 11 f.

<sup>1130</sup> BVerfGE 19, 206 (216); 108, 282 (299).



ten, denn der Abgeordnete gibt seine Grundrechte nicht beim Betreten an der Tür des Land- oder Bundestages ab. Er bleibt weiterhin grundrechtsberechtigt, auch wenn sich für den Fall, dass er gerade seinen verfassungsrechtlichen Status gegen Verfassungsorgane geltend macht, Besonderheiten ergeben. Aus der Freiheit des Mandats gemäß Art. 38 I 2 GG folgt, dass der Abgeordnete an Weisungen und Aufträge nicht gebunden und nur seinem Gewissen unterliegt. Entsprechend ist es ihm unbenommen, sich auch in seinem Abstimmungsverhalten nach seinen subjektiven Überzeugungen und Ansichten zu richten, auch wenn diese partikular sein mögen.<sup>1131</sup> Hierfür spricht auch der Umstand, dass ein Abgeordneter unter Umständen ja gerade aufgrund dieser spezifisch religiösen oder weltanschaulichen Haltung und Bereitschaft zu einem dieser entsprechenden Abstimmungsverhalten gewählt worden ist und es so dem Willen eines ausreichend großen Teils des Volkes entspricht, dass auch diesen Motiven Rechnung getragen wird. Eine darüber hinausgehende, strengere Verhaltensvorschrift kann somit keinen rechtlich-verbindlichen Charakter haben, sondern nur moralische<sup>1132</sup> Verpflichtungen hervorbringen.

Mit ebendiesem Anspruch fordert *Rawls* aber, wenn auch unter Anerkennung, dass hiervon die persönlichen Gedanken und Überlegungen sowie sogar Beratungen unter Mitgliedern von Vereinigungen wie Kirchen oder Universitäten nicht betroffen sein können und dort religiöse, philosophische und moralische Überzeugungen legitimer Weise eine Rolle spielen, hingegen für das Forum der Öffentlichkeit und der politischen Stellungnahme in diesem Forum die Beachtung des Ideals des öffentlichen Vernunftgebrauches. Bedingt durch die Annahmen, dass zum einen die Gesellschaft durch Beziehungen zwischen Personen konstituiert wird, die in diese hineingeboren werden und sodann in ihr bis zu ihrem Tod verbleiben, sowie zum anderen, dass in einer Demokratie politische Macht immer die Macht der Öffentlichkeit und damit der Gesamtheit aller freien und gleichen Bürger ist, verlangt *Rawls*, dass diese Macht in einer Art und Weise zu gebrauchen ist, dass ihre Ausübung gegenüber den anderen, ebenfalls freien und gleichen Mitgliedern der Gesellschaft gerechtfertigt werden kann. Dies ist jedoch nur möglich, wenn das liberale Legitimitätsprinzip beachtet wird, das heißt, wenn sich die Ausübung im Rahmen einer Verfassung verhält, von der man vernünftigerweise annehmen kann, dass sie alle Bürger im Lichte jedweder von ihnen bejahter Grundsätze annehmen können.<sup>1133</sup>

### *(cc) Public justification*

Hieraus folgt unmittelbar die Anforderung der *public justification*, des Erfordernisses öffentlicher Gründe: „Der weltanschaulich neutrale Staat, der seine Bürger mit gleicher Rücksicht und gleichem Respekt zu behandeln hat, muss sich auf Gründe beschränken, die im Prinzip jedermann diskursiv einsichtig gemacht werden kön-

<sup>1131</sup> So auch *Dreier*, Bioethik zwischen gesellschaftlicher Pluralität und staatlicher Neutralität, S. 13.

<sup>1132</sup> So auch *Rawls*, Politischer Liberalismus, S. 317.

<sup>1133</sup> *Rawls*, Politischer Liberalismus, S. 315 f.



nen. Selbst Majoritäten wäre es deshalb versagt, die normsetzende Staatsgewalt zum Agenten einer nur religiös zu begründenden Rechtspolitik zu machen.<sup>1134</sup> Das Prinzip der *public justification* erfüllt somit zugleich die Funktion einer Legitimationsgrenze des Mehrheitsprinzips und einer Sicherung vor einer Umwandlung einer Mehrheitsherrschaft in Repression für den Fall, dass der Nachvollzug einer Rechtfertigung von Normen der säkularen oder anders-religiösen Minderheit aufgrund einer religiösen Argumentation der Majorität unmöglich wird.<sup>1135</sup>

Darüber hinaus will Rawls den öffentlichen Vernunftgebrauch aber auch von allen Bürgern in einer Demokratie gewahrt wissen. Dies begründet er damit, dass diese, wenn sie abstimmen, sich ebenfalls an der politischen Zwangsgewalt beteiligen und daher ihr Stimmverhalten zu rechtfertigen haben. Aufgrund der Freiheit und Gleichheit der Bürger muss ein jeder vernünftigerweise mit deren Zustimmung zu den Grundlagen seines Tuns rechnen können.<sup>1136</sup> Darüber hinaus verlangt Rawls auch von den Bürgern, dass sie die säkularen Grundlagen des Rechtsstaates nicht nur anerkennen, sondern dies auch aus den richtigen, das heißt konkret: säkularen, Gründen tun. Dass, wie oben beschrieben, dies auch aufgrund ihrer vernünftigen religiösen Überzeugungen möglich wäre, ist sodann keine Frage der Normenbegründung, sondern der Stabilität der zuvor gefundenen Normen.<sup>1137</sup>

Hiermit ist die *public justification* als Säkularisierung der Normenbegründung die *conditio sine qua non* für die Bewältigung religiöser Pluralität und die Antwort auf die Frage, wie „eine [...] Gesellschaft freier und gleicher Bürger, die durch [inkompatible] religiöse, philosophische und moralische Lehren getrennt sind“, in eine stabile konstitutionelle Ordnung integriert werden können.<sup>1138</sup> Die weltanschauliche Vielfalt ist für eine Rechtsordnung, die dem Einzelnen Freiheitsbereiche belässt und ihm eine individuelle Lebensführung und Persönlichkeitsentwicklung zuerkennt, systemgewollt und programmatisch. Entsprechend ist dem aber auch im Rahmen der Normenbegründung Rechnung zu tragen, bei der sodann auch keine umfassende Lehre einen Anspruch auf hegemoniale Wahrheit erheben kann, und zu berücksichtigen, dass Rechtsnormen mit allgemeinem, das heißt sich nicht auf eine sich durch eine homogene Weltanschauung auszeichnende Gruppe beschränkendem Geltungsanspruch nicht legitim unter Rückgriff auf eine partikuläre Vorstellung des Guten begründet werden können, wenn hierüber angesichts des Faktums des Pluralismus Dissens besteht und ein dauerhaftes gemeinsames Verständnis einer umfassenden Lehre nur durch den repressiven Gebrauch von Staatsmacht – mehr oder weniger stabil – erzeugt werden kann.<sup>1139</sup>

<sup>1134</sup> Gutmann, Säkularisierung und Normenbegründung, S. 244; Gutmann, Religiöser Pluralismus und liberaler Verfassungsstaat, S. 295.

<sup>1135</sup> Gutmann, Religiöser Pluralismus und liberaler Verfassungsstaat, S. 295; vergleiche auch Nagel, Gleichheit und Parteilichkeit, S. 218.

<sup>1136</sup> Rawls, Politischer Liberalismus, S. 318.

<sup>1137</sup> Gutmann, Religiöser Pluralismus und liberaler Verfassungsstaat, S. 297.

<sup>1138</sup> Gutmann, Säkularisierung und Normenbegründung, S. 245; Rawls, Politischer Liberalismus, S. 14.

<sup>1139</sup> Rawls, Politischer Liberalismus, S. 107; Gutmann, Religiöser Pluralismus und liberaler Verfassungsstaat, S. 297.

## IV. Fazit

Wie gezeigt, beruhen Konzepte einer menschlichen Würde als einer Würde der Gattung selbst oder einer umfassenden Heiligkeit und daher weitreichenden Unantastbarkeit der menschlichen Natur, die über den ganz basalen und zentralen Kern dessen, was den Menschen ausmacht beziehungsweise als Bestandteil eines guten menschlichen Lebens gezählt werden kann, entweder unmittelbar oder zumindest ihren Grundannahmen zufolge, auf umfassenden religiösen, metaphysischen oder zumindest anderweitig partikularen Überzeugungen, die dem bloßen Faktum des natürlichen, kontingenterweise vorkommenden Seins einen diesem ansonsten nicht zukommenden normativen Anspruch verleihen. Dass dies jedoch mit den Grundsätzen eines liberalen Verfassungsstaates nicht vereinbar ist, ist nunmehr deutlich geworden.

Mitglieder moderner und liberaler Gesellschaften stimmen schon in den basalen Fragen der guten Lebensweise und ihrer weltanschaulichen Orientierung nicht mehr überein. „*Inkompatible Wahrheitsansprüche, Glaubenssätze, Überzeugungen und Lebensformen stehen in der fragmentarischen Moderne nebeneinander und gegeneinander.*“<sup>1140</sup> Es obliegt einem jeden selbst, die je individuelle Lebensführung und -form zu bestimmen. Eine Gesellschaft wird dann als eine im modernen Sinne pluralistische bezeichnet, wenn nicht bestimmten Ideologien Vorrang gegenüber anderen eingeräumt wird, die hingegen als gescheitert oder defizitär abgetan werden.<sup>1141</sup> Anders als politische Ordnungen, die ihre Legitimation auf religiöse oder weltanschauliche Prämissen stützen, weswegen sie auf eine äquivalente ethische Homogenität angewiesen sind und davon abweichende Überzeugungen nicht zulassen (können), identifizieren sich modern-liberale Staaten nicht mehr mit einer bestimmten Religion oder Weltanschauung.<sup>1142</sup> In solchen politischen Ordnungen schafft das Recht zunächst einmal nur die ein friedliches Zusammenleben der Bürger sichernden Rahmenbedingungen, die allen Bürgern gegenüber Geltung beanspruchen und von allen akzeptiert werden müssen, dies aber auch können, da sie sich zu ihrer Begründung und Legitimation nicht auf ethische Vorentscheidungen beziehen, sondern einen gerechten Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Überzeugungen und Lebensformen gewährleisten. Im Gegensatz zu dem, was als das Rechte bezeichnet werden kann, verbleibt die Entscheidung darüber, wie die Freiheiten, die innerhalb dieser Rahmenbedingungen gewährt werden, genutzt werden sollen, bei dem einzelnen Bürger selbst, der sie vor dem Hintergrund seiner individuellen Konzeption eines guten Lebens oder des Guten frei ausgestalten kann.<sup>1143</sup>

In Konsequenz dessen müssen diese partikularen Überzeugungen aber, um eben diese Freiheit auch den anderen freien und gleichen Menschen zu belassen, bei der Begründung von Rechtsnormen unbeachtet bleiben. Alleine sie heranzuziehen, um

<sup>1140</sup> Dreier, Bioethik, S. 85.

<sup>1141</sup> Huster, Die ethische Neutralität des Staates, S. 5–8.

<sup>1142</sup> Huster, Die ethische Neutralität des Staates, S. 10.

<sup>1143</sup> Huster, Die ethische Neutralität des Staates, S. 11.

die Freiheit anderer einzuschränken, die diese Überzeugungen nicht teilen und die eine (alleine) hierauf beruhende Rechtfertigung einer Freiheitsbeschränkung daher nicht nachvollziehen können, ist somit unzulässig. Und dies gilt unabhängig davon, ob man auf historische Aspekte oder machtpolitische Klugheit, den ethischen Liberalismus, Autonomieerwägungen, persönlichkeitsidealistische Konzeptionen oder zuvorderst auf eine gerechtigkeitstheoretische, politisch liberale Begründung rekurriert.

Alleinig valide Argumente, die eine Unverfügbarkeit der Natürlichkeit des menschlichen Genoms begründen, die sich dabei jedoch im Rahmen einer säkularen, religiös „neutralen“ Rechtsordnung als rechtliche formulieren lassen, vermögen jedoch nicht zu überzeugen. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen zeigt sich hier, dass die freiheitliche Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland keine normativen Ressourcen bereithält, mithilfe derer es gelingen würde, verbessernde Eingriffe in das menschliche Genom als schlechthin verboten zu klassifizieren und dem demokratischen Gesetzgeber eine andere Regelung als deren Verbot zu untersagen. Auch Art. 1 I GG vermag aus den genannten Erwägungen kein anderes Ergebnis zu begründen. Dies bestärkt die Vermutung, dass freiheitliche Rechtsordnungen auch mit Blick auf Eingriffe in das menschliche Genom auf Permissivität „programmiert“ zu sein scheinen.

Es kann daher konstatiert werden, dass die Begründungsressourcen des säkularen Rechtsstaates im Fall der verbessernden Humangenetik an ihre Grenzen stoßen: Kategorische, das heißt auch den demokratischen Gesetzgeber bindende Grenzen lassen sich ohne den Rückgriff auf religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, deren Übersetzung in eine für alle Bürger nachvollziehbare Argumentation jedoch versagt bleibt, nicht begründen. Die weltanschauliche Begründungsneutralität des Staates, die religiöse und anderweitig transzendente Gehalte als Begründungsressourcen für Rechtsnormen sperrt, verhindert somit in Übereinstimmung mit den Prinzipien des politischen Liberalismus die Begründung kategorischer Verbote im Hinblick auf genverbessernde Eingriffe. Verfassungsrechtlich steht es damit dem Gesetzgeber zu, genetische Enhancements grundsätzlich, gegebenenfalls eingeschränkt, zu erlauben.

Damit einher geht, dass es dem Staat lediglich offensteht, ein ethisches Minimum zu gewährleisten.<sup>1144</sup> Das Individuum mag sich dabei allerdings der Frustration und Empörung darüber ausgesetzt sehen, dass andere „*die eigenen Grundüberzeugungen in für den Jeweiligen irritierender, anstößiger, verstörender und die eigenen Gefühls- und Vorstellungswelt verletzender Weise*“ missachten und sich diesen zuwider – jedoch unter Umständen ihren eigenen entsprechend – verhalten. Anhand dieser Thematik und dem gefundenen Ergebnis wird die Befindlichkeit einer pluralen Gesellschaft, die von unterschiedlichen Werthaltungen geprägt ist, als mitunter zerrissen offenbar.<sup>1145</sup> Die plurale Gesellschaft gestaltet sich für die individuellen

<sup>1144</sup> Dreier, Bioethik, S. 86.

<sup>1145</sup> Dreier, Bioethik, S. 85.

Überzeugungen und Wertvorstellungen daher möglicherweise als Zumutung und die Rechtslage, gemessen an subjektiven und partikular geeichten Bewertungsmaßstäben, unter Umständen als unerträglich.

Letztendlich ist dies aber hinzunehmen und sogar Ausdruck der Gewährleistungen und Vorteile der teils im Grundgesetz verankerten, teils als eine transzendente Legitimitätsvoraussetzung des seine Bürger als Gleiche behandelnden Rechtsstaats fungierenden Prinzipien des politischen Liberalismus und der Neutralität des Staates einer freiheitlichen Gesellschaft. Der Umstand, dass der politische Liberalismus partikular motivierten Argumenten als einzige, die im Hinblick auf genetische Enhancements kategorische Aussagen zu treffen vermögen, ihre Wirksamkeit im Rahmen der Begründung allgemein geltender Rechtsnormen abspricht, stellt auch keine Schwäche des politischen Liberalismus dar. Nur durch die so geschaffene Trennung von Recht und Moral kann es gelingen, in einer Gesellschaft, in der divergierende ethische Präferenzen herrschen, eine gemeinsame stabilisierende Basis, sei es nun als *modus vivendi* oder in der Form eines übergreifenden Konsenses, zu erreichen.<sup>1146</sup>

Mag das Wissen um Verhaltensweisen, die den eigenen Wertvorstellungen diametral gegenüberstehen, das religiöse Bewusstsein auch stressen. Dies auszuhalten ermöglicht gerade die am politischen Liberalismus orientierte ethische Begründungsneutralität des Staates, die alleine gewährleistet, dass jeder vorbehaltlich schützenswürdiger Interessen Dritter seinen eigenen Vorstellungen folgen und sein Leben diesen entsprechend ausgestalten darf. Indem der Staat nicht mehr als ein ethisches Minimum gewährleistet, bietet er seinen Bürgern die Möglichkeit individueller Freiheitsausübung und so der Vermeidung höchstpersönlicher Gewissenskonflikte.

In die Praxis der Gesetzgebung übersetzt stellt dies sodann, da eine von Verfassungen wegen vorgegebene Antwort auf die Frage der Zulässigkeit genetischer Enhancements nicht existiert, vor dem Hintergrund der verbleibenden Verhandlungbarkeit eine Anregung zur politischen Deliberation dar. Dem Prozess dieser obliegt es, auszuhandeln, ob genverbessernde Techniken angewendet werden dürfen oder nicht. Da demokratische Entscheidungen jedoch auf sich stets verändernden Mehrheiten beruhen, können sie selbst nur temporärer Natur und dem Wandel unterworfen sein, sobald sich die politischen Kräfte verändern. Eine gewisse Frustration des religiösen Bewusstseins ist wahrscheinlich, es darf aber mit guten Gründen eine Anerkennung des vernünftigen Pluralismus mit den daraus resultierenden Konsequenzen erwartet werden.

---

<sup>1146</sup> Vgl. Dreier, Bioethik, S. 86.

# Literatur

- Ach, Johann S.*, Enhancement, in: Bohlken, Eike/Thies, Christian (Hrsg.), Handbuch Anthropologie – Der Mensch zwischen Natur, Kultur und Technik, Verlag J.B. Metzler, Stuttgart 2009
- Ackermann, Bruce*, Political Liberalisms, *The Journal of Philosophy*, Vol. 91, No. 7 (July 1994), S. 364–386
- Adomeit, Klaus/Mohr, Jochen*, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), 2. Auflage, Richard Boorberg Verlag, Stuttgart 2011
- Alexy, Robert*, Theorie der Grundrechte, Reihe: suhrkamp taschenbuch wissenschaft, Band 582, 3. Auflage, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1996 (zit.: Alexy, Theorie der Grundrechte (a))
- Alexy, Robert*, Theorie der Grundrechte, Reihe: Studien und Materialien zur Verfassungsgerichtsbarkeit (Hrsg.: Starck, Christian), Band 28, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2006 (zit.: Alexy, Theorie der Grundrechte (b))
- Allhoff, Fritz*, Germ-Line Genetic Enhancement and Rawlsian Primary Goods, *Journal of Evolution and Technology*, Vol. 18 Issue 1 (May 2008), S. 10–26
- Alternativkommentar zum Grundgesetz*: siehe Wassermann
- Anderson, W. French*, Prospects for Human Gene Therapy, in: *Science*, Vol. 226, No. 4673 (October 1984), S. 401–409
- ders.*, Human Gene Therapy: Scientific and Ethical Considerations, in: *The Journal of Medicine and Philosophy*, Vol. 10 Issue 3 (August 1985), S. 275–291
- ders.*, Genetics and Human Malleability, in: *Hastings Center Report*, Vol. 20, No. 1 (January–February 1990), S. 21–24
- Arbeitsgruppe „In-vitro-Fertilisation“*: siehe Bundesminister für Forschung und Technologie
- Aristoteles*, Politik, übersetzt von Gigon, Olof (Hrsg.), Reihe: Literatur Philosophie Wissenschaft, 4. Auflage, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1996
- ders.*, Nikomachische Ethik, übersetzt von Wolf, Ursula (Hrsg.), Reihe: rowohlt's enzyklopädie, Rowohlt's Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 2008
- Ashley-Koch, A./Yang, Q./Olney, R. S.*, Sickie Hemoglobin (Hb S) Allele and Sickie Cell Disease: A HuGE Review, *American Journal of Epidemiology*, Vol. 151 (2000), No. 9, S. 839–845
- Badura, Peter*, Generalprävention und Würde des Menschen, *Juristenzeitung* 1964, S. 337–344
- Bamberger, Heinz Georg/Roth, Herbert*, Beck'scher Online-Kommentar BGB, Stand: 1. Mai 2012, Edition: 23, Verlag C.H. Beck, München, zit.: BeckOK BGB-Bearbeiter
- Bauer, Jobst-Hubertus/Göpfert, Burkard/Krieger, Steffen*, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz Kommentar, 3. Auflage, Verlag C.H. Beck, München 2011
- Baumgartner, Hans Michael*, Am Anfang des menschlichen Lebens steht nicht der Mensch, *Zeitschrift für medizinische Ethik* 39 (1993), S. 257–259
- Bayertz, Kurt*, Auf der Suche nach einer neuen Moral – Ethische Überlegungen zum Amstad-Bericht, Sammlung *Folia Bioethica* (Hrsg.: Schweizerische Gesellschaft für biomedizinische Ethik), Genf 1991

- ders.*, Introduction: Sanctity of Life and Human Dignity, in: *ders.* (Hrsg.), *Sanctity of Life and Human Dignity*, Reihe: *Philosophy and Medicine* (Hrsg.: Engelhardt, H. Tristram/Spicker, Stuart F.), Volume 52, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1996, S. xi–xix
- ders.*, Human Dignity: Philosophical Origin and Scientific Erosion of an Idea, in: *ders.* (Hrsg.), *Sanctity of Life and Human Dignity*, Reihe: *Philosophy and Medicine* (Hrsg.: Engelhardt, H. Tristram/Spicker, Stuart F.), Volume 52, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1996, S. 73–90
- ders.*, The Normative Status of the Human Genome: A European Perspective, in: Hoshino, Kazumasa (Hrsg.), *Japanese and Western Bioethics – Studies in Moral Diversity*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1997, S. 167–180
- Baylis, Françoise/Robert, Jason Scott*, The Inevitability of Genetic Enhancement Technologies, *Bioethics* Vol. 18 (2004), No. 1, S. 1–26
- Beauchamp, Tom L./Childress, James F.*, *Principles of Biomedical Ethics*, 6. Auflage, Oxford University Press, New York 2009
- BeckOK BGB*: siehe Bamberger, Heinz Georg et al.
- BeckOK SBG V*: siehe Rolf, Christian et al.
- BeckOK StGB*: siehe von Heintschel-Heinegg
- Beck, Susanne*, Enhancement – die fehlende rechtliche Debatte einer gesellschaftlichen Entwicklung, *Medizinrecht* 24 (2006), S. 95–102
- Beck, Birgit/Stroop, Barbara*, A Pharmaceutical Shortcut to (fraudulent) Happiness? An analysis of underlying notions of well-being and authenticity in the debate on mood enhancement, bislang unveröffentlichtes Manuskript
- Becker, Peter Emil*, *Zur Geschichte der Rassenhygiene – Wege ins Dritte Reich*, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1988
- Becker, Ulrich/Kingreen, Thorsten*, *SBG V – Gesetzliche Krankenversicherung – Kommentar*, 2. Auflage, Verlag C.H. Beck, München 2010, zit.: Becker/Kingreen-Bearbeiter, *SBG V*
- Benda, Ernst*, Erprobung der Menschenwürde am Beispiel der Humangenetik, in: Flöhl, Rainer (Hrsg.), *Genforschung – Fluch oder Segen? – Interdisziplinäre Stellungnahmen*, Reihe: *Gentechnologie – Chancen und Risiken*, Band 3, J. Schweitzer Verlag, München 1985, S. 205–231
- ders.*, Humangenetik und Recht – eine Zwischenbilanz, *Neue Juristische Wochenschrift* 1985, S. 1730–1734
- ders.*, Verständigungsversuche über die Würde des Menschen, *Neue Juristische Wochenschrift* 2001, S. 2147–2148
- Bilsdorfer, Peter*, Rechtliche Probleme der In-vitro-Fertilisation und des Embryo-Transfers, *Monatsschrift für deutsches Recht* 1984, S. 803–806
- Birnbacher, Dieter*, Gefährdet die moderne Reproduktionsmedizin die menschliche Würde?, in: Braun, Volkmar/Mieth, Dieter/Steigleder, Klaus (Hrsg.), *Ethische und rechtliche Fragen der Gentechnologie und der Reproduktionsmedizin*, Reihe: *Gentechnologie – Chancen und Risiken*, Band 13, J. Schweitzer Verlag, München 1987, S. 77–88
- ders.*, Natürlichkeit, Reihe: *Grundthemen Philosophie* (Hrsg.: Birnbacher, Dieter/Stekeler-Weithofer, Pirmin/Tetens, Holm), Walter de Gruyter, Berlin 2006
- ders.*, Menschenwürde und Lebensrecht als Maßstäbe für PGD? Ein Kommentar aus philosophischer Sicht, in: Gethmann, Carl Friedrich/Huster, Stefan (Hrsg.), *Recht und Ethik in der Präimplantationsdiagnostik*, Wilhelm Fink Verlag, München 2010, S. 13–33
- Bizer, Johann*, Postmortaler Persönlichkeitsschutz? – Rechtsgrund und Länge der Schutzfristen für personenbezogene Daten Verstorbener nach den Archivgesetzen des Bundes und der Länder, *Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht* 1993, S. 653–656
- Black, Edwin*, *War against the Weak – Eugenics and America's Campaign to Create a Master Race*, Four Walls Eight Windows, New York 2003
- Bleckmann, Albert*, Vereinigte Staaten von Amerika, U.S. Supreme Court, *Roe/Wade*, *Europäische Grundrechte Zeitschrift* 1974, S. 52–56
- Bock, Gisela*, Sterilisationspolitik im Nationalsozialismus: Die Planung einer heilen Gesellschaft durch Prävention, in: Dörner, Klaus (Hrsg.), *Fortschritte der Psychiatrie im Umgang mit Men-*

- schen – Wert und Verwertung des Menschen im 20. Jahrhundert, 36. Gütersloher Fortbildungswoche 1984, Psychiatrie-Verlag, Rehburg-Loccum 1984, S. 88–104
- Bock, Kerstin Wolfgard*, Der Rechtsrahmen für Arzneimittel für neuartige Therapien auf unionaler und nationaler Ebene mit Fokus auf Therapien mit autologen adulten Stammzellen, Reihe: Münsterische Beiträge zur Rechtswissenschaft – Neue Folge, Band 18, Nomos, Baden-Baden 2012, zugl.: Diss. Münster 2012
- Böckenförde, Ernst-Wolfgang*, Staat, Gesellschaft, Freiheit – Studien zur Staatstheorie und zum Verfassungsrecht, Reihe: suhrkamp taschenbuch wissenschaft, Band 163, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1976
- ders.*, Menschenwürde als normatives Prinzip – Die Grundrechte in der bioethischen Debatte, Juristenzeitung 2003, S. 809–815
- Böckenförde-Wunderlich, Barbara*, Präimplantationsdiagnostik als Rechtsproblem – Ärztliches Standesrecht, Embryonenschutzgesetz, Verfassung, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2002, zugl. Diss. Heidelberg 2001
- Bonner Kommentar zum Grundgesetz*, s. Dolzer et al.
- Boorse, Christopher*, On the Distinction between Disease and Illness, in: Philosophy and Public Affairs, Vol. 5, No. 1 (Autumn, 1975), S. 49–68
- ders.*, Health as a Theoretical Concept, in: Philosophy of Science, Vol. 44, No. 4 (December, 1977), S. 542–573
- Bostrom, Nick/Sandberg, Anders*, The Wisdom of Nature: An Evolutionary Heuristic for Human Enhancement, in: Savulescu, Julian/Bostrom, Nick (Hrsg.), Human Enhancement, Oxford University Press, New York 2009, S. 375–416; in deutscher Übersetzung: Die Weisheit der Natur: Eine Evolutionäre Heuristik für Enhancement des Menschen, in: Knoepffler, Nikolaus/Savulescu, Julian (Hrsg.), Der neue Mensch? Enhancement und Genetik, Reihe: Angewandte Ethik, Band 11, Verlag Karl Alber, Freiburg 2009, S. 83–126
- Braun, Kathrin*, Die besten Gründe für eine kategorische Auffassung der Menschenwürde, in: Kettner, Matthias (Hrsg.), Biomedizin und Menschenwürde, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2004, S. 81–99
- Brock, Dan W.*, Enhancements of Human Function: Some Distinctions for Policymakers, in: Parens, E. (Hrsg.), Enhancing Human Traits: Ethical and Social Implications, Georgetown University Press, Washington 1998, S. 48–69
- ders.*, Shaping Future Children: Parental Rights and Societal Interests, The Journal of Political Philosophy, Vol. 13 (2005), No. 4, S. 377–398
- Broberg, Gunnar/Roll-Hansen, Nils*, Eugenics and the Welfare State – Norway, Sweden, Denmark, and Finland, Michigan State University Press, East Lansing 2005
- Brocks, Dietrich/Pohlmann, Andreas/Senft, Mario*, Das neue Gentechnikgesetz – Entstehungsgeschichte, Internationale Entwicklung, Naturwissenschaftliche Grundlagen, Gentechnische Arbeiten in gentechnischen Anlagen, Freisetzung von Organismen, Inverkehrbringen von Produkten, Genehmigungsverfahren – Eine praxisgerechte Einführung mit Gesetzestext und Verordnungen, Verlag C.H. Beck, München 1991
- Brohm, Winfried*, Forum: Humanbiotechnik, Eigentum und Menschenwürde, Juristische Schulung 1998, S. 197–205
- Brugger, Winfried*, Abtreibung – ein Grundrecht oder ein Verbrechen? Ein Vergleich der Urteile des United States Supreme Court und des BVerfG, Neue Juristische Wochenschrift 1986, S. 896–901
- Buchanan, Allen/Brock, Dan W./Daniels, Norman/Wikler, Daniel*, From Chance to Choice – Genetics & Justice, Cambridge University Press, Cambridge 2007
- Buchanan, Allen*, Beyond Humanity?, Reihe: Uehiro Series in Practical Ethics (Hrsg.: Savulescu, Julian), Oxford University Press, Oxford 2011
- ders.*, Better than Human? The Promise and Perils of Enhancing Ourselves, Oxford University Press, Oxford 2011
- von Bülow, Detlev*, Dolly und das Embryonenschutzgesetz, Deutsches Ärzteblatt 1997, 94(12), A-718–725



- Bundesärztekammer*, Richtlinien zur Forschung an frühen menschlichen Embryonen, Deutsches Ärzteblatt 1985, 82(50), A 3757–3764
- dies.*, Richtlinien zum Gentransfer in menschliche Körperzellen, Deutsches Ärzteblatt 1995, 92(11), A 789–794
- dies.*, (Muster-)Berufsordnung für die deutschen Ärztinnen und Ärzte, Deutsches Ärzteblatt 1997, 94(37), A 2354–2364
- Bundesminister für Forschung und Technologie*, In-vitro-Fertilisation, Genomanalyse und Gentherapie – Bericht der gemeinsamen Arbeitsgruppe des Bundesministers für Forschung und Technologie und des Bundesministers der Justiz, Reihe: Gentechnologie – Chancen und Risiken, Band 6, J. Schweitzer Verlag, München 1985, zit.: Bundesminister für Forschung und Technologie, Benda-Kommission
- Calliess, Christian*, Grundlagen, Grenzen und Perspektiven europäischen Richterrechts, Neue Juristische Wochenschrift 2005, S. 929–933
- Cancik, Hubert*, „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, in: Funke, Hermann (Hrsg.), Utopie und Tradition – Platons Lehre vom Staat der Moderne, Königshausen & Neumann, Würzburg 1987, S. 73–107
- Chan, C. K.*, Eugenics on the Rise: A Report from Singapore, in: Chadwick, Ruth F. (Hrsg.), Ethics, Reproduction and Genetic Control, Routledge, London 1992, S. 164–171
- Chatterjee, Anjan*, Cosmetic neurology – The controversy over enhancing movement, mentation, and mood, Neurology, Vol. 63 Issue 6 (28. September 2004), S. 968–974
- Cicero, Marcus Tullius*, De officiis – Vom pflichtgemäßen Handeln (Lateinisch und Deutsch), Philipp Reclam Jun., Stuttgart 1976
- Classen, Claus Dieter*, Die Forschung mit embryonalen Stammzellen im Spiegel der Grundrechte, Deutsches Verwaltungsblatt 2002, S. 141–148
- Coenen, Christopher/Schuijff, Mirjam/Smits, Martijntje*, The Politics of Human Enhancement and the European Union, in: Savulescu, Julian/ ter Meulen, Ruud/ Kahane, Guy (Hrsg.), Enhancing Human Capacities, Wiley-Blackwell, Chichester 2011, S. 521–535
- Coester-Waltjen, Dagmar*, Befruchtungs- und Gentechnologie bei Menschen – rechtliche Probleme von morgen?, Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 1984, S. 230–236
- Culver, Charles M./Gert, Bernard*, Philosophy in Medicine – Conceptual and Ethical Issues in Medicine and Psychiatry, Oxford University Press, New York 1982
- Daecke, Sigurd Martin*, Schöpfung an der Börse – Gentechnik innerhalb der „Creatio continua“, Evangelische Kommentare 5/1997, S. 286–287
- Daniels, Norman*, Can Anyone Really Be Talking About Ethically Modifying Human Nature, in: Savulescu, Julian/Bostrom, Nick (Hrsg.), Human Enhancement, Oxford University Press, Oxford 2009, S. 25–42
- Dederer, Hans-Georg*, Menschenwürde des Embryo in vitro?, Archiv des öffentlichen Rechts 127 (2002), S. 1–26
- DeGrazia, David*, Human Identity and Bioethics, Cambridge University Press, Cambridge 2005
- dies.*, Enhancement Technologies and Human Identity, Journal of Medicine and Philosophy, Vol. 30 (2005) Issue 3, S. 261–283
- Desilets, Max/Vining, Daniel*, Quality Considerations in Population Policy, Population and Development Review, Vol. 9, No. 4 (December 1983), S. 753–761
- Deutsch, Erwin*, Die Infektion als Zurechnungsgrund, Neue Juristische Wochenschrift 1986, S. 757–759
- Deutsche Bischofskonferenz*, Instruktion der Kongregation für die Glaubenslehre über die Achtung vor dem beginnenden menschlichen Leben und die Würde der Fortpflanzung, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 74, 10. März 1987 (5. Auflage, 2000)
- Deutsche Forschungsgemeinschaft*, Entwicklung der Gentherapie – Stellungnahme der Senatskommission für Grundsatzfragen der Genforschung, Mitteilung 5, Wiley-VCH, Weinheim 2006, zit.: DFG, Entwicklung der Gentherapie
- Deutscher Bundestag*, 10. Wahlperiode, Unterrichtung (Bericht) Enquete-Kommission „Chancen und Risiken der Gentechnologie“, 6.01.1987, Drucksache 10/6775, zit.: Enquete-Kommission „Chancen und Risiken“

- Deutscher Bundestag, 11. Wahlperiode*, Gesetzesentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zum Schutz von Embryonen (Embryonenschutzgesetz – EschG), 25. Oktober 1989, Drucksache 11/5460
- ders.*, Beschlußempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses (6. Ausschuss) a) zu dem von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zum Schutz von Embryonen (Embryonenschutzgesetz – EschG) – Drucksache 11/5460– b) zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung Kabinettsbericht zur künstlichen Befruchtung beim Menschen – Drucksache 11/1856– c) zu dem Antrag der Abgeordneten Frau Dr. Däubler-Gmelin et al., 8. Oktober 1990, Drucksache 11/8057
- Deutscher Bundestag, 13. Wahlperiode*, Beschlußempfehlung und Bericht des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (13. Ausschuß), 28. Juni 1995, Drucksache 13/1850
- ders.*, Unterrichtung durch die Bundesregierung, Bericht zur Frage eines gesetzgeberischen Handlungsbedarfs beim Embryonenschutzgesetz aufgrund der beim Klonen von Tieren angewandten Techniken und der sich abzeichnenden weiteren Entwicklung, 26. Juni 1998, Drucksache 13/11263
- Deutscher Bundestag, 14. Wahlperiode*, Schlussbericht der Enquete-Kommission „Recht und Ethik in der modernen Medizin“, 14. Mai 2002, Drucksache 14/9020, zit.: Enquete-Kommission „Recht und Ethik“
- Deutscher Bundestag, 16. Wahlperiode*, Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung europäischer Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung, 6. Juni 2006, Drucksache 16/1780
- Deutscher Ethikrat*, Stellungnahme Präimplantationsdiagnostik, <http://www.ethikrat.org/dateien/pdf/stellungnahme-praeimplantationsdiagnostik.pdf> (zuletzt aufgerufen am 27.12.2012), Berlin 2011
- Deutscher Juristentag, 56.*, 56. Deutscher Juristentag: Die Beschlüsse, Neue Juristische Wochenschrift 1986, S. 3069–3075
- von Doemming, Klaus-Berto/Füsslein, Rudolf Werner/Matz, Werner*, Entstehungsgeschichte der Artikel des Grundgesetzes – im Auftrage der Abwicklungsstelle des Parlamentarischen Rates und des Bundesministeriums des Innern auf Grund der Verhandlungen des Parlamentarischen Rates, Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart I (1951)
- Dolzer, Rudolf/Kahl, Wolfgang/Waldhoff, Christian/Graßhof, Karin*, Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Band 1: Einleitung – Art. 3, Stand: 150. Lieferung, Februar 2011, Band 3: Art. 6 II – 14, Stand: 149. Lieferung, Dezember 2010, C.F. Müller, Heidelberg, zit.: Bearbeiter in Bonner Kommentar zum GG
- Dreier, Horst*, Stufungen des vorgeburtlichen Lebensschutzes, Zeitschrift für Rechtspolitik 2002, S. 377–383
- ders.*, Grundgesetz Kommentar, Band I: Artikel 1–19, 2. Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen 2004, zit.: Dreier-Bearbeiter, GG
- ders.*, Bioethik zwischen gesellschaftlicher Pluralität und staatlicher Neutralität, in: Kolleg-Forschergruppe „Normenbegründung in Medizinethik und Biopolitik“ WWU Münster (Hrsg.), Preprints and Working Papers of the Centre for Advanced Study in Bioethics, 2010.1, Münster 2010, online abrufbar unter <http://www.uni-muenster.de/KFG-Normenbegrueundung/publikationen/preprints.html> (zuletzt aufgerufen am 27.12.2012)
- ders.*, Bioethik – Politik und Verfassung, Mohr Siebeck, Tübingen 2013
- drze:* siehe Fuchs et al.
- Dürig, Günter*, Der Grundrechtssatz von der Menschenwürde – Entwurf eines praktikablen Wertsystems der Grundrechte aus Art. 1 Abs. I in Verbindung mit Art. 19 Abs. II des Grundgesetzes, Archiv für öffentliches Recht 81 (1956), S. 117–157
- Eberbach, Wolfram H.*, Die Verbesserung des Menschen – Tatsächliche und rechtliche Aspekte der wunscherfüllenden Medizin, Medizinrecht 26 (2008), S. 325–336
- Enders, Christoph*, Die Menschenwürde in der Verfassungsordnung – Zur Dogmatik des Art. 1 GG, Reihe: Jus Publicum, Band 27, Mohr Siebeck, Tübingen 1997

- Engelhardt, H. Tristram/Wildes, Kevin Wm., Health and Disease – Philosophical Perspectives, in: Reich, Warren Thomas (Hrsg.), Encyclopedia of Bioethics, Band 2 – Dec-Hyp, Simon & Schuster Macmillan, New York 1995
- Enquete-Kommission „Chancen und Risiken“: siehe Deutscher Bundestag, 10. Wahlperiode
- Enquete-Kommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“: siehe Deutscher Bundestag, 14. Wahlperiode
- Epping, Volker/Hillgruber, Christian, Grundgesetz Kommentar, Verlag C.H. Beck, München 2009, zit.: Epping/Hillgruber-Bearbeiter, GG
- Eser, Albin/Frühwald, Wolfgang/Honnefelder, Ludger/Markl, Hubert/Reiter, Johannes/Tanner, Widmar/Winnacker, Ernst-Ludwig, Klonierung beim Menschen. Biologische Grundlagen und ethisch-rechtliche Bewertung, Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik 2 (1997), S. 357–373
- ders., Lebensbeginn, in: Korff, Wilhelm/Beck, Lutwin/Mikat, Paul (Hrsg.), Lexikon der Bioethik, Band 2 – G-Pa, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2000, S. 539–541
- Esser, Josef, Bemerkungen zur Unentbehrlichkeit des juristischen Handwerkszeugs, Juristenzeitung 1975, S. 555–558
- Europarat, Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin: Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin, 4. April 1997, online einsehbar unter: <http://conventions.coe.int/Treaty/ger/Treaties/Html/164.htm> (zuletzt aufgerufen am 27.12.2012), zit.: Europarat, Bioethik-Konvention
- Europarat – Lenkungsausschuss für Bioethik, Entwurf eines Zusatzprotokolls zum Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin über biomedizinische Forschung, 18. Juli 2001, CDBI/INF (2001) 5:1–22, online einsehbar unter: [http://www.jura.uni-augsburg.de/forschung/medizinrecht/medienverzeichnis/pdf\\_datein\\_fuer\\_downloads/forschungsprotokoll.pdf](http://www.jura.uni-augsburg.de/forschung/medizinrecht/medienverzeichnis/pdf_datein_fuer_downloads/forschungsprotokoll.pdf) (zuletzt aufgerufen am 27.12.2012)
- Faßbender, Kurt, Präimplantationsdiagnostik und Grundgesetz – Ein Beitrag zur verfassungsrechtlichen und dogmatischen Strukturierung der aktuellen Diskussion, Neue Juristische Wochenschrift 2001, S. 2745–2753
- Fateh-Moghadam, Bijan, Religiöse Rechtfertigung? Die Beschneidung von Knaben zwischen Strafrecht, Religionsfreiheit und elterlichem Sorgerecht, Rechtswissenschaft 2010, S. 115–142
- ders., Rechtliche Aspekte der somatischen Gentherapie, in: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften/Fehse, Boris/ Domasch, Silke (Hrsg.), Gentherapie in Deutschland – Eine interdisziplinäre Bestandsaufnahme – Themenband der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Gentechnologiebericht, Reihe: Interdisziplinäre Forschungsgruppe – Forschungsberichte, Band 27, Forum W – Wissenschaftlicher Verlag, Dornburg 2011, S. 151–184
- Fechner, Erich, Menschenwürde und generative Forschung und Technik – eine rechtstheoretische und rechtspolitische Untersuchung, Juristenzeitung 1986, S. 653–664
- Fischer, Thomas, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, Reihe Beck'sche Kurzkommentare, Band 10, 57. Auflage, Verlag C.H. Beck, München 2010, zit.: Fischer, StGB
- Flämig, Christian, Die genetische Manipulation des Menschen – Ein Beitrag zu den Grenzen der Forschungsfreiheit, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1985
- Forkel, Hans, Verfügungen über Teile des menschlichen Körpers – Ein Beitrag zur zivilrechtlichen Erfassung der Transplantationen, Juristenzeitung 1974, S. 593–599
- Freeman, Samuel, Deliberative Democracy: A Sympathetic Comment, Philosophy & Public Affairs, Vol. 29, No. 4 (2000), S. 371–418
- Frommel, Monika, Taugt das Embryonenschutzgesetz als ethisches Minimum gegen Versuche der Menschenzüchtung?, Kritische Justiz 33 (2000), S. 341–351
- dies., Die Menschenwürde des Embryos in vitro, Kritische Justiz 35 (2002), S. 411–426
- Fuchs, Michael, Enhancement, in: Korff, Wilhelm/Beck, Lutwin/Mikat, Paul (Hrsg.), Lexikon der Bioethik, Band 1 – A-F, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2000, S. 604–605
- ders./Lanzerath, Dirk/Hillebrand, Ingo/Runkel, Thomas/Balcerak, Magdale-na/Schmitz, Barbara, drze Sachstandsbericht Nr. 1: Enhancement – Die ethische Diskussion über biomedizinische Verbesserungen des Menschen, Deutsches Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften, Bonn 2002, zit.: drze, Sachstandsbericht Nr. 1– Enhancement

- Fukuyama, Francis*, Das Ende des Menschen – Aus dem Amerikanischen von Klaus Kochmann, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 2002
- Galton, Francis*, Hereditary Genius – An Inquiry into its Laws and Consequences, Macmillan & Co., London 1892
- ders.*, Essays in Eugenics, reprinted from the 1909 edition, University Press of the Pacific, Honolulu 2004
- Geddert-Steinacher, Tatjana*, Menschenwürde als Verfassungsbegriff – Aspekte der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz, Reihe: Tübinger Schriften zum Staats- und Verwaltungsrecht, Band 5, Duncker & Humblot, Berlin 1990
- Giddens, Anthony*, BBC Reith Lectures 2009– Week Two, Hong Kong – Risk, online einsehbar unter: [http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/events/reith\\_99/week2/week2.htm](http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/events/reith_99/week2/week2.htm) (zuletzt aufgerufen am 27.12.2012)
- Giwer, Elisabeth*, Rechtsfragen der Präimplantationsdiagnostik – Eine Studie zum rechtlichen Schutz des Embryos im Zusammenhang mit der Präimplantationsdiagnostik unter besonderer Berücksichtigung grundrechtlicher Schutzpflichten, Reihe: Schriften zum öffentlichen Recht, Band 859, Duncker & Humblot, Berlin 2001, zugl. Diss. Köln 2000
- Glover, Jonathan*, Choosing Children – Genes, Disability, and Design, Oxford University Press, Oxford 2006
- Graf Vitzthum, Wolfgang*, Die Menschenwürde als Verfassungsbegriff, Juristenzeitung 1985, S. 201–209
- ders.*, Gentechnologie und Menschenwürde, Medizinrecht 3 (1985), S. 249–257
- ders.*, Gentechnologie und Menschenwürdeargument, in: Klug, Ulrich/Kriele, Martin (Hrsg.), ARSP Beiheft Nr. 33– Menschen- und Bürgerrechte, Vorträge aus der Tagung der deutschen Sektion der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR) in der Bundesrepublik Deutschland vom 9.–12. Oktober 1986 in Köln, Franz Steiner Verlag Wiesbaden, Stuttgart 1988, S. 119–138
- Graumann, Sigrid*, Die somatische Gentherapie – Entwicklung und Anwendung aus ethischer Sicht, Reihe: Ethik in den Wissenschaften (Hrsg.: Mieth, Dietmar), Band 12, A. Francke Verlag, Tübingen 2000
- Greely, Henry T.*, Of Nails and Hammers: Human Biological Enhancement and U.S. Policy Tools, in: Savulescu, Julian/ter Meulen, Ruud/Kahane, Guy (Hrsg.), Enhancing Human Capacities, Wiley-Blackwell, Chichester 2011, S. 503–520
- Green, Ronald M.*, Babies by Design – The Ethics of Genetic Choice, Yale University Press, New Haven 2007
- Grimm, Dieter*, Das Grundgesetz nach vierzig Jahren, Neue Juristische Wochenschrift 1989, S. 1305–1312
- Grotius, Hugo*, Vom Recht des Krieges und des Friedens, in: Schätzel, Walter (Hrsg.), Die Klassiker des Völkerrechts in modernen deutschen Übersetzungen, Band I, Verlag J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1950
- Guckes, Barbara*, Das Argument der schiefen Ebene – Schwangerschaftsabbruch, die Tötung Neugeborener und Sterbehilfe in der medizinethischen Diskussion, Reihe: Jahrbuch des Arbeitskreises Medizinischer Ethik-Kommissionen in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.: Toellner, Richard/von Bergmann, Klaus/Doppelfeld, Elmar/Jäger, Lothar/Just, Hanjörg), Band 9, Gustav Fischer, Stuttgart 1997; zugl.: Diss Göttingen 1995
- Günther, Hans-Ludwig*, Keimbahnintervention, in: Korff, Wilhelm/Beck, Lutwin/Mikat, Paul (Hrsg.), Lexikon der Bioethik, Band 2 – G-Pa, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2000, S. 351–352
- ders./Taupitz, Jochen/Kaiser, Peter*, Embryonenschutzgesetz – Juristischer Kommentar mit medizinisch-naturwissenschaftlichen Einführungen, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2008, zit.: Günther/Taupitz/Kaiser-Bearbeiter, Embryonenschutzgesetz
- Gutmann, Thomas*, Gesetzgeberischer Paternalismus ohne Grenzen? Zum Beschluß des Bundesverfassungsgerichts zur Lebendspende von Organen – Besprechung von BVerfG (1. Kammer des Ersten Senates), Beschl. V. 11.8.1999–1 BvR 2181–83/98, Neue Juristische Wochenschrift 1999, S. 3387–3389

- ders., „Gattungsethik“ als Grenze der Verfügung des Menschen über sich selbst?, in: van den Daele, Wolfgang (Hrsg.), *Biopolitik, Leviathan – Zeitschrift für Sozialwissenschaft*, Sonderheft 23/2005, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2005, S. 235–264
- ders., Rechtliche und rechtsphilosophische Fragen der Präimplantationsdiagnostik, in: Gethmann, Carl Friedrich/Huster, Stefan (Hrsg.), *Recht und Ethik in der Präimplantationsdiagnostik*, Wilhelm Fink Verlag, München 2010, S. 61–102
- ders., Säkularisierung und Normenbegründung, in: Jansen, Nils/Oestmann, Peter, *Gewohnheit. Gebot. Gesetz. – Normativität in Geschichte und Gegenwart: eine Einführung*, Mohr Siebeck, Tübingen 2011, S. 221–248
- ders., Würde und Autonomie. Überlegungen zur Kantischen Tradition, *Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik* 15 (2010), S. 5–34
- ders., Religiöser Pluralismus und liberaler Verfassungsstaat, in: Gabriel, Karl/Spieß, Christian/Winkler, Katja (Hrsg.), *Modelle des religiösen Pluralismus – Historische, religionssoziologische und religionspolitische Perspektiven*, Reihe: Katholizismus zwischen Religionsfreiheit und Gewalt, Band 5, Ferdinand Schöningh, Paderborn 2012, S. 291–315
- ders., Short cuts to happiness – Zu den rechtlichen Grenzen der Selbstbestimmung in der Medizin, in: Ach, Johann S. (Hrsg.), *Grenzen der Selbstbestimmung in der Medizin*, mentis, Münster 2013 (im Erscheinen befindlich), S. 137–151
- Häberle, Peter, Die Abhörentscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 15.12.1970 – Analyse und Kritik des Urteils sowie des Minderheitsvotums vom 4. Januar 1971, *Juristenzeitung* 1971, S. 145–156
- Habermas, Jürgen, Reconciliation through the Public Use of Reason: Remarks on John Rawls's Political Liberalism, *The Journal of Philosophy*, Vol. 92, No. 3 (March 1995), S. 109–131
- ders., Richtigkeit versus Wahrheit – Zum Sinn der Sollgeltung Moralischer Urteile und Normen, in: ders. (Hrsg.), *Wahrheit und Rechtfertigung – Philosophische Aufsätze, erweiterte Ausgabe*, Reihe: suhrkamp taschenbuch wissenschaft, Band 1723, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2004, S. 299–346
- ders., Die Zukunft der menschlichen Natur – Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik? – Erweiterte Ausgabe, Reihe: suhrkamp taschenbuch wissenschaft, Band 1744, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2005
- Hallek, Michael/Winnacker, Ernst-Ludwig/Bröcker, Eva-Bettina, Gentherapie: welche Chancen und Risiken sind mit den molekularbiologischen Behandlungsverfahren der Medizin verbunden? – Eine Betrachtung unter Berücksichtigung ethischer Gesichtspunkte, in: Hallek, Michael/Winnacker, Ernst-Ludwig (Hrsg.), *Ethische und juristische Aspekte der Gentherapie*, Herbert Utz Verlag, München 1999, S. 9–17
- Harris, John, Clones, Genes, and Immortality – Ethics and the Genetic Revolution, Oxford University Press, Oxford 1998
- ders., *Enhancing Evolution – The Ethical Case for Making Better People*, Princeton University Press, Princeton 2007
- Heilinger, Jan-Christoph, *Anthropologie und Ethik des Enhancements*, Reihe: Humanprojekt – Interdisziplinäre Anthropologie – Im Auftrag der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (Hrsg.: Ganten, Detlev/Gerhardt, Volker/Heilinger, Jan-Christoph/Nida-Rümelin, Julian), De Gruyter, Berlin 2010
- von Heintschel-Heinegg, Bernd, Beck'scher Online-Kommentar StGB, Stand: 15. März 2012, Edition: 8, Verlag C.H. Beck, München, zit.: BeckOK StGB-Bearbeiter
- Herdegen, Matthias, Die Menschenwürde im Fluß des bioethischen Diskurses, *Juristenzeitung* 2001, S. 773–779
- Herzog, Roman, Der Verfassungsauftrag zum Schutze des ungeborenen Lebens, *Juristische Rundschau* 1969, S. 441–445
- Heun, Werner, Embryonenforschung und Verfassung – Lebensrecht und Menschenwürde des Embryos, *Juristenzeitung* 2002, S. 517–524
- ders., Menschenwürde und Lebensrecht als Maßstäbe der PID? Dargestellt aus verfassungsrechtlicher Sicht, in: Gethmann, Carl Friedrich/Huster, Stefan (Hrsg.), *Recht und Ethik in der Präimplantationsdiagnostik*, Wilhelm Fink Verlag, München 2010, S. 103–127

- Hilgendorf, Eric*, Scheinargumente in der Abtreibungsdiskussion – am Beispiel des Erlanger Schwangerschaftsfalls, *Neue Juristische Wochenschrift* 1996, S. 758–762
- ders.*, Lebensschutz zwischen Begriffsjurisprudenz und „Ratioismus“, *Neue Juristische Wochenschrift* 1997, S. 3074–3075
- ders.*, Die mißbrauchte Menschenwürde – Probleme des Menschenwürdetopos am Beispiel der bioethischen Diskussion, in: Byrd, Sharon B./Hruschka, Joachim/Joerden, Jan C. (Hrsg.), *Jahrbuch für Recht und Ethik* 7 (1999), Themenschwerpunkt: Der analysierte Mensch, S. 137–158
- Hillgruber, Christian*, *Der Schutz des Menschen vor sich selbst*, Verlag Franz Vahlen, München 1992
- ders.*, Das Vor- und Nachleben von Rechtssubjekten – Über den Anfang und das Ende der Rechtsfähigkeit im öffentlichen Recht, *Juristenzeitung* 1997, S. 975–980
- Hirsch, Günter E.*, Die „Pille danach“, *Medizinrecht* 5 (1987), S. 12–16
- Hitler, Adolf*, *Mein Kampf*, 342.–346. Auflage, Zentralverlag der NSDAP, München 1938
- Hobbes, Thomas*, *Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates* – Teil I und II, aus dem Englischen von Walter Euchner, Kommentar von Lothar R. Waas, Reihe: Studienbibliothek, Band 18, Suhrkamp Verlag, Berlin 2011
- Höffe, Otfried*, *Lexikon der Ethik*, 7. Auflage, Verlag C.H. Beck, München 2008
- Hörnle, Tatjana*, Menschenwürde und Lebensschutz, *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie* 89 (2003), S. 318–338
- Hoerster, Norbert*, Rechtsethik ohne Metaphysik – Theodor Viehweg zur Vollendung des 75. Lebensjahres am 30.4.1982, *Juristenzeitung* 1982, S. 265–272
- ders.*, Zur Bedeutung des Prinzips der Menschenwürde, *Juristische Schulung* 1983, S. 93–96
- ders.*, Forum: Ein Lebensrecht für die menschliche Leibesfrucht?, *Juristische Schulung* 1989, S. 172–178
- ders.*, Abtreibung im säkularen Staat – Argumente gegen den § 218, 2. Auflage, Reihe: suhrkamp taschenbuch wissenschaft, Band 929, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1995
- ders.*, Das angebliche Menschenrecht des Embryos auf Leben, *Juristische Rundschau* 1995, S. 51–53
- Hofmann, Hasso*, Biotechnik, Gentherapie, Genmanipulation – Wissenschaft im rechtsfreien Raum?, *Juristenzeitung* 1986, S. 253–260
- ders.*, Zur Herkunft der Menschenrechtserklärungen, *Juristische Schulung* 1988, S. 841–848
- ders.*, Die versprochene Menschenwürde, *Archiv des öffentlichen Rechts* 118 (1993), S. 353–377
- Holderegger, Adrian*, Was zeichnet den Menschen als Menschen aus? – Antwortversuche zur Würde des Menschen, *Zeitschrift für medizinische Ethik* 40 (1994), S. 275–288
- Homer*, *Odyssee*, Griechisch und deutsch, übersetzt von Weiher, Anton (Hrsg.), Reihe: Sammlung Tusculum, 13. Auflage, Artemis & Winkler, Düsseldorf 2007
- Honnefelder, Ludger*, Humangenetik und Menschenwürde, in: Brose, Thomas/Lutz-Bachmann, Matthias (Hrsg.), *Umstrittene Menschenwürde*, Morus, Hildesheim 1994, S. 157–175
- ders.*, Ethik, in: Korff, Wilhelm/Beck, Lutwin/Mikat, Paul (Hrsg.), *Lexikon der Bioethik*, Band 1 – A-F, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2000, S. 654–662
- Hufen, Friedhelm*, Präimplantationsdiagnostik aus verfassungsrechtlicher Sicht, *Medizinrecht* 19 (2001), S. 440–451
- ders.*, Streit um die Präimplantationsdiagnostik (PID) – Pro, *Zeitschrift für Rechtspolitik* 2002, S. 372
- ders.*, Erosion der Menschenwürde?, *Juristenzeitung* 2004, S. 313–318
- ders.*, Individuelle Rechte und die Zulassung der Präimplantationsdiagnostik, in: Gethmann, Carl Friedrich/Huster, Stefan (Hrsg.), *Recht und Ethik in der Präimplantationsdiagnostik*, Wilhelm Fink Verlag, München 2010, S. 129–153
- von Humboldt, Wilhelm*, Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen, Philipp Reclam jun., Stuttgart 1967
- Huppenbauer, Markus*, Anthropotechnik und Humandesign: Ein philosophisch-theologischer Essay zur gentechnologischen Veränderung des Menschen, in: Kubli, Eric/Reichardt, Anna Katharina (Hrsg.), *Die Perfektion des Menschen*, Peter Lang, Bern 2001, S. 189–210



- Huster, Stefan*, Die ethische Neutralität des Staates – Eine liberale Interpretation der Verfassung, Mohr Siebeck, Tübingen 2002
- Ibelgaufits, Horst/Winnacker, Ernst-Ludwig*, Keimbahnintervention, in: Korff, Wilhelm/Beck, Lutwin/Mikat, Paul (Hrsg.), Lexikon der Bioethik, Band 2 – G-Pa, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2000, S. 349–351
- Illich, Ivan*, Die Enteignung der Gesundheit – Medical Nemesis, Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, 1975
- Isensee, Josef*, Die alten Grundrechte und die biotechnische Revolution, in: Bohnert, Joachim/Gramm, Christoph/Kindhäuser, Urs/Lege, Joachim/Rinken, Alfred/Robbers, Gerhard (Hrsg.), Verfassung – Philosophie – Kirche – Festschrift für Alexander Hollerbach zum 70. Geburtstag, Duncker & Humblot, Berlin 2001, S. 243–266
- ders.*, Menschenwürde: die säkulare Gesellschaft auf der Suche nach dem Absoluten, Archiv des öffentlichen Rechts 131 (2006), S. 173–218
- Isensee, Josef/Kirchhof, Paul*, Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band I – Grundlagen von Staat und Verfassung, 2. Auflage, C.F. Müller Verlag, Heidelberg 1995, zit.: Isensee/Kirchhof-Bearbeiter, HStR I; Band II – Verfassungsstaat, 3. Auflage, C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2004, zit.: Isensee/Kirchhof-Bearbeiter, HStR II; Band V – Allgemeine Grundrechtslehren, 2. Auflage, C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2000, zit.: Isensee/Kirchhof-Bearbeiter, HStR V; Band VI – Freiheitsrechte, 2. Auflage, C.F. Müller Juristischer Verlag, Heidelberg 2001, zit.: Isensee/Kirchhof-Bearbeiter, HStR VI; Band VII – Freiheitsrechte, 3. Auflage, C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2009, zit.: Isensee/Kirchhof-Bearbeiter, HStR VII
- Ipsen, Jörn*, Der „verfassungsrechtliche Status“ des Embryos in vitro – Anmerkung zu einer aktuellen Debatte, Juristenzeitung 2001, S. 989–996
- ders.*, Zur Zukunft der Embryonenforschung, Neue Juristische Wochenschrift 2004, S. 268–270
- Jarass, Hans D.*, Grundrechte als Wertentscheidung bzw. objektivrechtliche Prinzipien in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Archiv des öffentlichen Rechts 110 (1985), S. 363–397
- ders.*, Das allgemeine Persönlichkeitsrecht im Grundgesetz, Neue Juristische Wochenschrift 1989, S. 857–862
- ders./Pieroth, Bodo*, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland – Kommentar, 10. Auflage, Verlag C.H. Beck, München 2009, zit.: Jarass/Pieroth, GG
- Jeand'Heur, Bernd*, Grundrechte im Spannungsverhältnis zwischen subjektiven Freiheitsgarantien und objektiven Grundsatznormen, Juristenzeitung 1995, S. 161–167
- Jerouschek, Günter*, Vom Wert und Unwert der pränatalen Würde – Anmerkungen zu den Kontroversen um das Abtreibungsverbot der §§ 218 ff. StGB, Juristenzeitung 1989, S. 279–285
- Jeschek, Hans-Heinrich/Weigend, Thomas*, Lehrbuch des Strafrechts – Allgemeiner Teil, 5. Auflage, Duncker & Humblot, Berlin 1996
- Juengst, Eric T.*, What does Enhancement mean?, in: Parens, Erik (Hrsg.), Enhancing Human Traits: Ethical and Social Implications, Georgetown University Press, Washington 1998, S. 29–47
- Kant, Immanuel*, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: Kants Werke – Akademie-Textausgabe – Unveränderter photomechanischer Abdruck des Textes der von der Preußischen Akademie der Wissenschaften 1902 begonnenen Ausgabe von Kants gesammelten Schriften, Band IV – Kritik der reinen Vernunft (1. Aufl. 1781), Prolegomena, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaften, Walter de Gruyter & Co., Berlin 1968
- ders.*, Kritik der praktischen Vernunft, in: Kants Werke – Akademie-Textausgabe – Unveränderter photomechanischer Abdruck des Textes der von der Preußischen Akademie der Wissenschaften 1902 begonnenen Ausgabe von Kants gesammelten Schriften, Band V – Kritik der praktischen Vernunft, Kritik der Urtheilskraft, Walter de Gruyter & Co., Berlin 1968
- ders.*, Die Metaphysik der Sitten, in: Kants Werke – Akademie-Textausgabe – Unveränderter photomechanischer Abdruck des Textes der von der Preußischen Akademie der Wissenschaften 1902 begonnenen Ausgabe von Kants gesammelten Schriften, Band VI – Die Religion inner-



- halb der Grenzen der bloßen Vernunft, Die Metaphysik der Sitten, Walter de Gruyter & Co., Berlin 1968
- ders.*, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, Kultursoziologische Reihe – Geschichtsphilosophische Dokumente (Hrsg.: Rossmann, Kurt), Adolf Rausch Verlag, Heidelberg 1946
- Kass, Frances M.*, Is There a Problem With Enhancement?, *The American Journal of Bioethics*, Vol. 5 Issue 3 (May, June 2005), S. 5–14
- Kasseler Kommentar*: siehe Leitherer
- Kaufmann, Arthur*, Der entfesselte Prometheus – Fragen der Humangenetik und der Fortpflanzungstechnologien aus rechtlicher Sicht, in: Flöhl, Rainer (Hrsg.), *Genforschung – Fluch oder Segen? – Interdisziplinäre Stellungnahmen*, Reihe: Gentechnologie – Chancen und Risiken, Band 3, J. Schweitzer Verlag, München 1985, S. 259–277
- Kern, Bernd-Rüdiger/Richter, Isabell*, Haftung für den Erfolgseintritt? Die garantierte ärztliche Leistung, in: Wienke, Albrecht/Eberbach, Wolfram H./Kramer, Hans-Jürgen/Janke, Kathrin (Hrsg.), *Die Verbesserung des Menschen – Tatsächliche und rechtliche Aspekte der wunscherfüllenden Medizin*, Schriftenreihe Medizinrecht (Hrsg.: Spickhoff, Andreas), Springer, Heidelberg 2009, S. 129–144
- Kevles, Daniel J.*, In the Name of Eugenics – Genetics and the Uses of Human Heredity, Alfred A. Knopf, New York 1985
- Kindhäuser, Urs/Neumann, Ulfried/Paeffgen, Hans-Ullrich*, Strafbgesetzbuch – Band 2: §§ 80–230, 4. Auflage, Nomos, Baden-Baden 2013, zit.: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen-Bearbeiter, StGB
- Kirchhof, Paul*, Genforschung und die Freiheit der Wissenschaft, in: Höffe, Otfried/Honnefelder, Ludger/Isensee, Josef/Kirchhof, Paul (Hrsg.), *Gentechnik und Menschenwürde*, DuMont Literatur und Kunst Verlag, Köln 2002, S. 9–35
- Klein, Eckart*, Grundrechtliche Schutzpflicht des Staates, *Neue Juristische Wochenschrift* 1989, S. 1633–1640
- Kloepfer, Michael*, Leben und Würde des Menschen, in: Badura, Peter/Dreier, Horst (Hrsg.), *Festschrift 50 Jahre Bundeseverfassungsgericht*, Zweiter Band, Mohr Siebeck, Tübingen 2001, S. 77–104
- ders.*, Humangenetik als Verfassungsfrage, *Juristenzeitung* 2002, 417–428
- Knoepffler, Nikolaus*, Menschenwürde in der Bioethik, Springer-Verlag, Berlin 2004
- Koch, Klaus*, Imago Dei – Die Würde des Menschen im biblischen Text, Berichte aus den Sitzungen der Joachim Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften e. V., Hamburg, vorgelegt in der Sitzung vom 7. Juli 2000, Verlag Wandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2000
- ders.*, Perspektiven biblischen Menschenverständnisses im Zeitalter der Technologie, in: Herms, Eilert (Hrsg.), *Menschenbild und Menschenwürde*, Reihe: Veröffentlichungen der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie, Band 17, Chr. Kaiser Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2011, S. 48–70
- Köbl, Ursula*, Gentechnologie zu eugenischen Zwecken – Niedergang oder Steigerung der Menschenwürde?, in: Forkel, Hans/Kraft, Alfons (Hrsg.), *Beiträge zum Schutz der Persönlichkeit und ihrer schöpferischen Leistungen – Festschrift für Heinrich Hubmann zum 70. Geburtstag*, Alfred Metzner Verlag, Frankfurt am Main 1985, S. 161–192
- Körtner, Ulrich J.H.*, Mysterium Mensch – Die christliche Ethik duldet keine „Anthropotechnik“, *Evangelische Kommentare* 3/2000, S. 7–10
- Kovács, Jozsef*, Concepts of Health and Disease, in: *The Journal of Medicine and Philosophy*, Vol. 14 Issue 3 (June 1989), S. 261–267
- ders.*, The concept of health and disease, in: *Medicine, Health Care and Philosophy*, Vol. 1 (1998), No. 1, S. 31–39
- Kriele, Martin*, Urteilsanmerkung zu BVerfG, Urteil v. 25.5.1975–1 BvF 1–6/74, *Juristenzeitung* 1975, S. 222–225
- Krüger, Thomas*, „Wie der Wind verfliegt meine Würde...“ (Hiob 30,15) – Elend und Würde des Menschen in alttestamentlicher Sicht, in: Herms, Eilert (Hrsg.), *Menschenbild und Menschenwürde*, Reihe: Veröffentlichungen der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie, Band 17, Chr. Kaiser Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2011, S. 271–287

- Kuhlmann, Andreas*, Abtreibung und Selbstbestimmung – Die Intervention der Medizin, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1996
- ders.*, Politik des Lebens – Politik des Sterbens. Biomedizin in der liberalen Demokratie, Alexander Fest Verlag, Berlin 2001
- Lackner, Karl/Kühl, Kristian*, Strafgesetzbuch Kommentar, 26. Auflage, Verlag C.H. Beck, München 2007, zit.: Lackner/Kühl, StGB
- LANZERATH, Dirk/HONNEFELDER, LUDGER*, Krankheitsbegriff und ärztliche Anwendung der Humangenetik, in: Düwell, Marcus/Mieth, Dietmar (Hrsg.), Ethik in der Humangenetik – Die neueren Entwicklungen der genetischen Frühdiagnostik aus ethischer Perspektive, Reihe: Ethik in den Wissenschaften (Hrsg.: Mieth, Dietmar), Band 10, A. Francke Verlag, Tübingen 1998
- Larmore, Charles*, Strukturen moralischer Komplexität, aus dem Amerikanischen von Klaus Laermann, Verlag J.B. Metzler, Stuttgart 1994
- ders.*, Politischer Liberalismus, in: Honneth, Axel (Hrsg.), Kommunitarismus – Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften, Reihe: Theorie und Gesellschaft (Hrsg.: Honneth, Axel/Joas, Hans/Offe, Claus), Band 26, Campus Verlag, 2. Auflage, Frankfurt am Main 2004, S. 131–156
- Laufs, Adolf*, Die künstliche Befruchtung beim Menschen – Zulässigkeit und zivilrechtliche Folgen, Juristenzeitung 1986, S. 769–777
- ders.*, Fortpflanzungsmedizin und Menschenwürde, Neue Juristische Wochenschrift 2000, S. 2716–2718
- ders./Uhlenbruck, Wilhelm*, Handbuch des Arztrechts, 4. Auflage, C.H. Beck, München 2010, zit.: Laufs/Uhlenbruck-Verfasser
- Leithner, Stephan*, Kasseler Kommentar Sozialversicherungsrecht, Band 1, Stand: 72. Ergänzungslieferung (1. Dezember 2011), Verlag C.H. Beck, München 2011, zit.: Kasseler Kommentar-Bearbeiter, Sozialversicherungsrecht I
- Lenk, Christian*, Therapie und Enhancement – Ziele und Grenzen der modernen Medizin, Reihe: Münsteraner Bioethik-Studien (Hrsg.: Siep, Ludwig), Band 2, LIT Verlag, Münster 2002, zugl.: Diss. Münster 2001
- Lerche, Peter*, Verfassungsrechtliche Aspekte der Gentechnologie, in: Lukes, Rudolf/Scholz, Rupert (Hrsg.), Rechtsfragen der Gentechnologie – Vorträge anlässlich eines Kolloquiums Recht und Technik – Rechtsfragen der Gentechnologie in der Tagungsstätte der Max-Planck-Gesellschaft „Schloß Ringberg“ am 18./19./20. November 1985, Reihe: Recht – Technik – Wissenschaft (Hrsg.: Lukes, Rudolf), Band 43, Carl Heymanns Verlag, Köln 1986, S. 88–111
- Lexikon der Biologie*: siehe Sauermost et al.
- Little, Margaret Olivia*, Cosmetic Surgery, Suspect Norms, and the Ethics of Complicity, in: Parens, Erik (Hrsg.), Enhancing Human Traits – Ethical and Social Implications, Reihe: Hastings Center Studies in Ethics (Hrsg.: Hanson, Mark J./Callahan, Daniel), Georgetown University Press, Washington, D.C. 1998, S. 162–176
- Locke, John*, The Second Treatise of Government – Über die Regierung – Englisch/Deutsch, übersetzt von Dorothee Todow (Hrsg.: Mayer-Tasch, Peter Cornelius), Philipp Reclam jun., Stuttgart 2012
- Lorenz, Dieter*, Die verfassungsrechtliche Garantie der Menschenwürde und ihre Bedeutung für den Schutz menschlichen Lebens vor der Geburt, Zeitschrift für Lebensrecht 2001, S. 38–49
- ders.*, Embryonenforschung als Humanexperiment – Zur Bestimmungsbefugnis über vorgeburtliches menschliches Leben, in: Eberle, Carl-Eugen/Ibler, Martin/Lorenz, Dieter (Hrsg.), Der Wandel des Staates vor den Herausforderungen der Gegenwart – Festschrift für Winfried Brohm zum 70. Geburtstag, Verlag C.H. Beck, München 2002, S. 441–454
- Losch, Bernhard*, Lebensschutz am Lebensbeginn: Verfassungsrechtliche Probleme des Embryonenschutzes, Neue Juristische Wochenschrift 1992, S. 2926–2932
- ders.*, Das BVerfG hat gesprochen: Embryonen sind Menschen zweiter Klasse, Kritische Vierteljahrsschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 76 (1993), S. 313–317
- von Mangoldt, Hermann/Klein, Friedrich/Starck, Christian*, Kommentar zum Grundgesetz, Band 1: Präambel, Artikel 1 bis 19, 6. Auflage, Verlag Franz Vahlen, München 2010, zit.: von Mangoldt/Klein/Starck-Bearbeiter, GG

- Maunz, Theodor/Dürig, Günther*, Grundgesetz Kommentar, Band I – Texte, Art. 1–5, Stand: 60. Lieferung, Oktober 2010, Band II – Art. 6–15, Stand: 60. Lieferung, Oktober 2010, Verlag C.H. Beck, München, zit.: Maunz/Dürig-Bearbeiter, GG
- Maurer, Hartmut*, Die medizinische Organtransplantation in verfassungsrechtlicher Sicht, Die öffentliche Verwaltung 33 (1980), S. 7–15
- Mauron, Alex*, Genom-Metaphysik, in: Rehmann-Sutter, Christoph/Müller, Hansjakob (Hrsg.), Ethik und Gentherapie – Zum praktischen Diskurs um die molekulare Medizin, 2. Auflage, A. Francke Verlag, Tübingen 2003, S. 237–249
- Merkel, Reinhardt*, Ärztliche Entscheidungen über Leben und Tod in der Neonatalmedizin – Ethische und strafrechtliche Probleme, Juristenzeitung 1996, S. 1145–1155
- ders.*, Forschungsobjekt Embryo – Verfassungsrechtliche und ethische Grundlagen der Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2002
- Merki, H.*, Ebenbildlichkeit, in: Klausner, Theodor (Hrsg.), Reallexikon für Antike und Christentum – Sachwörterbuch zur Auseinandersetzung des Christentums mit der antiken Welt, Band 4 – Dogma II bis Empore, Anton Hiersemann, Stuttgart 1959
- Mill, John Stuart*, Über die Freiheit, übersetzt von Bruno Lemke (Hrsg.: Schlenke, Manfred), Philipp Reclam jun., Stuttgart 1974
- Müller, Hansjakob*, Gentherapie – Unter besonderer Berücksichtigung der Behandlung bei Erbkrankheiten, in: Rehmann-Sutter, Christoph/Müller, Hansjakob (Hrsg.), Ethik und Gentherapie – Zum praktischen Diskurs um die molekulare Medizin, 2. Auflage, A. Francke Verlag, Tübingen 2003, S. 41–58
- von Münch, Ingo/Kunig, Philip*, Grundgesetz-Kommentar, Band 1: Präambel, Art. 1–19, 5. Auflage, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München 2000, zit.: von Münch/Kunig-Bearbeiter, GG
- Münchener Kommentar*: siehe Säcker et al.
- Müri, Walter*, Der Arzt im Altertum – Griechische und lateinische Quellenstücke von Hippokrates bis Galen mit der Übertragung ins Deutsche, 6. Auflage, Artemis & Winkler, Düsseldorf 2001
- Murswiek, Dietrich*, Die staatliche Verantwortung für die Risiken der Technik – Verfassungsrechtliche Grundlagen und immissionsschutzrechtliche Ausformung, Duncker & Humblot, Berlin 1985, zit.: Murswiek, Staatliche Verantwortung
- ders.*, Entschädigung für immissionsbedingte Waldschäden, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 1986, S. 611–615
- Nagel, Thomas*, Eine Abhandlung über Gleichheit und Gerechtigkeit und andere Schriften zur politischen Philosophie, übersetzt und mit Nachbemerkungen sowie einem Schriftenverzeichnis herausgegeben von Michael Gebauer, Ferdinand Schöningh, Paderborn 1994, zit.: Nagel, Gleichheit und Gerechtigkeit
- Nationaler Ethikrat*, Genetische Diagnostik vor und während der Schwangerschaft (23. Januar 2003), Nationaler Ethikrat, Berlin 2003, in der Fassung, wie sie unter [http://www.ethikrat.org/stellungnahmen/pdf/Stellungnahme\\_Genetische-Diagnostik.pdf](http://www.ethikrat.org/stellungnahmen/pdf/Stellungnahme_Genetische-Diagnostik.pdf) (zuletzt aufgerufen am 27.12.2012) zu finden ist, zit.: Nationaler Ethikrat, Genetische Diagnostik
- von Nell-Breuning, Oswald*, Gerechtigkeit und Freiheit – Grundzüge katholischer Soziallehre, Europa Verlag, Wien 1980
- Nettesheim, Martin*, Die Garantie der Menschenwürde zwischen metaphysischer Überhöhung und bloßem Abwägungstopos, Archiv des öffentlichen Rechts 130 (2005), S. 71–113
- Neumann, Ulfrid*, Die „Würde des Menschen“ in der Diskussion um Gentechnologie und Befruchtungstechnologien, in: Klug, Ulrich/ Kriele, Martin (Hrsg.), ARSP Beiheft Nr. 33– Menschen- und Bürgerrechte, Vorträge aus der Tagung der deutschen Sektion der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR) in der Bundesrepublik Deutschland vom 9.–12. Oktober 1986 in Köln, Franz Steiner Verlag Wiesbaden, Stuttgart 1988, S. 139–152
- ders.*, Die Menschenwürde als Menschenbürde – oder wie man ein Recht gegen den Berechtigten wendet, in: Kettner, Matthias (Hrsg.), Biomedizin und Menschenwürde, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2004, S. 42–62
- ders.*, Die Tyrannei der Würde – Argumentationstheoretische Erwägungen zum Menschenwürdeprinzip, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 84 (1998), S. 153–166

- Nunner-Winkler, Gertrud, Können Klone eine Identität ausbilden?, in: van den Daele, Wolfgang (Hrsg.), Biopolitik, Leviathan – Zeitschrift für Sozialwissenschaft, Sonderheft 23/2005, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2005, S. 265–294
- Nordenfelt, Lennart, On the Nature of Health – An Action-Theoretic Approach, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht 1987
- Nussbaum, Martha C., Die Grenzen der Gerechtigkeit – Behinderung, Nationalität und Spezieszugehörigkeit, übersetzt von Celikates, Robin/Engels, Eva, Suhrkamp Verlag, Berlin 2010
- dies., Rawls's Political Liberalism. A Reassessment, Ratio Juris, Vol. 14, No. 1 (March 2011), S. 1–24
- Ossenbühl, Fritz, Die Interpretation der Grundrechte in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Neue Juristische Wochenschrift 1976, S. 2100–2107
- Oxford Dictionary of English: siehe Soanes et al.
- Palandt, Dr. Otto, Bürgerliches Gesetzbuch, Reihe: Beck'sche Kurzkommentare, Band 7, 71. Auflage, Verlag C.H. Beck, München 2012, zit.: Palandt-Bearbeiter, BGB
- Pannenberg, Wolfhart, Christliche Wurzeln des Gedankens der Menschenwürde, in: Kerber, Walter (Hrsg.), Menschenrechte und kulturelle Identität – Ein Symposium, Reihe: Fragen einer neuen Weltkultur – Veröffentlichungen des Forschungs- und Studienprojekts der Rottendorf-Stiftung an der Hochschule für Philosophie Philosophische Fakultät S.J., München, Band 8, Kindt Verlag, München 1991, S. 61–76
- Parens, Erik, Authenticity and Ambivalence – Toward understanding the Enhancement Debate, Hastings Center Report, Vol. 35 Issue 3 (May/June 2005), S. 34–41
- Parfit, Derek, Reasons and Persons, Oxford University Press, Oxford 1987
- Parlamentarischer Rat, 1948–1949– Akten und Protokolle, Band 5/1, Ausschuss für Grundsatzfragen, Harald Boldt Verlag, Boppard am Rhein 1993
- Pascal, Blaise, Pensées, Texte de l'Édition Brunschvicg, Introduction et Notes par Ch.-Marc des Granges, Classiques Garnier, Garnier Frères, Paris 1964
- Pawlenka, Claudia, Der Künstliche Mensch, „Gen Doping“ und die Naturalisierung der Leistung im Sport, in: Kaminsky, Carmen/Hallich, Oliver (Hrsg.), Verantwortung für die Zukunft – Zum 60. Geburtstag von Dieter Birnbacher, Reihe: Ethik in der Praxis – Studien (Hrsg.: Sass, Hans-Martin), Band 22, Lit Verlag, Berlin 2006
- Pico della Mirandola, De hominis dignitate – Über die Würde des Menschen – Lateinisch/Deutsch, auf der Textgrundlage der Editio princeps, übersetzt von Gerd von der Gönna (Hrsg.), Philipp Reclam jun., Stuttgart 1997
- Pieroth, Bodo/Schlink, Bernhard, Grundrechte – Staatsrecht II, 27. Auflage, C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2011
- Plato, Protagoras, herausgegeben von Denyer, Nicholas, Reihe: Cambridge Greek and Latin Classics, Cambridge University Press, Cambridge 2008
- Platon, Der Staat – Politeia – Griechisch-deutsch, übersetzt von Rufener, Rüdiger (Hrsg.: Szlezák, Thomas A.), Reihe: Sammlung Tusculum, Artemis & Winkler, Düsseldorf 2000
- Pogge, Thomas W., John Rawls, Verlag C.H. Beck, München 1994
- Pschyrembel – Klinisches Wörterbuch, 261. Auflage, Walter de Gruyter, Berlin 2007
- Punt, Jozef, Die Idee der Menschenrechte – Ihre geschichtliche Entwicklung und ihre Rezeption durch die moderne katholische Sozialverkündigung, Reihe: Abhandlungen zur Sozialethik (Hrsg.: Rauscher, Anton/Roos, Lothar), Band 26, Ferdinand Schöningh, Paderborn 1987, zugl.: Diss. Augsburg 1985
- Quante, Michael, Personales Leben und menschlicher Tod – Personale Identität als Prinzip der biomedizinischen Ethik, Reihe: suhrkamp taschenbuch wissenschaft, Band 1573, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2002
- ders., Person, Reihe: Grundthemen der Philosophie (Hrsg.: Birnbacher, Dieter/Stekeler-Weithofer, Pirmins/Tenes, Holm), Walter de Gruyter, Berlin 2007
- Ramm, Thilo, Die Fortpflanzung – Ein Freiheitsrecht?, Juristenzeitung 1989, S. 861–874
- Rawls, John, Eine Theorie der Gerechtigkeit, Reihe: suhrkamp taschenbuch wissenschaft, Band 271, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1976
- ders., Reply to Habermas, The Journal of Philosophy, Vol. 92, No. 3 (March 1995), S. 132–180

- ders., *Politischer Liberalismus*, Reihe: suhrkamp taschenbuch wissenschaft, Band 1642, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2003
- Regenass-Klotz, Mechthild, *Grundzüge der Gentechnik – Theorie und Praxis*, 2. Auflage, Birkhäuser Verlag, Basel 2000
- Rehmann, Wolfgang A., *AMG – Arzneimittelgesetz – Kommentar*, 3. Auflage, Verlag C.H. Beck, München 2008
- Rehmann-Sutter, Christoph, *Keimbahnveränderungen in Nebenfolge? – Ethische Überlegungen zur Abgrenzbarkeit der somatischen Gentherapie*, in: Rehmann-Sutter, Christoph/Müller, Hansjakob (Hrsg.), *Ethik und Gentherapie – Zum praktischen Diskurs um die molekulare Medizin*, 2. Auflage, A. Francke Verlag, Tübingen 2003, S. 187–205
- Reinhardt, Heinrich, *Freiheit zu Gott – Der Grundgedanke des Systematikers Giovanni della Mi-randola (1463–1494)*, Acta humaniora, Weinheim 1989
- Reiss, Michael J./Straughan, Roger, *Improving Nature? The science and ethics of genetic engineering*, Cambridge University Press, Cambridge 1996
- Rengier, Rudolf, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, Verlag C.H. Beck, München 2009
- Resnik, David B., *The Moral Significance of the Therapy-Enhancement Distinction in Human Genetics*, Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 9 (2000), S. 365–377
- Riedel, Eibe H., *Gentechnologie und Embryonenschutz als Verfassungs- und Regelungsproblem*, Europäische Grundrechte Zeitschrift 1986, S. 469–478
- Roberts, Melinda, *The Nonidentity Problem*, in: Zalta, Edward N. (Hrsg.), *The Stanford Encyclopedia in Philosophie* (Fall 2009 Edition), online einsehbar unter: <http://plato.stanford.edu/archives/fall2009/entries/nonidentity-problem/> (zuletzt aufgerufen am 2.07.2013)
- Rochlitz, Christoph, *Gentherapeutische Ansätze bei Krebserkrankungen*, in: Rehmann-Sutter, Christoph/Müller, Hansjakob (Hrsg.), *Ethik und Gentherapie – Zum praktischen Diskurs um die molekulare Medizin*, 2. Auflage, A. Francke Verlag, Tübingen 2003, S. 59–69
- Rolf, Christian/Giesen, Richard/Kreikebohm, Ralf/Udsching, Peter, *Beck'scher Online-Kommentar Sozialrecht*, Stand: 1. März 2012, Edition: 25, Verlag C.H. Beck, München, zit.: BeckOK SGB V-Bearbeiter
- Rosenau, Henning, *Reproduktives und therapeutisches Klonen*, in: Amelung, Knuth/Beulke, Werner/Lilie, Hans/Rosenau, Henning/Rüping, Hinrich/Wolfslast, Gabriele (Hrsg.): *Strafrecht – Biorecht – Rechtsphilosophie – Festschrift für Hans-Ludwig Schreiber zum 70. Geburtstag am 10. Mai 2003*, C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2003, S. 761–781
- Rothschuh, Karl E., *Der Krankheitsbegriff (Was ist Krankheit?)*, in: ders. (Hrsg.), *Was ist Krankheit? – Erscheinung, Erklärung, Sinngebung*, Reihe: Wege der Forschung, Band CCCLXII, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, Darmstadt 1975, S. 397–420
- Roxin, Claus, *Strafrecht Allgemeiner Teil, Band I – Grundlagen, der Aufbau der Verbrechenslehre*, 4. Auflage, Verlag C.H. Beck, München 2006
- Rupp, Hans Heinrich, *Vom Wandel der Grundrechte*, Archiv für öffentliches Recht 101 (1976), S. 161–201
- Rust, Ursula/Falke, Josef, *AGG – Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz mit weiterführenden Vorschriften – Kommentar*, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2007, zit.: Rust/Falke-Bearbeiter, AGG
- Sachs, Michael, *Grundgesetz Kommentar*, 6. Auflage, Verlag C.H. Beck, München 2011, zit.: Sachs-Bearbeiter, GG
- Säcker, Franz Jürgen/Rixecker, Roland, *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 1 – Allgemeiner Teil, §§ 1–240, ProstG, AGG*, 6. Auflage, Verlag C.H. Beck, München 2012
- Sandel, Michael J., *The Case against Perfection – Ethics in the Age of Genetic Engineering*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 2009
- ders., *The Case against Perfection – What's wrong with designer children, bionic athletes, and genetic engineering?*, The Atlantic Monthly, Vol. 293, No. 3 (April 2004), online einsehbar unter: <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2004/04/the-case-against-perfection/2927/> (zuletzt aufgerufen 27.12.2012)



- Sauermost, Rolf/Freudig, Doris/Bonk, Michael/Genaust, Helmut/Gack, Claudia*, Lexikon der Biologie, Band 8– Kapkastanie bis Lynx, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2002; Band 13– Sinalbin bis Tractus, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2004
- Schmidt-Bleibtreu, Bruno/Hofmann, Hans/Hopfauf, Axel*, Kommentar zum Grundgesetz, 12. Auflage, Carl Heymanns Verlag, Köln 2011, zit.: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf-Bearbeiter, GG
- Schmidt-Jortzig, Eduard*, Systematische Bedingungen der Garantie unbedingten Schutzes der Menschenwürde in Art. 1 GG – unter besonderer Berücksichtigung der Probleme am Anfang des menschlichen Lebens, Die öffentliche Verwaltung 54 (2001), S. 925–932
- Schöne-Seifert, Bettina*, Contra Potentialitätsargument: Probleme einer traditionellen Begründung für embryonalen Lebensschutz, in: Damschen, Gregor/Schönecker, Dieter (Hrsg.), Der moralische Status menschlicher Embryonen – Pro und contra Spezies-, Kontinuums-, Identitäts- und Potentialitätsargument, Walter de Gruyter Berlin 2003, S. 169–185
- Schönke, Adolf/Schröder, Horst*, Strafrechtbuch Kommentar, 27. Auflage, Verlag C.H. Beck, München 2006, zit.: Schönke/Schröder-Bearbeiter, StGB
- Scholz, Rupert*, Nießbrauch contra Raucher – OVG Berlin, NJW 1975, 2261 und VG Schleswig, JR 1975, 130, Juristische Schulung 1976, S. 232–237
- Schroth, Ulrich*, Forschung an embryonalen Stammzellen und Präimplantationsdiagnostik im Lichte des Rechts, Juristenzeitung 2002, S. 170–179
- Schwabe, Jürgen*, Probleme der Grundrechtsdogmatik, Darmstadt 1977
- ders.*, Der Schutz des Menschen vor sich selbst, Juristenzeitung 1998, S. 66–75
- Seelmann, Kurt*, Menschenwürde als Würde der Gattung – ein Problem des Paternalismus?, in: Fateh-Moghadam, Bijan/Sellmaier, Stephan/Vossenkuhl, Wilhelm (Hrsg.), Grenzen des Paternalismus, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2010, S. 206–219
- Seewald, Otfried*, Zum Verfassungsrecht auf Gesundheit, Carl Heymanns Verlag, Köln 1981
- Siepe, Ludwig*, Wissen – Vorbeugen – Verändern – Über die ethischen Probleme beim gegenwärtigen Stand des Genomprojekts, in: Honnefelder, Ludger/Mieth, Dietmar/Propping, Peter/Siepe, Ludwig/Wiesemann, Claudia, Das genetische Wissen und die Zukunft des Menschen, Walter de Gruyter, Berlin 2003, S. 78–86
- ders.*, Moral und Gattungsethik, Deutsche Zeitschrift für Philosophie 50 (2002) 1, S. 111–120
- Singer, Maxine/Berg, Paul*, Gene und Genome, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 1992
- Singer, Peter*, Praktische Ethik, Philipp Reclam jun., Stuttgart 1984
- Singer, Reinhard*, Vertragsfreiheit, Grundrechte und der Schutz des Menschen vor sich selbst, Juristenzeitung 1995, S. 1133–1141
- Sinshemer, Robert L.*, The Prospect of Designed Genetic Change, in: Chadwick, Ruth F. (Hrsg.), Ethics, Reproduction and Genetic Control, Routledge, London 1992, S. 136–146
- Soanes, Catherine/Stevenson, Angus*, The Oxford Dictionary of English, 3. Auflage, Oxford University Press, Oxford 2011
- Spaemann, Robert*, Symposium zu: Jürgen Habermas: Die Zukunft der menschlichen Natur – Habermas über Bioethik, Deutsche Zeitschrift für Philosophie 50 (2002) 1, S. 105–109
- Spiekerkötter, Jörg*, Verfassungsfragen der Humangenetik – Insbesondere Überlegungen zur Zulässigkeit der Genmanipulation sowie der Forschung an menschlichen Embryonen, Reihe: Gentechnologie – Chancen und Risiken, Band 19, J. Schweitzer Verlag, Frankfurt am Main 1989
- Spinner, Johannes*, Die Situation der Menschenwürde in der westlichen Kultur, Wissenschaftlicher Verlag Berlin, Berlin 2005
- Starck, Christian*, Verfassungsrechtliche Grenzen der Biowissenschaft und Fortpflanzungsmedizin, Juristenzeitung 2002, S. 1065–1072
- ders.*, Praxis der Verfassungsauslegung, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1994
- von Staudinger, J.*, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch 1 – Allgemeiner Teil – §§ 90–124; 130–133 (Allgemeiner Teil 3), Sellier & de Gruyter, Berlin 2012, zit.: Staudinger-Bearbeiter, BGB
- Stein, Tine*, Recht und Politik im biotechnischen Zeitalter, Deutsche Zeitschrift für Philosophie 50 (2002) 6, S. 855–870

- Stein, Ekkehart/Frank, Götz*, Staatsrecht, 21. Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen 2010
- Steinborn, Volker*, Gentechnikgesetz, Reihe: Erläuterte Textausgabe, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2009, zit.: Steinborn, GenTG
- Steiner, Udo*, Verfassungsfragen des Sports, Neue Juristische Wochenschrift 1991, S. 2729–2736
- ders.*, Das Bundesverfassungsgericht und die Volksgesundheit, Medizinrecht 21 (2003), S. 1–7
- Stern, Klaus*, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band III/1: Allgemeine Lehren der Grundrechte – Grundlagen und Geschichte, nationaler und internationaler Grundrechtskonstitutionalismus, juristische Bedeutung der Grundrechte, Grundrechtsberechtigte, Grundrechtsverpflichtete, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München 1988, zit.: Stern, Staatsrecht III/1; Band IV/1: Die einzelnen Grundrechte – Der Schutz und die freiheitliche Entfaltung des Individuums, Verlag C.H. Beck, München 2006, zit.: Stern, Staatsrecht IV/1
- Sternberg-Lieben, Detlev*, Gentherapie und Strafrecht, Juristische Schulung 1986, S. 673–680
- Stock, Gregory*, Redesigning Humans – Choosing our Children's Genes, Profile Books, London 2003
- Stöcker, Hans A.*, Menschliche Würde und kritische Jurisprudenz – Zur utilitaristischen Auslegung des Art. 1 I GG, Juristenzeitung 1968, S. 685–691
- Strachan, Tom/Read, Andrew P.*, Molekulare Humangenetik, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 1996
- Stürner, Rolf*, Die Unverfügbarkeit ungeborenen menschlichen Lebens und die menschliche Selbstbestimmung, Juristenzeitung 1990, S. 709–724
- Taupitz, Jochen*, Privatrechtliche Rechtspositionen um die Genomanalyse: Eigentum, Persönlichkeit, Leistung, Juristenzeitung 1992, S. 1089–1099
- The President's Council on Bioethics*, Beyond Therapy – Biotechnology and the Pursuit of Happiness – A Report of The President's Council on Bioethics, Washington, D.C., Oktober 2003, online einsehbar unter: [bioethics.georgetown.edu/pcbe/reports/beyondtherapy](http://bioethics.georgetown.edu/pcbe/reports/beyondtherapy)
- Thomas, Veit*, Würde als absoluter und relationaler Begriff, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 87 (2001), S. 299–310
- Umbach, Dieter C./Clemens, Thomas*, Grundgesetz – Mitarbeiterkommentar und Handbuch, Band I, C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2011, zit.: Umbach/Clemens-Bearbeiter, GG
- Unruh, Peter*, Zur Dogmatik der grundrechtlichen Schutzpflichten, Duncker & Humboldt, Berlin 1996
- Vogel, Friedrich*, Humangenetik und Konzepte der Krankheit, in: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Jahrgang 1990, 6. Abhandlung, vorgetragen in der Sitzung vom 5. Mai 1990, Springer-Verlag, Berlin 1990, S. 331–353
- Voss, Daniela*, Rechtsfragen der Keimbahntherapie, Reihe: Schriften zum Planungs-, Verkehrs- und Technikrecht (Hrsg.: Ronellenfitsch, Michael/Grupp, Klaus), Band 3, Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2001, zugl.: Diss. Tübingen 2000
- Wagner, Dietrich*, Der gentechnische Eingriff in die menschliche Keimbahn – Rechtlich-ethische Bewertung – Nationale und internationale Regelungen im Vergleich, Reihe: Recht & Medizin, (Hrsg.: Deutsch, Erwin/Laufs, Adolf/Schreiber, Hans-Ludwig), Band 86, Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2007, zugl.: Diss. Göttingen 2005
- Wagner, Hellmut/Morsey, Benedikt*, Rechtsfragen der somatischen Gentherapie, Neue Juristische Wochenschrift 1996, S. 1565–1570
- Walters, LeRoy/Palmer, Julie Gage*, The Ethics of Human Gene Therapy, Oxford University Press, New York 1997
- Warnock, Mary*, Ethical challenges in embryo manipulation, British Medical Journal, Vol. 304 (19. April 1992), S. 1045–1049
- Wassermann, Rudolf*, Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Band I – Art. 1–20, Reihe: Alternativkommentare, Luchterhand, Neuwied 1984, zit.: Alternativkommentar GG-Bearbeiter
- Weingart, Peter/Kroll, Jürgen/Bayertz, Kurt*, Rasse, Blut und Gene – Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland, Reihe: suhrkamp taschenbuch wissenschaft, Band 1022, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1992



- Weiß, Axel, Das Lebensrecht des Embryos – ein Menschenrecht, *Juristische Rundschau* 1992, S. 182–184
- Welling, Lioba Ilona Luisa, Limited Sources of Normative Justification in the Secular Constitutional State? On the Role of Religiously Motivated Arguments in Bioethical Debates, in: *Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik* 16 (2011), S. 41–63
- Weltärztebund (*The World Medical Association, WMA*), Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, online einsehbar unter: <http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html> (zuletzt aufgerufen am 27.12.2012)
- Weltärztebund (*The World Medical Association, WMA*), *Ethikabteilung (Ethics Unit)*, Handbuch der ärztlichen Ethik, online einsehbar unter: [http://www.wma.net/en/30publications/30ethics-manual/pdf/ethics\\_manual\\_german.pdf](http://www.wma.net/en/30publications/30ethics-manual/pdf/ethics_manual_german.pdf) (zuletzt aufgerufen am 27.12.2012), 2005
- Werner, Micha H., Menschenwürde in der bioethischen Debatte – Eine Diskurstopologie, in: Kettner, Matthias (Hrsg.), *Biomedizin und Menschenwürde*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2004, S. 191–220
- Wessels, Johannes/Beulke, Werner, *Strafrecht Allgemeiner Teil – Die Straftat und ihr Aufbau*, 39. Auflage, C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2009
- Wetz, Franz Josef, Die Würde des Menschen – Ein Phantom?, *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie* 87 (2001), S. 311–327
- Wildfeuer, Armin G., Person, in: Korff, Wilhelm/Beck, Lutwin/Mikat, Paul (Hrsg.), *Lexikon der Bioethik*, Band 3– Pe-Z, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2000, S. 5–9
- Wittreck, Fabian, Menschenwürde und Folterverbot, *Die öffentliche Verwaltung* 56 (2003), S. 873–882
- World Health Organization, Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19–22 June 1946, signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and rendered into force on 7 April 1948
- Zimmerli, Walther Ch., Gesundheit als offenes System, in: Bartsch, Hans Helge/Bengel, Jürgen (Hrsg.), *Salutogenese in der Onkologie – Tumorthherapie und Rehabilitation*, Karger, Freiburg 1997
- Zimmerman, Burke K., Human Germ-Line Therapy: The Case for Its Development and Use, *The Journal of Medicine and Philosophy*, Vol. 16 Issue 6 (December 1991), S. 593–612
- Zoglauer, Thomas, *Konstruiertes Leben – Ethische Probleme der Humangenetik*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2002
- Zunke, Christine, *Das Subjekt der Würde – Kritik der deutschen Stammzelldebatte*, PapyRossa Verlag, Köln 2004